

발 간 등 록 번 호

11-1170000-100074-09

2025

법령해석 사례집

상

MINISTRY OF GOVERNMENT LEGISLATION



법제처

[상권]

제1장 기획재정·금융·공정거래

제1절 기획재정·금융	3
1. 「복권 및 복권기금법」 제23조제1항 등 관련(24-0965)	3
2. 「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정」 제7조제1호 등 관련(25-0037)	7
3. 「소득세법」 제12조제3호마목 등 관련(25-0087)	11
4. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조제1항제2호 단서 관련(25-0152)	14
5. 「신용협동조합법」 제31조제1항 등 관련(25-0257)	18

제2장 산업통상자원·중소기업

제1절 산업통상자원	23
1. 「유통산업발전법」 제12조 등 관련(24-1003)	23
2. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호다목 등 관련(25-0175)	27
3. 「전기사업법」 제7조제5항제2호 등 관련(25-0204)	30
4. 「전기안전관리법 시행규칙」 제26조제1호 등 관련(25-0241)	35
제2절 중소기업	39
1. 「경영지도사 및 기술지도사에 관한 법률」 제2조제2항 등 관련(24-0935)	39
2. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제12조제3항 등 관련(25-0050)	43

제3장 교육·여성가족·문화체육관광

제1절 교육	49
--------	----

1. 「학교체육 진흥법」 제6조제1항제3호 등 관련(24-0921)	49
2. 「고등교육법 시행령」 제29조제2항 등 관련(25-0101)	53
제2절 여성가족·청소년	58
1. 「청소년복지 지원법」 제5조제3항 등 관련(25-0067)	58
2. 「양성평등기본법」 제21조제2항 등 관련(25-0216, 25-0263)	61
3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2제4항 등 관련(25-0293)	65
제3절 문화체육관광	68
1. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령」 제4조의2제4호 등 관련(24-0767)	68
2. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제10조 등 관련(24-0912)	72
3. 「관광진흥개발기금법 시행령」 제1조의2제1항 등 관련(24-0967)	79
4. 「성균관·향교·서원전통문화의 계승·발전 및 지원에 관한 법률」 제3조제3항 등 관련(24-1009)	82
5. 문화관광부령 제26호 「관광진흥법 시행규칙」 부칙 제2항 및 문화관광부령 제179호 「관광진흥법 시행규칙」 부칙 제2조 등 관련(25-0078)	85
6. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제2조제4호 등 관련(25-0194, 25-0336, 25-0337)	91

제4장 국방·국가보훈

제1절 국방	101
1. 「병역법」 제29조 등 관련(25-0102)	101
2. 「병역법」 제30조 등 관련(25-0313)	107

제5장 행정자치·인사·안전

제1절 행정일반·지방자치	113
1. 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제59조제13호 등 관련 (24-0824, 24-0877, 24-0937)	113
2. 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제1호 및 제4호 등 관련 (24-0880, 25-0164, 25-0165, 25-0166)	119

3. 「공유재산 및 물품 관리법」 제94조의2 및 같은 법 시행령 제91조 등 관련(24-0955)	125
4. 「지방자치법 시행령」 제44조제1항제5호 등 관련(24-0961)	130
5. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제2조제4호 등 관련(24-0962, 25-0001)	134
6. 「공공감사에 관한 법률」 제2조제1호 등 관련(24-1010, 25-0223)	141
7. 「10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법」 제28조 등 관련 (25-0009)	145
8. 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」 제2조 등 관련(25-0022)	151
9. 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률 시행령」 제2조제1호 등 관련(25-0027) ·	155
10. 「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련(25-0032)	160
11. 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」 제2조 등 관련(25-0043)	164
12. 「지방재정법」 제27조의6제1항 등 관련(25-0172)	168
13. 「조달사업에 관한 법률」 제13조 등 관련(25-0182)	173
14. 「소세·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법 시행규칙」 제4조제1항제2호 관련(25-0184)	178
15. 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 등 관련(25-0238)	182
16. 「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련(25-0242)	187
17. 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제38조제1항제28호 등 관련(25-0243)	190
18. 「지방교육자치에 관한 법률」 제21조 등 관련(25-0262)	194
19. 「대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법」 제3조제1항 등 관련(25-0270)	196
20. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제11조제3항 등 관련(25-0331)	199
21. 「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련(25-0351)	202
22. 법률 제10441호 행정사법 전부개정법률 부칙 제3조 관련(25-0360)	205
23. 「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련(25-0399)	210
제2절 공무원	214
1. 「공무원임용령」 제2조제7호 등 관련(24-0930)	214
2. 「교육공무원법」 제47조제1항 등 관련(24-0944)	218
3. 「지방공무원 임용령」 제33조의2 등 관련(25-0198)	221
4. 「지방공무원 임용령」 제25조제1항 등 관련(25-0261)	225
5. 「공무원임용령」 제57조의4 등 관련(25-0318)	229

제3절 경찰·소방·국민안전 232

1. 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 등 관련(24-0864) 232
2. 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제19조 등 관련(25-0011) 237
3. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 7 제2호나목 등 관련(25-0033) 240
4. 「위험물안전관리법」 제6조제1항 및 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 1의2 등 관련(25-0235) 244
5. 「유선 및 도선 사업법」 제24조의2제1항 등 관련(25-0268) 248
6. 「청원경찰법 시행령」 제11조제1항 등 관련(25-0273) 251
7. 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」 제2조제2호가목 등 관련(25-0280) 254

제6장 농림축산·산림·해양수산

제1절 농림축산 259

1. 「농업협동조합법」 제51조제7항 등 관련(24-0856) 259
2. 「농지법 시행령」 제29조제2항제1호 등 관련(24-0911) 263
3. 「축산법」 제2조제8호 등(25-0015) 268
4. 「축산법」 제24조 등(25-0016) 271
5. 「농지법」 제34조제2항 및 「농지법 시행령」 제34조 등 관련(25-0088) 274
6. 「농업산·학협동심의회 규정」 제6조의2 제2항 등 관련(25-0186, 25-0256) 280
7. 「농지법」 제42조 제1항제1호 등 관련(25-0266) 283
8. 「농업산·학협동심의회 규정」 제5조제2항 등 관련(25-0283, 25-0296) 286

제2절 산림 289

1. 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」 제20조제1항 제2호의3 등 관련(24-0913) 289
2. 「산지관리법」 제15조의2제1항 등 관련(25-0055) 293
3. 「산림보호법」 제21조의9제4항 관련(25-0161) 297
4. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조 등 관련(25-0358) 300

제3절 해양수산 305

1. 「낚시 관리 및 육성법」 제2조제1호 등 관련(24-0995) 305
2. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제25조 등 관련(25-0282) 308

제7장 보건복지·식품의약품

제1절 보건복지	315
1. 「사회보장 기본법」 제19조 및 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제35조 등 관련(24-0855)	315
2. 「실종아동등의 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조제1호나목 등 관련(25-0075)	320
3. 「장사 등에 관한 법률 시행령」 별표 4 제3호마목 등 관련(25-0192)	324
4. 「노인복지법」 제32조제1항제3호 등 관련(25-0341)	328
제2절 식품의약품	335
1. 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제3조 등 관련(24-0793)	335
2. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제51조제1항 등 관련(25-0039)	340
3. 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙」 별표 7 등 관련(25-0074)	344
4. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제51조 및 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 6 제3호가목 등 관련(25-0378)	348

제8장 환경·고용노동

제1절 환경	355
1. 「물환경보전법 시행규칙」 별표 19의2 제1호나목 등 관련(24-0811)	355
2. 「대기환경보전법 시행령」 제17조제5항 등 관련(24-0951)	360
3. 법률 제11879호 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제4조 등 관련(24-0987) ...	367
4. 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조제3항제2호 등 관련(25-0018) ...	374
5. 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3 등 관련(25-0079)	379
제2절 고용노동	384
1. 「산업재해보상보험법」 제51조제1항 등 관련(25-0058)	384
2. 「구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률」 제7조제3항제5호 등 관련(25-0068, 25-0145) ...	388
3. 「고용보험법」 제40조제2항 등 관련(25-0109)	395
4. 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제2조제6호 등 관련(25-0134)	398

5. 「고용보험법 시행령」 제95조의3제1항 등 관련(25-0155)	402
--	-----

제9장 국토교통

제1절 국토개발·건축·건설 407

1. 「건축법」 제11조 및 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제4조 등 관련(24-0716) ..	407
2. 「개발이익 환수에 관한 법률」 제9조 등 관련(24-0791)	413
3. 「도시 및 주거환경정비법 시행령」 제37조제3항제3호 등 관련(24-0893)	417
4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조제5항 등 관련(24-0895)	422
5. 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조제1항 관련(24-0904)	426
6. 「건축사법」 제23조제7항 등 관련(24-0906)	429
7. 「도시 및 주거환경정비법」 제35조제5항 등 관련(24-0931, 24-0996, 24-0997, 24-0998)	432
8. 「도시개발법」 제66조제1항 등(24-0942)	438
9. 「건축법 시행령」 제37조 등 관련(24-0981)	442
10. 「건축법」 제70조제3호 등 관련(24-0989)	445
11. 「건축법」 제22조제1항 등 관련(24-0991)	448
12. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제1항제1호 등 관련(25-0005, 25-0144)	452
13. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제91조제6항 등 관련(25-0012)	459
14. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제71조제1항제3호 및 별표 4 등 관련(25-0061) ..	462
15. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제4항 등 관련(25-0066, 25-0125)	468
16. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의3제2항 등 관련(25-0091)	472
17. 「건축법」 제52조제4항 등 관련(25-0119)	475
18. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제24조제2항 등 관련(25-0120)	479
19. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제1항제3호 등 관련(25-0126)	483
20. 법률 제20044호 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 일부개정법을 부칙 제3조 등 관련(25-0132)	487
21. 「건축법 시행령」 제110조의3제1항 등 관련(25-0141, 25-0295)	494
22. 「건축법」 제80조의2 등 관련(25-0146, 25-0240)	501
23. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제85조제7항 등 관련(25-0158)	509
24. 「도시개발법 시행령」 제35조 등 관련(25-0174)	513

25. 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호 등 관련(25-0224)	517
26. 「건축법」 제19조 등 관련(25-0227, 25-0279)	521
27. 「건축법 시행령」 제119조 등 관련(25-0252)	526
28. 「건축법 시행령」 제56조제1항 등 관련(25-0276)	529
29. 「도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법」 제50조제1항 등 관련(25-0314, 25-0366)	533
30. 「주택법」 제5조제3항 등 관련(25-0315, 25-0362)	539
31. 「건축법 시행령」 제19조 등 관련(25-0317)	546
제2절 주택관리·부동산	552
1. 「주택법 시행령」 제16조제1항제2호 등 관련(24-0861)	552
2. 「주택법」 제11조제1항 등 관련(24-0949)	556
3. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제44조제3항 등 관련(24-0990)	561
4. 「주택법」 제14조의2제2항 등 관련(25-0008)	564
5. 「도시 및 주거환경정비법」 제76조제1항제7호 등 관련(25-0035)	568
6. 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제17조 등 관련(25-0064, 25-0168, 25-0169)	573
7. 「주택법 시행규칙」 제7조제6항 등 관련(25-0129)	580
8. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제49조 등 관련(25-0179)	585
9. 「공동주택관리법 시행령」 제26조제1항 등 관련(25-0195)	590
10. 「공동주택관리법」 제35조제1항 등 관련(25-0200)	593
11. 「공인중개사법」 제10조제1항제11호 등 관련(25-0211)	597
제3절 도로·교통	600
1. 「철도사업법」 제10조 등 관련(24-0898)	600
2. 「자동차관리법」 제2조 등 관련(24-0923)	603
3. 「화물자동차 운수사업법」 제40조의3 등 관련(24-0973)	608
4. 「도로법」 제112조제2항 등 관련(24-0983)	611
5. 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제63조제1항 및 별표 6 제1호나목 등 관련(24-1001)	614
6. 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제5조 등 관련(25-0108)	617
7. 「도로법」 제27조제1항 등 관련(25-0112, 25-0335)	622
8. 「화물자동차 운수사업법」 제2조제3호 등 관련(25-0247)	628
9. 「도로법」 제2조제2호가목 등 관련(25-0278)	631

제10장 기타

1. 「전자정부법」 제2조제4호 등 관련(24-0843) 637
2. 「협동조합 기본법」 제30조제2항 등 관련(25-0023) 641
3. 「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련(25-0081) 644
4. 「전기통신사업법」 제80조 등 관련(25-0085) 647
5. 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제29조 등 관련(25-0185) 651
6. 「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련(25-0189) 654

2025 법령해석 사례집 상

CHAPTER

1

기획재정·금융·공정거래

제1절 기획재정·금융

제1절 기획재정·금융

질의제목 1 ▶ 안전번호 24-0965

「복권 및 복권기금법」 제23조제1항 단서에 따른 복권수익금의 기금 등에 대한 배분비율 가감 조정의 한계(「복권 및 복권기금법」 제23조제1항 등 관련)

01 질의요지

「복권 및 복권기금법」(이하 “복권법”이라 함) 제23조제1항 본문에서는 매년 복권수익금 가운데 100분의 35는 같은 항 각 호의 기금 등에 배분하되 그 배분비율은 대통령령으로 정한다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 복권위원회는 같은 항 각 호의 기금 등의 자금소요 및 같은 법 제22조제3항에 따른 평가 결과 등을 고려하여 각 기금 등의 배분비율에 대하여 100분의 20의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 가감 조정할 수 있다고 규정하고 있는바,

복권법 제23조제1항 단서에 따라 같은 항 각 호의 기금 등(이하 “기금등”이라 함)에 대한 복권수익금 배분비율을 가감 조정하는 경우, 그 가감 조정 결과에 따라 복권수익금 중 기금등에 배분되는 총량(이하 “배분총량”이라 함)은 같은 법 제23조제1항 본문에 따른 복권수익금의 100분의 35를 반드시 유지해야 하는지, 아니면 복권수익금의 100분의 35보다 적거나 많을 수 있는지?

02 회답

복권법 제23조제1항 단서에 따라 기금등에 대한 복권수익금 배분비율을 가감 조정하는 경우, 그 가감 조정 결과에 따른 기금등의 배분총량은 같은 법 제23조제1항 본문에 따른 복권수익금의 100분의 35를 반드시 유지해야 합니다.

03 이유

먼저 복권법 제23조제1항 본문에서는 ① 매년 복권수익금 가운데 100분의 35는 기금등에 배분하도록 하여 기금등에 대한 ‘배분총량’을 정하는 내용과 ② 그 배분비율은 대통령령으로 정하도록 하여 기금등에 대한 ‘배분비율’을 정하는 내용 등 두 가지의 내용을 규정하고 있고, 같은 항 단서에는 ‘배분비율’에 대하여 가감 조정할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 기금등에 대한 복권수익금의 ‘배분총량’에 대하여 가감 조정하는 내용은 규정하고 있지 않은바, 복권법 제23조제1항은 기금등에 배분하는 복권수익금의 배분총량과 배분비율을 규정하되, 배분비율을 가감 조정할 수 있도록 한 것으로서, 기금등에 대한 복권수익금 배분비율을 가감 조정하는 경우, 복권법 제23조제1항 본문에 따른 배분총량인 복권수익금의 100분의 35를 유지하면서 같은 항 단서에 따라 기금등의 배분비율을 가감 조정할 수 있다고 해석하는 것이 해당 규정의 문언 및 규정 체계에 부합하는 해석입니다.

그리고 복권법 제23조제1항 단서의 배분비율 가감조정제는 2011년 3월 30일 법률 제10487호로 일부개정된 복권법에서 처음 도입되었는데, 이는 복권수익금의 100분의 35를 기금등에 일정한 비율로 의무적으로 배분하는 법정배분제도가 재원활용의 경직·비효율화 문제를 초래함에 따라, 기금등의 자금소요, 성과평가 결과 등을 고려하여 각 기금등의 ‘배분비율’에 대해 100분의 20 범위에서 가감 조정할 수 있도록 하기 위한 것으로서¹⁾, 복권법 시행령 제17조제1항 각 호에서 규정하고 있는 각 기금등별 배분비율을 가감 조정하여 보다 탄력적으로 재원을 운용할 수 있도록 하려는 취지이지, 가감 조정을 통해 배분총량이 조정되어 복권수익금의 100분의 35보다 많거나 적게 기금등에 배분할 수 있도록 하려는 취지는 아니라고 할 것인바, 이러한 복권법의 입법연혁 및 취지에 비추어 보더라도 가감 조정 결과에 따른 기금등에 대한 복권수익금의 배분총량은 복권법 제23조제1항 본문에 따른 배분총량인 복권수익금의 100분의 35보다 많거나 적을 수는 없다고 할 것입니다.

아울러 복권법은 복권수익금의 합리적 배분과 투명한 사용을 통하여 국민의 복지 증진에 이바지함을 목적(제1조)으로 하는 법률로, 같은 법 제23조제3항에 따르면 같은 조 제1항에 따라 배분된 복권수익금과 같은 조 제4항에 따른 비용 및 경비를 제외한 복권기금은 임대주택의 건설 등 저소득층의 주거안정 지원사업, 장애인·불우청소년 등 소외계층에 대한 복지사업 등 공익사업에 사용되는데, 만약 기금등에 대한 복권수익금 배분비율의 가감 조정

1) 2011. 3. 30. 법률 제10487호로 일부개정된 복권법 주요내용 및 2010. 10. 29. 의안번호 제1809704호로 발의된 복권 및 복권기금법 일부개정법률안(대안반영 폐기)에 대한 국회 기획재정위원회 검토보고서 참조

따라 배분총량도 조정되어 복권수익금의 100분의 35보다 많게 기금등에 배분할 수 있다고 해석하는 경우, 복권법 제23조제3항에 따라 공익사업에 배분되는 복권기금이 줄어들게 되고, 공익사업에 대한 배분총량의 예측가능성을 확보하기 어려워 공익사업의 안정적 운영을 저해하는 결과를 초래할 우려가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 복권법 제23조제1항 단서에 따라 기금등에 대한 복권수익금 배분비율을 가감 조정하는 경우, 그 가감 조정 결과에 따른 기금등의 배분총량은 같은 법 제23조제1항 본문에 따른 복권수익금의 100분의 35를 반드시 유지해야 합니다.

법령정비 권고사항

복권법 제23조제1항에 따라 복권수익금 가운데 기금등에 배분되는 총량을 조정할 필요가 있는지를 정책적으로 검토하고, 그 배분총량을 조정할 필요가 있다면 이를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

복권 및 복권기금법

제23조(복권기금의 배분 및 용도) ① 매년 복권수익금 가운데 100분의 35는 다음 각 호의 기금 등에 배분하되 그 배분 비율은 대통령령으로 정한다. 다만, 복권위원회는 다음 각 호의 기금 등의 자금소요 및 제22조제3항에 따른 평가 결과 등을 고려하여 각 기금 등의 배분비율에 대하여 100분의 20의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 가감 조정할 수 있다.

1. 「과학기술기본법」 제22조에 따른 과학기술진흥기금
2. 「국민체육진흥법」 제19조에 따른 국민체육진흥기금
3. 「근로복지기본법」 제87조에 따른 근로복지진흥기금
4. 삭제 <2016. 3. 29.>
5. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제63조에 따른 중소기업창업 및 진흥기금
6. 「국가유산보호기금법」 제3조에 따른 국가유산보호기금
7. 지방자치단체
8. 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제160조에 따른 제주특별자치도개발사업특별회계
9. 「사회복지공동모금회법」에 따른 사회복지공동모금회
10. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제58조제1항에 따른 산림환경기능증진자금

11. 「한국보훈복지의료공단법」에 따른 한국보훈복지의료공단

② (생략)

③ 제1항에 따라 배분된 복권수익금과 제4항에 따른 비용 및 경비를 제외한 복권기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업에 사용한다. 다만, 제5호의 사업에 사용되는 복권기금의 비율은 100분의 5 범위로 한다.

1. 임대주택의 건설 등 저소득층의 주거안정 지원사업
2. 국가유공자에 대한 복지사업
3. 저소득층, 장애인, 성폭력·가정폭력·성매매 피해여성, 불우청소년 등 소외계층에 대한 복지사업과 다문화가족 지원사업
4. 문화·예술 진흥사업
5. 공익사업으로서 대통령령으로 정하는 사업 ~ ⑥ (생략)

④ 복권으로 인한 사행심을 억제하고 중독을 예방·치유하기 위한 교육 및 홍보에 필요한 비용과 복권기금의 조성·운용 및 관리에 드는 경비는 기금에서 지급한다.

⑤·⑥ (생략)

복권 및 복권기금법 시행령

제17조(복권수익금의 배분 및 용도) ① 법 제23조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 복권수익금 배분비율은 다음 각 호와 같다.

1. 「과학기술기본법」 제22조에 따른 과학기술진흥기금: 100분의 12.583
2. 「국민체육진흥법」 제19조에 따른 국민체육진흥기금: 100분의 10.371
3. 「근로복지기본법」 제87조에 따른 근로복지진흥기금: 100분의 5.310
4. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제63조에 따른 중소벤처기업창업 및 진흥기금: 100분의 6.356
5. 「국가유산보호기금법」 제3조에 따른 국가유산보호기금: 100분의 14.286
6. 지방자치단체: 100분의 17.267
7. 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제160조에 따른 제주특별자치도개발사업특별회계: 100분의 17.267
8. 「사회복지공동모금회법」에 따른 사회복지공동모금회: 100분의 4.286
9. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제58조제1항에 따른 산림환경기능증진자금: 100분의 5.846
10. 「한국보훈복지의료공단법」에 따른 한국보훈복지의료공단: 100분의 6.428

② 복권위원회는 법 제23조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 제1항 각 호에 따른 배분비율을 가감 조정할 때에는 다음 각 호의 사항을 반영하여야 한다.

1. 제1항에 따른 기금 등(이하 이 조에서 “기금등”이라 한다)의 자체수입, 여유자금, 부채 등 자금여건에 관한 사항
2. 법 제22조제3항에 따른 성과평가 결과
3. 법 제24조제2항에 따른 복권수익금 사용계획서의 심의·조정 결과

③ ~ ⑦ (생략)

질의제목 2

▶ 안전번호 25-0037

민원인 - 농업·임업용 방조망에 해당하지 않으나 유사한 기능을 수행하는 농·임업용 기자재에 대한 부가가치세 환급 가부(「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정」 제7조제1호 등 관련)

01 질의요지

「조세특례제한법」 제105조의2제1항 각 호 외의 부분에서는 같은 항 각 호에 해당하는 세무서장(이하 “관할 세무서장”이라 함)은 대통령령으로 정하는 농민, 임업에 종사하는 자와 어민(이하 “농어민등”이라 함)이 농업·임업 또는 어업에 사용하기 위하여 구입하는 기자재¹⁾ 또는 직접 수입하는 기자재로서 대통령령으로 정하는 것에 대해서는 기자재를 구입 또는 수입한 때에 부담한 부가가치세액을 해당 농어민등에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 환급할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정」(이하 “영농기자재등면세규정”이라 함) 제7조제1호에서는 「조세특례제한법」 제105조의2제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 것” 중 하나로 영농기자재등면세규정 별표 5의 농·임업용 기자재를 규정하고 있으며, 같은 표 제12호에서는 농·임업용 기자재 중 하나로 농업·임업용 방조망(防鳥網)²⁾ 및 방풍망³⁾을 규정하고 있는바,

관할 세무서장은 농어민등이 영농기자재등면세규정 제7조제1호 및 별표 5 제12호에 따른 농업·임업용 방조망에 해당하지 않으나 유사한 기능을 수행하는 농·임업용 기자재(이하 “이 사안 기자재”라 함)⁴⁾를 구입 또는 수입한 때에 부담한 부가가치세액을 「조세특례제한법」 제105조의2제1항에 따라 해당 농어민등에게 환급할 수 있는지?

1) 「부가가치세법」 제2조제5호에 따른 일반과세자로부터 구입하는 기자재만 해당하며, 이하 같음

2) 농작물의 조류피해를 막기 위하여 치는 그물을 말함(농업용어사전 참조)

3) 과수·수실류·작물 재배용 및 축산업용에 한정하며, 이하 같음

4) 이 사안 기자재가 영농기자재등면세규정 제7조제1호 및 별표 5에서 규정하고 있는 부가가치세 환급이 적용되는 농·임업용 기자재에 해당하지 않음을 전제로 함

02 회답

관할 세무서장은 농어민등이 이 사안 기자재를 구입 또는 수입한 때에 부담한 부가가치세액을 해당 농어민등에게 환급할 수 없습니다.

03 이유

조세법률주의의 원칙상 과세요건이거나 비과세요건 또는 조세감면요건을 막론하고 조세법규의 해석은 특별한 사정이 없는 한 법문대로 해석할 것이고, 합리적 이유 없이 확장해석하거나 유추해석하는 것은 허용되지 아니하며⁵⁾, 특히 감면요건 가운데 명백히 특혜규정이라고 볼 수 있는 것은 엄격하게 해석하는 것이 조세공평의 원칙에도 부합한다고 할 것이고⁶⁾, 이러한 법리는 국세 환급요건에 관한 규정의 해석에도 그대로 적용된다 할 것인데⁷⁾, 「조세특례제한법」 제105조의2에서는 농어민등이 농업·임업 또는 어업에 사용하기 위하여 구입하는 기자재 등에 대한 부가가치세의 환급에 관한 특례를 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 영농기자재등면세규정 제7조제1호 및 별표 5에서는 「조세특례제한법」 제105조의2제1항에 따라 부가가치세 환급이 적용되는 농·임업용 기자재를 규정하고 있는바, 이러한 부가가치세 환급에 관한 특례 규정들은 법문대로 엄격하게 해석하여야 할 것이고, 농어민등에게 유리하다고 하여 합리적 이유 없이 확장해석하거나 유추해석하는 것은 허용되지 아니한다고 할 것입니다.

그런데 「조세특례제한법」 제105조의2의 위임에 따라 마련된 영농기자재등면세규정 제7조제1호 및 별표 5에서는 부가가치세 환급 대상이 되는 농·임업용 기자재를 규정하면서, 농업·임업용 방조망 및 방풍망(제12호), 농업·임업용 양수기(제13호), 범씨발아기(제14호) 등을 규정하고 있으나, ‘농업·임업용 방조망과 유사한 것’은 별도로 규정하고 있지 않은바, 이 사안 기자재가 농업·임업용 방조망과 유사한 기능을 수행하더라도 같은 표 제12호에 따른 농업·임업용 방조망에 해당하지 않는 이상, 관할 세무서장은 원칙적으로 「조세특례제한법」 제105조의2제1항, 영농기자재등면세규정 제7조제1호 및 별표 5에 따라 농어민등이 이 사안 기자재를 구입 또는 수입한 때에 부담한 부가가치세액을 해당 농어민등에게 환급할 수는

5) 대법원 2000. 12. 26. 선고 98두1192 판결례 참조

6) 대법원 2009. 8. 20. 선고 2008두11372 판결례 등 참조

7) 대고등법원 2020. 2. 21. 선고 2018누3739 판결례 참조

없다고 할 것입니다.

한편 「조세특례제한법」 제105조의2 및 영농기자재등면세규정 제7조는 농업·임업·어업용 기자재에 대한 부가가치세를 해당 농어민등에게 직접 환급해 줌으로써 농어민등을 지원하기 위한 것이므로⁸⁾ 농어민등이 방조망과 유사한 기능을 수행하는 이 사안 기자재를 구입 또는 수입한 때에 부담한 부가가치세액도 환급받을 수 있다는 의견이 있으나, 영농기자재등면세 규정 제7조제1호 및 별표 5에서 농·임업용 기자재 중에서 일부만을 특정하여 부가가치세 환급이 적용되는 농·임업용 기자재로 정하고 있고, 이 사안 기자재가 방조망과 유사한 기능을 수행한다는 점만을 이유로 부가가치세 환급 대상에 해당한다고 해석하게 된다면 합리적 이유 없이 부가가치세 환급 대상을 확장해석하는 것으로서 조세공평주의에 반하게 될 우려가 있는 점 등을 고려해 볼 때, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 관할 세무서장은 농어민등이 이 사안 기자재를 구입 또는 수입한 때에 부담한 부가가치세액을 해당 농어민등에게 환급할 수 없습니다.

법령정비 권고사항

농어업 경제상황, 세제지원 효과, 세수손실 규모 등을 고려하여, 영농기자재등면세규정 제7조제1호 및 별표 5에 방조망과 유사한 기능을 수행하는 농·임업용 기자재를 추가할 필요가 있는지를 정책적으로 검토하고, 필요하다고 판단되는 경우 이를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

조세특례제한법

제105조의2(농·업·임업·어업용 기자재에 대한 부가가치세의 환급에 관한 특례) ① 다음 각 호에 해당하는 세무서장(이하 이 조에서 “관할 세무서장”이라 한다)은 대통령령으로 정하는 농민, 임업에 종사하는 자와 어민(이하 이 조에서 “농어민등”이라 한다)이 농업·임업 또는 어업에 사용하기 위하여 구입하는 기자재(「부가가치세법」 제2조제5호에 따른 일반과세자로부터 구입하는 기자재만 해당한다) 또는 직접 수입하는 기자재로서 대통령령으로 정하는 것에 대해서는 기자재를 구입 또는 수입한 때에 부담한 부가가치세액을 해당 농어민등에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 환급할 수

8) 2001. 12. 29. 법률 제6538호로 일부개정된 「조세특례제한법」 개정이유 참조

있다.

1.·2. (생 략)

② ~ ⑨ (생 략)

농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정

제7조(부가가치세 환급대상 농·임·어업용 기자재의 범위) 법 제105조의2제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 별표 5의 농·임업용 기자재
2. 별표 6의 어업용 기자재

[별표 5]

부가가치세 환급이 적용되는 농·임업용 기자재(제7조제1호 관련)

1. ~ 11. (생 략)
12. 농업·임업용 방조망(防鳥網) 및 방풍망(과수·수실류·작물 재배용 및 축산업용에 한정한다)
13. ~ 66. (생 략)

민원인 - 「소득세법」 제12조제3호머목2)의 '6세 이하인 자녀'의 범위(「소득세법」 제12조제3호머목 등 관련)

01 질의요지

「소득세법」 제12조제3호머목에서는 '근로자 또는 그 배우자의 출산이나 자녀의 보육과 관련하여 사용자로부터 지급받는 다음의 급여'를 비과세소득으로 규정하면서, 해당 비과세소득의 하나로 같은 목 2)에서는 '근로자 또는 그 배우자의 해당 과세기간 개시일을 기준으로 6세 이하(6세가 되는 날과 그 이전 기간을 말한다. 이하 이 조 및 제59조의4에서 같다)인 자녀의 보육과 관련하여 사용자로부터 지급받는 급여로서 월 20만원 이내의 금액'을 규정하고 있는바,

근로자 또는 그 배우자의 해당 과세기간 개시일을 기준으로 출생 후 6년 초과 7년 미만의 기간이 경과한 자녀(이하 "이 사안 자녀"라 함)가 「소득세법」 제12조제3호머목2)의 6세 이하인 자녀에 해당하는지?

02 회답

이 사안 자녀는 「소득세법」 제12조제3호머목2)의 6세 이하인 자녀에 해당하지 않습니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수 밖에 없다고 할 것인데¹⁾, 「소득세법」 제12조제3호머목2)에서는 해당 과세기간 개시일을 기준으로 6세 이하인 자녀의 의미와 관련하여 '6세 이하' 뒤에 괄호를 두어 '6세가 되는 날과 그 이전 기간을 말한다'고 규정하여

1) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

그 의미를 명확히 하고 있는바, 이는 6세가 되는 날까지의 자녀를 의미하는 것이지, 6세가 되는 날이 지났으나 7세가 되는 날 전까지의 자녀를 의미하는 것은 아니므로, 해당 과세기간 개시일을 기준으로 6세가 되는 날이 지난 이 사안 자녀의 경우는 「소득세법」 제12조제3호머목2)의 6세 이하인 자녀에 해당하지 않음이 문언상 분명합니다.

그리고 현행 「소득세법」 제12조제3호머목2)의 규정은 구 「소득세법」²⁾에서 ‘6세 이하’라고만 규정하고 있던 것을 2024년 12월 31일 법률 제20615호로 일부개정된 현행 「소득세법」에서 ‘6세 이하’ 부분에 괄호를 두어 ‘6세가 되는 날과 그 이전 기간을 말한다’라고 규정한 것인데, 이는 만 6세가 지났으나 만 7세가 되기 전인 사람까지 ‘6세 이하’에 해당하는 것으로 오인되는 것을 방지하기 위한 것³⁾인바, 만 6세가 지났으나 만 7세가 되기 전인 이 사안 자녀의 경우는 「소득세법」 제12조제3호머목2)의 6세 이하인 자녀에 해당하지 않는다고 보는 것이 「소득세법」의 입법연혁 및 개정 취지에 부합하는 해석입니다.

또한 조세법률주의의 원칙상 과세요건이거나 비과세요건 또는 조세감면요건을 막론하고 조세법규의 해석은 특별한 사정이 없는 한 법문대로 해석하여야 할 것이고, 납세자에게 유리하다고 하여 합리적 이유 없이 확장해석하거나 유추해석하는 것은 허용되지 않는다고 할 것인바⁴⁾, 「소득세법」 제12조제3호머목2)에서 괄호를 두어 ‘6세 이하’의 의미를 ‘6세가 되는 날과 그 이전 기간을 말한다’고 규정하여 6세가 되는 날이 지난 자녀의 경우는 이에 해당하지 않음을 명확히 하고 있음에도 해당 과세기간 개시일을 기준으로 6세가 되는 날이 지난 이 사안 자녀가 「소득세법」 제12조제3호머목2)의 6세 이하인 자녀에 해당한다고 해석하는 것은 합리적인 이유 없이 비과세요건을 확장해석하는 것으로서 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 이 사안 자녀는 「소득세법」 제12조제3호머목2)의 6세 이하인 자녀에 해당하지 않습니다.

2) 2024. 12. 31. 법률 제20615호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 같음.

3) 2024. 9. 2. 의안번호 제2203518호로 발의된 소득세법 일부개정법률안에 대한 국회 기획재정위원회 검토보고서 참조

4) 대법원 2000. 12. 26. 선고 98두1192 판결례 및 대법원 2006. 5. 25. 선고 2005다19163 판결례 참조

**소득세법**

제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

- 1.·2. (생 략)
3. 근로소득과 퇴직소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득
 - 가. ~ 러. (생 략)
 - 머. 근로자 또는 그 배우자의 출산이나 자녀의 보육과 관련하여 사용자로부터 지급받는 다음의 급여
 - 1) (생 략)
 - 2) 근로자 또는 그 배우자의 해당 과세기간 개시일을 기준으로 6세 이하(6세가 되는 날과 그 이전 기간을 말한다. 이하 이 조 및 제59조의4에서 같다)인 자녀의 보육과 관련하여 사용자로부터 지급받는 급여로서 월 20만원 이내의 금액

질의제목 4

▶ 안전번호 25-0152

민원인 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조제1항제2호 단서의 “제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우”는 여성기업 등과 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역계약을 체결하는 경우로 한정되는지(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조제1항제2호 단서 관련)

01 질의요지

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 함) 제7조제1항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부치도록 하면서(본문), 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명(指名)하여 경쟁에 부치거나 수의계약(隨意契約)을 할 수 있다고 규정하고 있고(단서), 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제26조제1항제5호가목5)에서는 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 여성기업, 장애인기업 등 같은 목 5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역계약(이하 “제조계약등”이라 함)을 규정하고 있는 한편,

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”이라 함) 제30조제1항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 수의계약을 체결하려는 경우 원칙적으로 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하되(본문), 추정가격이 2천만원 이하인 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있도록 하면서, 여성기업, 장애인기업 등 같은 영 제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “여성기업등”이라 함)와 계약을 체결하는 경우에는 추정가격이 5천만원 이하인 경우까지 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있도록 규정(단서 및 제2호)하고 있는바,

국가계약법 시행령 제30조제1항제2호 단서의 “제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우”는 여성기업등과 제조계약등을 체결하는 경우로 한정되는지, 아니면 여성기업등과 제조계약등 외의 계약을 체결하는 경우도 포함하는지?

02 회답

국가계약법 시행령 제30조제1항제2호 단서의 “제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우”에는 여성기업등과 제조계약등 외의 계약을 체결하는 경우도 포함됩니다.

03 이유

국가계약법 시행령 제30조제1항 본문에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 단서 및 같은 항 제2호 단서에서는 같은 영 제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 추정가격이 5천만원 이하인 경우까지 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다고 규정하고 있는데, 같은 영 제30조제1항제2호 단서에서 인용하고 있는 같은 영 제26조제1항제5호가목5)에서는 수의계약이 가능한 경우를 여성기업등과 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 ‘제조계약등’을 체결하는 경우로 한정하고 있어, 같은 영 제30조제1항제2호단서의 ‘여성기업등과 계약을 체결하는 경우’도 제조계약등을 체결하는 경우로 한정되는지, 아니면 제조계약등 외의 계약을 체결하는 경우도 포함하는지가 문제됩니다.

먼저 국가계약법 시행령 제30조제1항제2호 단서에서는 예외적으로 추정가격이 5천만원 이하인 경우에도 1인으로부터 받은 견적서로 수의계약을 할 수 있는 경우로 ‘같은 영 제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우’라고 규정하여 계약의 상대방은 여성기업등으로 한정하고 있는 반면, 계약의 종류에 관하여는 특별한 규정을 두고 있지 아니한바, 국가계약법령상 계약의 종류를 한정하려는 경우에는 물품·공사(工事) 및 용역의 계약(국가계약법 제4조), 물품구매계약 또는 물품제조계약(국가계약법 제14조제4항), 임차계약·운송계약·보관계약(국가계약법 제20조) 또는 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역계약(국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목3) 단서) 등과 같이 계약의 종류를 구체적으로 규정하고 있는 점을 고려하면, 국가계약법 시행령 제30조제1항제2호 단서의 ‘같은 영 제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우’는 여성기업등과 제조계약등을 체결하는 경우로 한정되는 것이 아니라 여성기업등과 제조계약등 외의 계약을 체결하는 경우도 포함한다고

보는 것이 문언 및 규정 체계에 부합합니다.

또한 국가계약법 시행령 제30조제1항제2호 단서는 구 국가계약법 시행령(2018년 12월 4일 대통령령 제29318호로 일부개정되기 전의 것을 말함)에서 여성기업 및 장애인기업과 추정가격 5천만원 이하인 계약을 체결하는 경우에만 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있도록 하던 것을, 사회적기업 등에 대한 지원을 확대하기 위하여 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업 또는 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자와 계약을 체결하는 경우까지로 하면서⁵⁾, 국가계약법 시행령 제30조제1항제2호 단서에서 “제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우”라고 규정하고 있는바, 이러한 입법연혁 및 문언에 비추어 보면 계약의 상대방 외에 계약의 종류까지 한정하려는 것으로 해석하기는 어렵다고 할 것입니다.

한편 국가계약법 시행령 제30조제1항제2호 단서에서 같은 영 제26조제1항제5호가목5)를 인용하여 규정한 것은 여성기업등과 수의계약 시 1인 견적서에 의할 수 있는 경우를 같은 목 5)에 따라 수의계약이 가능한 경우와 일치되게 하기 위한 것이므로 같은 영 제30조제1항제2호 단서의 “제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우”는 여성기업등과 제조계약등을 체결하는 경우로 한정해야 한다는 의견이 있으나, 국가계약법 시행령 제26조는 수의계약을 할 수 있는 사유를 정한 규정인 반면, 같은 영 제30조제1항은 수의계약을 할 수 있는 경우에 몇 명에게 견적서를 받아야 하는지를 정한 규정으로서 양 규정의 규율대상이 다르고, 여성기업등은 같은 영 제26조제1항제5호가목5)에 해당하는 경우 외에도 같은 조의 다른 수의계약 사유에 해당하면 수의계약의 상대방이 될 수 있다는 점을 고려하면, 국가계약법 시행령 제30조제1항제2호 단서에 따라 1인으로부터 받은 견적서에 의해 수의계약을 체결할 수 있는 경우를 같은 영 제26조제1항제5호가목5)에 따라 여성기업등과 수의계약을 체결할 수 있는 경우와 반드시 일치되게 해석해야 할 이유도 없다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 국가계약법 시행령 제30조제1항제2호 단서의 “제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우”에는 여성기업등과 제조계약등 외의 계약을 체결하는 경우도 포함됩니다.

5) 2018. 12. 4. 대통령령 제29318호로 일부개정된 국가계약법 시행령에 대한 조문별 개정이유서 참조

**국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령**

제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 4. (생략)

5. 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약

1) ~ 4) (생략)

5) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역계약

가) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업

나) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업

다) 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자

6)·7) (생략)

나. ~ 자. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

제30조(견적에 의한 가격결정 등) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

1. 제26조제1항제1호가목·나목, 같은 항 제2호, 같은 항 제5호가목7), 같은 호 마목·사목·아목, 제27조 및 제28조에 따른 계약의 경우

2. 추정가격이 2천만원 이하인 경우. 다만, 제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하인 경우로 한다.

3. (생략)

② ~ ⑦ (생략)

질의제목 5

▶ 안전번호 25-0257

민원인 - 신용협동조합의 이사장으로 선출되어 두 차례 연임한 자는 이후에 다시 이사장이 될 수 없는지 여부(「신용협동조합법」 제31조제1항 등 관련)

01 질의요지

「신용협동조합법」 제27조제1항에서는 같은 법 제2조제1호에 따른 신용협동조합(이하 “조합”이라 함)에 임원으로 이사장 1명, 부이사장 1명을 포함하여 5명 이상 9명 이하의 이사와 감사 2명 또는 3명을 둔다고 규정하고 있고, 같은 법 제27조제2항에서는 임원은 정관에서 정하는 바에 따라 총회에서 선출한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제31조제1항 본문에서는 임원의 임기는 4년으로 하며, 연임할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 단서에서 이사장은 두 차례만 연임할 수 있다고 규정하고 있는바,

「신용협동조합법」 제27조제2항에 따라 조합의 이사장으로 선출되고 두 차례 연임을 한 자는 그 임기가 연속되지 않는 경우 다시 이사장으로 선임될 수 있는지?

02 회답

「신용협동조합법」 제27조제2항에 따라 조합의 이사장으로 선출되고 두 차례 연임을 한 자는 그 임기가 연속되지 않는 경우 다시 이사장으로 선임될 수 있습니다.

03 이유

먼저 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데¹⁾, “연임”은 원래 정해진 임기를 다 마친 뒤에 다시 계속하여 그 직위에 머무르는 것을 의미하는바²⁾, 「신용협동조합법」 제31조제1항 단서에서 이사장은 두 차례만

1) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

연임할 수 있다고 규정하고 있는 것은 그 문언상 조합의 이사장으로 선임된 후 최초의 임기를 마치고 계속하여 두 차례 더 선임되어 그 정해진 임기를 마친 뒤에 다시 계속하여 조합의 이사장으로 선임되어 그 직무를 수행하는 것(3차 연임)을 금지하는 규정이라고 할 것이고, 두 차례 연임한 이사장이 임기가 연속되지 않는 경우에 다시 이사장으로 선임되는 것까지 금지하는 규정이라고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

그리고 임기가 연속되지 않더라도 다시 위촉·임용되는 것을 제한하기 위해 “연임”과는 별도로 “중임”이라는 용어를 사용하여 중임 제한 규정을 두고 있는 조세심판관의 임기에 관한 「국세기본법」 제67조제5항, 교장의 임기에 관한 「교육공무원법」 제29조의2제3항 및 동별 대표자의 임기에 관한 「공동주택관리법 시행령」 제13조제2항 등의 입법례에 비추어 보더라도, 이사장의 연임을 제한하고 있는 「신용협동조합법」 제31조제1항 단서를 임기가 연속되지 않더라도 다시 위촉·임용되는 것을 제한하는 “중임”과 같이 해석할 수는 없다고 할 것입니다.

아울러 종전에 이사장은 1차에 한하여 연임할 수 있던 것을 2012년 12월 11일 법률 제11545호로 일부개정된 「신용협동조합법」에서 현행과 같이 두 차례만 연임할 수 있도록 개정된 것인데, 이는 「농업협동조합법」, 「수산업협동조합법」 등 다수의 입법례가 조합의 이사장 또는 조합장에 대하여 2차 연임을 허용하고 있는 반면 「신용협동조합법」은 조합 이사장에 대하여 1차 연임만 허용하는 것은 형평에 맞지 않을 수 있다는 점을 고려해 신용협동조합의 이사장도 2차에 한하여 연임할 수 있도록 연임제한을 완화하려는 취지였던바²⁾, 두 차례 연임한 이사장이 그 임기가 연속되지 않는 경우에도 다시 이사장으로 선임되는 것까지 금지하려는 취지가 있는 것으로 보이지는 않는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「신용협동조합법」 제27조제2항에 따라 조합의 이사장으로 선출되고 두 차례 연임을 한 자는 그 임기가 연속되지 않는 경우 다시 이사장으로 선임될 수 있습니다.

2) 법제처 2015. 12. 7. 회신 15-0798 해석례 및 국립국어원 표준국어대사전 참조

3) 2012. 9. 6. 의안번호 제1901603호로 발의된 신용협동조합법 일부개정법률안에 대한 국회 정무위원회 검토보고서 참조



관계법령

신용협동조합법

제27조(임원) ① 조합에 임원으로 이사장 1명, 부이사장 1명을 포함하여 5명 이상 9명 이하의 이사와 감사 2명 또는 3명을 둔다.

② 임원은 정관에서 정하는 바에 따라 총회에서 선출(임원의 결원으로 인한 보궐선거의 경우에는 정관에서 따로 정하는 바에 따른다)하되, 이사장을 포함한 임원의 3분의 2 이상은 조합원이어야 한다.

③ ~ ⑬ (생략)

제31조(임기 등) ① 임원의 임기는 4년으로 하며, 연임할 수 있다. 다만, 이사장은 두 차례만 연임할 수 있다.

②·③ (생략)

CHAPTER

2

산업통상자원·중소기업

제1절 산업통상자원

제2절 중소기업

제1절 산업통상자원

질의제목 1

▶ 안전번호 24-1003

민원인 - 「유통산업발전법」 제12조제2항제2호라목에 따라 입점상인 2분의 1 이상이 동의하여 지정한 자의 관리비 청구·수령 업무 개시 시기(「유통산업발전법」 제12조 등 관련)

01 질의요지

「유통산업발전법」 제12조제1항에서는 대규모점포등개설자¹⁾는 대규모점포등²⁾을 유지·관리하기 위하여 필요한 업무(제3호) 등을 수행한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 매장이 분양된 대규모점포에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “대규모점포등관리자”라 함)가 같은 조 제1항 각 호의 업무를 수행한다고 규정하면서, 같은 조 제2항제1호에서는 매장면적의 2분의 1 이상을 직영하는 자가 있는 경우에는 그 직영하는 자를, 같은 항 제2호에서는 매장면적의 2분의 1 이상을 직영하는 자가 없는 경우에는 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 그 업무를 수행하도록 규정하고 있으며, 같은 항 제2호라목에서는 같은 호 가목부터 다목까지의 어느 하나에 해당하는 자가 없는 경우에는 입점상인³⁾ 2분의 1 이상이 동의하여 지정하는 자(전단)를 규정하면서, 이 경우 6개월 이내에 같은 호 가목 또는 나목에 따른 법인·협동조합 또는 사업조합(이하 “법인등”이라 함)을 설립하여야 한다고 규정(후단)하고 있고, 같은 법 제12조의3제1항에서는 대규모점포등관리자는 대규모점포등을 유지·관리하기 위한 관리비를 입점상인에게 청구·수령하고 그 금원을 관리할 수 있다고 규정하고 있는바,

1) 「유통산업발전법」 제8조에 따라 대규모점포등의 개설등록을 한 자를 말하며(「유통산업발전법」 제11조제1항 참조), 이하 같음

2) 대규모점포 및 준대규모점포를 말하며(「유통산업발전법」 제7조의5제1항 참조), 이하 같음

3) 해당 대규모점포 또는 등록 준대규모점포에 입점(入店)하여 영업을 하는 상인을 말하며(「유통산업발전법」 제12조제2항제2호 가목 참조), 이하 같음

「유통산업발전법」 제12조제2항제2호라목 전단에 따라 입점상인 2분의 1 이상이 동의하여 지정한 자는 같은 목 후단에 따라 6개월 이내에 법인등을 설립하기 전까지 같은 법 제12조의3에 따라 관리비 청구·수령 업무를 개시할 수 있는지?

02 회답

「유통산업발전법」 제12조제2항제2호라목 전단에 따라 입점상인 2분의 1 이상이 동의하여 지정한 자는 같은 목 후단에 따라 6개월 이내에 법인등을 설립하기 전까지 같은 법 제12조의3에 따라 관리비 청구·수령 업무를 개시할 수 있습니다.

03 이유

「유통산업발전법」 제12조제2항에서는 매장이 분양된 대규모점포 및 등록 준대규모 점포에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 같은 조 제1항 각 호의 업무를 수행한다고 규정하면서, 같은 조 제2항제2호에서는 매장면적의 2분의 1 이상을 직영하는 자가 없는 경우에는 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 그 업무를 수행한다고 규정하고 있고, 같은 호 각 목으로 입점상인 3분의 2 이상이 동의하여 설립한 「민법」 또는 「상법」에 따른 법인(가목), 입점상인 3분의 2 이상이 동의하여 설립한 「중소기업협동조합법」에 따른 협동조합 또는 사업협동조합(나목), 입점상인 3분의 2 이상이 동의하여 조직한 자치관리단체(다목)를 각각 규정하고 있으며, 같은 호 라목에서는 같은 호 가목부터 다목까지의 어느 하나에 해당하는 자가 없는 경우에는 입점상인 2분의 1 이상이 동의하여 지정하는 자(전단)를 규정하면서 이 경우 6개월 이내에 법인등을 설립하여야 한다(후단)고 규정하고 있는바, 「유통산업발전법」 제12조제2항제2호라목 후단은 같은 목 전단에 따라 입점상인 2분의 1 이상이 동의하여 지정된 자는 6개월 이내에 법인등을 설립하도록 하는 의무를 규정한 것으로서, 같은 목 후단의 요건을 갖추어야만 대규모점포등관리자로서의 업무를 수행할 수 있다는 취지의 규정을 별도로 두고 있지 않다는 점을 고려하면, 같은 목 전단에 따라 입점상인 2분의 1 이상이 동의하여 지정된 자는 한시적으로 업무를 수행하되, 만약 6개월 이내에 법인등을 설립하지 못하면 임시적인 대규모점포등관리자로서의 지위를 유지하지 못하고 효력을 잃게 되는 것이고⁴⁾, 6개월 이내에 법인등이 설립되기 전까지는 대규모점포등관리자로서의 업무를 수행할 수 있다고 할 것입니다.

그리고 「유통산업발전법」 제12조제3항 전단에서는 대규모점포등관리자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·시장·군수·구청장(이하 “시장등”이라 함)에게 신고를 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제6조제1항에서는 대규모점포등관리자는 같은 법 제12조제3항 전단에 따라 업무를 수행하게 된 날부터 20일 이내에 별지 제4호서식의 대규모점포등관리자신고서에 같은 법 제12조제2항 각 호의 어느 하나에 해당함을 증명하는 서류 등을 첨부하여 시장등에게 신고하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 별지 제4호서식의 관리자란에는 관리자인 법인의 명칭을 쓰도록 하면서 법인 뒤에 괄호를 두어 조합, 자치관리단체, 지정한 자를 규정하여 “지정한 자”도 관리자로서 대규모점포등관리자 신고를 할 수 있는 것으로 규정되어 있는바, 위 규정들은 「유통산업발전법」 제12조제2항제2호라목 후단에 따라 6개월 이내에 법인등이 설립되기 전이라도 같은 목 전단에 따라 입점상인 2분의 1 이상이 동의하여 지정한 자는 대규모점포등관리자로서 대규모점포등을 유지하고 관리하는 업무를 수행할 수 있음을 전제로 한 것이라 할 것입니다.

또한 종전 「유통산업발전법」⁵⁾에서는 대규모점포관리자등의 요건을 “입점상인 2분의 1 이상이 동의하여 지정하는 자”로만 규정하고 있었던 것을 2003년 7월 30일 법률 제6959호로 전부개정된 「유통산업발전법」 제12조제2항제2호라목에서는 후단을 신설하여 “이 경우 6개월 이내에 가목 또는 나목에 따른 법인·협동조합 또는 사업조합을 설립하여야 한다”는 내용을 규정하게 된 것인바, 그 입법 취지는 같은 법 제12조제2항제2호가목부터 다목까지에 해당하는 자가 없을 경우 입점상인 2분의 1 이상이 동의하여 지정하는 자가 한시적으로 대규모점포등관리자가 되도록 하되, 그 후 대규모점포등의 관리에 공백이 생기지 않도록 일정 기간 내에 법인, 협동조합 또는 사업조합과 같은 형태로 조직화하도록 하기 위한 것이라 할 것⁶⁾이므로, 매장이 분양된 대규모점포에서 「유통산업발전법」 제12조제2항제2호라목 전단에 따라 입점상인 2분의 1 이상이 동의하여 지정된 자는 6개월 이내에 법인등이 설립되기 전에도 같은 법 제12조의3제1항에 따라 입점상인에게 한시적으로 관리비를 청구·수령하는 등 대규모점포등을 유지·관리하기 위하여 필요한 업무를 수행할 수 있다고 보는 것이 입법취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

따라서 「유통산업발전법」 제12조제2항제2호라목 전단에 따라 입점상인 2분의 1 이상이 동의하여 지정한 자는 같은 목 후단에 따라 6개월 이내에 법인등을 설립하기 전까지 같은 법 제12조의3에 따라 관리비 청구·수령 업무를 개시할 수 있습니다.

4) 법제처 2018. 4. 2. 회신 18-0273 해석례 참조

5) 2003. 7. 30. 법률 제6959호로 전부개정되기 전의 「유통산업발전법」 제13조제2항제4호 참조

6) 법제처 2017. 4. 26. 회신 17-0247 해석례 참조



관계법령

유통산업발전법

제12조(대규모점포등개설자의 업무 등) ① 대규모점포등개설자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 상거래질서의 확립
2. 소비자의 안전유지와 소비자 및 인근 지역주민의 피해·불만의 신속한 처리
3. 그 밖에 대규모점포등을 유지·관리하기 위하여 필요한 업무

② 매장이 분양된 대규모점포 및 등록 준대규모점포에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “대규모점포등관리자”라 한다)가 제1항 각 호의 업무를 수행한다.

1. 매장면적의 2분의 1 이상을 직영하는 자가 있는 경우에는 그 직영하는 자
2. 매장면적의 2분의 1 이상을 직영하는 자가 없는 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
가. 해당 대규모점포 또는 등록 준대규모점포에 입점(入店)하여 영업을 하는 상인(이하 “입점상인”이라 한다) 3분의 2 이상이 동의(동의를 얻은 입점상인이 운영하는 매장면적의 합은 전체 매장면적의 2분의 1 이상이어야 한다. 이하 이 장에서 같다)하여 설립한 「민법」 또는 「상법」에 따른 법인
나. 입점상인 3분의 2 이상이 동의하여 설립한 「중소기업협동조합법」 제3조제1항제1호에 따른 협동조합(이하 “협동조합”이라 한다) 또는 같은 항 제2호에 따른 사업협동조합(이하 “사업조합”이라 한다)
- 다. 입점상인 3분의 2 이상이 동의하여 조직한 자치관리단체. 이 경우 6개월 이내에 가목 또는 나목에 따른 법인·협동조합 또는 사업조합의 자격을 갖추어야 한다.
- 라. 가목부터 다목까지의 어느 하나에 해당하는 자가 없는 경우에는 입점상인 2분의 1 이상이 동의하여 지정하는 자. 이 경우 6개월 이내에 가목 또는 나목에 따른 법인·협동조합 또는 사업조합을 설립하여야 한다.

③ 대규모점포등관리자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 한다. 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

④ ~ ⑤ (생략)

제12조의3(대규모점포등의 관리비 등) ① 대규모점포등관리자는 대규모점포등을 유지·관리하기 위한 관리비를 입점상인에게 청구·수령하고 그 금원을 관리할 수 있다.

② ~ ⑥ (생략)

질의제목 2

▶ 안전번호 25-0175

민원인 - 양수 발전이 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호다목에 따른 수력을 이용하여 전기를 생산하는 신·재생에너지 발전에 해당하는지 여부(「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호다목 등 관련)

01 질의요지

「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」(이하 “신재생에너지법”이라 함) 제2조 제2호에서는 “재생에너지”란 햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水)·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 태양에너지(가목), 풍력(나목), 수력(다목) 등 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4호에서는 “신·재생에너지 발전”이란 신에너지 및 재생에너지(이하 “신·재생에너지”라 함)를 이용하여 전기를 생산하는 것을 말한다고 규정하고 있는바,

양수(揚水) 발전¹⁾은 신재생에너지법 제2조제2호다목에 따른 수력을 이용하여 전기를 생산하는 신·재생에너지 발전²⁾에 해당하는지?

02 회답

양수 발전은 신재생에너지법 제2조제2호다목에 따른 수력을 이용하여 전기를 생산하는 신·재생에너지 발전에 해당하지 않습니다.

03 이유

먼저 신재생에너지법 제2조제2호에서는 “재생에너지”란 햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水)·

1) 전기가 남을 때 펌프 등 외부전력기기를 사용하여 물을 상부로 끌어 올렸다가 전기가 필요할 때 상부에 모아두었던 물을 방류하여 발전기를 돌리는 방식의 발전을 말함(한국수력원자력 홈페이지 설명 참조)

2) 신재생에너지법 제2조제4호에 따른 신·재생에너지 발전을 말함

생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 태양에너지(가목), 풍력(나목), 수력(다목) 등 같은 항 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4호에서는 “신·재생에너지 발전”이란 신·재생에너지를 이용하여 전기를 생산하는 것을 말한다고 규정하고 있는바, 이를 종합하여 보면 신·재생에너지 발전 중 하나인 “수력 발전”은 자연 상태의 물 또는 강수(降水) 등을 변환시켜 이를 에너지원으로 이용하여 전기를 생산하는 발전 방식을 의미한다고 할 것입니다.

그런데 “양수 발전”은 물의 위치에너지를 확보하기 위하여 하부에 저장되어 있는 물을 펌프 등 외부 전력기기를 사용하여 상부로 끌어 올려 이를 방수하여 전기를 생산하는 방식으로서 자연 상태 그대로의 물 또는 강수(降水) 등을 이용하여 전기를 생산하는 것이 아니라, 이미 생산한 전기 등 인공적인 방식의 에너지를 투입하여 인위적으로 위로 퍼 올린 물³⁾을 이용하여 전기를 생산하는 것인바, 문언상 “양수 발전”은 신재생에너지법 제2조제2호다목에 따른 재생에너지인 수력을 이용하여 전기를 생산하는 신·재생에너지 발전에 해당한다고 보기는 어렵습니다.

또한 신재생에너지법은 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급 촉진과 신·재생에너지 산업의 활성화를 통하여 에너지원을 다양화함으로써 환경의 보전, 국가경제의 건전하고 지속적인 발전 및 국민복지의 증진에 이바지함을 목적으로 하는 법률로(제1조), 산업통상자원부장관은 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급을 촉진하기 위한 기본계획 및 실행계획을 수립하고(제5조·제6조), 정부는 이러한 실행계획을 시행하는 데에 필요한 사업비를 회계연도마다 세출예산에 계상(計上)하여야 하며(제9조), 국가 또는 지방자치단체는 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급에 관한 사업을 위하여 필요하다고 인정하면 「국유재산법」 또는 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 수의계약(隨意契約)으로 국유·공유재산을 신·재생에너지 기술개발 등의 사업을 하는 자에게 임대·처분할 수 있도록 하는(제26조) 등 정부와 지방자치단체 등의 지원을 통해 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급을 촉진하는 한편, 질서있는 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급을 위하여 국가기관이나 지방자치단체 등이 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급에 관한 계획을 수립·시행하려면 미리 산업통상자원부장관과 협의하여야 하고(제7조), 설비인증을 받은 신·재생에너지 설비 제조·수입판매자는 신·재생에너지 설비의 결함으로 인하여 제3자가 입을 수 있는 손해를 담보하기 위하여 보험 또는 공제에 가입하여야 하며(제13조의2), 이를 위반한 경우 1천만원 이하의 과태료 부과 대상이 되는(제35조제1항제4호) 등의 규제를 동시에 실시하고 있는바,

3) 국립국어원 표준국어대사전 참조

이러한 지원과 규제의 대상이 되는 신·재생에너지의 범위를 합리적인 이유 없이 확대하여 해석하기는 어렵다는 점에서, 신재생에너지법에 따른 “수력 발전”은 자연 상태의 물 또는 강수(降水) 등을 변환시켜 이를 에너지원으로 이용하여 전기를 생산하는 발전 방식으로 한정하여 해석할 필요가 있습니다.

한편 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」(이하 “발전소주변지역법”이라 함) 제2조 단서 및 같은 법 시행령 제2조제1항에서는 수력발전소를 양수발전소인 경우(제1호)와 양수발전소 외의 수력발전소인 경우(제2호)로 구분하여 수력발전소의 주변지역을 규정하고 있으므로, 양수 발전도 신재생에너지법 제2조제2호다목에 따른 수력을 이용하여 전기를 생산하는 신·재생에너지 발전에 해당한다는 의견이 있으나, 발전소주변지역법은 발전소의 주변지역에 대한 지원사업을 효율적으로 추진하여 지역발전에 기여함을 목적으로 하는 법률로서, 신·재생에너지의 이용·보급 촉진 및 신·재생에너지 산업의 활성화를 통해 에너지원을 다양화하고, 온실가스 배출의 감소를 추진하는 것을 목적으로 하는 신재생에너지법과는 입법 목적과 규율 내용이 다른 별도의 법률인바, 발전소주변지역법에 따른 수력발전소에 해당하는지 여부와 신재생에너지법에 따른 신·재생에너지 발전에 해당하는지 여부는 별도의 법률에서 규율하고 있는 별개의 사항이라 할 것이므로, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 양수 발전은 신재생에너지법 제2조제2호다목에 따른 수력을 이용하여 전기를 생산하는 신·재생에너지 발전에 해당하지 않습니다.



관계법령

신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. (생 략)
2. “재생에너지”란 햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水)·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
 - 가. 나. (생 략)
 - 다. 수력
 - 라. ~ 아. (생 략)
3. (생 략)
4. “신·재생에너지 발전”이란 신·재생에너지를 이용하여 전기를 생산하는 것을 말한다.
5. (생 략)

질의제목 3

▶ 안전번호 25-0204

민원인 - 허가권자는 「전기사업법」 제7조제5항제2호에 따른 허가기준에 부합하는지 여부를 판단하기 위하여 주민 설명회 개최 결과의 제출을 요구할 수 있는지 여부(「전기사업법」 제7조제5항제2호 등 관련)

01 질의요지

「전기사업법」 제7조제1항에서는 전기사업¹⁾을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 전기사업의 종류별 또는 규모별로 산업통상자원부장관 또는 시·도지사(이하 “허가권자”라 함)의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제5항에서는 전기사업의 허가기준으로 전기사업이 계획대로 수행될 수 있을 것(제2호), 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」(이하 “신재생에너지법”이라 함) 제2조에 따른 태양에너지 중 태양광, 풍력, 연료전지를 이용하는 발전사업의 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 발전사업 내용에 대한 사전고지를 통하여 주민 의견수렴 절차를 거칠 것(제5호) 등을 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제4조의2제1항에서는 발전사업을 하려는 자는 같은 법 제7조제5항제5호에 따라 발전사업의 내용에 관해 주민의 의견을 들으려는 경우 발전소가 입지하는 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문에 발전사업의 주요 내용(제2호), 의견제출 기간 및 방법(제4호) 등 같은 항 각 호의 사항을 공고하고, 발전사업의 내용을 주민이 열람할 수 있도록 해야 한다고 규정하고 있으며, 같은 영 제4조의2제3항에서는 같은 조 제1항에 따라 공고된 발전사업의 내용에 대하여 의견이 있는 자는 같은 항 제4호에 따른 의견제출 기간 및 방법에 따라 의견을 제출할 수 있다고 규정하고 있는바,

「전기사업법」 제7조제1항에 따라 신재생에너지법 제2조에 따른 태양에너지 중 태양광을 이용하는 발전사업의 허가를 받으려는 자가 「전기사업법」 제7조제5항제5호 및 같은 법 시행령 제4조의2에 따른 의견수렴 결과를 제출한 경우, 허가권자는 같은 법 제7조제5항제2호에 따른 허가기준에 부합하는지 여부를 판단하기 위하여 주민 설명회²⁾ 개최 결과를 제출하도록 요구할 수 있는지?

1) 발전사업·송전사업·배전사업·전기판매사업 및 구역전기사업을 말하며(「전기사업법」 제2조제1호 참조), 이하 같음

2) 발전사업 내용의 사전고지 및 의견 수렴을 위하여 해당 발전사업의 시행으로 영향을 받게 되는 지역의 주민을 대상으로 개최하는 설명회를 말함

02 회답

이 사안의 경우, 허가권자는 「전기사업법」 제7조제5항제2호에 따른 허가기준에 부합하는지 여부를 판단하기 위하여 주민 설명회 개최 결과를 제출하도록 요구할 수 없습니다.

03 이유

「전기사업법」 제7조제1항에서는 전기사업을 하려는 자는 허가권자의 허가를 받아야 한다고 규정하면서, 같은 조 제5항제2호에서는 전기사업의 허가기준 중 하나로 전기사업이 계획대로 수행될 수 있을 것을 규정하고 있고, 같은 항 제5호에서는 신재생에너지법 제2조에 따른 태양에너지 중 태양광 등을 이용하는 발전사업의 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 발전사업의 내용에 대한 사전고지를 통하여 주민 의견수렴 절차를 거칠 것을 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제4조의2에서는 태양광 등을 이용하는 발전사업에 대한 의견수렴 절차로 일간신문 공고 및 주민열람을 규정하고 있을 뿐, 주민 설명회 개최에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않습니다.

그런데 「민원 처리에 관한 법률」 제6조제2항에서는 행정기관의 장은 법령의 규정 또는 위임이 있는 경우를 제외하고는 민원 처리의 절차 등을 강화하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 같은 법 제10조제1항에서는 행정기관의 장은 민원을 접수·처리할 때에 민원인에게 법령·훈령 등에서 정한 구비서류 외의 서류를 추가로 요구하여서는 아니 된다고 규정하고 있는 점을 종합하여 보면, 신재생에너지법 제2조에 따른 태양광을 이용하는 발전사업의 허가를 받으려는 자에게 「전기사업법 시행령」 제4조의2에 따른 일간신문 공고를 통한 의견수렴 결과 외에 「전기사업법」 제7조제5항제2호에 따른 허가기준에 부합하는지 여부를 판단하기 위하여 주민 설명회 개최 결과의 제출을 요구하려면 전기사업법령에 이에 대한 규정이 있어야 할 것입니다.

이와 관련하여 「전기사업법 시행규칙」 제4조제1항에서는 「전기사업법」 제7조제1항에 따라 전기사업의 허가를 신청하려는 자는 전기사업허가신청서에 같은 규칙 별표 1의 작성방법에 따라 작성한 사업계획서³⁾(제1호), 정관, 재무상태표 및 손익계산서(제2호),

3) 이 경우 「전기사업법 시행규칙」 별표 1의2에 따른 서류를 첨부하여야 함

「전기사업법 시행령」 제4조의2에 따른 의견수렴 결과(제4호) 등을 첨부하여 산업통상자원부장관에게 제출해야 한다고 규정하고 있고, 「전기사업법 시행규칙」 별표 1의2에서는 사업계획서의 구비서류를 세부적으로 정하면서, ‘계획에 따른 수행 가능 여부 관련’ 구비서류(제3호)로 발전설비 건설 예정지역 관할 지방자치단체의 발전설비와 접속설비 건설에 대한 의견서, 발전기의 전력계통 접속에 따른 영향에 관한 한국전력공사의 의견서⁴⁾, 부지의 확보 및 배치 계획 관련 증명서류 등을 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제4조제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 전기사업 허가의 신청을 받은 산업통상자원부장관은 관할 지방자치단체의 장에게 같은 조 제1항제4호에 따른 의견수렴 결과에 대한 의견을 들을 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 태양광 등을 이용하는 발전사업 허가 신청 시의 첨부서류로 주민 설명회 개최 결과서, 태양광 발전설비 건설에 대한 지역주민 의견서 등은 별도로 규정하고 있지 않은바, 허가권자는 신재생에너지법 제2조에 따른 태양광을 이용하는 발전사업의 허가를 받으려는 자에게 「전기사업법 시행령」 제4조의2에 따른 일간신문 공고를 통한 의견수렴 결과 외에 주민 설명회 개최 결과를 제출하도록 요구할 수 없다고 할 것입니다.

아울러 태양광, 풍력, 연료전지 발전사업에 대한 지역주민의 수용성(受容性)을 제고하기 위하여 2020년 3월 31일 법률 제17170호로 일부개정된 「전기사업법」에서 태양광, 풍력, 연료전지를 이용하는 발전사업의 허가를 받으려는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 발전사업 내용에 대한 사전고지를 통하여 주민 의견수렴 절차를 거치도록 하는 내용으로 태양광 등 발전사업 허가 요건을 신설하였는데⁵⁾, 그 위임에 따라 마련된 「전기사업법 시행령」 제4조의2에서는 태양광 등 발전사업의 사전고지 및 의견수렴 방법으로 해당 지역 일간신문에 발전사업의 주요내용을 공고하고, 발전사업의 내용을 주민이 열람할 수 있도록 규정하고 있을 뿐, 「전기사업법」 제7조제5항제2호에 따른 허가기준에 부합하는지 여부의 판단에 필요한 의견수렴 결과 확인 서류를 달리 정하고 있지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 허가권자는 「전기사업법」 제7조제5항제2호에 따른 허가기준에 부합하는지 여부를 판단하기 위하여 주민 설명회 개최 결과를 제출하도록 요구할 수 없습니다.

4) 발전설비용량이 1만킬로와트 초과인 신청자만 해당함

5) 2020. 3. 31. 법률 제17170호로 일부개정된 「전기사업법」 개정이유 및 주요내용 참조

법령정보 권고사항

발전사업 허가기준인 ‘전기사업이 계획대로 수행될 수 있을 것’을 판단하기 위하여 허가를 받으려는 자에게 주민설명회 개최 결과서의 제출을 요구하여야 한다면 이를 법령에 명확하게 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

전기사업법

제7조(전기사업의 허가) ① 전기사업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 전기사업의 종류별 또는 규모별로 산업통상자원부장관 또는 시·도지사(이하 “허가권자”라 한다)의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② ~ ④ (생략)

⑤ 전기사업의 허가기준은 다음 각 호와 같다.

1. (생략)

2. 전기사업이 계획대로 수행될 수 있을 것

3. ~ 4의2. (생략)

5. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조에 따른 태양에너지 중 태양광, 풍력, 연료전지를 이용하는 발전사업의 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 발전사업 내용에 대한 사전고지를 통하여 주민 의견수렴 절차를 거칠 것

6. (생략)

⑥ 제1항에 따른 허가의 세부기준·절차와 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

전기사업법 시행령

제4조의2(발전사업에 대한 의견수렴 절차) ① 발전사업을 하려는 자는 법 제7조제5항제5호에 따라 발전사업의 내용에 관해 주민의 의견을 들으려는 경우 발전소가 입지하는 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문(발전소가 행정구역의 경계에 입지하는 경우에는 인접한 다른 행정구역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문을 포함한다)에 다음 각 호의 사항을 공고하고, 발전사업의 내용을 주민이 열람할 수 있도록 해야 한다.

1. 발전사업의 명칭, 위치 및 면적

2. 발전사업의 주요 내용(발전설비용량, 사업개시 예정일, 사업 운영기간 등을 포함해야 한다)

3. 발전사업 허가 신청자[발전사업을 위하여 새로 설립된 법인인 경우에는 신청자의 최대주주(누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식인 신청자의 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 가장 많은 주주를 말한다)를 포함한다]

4. 의견제출 기간 및 방법

② (생 략)

- ③ 제1항에 따라 공고된 발전사업의 내용에 대하여 의견이 있는 자는 같은 항 제4호에 따른 의견제출 기간 및 방법에 따라 의견을 제출할 수 있다.

전기사업법 시행규칙

제4조(사업허가의 신청) ① 법 제7조제1항에 따라 전기사업의 허가를 신청하려는 자는 별지 제1호서식의 전기사업허가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다. 이하 같다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다. 이하 같다)를 첨부하여 산업통상자원부장관에게 제출해야 한다. 다만, 발전설비용량이 3천 킬로와트 이하인 발전사업의 허가를 받으려는 자는 특별시장·광역시장·별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)에게 제출해야 한다.

1. 별표 1의 작성방법에 따라 작성한 사업계획서. 이 경우 별표 1의2에 따른 서류를 첨부하여야 한다.
2. 정관, 재무상태표 및 손익계산서(신청자가 법인인 경우만 해당하며, 설립 중인 법인의 경우에는 정관만 제출한다)
3. 신청자(발전설비용량 3천킬로와트 이하인 신청자는 제외한다. 이하 이 호에서 같다)의 주주명부. 이 경우 신청자가 재무능력을 평가할 수 없는 신설법인인 경우에는 신청자의 최대주주를 신청자로 본다.
4. 「전기사업법 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제4조의2에 따른 의견수렴 결과(「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조에 따른 태양에너지 중 태양광, 풍력, 연료전지를 이용하는 발전사업인 경우만 해당한다)
5. 법 제7조의3제1항에 따라 의제받으려는 인·허가등에 관하여 해당 법률에서 정하는 관련 서류

제7조(허가의 심사기준) ①·② (생 략)

③ 법 제7조제5항제2호에 따른 전기사업이 계획대로 수행될 수 있는지에 대한 심사기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전기설비 건설 예정지역의 수용(受用) 정도가 높을 것
2. 별표 1 제1호바목부터 자목까지의 계획이 구체적이며 실현 가능할 것
3. 발전소를 적기에 준공하고, 발전사업을 지속적·안정적으로 운영할 수 있을 것

④·⑤ (생 략)

질의제목 4

▶ 안전번호 25-0241

민원인 - 전기안전관리업무를 대행하게 할 수 있는 전기설비의 규모(「전기안전관리법 시행규칙」 제26조제1호 등 관련)

01 질의요지

「전기안전관리법」 제22조제1항에서는 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 전기안전관리업무를 수행하게 하기 위하여 전기안전관리자를 선임해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항 본문에서는 같은 조 제1항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 규모 이하의 전기설비의 소유자 또는 점유자는 자본금, 기술인력 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 전기안전관리대행사업자(제2호) 등 같은 조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 전기안전관리업무를 대행하게 할 수 있다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제26조제1호에서는 같은 법 제22조제3항에 따라 전기안전관리대행사업자(이하 “대행사업자”라 함)가 전기안전관리업무를 대행할 수 있는 전기설비의 규모로 전기수용설비는 용량 1천킬로와트 미만인 것(가목), 그 밖의 발전설비¹⁾는 용량 300킬로와트(비상용 예비발전설비의 경우에는 500킬로와트) 미만인 것(라목) 등을 규정하고 있는바,

용량 800킬로와트의 전기수용설비와 용량 610킬로와트의 비상용 예비발전설비(이하 “이사안 전기설비”라 함)의 소유자는 「전기안전관리법」 제22조제3항 및 같은 법 시행규칙 제26조제1호에 따라 이 사안 전기설비 모두에 대하여 전기안전관리업무를 대행사업자에게 대행하게 할 수 있는지²⁾?

1) 전기사업용 신재생에너지 발전설비의 경우 원격감시·제어기능을 갖춘 것으로 한정함

2) 전기수용설비와 비상용 예비발전설비는 하나의 사업장에 설치된 것으로서 두 전기설비 모두에 대한 전기안전관리업무를 하나의 대행사업자에게 대행하게 하려는 경우를 전제로 함

02 회답

이 사안 전기설비의 소유자는 「전기안전관리법」 제22조제3항 및 같은 법 시행규칙 제26조제1호에 따라 이 사안 전기설비 모두에 대하여 전기안전관리업무를 대행사업자에게 대행하게 할 수 없습니다.

03 이유

먼저 「전기안전관리법」 제22조제1항에서는 전기사업자나 자가용전기설비의 소유자는 원칙적으로 전기설비에 대한 전기안전관리자를 선임하도록 규정하면서, 같은 조 제3항에서는 예외적으로 자가용전기설비와 신재생에너지 발전설비³⁾ 중 “산업통상자원부령으로 정하는 규모 이하의 전기설비”의 경우 같은 법 제30조에 따른 한국전기안전공사(제1호), 대행사업자(제2호), 개인대행자(제3호)에게 전기안전관리업무를 대행하게 할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제26조에서는 전기안전관리업무를 대행하는 자에 따라 전기안전관리업무를 대행할 수 있는 전기설비의 규모를 구분하여 정하면서, 같은 조 제1호에서는 한국전기안전공사 및 대행사업자가 대행이 가능한 전기설비의 규모를 용량 1천킬로와트 미만인 전기수용설비(가목), 용량 500킬로와트 미만인 비상용 예비발전설비(라목) 등의 전기설비를 규정하고 있는바, 「전기안전관리법 시행규칙」 제26조제1호 각 목에서는 대행사업자의 경우 전기안전관리업무를 대행이 가능한 전기설비의 규모를 전기수용설비, 신재생에너지 발전설비 중 태양광발전설비 등 전기설비의 종류별로 구분하여 규정하고 있어, 대행사업자가 여러 종류의 전기설비에 대한 전기안전관리업무를 모두 대행하려면 각각의 전기설비가 모두 같은 규칙 제26조제1호 각 목에서 규정하고 있는 전기설비의 종류별 규모 기준을 충족해야 할 것입니다.

그런데 이 사안 전기설비의 경우, 전기수용설비(용량 800킬로와트)는 「전기안전관리법 시행규칙」 제26조제1호가목에 따른 규모 기준인 “용량 1천킬로와트 미만인 것”을 충족하나, 비상용 예비발전설비(용량 610킬로와트)는 같은 호 라목에 따른 “용량 500킬로와트 미만인 것”이라는 규모 기준을 충족하지 않는바, 이 사안 전기설비에는 대행사업자가 대행할 수 없는 전기설비가 포함되어 있으므로, 그 소유자는 이 사안 전기설비 모두에 대하여 전기안전관리

3) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신에너지와 재생에너지를 이용하여 전기를 생산하는 발전설비를 말함

업무를 하나의 대행사업자에게 대행하게 할 수는 없다고 할 것입니다.

그리고 「전기안전관리법」은 전기재해의 예방과 전기설비 안전관리에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 생명과 재산을 보호하고 공공의 안전을 확보함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 제22조에서 전기사업자나 자가용전기설비 소유자 또는 점유자의 전기설비에 대한 전기안전관리자의 선임을 원칙으로 하면서(제1항), 일정한 규모 이하의 자가용전기설비의 경우 전기안전관리업무의 대행이 가능하도록 규정한 것은 일정한 규모 이하의 자가용전기설비의 경우 전기설비 관련 사고의 위험성이 상대적으로 낮으므로 전기안전관리자 선임에 대해서는 예외적으로 대행할 수 있도록 한 것으로 보이는데, 대행하게 하려는 여러 전기설비 중 일부는 같은 법 시행규칙 제26조제1호 각 목에 따른 규모 기준을 충족하고, 일부는 그 규모를 초과하여 기준을 충족하지 않는 경우에 전체 전기설비에 대하여 「전기안전관리법」 제22조제3항 및 같은 법 시행규칙 제26조제1호에 따라 전기안전관리업무를 대행하게 할 수 있다고 해석하는 것은 이러한 전기안전관리법령의 입법 목적 및 관련 규정의 취지에 부합하지 않습니다.

아울러 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데⁴⁾, 이 사안 전기설비 중 비상용 예비발전설비의 경우 「전기안전관리법 시행규칙」 제26조제1호라목의 규모 기준을 충족하지 못했음에도 불구하고 대행사업자에게 전기수용설비뿐만 아니라 비상용 예비발전설비에 대한 전기안전관리업무까지 일괄하여 대행하게 할 수 있다고 해석하는 경우, 같은 규칙 제26조제1호 각 목에 따른 규모 기준 중 하나만 충족하면 같은 호에 따른 기준을 충족하지 못하는 다른 전기설비의 규모와 관계없이 그 전체 전기설비에 대하여 대행이 가능하게 되는 결과가 초래되는바, 이는 일정 규모 이하의 전기설비에 대해서만 예외적으로 전기안전관리업무의 대행을 인정하고 있는 「전기안전관리법」 제22조제3항 및 같은 법 시행규칙 제26조를 합리적인 이유 없이 확대하여 해석하는 것으로 타당하지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안 전기설비의 소유자는 「전기안전관리법」 제22조제3항 및 같은 법 시행규칙 제26조제1호에 따라 이 사안 전기설비 모두에 대하여 전기안전관리업무를 대행사업자에게 대행하게 할 수 없습니다.

4) 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조



관계법령

전기안전관리법

제22조(전기안전관리자의 선임 등) ① 전기사업자나 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 전기설비(휴지 중인 전기설비는 제외한다)의 공사·유지 및 운용에 관한 전기안전관리업무를 수행하게 하기 위하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 「국가기술자격법」에 따른 전기·기계·토목 분야의 기술자격을 취득한 사람 중에서 각 분야별로 전기안전관리자를 선임하여야 한다.

② (생략)

③ 제1항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 규모 이하의 전기설비(자가용전기설비와 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신에너지와 재생에너지를 이용하여 전기를 생산하는 발전설비만 해당한다)의 소유자 또는 점유자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 전기안전관리업무를 대행하게 할 수 있고, 전기안전관리업무를 대행하는 자는 전기안전관리자로 선임된 것으로 본다. 다만, 제1호에 따른 안전공사는 격지, 오지 등 산업통상자원부령으로 정하는 지역으로서 산업통상자원부장관이 정하는 전기설비에 한정하여 대행할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

④ ~ ⑧ (생략)

전기안전관리법 시행규칙

제26조(전기안전관리업무를 대행규모) 법 제22조제3항에 따라 안전공사, 같은 항 제2호에 따른 전기안전관리대행사업자(이하 “대행사업자”라 한다) 및 같은 항 제3호에 따른 자(이하 “개인대행사”라 한다)가 전기안전관리업무를 대행할 수 있는 전기설비의 규모는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 안전공사 및 대행사업자: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전기설비(둘 이상의 전기설비 용량의 합계가 4천 500킬로와트 미만 경우로 한정한다)

가. 전기수용설비: 용량 1천킬로와트 미만인 것

나. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 신에너지와 재생에너지를 이용하여 전기를 생산하는 발전설비(이하 이 조에서 “신재생에너지 발전설비”라 한다) 중 태양광발전설비: 용량 1천킬로와트(원격감시·제어기능을 갖춘 경우 용량 3천킬로와트) 미만인 것

다. 전기사업용 신재생에너지 발전설비 중 연료전지발전설비(원격감시·제어기능을 갖춘 것으로 한정한다): 용량 500킬로와트 미만인 것

라. 그 밖의 발전설비(전기사업용 신재생에너지 발전설비의 경우 원격감시·제어기능을 갖춘 것으로 한정한다): 용량 300킬로와트(비상용 예비발전설비의 경우에는 용량 500킬로와트) 미만인 것

2. (생략)

제2절 중소기업

질의제목 1

▶ 안전번호 24-0935

민원인 - 경영지도사가 자격증 또는 등록증에 기재되어 있는 전문분야 업무 외에 다른 전문분야 업무를 수행할 수 있는지 여부(「경영지도사 및 기술지도사에 관한 법률」 제2조제2항 등 관련)

01 질의요지

「경영지도사 및 기술지도사에 관한 법률」(이하 “경영기술지도사법”이라 함) 제2조제1항에서 경영지도사 및 기술지도사는 중소기업에 경영 및 기술에 대한 전문적이고 종합적인 진단·지도를 수행하는 것을 그 업무로 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서 경영지도사의 전문분야 및 그 업무는 같은 항 각 호와 같다고 규정하면서, 같은 항 각 호에서는 인적자원관리(제1호), 재무관리(제2호), 생산관리(제3호), 마케팅관리(제4호) 등을 규정하고 있는바,

경영지도사가 자격증¹⁾ 또는 등록증²⁾에 기재되어 있는 전문분야 업무 외에 다른 전문분야 업무를 수행할 수 있는지?

02 회답

경영지도사가 자격증 또는 등록증에 기재된 전문분야 업무 외에 다른 전문분야 업무도 수행할 수 있습니다.

1) 경영기술지도사법 시행령 제3조제6항 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따른 경영지도사 자격증을 말하며, 이하 같음

2) 경영기술지도사법 시행령 제7조제2항, 같은 법 시행규칙 제4조에 따른 경영지도사 등록증을 말하며, 이하 같음

03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 합니다³⁾.

경영기술지도사법 제2조제1항에서 경영지도사는 중소기업에 경영 및 기술에 대한 전문적이고 종합적인 진단·지도를 수행하는 것을 그 업무로 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서 경영지도사의 전문분야 및 그 업무로 인적자원관리 분야는 인사, 조직, 노무, 사무관리의 진단·지도(제1호), 재무관리 분야는 재무관리와 회계의 진단·지도(제2호), 생산관리 분야는 생산, 품질관리의 진단·지도(제3호) 등을 구체적으로 규정하고 있을 뿐, 경영기술지도사법령에서 경영지도사의 업무를 전문분야별로 한정하여 수행하도록 하거나 경영지도사가 본인의 전문분야가 아닌 다른 전문분야 업무를 수행하는 경우를 금지하는 등의 규정을 별도로 두고 있지 않은바, 이러한 경영기술지도사법령의 규정 체계에 비추어 보면, 경영지도사는 본인의 전문분야에 관한 업무만을 수행할 수 있는 것은 아니고, 본인의 전문분야 업무 외에 다른 전문분야 업무도 수행할 수 있다 할 것입니다.

그리고 경영기술지도사법령에서는 경영지도사가 아닌 자가 경영기술지도사법 제2조에서 규정하고 있는 경영지도사 업무를 업으로 행하는 것을 제한하고 있지 않으므로⁴⁾ 경영지도사가 아닌 자도 경영지도사의 업무를 수행할 수 있는데, 만약 경영지도사가 자격증 또는 등록증에 기재되어 있는 본인의 전문분야 외에 다른 전문분야의 업무를 수행할 수 없다고 해석하게 된다면 경영지도사 자격이 있는 자가 경영지도사 자격이 없는 자에 비해 일정 분야의 경영지도사 업무 수행을 할 수 없는 불합리한 결과를 초래하게 되고, 경영지도사자격시험 과목에는 전문분야 과목 외에도 공통적으로 중소기업 관계 법령, 회계학개론, 경영학, 기업진단론 등 기업이나 경영에 관한 과목이 포함되어 있어⁵⁾ 경영지도사 자격을 가진 자는 중소기업 경영 등에 대한 전반적인 지식을 갖고 있다고 볼 수 있는바, 경영지도사는 그 전문분야가 아니더라도 경영기술지도사법 제2조에 따른 경영지도사의 업무를 수행할 수 있다고 할 것입니다.

3) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

4) 헌법재판소 2020. 5. 12. 결정 2020헌마632 결정례, 헌법재판소 2020. 4. 21. 결정 2020헌마546 결정례, 법제처 2020. 7. 14. 회신 20-0321 해석례 등 참조

5) 경영지도사법 시행령 별표 2 참조

한편 경영기술지도사법이 제정되기 전 경영지도사에 관한 내용을 규정하고 있었던 구 「중소기업진흥에 관한 법률」(2020년 4월 7일 법률 제17242호로 타법개정되기 전의 것을 말하며, 이하 “구 중소기업진흥법”이라 함)과 다르게 경영기술지도사법에서는 경영지도사의 업무를 전문분야별로 구분하여 규정하고 있으므로 경영지도사는 본인의 전문분야에 해당하는 업무만 수행할 수 있다는 의견이 있으나, 경영기술지도사법은 경영과 기술에 대한 전문적이고 종합적인 진단·지도를 수행하는 경영·기술 지도사 제도를 확립하기 위해 구 중소기업진흥법에서 규정하고 있었던 경영·기술 지도사 관련 내용을 분리하여 별도의 법률로 제정된 것으로⁶⁾, 경영기술지도사법에서 규정하고 있는 경영지도사의 업무 영역은 구 중소기업진흥법과 다르지 않고⁷⁾, 경영지도사의 업무는 경영지도사 자격제도가 도입된 이래 자격 취득 여부와 상관없이 누구나 해당 업무를 수행할 수 있는 비독점적 자격 형태로 운영되어 왔으며⁸⁾, 경영기술지도사법령에서 경영지도사의 업무가 전문분야로 제한된다는 명문의 규정도 두고 있지 않다는 점에서, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 경영지도사가 자격증 또는 등록증에 기재된 전문분야 업무 외에 다른 전문분야 업무도 수행할 수 있습니다.



관계법령

경영지도사 및 기술지도사에 관한 법률

제2조(업무) ① 경영지도사 및 기술지도사(이하 “지도사”라 한다)는 중소기업에 경영 및 기술에 대한 전문적이고 종합적인 진단·지도를 수행하는 것을 그 업무로 한다.

② 경영지도사의 전문분야 및 그 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 인적자원관리: 인사, 조직, 노무, 사무관리의 진단·지도
2. 재무관리: 재무관리와 회계의 진단·지도
3. 생산관리: 생산, 품질관리의 진단·지도
4. 마케팅관리: 유통·판매관리 및 수출입 업무의 진단·지도
5. 제1호부터 제4호까지와 관련된 상담, 자문, 조사, 분석, 평가, 확인
6. 제1호, 제3호 및 제4호와 관련된 업무의 대행(중소기업 관계 법령에 따라 기관에 하는 신고, 신청, 진술, 보고 등의 행위를 말한다)

③ 기술지도사의 전문분야 및 그 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 기술혁신관리: 기술경영, 연구개발, 기술고도화의 진단·지도

6) 2020. 4. 7. 법률 제17242호로 제정되어 2021. 4. 8. 시행된 경영기술지도사법 개정이유서 참조

7) 헌법재판소 2020. 5. 12. 결정 2020헌마632 결정례 참조

8) 법제처 2020. 7. 14. 회신 20-0321 해석례 참조

2. 정보기술관리: 정보통신, 시스템응용, 소프트웨어의 진단·지도
3. 제1호 및 제2호와 관련된 상담, 자문, 조사, 분석, 평가, 확인, 증명 및 업무의 대행(중소기업 관계 법령에 따라 기관에 하는 신고, 신청, 진술, 보고 등의 대행을 말한다)
- ④ 제2항제6호 및 제3항제3호에 따른 중소기업 관계 법령은 중소벤처기업부 소관 법령 등 중소기업의 경영 또는 기술과 관련된 법령으로서 그 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다.

질의제목 2

▶ 안전번호 25-0050

민원인 - 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제12조제3항에서 규정하고 있는 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사”의 의미(「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제12조제3항 등 관련)

01 질의요지

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 함) 제12조 제2항에서는 중소벤처기업부장관은 경쟁제품¹⁾ 중에서 공공기관이 발주하는 공사에 필요한 자재로서 공사의 품질과 효율성을 해치지 아니하는 범위에서 공공기관이 직접 구매하여 제공하기에 적합한 제품을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 선정하고, 고시하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항 본문에서는 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사”를 발주하려는 공공기관의 장은 같은 조 제2항에 따라 중소벤처기업부장관이 고시한 제품(이하 “직접구매 대상품목”이라 함)의 직접구매 여부를 검토하여 직접구매를 할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제11조 제1항에서는 같은 법 제12조제3항 본문에서 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사”란 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 종합공사²⁾를 시공하는 업종³⁾에 해당하는 공사인 경우에는 공사 추정가격이 40억원 이상인 공사를 말한다고 규정하고 있는바,

공공기관이 발주한 공사가 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 종합공사를 시공하는 업종에 해당하는 수개의 공사가 복합된 종합공사인 경우⁴⁾, 판로지원법 제12조제3항 본문에 따른 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사”에 해당하는지 여부를 판단할 때 발주한 전체 공사를 대상으로 판단하여야 하는지, 아니면 각각의 업종별 공사를 대상으로 판단하여야 하는지?

- 1) 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품 중 중소벤처기업부장관이 지정한 중소기업자간 경쟁 제품을 의미하며(판로지원법 제6조제1항 참조), 이하 같음
- 2) “종합공사”란 종합적인 계획, 관리 및 조정을 하면서 시설물을 시공하는 건설공사를 말하며(「건설산업기본법」 제2조제5호 참조), 이하 같음
- 3) 토목공사업, 건축공사업, 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업, 조경공사업
- 4) 공공기관이 발주한 공사는 한 건의 종합공사로서 공공기관과 수급인 사이에 해당 종합공사에 관하여 한 건의 계약이 체결되었음을 전제함

02 회답

이 사안의 경우, 판로지원법 제12조제3항 본문에 따른 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사”에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 발주한 전체 공사를 대상으로 판단하여야 합니다.

03 이유

먼저 판로지원법 제12조제3항 본문에서는 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사”를 발주하려는 공공기관의 장은 직접구매 대상품목의 직접구매 여부를 검토하여 직접구매를 할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제11조제1항에서 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사”란 종합공사를 시공하는 업종에 해당하는 공사인 경우에는 공사 추정가격이 40억원 이상인 공사를 말하고, 전문공사⁵⁾를 시공하는 업종에 해당하는 공사, 전기공사, 정보통신공사 또는 소방시설공사 등인 경우에는 공사 추정가격이 3억원 이상인 공사를 말한다고 규정하고 있는바, 이러한 내용을 종합하면 공공기관이 발주한 하나의 공사가 추정가격이 40억원 이상인 종합공사이거나 추정가격이 3억원 이상인 전문공사 등 비종합공사인 경우는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사에 해당된다고 할 것이고, 같은 법 제12조제3항에 따른 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사”를 판단할 때 공공기관이 발주한 하나의 종합공사를 다시 토목공사업, 건축공사업, 조경공사업 등 업종별로 구분하고 해당 업종별 공사의 추정가격으로 그 규모를 판단한다는 취지의 규정도 두고 있지 않으므로, 이 사안과 같이 공공기관이 발주한 공사가 종합공사에 해당한다면 발주한 전체 공사를 대상으로 그 공사 추정가격이 40억원 이상인 경우 대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사에 해당된다고 할 것입니다.

그리고 판로지원법은 중소기업제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원함으로써 중소기업의 경쟁력 향상과 경영안정에 이바지함을 목적으로 하는(제1조) 법률로서, 같은 법 제12조에서 규정하고 있는 공사용 자재의 직접구매제도는 공공기관이 발주하는 대규모 공사에 필요한 자재에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 공공기관이 직접 구매하도록 함으로써 중소기업 제품의 구매를 확대하여 중소기업의 경영안정을 지원하기 위한 것인데⁶⁾, 만약 공공기관이

5) “전문공사”란 시설물의 일부 또는 전문 분야에 관한 건설공사를 의미하며(「건설산업기본법」 제2조제6호 참조), 이하 같음

6) 2004. 12. 31. 법률 제7285호로 일부개정된 중소기업진흥및제품구매촉진에관한법을 주요내용 및 청구지방법원 2010. 3. 9.자 2010카합44 결정례 참조

발주한 하나의 종합공사를 각각의 업종별 공사로 나누어 개별적으로 판단하게 되면 하나의 종합공사에서 분리된 각각의 업종별 공사가 40억원 이상인 공사에 해당하지 않게 될 가능성이 높아져 직접구매에 필요한 조치를 하지 않을 수 있게 되어 직접구매제도의 실효성을 확보하기 어렵게 될 우려가 있는바, 같은 조 제3항에서 규정하고 있는 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사”에 해당하는지 여부는 발주한 전체 공사를 대상으로 판단하는 것이 중소기업 제품 구매 확대에 기여하여 중소기업의 경영안정을 도모하려는 규정의 취지에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 판로지원법 제12조제3항 본문에 따른 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사”에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 발주한 전체 공사를 대상으로 판단하여야 합니다.



관계법령

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

제12조(공사용 자재의 직접구매 증대) ① 중소벤처기업부장관은 경쟁제품으로 지정된 공용 자재의 구매를 늘리기 위하여 필요한 조치를 할 수 있다.

② 중소벤처기업부장관은 경쟁제품 중에서 공공기관이 발주하는 공사에 필요한 자재로서 공사의 품질과 효율성을 해치지 아니하는 범위에서 공공기관이 직접 구매하여 제공하기에 적합한 제품을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 선정하고, 고시하여야 한다.

③ 대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사를 발주하려는 공공기관의 장은 제2항에 따라 중소벤처기업부장관이 고시한 제품의 직접구매 여부를 검토하여 직접구매를 할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 중소벤처기업부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 직접구매를 이행할 수 없는 사유로 고시한 경우에는 그러하지 아니하다.

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령

제11조(공사용 자재의 직접구매 증대 등) ① 법 제12조제3항 본문에서 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 공사”란 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 종합공사를 시공하는 업종에 해당하는 공사인 경우에는 공사 추정가격이 40억원 이상인 공사를 말하고, 같은 법 시행령 별표 1에 따른 전문공사를 시공하는 업종에 해당하는 공사, 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사 또는 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사 등인 경우에는 공사 추정가격이 3억원 이상인 공사를 말한다.

② 공공기관의 장이 제1항에 따른 공사를 발주하는 경우 법 제12조제2항에 따라 중소벤처기업부장관이 선정하여 고시한 품목(이하 “직접구매 대상품목”이라 한다)의 구매는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1.·2. (생 략)

CHAPTER

3

교육·여성가족·
문화체육관광

제1절 교육

제2절 여성가족·청소년

제3절 문화체육관광

제1절 교육

질의제목 1 ▶ 안전번호 24-0921

민원인 - 학교의 장이 소속 학교에 학교운동부를 반드시 구성해야 하는지 여부(「학교체육 진흥법」 제6조제1항제3호 등 관련)

01 질의요지

「학교체육 진흥법」 제2조제3호에서는 “학교운동부”란 학생선수¹⁾로 구성된 학교²⁾ 내 운동부를 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제6조제1항 각 호 외의 부분에서는 학교의 장은 학생의 체력증진과 체육활동 활성화를 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 제3호에서는 같은 법 제10조에 따른 학교스포츠클럽 및 같은 법 제11조에 따른 학교운동부 운영을 규정하고 있는바,

학교의 장은 「학교체육 진흥법」 제6조제1항제3호에 따라 소속 학교에 학교운동부를 반드시 구성해야 하는지?

02 회답

학교의 장은 「학교체육 진흥법」 제6조제1항제3호에 따라 소속 학교에 학교운동부를 반드시 구성해야 하는 것은 아닙니다.

1) 학교운동부에 소속되어 운동하는 학생이나 「국민체육진흥법」 제33조와 제34조에 따른 체육단체에 등록되어 선수로 활동하는 학생을 말하며(「학교체육 진흥법」 제2조제4호 참조), 이하 같음.

2) 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교를 말하며(「학교체육 진흥법」 제2조제2호 참조), 이하 같음.

03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 하는바³⁾, 학교의 장이 「학교체육 진흥법」 제6조제1항제3호에 따라 소속 학교에 학교운동부를 반드시 구성해야 하는지 여부는 문언의 형식적인 표현 외에도 관련 법령의 규정체계 및 입법취지 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 조화롭게 해석할 필요가 있습니다.

먼저 「학교체육 진흥법」 제2조제3호에서 “학교운동부”에 대하여 별도로 정의하고 있음에도 불구하고, 같은 법 제6조제1항제3호에서는 학교의 장이 취하여야 하는 조치사항 중 하나로 “제11조에 따른 학교운동부 운영”이라고 규정하여 같은 법 제11조를 인용하여 규정하고 있는데, 같은 법 제11조에서는 “학교운동부 운영 등”이라는 조 제목 하에 최저학력에 미달하는 학생선수의 경기대회 참가 제한(제1항), 학생선수에 대한 기초학력보장 프로그램의 제공(제2항), 상시 합숙훈련의 근절 노력(제4항), 학교운동부 관련 후원금의 학교회계 편입(제5항) 등에 관한 사항을 규정하고 있어, 이미 학생선수나 학교운동부가 있는 것을 전제로 학생선수 등의 관리 및 편의제공에 대한 내용을 규정하고 있고, 학교의 장으로 하여금 소속 학교에 학교운동부를 반드시 구성하여 운영하도록 하는 취지의 규정을 별도로 두고 있지 않은 점 등을 고려하면, 같은 법 제6조제1항제3호는 학교에 학교운동부가 구성된 경우 그 학교의 장이 같은 법 제11조에 규정된 학교운동부의 운영에 관한 조치를 취하도록 하려는 것이지, 모든 학교의 장이 소속 학교에 학교운동부를 반드시 구성·운영하도록 하려는 취지는 아니라 할 것입니다.

그리고 「학교체육 진흥법」 제6조제1항에 따라 학교의 장이 조치해야 하는 내용을 살펴보면, 학교의 장은 소속 학교의 체육교육과정 운영 충실 및 체육수업의 질 제고(제1호), 학생선수의 학습권 보장 및 인권보호(제4호), 유아 및 장애학생의 체육활동 활성화(제6호) 등의 조치를 취하여야 하는데, 같은 조 제2항에서는 학교의 장으로 하여금 같은 조 제1항에 따른 조치를 시행하기 위하여 필요한 경비를 예산의 범위에서 확보하도록 규정하여 학교의 장이 해당 조치를 취할 때 예산을 고려할 수 있도록 하고 있는 등 해당 규정의 내용이나 효력은

3) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례

포괄적·추상적인 성격을 가지고 있다고 볼 것⁴⁾이므로, 같은 법 제6조만으로는 학교의 장이 학생의 체력증진과 체육활동 활성화를 위하여 취하여야 하는 조치의 구체적인 방법까지 정하였다고 보기는 어렵습니다.

아울러 「초·중등교육법」 제31조제1항에서는 학교운영의 자율성을 높이고 지역의 실정과 특성에 맞는 다양하고도 창의적인 교육을 할 수 있도록 초등학교·중학교·고등학교 등 각종 학교에 학교운영위원회를 구성·운영해야 한다고 규정하면서, 같은 법 제32조제1항제12호에서는 학교에 두는 학교운영위원회의 심의사항 중 하나로 “학교운동부의 구성·운영”을 규정하고 있는데, 이는 교원 대표, 학부모 대표 및 지역사회 인사로 구성된 학교운영위원회에서 학교운동부의 구성·운영에 관한 사항을 심의하도록 함으로써 학교의 자율성을 확대하고, 해당 학교의 구체적인 실정에 맞게 학교운동부 제도를 운용할 수 있도록 한 것인바⁵⁾, 학교운동부의 구성에 대해서는 해당 학교의 장이 예산 상황, 훈련 장소 및 시설 확보 여부, 학생선수의 현황 등 해당 학교의 상황과 여건 등을 종합적으로 고려하여 학교운영위원회의 심의를 거쳐 판단할 수 있는 사항이라는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 학교의 장은 「학교체육 진흥법」 제6조제1항제3호에 따라 소속 학교에 학교운동부를 반드시 구성해야 하는 것은 아닙니다.



관계법령

학교체육 진흥법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 2. (생략)
3. “학교운동부”란 학생선수로 구성된 학교 내 운동부를 말한다.
4. ~ 8. (생략)

제6조(학교체육 진흥의 조치 등) ① 학교의 장은 학생의 체력증진과 체육활동 활성화를 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 2. (생략)
3. 제10조에 따른 학교스포츠클럽 및 제11조에 따른 학교운동부 운영
4. ~ 10. (생략)

4) 법제처 2008. 2. 28. 회신 07-0471 해석례 참조

5) 법제처 2021. 4. 19. 회신 21-0004 해석례 참조

②·③ (생 략)

제10조(학교스포츠클럽 운영) ① 학교의 장은 학생들이 신체활동 프로그램에 참여할 수 있도록 학교스포츠클럽을 운영하여 학생들의 체육활동 참여기회를 확대하여야 한다.

② 학교의 장은 제1항에 따라 학교스포츠클럽을 운영하는 경우 학교스포츠클럽 전담교사를 지정하여야 한다.

③ 제2항에 따른 학교스포츠클럽 전담교사에게는 학교 예산의 범위에서 소정의 지도수당을 지급한다.

④ 학교의 장은 학교스포츠클럽 활동내용을 학교생활기록부에 기록하여 상급학교 진학자료로 활용할 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 학교의 장은 교육부령으로 정하는 바에 따라 일정 비율 이상의 학교스포츠클럽을 해당 학교의 여학생들이 선호하는 종목의 학교스포츠클럽으로 운영하여야 한다.

제11조(학교운동부 운영 등) ① 학교의 장은 학생선수가 일정 수준의 학력기준(이하 “최저학력”이라 한다)에 도달하지 못한 경우에는 교육부령으로 정하는 경기대회의 참가를 허용하여서는 아니 된다. 다만, 학생선수가 제2항에 따른 기초학력보장 프로그램을 이수한 경우에는 그 참가를 허용하여야 한다.

② 학교의 장은 최저학력에 도달하지 못한 학생선수에게 별도의 기초학력보장 프로그램을 제공하여야 한다.

③ 최저학력의 기준 및 실시 시기에 필요한 사항과 기초학력보장 프로그램의 운영 등에 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

④ 학교의 장은 학생선수의 학습권 보장 및 신체적·정서적 발달을 위하여 학기 중의 상시 합숙훈련이 근절될 수 있도록 노력하여야 한다. 다만, 경기대회 참가 등을 위하여 불가피하게 합숙훈련을 실시하는 경우에는 학생선수의 안전 및 인권보호를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 학교의 장은 원거리에서 통학하는 학생선수를 위하여 기숙사를 운영할 수 있다. 이 경우 필요한 사항은 교육부령으로 정한다.

⑥ 학교의 장은 학교운동부 관련 후원금을 「초·중등교육법」 제30조의2에 따라 설치된 학교회계에 편입시켜 운영하여야 한다.

⑦ 국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 학교운동부 운영과 관련된 경비를 지원할 수 있다

질의제목 2

▶ 안전번호 25-0101

교육부 - 전문대학을 졸업한 사람으로서 25세 이상이거나 산업체 근무 경력이 2년 이상인 사람이 전문대학의 학사학위가 수여되는 전공심화과정의 연도별 총학생수와 별도로 입학할 수 있는지 (「고등교육법 시행령」 제29조제2항 등 관련)

01 질의요지

「고등교육법」 제32조에서는 전문대학 등 대학¹⁾의 학생 정원에 관한 사항은 대통령령으로 정하는 범위에서 학칙으로 정하도록 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제28조제1항 본문에서는 같은 법 제32조에 따른 대학의 학생정원은 입학정원을 기준으로 하여 학칙이 정하는 모집단위별로 학칙으로 정하되, 「대학설립·운영규정」에 따른 교사, 교지, 교원 및 수익용 기본재산에 따라 정해지는 학생 수의 범위에서 정하여야 한다고 규정하고 있으며, 「고등교육법 시행령」 제29조제2항 전단에서는 같은 항 각 호의 사람의 입학의 경우에는 같은 영 제28조제1항에도 불구하고 그 정원이 따로 있는 것으로 본다고 규정하면서, 같은 영 제29조제2항제12호에서는 전문대학²⁾에 입학하는 25세 이상인 자 또는 산업체 근무 경력이 2년 이상 있는 자를, 같은 항 제13호에서는 같은 법 제50조의2 및 제54조의2에 따라 학사학위가 수여되는 전공심화과정(이하 “학위심화과정”이라 함)에 입학하는 자를 각각 규정하고 있고,

「고등교육법 시행령」 제29조제2항 후단에서는 같은 항 제12호·제13호 등에 해당하는 사람의 총학생수는 별표 1의 기준을 따른다고 규정하면서, 같은 영 별표 1 제6호에서는 같은 영 제29조제2항제12호에 해당하는 자에 대하여 학년별·연도별 총학생수의 제한을 두지 않고 있고, 같은 표 제7호에서는 같은 영 제29조제2항제13호에 해당하는 자의 연도별 총학생수는 해당 연도 입학정원의 100분의 20을 초과할 수 없다고 규정하고 있는바,

「고등교육법 시행령」 제29조제2항제12호에 따른 25세 이상인 자 또는 산업체 근무 경력이 2년 이상 있는 자가 「고등교육법」 제50조의2에 따른 전문대학의 학위심화과정에 입학하는 경우³⁾, 전문대학의 장은 같은 영 별표 1 제7호에 따른 학위심화과정의 연도별 총학생수의

1) 산업대학·교육대학·전문대학·원격대학·기술대학 및 각종학교를 포함함

2) 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권에 소재하는 전문대학은 제외하며, 이하 같음

3) 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권에 소재하는 전문대학이 아닌 전문대학에 입학하는 경우를 전제로 함

범위에서 입학할 수 있는지, 아니면 학위심화과정의 연도별 총학생수와 별도로 입학할 수 있는지?

02 회답

이 사안의 경우, 전문대학의 장은 「고등교육법 시행령」 별표 1 제7호에 따른 학위심화과정의 연도별 총학생수와 별도로 입학할 수 있습니다.

03 이유

「고등교육법 시행령」 제28조제1항 본문에서는 「고등교육법」 제32조에 따른 대학의 학생정원은 입학정원을 기준으로 하여 모집단위별로 학칙으로 정하되, 「대학설립·운영 규정」에 따른 교사, 교지, 교원 및 수익용 기본재산에 따라 정해지는 학생수의 범위에서 정하여야 한다고 규정하고 있고, 「고등교육법 시행령」 제29조제2항제12호에 따른 전문대학에 입학하는 25세 이상인 자 또는 산업체 근무 경력이 2년 이상 있는 자(이하 “25세 이상인 자등”이라 함), 「고등교육법 시행령」 제29조제2항제13호에 따른 학위심화과정에 입학하는 자의 경우에는 같은 영 제28조제1항 본문에도 불구하고 그 정원이 따로 있는 것으로 보되, 같은 영 별표 1의 기준을 따른다고 규정하고 있으며, 같은 표 제6호에서는 25세 이상인 자등의 연도별 총 학생수에 대해서는 제한을 두지 않은 반면, 같은 표 제7호에서는 학위심화과정에 입학하는 연도별 총 학생수는 해당 연도 입학정원의 100분의 20을 초과할 수 없고, 모집단위별 총 학생수는 해당 모집단위의 입학정원을 초과할 수 없다고 규정하고 있는바, 이 사안은 「고등교육법 시행령」 제29조제2항제12호에 따른 25세 이상인 자등이 「고등교육법」 제50조의2에 따른 학위심화과정에 입학하려는 경우, 전문대학의 장이 같은 영 별표 1 제7호에서 정하고 있는 학위심화과정의 연도별 총학생수와 별도로 입학할 수 있는지가 문제가 됩니다.

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원하여, 위와 같은

법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 하는바⁴⁾, 이 사안과 같이 입학정원의 학년별·연도별 총학생수의 제한이 없는 25세 이상인 자등에 대해 학위심화과정의 연도별 총학생수와 별도로 입학할 수 있는지 여부는 문언의 형식적인 표현 외에도 해당 규정의 입법취지와 입법연혁 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 조화롭게 해석할 필요가 있습니다⁵⁾.

먼저 「고등교육법 시행령」 제29조제2항제12호에서는 25세 이상인 자등의 입학의 경우에는 같은 영 제28조제1항에도 불구하고 그 정원이 따로 있는 것으로 본다고 규정하면서, 25세 이상인 자등의 총학생수는 별표 1의 기준에 따른다고 규정하고 있는데, 이처럼 25세 이상인 자등을 정원 외로 입학할 수 있도록 한 취지는 같은 영 제28조제1항에 따른 학생정원의 예외를 인정함으로써 25세 이상인 자 또는 이미 전문대학을 졸업한 성인 재직자로서 계속교육을 희망하는 자 등 평생직업교육을 필요로 하는 다양한 교육수요 계층에게 고등교육의 기회를 폭넓게 보장하기 위한 것으로서, 특히 직업교육을 희망하는 성인 학습자의 학습 기회를 확대하기 위하여 종전의 「고등교육법 시행령」(2024년 2월 20일 대통령령 제34227호로 일부개정되기 전의 것을 말함) 별표 1 제6호에서 25세 이상인 자등에 대해 입학정원의 100분의 5 이하로 하도록 상한을 두던 것을 현행과 같이 상한을 폐지하는 것으로 개정하여 학년별·연도별 총학생수의 제한 없이 입학할 수 있도록 하였습니다⁶⁾.

그런데 「고등교육법 시행령」 제29조제2항 후단 및 제13호에서는 학위심화과정에 입학하는 연도별 총학생 수는 별표 1 제7호에 따라 해당 연도 입학정원의 100분의 20을 초과할 수 없고, 모집단위별 총학생수는 해당 모집단위의 입학정원을 초과할 수 없다고 규정하고 있는데, 이러한 학위심화과정을 둔 취지는 전문대학 졸업자의 직무능력을 제고하고 계속 교육의 기회를 확대하기 위한 것으로서⁷⁾, 전문대학과 4년제 대학을 구분하는 현행 학제의 기본 체계를 유지하기 위하여 그 모집인원을 일정 범위 내로 제한한 것이어서⁸⁾, 고등교육법령의 입법 연혁 및 학위심화과정을 둔 취지 등을 종합적으로 고려하면, 학위심화과정의 학생모집에서 25세 이상인 자등의 입학정원의 예외를 제한하려는 취지로 보이지는 않는다고 할 것인바, 이 사안과 같이 25세 이상인 자등의 경우에는 입학정원의 학년별·연도별 총학생수의 제한 없이 학위심화과정의 연도별 총학생수와 별도로 입학할 수 있다고 할 것입니다.

4) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 등 참조

5) 법제처 2023. 2. 14. 회신 22-0786 해석례 등 참조

6) 2024. 2. 20. 대통령령 제34227호로 일부개정된 「고등교육법 시행령」에 대한 입법예고안 참조

7) 2006. 11. 13. 의안번호 제175351호로 발의된 고등교육법 일부개정법률안에 대한 국회 교육위원회 검토보고서 참조

8) 2007. 11. 15. 대통령령 제20382호로 일부개정된 「고등교육법 시행령」 개정이유 및 주요내용 참조

아울러 「고등교육법」은 「교육기본법」 제9조에 따라 고등교육에 관한 사항을 정하고 있는 법률인데, 「교육기본법」 제3조에서는 모든 국민은 평생에 걸쳐 학습하고, 능력과 적성에 따라 교육 받을 권리를 가진다고 규정하고 있고, 같은 법 제4조에서는 모든 국민은 성별, 종교, 신념, 인종, 사회적 신분, 경제적 지위 또는 신체적 조건 등을 이유로 교육에서 차별을 받지 아니하도록 규정하고 있는바, 교육 관계 법령을 해석할 때에는 국민의 학습권과 균등한 교육기회를 충분히 보장하는 방향으로 해석할 필요가 있는 점, 「고등교육법 시행령」 별표 1 제6호에 따르면 25세 이상인 자등의 경우에도 같은 영 제28조제3항제1호(교원의 양성과 관련되는 모집단위별 정원) 및 제2호(의료인, 의료기사, 약사 및 한약사, 수의사에 해당하는 인력의 양성과 관련되는 모집단위별 정원)에 해당하는 모집단위별 총학생수는 교육부장관이 정하도록 규정하고 있어, 모집단위별 총학생수의 제한을 통해 정원 외 특별전형 총학생수를 규율할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 전문대학의 장은 「고등교육법 시행령」 별표 1 제7호에 따른 학위심화과정의 연도별 총학생수와 별도로 입학할 수 있습니다.

법령정비 권고사항

「고등교육법 시행령」 제29조제2항제12호에 따른 전문대학에 입학하는 25세 이상인 자 또는 산업체 근무 경력이 2년 이상 있는 자가 「고등교육법」 제50조의2에 따른 학사학위가 수여되는 전공심화 과정에 입학하는 경우, 「고등교육법 시행령」 제29조제2항제13호에 따른 학사학위가 수여되는 전공심화과정의 연도별 총학생수와 별도로 입학할 수 있는지 여부에 대하여 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

고등교육법

제49조(전공심화과정) 전문대학을 졸업한 사람의 계속교육을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 전문대학에 전공심화과정을 설치·운영할 수 있다.

제50조의2(전공심화과정에 대한 학위수여) ① 제49조에 따른 전공심화과정에 입학하여 학칙으로 정하는 과정을 이수한 사람에게는 학사학위를 수여할 수 있다.

② 제1항에 따라 학사학위가 수여되는 전공심화과정을 설치·운영하려는 자는 교육부장관의 인가를 받아야 한다.

③ ~ ⑦ (생 략)

고등교육법 시행령

제29조(입학·편입학 등) ① (생 략)

② 다음 각 호의 사람의 입학의 경우에는 제28조제1항에도 불구하고 그 정원이 따로 있는 것으로 본다.
이 경우 제2호·제3호·제8호·제9호·제11호·제12호·제13호 또는 제14호에 해당하는 사람의
총학생수는 별표 1의 기준을 따른다.

1. ~ 11. (생 략)

12. 전문대학(「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권에 소재하는 전문대학은 제외한다)에
입학하는 25세 이상인 자 또는 산업체 근무 경력이 2년 이상 있는 자

13. 법 제50조의2 및 제54조의2에 따라 학사학위가 수여되는 전공심화과정에 입학하는 자

14. ~ 16. (생 략)

③ ~ ⑦ (생 략)

제2절

여성가족·청소년

질의제목 1

▶ 안전번호 25-0067

여성가족부 - 국가 및 지방자치단체는 「청소년복지 지원법」 제5조제3항에 따라 생리용품의 이용권을 통해 생리용품과 함께 생리용품을 담을 봉투를 지원할 수 있는지 여부(「청소년복지 지원법」 제5조제3항 등 관련)

01 질의요지

「청소년복지 지원법」(이하 “청소년복지법”이라 함) 제5조제3항에서는 국가 및 지방자치단체는 여성청소년의 건강한 성장을 위하여 여성청소년이 생리용품을 신청하는 경우 이를 지원한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 생리용품 지원의 기준·범위, 방법, 신청 및 지급절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제3조의2제2항에서는 국가 및 지방자치단체는 여성청소년에게 생리용품을 직접 지급하거나 생리용품의 이용권을 지급할 수 있다고 규정하고 있는바,

국가 및 지방자치단체는 청소년복지법 제5조제3항에 따라 생리용품의 이용권을 통해 생리용품을 지원하는 경우, 생리용품과 함께 생리용품을 담을 봉투도 지원할 수 있는지¹⁾?

02 회답

국가 및 지방자치단체는 청소년복지법 제5조제3항에 따라 생리용품의 이용권을 통해 생리용품을 지원하는 경우, 생리용품과 함께 생리용품을 담을 봉투도 지원할 수 있습니다.

1) 생리용품을 이용할 수 있도록 금액이 기재된 증표(바우처카드)를 통해 그 금액의 범위 내에서 생리용품과 함께 생리용품을 담을 봉투까지 구매하는 경우를 전제로 함

03 이유

청소년복지법 제5조제3항에서는 국가 및 지방자치단체는 여성청소년의 건강한 성장을 위하여 여성청소년이 생리용품을 신청하는 경우 이를 지원한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 생리용품 지원의 기준·범위, 방법, 신청 및 지급절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제3조의2제2항에서는 국가 및 지방자치단체는 여성청소년에게 생리용품을 직접 지급하거나 생리용품의 이용권을 지급할 수 있다고 규정하고 있는바, 청소년복지법 제5조제3항에 따라 지원하는 생리용품에 대해서는 문언뿐만 아니라 입법연혁, 제도의 취지 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 조화롭게 해석할 필요가 있습니다.

먼저 청소년복지법 제5조제3항 및 제4항은 2017년 12월 12일 법률 제15210호로 일부개정된 청소년복지법에서 신설된 규정으로, 저소득층 여성청소년들이 경제적 어려움으로 인해 생리용품을 구입하지 못하여 비위생적인 물품을 사용하는 등 어려움을 겪고 있어 여성청소년의 건강한 성장을 지원하려는 취지에서 여성청소년에게 “보건위생에 필수적인 물품”을 지원할 수 있는 법적 근거를 마련한 것인데²⁾, 이후 2021년 4월 20일 법률 18101호로 청소년복지법이 일부개정되면서 “보건위생물품”이라는 용어를 “생리용품”으로 변경하고 여성청소년이 생리용품을 신청하는 경우 이에 대한 지원을 의무화한 것인바³⁾, 이러한 입법연혁과 규정취지를 고려하면, 생리용품을 담을 봉투는 생리용품을 지원받는 여성청소년에게 편의를 제공하고 그 지원을 원활하게 하는 필수적인 사항에 해당하는 것으로 볼 수 있으므로, 국가 및 지방자치단체가 청소년복지법 제5조제3항에 따라 생리용품의 이용권을 통해 생리용품을 지원하는 경우 생리용품뿐만 아니라 생리용품을 담을 봉투까지 지원할 수 있다고 할 것입니다.

또한 「청소년 기본법」 제49조에 따르면 국가는 청소년들의 의식·태도·생활 등에 관한 사항을 정기적으로 조사하고, 이를 개선하기 위하여 청소년의 복지향상 정책을 수립·시행하여야 하며, 기초생활 보장 등의 시책을 추진할 때에는 정신적·신체적·경제적·사회적으로 특별한 지원이 필요한 청소년을 우선적으로 배려하여야 하고, 청소년의 삶의 질을 향상하기 위하여 구체적인 시책을 마련하도록 하고 있으며, 이러한 취지를 반영하여 청소년복지법에서는

2) 2017. 12. 12. 법률 제15210호로 일부개정된 청소년복지법 개정이유 및 주요내용 참조

3) 2021. 4. 20. 법률 제18101호로 일부개정된 청소년복지법 개정이유 및 주요내용 참조

청소년복지 향상에 관한 사항을 규정하고 있는데, 같은 법 제5조제3항은 여성청소년의 건강한 성장을 위하여 여성청소년에게 생리용품을 지원하는 것으로서 그 지원 방법은 경제적인 측면뿐만 아니라 해당 용품을 지원받는 여성청소년의 인권 등 다양한 부분을 고려하여 세심하게 결정할 필요가 있는바⁴⁾, 국가 및 지방자치단체가 청소년복지법 제5조제3항에 따라 지원할 수 있는 생리용품에는 이를 담을 봉투까지 포함할 수 있다고 보는 것이 청소년복지법의 입법목적 및 여성청소년 생리용품 지원 제도의 목적에도 부합하는 해석입니다.

따라서 국가 및 지방자치단체는 청소년복지법 제5조제3항에 따라 생리용품의 이용권을 통해 생리용품을 지원하는 경우, 생리용품과 함께 생리용품을 담을 봉투도 지원할 수 있습니다.



관계법령

청소년복지 지원법

제5조(건강한 성장지원) ①·② (생 략)

③ 국가 및 지방자치단체는 여성청소년의 건강한 성장을 위하여 여성청소년이 생리용품을 신청하는 경우 이를 지원한다.

④ 제1항에 따른 시책의 마련, 제2항에 따른 건강·체력 기준의 설정·보급 및 제3항에 따른 생리용품 지원의 기준·범위, 방법, 신청 및 지급절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

청소년복지 지원법 시행령

제3조의2(생리용품 지원의 대상과 방법 등) ① (생 략)

② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 여성청소년에게 생리용품을 직접 지급하거나 생리용품의 이용권[생리용품을 이용할 수 있도록 금액이나 수량이 기재(전자적 또는 자기적 방법에 의한 기록을 포함한다)된 증표를 말한다]을 지급할 수 있다.

③ ~ ⑤ (생 략)

4) 2017. 6. 29. 의안번호 제2007700호로 발의된 청소년복지법 일부개정법률안에 대한 국회 여성가족위원회 검토보고서 참조

질의제목 2

▶ 안전번호 25-0216, 25-0263

여성가족부·서울특별시교육청 - 교육청이 위원회를 구성할 때 「양성평등기본법」 제21조제2항이 적용되는지 여부(「양성평등기본법」 제21조제2항 등 관련)

01 질의요지

「양성평등기본법」 제21조제2항 본문에서는 국가와 지방자치단체는 위원회¹⁾를 구성할 때 위촉직 위원의 경우에는 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 단서 및 제1호에서는 해당 분야 특정 성별의 전문인력 부족 등 부득이한 사유가 있다고 인정되어 국가 및 시·도가 구성하는 위원회의 경우 양성평등실무위원회의 의결을 거친 경우는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바,

교육청이 위원회를 구성할 때 「양성평등기본법」 제21조제2항이 적용되는지?

02 회답

교육청이 위원회를 구성할 때 「양성평등기본법」 제21조제2항이 적용됩니다.

03 이유

「양성평등기본법」 제21조제2항에서는 국가와 지방자치단체는 위원회를 구성할 때 위촉직 위원은 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 하되, 해당 분야 특정 성별의 전문인력 부족 등 부득이한 사유가 있다고 인정되어 같은 법 제12조제1항에 따른 양성평등실무위원회 등의 의결을 거친 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는데, 양성평등기본법령에서 같은 법 제21조제2항의 적용대상이 되는 “지방자치단체”의 개념이나 그 범위를 직접 규정하고 있지 않으므로, 교육청이 위원회를 구성할 때 「양성평등기본법」

1) 위원회, 심의회, 협의회 등 명칭을 불문하고 행정기관의 소관 사무에 관하여 자문에 응하거나 조정, 협의, 심의 또는 의결 등을 하기 위한 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관을 말하며, 이하 같음(「양성평등기본법」 제21조제2항 참조)

제21조제2항이 적용되지는 여부는 문언과 함께 입법연혁, 제도의 취지, 지방자치 관련 법령의 전체적인 체계 등을 종합하여 판단하여야 할 것입니다.

먼저 지방자치단체의 종류, 조직 및 운영 등에 관한 사항을 정하고 있는 법령인 「지방자치법」과 「지방교육자치에 관한 법률」(이하 “교육자치법”이라 함)에 따르면, 지방자치단체는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 함) 및 시·군·구로 구분되고, 지방자치단체의 집행 및 대표기관으로 시·도지사²⁾ 등 지방자치단체의 장을 두면서³⁾, 지방자치단체의 교육·학예 분야의 전문성과 특수성을 고려하여 시·도의 교육·학예에 관한 사무의 집행기관으로 교육감을 두도록 하여⁴⁾, 지방자치단체의 사무 영역에 따라 지방자치단체의 장과 교육감이 별개의 집행 및 대표기관으로 병존⁵⁾하도록 하고 있고, 교육청 등 지방교육행정기관은 시·도의 교육·학예에 관한 사무의 집행기관인 교육감을 보조·보좌하거나 시·도의 교육·학예에 관한 사무를 분장하기 위하여 설치된 기관으로서 시·도의 기관에 해당하는바⁶⁾, 「양성평등기본법」 제21조제2항에서 위원회 성별 균형참여 제도의 시행 주체로 규정하고 있는 지방자치단체에는 교육청도 포함된다고 할 것입니다.

그리고 「양성평등기본법」은 「대한민국헌법」의 양성평등 이념을 실현하기 위한 국가와 지방자치단체의 책무 등에 관한 기본적인 사항을 규정함으로써 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에서 양성평등을 실현하는 것을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 「양성평등기본법」 제21조제2항의 위원회 성별 균형참여 제도는 국가와 지방자치단체의 정책결정과정에서 양성 의견의 균형을 있게 반영하기 위하여 도입된 것인바⁷⁾, 위원회 구성 시 양성 의견의 균형을 도모하려는 규정의 취지는 교육청 등 지방교육행정기관에도 해당한다고 할 것이고, 「양성평등기본법」에 따르면 국가와 지방자치단체는 양성평등 실현을 위하여 법적·제도적 장치를 마련하고 이에 필요한 재원을 마련할 책무를 지고, 예산이 여성과 남성에게 미치는 영향을 분석하여 이를 재정운용에 반영하는 성인지(性認知) 예산을 실시하여야 하며, 차별로 인하여 특정 성별의 참여가 현저히 부진한 분야는 해당 성별의 참여를 촉진하기 위하여 관계 법령에서 정하는 바에 따라 적극적 조치를 취하도록 노력하여야 하는데⁸⁾, 이러한 책무와

2) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사를 말하며, 이하 같음.

3) 「지방자치법」 제2조, 제106조, 제114조 및 제116조 참조

4) 교육자치법 제2조 및 제18조 참조

5) 대법원 2001. 5. 8. 선고 99다69341 판결례 및 법제처 2024. 10. 29. 회신 24-0673 해석례 참조

6) 법제처 2020. 9. 17. 회신 20-0356 해석례 참조

7) 2013. 5. 1. 의안번호 제1904781호로 발의된 「여성발전기본법」 일부개정법률안에 대한 국회 여성가족위원회 검토보고서, 2013. 8. 13. 법률 제12080호로 일부개정된 「여성발전기본법」 개정이유 및 주요내용 참조

8) 「양성평등기본법」 제5조, 제14조, 제16조 및 제20조 참조

양성평등정책의 기본시책은 교육청 등 지방교육행정기관에도 동일하게 적용할 필요가 있으므로, 교육청이 위원회를 구성할 때에도 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 않도록 해야 한다고 해석하는 것이 입법 목적 및 규정 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 「양성평등기본법」 제15조에서는 국가와 지방자치단체는 성별영향평가⁹⁾를 하여야 한다고 규정하면서, 성별영향평가의 대상·방법·시기 등에 필요한 사항은 따로 법률에서 정하도록 하고 있고, 그에 따라 「성별영향평가법」에서는 성별영향평가 제도의 세부적인 사항을 정하고 있는데, 「성별영향평가법」 제2조제3호에서 “지방자치단체”에 “교육청”을 포함하여 규정하고 있는 것은 「양성평등기본법」에서 “지방자치단체”에 “교육청”이 포함되는 것을 전제로 규정한 것으로 보이는 점, 교육에 관한 국가·지방자치단체의 책임을 정하고 교육제도와 그 운영에 관한 기본적인 사항을 규정하고 있는 「교육기본법」 제17조의2에서는 국가와 지방자치단체는 양성평등의식을 보다 적극적으로 증진하고 학생에게 성(性)에 대한 선량한 정서를 함양시키기 위하여 양성평등의식과 실천 역량을 고취하는 교육적 방안 등을 포함한 시책을 수립·실시하여야 한다고 규정하고 있는 등 국가와 지방자치단체의 교육 시책으로도 양성평등기본법령의 양성평등 실현을 위한 정책을 실시하고 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 교육청이 위원회를 구성할 때 「양성평등기본법」 제21조제2항이 적용됩니다.



관계법령

양성평등기본법

제21조(정책결정과정 참여) ① (생 략)

② 국가와 지방자치단체는 위원회(위원회, 심의회, 협의회 등 명칭을 불문하고 행정기관의 소관 사무에 관하여 자문에 응하거나 조정, 협의, 심의 또는 의결 등을 하기 위한 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관을 말한다. 이하 같다)를 구성할 때 위촉직 위원의 경우에는 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 해당 분야 특정 성별의 전문인력 부족 등 부득이한 사유가 있다고 인정되어 다음 각 호의 구분에 따른 위원회의 의결을 거친 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 국가 및 시·도가 구성하는 위원회: 실무위원회
2. 시·군·구가 구성하는 위원회: 시·도위원회

③ 국가와 지방자치단체는 매년 위원회의 성별 참여현황을 여성가족부장관에게 제출하여야 하고, 여성가족부장관은 위원회의 성별 참여현황을 공표하고 이에 대한 개선을 권고할 수 있다.

9) 제정·개정을 추진하는 법령과 성평등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 계획 및 사업 등이 성평등에 미치는 영향을 평가하는 것을 말하며, 이하 같음(「양성평등기본법」 제15조제1항 참조)

④ 국가와 지방자치단체는 관리직위에 여성과 남성이 균형있게 임용될 수 있도록 다음 각 호의 사항을 고려하여 해당 기관의 연도별 임용목표비율을 포함한 중장기 계획(이하 이 조에서 “관리직 목표제”라 한다) 등을 시행하여야 한다.

1. 직종·직급·고용형태별 남녀 직원 현황
2. 관리직 남녀 비율 현황
3. 남녀 직원 근속연수 현황
4. 승진 대상자 중 남녀의 승진 비율
5. 남녀 관리직에 대한 연도별 임용 목표 및 달성 시기

⑤ (생략)

질의제목 3

▶ 안전번호 25-0293

민원인 - 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제2항 단서에 따라 추가로 사용할 수 있는 육아휴직 기간이 같은 법 제19조의2제4항 단서에 따라 가산할 수 있는 육아기 근로시간 단축의 기간에 포함되는지(「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2제4항 등 관련)

01 질의요지

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 “남녀고용평등법”이라 함) 제19조제2항 본문에서는 육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자의 경우 6개월 이내에서 추가로 육아휴직을 사용할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제19조의2제4항 본문에서는 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 근로자가 같은 법 제19조제2항 본문에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간의 두 배를 가산한 기간 이내로 한다고 규정하고 있는바,

남녀고용평등법 제19조제2항 단서에 따라 추가로 사용할 수 있는 육아휴직 기간이 같은 법 제19조의2제4항 단서에 따라 가산할 수 있는 육아기 근로시간 단축의 기간에 포함되는지?

02 회답

남녀고용평등법 제19조제2항 단서에 따라 추가로 사용할 수 있는 육아휴직 기간은 같은 법 제19조의2제4항 단서에 따라 가산할 수 있는 육아기 근로시간 단축의 기간에 포함되지 않습니다.

03 이유

먼저 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더

이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데¹⁾, 육아기 근로시간 단축의 기간을 정하고 있는 남녀고용평등법 제19조의2제4항 단서에서는 근로자가 같은 법 제19조제2항 본문에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간의 두 배를 가산한 기간 이내로 한다고 규정하고 있는바, 남녀고용평등법 제19조의2제4항 단서에 따라 육아기 근로시간 단축의 기간에 가산할 수 있는 육아휴직 기간은 같은 법 제19조제2항 본문에 따른 육아휴직 기간만 해당하는 것이고, 같은 항 단서에 따라 추가로 사용할 수 있는 육아휴직 기간은 해당하지 않는다는 것이 문언상 명확합니다.

또한 남녀고용평등법 제19조제2항 단서는 2024년 10월 22일 법률 제20521호로 일부개정된 남녀고용평등법에서 부모 모두 각각 육아휴직 사용 시 육아휴직 기간을 연장하여 사용할 수 있도록 하여 부모 맞돌봄 문화를 확산하고, 근로자의 일·가정 양립 지원을 강화하려는 취지²⁾로 신설되었는데, 이때 같은 법 제19조의2제4항 단서도 함께 개정하여 육아기 근로시간 단축의 기간에 가산할 수 있는 육아휴직 기간을 “제19조제2항에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간”에서 “제19조제2항 본문에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간”으로 변경하였는바, 육아휴직의 기간을 정하고 있는 남녀고용평등법 제19조제2항에 단서를 신설하여 근로자가 사용할 수 있는 육아휴직 기간을 확대하면서도, 육아기 근로시간 단축의 기간에 가산할 수 있는 육아휴직 기간의 경우에는 종전과 같이 같은 법 제19조제2항 본문에 따른 육아휴직 기간으로 한정하여 규정하고 있는 입법연혁에 비추어 보면, 남녀고용평등법 제19조의2제4항 단서에 따라 육아기 근로시간 단축의 기간에 가산할 수 있는 육아휴직 기간은 같은 법 제19조제2항 본문에 따른 육아휴직 기간으로 한정되고, 같은 항 단서에 따라 추가로 사용할 수 있는 육아휴직 기간은 육아기 근로시간 단축의 기간에 가산할 수 있는 육아휴직 기간에 포함되지 않는다고 해석하는 것이 해당 규정의 입법 연혁과 취지에 부합하는 해석입니다.

따라서 남녀고용평등법 제19조제2항 단서에 따라 추가로 사용할 수 있는 육아휴직 기간은 같은 법 제19조의2제4항 단서에 따라 가산할 수 있는 육아기 근로시간 단축의 기간에 포함되지 않습니다.

1) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

2) 2024. 6. 10. 의안번호 제2200256호로 발의된 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 환경노동위원회 검토보고서 참조

**남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률**

제19조(육아휴직) ① 사업주는 임신 중인 여성 근로자가 모성을 보호하거나 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다. 이하 같다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 “육아휴직”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자의 경우 6개월 이내에서 추가로 육아휴직을 사용할 수 있다.

1. 같은 자녀를 대상으로 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 사용한 경우의 부 또는 모
2. 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 부 또는 모
3. 고용노동부령으로 정하는 장애아동의 부 또는 모

③ ~ ⑥ (생 략)

제19조의2(육아기 근로시간 단축) ① 사업주는 근로자가 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②·③ (생 략)

④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 근로자가 제19조제2항 본문에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간의 두 배를 가산한 기간 이내로 한다.

⑤ ~ ⑦ 생 략

제3절 문화체육관광

질의제목 1

▶ 안전번호 24-0767

경기도 여주시 - 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령」 제4조의2제4호에 따른 “65세 이상의 사람, 장애인 및 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자를 위한 행사”의 범위(「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령」 제4조의2제4호 등 관련)

01 질의요지

「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」(이하 “체육시설법”이라 함) 제5조제1항에서는 국가와 지방자치단체는 국내·외 경기대회의 개최와 선수 훈련 등에 필요한 운동장이나 체육관 등 체육시설(이하 “전문체육시설”이라 함)을 대통령령으로 정하는 바에 따라 설치·운영하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제6조제1항에서는 국가와 지방자치단체는 국민이 거주지와 가까운 곳에서 쉽게 이용할 수 있는 생활체육시설(이하 “생활체육시설”이라 함)을 대통령령으로 정하는 바에 따라 설치·운영하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제5조제3항 및 같은 법 제6조제3항에서는 전문체육시설 및 생활체육시설의 사용을 촉진하기 위하여 지방자치단체는 「공유재산 및 물품 관리법」, 그 밖의 다른 법률의 규정에도 불구하고 그 사용료의 전부나 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 감면할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

체육시설법 제5조제3항 및 같은 법 제6조제3항의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제4조의2에서는 지방자치단체는 전문체육시설 및 생활체육시설이 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행사 또는 활동에 사용되는 경우에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 사용료를 감면할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제4호에서는 “65세 이상의 사람, 장애인 및 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자를 위한 행사”를 규정하고 있는바,

「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령」(이하 “체육시설법 시행령”이라 함) 제4조의2 4호에 따른 “65세 이상의 사람, 장애인 및 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자를 위한

행사”는 65세 이상의 사람, 장애인 및 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자(이하 “대상자”라 함) 2인 이상의 사적 이용¹⁾을 포함하는지?

02 회답

체육시설법 시행령 제4조의2제4호에 따른 “65세 이상의 사람, 장애인 및 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자를 위한 행사”는 대상자 2인 이상의 사적 이용을 포함하지 않습니다.

03 이유

먼저 동일한 법령에서 사용되는 용어는 법령에 다른 규정이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 동일하게 해석·적용되어야 하는데²⁾, 체육시설법 시행령 제4조의2에서는 전문체육시설 및 생활체육시설이 사용되는 경우 그 사용료를 감면할 수 있는 행사나 활동으로, 제1호에서 국가나 다른 지방자치단체가 주최하거나 주관하는 행사, 제2호에서 「국민체육진흥법」 제33조에 따른 대한체육회 또는 「국민체육진흥법」 제34조에 따른 대한장애인체육회가 주관하는 행사, 제3호에서 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자 및 그 유족 또는 가족을 위한 행사, 제4호에서 65세 이상의 사람, 장애인 및 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자를 위한 행사 등에 전문체육시설 및 생활체육시설이 사용되는 경우 그 사용료를 감면할 수 있도록 규정하고 있으므로, 같은 조 제4호에 따른 “행사”의 의미를 해석할 때에는 같은 조 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 “행사”의 의미를 고려하여 해석해야 할 것입니다.

그런데 체육시설법 시행령 제4조의2제1호 및 제2호에서는 국가나 지방자치단체, 법정 단체 등이 주최하거나 주관하는 행사를 규정하고 있고, 같은 조 제3호에서는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따라 등록된 국가유공자 및 그 유족·가족을 위한 행사를, 같은 조 제4호에서는 대상자를 위한 행사를 각각 규정하여 그 행사의 목적과 대상을 구체적으로 규정하고 있는 점에 비추어 보면, 체육시설법 시행령 제4조의2제1호 및 제2호에 따른 행사는

1) 주최자, 특정한 의미나 목적, 기념할 만한 사건 등이 없이 2인 이상이 모여 해당 체육시설을 이용하는 것을 의미하는 것으로 전제하며, 이하 같음

2) 대법원 1997. 9. 9. 선고 97누2979 판결례 참조

국가나 지방자치단체, 법정 단체 등의 주체가 공적으로 주최·주관하는 행사를 의미하는 것으로서, 같은 조 제3호 및 제4호에 따른 행사도 이러한 행사에 준하는 정도로 공적으로 주최·주관하는 행사를 의미하는 것이라고 보는 것이 합리적입니다.

그리고 일반적으로 공유재산의 관리·처분에 관한 사항은 「공유재산 및 물품 관리법」(이하 “공유재산법”이라 함)이 적용되나, 체육시설법 제5조제3항 및 제6조제3항에서 공유재산법 등에도 불구하고 사용료의 전부나 일부를 감면할 수 있도록 규정하여 공유재산법 제22조에 따른 사용료 징수의 원칙에 대한 예외를 규정한 것이라는 점, 체육시설법 제5조 및 제6조에 따른 전문체육시설 및 생활체육시설은 공유재산법에 따른 행정재산 중 공공용재산인 공공시설에 해당하는 것이어서 「지방자치법」 제156조제1항 본문에 따라 그 사용료의 징수에 관해 지방자치단체에 재량이 부여되어 있고, 체육시설법 시행령 제4조의2제7호에서는 “그 밖에 사용료 감경이 필요하여 지방자치단체의 조례로 정하는 행사 또는 활동”을 규정하고 있어 같은 조 제1호부터 제6호까지의 규정에 해당하지 않는 경우에도 지방자치단체의 정책적 필요에 따라 사용료를 감경할 수 있는 경우를 조례로 정할 수 있도록 위임하고 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 만약 국가나 지방자치단체 등이 공적으로 주최·주관하는 행사가 아닌, 대상자들의 사적 이용에 대해 체육시설 사용료를 감경할 필요성이 있다면, 같은 조 제7호에 따라 지방자치단체의 조례로 정해야 할 것이지, 같은 조 제4호에 따른 “행사”의 범위를 지나치게 확대 해석하여 대상자 2인 이상의 사적 이용이 포함된다고 보는 것은 같은 조의 규정 체계에 부합하지 않습니다.

아울러 체육시설법 시행령 제4조의2의 입법연혁을 살펴보면, 종전에는 국가나 다른 지방자치단체가 주최하거나 주관하는 행사, 대한체육회·대한장애인체육회 등이 주관하는 행사 등 같은 조 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 “행사”에 전문체육시설 및 생활체육시설이 사용되는 경우 그 사용료를 감면할 수 있도록 규정하였다가, 2016년 8월 2일 대통령령 제27426호로 일부개정된 체육시설법 시행령 제4조의2에서 학교의 체육활동과 관련된 정규수업 또는 방과 후 활동(제5호), 학교 밖 청소년의 체육활동과 관련된 자립지원 활동(제6호)에 체육시설이 사용되는 경우를 사용료 감면 대상으로 신설하면서, “각 호의 규정에 따른 행사 또는 활동”에 체육시설이 사용되는 경우 그 사용료를 감면할 수 있도록 한 것인바, 체육시설법 시행령 제4조의2 각 호 외의 부분에서 “활동”을 추가하였다고 하더라도 이를 같은 조 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 행사에 체육시설을 개별적·사적으로 이용하는 경우까지 포함하려는 취지로 볼 수는 없다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 체육시설법 시행령 제4조의2제4호에 따른 “65세 이상의 사람, 장애인 및 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자를 위한 행사”는 대상자 2인 이상의 사적 이용을 포함하지 않습니다.



관계법령

체육시설의 설치·이용에 관한 법률

제5조(전문체육시설) ① 국가와 지방자치단체는 국내·외 경기대회의 개최와 선수 훈련 등에 필요한 운동장이나 체육관 등 체육시설을 대통령령으로 정하는 바에 따라 설치·운영하여야 한다.

② (생략)

③ 제1항에 따른 체육시설의 사용을 촉진하기 위하여 지방자치단체는 「공유재산 및 물품 관리법」, 그 밖의 다른 법률의 규정에도 불구하고 그 사용료의 전부나 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 감면할 수 있다.

제6조(생활체육시설) ① 국가와 지방자치단체는 국민이 거주지와 가까운 곳에서 쉽게 이용할 수 있는 생활체육시설을 대통령령으로 정하는 바에 따라 설치·운영하여야 한다.

② (생략)

③ 제1항에 따른 체육시설의 사용을 촉진하기 위하여 지방자치단체는 「공유재산 및 물품 관리법」, 그 밖의 다른 법률의 규정에도 불구하고 그 사용료의 전부나 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 감면할 수 있다.

체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령

제4조의2(전문체육시설 및 생활체육시설의 사용료 감면) 지방자치단체는 법 제5조제3항 및 제6조제3항에 따라 전문체육시설 및 생활체육시설이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행사 또는 활동에 사용되는 경우에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 사용료를 감면할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

4. 65세 이상의 사람, 장애인 및 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자를 위한 행사

5. ~ 7. (생략)

질의제목 2

▶ 안전번호 24-0912

민원인 - 전동 고카트를 이용하는 시설을 운영하는 영업이 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제10조제1항제1호에서 규정하고 있는 자동차경주장업에 포함되는지(「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제10조 등 관련)

01 질의요지

「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」(이하 “체육시설법”이라 함) 제10조제1항제1호에서는 자동차경주장업을 등록 체육시설업으로 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 별표 4 제2호바목 1) 및 2)에서 자동차경주장업의 시설 기준을 규정하고 있는 한편,

「관광진흥법」 제5조제2항에서는 같은 법 제3조제1항제6호에 따른 유원시설업¹⁾ 중 대통령령으로 정하는 유원시설업을 경영하려는 자는 문화체육관광부령으로 정하는 시설과 설비를 갖추어 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다고 규정하면서, 같은 법 시행규칙 별표 11 제1호나목1)가)에서 ‘유기시설 또는 유기기구’ 중 고카트를 ‘주로 주행형²⁾’의 ‘스포츠카’로서 ‘자동차형 승용물이 엔진 또는 전기 동력장치로 구동하여 정해진 주로(완충장치가 있는 별도로 구분된 영구적인 주로)를 따라 단독 주행하여 30km/h이하(ISO 17842-1)로 주행하는 기구(전동카, 고카트 등)’로 규정하고 있는바,

전동 고카트³⁾를 이용하는 시설을 운영하는 영업이 체육시설법 제10조제1항제1호에서 규정하고 있는 자동차경주장업에 포함되는지?

1) 유기시설이나 유기기구를 갖추어 이를 관광객에게 이용하게 하는 업(다른 영업을 경영하면서 관광객의 유치 또는 광고 등을 목적으로 유기시설이나 유기기구를 설치하여 이를 이용하게 하는 경우를 포함한다)을 말하며(「관광진흥법」 제3조제1항제6호 참조), 이하 같음

2) 안전성검사 대상 유기시설 또는 유기기구는 주행형, 고정형, 관람형, 놀이형으로 구분되고, 주로 주행형은 일정한 주로를 가지고 있으며 그 주로를 이용하여 승용물이 운행되는 유기시설 또는 유기기구를 말하며(「관광진흥법 시행규칙」 별표 11 제1호나목1)가) 참조), 이하 같음

3) 전기 동력장치로 구동하여 30km/h이하로 주행하는 자동차형 승용물을 말하며(「관광진흥법 시행규칙」 별표 11 제1호나목1)가) 주로 주행형 중 스포츠카 참조), 이하 같음.

02 회답

전동 고카트를 이용하는 시설을 운영하는 영업은 체육시설법 제10조제1항제1호에서 규정하고 있는 자동차경주장업에 포함되지 않습니다.

03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 할 것입니다⁴⁾.

먼저 관광진흥법령에서의 유기사설 또는 유기기구란 이용자에게 재미, 즐거움, 스틸을 제공할 목적으로 기계·전기·전자 장치 등을 활용하여 일정 공간 내에서 정형화된 방법으로 이용하도록 설치된 시설 또는 기구⁵⁾를 말하고, 「관광진흥법」 제5조제2항에서는 같은 법 제3조제1항제6호에 따라 유원시설업 중 대통령령으로 정하는 유원시설업을 경영하려는 자는 문화체육관광부령으로 정하는 시설과 설비를 갖추어 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 별표 11 제1호나목1)가)에서는 ‘안전성 검사 대상인 유기사설 또는 유기기구’의 한 종류로 주로 주행형의 스포츠카를 규정하면서 ‘자동차형 승용물이 엔진 또는 전기 동력장치로 구동하여 정해진 주로(완충장치가 있는 별도로 구분된 영구적인 주로)를 따라 단독 주행하여 30km/h이하(ISO 17842-1)로 주행하는 기구(전동카, 고카트 등)’라고 규정하고 있는바, 유기사설 또는 유기기구 중 하나로 고카트를 규정하고 있습니다.

그리고 「관광진흥법 시행규칙」 별표 1의2에서는 안내소를 설치하고 구급약품을 비치하는 등 유원시설업의 시설 및 설비기준을 정하고 있고, 「관광진흥법」 제33조, 같은 법 시행규칙 제40조 및 「유기사설 또는 유기기구 안전성검사 등의 기준 및 절차」(문화체육관광부 고시)에서는 허가 전 정상작동 또는 고장 등으로 발생할 수 있는 예상 상황을 가정하여 점검하고

4) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

5) 「유기사설 또는 유기기구 안전성검사 등의 기준 및 절차」(문화체육관광부 고시) 제3조제1항제1호 참조

시운전하는 등 안전성검사를 받고, 다음 연도부터 주로의 균열, 변형 등에 대해 연 1회 이상 정기 안전성검사를 받으며, 부적합 판정 및 사고 발생 시 재검사를 받도록 규정하고 있는 등 별도의 규정 체계를 마련하고 있는 점에 비추어 볼 때, 전동 고카트는 자동차형 승용물인 유기기구로서 이를 이용하는 시설을 운영하는 영업은 관광진흥법령에 따라 허가·관리되어야 할 대상이라고 할 것입니다.

한편 체육시설법 제10조제1항에서는 체육시설업을 등록 체육시설업과 신고 체육시설업으로 구분하여 골프장업, 스키장업, 자동차경주장업을 등록 체육시설업(제1호)으로, 골프 연습장업, 체력단련장업, 썰매장업 등을 신고 체육시설업(제2호)으로 규정하고 있고, 같은 법 제11조제1항에서는 체육시설업자는 체육시설업의 종류에 따라 문화체육관광부령으로 정하는 시설 기준에 맞는 시설을 설치하고 유지·관리하여야 한다고 규정하면서, 자동차경주장업의 정의에 대해서는 규정하고 있지 않으며, 같은 법 시행규칙 별표 4 제2호바목 1) 및 2)에서는 자동차경주장업을 2륜 자동차경주장업과 4륜 자동차경주장업으로 구분하여 4륜 자동차경주장업의 필수시설인 ① 운동시설은 ‘트랙은 길이 2킬로미터 이상으로서 출발지점과 도착지점이 연결되는 순환형태여야 하고, 트랙의 폭은 11미터 이상 15미터 이하여야 하며, 출발지점에서 첫 번째 곡선 부분 시작지점까지는 250미터 이상의 직선구간’이도록 하고, ② 안전시설은 ‘경주 중인 차량이 트랙을 이탈하는 경우 안전지대 바깥쪽으로 벗어나지 아니하고 정지할 수 있는 정도의 수직 보호벽(높이 69센티미터 이상이어야 함)을 가드레일(2단 이상)이나 콘크리트벽’으로 설치하도록 하는 등 시설 기준을 정하고 있습니다.

이와 관련하여 체육시설법에서 체육시설업을 등록업과 신고업으로 구분한 것은 시설의 규모와 인근지역에 미치는 영향력의 정도를 기준으로 그 사업의 효과가 큰 경우에는 등록업으로, 소규모의 체육시설업은 신고업으로 정하려는 취지⁶⁾인바, 같은 법에서 ‘골프장업, 스키장업, 자동차경주장업’만을 등록업으로 규정하고, ‘요트장업, 조정장업, 카누장업, 빙상장업, 승마장업’ 등 대부분의 업종은 신고업으로 규정하고 있으며, 등록업인 자동차경주장업은 인근지역에 미치는 영향력이 큰 대규모 체육시설로서 같은 법에 따라 사업계획의 승인(제12조)을 받고 시설 기준에 맞는 시설을 갖추어 등록(제19조)하여야 하며 반기마다 안전관련 시설 기준 준수 여부 등에 대한 안전점검(제4조의3)을 받도록 규정하고 있습니다.

위에서 살펴본 바를 종합해보면, 자동차경주장업의 경우 체육시설업을 건전하게 발전시켜 국민의 건강 증진과 여가 선용에 이바지하는 것을 목적으로 하는 체육시설법에서 시설의

6) 1993. 11. 11. 의안번호 제140503호로 발의된 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 개정법률안에 대한 국회 문화체육공보위원회 심사보고서 참조

규모와 인근지역에 미치는 영향력이 큰 등록업으로 분류되어 있고, 길이 2킬로미터 이상, 폭 11미터 이상 15미터 이하의 트랙을 갖추도록 하는 등 대규모 시설 기준을 정하고 있는 반면, 전동 고카트의 경우 구조가 단순하고 전기 동력장치로 구동되지만 속도가 30km/h 이하로 제한되어 있어 일반적인 자동차경주에 비해 대형 사고의 위험성이 낮고, 관광사업을 육성하여 관광 진흥에 이바지하는 것을 목적으로 하는 「관광진흥법」에서 유원시설 또는 유원기구 중 하나로서 이를 이용하게 하는 영업을 유원시설업으로 규정하면서 자동차경주장업과 같이 대규모 시설 기준을 요구하고 있지 않은바, 입법목적이 다른 체육시설법령과 관광진흥법령에서 각각 규율하고 있는 자동차경주장업과 유원시설업은 규율하려는 영업의 대상이 다른 것으로 보이므로, 전동 고카트를 이용하는 시설을 운영하는 영업은 체육시설법 제10조제1항제1호에서 규정하고 있는 자동차경주장업에 포함되지 않는 것으로 보는 것이 관련 법령의 체계에 부합하는 해석입니다.

또한 형벌법규의 해석은 엄격하여야 하고 명문규정의 의미를 피고인에게 불리한 방향으로 지나치게 확장 해석하거나 유추해석하는 것은 죄형법정주의의 원칙에 어긋나는 것으로서 허용되지 않으며, 이러한 법해석의 원리는 그 형벌법규의 적용대상이 행정법규가 규정한 사항을 내용으로 하고 있는 경우에 그 행정법규의 규정을 해석하는 데에도 마찬가지로 적용된다고 할 것⁷⁾인데, 체육시설법 제38조제1항에서는 같은 법 제12조에 따른 사업계획의 승인을 받지 아니하고 등록 체육시설업의 시설을 설치한 자(제1호)와 같은 법 제19조제1항 또는 제2항에 따른 등록(변경등록은 제외함)을 하지 아니하고 체육시설업의 영업을 한 자(제2호)는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있는바, 전동 고카트를 이용하는 시설을 운영하는 영업이 자동차경주장업에 포함된다고 보아 사업계획의 승인을 받지 않거나 등록을 하지 않을 경우 벌칙의 대상으로 보는 것은 합리적인 근거 없이 처벌 대상을 확대하는 해석으로서 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 전동 고카트를 이용하는 시설을 운영하는 영업은 체육시설법 제10조제1항제1호에서 규정하고 있는 자동차경주장업에 포함되지 않습니다.

7) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90도1516 전원합의체 판결례 참조



관계법령

체육시설의 설치·이용에 관한 법률

제10조(체육시설업의 구분·종류) ① 체육시설업은 다음과 같이 구분한다.

1. 등록 체육시설업 : 골프장업, 스키장업, 자동차경주장업
 2. 신고 체육시설업 : 요트장업, 조정장업, 카누장업, 빙상장업, 승마장업, 종합 체육시설업, 수영장업, 체육도장업, 골프 연습장업, 체력단련장업, 당구장업, 썰매장업, 무도학원업, 무도장업, 야구장업, 가상체험 체육시설업, 체육교습업, 인공암벽장업
- ② 제1항 각 호에 따른 체육시설업(골프장업은 제외한다)은 그 종류별 범위와 회원 모집, 시설 규모, 운영 형태 등에 따라 그 세부 종류를 대통령령으로 정할 수 있다.

제11조(시설 기준 등) ① 체육시설업자는 체육시설업의 종류에 따라 문화체육관광부령으로 정하는 시설 기준에 맞는 시설을 설치하고 유지·관리하여야 한다.

② (생략)

체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행규칙

제8조(체육시설업의 시설 기준) 법 제11조제1항에 따른 체육시설업의 종류별 시설 기준은 별표 4와 같다.

[별표 4]

체육시설업의 시설 기준(제8조 관련)

1. (생략)
2. 체육시설업의 종류별 기준
가. ~ 마.(생략)

2) 4륜 자동차경주장업

구분	시설기준
필수시설 ① 운동시설	○ 트랙은 길이 2킬로미터 이상으로서 출발지점과 도착지점이 연결되는 순환형 태여야 하고, 트랙의 폭은 11미터 이상 15미터 이하여야 하며, 출발지점에서 첫 번째 곡선 부분 시작지점까지는 250미터 이상의 직선구간이어야 한다. (이하 생략)
② 안전시설	○ 출발지점을 제외한 트랙의 직선 부분은 트랙의 좌우 흰색선 바깥쪽으로 3미

터 이상 5미터 이하의 안전지대를 두어야 하며, 트랙의 곡선 부분은 다음의 공식에 따른 폭의 안전지대를 두어야 한다. 다만, 안전지대의 바닥에 깊이 25센티미터 이상으로 자갈을 까는 경우 안전지대의 폭은 트랙의 직선 부분은 2미터 이상, 곡선 부분은 위의 공식에 따라 산출된 폭의 2분의 1 이상으로 할 수 있다.

안전지대의 폭(미터)=(속도)2/300
 ※ 속도의 단위는 시간당 킬로미터임
 (이하 생략)

관광진흥법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.~ 5. (생 략)

6. 유원시설업(遊園施設業) : 유기시설(遊技施設)이나 유기기구(遊技機具)를 갖추어 이를 관광객에게 이용하게 하는 업(다른 영업을 경영하면서 관광객의 유치 또는 광고 등을 목적으로 유기시설이나 유기기구를 설치하여 이를 이용하게 하는 경우를 포함한다)

7. (생 략)

② (생 략)

제5조(허가와 신고) ① 제3조제1항제5호에 따른 카지노업을 경영하려는 자는 전용 영업장 등 문화체육관광부령으로 정하는 시설과 기구를 갖추어 문화체육관광부장관의 허가를 받아야 한다.

② 제3조제1항제6호에 따른 유원시설업 중 대통령령으로 정하는 유원시설업을 경영하려는 자는 문화체육관광부령으로 정하는 시설과 설비를 갖추어 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

③ ~ ⑥ (생 략)

제33조(안전성검사 등) ① 유원시설업자 및 유원시설업의 허가 또는 변경허가를 받으려는 자(조건부영업허가를 받은 자로서 그 조건을 이행한 후 영업을 시작하려는 경우를 포함한다)는 문화체육관광부령으로 정하는 안전성검사 대상 유기시설 또는 유기기구에 대하여 문화체육관광부령에서 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 실시하는 안전성검사를 받아야 하고, 안전성검사 대상이 아닌 유기시설 또는 유기기구에 대하여는 안전성검사 대상에 해당되지 아니함을 확인하는 검사를 받아야 한다. 이 경우 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 성수기 등을 고려하여 검사시기를 지정할 수 있다.

② ~ ⑤ (생 략)

관광진흥법 시행규칙

제40조(유기시설 또는 유기기구의 안전성검사 등) ① 법 제33조제1항에 따른 안전성검사 대상 유기시설 또는 유기기구와 안전성검사 대상이 아닌 유기시설 및 유기기구는 별표 11과 같다.

② ~ ⑨ (생 략)

[별표 11]

안전성검사 대상 유기사설 또는 유기기구와
안전성검사 대상이 아닌 유기사설 또는 유기기구(제40조제1항 관련)

1. 안전성검사 대상 유기사설 또는 유기기구

가. 대 상

안전성검사 대상 유기사설 또는 유기기구는 위험요소가 많아 안전성검사를 받아야 하는 유기사설 또는 유기기구로서 제2호의 안전성검사의 대상이 아닌 유기사설 또는 유기기구에 해당하는 것을 제외한 유기사설 또는 유기기구를 말한다.

나. 구 분

1) 안전성검사 대상 유기사설 또는 유기기구는 다음과 같이 구분한다.

가) 주행형

분류	내용	대표 유기사설 또는 유기기구	정의(유기사설 또는 유기기구의 유사기구명)
주로 주행형	일정한 주로(도로 또는 이와 유사한 주로)를 가지고 있으며 그 주로를 이용하여 승용물이 운행되는 유기사설 또는 유기기구	스포츠카	자동차형 승용물이 엔진 또는 전기 동력장치로 구동하여 정해진 주로(완충장치가 있는 별도로 구분된 영구적인 주로)를 따라 단독 주행하여 30 km/h이하(ISO 17842-1)로 주행하는 기구(전동카, 고카트 등)
		무궤도열차	건인차량에 객차를 연결하여 많은 이용자가 탑승하여 정해진 주로(페인트 표시 등)를 따라 이동하는 기구(패밀리열차, 코끼리열차, 트램카 등)
		보틀레이	이용자가 무동력 승용물에 탑승하여 경사진 일정한 홈 형 주로를 따라 브레이크로 속도 조절하며 하강하는 시설·기구(슈퍼보틀레이, 알파인슬라이드, 롤러루지 등)

(이하 생략)

질의제목 3

▶ 안전번호 24-0967

외교부 - 「관광진흥개발기금법 시행령」 제1조의2제1항제1호의 “외교관여권이 있는 자”에 대한민국 외교관여권이 있는 자가 포함되는지 여부(「관광진흥개발기금법 시행령」 제1조의2제1항 등 관련)

01 질의요지

「관광진흥개발기금법」(이하 “관광기금법”이라 함) 제2조제3항에서는 국내 공항과 항만을 통하여 출국하는 자로서 대통령령으로 정하는 자는 1만원의 범위에서 대통령령으로 정하는 금액을 기금에 납부하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제1조의2제1항제1호에서는 “외교관여권이 있는 자”를 같은 법 제2조제3항에 따른 출국 납부금의 면제 대상자로 규정하고 있는바,

관광기금법 시행령 제1조의2제1항제1호의 “외교관여권이 있는 자”에 대한민국 외교관여권이 있는 자도 포함되는지?

02 회답

관광기금법 시행령 제1조의2제1항제1호의 “외교관여권이 있는 자”에 대한민국의외교관여권이 있는 자도 포함됩니다.

03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 할 것입니다¹⁾.

1) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

먼저 관광기금법 제2조제3항에서는 국내 공항과 항만을 통하여 출국하는 자로서 대통령령으로 정하는 자는 1만원의 범위에서 대통령령으로 정하는 금액을 기금에 납부하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제1조의2제1항에서는 출국납부금의 면제 대상자를 정하면서, 같은 항 제2호에서는 “12세 미만인 어린이”, 같은 항 제4호에서는 “대한민국에 주둔하는 외국의 군인 및 군무원”, 같은 항 제8호에서는 “국제선 항공기 및 국제선 선박을 운항하는 승무원과 승무교대를 위하여 출국하는 승무원”을 규정하는 등 같은 항 각 호에서는 연령이나 국적 등 적용 대상의 범위를 한정하려는 경우에는 이를 명시적으로 규정하고 있는데 반해, 같은 항 제1호에서는 “외교관여권이 있는 자”라고 규정하여 외교관여권이 있는 자의 범위에 대해 별도로 한정하거나 특정하지 않고 있고, 해당 외교관여권이 대한민국의 외교관여권이든 외국의 외교관여권이든 구별하지 않고 규정하고 있으므로 관광기금법 시행령 제1조의2제1항제1호의 외교관 여권이 있는 자는 대한민국 외교관여권인지 외국의 외교관여권인지를 구별하지 않고 출국납부금이 면제된다고 보는 것이 같은 항의 문언 및 규정체계에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

그리고 관광기금법 시행령 제1조의2제1항의 입법연혁을 살펴보면, 구 관광기금법 시행령²⁾ 제1조의2제1항에서는 “관광목적으로 출국하는 13세 이상 64세 이하의 자”를 출국납부금의 납부 대상자로 규정하고 있었으나, 그 납부 대상자를 확대하기 위하여 1998년 11월 13일 대통령령 제15929호로 관광기금법 시행령을 일부개정하여 제1조의2제1항 각 호에 해당하는 자를 제외한 모든 내국인을 출국납부금의 납부 대상자로 규정하면서³⁾, 같은 항 제1호로 “외교관여권의 소지자”를 신설하여 규정하였고, 그러한 내용이 현행 관광기금법 시행령 제1조의2제1항제1호의 규정으로 유지되어 온 것인데, 같은 호에서 “외교관여권의 소지자”를 규정한 것이 “국외에 여행하는 내국인” 중 외교관여권 소지자를 출국납부금의 부과 대상자에서 제외하려는 것이었다는 점⁴⁾을 고려하면, 별도의 법령 개정 없이 대한민국 외교관여권이 있는 사람이 관광기금법 시행령 제1조의2제1항제1호에 포함되지 않는다고 해석하는 것은 입법연혁 및 취지에도 부합하지 않는다고 할 것입니다.

따라서 관광기금법 시행령 제1조의2제1항제1호의 “외교관여권이 있는 자”에 대한민국 외교관여권이 있는 자도 포함됩니다.

2) 1998. 11. 13. 대통령령 제15929호로 일부개정되기 전의 것을 말함

3) 1998. 9. 17. 법률 제5565호로 일부개정된 관광기금법 제2조제3항 참조

4) 1998. 11. 13. 대통령령 제15929호 일부개정된 관광기금법 시행령 개정이유 및 주요골자 참조



관계법령

관광진흥개발기금법

제1조(목적) 이 법은 관광사업을 효율적으로 발전시키고 관광을 통한 외화 수입의 증대에 이바지하기 위하여 관광진흥개발기금을 설치하는 것을 목적으로 한다.

제2조(기금의 설치 및 재원) ① 정부는 이 법의 목적을 달성하는 데에 필요한 자금을 확보하기 위하여 관광진흥개발기금(이하 “기금”이라 한다)을 설치한다.

② 기금은 다음 각 호의 재원(財源)으로 조성한다.

1. 정부로부터 받은 출연금
2. 「관광진흥법」 제30조에 따른 납부금
3. 제3항에 따른 출국납부금
4. 「관세법」 제176조의2제4항에 따른 보세판매장 특허수수료의 100분의 50
5. 기금의 운용에 따라 생기는 수익금과 그 밖의 재원

③ 국내 공항과 항만을 통하여 출국하는 자로서 대통령령으로 정하는 자는 1만원의 범위에서 대통령령으로 정하는 금액을 기금에 납부하여야 한다.

④ ~ ⑦ (생 략)

관광진흥개발기금법 시행령

제1조의2(납부금의 납부대상 및 금액) ① 「관광진흥개발기금법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제3항에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 제외한 자를 말한다.

1. 외교관여권이 있는 자
2. 12세 미만인 어린이
3. 국외로 입양되는 어린이와 그 호송인
4. 대한민국에 주둔하는 외국의 군인 및 군무원
5. 입국이 허용되지 아니하거나 거부되어 출국하는 자
6. 「출입국관리법」 제46조에 따른 강제퇴거 대상자 중 국비로 강제 출국되는 외국인
7. 공항통과 여객으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당되어 보세구역을 벗어난 후 출국하는 여객
 - 가. 항공기 탑승이 불가능하여 어쩔 수 없이 당일이나 그 다음 날 출국하는 경우
 - 나. 공항이 폐쇄되거나 기상이 악화되어 항공기의 출발이 지연되는 경우
 - 다. 항공기의 고장·납치, 긴급환자 발생 등 부득이한 사유로 항공기가 불시착한 경우
 - 라. 관광을 목적으로 보세구역을 벗어난 후 24시간 이내에 다시 보세구역으로 들어오는 경우
8. 국제선 항공기 및 국제선 선박을 운항하는 승무원과 승무교대를 위하여 출국하는 승무원

② 법 제2조제3항에 따른 납부금은 7천원으로 한다. 다만, 선박을 이용하는 경우에는 1천원으로 한다.

질의제목 4

▶ 안전번호 24-1009

문화체육관광부 - 지방자치단체의 장은 「성균관·향교·서원전통문화의 계승·발전 및 지원에 관한 법률」 제3조제3항을 근거로 성균관·향교·서원에 지방보조금을 운영비로 교부할 수 있는지(「성균관·향교·서원전통문화의 계승·발전 및 지원에 관한 법률」 제3조제3항 등 관련)

01 질의요지

「성균관·향교·서원전통문화의 계승·발전 및 지원에 관한 법률」(이하 “성균관·향교·서원법”이라 함) 제3조제3항에서는 국가 및 지방자치단체는 성균관·향교·서원전통문화의 계승·발전을 위하여 예산의 범위에서 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」(이하 “지방보조금법”이라 함) 제6조제2항 전단에서는 지방자치단체의 장은 법령에 명시적 근거가 있는 경우 외에는 지방보조금을 운영비로 교부할 수 없다고 규정하고 있는바,

지방자치단체의 장은 성균관·향교·서원법 제3조제3항을 근거로 성균관·향교·서원에 지방보조금을 운영비로 교부할 수 있는지?

02 회답

지방자치단체의 장은 성균관·향교·서원법 제3조제3항을 근거로 성균관·향교·서원에 지방보조금을 운영비로 교부할 수 없습니다.

03 이유

먼저 지방보조금법 제6조제2항 전단에서는 지방자치단체의 장은 법령에 명시적 근거가 있는 경우 외에는 지방보조금을 운영비로 교부할 수 없다고 규정하고 있는데, 해당 규정은 구 「지방재정법」(2014년 5월 28일 법률 제12687호로 일부개정된 것을 말함) 제32조의2

제2항에서 지방재정의 건전성을 강화하기 위해 지방자치단체의 보조금 관리체계를 강화하려는 취지로 신설된 것¹⁾으로, 이후 지방보조금의 관리체계를 정비·강화함으로써 지방보조금의 적정한 지급과 효율적 관리를 도모하기 위해 지방보조금법을 별도로 제정하고 「지방재정법」상 지방보조금과 관련된 조문을 분리하여 지방보조금법으로 규정한 것인 점²⁾을 고려할 때, 지방보조금법 제6조제2항 전단에 따른 “법령에 명시적 근거가 있는 경우”란 법령에서 지방보조금을 운영비로 교부할 수 있도록 명시하고 있거나 적어도 그에 상응하는 명문의 규정이 있는 경우이어야 할 것이고, 지방자치단체의 포괄적 책무를 규정하고 있는 추상적·선언적 규정만 두고 있는 경우에는 해당 규정을 운영비에 대한 지방교부금의 명시적인 근거로 볼 수는 없다고 할 것³⁾입니다.

그런데 성균관·향교·서원법 제2조제4호에 따르면 “성균관·향교·서원전통문화”란 성균관, 향교 및 서원을 중심으로 형성된 유형의 문화유산과 이에 따라 여러 세대에 걸쳐 전승되어 온 무형의 문화유산을 말하고, 같은 법 제3조제3항에서는 국가 및 지방자치단체는 “성균관·향교·서원전통문화”의 계승·발전을 위하여 예산의 범위에서 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다고만 규정하고 있을 뿐, 성균관, 향교, 서원이라는 교육기관의 운영에 관한 사항에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않고, 그에 상응하는 규정으로 볼 만한 명시적 규정도 없는바, 성균관·향교·서원법 제3조제3항은 성균관·향교·서원전통문화의 계승·발전을 위한 국가와 지방자치단체의 책무를 규정하고 있는 추상적·선언적 규정에 해당한다고 할 것이므로, 이를 근거로 성균관·향교·서원의 운영비로 지방보조금을 교부할 수는 없다고 할 것입니다.

아울러 성균관·향교·서원법령의 규정 체계를 살펴보면, 성균관·향교·서원법 제9조제1항에서는 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 성균관·향교·서원전통문화의 계승·발전에 필요한 경우 지역주민·시민단체·전문가 등으로 구성된 협의체(이하 “협의체”라 함)를 설치·운영할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 협의체의 “설치·운영”에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제6조제2항 본문에서는 협의체의 회의에 출석하는 위원과 관계 전문가 등에게는 예산의 범위에서 수당과 여비, 그 밖의 경비를 지급할 수 있다고 구체적으로 규정하고 있는 반면, 성균관·향교·서원에 대해서는 이와 같은 운영비 지급에 관한 명문의 규정이 없다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

1) 2014. 5. 28. 법률 제12678호로 일부개정된 「지방재정법」 개정이유 및 주요내용 참조

2) 2021. 1. 12. 법률 제17892호로 제정된 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제정이유 및 주요내용 참조

3) 법제처 2014. 11. 19. 회신 14-0685 해석례 참조

따라서 지방자치단체의 장은 성균관·향교·서원법 제3조제3항을 근거로 성균관·향교·서원에 지방보조금을 운영비로 교부할 수 없습니다.



관계법령

성균관·향교·서원전통문화의 계승·발전 및 지원에 관한 법률

제3조(국가 등의 책무) ①·② (생략)

③ 국가 및 지방자치단체는 성균관·향교·서원전통문화의 계승·발전을 위하여 예산의 범위에서 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.

지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률

제6조(지방보조금의 예산 편성 및 운영) ① (생략)

② 지방자치단체의 장은 법령에 명시적 근거가 있는 경우 외에는 지방보조금을 운영비로 교부할 수 없다. 이 경우 운영비로 사용할 수 있는 경비의 종목은 대통령령으로 정한다.

③ (생략)

질의제목 5

▶ 안전번호 25-0078

문화체육관광부 - 문화관광부령 제26호 「관광진흥법 시행규칙」 시행일 전에 관광특구로 지정받은 지역이 법률 제8531호 「관광진흥법」 제70조제1항에 따른 지정요건의 적용을 받는지(문화관광부령 제26호 「관광진흥법 시행규칙」 부칙 제2항 및 문화관광부령 제179호 「관광진흥법 시행규칙」 부칙 제2조 등 관련)

01 질의요지

종전 「관광진흥법 시행규칙」(1999년 6월 26일 문화관광부령 제26호로 전부개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 같음)의 시행일인 1999년 6월 26일 전에 관광특구로 지정된 지역은 개정 「관광진흥법」(2007년 7월 19일 법률 제8531호로 일부개정되어 2007년 10월 20일 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제70조제1항에 따른 지정요건의 적용을 받는지?

02 회답

종전 「관광진흥법 시행규칙」의 시행일인 1999년 6월 26일 전에 관광특구로 지정된 지역은 개정 「관광진흥법」 제70조제1항에 따른 지정요건의 적용을 받지 않습니다.

03 이유

종전 「관광진흥법」(1999년 1월 21일 법률 제5654호로 전부개정되어 1999년 3월 22일 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제67조제1항에서는 관광특구는 관광지등 또는 외국인관광객이 주로 이용하는 지역 중에서 시·도지사의 신청에 의하여 문화관광부장관이 지정한다고 규정하고 있고, 종전 「관광진흥법 시행규칙」 제59조제1항에서는 관광특구 지정요건을 규정하면서, 같은 규칙 부칙 제2항에서는 같은 규칙 시행 당시 종전의 규정에 의하여 관광특구로 지정된 지역은 제59조의 개정규정에 의한 지정요건에 적합한 것으로 본다는 경과조치를 규정하고 있으며, 이후 관광진흥법령에서는 종전 「관광진흥법 시행규칙」에서 규정하고 있던 지정요건에 관한 사항을 구 「관광진흥법 시행령」(2005년 4월

22일 대통령령 제18800호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제56조의2에 상항하여 규정하면서 그 지정요건을 강화하였고¹⁾, 같은 영 부칙 제4조에서는 같은 영 제56조의2의 개정규정은 이 영 시행 후 지정되는 관광특구부터 적용한다는 적용례를 규정하고 있는 한편, 구 「관광진흥법 시행규칙」(2005년 5월 6일 문화관광부령 제115호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제59조제1항에서는 구 「관광진흥법 시행령」 제56조의2의 위임에 따른 관광특구 지정요건의 세부기준을 규정하면서, 같은 규칙 제59조의 개정규정에 관한 부칙은 별도로 규정하지 않았습니다.

개정 「관광진흥법」에서는 구 「관광진흥법 시행령」에서 규정하고 있던 관광특구 지정요건에 관한 사항을 같은 법 제70조제1항에 상항하여 규정하고, 이에 따라 개정 「관광진흥법 시행령」(2007년 11월 13일 대통령령 제20374호로 전부개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제58조 및 개정 「관광진흥법 시행규칙」(2007년 12월 31일 문화관광부령 제179호로 전부개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제64조에서는 지정요건의 실질적인 내용 변경 없이 개정 「관광진흥법」 제70조제1항에서 위임한 사항을 규정하고 있으며, 개정 「관광진흥법 시행규칙」 부칙 제2조에서는 문화관광부령 제26호 관광진흥법시행규칙 개정령의 시행일인 1999년 6월 26일 당시 종전의 규정에 따라 관광특구로 지정된 지역은 제64조의 개정규정에 따른 지정요건의 세부기준에 적합한 것으로 본다는 경과조치를 규정하고 있는바, 이 사안에서는 종전 「관광진흥법 시행규칙」의 시행일인 1999년 6월 26일 전에 관광특구로 지정된 지역이 개정 「관광진흥법」 제70조제1항에 따른 지정요건의 적용을 받는다고 볼 것인지가 문제됩니다.

먼저 경과조치는 새로 제정되거나 개정된 법령에 의한 기득권 침해 방지 등의 정책적 필요에 의해 특정한 사안이나 사람에 대해 구법령을 적용하기 위해 두는 것²⁾인데, 종전 「관광진흥법 시행규칙」 부칙 제2항에서는 “이 규칙 시행당시 종전의 규정에 의하여 관광특구로 지정된 지역은 제59조의 개정규정에 의한 지정요건에 적합한 것으로 본다”는 경과조치를 두어 종전 「관광진흥법 시행규칙」의 시행일인 1999년 6월 26일 전에 관광특구로 지정된 지역에 대해서는 같은 규칙 제59조에 따른 지정요건이 적용되지 않음을 명시적으로 규정한바, 이는 신법령 시행 전 이미 관광특구로 지정된 지역에 대해서는 구법령의 지정요건을 신법령의 지정요건으로 인정하여 해당 지역을 신법령의 지정요건 적용 대상에서 제외한 것³⁾으로서,

1) 관광특구로 지정될 수 있는 지역의 요건으로 임야·농지 등 관광활동과 직접적인 관련성이 없는 토지가 관광특구 전체 면적의 10퍼센트를 초과하지 않도록 하는 요건이 신설되는 등 지정요건 일부가 강화됨(구 「관광진흥법 시행령」 제56조의2 참조)

2) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.643 참조

3) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.643 참조

1999년 6월 26일 전에 관광특구로 지정된 지역에 대해서는 이 사안 특구 지정시의 「관광진흥법 시행규칙」(1999년 6월 26일 문화관광부령 제26호로 전부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 같음) 제23조의3제1항에 따른 지정요건보다 강화된 요건을 새로이 적용받지 않도록 함으로써 해당 지역 이해관계인들의 기득권 및 신뢰를 법적으로 보호하려는 취지로 볼 수 있습니다.

다음으로 구 「관광진흥법 시행령」 부칙 제4조에서는 “제56조의2의 개정규정은 이 영 시행후 지정되는 관광특구부터 적용한다”는 적용례를 두어 같은 영 제56조의2에 따른 지정요건은 같은 영의 시행일(2005년 4월 22일) 후에 지정되는 관광특구부터 적용됨을 명시적으로 규정한 한편, 그 위임에 따라 구 「관광진흥법 시행규칙」 제59조제1항에서는 관광특구 지정요건의 세부기준을 규정하면서, 같은 규칙 제59조의 개정규정과 관련한 별도의 부칙을 두지 않았는데, ① 구 「관광진흥법 시행령」 부칙 제4조에서 적용례를 둔 취지는 같은 영 제56조의2가 신설됨에 따라 해당 관광특구의 지정요건을 적용하는 시기 및 그 대상에 대하여 구체적으로 규정함으로써 집행상의 논란을 방지하는 한편, 같은 영의 시행일인 2005년 4월 22일 전에 관광특구로 이미 지정받은 지역에 대해서는 강화된 관광특구의 지정요건이 적용되지 않도록 한 것이고⁴⁾, ② 종전 「관광진흥법 시행규칙」 부칙 제2항은 「관광진흥법 시행규칙」이 전부개정되지 않는 이상 해당 법령이 일부개정을 거듭하더라도 그 효력을 계속 유지하고 있는 것⁵⁾이므로, 이러한 사항을 종합적으로 고려하면 구 「관광진흥법 시행령」이 시행된 당시에도 종전 「관광진흥법 시행규칙」 부칙 제2항 및 구 「관광진흥법 시행령」 부칙 제4조에 따라 종전 「관광진흥법 시행규칙」의 시행일인 1999년 6월 26일 전에 관광특구로 지정된 지역에 대해서는 이전보다 강화된 지정요건(구 「관광진흥법 시행령」 제56조의2)이 적용되지 않고, 이 사안 특구 지정시의 「관광진흥법 시행규칙」 제23조의3제1항에 따른 지정요건이 적용된다고 보는 것이 타당할 것입니다.

그리고 전부개정이 이루어진 개정 「관광진흥법 시행규칙」에서는 부칙 제2조에서 “문화관광부령 제26호 관광진흥법시행규칙개정령의 시행일인 1999년 6월 26일 당시 종전의 규정에 따라 관광특구로 지정된 지역은 제64조의 개정규정에 따른 지정요건의 세부기준에 적합한 것으로 본다”는 경과조치를 두었는데, 전부개정은 기존 법령을 폐지하고 새로운 법령을 제정하는 것과 마찬가지로 종전의 본칙은 물론 부칙 규정도 모두 소멸하여 특별한 사정이 없으면 종전의 부칙도 모두 실효되는 것으로 볼 수 있을 것이나⁶⁾, 전부개정된 법령에서 종전

4) 법제처 2024. 12. 16. 회신 24-0809 해석례 참조

5) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.706 참조

6) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2011두27919 판결례 참조

법령 부칙의 경과규정을 계속 적용한다는 별도 규정을 두는 경우에는 그 효력이 존속한다고 할 것이므로⁷⁾, 개정 「관광진흥법 시행규칙」에서 법령의 전부개정에 따라 종전 부칙 중 현재까지 유효한 부칙을 개정 「관광진흥법 시행규칙」에 다시 규정⁸⁾하면서 그 중 하나로서 같은 규칙 부칙 제2조에서 종전 「관광진흥법 시행규칙」 부칙 제2항과 관련한 경과조치를 둔 것인바, 비록 개정 「관광진흥법 시행규칙」 부칙 제2조에서 “제64조의 개정규정에 따른 지정요건의 세부기준”에 적합한 것으로 본다고 규정하였다고 하더라도, 이는 관광특구의 지정요건이 부령에서 대통령령, 법률로 상향하여 규정되는 과정에서 최종적으로 부령에서는 지정요건의 세부기준만을 규정하게 됨에 따라 같은 규칙 부칙 제2조에서도 종전 「관광진흥법 시행규칙」 부칙 제2항의 문언을 일부 수정하여 규정한 것으로 보아야 할 것이지, 1999년 6월 26일 전에 관광특구로 지정된 지역에 대해 개정 「관광진흥법」 제70조제1항제2호 외에 같은 항 제1호, 제3호 및 제4호에 따른 지정요건을 소급해서 적용하려는 취지로 볼 수는 없습니다.

따라서 종전 「관광진흥법 시행규칙」의 시행일인 1999년 6월 26일 전에 관광특구로 지정된 지역은 개정 「관광진흥법」 제70조제1항에 따른 지정요건의 적용을 받지 않습니다.

7) 법제처 2022. 10. 28. 회신 22-0499 해석례 참조

8) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.707 참조

**관광진흥법 시행규칙(1999. 6. 26. 문화관광부령 제26호로 전부개정되어 같은 날 시행된 것)**

제59조(관광특구의 지정신청등) ①법 제67조의 규정에 의하여 시·도지사가 관광특구의 지정을 신청하는 경우 그 대상지역은 다음 각호의 요건에 적합하여야 하며, 해당지역주민등의 의견을 수렴하여야 한다.

1. 지정하고자 하는 지역안에接客시설, 쇼핑·상가시설, 휴양·오락시설, 숙박시설, 공공편익시설, 관광안내시설등이 분포되어 있어 외국인 관광객의 다양한 관광수요를 충족시킬 수 있을 것
 2. 통계전문기관의 조사결과 당해지역의 최근 1년간 외국인 관광객이 10만명이상일 것
 3. 지정하고자 하는 지역이 다른 지역과 바다·산림·하천 또는 도로등에 의하여 명확히 구분될 것
- ② ~ ④ (생 략)

문화관광부령 제26호 관광진흥법 시행규칙 부칙

②(관광특구의 경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 규정에 의하여 관광특구로 지정된 지역은 제59조의 개정규정에 의한 지정요건에 적합한 것으로 본다.

관광진흥법 시행령(2005. 4. 22. 대통령령 제18800호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것)

제56조의2(관광특구의 지정요건) 법 제67조의 규정에 의하여 관광특구로 지정될 수 있는 지역은 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 지역으로 한다.

1. 문화관광부령이 정하는 바에 따라接客시설, 상가시설, 휴양·오락시설, 숙박시설, 공공편익시설 및 관광안내시설이 분포되어 있어 외국인 관광객의 관광수요를 충족시킬 수 있는 지역일 것
2. 문화관광부장관이 고시하는 기준을 갖춘 통계전문기관의 통계 결과 당해 지역의 최근 1년간 외국인 관광객이 10만명(서울특별시 50만명) 이상일 것
3. 임야·농지·공업용지 또는 택지 등 관광활동과 직접적인 관련성이 없는 토지가 관광특구 전체 면적의 10퍼센트를 초과하지 아니할 것
4. 제1호 내지 제3호의 요건을 갖춘 지역이 서로 분리되어 있지 아니할 것

대통령령 제18800호 관광진흥법 시행령 부칙

제4조(관광특구의 지정요건에 관한 적용례) 제56조의2의 개정규정은 이 영 시행 후 지정되는 관광특구부터 적용한다.

관광진흥법(2007. 7. 19. 법률 제8531호로 일부개정되어 2007. 10. 20. 시행된 것)

제70조(관광특구의 지정) ①관광특구는 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 지역 중에서 시장·군수·구청장의 신청에 따라 시·도지사가 지정한다.

1. 외국인 관광객 수가 대통령령으로 정하는 기준 이상일 것
2. 문화관광부령으로 정하는 바에 따라 관광안내시설, 공공편의시설 및 숙박시설 등이 갖추어져 외국인 관광객의 관광수요를 충족시킬 수 있는 지역일 것
3. 임야·농지·공업용지 또는 택지 등 관광활동과 직접적인 관련성이 없는 토지의 비율이 대통령령으로 정하는 기준을 초과하지 아니할 것
4. 제1호부터 제3호까지의 요건을 갖춘 지역이 서로 분리되어 있지 아니할 것

② (생 략)

관광진흥법 시행령(2007. 11. 13. 대통령령 제20374호로 전부개정되어 같은 날 시행된 것)

제58조(관광특구의 지정요건) ① 법 제70조제1항제1호에서 “대통령령으로 정하는 기준”이란 문화관광부장관이 고시하는 기준을 갖춘 통계전문기관의 통계결과 해당 지역의 최근 1년간 외국인 관광객 수가 10만명(서울특별시 50만 명)인 것을 말한다.

② 법 제70조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 기준”이란 관광특구 전체 면적 중 임야·농지·공업용지 또는 택지 등 관광활동과 직접적인 관련성이 없는 토지가 차지하는 비율이 10퍼센트인 것을 말한다.

관광진흥법 시행규칙(2007. 12. 31. 문화관광부령 제179호로 전부개정되어 같은 날 시행된 것)

제64조(관광특구의 지정신청 등) ① 법 제70조제1항제2호에 따른 관광특구 지정요건의 세부기준은 별표 21과 같다.

②·③ (생 략)

문화관광부령 제179호 관광진흥법 시행규칙 부칙

제2조(관광특구에 관한 경과조치) 문화관광부령 제26호 관광진흥법시행규칙개정령의 시행일인 1999년 6월 26일 당시 종전의 규정에 따라 관광특구로 지정된 지역은 제64조의 개정규정에 따른 지정요건의 세부기준에 적합한 것으로 본다.

질의제목 6

▶ 안전번호 25-0194, 25-0336, 25-0337

문화체육관광부 - 골프장업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 이용하기로 1년 미만의 기간을 정하여 약정한 경우에도 회원제 골프장의 “회원”에 해당하는지 등(「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제2조제4호 등 관련)

01 질의요지

「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」(이하 “체육시설법”이라 함) 제2조제4호에서는 “회원”이란 1년 이상의 기간을 정하여 체육시설업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 일반이용자보다 유리한 조건으로 우선적으로 이용하기로 체육시설업자¹⁾와 약정한 자를 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제10조의2제1항에서는 골프장업의 세부 종류는 다음 각 호와 같다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 회원을 모집하여 경영하는 골프장인 회원제 골프장업을, 제2호에서는 회원을 모집하지 아니하고 경영하는 골프장업인 비회원제 골프장업을 규정하고 있는바,

가. 골프장업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 이용하기로 1년 미만의 기간을 정하여 약정한 경우에 회원제 골프장의 “회원”에 해당하는지²⁾?

나. 골프장업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 이용하기로 일반이용자보다 유리한 조건으로 약정하지 않은 경우에 회원제 골프장의 “회원”에 해당하는지³⁾?

다. 골프장업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 일반이용자보다 우선적으로 이용하는 사항을 약정하지 않은 경우에 회원제 골프장의 “회원”에 해당하는지⁴⁾?

02 회답

- 1) 체육시설법 제12조에 따른 사업계획 승인을 받은 자를 포함하며, 이하 같음
- 2) 질의 가.는 ‘1년 이상의 기간’ 요건에 관한 것으로, 그 외에 다른 요건은 모두 충족된 것을 전제로 함.
- 3) 질의 나.는 ‘유리한 조건’ 요건에 관한 것으로, 그 외에 다른 요건은 모두 충족된 것을 전제로 함.
- 4) 질의 다.는 ‘우선적으로 이용’ 요건에 관한 것으로, 그 외에 다른 요건은 모두 충족된 것을 전제로 함.

가. 질의 가에 대해

골프장업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 이용하기로 1년 미만의 기간을 정하여 약정한 경우에는 회원제 골프장의 “회원”에 해당하지 않습니다.

나. 질의 나에 대해

골프장업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 이용하기로 일반이용자보다 유리한 조건으로 약정하지 않은 경우에는 회원제 골프장의 “회원”에 해당하지 않습니다.

다. 질의 다에 대해

골프장업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 일반이용자보다 우선적으로 이용하는 사항을 약정하지 않은 경우에는 회원제 골프장의 “회원”에 해당하지 않습니다.

03 이유

가. 질의 가, 나 및 다의 공통사항

체육시설법 제2조제4호에서는 “회원”이란 1년 이상의 기간을 정하여 체육시설업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 일반이용자보다 유리한 조건으로 우선적으로 이용하기로 체육시설업자와 약정한 자를 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제5호에서는 “일반이용자”란 1년 미만의 일정 기간을 정하여 체육시설의 이용 또는 그 시설을 활용한 교습행위의 대가를 내고 체육시설을 이용하거나 그 시설을 활용한 교습을 받기로 체육시설업자와 약정한 사람을 말한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제10조의2제1항에서는 골프장업의 세부 종류를 회원을 모집하여 경영하는 골프장인 회원제 골프장업(제1호)과 회원을 모집하지 아니하고 경영하는 골프장업인 비회원제 골프장업(제2호)으로 정하고 있는 한편,

체육시설법 제21조제2항에서는 비회원제 골프장을 운영하는 자는 예약 순서대로 예약자가 골프장을 이용하도록 하되, 예약자가 없는 경우에는 이용자의 도착 순서에 따라 골프장을 이용하게 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 비회원제 골프장을 운영하는 자는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다고 규정하면서 같은

항 제1호에서는 회원을 모집하는 행위를, 같은 항 제2호에서는 이용 우선권을 제공하거나 판매하는 행위를 규정하고 있는바, 이 사안에서는 회원제 골프장의 “회원”은 ① 1년 이상의 기간, ② 일반이용자보다 유리한 조건, ③ 우선적으로 이용 요건 모두를 충족하는 경우에만 해당하는지가 문제됩니다.

나. 질의 가에 대해

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데⁵⁾, 체육시설법 제2조제4호에서는 “회원”이란 1년 이상의 기간을 정하여 체육시설업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 일반이용자보다 유리한 조건으로 우선적으로 이용하기로 체육시설업자와 약정한 자를 말한다고 규정하고 있는바, 일반적으로 ‘이상’이란 수량이나 정도가 일정한 기준보다 더 많거나 나음을 의미하고⁶⁾, 같은 조 제5호에서 일반이용자를 정의하면서 ‘1년 미만’의 기간을 규정하여 회원과 일반이용자의 약정 기간을 각각 ‘1년 이상’과 ‘1년 미만’으로 구분하여 규정하고 있으므로, 이 사안과 같이 1년 ‘미만’의 기간을 정하여 약정한 경우는 회원에 해당하지 않는 것이 문언상 명확합니다.

그리고 회원의 정의규정에 대한 입법연혁을 살펴보면, 종전에는 회원의 약정 기간에 대하여 별도로 규정하고 있지 않던 것을, 2022년 1월 18일 법률 제18781호로 일부개정된 체육시설법에서 ‘1년 이상의 기간’ 요건을 추가한 것인데, 이는 회원제 골프장의 회원은 일반 이용자보다 우선하여 체육시설을 이용하거나 체육시설을 이용하는 교습행위를 유리한 조건으로 이용할 권리가 있음에도 불구하고 회원제 골프장이 병설 대중골프장을 이용해 편법으로 회원권을 과도하게 분양하는 등 기존 회원의 권리를 침해하는 피해가 발생함에 따라⁷⁾, 이러한 대중골프장의 회원모집 및 유사 행위 등의 편법운영을 막기 위해 체육시설의 회원 개념을 재정의하고, 대중골프장 운영자의 회원 모집행위 금지, 예약자 우선 이용제공 등 체육시설의 이용 질서를 규정한 것으로서⁸⁾, 이처럼 회원의 범위를 명확하게 하기 위하여 그 범위를 제한하는 방향으로 개정된 입법연혁 및 취지에 비추어 보더라도 회원제 골프장의 회원은 ‘1년 이상의 기간’ 요건을 충족해야 한다고 보는 것이 타당합니다.

5) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

6) 국립국어원 표준국어대사전 참조

7) 2021. 3. 16. 의안번호 제2108817호로 발의된 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 문화체육관광위원회 심사보고서 참조

8) 2022. 1. 18. 법률 제18781호로 일부개정된 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 개정이유 참조

따라서 골프장업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 이용하기로 1년 미만의 기간을 정하여 약정한 경우에는 회원제 골프장의 “회원”에 해당하지 않습니다.

다. 질의 내에 대해

먼저 “회원”의 정의규정에 대한 입법연혁을 살펴보면, 종전에는 일반적으로 어느 것이 선택되어도 차이가 없는 둘 이상의 일을 나열할 때 사용되는 보조사 “거나”를 사용하여⁹⁾ “회원”이란 체육시설업의 시설 또는 그 시설을 이용한 교습행위를 일반이용자보다 우선적으로 이용하거나 유리한 조건으로 이용하기로 체육시설업자와 약정한 자를 말한다고 규정하고 있어, 두 가지 기준 중 어느 하나에만 해당하더라도 회원으로 볼 수 있던 것을, 2022년 1월 18일 법률 제18781호로 체육시설법을 일부개정하면서 1년 이상의 기간을 정하여 체육시설업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 일반이용자보다 유리한 조건으로 우선적으로 이용하기로 체육시설업자와 약정한 자를 말한다고 규정하여 두 가지 요건을 모두 충족해야 하는 것으로 회원의 범위를 명확히¹⁰⁾ 한 것입니다.

이러한 법률 개정의 취지는 회원제 골프장의 회원은 일반 이용자보다 우선하여 체육시설을 이용하거나 체육시설을 이용하는 교습행위를 유리한 조건으로 이용할 권리가 있음에도 불구하고 회원제 골프장이 병설 대중골프장을 이용해 편법으로 회원권을 과도하게 분양하는 등 기존 회원의 권리를 침해하는 피해가 발생함에 따라¹¹⁾, 대중골프장의 회원모집 및 유사 행위 등의 편법운영을 막기 위해 체육시설의 회원 개념을 재정의하고, 대중골프장 운영자의 회원 모집행위 금지, 예약자 우선 이용제공 등 체육시설의 이용 질서를 규정하려는 것으로서¹²⁾, 이러한 입법연혁과 개정취지에 비추어 보더라도 회원제 골프장의 “회원”은 일반이용자보다 유리한 조건 요건을 충족해야 한다고 보는 것이 타당합니다.

그리고 체육시설법 제2조제4호에서는 “회원”이란 1년 이상의 기간을 정하여 체육시설업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 일반이용자보다 유리한 조건으로 우선적으로 이용하기로 체육시설업자와 약정한 자를 말한다고 규정하고 있는데, 여기서 ‘유리한 조건’이란 통상적으로 가격혜택을 의미¹³⁾하고, 같은 조 제5호에서는 “일반이용자”를

9) 국립국어원 표준국어대사전 참조

10) 2021. 3. 16. 의안번호 제2108817호로 발의된 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 문화체육관광위원회 심사보고서 참조

11) 2021. 3. 16. 의안번호 제2108817호로 발의된 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 문화체육관광위원회 심사보고서 참조

12) 2022. 1. 18. 법률 제18781호로 일부개정된 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 개정이유 참조

‘이용료를 내고 체육시설을 이용하는 자’로 규정하고 있는바, 회원제 골프장의 “회원”은 골프장업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 일반이용자보다 이용료 할인 등의 유리한 조건의 혜택을 받고 이용하기로 약정한 자여야 한다고 해석하는 것이 관련 규정의 체계에 부합하는 해석입니다.

또한 침익적 행정처분의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하고 행정처분의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 되는데¹⁴⁾ 체육시설법 제21조제3항에서는 비회원제 골프장을 운영하는 자는 회원을 모집하는 행위(제1호)를 하여서는 아니 된다고 규정하면서, 같은 법 제30조제5호에서는 같은 법 제21조에 따른 체육시설의 이용 질서를 위반한 때 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 기간을 정하여 그 시정을 명할 수 있고, 같은 법 제32조제2항제6호에서는 같은 법 제30조에 따른 시정명령을 받고 이를 이행하지 아니한 경우 영업정지를 명할 수 있다고 규정하고 있는바, 체육시설법상 “회원”을 일반이용자보다 유리한 조건 요건을 충족하지 않는 자까지 의미한다고 해석하는 것은 침익적 행정처분의 근거 규정을 체육시설업자에게 불리한 방향으로 지나치게 확장 해석하는 것으로서 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 골프장업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 이용하기로 일반이용자보다 유리한 조건으로 약정하지 않은 경우에는 회원제 골프장의 “회원”에 해당하지 않습니다.

라. 질의 다에 대해

체육시설법 제2조제4호에서는 “회원”이란 1년 이상의 기간을 정하여 체육시설업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 일반이용자보다 유리한 조건으로 우선적으로 이용하기로 체육시설업자와 약정한 자를 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제10조의2제1항에서는 골프장업의 세부 종류를 회원제 골프장업과 비회원제 골프장업으로 구분하여 규정하면서, 같은 법 제21조제2항에서는 비회원제 골프장을 운영하는 자는 예약 순서대로 예약자가 골프장을 이용하도록 하고, 같은 조 제3항에서는 비회원제 골프장을 운영하는 자는 이용 우선권을 제공하거나 판매하는 행위(제2호) 등을 하여서는 아니된다고 규정하여 비회원제 골프장에서의 우선 이용권 제공을 금지하고 있는바, 이러한 규정들을 종합해 보면, 회원제 골프장의 회원은 일반이용자보다 ‘우선적으로 이용’하기로 약정한 자여야 한다고 해석하는

13) 2021. 3. 16. 의안번호 제2108817호로 발의된 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 문화체육관광위원회 심사보고서 참조

14) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

것이 관련 규정의 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 회원의 정의규정에 대한 입법연혁을 살펴보면, 종전에는 일반적으로 어느 것이 선택되어도 차이가 없는 둘 이상의 일을 나열할 때 사용되는 보조사 “거나”를 사용하여¹⁵⁾ “회원”이란 체육시설업의 시설 또는 그 시설을 이용한 교습행위를 일반이용자보다 “우선적으로 이용하거나 유리한 조건으로 이용하기로” 체육시설업자와 약정한 자를 말한다고 규정하고 있어, 두 가지 기준 중 어느 하나에만 해당하더라도 회원으로 볼 수 있던 것을, 2022년 1월 18일 법률 제18781호로 체육시설법을 일부개정하면서 1년 이상의 기간을 정하여 체육시설업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 일반이용자보다 “유리한 조건으로 우선적으로 이용하기로” 체육시설업자와 약정한 자를 말한다고 규정하여 두 가지 요건을 모두 충족해야 하는 것으로 회원의 범위를 명확히¹⁶⁾ 한 것입니다.

이러한 법률 개정의 취지는 회원제 골프장의 회원은 일반 이용자보다 우선하여 체육시설을 이용하거나 체육시설을 이용하는 교습행위를 유리한 조건으로 이용할 권리가 있음에도 불구하고 회원제 골프장이 병설 대중골프장을 이용해 편법으로 회원권을 과도하게 분양하는 등 기존 회원의 권리를 침해하는 피해가 발생함에 따라¹⁷⁾, 대중골프장의 회원모집 및 유사 행위 등의 편법운영을 막기 위해 체육시설의 회원 개념을 재정의하고, 대중골프장 운영자의 회원 모집행위 금지, 예약자 우선 이용제공 등 체육시설의 이용 질서를 규정하려는 것으로서¹⁸⁾, 이러한 입법연혁과 개정취지에 비추어 보더라도 회원제 골프장의 회원은 ‘일반이용자보다 우선적으로 이용’ 요건을 충족해야 한다고 보는 것이 타당합니다.

또한 체육시설법 제21조제3항제2호에서는 비회원제 골프장을 운영하는 자는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 회원을 모집하는 행위를, 같은 항 제2호에서는 이용 우선권을 제공하거나 판매하는 행위를 규정하고 있는데, 이처럼 체육시설법에서 비회원제 골프장의 이용 질서와 관련하여 회원을 모집하는 행위를 금지하는 것 외에도 이용 우선권을 제공하거나 판매하는 행위를 금지하는 별도의 명시적인 규정을 두고 있는 것은 이용 우선권은 체육시설법상으로는 거래 현실에서 회원권의 핵심 징표에 해당¹⁹⁾하기 때문인 것으로, 이러한 규정 체계를 고려하면 회원제

15) 국립국어원 표준국어대사전 참조

16) 2021. 3. 16. 의안번호 제2108817호로 발의된 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 문화체육관광위원회 심사보고서 참조

17) 2021. 3. 16. 의안번호 제2108817호로 발의된 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 문화체육관광위원회 심사보고서 참조

18) 2022. 1. 18. 법률 제18781호로 일부개정된 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 개정이유 참조

골프장의 “회원”에 해당하기 위해서는 일반이용자보다 우선적으로 이용하는 요건을 충족해야 한다고 할 것입니다.

따라서 골프장업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 일반이용자보다 우선적으로 이용하는 사항을 약정하지 않은 경우에는 회원제 골프장의 “회원”에 해당하지 않습니다.



관계법령

체육시설의 설치·이용에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 3. (생 략)
4. “회원”이란 1년 이상의 기간을 정하여 체육시설업의 시설 또는 그 시설을 활용한 교습행위를 일반이용자보다 유리한 조건으로 우선적으로 이용하기로 체육시설업자(제12조에 따른 사업계획 승인을 받은 자를 포함한다)와 약정한 자를 말한다.
5. “일반이용자”란 1년 미만의 일정 기간을 정하여 체육시설의 이용 또는 그 시설을 활용한 교습행위의 대가(이하 “이용료”라 한다)를 내고 체육시설을 이용하거나 그 시설을 활용한 교습을 받기로 체육시설업자와 약정한 사람을 말한다.

제10조의2(골프장업의 세부 종류) ① 골프장업의 세부 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 회원제 골프장업: 회원을 모집하여 경영하는 골프장업
 2. 비회원제 골프장업: 회원을 모집하지 아니하고 경영하는 골프장업
- ②·③ (생 략)

19) 대구지방법원 상주지원 2023. 2. 23. 선고 2021가합5566 판결례 참조

CHAPTER

4

국방·국가보훈

제1절 국방

제1절 국방

질의제목 1

▶ 안전번호 25-0102

민원인 - 사회복지요원에 대한 소집해제처분이 취소된 경우 지방병무청장은 「병역법」 제33조에 따른 연장복무 등을 위하여 같은 법 제29조에 따른 사회복지요원 소집처분을 다시 하여야 하는지 여부(「병역법」 제29조 등 관련)

01 질의요지

「병역법」 제29조제1항 본문에서는 지방병무청장은 사회복지요원 소집 순서가 결정된 사람을 대상으로 복무기관을 정하여 사회복지요원을 소집한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 병무청장은 사회복지요원 소집이 연기된 사람으로서 그 사유가 없어진 사람 등 대통령령으로 정하는 사람에 대하여는 같은 조 제1항에도 불구하고 지방병무청장으로 하여금 따로 사회복지요원 소집을 하게 할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 제30조제2항에서는 사회복지요원이 복무를 이탈한 경우에는 그 복무이탈일수는 복무기간에 산입하지 아니한다고 규정하면서, 같은 조 제4항에서는 사회복지요원 복무기간의 계산과 소집해제 등 사회복지요원의 복무에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제57조제2항에서는 지방병무청장은 소집해제되는 달의 1일에 소집해제일을 명시하여 소집해제처분을 한다고 규정하고 있는 한편,

「병역법」 제33조제1항 본문에서는 사회복지요원이 정당한 사유 없이 복무를 이탈한 경우에는 그 이탈일수의 5배의 기간을 연장하여 복무하게 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제77조제2항에서는 병무청장은 지방병무청장의 명령이나 처분이 위법 또는 부당하다고 인정할 때에는 그 명령이나 처분을 중지하거나 취소할 수 있다고 규정하고 있는바,

사회복무요원에 대한 지방병무청장의 소집해제처분¹⁾에 따라 소집해제가 있는 후 복무기간 중 「병역법」 제30조제2항에 따른 복무이탈이 있었다는 점이 확인되어 병무청장이 같은 법 제77조제2항에 따라 그 소집해제처분을 취소한 경우, 같은 법 제33조에 따른 연장복무 등을 위하여 지방병무청장은 같은 법 제29조제1항 또는 제2항에 따라 위 사회복무요원에 대하여 사회복무요원 소집처분을 다시 하여야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 「병역법」 제33조에 따른 연장복무 등을 위하여 지방병무청장은 같은 법 제29조제1항 또는 제2항에 따른 사회복무요원 소집처분을 다시 하지 않아도 됩니다.

03 이유

「병역법」에 따르면 일반적으로 병역의무자는 19세가 되는 해에 병역을 감당할 수 있는지를 판정받기 위하여 병역판정검사를 받게 되고(제11조), 이러한 병역판정검사와 학력·연령 등 자질 등을 고려하여 보충역편입처분을 받은 후(제14조) 사회복무요원으로서의 복무를 명하는 사회복무요원 소집처분을 받게 되면(제29조), 국가기관, 지방자치단체 등의 공익목적에 필요한 사회서비스업무의 지원업무, 행정업무 등의 지원업무 등에 복무하게 되고(제26조), 복무기간이 경과하면 소집해제처분을 받아 소집해제됩니다.

그런데 「병역법」 제30조제2항에 따르면 사회복무요원이 복무를 이탈한 경우에는 그 복무이탈일수는 복무기간에 산입하지 아니하므로, 복무기간 중 복무이탈이 있어 복무를 마치지 못한 사회복무요원은 원칙적으로 복무기간이 만료되는 것을 전제로 하는 같은 법 제30조 및 같은 법 시행령 제57조 등에 따른 소집해제처분을 받고 소집해제될 수 없는바, 이 사안에서는 사회복무요원에 대한 지방병무청장의 소집해제처분이 있는 후 복무기간 중 복무이탈이 있었다는 점이 확인되어 그 소집해제처분이 취소된 경우, 지방병무청장이 같은 법 제33조에 따른 연장복무 등을 위하여 같은 법 제29조제1항 또는 제2항에 따른 사회복무요원 소집처분을 다시 하여야 하는지 여부가 문제됩니다.

1) 「병역법」 제30조제4항 및 같은 법 시행령 제57조에 따른 소집해제처분을 의미하며, 이하 같음

먼저 「병역법」 제29조에 따른 사회복무요원 소집처분은 보충역편입처분을 받은 사회복무요원 소집대상자에게 기초적 군사훈련과 구체적인 복무기관 및 복무분야를 정한 사회복무요원으로서의 복무를 명하는 구체적인 행정처분²⁾이고, 같은 법 제30조 및 같은 법 시행령 제57조 등에 따른 소집해제처분은 지방병무청장이 복무기간이 만료되는 사회복무요원에 대하여 소정의 절차를 거쳐 소집을 해제하는 행정처분으로, 사회복무요원소집처분과 소집해제처분은 별개의 법률효과를 발생시키는 서로 구분되는 행정처분이라 할 것인데, 이 사안과 같이 복무 이탈로 복무기간이 만료되지 않은 사회복무요원에 대한 소집해제처분에 하자가 있음을 이유로³⁾ 관련 법령에 따라 그 소집해제처분이 취소되는 경우 소집해제처분의 효력은 소멸된다 할 것이고, 별도의 규정이 없는 한 별개의 행정처분인 하자 없는 사회복무요원 소집처분까지 취소되거나 실효된다고 볼 수는 없으므로, 소집해제처분을 취소하는 처분을 받은 자는 사회복무요원으로 소집된 채로 복무가 만료되지 않은 상태에 있다고 할 것이고⁴⁾, 지방병무청장은 같은 법 제33조에 따른 연장복무 등을 위하여 이미 사회복무요원으로 소집되어 있는 자에 대해 같은 법 제29조 제1항 또는 제2항에 따른 소집처분을 다시 할 필요는 없다고 할 것입니다.

그리고 「병역법」 제29조제2항에서는 병무청장은 사회복무요원 소집이 연기된 사람으로서 그 사유가 없어진 사람 등 대통령령으로 정하는 사람에 대하여는 지방병무청장으로 하여금 따로 사회복무요원 소집을 하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제52조에서는 병역판정검사를 받고 그 해 소집을 희망하는 사람(제1호), 학군 군간부후보생 또는 의무·법무·군종·수의사관후보생으로서 해당 병적에서 제적되어 소집할 사람(제2호) 등 같은 법 제29조제2항에 따라 사회복무요원 소집 순서에 따르지 않고 따로 사회복무요원 소집을 할 수 있는 사람에 대하여 규정하고 있으며, 「사회복무요원 소집업무 규정」(병무청 훈령) 제3조에서는 사회복무요원 소집대상으로 병역판정검사결과 학력, 신체등급, 나이 등 자질을 고려하여 보충역에 편입된 사람(제1호), 부·모·배우자 또는 형제·자매 중 전사·순직자나 전·공상으로 인한 장애인이 있는 사유로 보충역에 편입된 사람(제2호) 등을 규정하고 있는바, 병역법령에서는 이미 사회복무요원소집처분을 받은 자나 소집해제처분 취소처분을 받은 자를 사회복무요원소집처분 대상자로 규정하고 있지 않습니다.

2) 대법원 2002. 12. 10. 선고 2001두5422 판결례 참조

3) 「병역법」 제30조제2항에 따라 사회복무요원이 복무를 이탈한 경우에는 그 복무이탈일수는 복무기간에 산입하지 아니함

4) 대법원 1985. 2. 28. 선고 85초13 판결례, 서울행정법원 2024. 6. 21. 선고 2023구합69169 판결례, 헌법재판소 2021. 6. 24. 선고 2018헌마526 결정례 등 참조

한편 소집해제처분이 취소되더라도 이미 소집해제처분을 받은 자에게 사회복지요원의 지위가 다시 부여된다고 볼 수 없고, 「병역법」 제33조제4항 단서에서 복무 이탈로 1년 6개월 이상의 징역 또는 금고의 실형을 선고받은 사람 등에 해당하는 경우에는 사회복지요원으로 소집하지 아니한다고 규정하고 있으므로 이 사안의 경우 같은 법 제29조에 따라 사회복지요원 소집처분을 다시 하여야 한다는 의견이 있으나, 같은 법 제33조제4항 단서에서 1년 6개월 이상의 징역 또는 금고의 실형을 선고받은 사람 등에 해당하는 경우에는 ‘사회복지요원으로 소집’하지 아니한다고 규정하고 있는 것은 구 「병역법」(2011년 7월 5일 법률 제10814호로 일부개정된 것) 제33조제4항에서 공익근무요원으로서 형의 선고를 받은 사람에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 남은 복무기간을 제26조제1항제1호 및 제2호에 따른 공익근무요원으로 복무하게 하되(본문), 1년 6개월 이상의 징역 또는 금고의 실형을 선고받은 사람 등의 경우에는 ‘그러하지 아니하다’(단서)고 규정하여 1년 6개월 이상의 실형을 선고받은 공익근무요원은 남은 복무기간을 복무하지 않도록 규정하고 있었던 것을 현행과 같이 개정한 것으로, 결국 「병역법」 제33조제4항 단서에서 규정하고 있는 ‘사회복지요원으로 소집하지 아니한다’는 것은 같은 항 본문과 달리 ‘남은 복무기간’을 사회복지요원으로 복무하게 하지 아니한다는 것을 의미한다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「병역법」 제33조에 따른 연장복무 등을 위하여 지방병무청장은 같은 법 제29조제1항 또는 제2항에 따른 사회복지요원 소집처분을 다시 하지 않아도 됩니다.



관계법령

병역법

제29조(사회복지요원의 소집 등) ① 지방병무청장은 사회복지요원 소집 순서가 결정된 사람을 대상으로 복무기관을 정하여 사회복지요원을 소집한다. 다만, 제26조제4항에 따라 선발한 사회복지요원은 복무기관과 복무분야를 정하여 따로 소집할 수 있다.

② 병무청장은 사회복지요원 소집이 연기된 사람으로서 그 사유가 없어진 사람 등 대통령령으로 정하는 사람에 대하여는 제1항에도 불구하고 지방병무청장으로 하여금 따로 사회복지요원 소집을 하게 할 수 있다.

③ 제1항과 제2항에 따라 사회복지요원으로 소집된 사람에 대하여는 제55조에 따른 군사교육소집을 하며, 그 군사교육소집 기간은 복무기간에 산입한다.

④ (생략)

제30조(사회복지요원의 복무기간 등) ① 사회복지요원의 복무기간은 2년 2개월로 한다.

② 사회복지요원이 징역·금고 또는 구류의 형을 받거나 복무를 이탈한 경우에는 그 형의 집행일수나 복무이탈일수는 복무기간에 산입하지 아니한다.

③ (생 략)

④ 사회복지요원 복무기간의 계산과 소집해제 등 사회복지요원의 복무에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제33조(사회복지요원의 연장복무 등) ① 사회복지요원이 정당한 사유 없이 복무를 이탈한 경우에는 그 이탈일수의 5배의 기간을 연장하여 복무하게 한다. 다만, 제89조의2제1호에 해당하는 사람의 경우에는 복무기간을 연장하지 아니한다.

② ~ ⑤ (생 략)

제77조(병무행정의 주관) ① (생 략)

② 병무청장은 지방병무청장의 명령이나 처분이 위법 또는 부당하다고 인정할 때에는 그 명령이나 처분을 중지하거나 취소할 수 있다.

병역법 시행령

제52조(사회복지요원 별도 소집 대상자) 법 제29조제2항에 따라 사회복지요원 소집 순서에 따르지 않고 따로 사회복지요원 소집을 할 수 있는 사람은 다음 각 호와 같다.

1. 병역판정검사를 받고 그 해 소집을 희망하는 사람
2. 학군 군간부후보생 또는 의무·법무·군종·수의사관후보생으로서 해당 병적에서 제적되어 소집할 사람
3. 사회복지요원 소집이 연기된 사람으로서 그 사유가 없어진 사람
4. 국외에서 귀국한 사람으로서 소집할 사람
5. 사회복지요원 소집 기피의 죄를 범한 사람으로서 형사처분이 종료된 사람 및 공소시효가 완성된 사람
6. 예술·체육요원, 공중보건 의사, 병역판정전담의사, 공익법무관, 공중방역수의사, 전문연구요원 또는 산업기능요원으로의 편입이 취소되어 소집할 사람
7. 제137조제7항에 따라 보충역으로 편입된 사람
8. 대체역법 제25조제2항에 따라 대체역의 편입이 취소되어 소집할 사람
9. 그 밖에 병무청장이 필요하다고 인정하는 사람

제56조(사회복지요원의 복무기간 등) ① 사회복지요원의 복무기간은 법 제29조에 따라 사회복지요원으로 소집된 날부터 기산한다.

② (생 략)

제57조(사회복지요원의 소집해제) ① 사회복지요원의 복무기관의 장은 제56조에 따른 복무기간이 만료될 사람의 명단, 보충역 복무기록표 및 병역증을 복무기간이 만료되는 달의 전달 10일까지 지방병무청장에게 송부하여야 한다.

② 지방병무청장은 소집해제되는 달의 1일에 소집해제일을 명시하여 소집해제처분을 하고, 사회복무요원 소집해제 처분서와 그 사실을 기재·정리한 병역증을 제1항에 따른 복무기관의 장에게 송부하여 소집해제일 당일 본인에게 병역증이 교부되도록 하여야 한다.

질의제목 2

▶ 안전번호 25-0313

민원인 - 사회복지요원에 대한 소집해제가 있는 후 복무이탈을 확인하여 소집해제처분이 취소된 경우, 해당 사회복지요원이 소집해제처분 취소 이후 복무하여야 하는 기간(「병역법」 제30조 등 관련)

01 질의요지

「병역법」 제30조에서는 사회복지요원의 복무기간 등에 대하여 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 사회복지요원이 복무를 이탈한 경우에는 그 복무이탈일수는 복무기간에 산입하지 아니한다고 규정하고 있는 한편,

「병역법」 제33조제1항에서는 사회복지요원이 정당한 사유 없이 복무를 이탈한 경우에는 그 이탈일수의 5배의 기간을 연장하여 복무하게 하되(본문), 같은 법 제89조의2제1호에 해당하는 사람의 경우에는 복무기간을 연장하지 아니한다(단서)고 규정하고 있고, 같은 법 제33조제4항 본문에서는 사회복지요원으로서 같은 법 제89조의2제1호에 따라 형을 선고받은 사람에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 남은 복무기간을 사회복지요원으로 복무하게 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제89조의2제1호에서는 사회복지요원으로서 정당한 사유 없이 통틀어 8일 이상 복무를 이탈하거나 해당 분야에 복무하지 아니한 사람은 3년 이하의 징역에 처한다고 규정하고 있는바,

사회복지요원에 대한 지방병무청장의 소집해제처분¹⁾에 따라 소집해제가 있는 후 복무기간 중 정당한 사유 없이 통틀어 7일 이하 복무를 이탈하였다는 점이 확인되어 병무청장이 「병역법」 제77조제2항에 따라 위 소집해제처분을 취소한 경우, 해당 사회복지요원이 소집해제처분 취소 이후 복무하여야 하는 기간은 복무이탈일수에 해당하는 기간인지, 아니면 복무이탈일수에 그 이탈일수의 5배의 기간을 더한 기간인지?

02 회답

이 사안의 경우, 사회복지요원이 소집해제처분 취소 이후 복무하여야 하는 기간은 복무이탈일수에 그 이탈일수의 5배의 기간을 더한 기간입니다.

1) 「병역법」 제30조제4항 및 같은 법 시행령 제57조에 따른 소집해제처분을 의미하며, 이하 같음

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데²⁾, 「병역법」 제30조 제1항에서는 사회복무요원의 복무기간에 대하여 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 사회복무요원이 복무를 이탈한 경우에는 그 복무이탈일수는 복무기간에 산입하지 아니한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제33조제1항에서는 사회복무요원이 정당한 사유 없이 복무를 이탈한 경우에는 그 이탈일수의 5배의 기간을 연장하여 복무하게 하되(본문), 같은 법 제89조의2제1호에 해당하는 사람의 경우에는 복무기간을 연장하지 아니한다(단서)고 규정하고 있고, 사회복무요원의 복무관리 및 행정처리 절차 등에 필요한 사항을 정하고 있는 병무청훈령인 「사회복무요원 복무관리 규정」 제2조제16호에서는 “복무이탈”이란 정당한 사유 없이 출근하지 아니하거나 해당 분야에 복무하지 아니하는 것을 말한다고 규정하고 있는바, 병역법령에 따라 사회복무요원이 복무기간 중 정당한 사유 없이 통틀어 7일 이하 복무를 이탈한 경우 복무이탈일수 동안 복무하였다고 볼 수 없어 해당 복무이탈일수는 복무기간에 산입되지 아니한다고 할 것이고(「병역법」 제30조제2항)³⁾, 동시에 해당 사회복무요원은 그 복무이탈일수의 5배의 기간을 연장하여 복무하여야 할 것이므로(같은 법 제33조제1항 본문), 이 사안과 같이 사회복무요원이 복무기간 중 정당한 사유 없이 통틀어 7일 이하 복무를 이탈하여 소집해제처분이 취소된 경우, 위 사회복무요원이 소집해제처분 취소 이후 복무하여야 하는 기간은 복무이탈일수(같은 법 제30조제2항)⁴⁾에 그 이탈일수의 5배의 기간(같은 법 제33조제1항 본문)을 더한 기간이라고 할 것입니다.

그리고 병역법령에 따라 사회복무요원이 정당한 사유 없이 복무를 이탈한 경우 원칙적으로 복무이탈기간을 사회복무요원으로서의 적법한 복무기간이라고 볼 수 없기 때문에⁵⁾ 이탈일수에 관계없이 그 복무이탈일수는 복무기간에 산입되지 아니하면서, 「병역법」 제33조제1항 본문에 따라 그 이탈일수의 5배의 기간을 연장하여 복무하게 하지만, 복무이탈 기간이 8일 이상인 때에는 같은 법 제89조의2제1호에 따라 3년 이하의 징역에 처하되 같은 법 제33조제1항 단서에 따라 복무기간을 연장하지 아니하고 있는바, 복무이탈 기간이 7일 이하인 때에는 같은 법 제33조제1항 본문에 따라 그 이탈일수의 5배의 기간을 연장하여

2) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

3) 헌법재판소 2011. 11. 24. 선고 2010헌마746 결정례 참조

4) 헌법재판소 2020. 9. 24. 선고 2019헌마472 결정례 참조

5) 헌법재판소 2011. 11. 24. 선고 2010헌마746 결정례 참조

복무하여야 한다고 해석하는 것이 8일 이상 복무를 이탈한 자와 7일 이하 복무를 이탈한 자를 구별하여 규정하고 있는 병역법령의 체계에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 사회복무요원이 소집해제처분 취소 이후 복무하여야 하는 기간은 복무이탈일수에 그 이탈일수의 5배의 기간을 더한 기간입니다.



관계법령

병역법

제30조(사회복무요원의 복무기간 등) ① 사회복무요원의 복무기간은 2년 2개월로 한다.

② 사회복무요원이 징역·금고 또는 구류의 형을 받거나 복무를 이탈한 경우에는 그 형의 집행일수나 복무이탈일수는 복무기간에 산입하지 아니한다.

③ (생략)

④ 사회복무요원 복무기간의 계산과 소집해제 등 사회복무요원의 복무에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제33조(사회복무요원의 연장복무 등) ① 사회복무요원이 정당한 사유 없이 복무를 이탈한 경우에는 그 이탈일수의 5배의 기간을 연장하여 복무하게 한다. 다만, 제89조의2제1호에 해당하는 사람의 경우에는 복무기간을 연장하지 아니한다.

② (생략)

③ 삭제

④ 사회복무요원으로서 제89조의2제1호 또는 제89조의3에 따라 형을 선고받은 사람에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 남은 복무기간을 사회복무요원으로 복무하게 한다. 다만, 제65조제1항제2호 및 제3호에 해당하는 사람의 경우에는 사회복무요원으로 소집하지 아니한다.

제89조의2(사회복무요원 등의 복무이탈) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 3년 이하의 징역에 처한다.

1. 사회복무요원, 예술·체육요원 또는 대체복무요원으로서 정당한 사유 없이 통틀어 8일 이상 복무를 이탈하거나 해당 분야에 복무하지 아니한 사람
2. ~ 5. (생략)

CHAPTER

5

행정자치·인사·안전

제1절 행정일반·지방자치

제2절 공무원

제3절 경찰·소방·국민안전

제1절 행정일반·지방자치

질의제목 1

▶ 안전번호 24-0824, 24-0877, 24-0937

행정안전부·경기도·용인시 - 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 물류단지 지정 등의 업무에 관한 특례시의 사무 특례 범위(「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제59조제13호 등 관련)

01 질의요지

「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」(이하 “지방분권균형발전법”이라 함) 제59조에서는 서울특별시·광역시 및 특별자치시가 아닌 인구 100만 이상 대도시(이하 “특례시”라 함)의 사무 특례에 관한 사항을 규정하면서, 같은 조 제13호에서는 특례시의 장은 관계 법률의 규정에도 불구하고 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」(이하 “물류시설법”이라 함) 제22조, 제22조의2, 제22조의3, 제22조의5부터 제22조의7까지, 제26조, 제27조, 제27조의2, 제28조, 제44조, 제46조, 제50조의3, 제52조의2, 제52조의3, 제53조, 제54조 및 제57조에 따른 물류단지의 지정·지정해제 및 개발·운영 등의 업무를 처리할 수 있다고 규정하고 있는바,

특례시의 장은 지방분권균형발전법 제59조제13호에 따른 물류단지의 지정·지정해제 및 개발·운영 등의 업무와 관련하여 물류시설법 제23조·제24조·제29조·제30조 및 제59조의2(이하 “이 사안 물류단지관련규정”이라 함)에 따라 물류단지 지정 고시 등의 업무를 처리할 수 있는지?

02 회답

특례시의 장은 지방분권균형발전법 제59조제13호에 따른 물류단지의 지정·지정해제 및

개발·운영 등의 업무와 관련하여 이 사안 물류단지관련규정에 따라 물류단지 지정 고시 등의 업무를 처리할 수 있습니다.

03 이유

지방분권균형발전법 제59조제13호에서는 “특례시의 장”이 물류시설법상의 물류단지 지정권자¹⁾가 아님에도 불구하고 처리할 수 있는 사무로서 “물류시설법 제22조, 제22조의2, 제22조의3, 제22조의5부터 제22조의7까지, 제26조, 제27조, 제27조의2, 제28조, 제44조, 제46조, 제50조의3, 제52조의2, 제52조의3, 제53조, 제54조 및 제57조에 따른 물류단지의 지정·지정해제 및 개발·운영 등의 업무”를 규정하면서, 같은 법 제23조(물류단지지정의 고시 등), 제24조(주민 등의 의견청취), 제29조(실시계획승인의 고시), 제30조(인·허가등의 의제) 및 제59조의2(「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」의 준용)는 명시적으로 인용하고 있지 않은바, 이 사안에서는 지방분권균형발전법 제59조제13호에 따라 특례시의 장에게 이양된 물류단지의 지정·지정해제 및 개발·운영 등의 업무와 관련하여, 같은 규정에서 명시적으로 인용하고 있지 않은 이 사안 물류단지관련규정에 따른 물류단지지정 고시 등의 업무도 특례시의 장이 처리할 수 있는지가 문제됩니다.

먼저 물류시설법 제4장(같은 법 제22조부터 제59조의3까지)에서는 ‘물류단지의 개발 및 운영’이라는 제목으로 물류단지의 지정(제22조·제22조의2)·지정해제(제26조), 물류단지개발 실시계획의 승인(제28조) 등에 관한 사항을 규정하고 있는데, 이 사안 물류단지관련규정인 같은 법 제23조에서는 물류단지지정권자가 물류단지를 지정하거나 지정내용을 변경할 때의 고시·열람 등에 관한 사항을, 같은 법 제24조에서는 물류단지지정권자가 물류단지를 지정하려는 때 의견청취에 관한 사항을, 같은 법 제29조에서는 물류단지지정권자가 물류단지개발실시계획을 승인하거나 승인한 사항을 변경승인한 때의 고시·열람 등에 관한 사항을, 같은 법 제30조에서는 물류단지지정권자가 실시계획을 승인 또는 변경승인 하는 경우 관련 인·허가 등의 의제를 위한 관계기관 협의에 관한 사항을, 같은 법 제59조의2제1항 본문에서는 물류단지 지정 및 개발절차에 관하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」(이하 “산단절차간소화법”이라 함)의 준용에 관한 사항을 규정하고 있고, 물류시설법에서는 이러한 물류단지 지정·지정해제 및 개발·운영 등과 관련된 사항을 ‘물류단지지정권자’인 국토교통부장관 또는 시·도지사의 사무로 규정하고 있습니다.

1) 국토교통부장관 또는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사를 말하며, 이하 같은

그리고 지방분권균형발전법은 지역 간 불균형 해소, 지역의 특성에 맞는 자립적 발전 및 지방자치분권을 통하여 지역이 주도하는 지역균형발전을 추진하여 지방시대를 구현하는 것을 목적으로 하는 법률로, 같은 법 제33조제1항에서는 국가는 「지방자치법」 제11조에 따른 사무배분의 기본원칙에 따라 그 권한 및 사무를 적극적으로 지방자치단체에 이양하여야 한다고 규정하고 있고, 「지방자치법」 제11조에서는 국가는 지방자치단체가 사무를 종합적·자율적으로 수행할 수 있도록 국가와 지방자치단체 간 또는 지방자치단체 상호 간의 사무를 서로 중복되지 아니하도록 배분하여야 한다고 규정하고 있으며(제1항), 국가가 지방자치단체에 사무를 배분하거나 지방자치단체가 사무를 다른 지방자치단체에 재배분할 때에는 사무를 배분받거나 재배분받는 지방자치단체가 그 사무를 자기의 책임하에 종합적으로 처리할 수 있도록 관련 사무를 포괄적으로 배분하여야 한다고 규정하고 있는바(제3항), 이 사안과 같이 지방분권균형발전법 제59조제13호에 따라 특례시의 장이 물류단지지정권자로부터 이양 받은 업무의 범위에 대해서도 이러한 지방분권균형발전법의 목적 및 사무배분의 기본원칙에 부합하는 방향으로 해석해야 할 것입니다.

그런데 지방분권균형발전법 제59조제13호는 종전에 국가 또는 시·도의 소관이었던 6개의 권한과 사무를 특례시에 이양하는 등의 내용으로 구 「지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법」²⁾을 일부개정하면서 같은 법 제41조제13호로 신설된 규정으로서, 기존에 시·도가 처리하였던 업무 중 특례시가 수행하는 것이 적합하다고 인정되는 업무를 특례시에 이양하여 기존 지방행정체제가 가진 문제점을 개선하고, 지역 특성에 맞는 자립적 발전 및 지방자치분권을 통하여 지역이 주도하는 지역균형발전이 효과적으로 이루어질 수 있도록 하기 위한 것인데, 「지방자치법」상 사무배분의 원칙에 따라 지역여건 및 수요를 반영한 물류단지 개발 및 운영을 위해서는 종합적인 사무처리 권한이 필요하다는 점을 고려하면, 같은 법 제59조제13호에 따라 특례시의 장에게 이양하려는 사무는 물류시설법 제4장에서 규정하고 있는 물류단지의 개발 및 운영에 관한 사항으로 종전 물류단지지정권자인 시·도지사가 종합적으로 처리하였던 물류단지 지정·지정해제 및 개발·운영 등에 관한 전반적인 업무를 의미한다고 보는 것이 지방자치단체 사무배분의 기본원칙에 부합하는 해석입니다.

또한 물류시설법 제22조 및 제22조의2에서는 일반물류단지 및 도시첨단물류단지는 국토교통부장관 또는 시·도지사에 그 지정권한을 부여하고 있고, 같은 법 제28조제1항에서는 시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 물류단지개발실시계획을 수립하여 물류단지지정권자의

2) 2023. 4. 26. 법률 제18851호로 일부개정된 것을 말함

승인을 받아야 한다고 규정하고 있는 등 지방분권균형발전법 제59조제13호에서 인용하고 있는 규정에서는 물류단지와 관련한 지정권·지정해제권, 실시계획의 승인권 등 권리·의무의 발생·변경·소멸 등에 관한 내용을 포함하고 있는 반면, 이 사안 물류단지관련규정은 물류시설법에 따라 물류단지지정권자에게 부여된 물류단지 지정이나 실시계획 승인 등의 권한을 행사하기 위해 필요한 절차적 사항을 규정한 것으로 볼 수 있는바, 지방분권균형발전법 제59조제13호에서는 물류시설법상 물류단지의 지정·지정해제 등의 권한을 특례시의 장에게 이양하고 있고, 물류단지 지정 등의 업무를 처리하기 위한 절차나 방법 등은 이러한 특례시의 장의 권한 행사에 수반되는 것으로서, 물류단지 지정 등의 업무를 처리하는 절차 등에 관한 규정을 명시적으로 인용하고 있지 않더라도, 주민에게 의견을 제시할 수 있는 기회를 주거나 이미 결정된 사항을 고시하는 등 이해관계인의 권익을 부당하게 침해할 우려가 없는 것이어서, 특례시의 장에게 명시적으로 이양된 행정권한을 실질적으로 행사하기 위해 필요한 경우라면 그와 관련된 물류시설법령상의 절차 규정 역시 적용할 수 있게 하여 물류단지의 지정 등에 관한 업무를 효율적이고 일관성 있게 처리할 수 있도록 하는 것이, 물류단지 지정권 등의 권한을 특례시의 장에게 이양하여 지방자치분권을 보장하려는 지방분권균형발전법의 취지에 비추어 볼 때 타당하다고 할 것입니다.

더욱이 물류시설법 제23조제1항에서는 물류단지지정권자가 물류단지를 지정하거나 지정 내용을 변경한 때에는 이를 관보 등에 고시하도록 규정하고 있고, 같은 법 제24조제1항에서는 물류단지지정권자는 물류단지를 지정하려는 때에는 주민 및 관계 전문가의 의견을 들어야 한다고 규정하고 있는 등 이 사안 물류단지관련규정에서는 ‘물류단지지정권자’를 그 사무 수행의 주체로 보고 있는데, 물류시설법에 따르면 ‘물류단지지정권자’는 일반적으로 물류시설법 제22조 및 제22조의2에 따라 물류단지를 지정하는 국토교통부장관 또는 시·도지사이고³⁾, 지방분권균형발전법 제59조제13호에서는 물류시설법 제22조 및 제22조의2를 명시적으로 인용하여 시·도지사의 물류단지 지정에 관한 행정권한을 특례시의 장에게 이양하고 있는바, 이 사안 물류단지관련규정에 따른 사무 수행 주체인 ‘물류단지 지정권자’에는 물류시설법 제22조 또는 제22조의2에 따라 물류단지 지정 권한이 있는 시·도지사뿐만 아니라 지방분권균형발전법 제59조제13호에 따라 물류단지 지정 권한을 명시적으로 이양 받은 특례시의 장도 포함된다고 볼 수 있으므로, 특례시의 장은 이양 받은 관할 지역 내 물류단지 지정 등과 관련된 업무 범위 내에서는 물류단지지정권자로서 이 사안 물류단지관련규정에 따른 업무를 처리할 수 있다고 할 것입니다.

3) 물류시설법 제22조의7제1항 참조

아울러 이 사안 물류단지관련규정 중 물류시설법 제59조의2는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지(이하 “산업단지”라 함)와 물류단지의 지정·개발 절차가 유사하고 산업단지와 마찬가지로 물류단지 개발 절차를 간소화하여 물류시설을 원활히 공급할 필요성이 인정되어 물류단지에 대해서도 산단절차간소화법을 준용하도록 한 것⁴⁾으로서, 그 규정 내용이 물류단지 ‘지정 및 개발절차’에 관하여 산단절차간소화법을 준용한다고 규정하여 사무의 권한에 관한 것이 아닌 절차에 관한 사항에 대해 준용한다고 규정하고 있고, 지방분권균형발전법에서 특례시의 장이 물류단지개발사업을 시행하는 경우 물류시설법상의 특정 규정의 적용을 배제하는 규정을 별도로 두고 있지 않는 점 등을 고려하면, 특례시의 장도 물류단지 지정 및 개발절차에 관해서는 물류시설법 제59조의2에 따라 산단절차간소화법을 준용하여 절차를 처리할 수 있도록 하는 것이 물류시설을 원활히 공급하기 위하여 물류단지 개발 절차를 간소화하려는 물류시설법 제59조의2의 입법취지에 부합한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 특례시의 장은 지방분권균형발전법 제59조제13호에 따른 물류단지의 지정·지정해제 및 개발·운영 등의 업무와 관련하여 이 사안 물류단지관련규정에 따라 물류단지 지정 고시 등의 업무를 처리할 수 있습니다.



관계법령

지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법

제59조(특례시의 사무 특례) 특례시의 장은 관계 법률의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 사무를 처리할 수 있다.

1. ~ 12. (생 략)

13. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제22조, 제22조의2, 제22조의3, 제22조의5부터 제22조의7까지, 제26조, 제27조, 제27조의2, 제28조, 제44조, 제46조, 제50조의3, 제52조의2, 제52조의3, 제53조, 제54조 및 제57조에 따른 물류단지의 지정·지정해제 및 개발·운영 등의 업무

물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률

제23조(물류단지지정의 고시 등) ① 물류단지지정권자가 물류단지를 지정하거나 지정내용을 변경한 때에는 대통령령으로 정하는 사항을 관보 또는 시·도의 공보에 고시하고, 관계 서류의 사본을 관할

4) 2008. 4. 22. 의안번호 제178329호 발의된 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법안」에 대한 국회 건설교통위원회 검토보고서 참조

시장·군수·구청장에게 보내야 한다.

② 물류단지로 지정되는 지역에 수용하거나 사용할 토지, 건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 제1항에 따른 고시내용에 그 토지 등의 세부목록을 포함시켜야 한다.

③ 제1항에 따라 관계 서류를 받은 시장·군수·구청장은 이를 14일 이상 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

제24조(주민 등의 의견청취) ① 물류단지지정권자는 물류단지를 지정하려는 때에는 주민 및 관계 전문가의 의견을 들어야 하고 타당하다고 인정하는 때에는 그 의견을 반영하여야 한다. 다만, 국방상 기밀(機密)사항이거나 대통령령으로 정하는 경미한 사항인 경우에는 의견 청취를 생략할 수 있다.

② 제1항에 따른 주민 및 관계 전문가의 의견청취에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제29조(실시계획승인의 고시) ① 물류단지지정권자는 제28조에 따라 실시계획을 승인하거나 승인한 사항을 변경승인한 때에는 대통령령으로 정하는 사항을 관보 또는 시·도의 공보에 고시하고, 관계 서류의 사본을 관할 시장·군수·구청장에게 보내야 한다.

②·③ (생 략)

제30조(인·허가등의 의제) ① 물류단지지정권자가 실시계획을 승인 또는 변경승인하는 경우에 다음 각 호의 인·허가등에 관하여 인·허가등의 관계 행정기관의 장과 미리 협의한 사항에 대해서는 해당 인·허가등을 받은 것으로 보며, 실시계획승인 또는 변경승인을 고시한 때에는 다음 각 호의 법률에 따른 해당 인·허가등의 고시 또는 공고를 한 것으로 본다.

1. ~ 31. (생 략)

② ~ ④ (생 략)

제59조의2(「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」의 준용) ① 물류단지 지정 및 개발절차에 관하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」을 준용한다. 다만, 같은 법 제17조 및 제18조는 준용하지 아니한다.

②·③ (생 략)

질의제목 2

▶ 안전번호 24-0880, 25-0164, 25-0165, 25-0166

행정안전부·전라남도 장흥군 - 일반산업단지의 일부 지정해제로 부지면적이 30퍼센트 이상 감소한 경우, 재해영향평가등의 재협의 대상에 해당하는지(「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제1호 및 제4호 등 관련)

01 질의요지

「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항에서는 관계행정기관의 장¹⁾은 재해영향평가등²⁾의 협의를 완료한 개발계획등³⁾이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 행정안전부장관과 재해영향평가등의 협의를 다시 해야 한다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 “개발계획등의 부지면적이 30퍼센트⁴⁾ 이상 증가하는 경우”를, 같은 항 제4호에서는 “개발사업의 토지이용에 관한 계획에 따른 토지이용 면적이 30퍼센트⁵⁾ 이상 변경되는 경우”를 각각 규정하고 있는 한편,

「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 “산업입지법”이라 함) 제7조제1항에서는 일반산업단지는 시·도지사⁶⁾ 또는 대도시시장⁷⁾이 지정한다고 규정하고 있고, 같은 법 제13조제2항에서는 산업단지지정권자는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 지역에 대한 산업단지 지정의 전부 또는 일부를 해제할 수 있다고 규정하고 있는바,

산업단지지정권자가 산업입지법 제13조제2항에 따라 이미 지정이 완료된 일반산업단지⁸⁾의 일부의 지정을 해제하여 기존에 지정된 일반산업단지 부지면적이 30퍼센트 이상 감소하는 경우, 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제1호 및 제4호에 따른 재해영향평가

1) 관계 중앙행정기관의 장, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사, 시장·군수·구청장 및 특별지방행정기관의 장을 말하며(「자연재해대책법」 제4조제1항 및 같은 법 시행령 제3조제1항), 이하 같음

2) 재해영향성검토 및 재해영향평가를 말하며(「자연재해대책법」 제4조제1항), 이하 같음

3) 자연재해에 영향을 미치는 행정계획 또는 개발사업을 말하며(「자연재해대책법」 제4조제1항 참조), 이하 같음

4) 개발계획등이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 증가 비율이 30퍼센트인 경우를 말함

5) 개발사업이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 증가 비율이 30퍼센트인 경우를 말함

6) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사를 말함(산업입지법 제3조제3항 참조)

7) 「지방자치법」 제198조에 따른 대도시의 시장을 말함(산업입지법 제5조제3항 참조)

8) 산업입지법 제7조에 따라 일반산업단지의 지정 시 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제1호나목2)에 따라 재해영향성검토 협의를 완료한 일반산업단지를 전제로 함

등의 재협의 대상에 해당하는지?9)

02 회답

이 사안의 경우, 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제1호 및 제4호에 따른 재해영향평가등의 재협의 대상에 해당하지 않습니다.

03 이유

「자연재해대책법」 제4조제1항에서는 관계행정기관의 장은 자연재해에 영향을 미치는 행정계획을 수립·확정하거나 개발사업의 허가·인가·승인·면허·결정·지정 등(이하 “허가등”이라 함)을 하려는 경우에는 그 행정계획 또는 개발사업(이하 “개발계획등”이라 함)의 확정·허가등을 하기 전에 행정안전부장관과 재해영향평가등의 협의를 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제5조의2에서는 관계행정기관의 장은 같은 법 제4조에 따라 재해영향평가등의 협의를 완료한 개발계획등이 변경되는 경우에는 그 변경되는 개발계획등의 확정·허가등을 하기 전에 같은 법 제4조에 따라 행정안전부장관과 재해영향평가등의 협의를 다시 하여야 한다고 규정하고 있으며(제1항), 같은 법 시행령 제6조의2제1항에서는 관계행정기관의 장은 같은 법 제4조에 따라 재해영향평가등의 협의를 완료한 개발계획등이 개발계획등의 부지면적이 30퍼센트 이상 증가하는 경우(제1호)나 개발사업의 토지이용에 관한 계획에 따른 토지이용 면적이 30퍼센트 이상 변경되는 경우(제4호) 등에 해당하는 경우에는 같은 법 제5조의2에 따라 행정안전부장관과 재해영향평가등의 협의를 다시 해야 한다고 규정하고 있습니다.

그런데 「자연재해대책법」 제5조제1항제2호에서는 재해영향평가등의 협의를 하여야 하는 개발계획등으로 산업 및 유통 단지 조성을 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제6조제1항 및 별표 1에서는 재해영향평가등의 협의 대상 행정계획 및 개발사업의 범위와 협의 시기를 정하고 있는데, 같은 표 제1호나목2)에서 산업입지법 제7조에 따른 일반산업단지의 지정을 “행정계획”으로 분류하고 있는바, 이 사안과 같이 일반산업단지의 일부의 지정을 해제하여

9) 본 사안은 개발실시계획 전 단계인 일반산업단지의 일부 지정 해제와 관련한 사안인바, 지정 해제로 인해 개발실시계획의 변경이 있는 경우 재해영향평가등의 재협의 대상에 해당하는지는 별론으로 함

부지면적의 30퍼센트 이상 감소되는 경우는 행정계획의 부지면적이 30퍼센트 이상 감소되는 경우에 해당한다고 할 것이므로, 결국 이 사안에서는 행정계획의 부지면적이 30퍼센트 이상 감소되는 경우가 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제1호에 따른 개발계획등의 부지면적이 30퍼센트 이상 증가하는 경우 및 같은 항 제4호에 따른 개발사업의 토지이용에 관한 계획에 따른 토지이용 면적이 30퍼센트 이상 변경되는 경우에 해당하는지가 문제됩니다.

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인바¹⁰⁾, 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제1호에서는 재해영향평가등의 재협의대상으로 “개발계획등(행정계획 또는 개발사업)의 부지면적이 30퍼센트 이상 증가하는 경우”를 규정하고 있는데, “증가”란 양이나 수치가 늘어남이란 의미하는 것이므로, 이 사안과 같이 행정계획의 부지면적이 30퍼센트 이상 “감소”되는 경우는 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제1호에 해당하지 않는 것이 문언상 명확하다고 할 것입니다.

다음으로 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제4호에서는 재해영향평가등의 재협의대상으로 “개발사업의 토지이용에 관한 계획에 따른 토지이용 면적이 30퍼센트 이상 변경되는 경우”를 규정하고 있는데, 이 사안과 같이 “일반산업단지의 일부를 지정해제”하는 것이 자연재해대책법령상 “개발사업의 토지이용에 관한 계획”에 해당하는지 살펴보면, 같은 영 별표 1 제2호에서는 재해영향평가등의 협의 대상이 되는 “개발사업”을 행정계획과 별도로 규정하면서, 같은 호 나목2)에서는 일반산업단지와 관련된 협의 대상 개발사업으로 산업입지법 제18조에 따른 일반산업단지개발실시계획(이하 “실시계획”이라 함)을 규정하고 있고, 산업입지법 제18조제1항에서는 일반산업단지의 사업시행자는 실시계획을 작성하여 일반산업단지지정권자의 승인을 받아야 한다고 규정하면서, 같은 영 제22조제1항에서는 일반산업단지의 사업시행자가 실시계획의 승인을 신청하려는 경우에는 토지이용계획을 포함한 일반산업단지개발실시계획승인신청서(이하 “실시계획신청서”라 함)를 산업단지 지정권자에게 제출하여야 한다고 규정하고 있는데, 같은 규칙 제9조제1항 및 별지 제9호 서식에 따른 실시계획신청서에는 토지이용계획이 포함되어 있습니다.

위와 같이 실시계획에 관한 산업입지법령의 규정을 종합하여 보면, 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제4호에 따른 “개발사업의 토지이용에 관한 계획”은 산업입지법 제18조에 따른 실시계획에 포함된 토지이용계획을 의미한다고 해석해야 할 것이고, 이 사안과 같이 산업입지법 제13조제2항에 따른 일반산업단지의 “일부 지정해제”는 “실시계획의

10) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

변경”과 구별되는 개념으로 자연재해대책법상 “행정계획의 변경”에 해당할 뿐 “개발사업의 변경”에 해당하지 않으므로, 일반산업단지의 일부를 지정해제하여 일반산업단지 부지면적이 30퍼센트 이상 감소되는 경우는 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제4호에 따른 “개발사업”의 토지이용에 관한 계획의 변경에 해당하지 않는다고 할 것입니다.

아울러 ① 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제1호의 내용은 2008년 2월 22일 대통령령 제20640호로 일부개정된 「자연재해대책법 시행령」 별표 1에서 사전재해영향성 검토¹¹⁾ 협의 실시 대상 범위를 행정계획 및 개발사업의 변경의 경우에는 대상 규모가 “30퍼센트 이상 증가하는 경우”로 규정¹²⁾한 이후 유지되어 온 규정으로, 이후 재해영향평가등에 관한 협의의 실효성을 제고하기 위하여 2018년 12월 31일 대통령령 제29441호로 일부개정된 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제4호에서 “개발사업의 토지이용에 관한 계획에 따른 토지이용 면적이 30퍼센트 이상 변경되는 경우”를 재해영향평가의 재협의 대상에 추가한 것¹³⁾인바, 입법연혁적으로 재해영향평가등의 재협의 대상으로 “행정계획의 부지면적이 30퍼센트 이상 감소되는 경우”는 포함된 적이 없는 점, ② 자연재해대책법령에서는 사업의 단계 및 규모 등에 관계없이 동일한 협의의 기준을 적용할 경우 재해영향평가등 제도 운영의 실효성이 저하되고 행정에 비효율이 초래될 수 있다는 점을 고려하여 협의 대상 사업의 단계 및 규모에 따라 협의 기준을 달리 정하고 있는 점¹⁴⁾도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「자연재해대책법 시행령」 제6조의2제1항제1호 및 제4호에 따른 재해영향평가등의 재협의 대상에 해당하지 않습니다.



관계법령

자연재해대책법

제5조의2(재해영향평가등의 재협의) ① 관계행정기관의 장은 제4조에 따라 재해영향평가등의 협의를 완료한 개발계획등이 변경되는 경우에는 그 변경되는 개발계획등의 확정·허가등을 하기 전에 제4조에

11) “사전재해영향성검토”란 자연재해에 영향을 미치는 각종 개발계획등으로 인한 재해 유발 요인을 예측·분석하고 이에 대한 대책을 마련하는 것을 말하며, 2017. 10. 24. 법률 제14912호로 일부개정된 「자연재해대책법」에서 이를 “재해영향성검토”와 “재해영향평가”로 나누어 규정함

12) 2008. 2. 22. 대통령령 제20640호로 일부개정된 「자연재해대책법 시행령」 개정이유 참조

13) 2018. 12. 31. 대통령령 제29441호로 일부개정된 「자연재해대책법 시행령」 개정이유 참조

14) 2017. 10. 24. 법률 제14912호로 일부개정된 「자연재해대책법」 개정이유 참조

따라 행정안전부장관과 재해영향평가등의 협의를 다시 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 변경의 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따라 재해영향평가등의 협의를 다시 하여야 하는 개발계획등의 범위 및 방법·절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자연재해대책법 시행령

제6조(재해영향평가등의 협의 대상 및 협의 방법 등) ① 법 제5조에 따라 관계행정기관의 장이 재해영향평가등의 협의를 요청하여야 하는 개발계획등의 범위와 협의 시기는 별표 1과 같다. 다만, 행정계획의 경우 행정안전부장관이 관계행정기관의 장으로부터 관계 법령에 따른 협의 요청을 받아 해당 행정계획에 관한 재해 영향을 검토한 경우에는 재해영향성검토 협의 절차를 이행한 것으로 보고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개발사업의 경우에는 재해영향평가 협의 대상 사업에서 제외한다.

1.·2. (생략)

② (생략)

제6조의2(재해영향평가등의 재협의 대상 등) ① 관계행정기관의 장은 법 제4조에 따라 재해영향평가등의 협의를 완료한 개발계획등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제5조의2에 따라 행정안전부장관과 재해영향평가등의 협의를 다시 해야 한다.

1. 개발계획등의 부지면적이 30퍼센트(개발계획등이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 증가 비율이 30퍼센트인 경우를 말한다) 이상 증가하는 경우

2.·3. (생략)

4. 개발사업의 토지이용에 관한 계획에 따른 토지이용 면적이 30퍼센트(개발사업이 2회 이상 변경되는 경우에는 누적된 변경 비율이 30퍼센트인 경우를 말한다) 이상 변경되는 경우

5.~8. (생략)

② (생략)

[별표 1]

재해영향평가등의 협의 대상 행정계획 및 개발사업의 범위 및 협의 시기

(제6조제1항 관련)

1. 행정계획

구분	대상 행정계획	협의 시기
나. 산업 및 유통단지 조성	2) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조에 따른 일반산업단지의 지정	관계 행정기관의 장과 협의 시

2. 개발사업

구분	대상 개발사업	협약 시기
나. 산업 및 유통단지 조성	2) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제18조에 따른 일반산업단지개발실시계획	관계 행정기관의 장과 협약 시

산업입지 및 개발에 관한 법률

제7조(일반산업단지의 지정) ① 일반산업단지는 시·도지사 또는 대도시시장에 지정한다. 다만, 대통령령으로 정하는 면적 미만의 산업단지의 경우에는 시장·군수 또는 구청장이 지정할 수 있다.

② ~ ⑦ (생략)

제13조(산업단지 지정의 해제) ① (생략)

② 산업단지지정권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 지역에 대한 산업단지 지정의 전부 또는 일부를 해제할 수 있다.

1. 2. (생략)

③ ~ ⑥ (생략)

질의제목 3

▶ 안전번호 24-0955

민원인 - 지방자치단체가 미술품을 효율적이고 적정하게 관리하는 데 필요한 사항을 조례로 정할 수 없는지(「공유재산 및 물품 관리법」 제94조의2 및 같은 법 시행령 제91조 등 관련)

01 질의요지

「공유재산 및 물품 관리법」(이하 “공유재산법”이라 함) 제94조의2제1항에서는 행정안전부장관은 지방자치단체가 공유재산과 물품의 관리·처분·수입 및 지출을 통일적으로 운영할 수 있게 하기 위하여 공유재산 및 물품의 운영기준을 정할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 지방자치단체는 같은 조 제1항에 따른 공유재산 및 물품의 운영기준에 따라 공유재산과 물품의 관리·처분·수입 및 지출에 관한 사항을 조례로 제정·운영할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

공유재산법 제91조에서는 「지방회계법」 제7조에 따른 일상경비등으로 취득한 물품과 그 밖에 대통령령으로 정하는 물품의 관리에 관하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공유재산법의 일부를 적용하지 아니할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 공유재산법 시행령 제91조제1항에서는 서화, 조각, 사진, 공예품 등 미술품(제6호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 물품에 대해서는 같은 법 제49조, 제52조, 제53조, 제57조, 제58조, 제60조, 제62조부터 제64조까지, 제69조, 제75조, 제78조, 제86조, 제93조 및 제94조를 적용하지 않을 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 영 제91조제2항에서는 지방자치단체의 장은 같은 조 제1항 각 호의 물품에 대해서는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 물품의 특성을 고려하여 그 물품을 효율적이고 적정하게 관리하는 데 필요한 사항을 정하여 관리하여야 한다고 규정하고 있는바,

지방자치단체는 미술품¹⁾을 효율적이고 적정하게 관리하는 데 필요한 사항을 조례로 정할 수 없는지?²⁾

1) 공유재산법 시행령 제91조제1항제6호의 미술품을 말하며, 이하 같음

2) 이 사안에서는 조례의 구체적인 규정에 대한 위법·부당 여부는 별론으로 함

02 회답

지방자치단체가 미술품을 효율적이고 적절하게 관리하는 데 필요한 사항을 조례로 정할 수 없는 것은 아닙니다.

03 이유

먼저 공유재산법 제94조의2에 따르면 행정안전부장관은 지방자치단체가 공유재산과 물품의 관리·처분·수입 및 지출을 통일적으로 운영할 수 있게 하기 위하여 공유재산 및 물품의 운영기준을 정할 수 있도록 하면서, 지방자치단체는 이러한 운영기준에 따라 공유재산과 물품의 관리·처분·수입 및 지출에 관한 사항을 조례로 제정·운영할 수 있다고 규정하고 있는데, 같은 법 제2조제2호에 따르면 “물품”이란 지방자치단체가 소유하는 동산(動産)과 지방자치단체가 사용하기 위하여 보관하는 동산 중 현금, 유가증권, 같은 법 제4조에 따른 공유재산을 제외한 동산을 말하는 것으로, 같은 법 시행령 제91조제1항제6호에서 서화, 조각, 사진, 공예품 등 미술품에 해당하는 “물품”에 대해서는 공유재산법의 일부 규정을 적용하지 않을 수 있도록 규정하고 있어, 같은 법 제94조의2의 “물품”에 “미술품”이 포함된다고 할 것이고, 같은 법 제2조제4호에 따르면 “관리”란 공유재산 및 물품의 취득·운용과 유지·보존을 위한 모든 행위를 말하는 것으로, 같은 법 제94조의2의 “관리”에는 효율적이고 적절하게 물품을 취득·운용·유지·보존하는 것이 포함된다고 할 것입니다.

그렇다면 공유재산법 제94조의2제1항의 문언상 행정안전부장관은 물품 운영기준으로 미술품의 효율적이고 적절한 관리에 관한 사항을 정할 수 있다고 할 것인데, 공유재산법 제94조의2는 2010년 2월 4일 법률 제10006호로 일부개정된 공유재산법에서 신설된 규정으로, 지방자치단체의 방만한 공유재산 및 물품 관리를 방지하고 일관되고 효율적인 공유재산 및 물품 관리 업무 추진을 위하여 행정안전부장관이 포괄적인 운영기준을 제시할 수 있도록 하되, 공유재산 및 물품 관리 업무가 지방자치단체의 고유사무인 점을 고려하여 지방자치단체는 행정안전부장관이 정한 공유재산 및 물품의 운영기준에 따라 공유재산과 물품의 관리·처분·수입 및 지출에 관한 사항을 조례로 제정·운영할 수 있다고 규정하고 있는 것인바³⁾, 이러한 공유재산법 제94조의2의 규정 체계 및 입법취지에 비추어 보면,

3) 2009. 9. 8. 의안번호 제1805896호로 발의(정부)된 공유재산 및 물품 관리법 일부개정법률안에 대한 국회 행정안전위원회 심사보고서 참조

지방자치단체는 같은 조 제1항에 따른 행정안전부장관이 정한 물품 운영기준에 따라 미술품의 효율적이고 적절한 관리에 관한 사항을 조례로 정할 수 없는 것은 아니라고 할 것입니다.

다음으로 공유재산법 시행령 제91조제1항에서는 미술품(제6호), 도서, 박물관 보존물품(제7호) 등과 같은 특정한 물품의 경우 공유재산법령을 일률적으로 적용하면 효율적인 관리가 어려울 수 있는 점을 고려하여 같은 법 제49조(물품의 분류), 제58조(물품관리기준의 설정), 제69조(보관의 원칙) 등의 규정을 적용하지 않을 수 있다고 규정하면서, 같은 법 시행령 제91조제2항에서는 지방자치단체의 장은 같은 조 제1항 각 호의 물품에 대해서는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 물품의 특성을 고려하여 그 물품을 효율적이고 적절하게 관리하는 데 필요한 사항을 정하여 관리하여야 한다고 규정하고 있는데, 같은 영 제91조제1항에 따라 미술품 등의 물품에 대해 적용이 배제되는 규정에는 공유재산법 제94조의2는 포함되어 있지 않고, 같은 영 제91조제2항에서는 지방자치단체의 장으로 하여금 ‘물품별 특성’을 고려하여 그 물품의 효율적 관리에 필요한 사항을 정하도록 한 것이라는 점에 비추어 보면, 미술품에 대하여는 공유재산법 제94조의2제1항에 따라 행정안전부장관이 미술품의 특성을 고려하여 전국적으로 체계적인 관리가 이루어질 수 있도록 운영기준을 제시할 수 있다고 할 것이고, 같은 법 제94조의2의 적용이 배제되는 것이 아니라면 같은 조 제2항을 근거로 행정안전부장관이 정한 운영기준에 따라 지방자치단체가 미술품을 효율적이고 적절하게 관리하는 데 필요한 사항을 조례로 정할 수도 있다고 해석하는 것이 공유재산법령의 체계에도 부합한다고 할 것입니다.

한편 공유재산법 시행령 제91조제2항에서 미술품 등을 효율적이고 적절하게 관리하는 데 필요한 사항을 정하여 관리하여야 하는 주체를 ‘지방자치단체의 장’으로 규정하고 있으므로, 미술품을 효율적이고 적절하게 관리하는 데 필요한 사항을 정할 수 있는 권한은 지방자치단체의 장에게 부여된 것이고, 공유재산법 제94조의2를 근거로 행정안전부장관이 정한 운영기준에 따라 지방자치단체의 조례를 제정하여 해당 사항을 정할 수 있다고 보는 것은 지방자치단체의 장의 권한을 침해할 우려가 있어 공유재산법령의 취지에 부합하지 않는다는 의견이 있습니다.

그러나 앞서 살펴본 바와 같이 공유재산법 시행령 제91조제2항은 미술품 등에 대해 공유재산법령을 그대로 적용하는 대신 지방자치단체의 장이 물품별 특성을 고려한 적정 기준을 마련하여 해당 물품을 관리하도록 함으로써 미술품 등에 대한 관리의 공백이 생기는 것을 방지하도록 하는 취지의 규정으로 해석하는 것이 합리적이고, 미술품 등에 대해 같은 법 제94조의2의 적용을 배제하는 명시적인 규정이 없는 이상, 지방자치단체의 장에게 같은

영 제91조제1항 각 호의 물품을 효율적이고 적정하게 관리하는 데 필요한 사항을 정할 수 있도록 전속적인 권한을 부여한 것으로 해석하기 어렵다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 지방자치단체가 미술품을 효율적이고 적정하게 관리하는 데 필요한 사항을 조례로 정할 수 없는 것은 아닙니다.



관계법령

공유재산 및 물품 관리법

제91조(일부 물품의 적용 배제) 「지방회계법」 제7조에 따른 일상경비등으로 취득한 물품과 그 밖에 대통령령으로 정하는 물품의 관리에 관하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.

제94조의2(공유재산 및 물품 운영기준) ① 행정안전부장관은 지방자치단체가 공유재산과 물품의 관리·처분·수입 및 지출을 통일적으로 운영할 수 있게 하기 위하여 공유재산 및 물품의 운영기준을 정할 수 있다.

② 지방자치단체는 제1항에 따른 공유재산 및 물품의 운영기준에 따라 공유재산과 물품의 관리·처분·수입 및 지출에 관한 사항을 조례로 제정·운영할 수 있다.

공유재산 및 물품 관리법 시행령

제91조(적용 배제) ① 법 제91조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물품에 대해서는 법 제49조, 제52조, 제53조, 제57조, 제58조, 제60조, 제62조부터 제64조까지, 제69조, 제75조, 제78조, 제86조, 제93조 및 제94조를 적용하지 않을 수 있다.

1. 지방자치단체의 사무 또는 사업의 집행에 필요한 서류
2. 지급명령서
3. 법령에 따라 몰수되거나 지방자치단체에 귀속된 물품
4. 지방자치단체의 사무 또는 사업의 집행에 필요한 물품으로서 법령에 따라 지방자치단체가 점유하여 보관하고 있는 물품
5. 「지방회계법」 제7조제2항에 따른 일상경비등으로 취득한 물품 중 해당 지방자치단체의 장이 자산으로 관리할 필요가 없다고 인정하는 물품
6. 서화, 조각, 사진, 공예품 등 미술품
7. 도서, 박물관 보존물품, 과학관 전시물품
8. 불용품 중 역사적·학술적 보존가치가 있다고 지방자치단체의 장이 인정하여 보관하는 물품
9. 지방자치단체의 장이 재활용하기 위하여 기부 등으로 받은 물품
10. 동식물 등 특수물품

11. 소프트웨어

12. 리스 물품

② 지방자치단체의 장은 제1항 각 호의 물품에 대해서는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 물품의 특성을 고려하여 그 물품을 효율적이고 적정하게 관리하는 데 필요한 사항을 정하여 관리하여야 한다.

질의제목 4

▶ 안전번호 24-0961

행정안전부 - 생활폐기물처리 대행을 하는 폐기물처리업자가 행정사무 감사 대상기관에 해당하는지
(「지방자치법 시행령」 제44조제1항제5호 등 관련)

01 질의요지

「지방자치법」 제49조제1항에서 지방의회는 매년 1회 그 지방자치단체의 사무에 대하여 시·도에서는 14일의 범위에서, 시·군 및 자치구에서는 9일의 범위에서 감사를 실시한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제44조제1항제5호에서는 행정사무 감사의 대상기관 중 하나로 같은 법 제117조제2항 및 제3항에 따라 위임·위탁된 사무¹⁾를 처리하는 단체 또는 기관(이하 “민간위탁단체등”이라 함)을 규정(전단)하고 있는²⁾ 한편,

「폐기물관리법」 제14조제1항에서는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(이하 “시장등”이라 함)은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 시장등은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제8조제1호에서는 같은 법 제14조제2항에서 “대통령령으로 정하는 자” 중 하나로 폐기물처리업자³⁾를 규정하고 있는바,

시장등으로부터 생활폐기물처리업무를 대행 받아 처리하는 폐기물처리업자(이하 “생활폐기물 처리대행자”라 함)⁴⁾가 「지방자치법 시행령」 제44조제1항제5호의 행정사무 감사 대상기관에 해당하는지?⁵⁾

1) 지방자치단체에 위임·위탁한 사무는 제외함

2) 이 경우 본회의가 특별히 필요하다고 의결하는 경우로 한정함(「지방자치법 시행령」 제44조제1항제5호 후단 참조)

3) 「폐기물관리법」 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자를 의미하며(「폐기물관리법 시행령」 제7조제1항제13호 참조), 이하 같음

4) 생활폐기물처리대행자가 개인인 경우는 제외함

5) 본회의가 특별히 필요하다고 의결하는 경우를 전제함

02 회답

생활폐기물처리대행자는 「지방자치법 시행령」 제44조제1항제5호의 행정사무 감사 대상기관에 해당하지 않습니다.

03 이유

먼저 생활폐기물처리대행자는 「폐기물관리법」 제14조제2항 및 같은 법 시행령 제8조제1호에 따라 시장등으로부터 생활폐기물처리 업무를 “대행”받아 처리하는 폐기물처리업자인데, “대행”이란 행정권한은 행정청의 명義와 책임으로 행사하되, 권한행사에 따른 실무를 대행기관으로 하여금 행하게 하는 것⁶⁾으로 위탁대상 업무를 수탁기관의 권한과 책임 아래 행사하도록 하는 “위탁”과 구별되는 개념⁷⁾으로서, 같은 법 제14조제2항에서 시장등은 생활폐기물의 처리를 대통령령으로 정하는 자에게 “대행”하게 할 수 있다고 규정하고 있는 반면, 같은 법 제62조제3항에서는 지방자치단체의 장은 폐기물처리시설 등의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요하다고 인정하면 그 관리·운영을 맡을 능력이 있는 자에게 “위탁”할 수 있다고 규정하여, “대행”과 “위탁”을 구별하여 규정하고 있는 「폐기물관리법」의 체계를 고려하면, 문언상 위탁업무를 처리하는 민간위탁단체등과 대행 업무를 처리하는 자는 구별되므로, 행정사무 감사 대상기관으로 민간위탁단체등을 규정하고 있는 「지방자치법 시행령」 제44조제1항제5호를 근거로 생활폐기물처리대행자가 행정사무 감사 대상기관에 해당한다고 해석하기는 어렵습니다.

또한 「지방자치법 시행령」 제44조제1항에서는 행정사무 감사 대상기관을 규정하면서 같은 항 제5호에서 민간위탁단체등의 경우에는 본회의가 특별히 필요하다고 의결하는 경우에만 그 대상으로 할 수 있도록 규정하고 있는바, 민간위탁단체등에 대한 행정사무 감사는 엄격한 요건을 갖춘 경우에만 제한적으로 실시하도록 하고 있는데, 이러한 규정의 체계 및 취지를 고려하면, 명시적 규정 없이 행정사무 감사의 대상에 “대행 업무를 처리하는 자”까지 포함하여 해석하기는 어렵다는 점, 「지방자치법」 제49조에 따른 행정사무 감사 제도는 지방의회가 “지방자치단체의 사무”에 대하여 정기적인 비판, 감시, 통제를 수행하도록 하기 위한 취지의 제도로⁸⁾, 지방의회와 지방자치단체장의 권한의 분리 및 배분의 한계에 관한 법 해석은

6) 법제처 2014. 7. 11. 회신 14-0310 해석례 참조

7) 법제처 2021. 11. 25. 회신 21-0739 해석례 참조

엄격하게 해야 할 것인데), 민간위탁단체등에 “대행 업무를 처리하는 자”를 포함하여 해석하는 것은 행정사무 감사 대상을 확장하여 해석하는 것으로 집행기관의 집행권한을 침해할 우려가 있다는 점¹⁰⁾ 등을 고려하면 생활폐기물처리대행자는 행정사무 감사 대상기관에 해당하지 않는다고 해석하는 것이 지방자치법령의 취지에 부합합니다.

아울러 「지방자치법」에 따른 지방의회의 행정사무 감사가 아니더라도, 「폐기물관리법」 제39조제1항제7호에 따라 지방자치단체의 장은 폐기물의 안전한 처리 등을 위해 폐기물 처리업자에게 보고하게 하거나 자료를 제출하게 할 수 있고, 관계 공무원에게 사무소나 사업장 등에 출입하여 관계 서류나 시설 또는 장비 등을 검사하게 하는 등 생활폐기물처리대행자에 대한 관리·감독을 할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 생활폐기물처리대행자는 「지방자치법 시행령」 제44조제1항제5호의 행정사무 감사 대상기관에 해당하지 않습니다.



관계법령

지방자치법

제49조(행정사무 감사권 및 조사권) ① 지방의회는 매년 1회 그 지방자치단체의 사무에 대하여 시·도에서는 14일의 범위에서, 시·군 및 자치구에서는 9일의 범위에서 감사를 실시하고, 지방자치단체의 사무 중 특정 사안에 관하여 본회의 의결로 본회의나 위원회에서 조사하게 할 수 있다.

② ~ ⑥ (생 략)

⑦ 제1항의 감사 또는 조사와 제3항의 감사를 위하여 필요한 사항은 「국정감사 및 조사에 관한 법률」에 준하여 대통령령으로 정하고, 제4항과 제5항의 선서·증언·감정 등에 관한 절차는 「국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률」에 준하여 대통령령으로 정한다.

제117조(사무의 위임 등) ① (생 략)

② 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 지방자치단체나 공공단체 또는 그 기관(사업소·출장소를 포함한다)에 위임하거나 위탁할 수 있다.

③ 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다.

④ (생 략)

8) 법제처 2021. 10. 15. 회신 21-0390 해석례 참조

9) 대법원 1992. 7. 28. 선고 92추31판결례 참조

10) 대법원 2003. 9. 23. 선고 2003추13 판결례 참조

지방자치법 시행령

제44조(행정사무 감사 또는 조사의 대상 기관) ① 감사 또는 조사의 대상 기관은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 법 제117조제2항 및 제3항에 따라 위임·위탁된 사무(지방자치단체에 위임·위탁한 사무는 제외한다)를 처리하는 단체 또는 기관. 이 경우 본회의가 특별히 필요하다고 의결하는 경우로 한정한다.
6. (생 략)
- ② (생 략)

폐기물관리법

제14조(생활폐기물의 처리 등) ①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 지정하는 지역은 제외한다.

②특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다.

③ ~ ⑩ (생 략)

질의제목 5

▶ 안전번호 24-0962, 25-0001

행정안전부 - 과학기술분야 정부출연연구기관과 국가과학기술연구회가 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제2조제4호에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당하는지 여부(「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제2조제4호 등 관련)

01 질의요지

- 가. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」(이하 “과기출연기관법”이라 함) 제8조에 따라 설립된 과학기술분야 정부출연연구기관(이하 “연구기관”이라 함)이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」(이하 “정보공개법 시행령”이라 함) 제2조제4호에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당하는지?
- 나. 과기출연기관법 제18조에 따라 설립된 국가과학기술연구회(이하 “연구회”라 함)가 정보공개법 시행령 제2조제4호에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당하는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

과기출연기관법 제8조에 따라 설립된 연구기관은 정보공개법 시행령 제2조제4호에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당합니다.

나. 질의 나에 대해

과기출연기관법 제18조에 따라 설립된 연구회는 정보공개법 시행령 제2조제4호에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당합니다.

03 이유

가. 질의 가 및 나의 공통사항

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 “정보공개법”이라 함) 제2조제3호마목 및 같은 법 시행령 제2조제4호에서는 같은 법에 따라 정보를 공개할 의무가 있는 공공기관의 하나로 ‘특별법에 의하여 설립된 특수법인’을 규정하고 있는바, 연구기관이나 연구회가 이에 해당하는지는 정보공개법의 입법 목적을 염두에 두고, 해당 법인에게 부여된 업무가 국가행정업무이거나, 이에 해당하지 않더라도 그 업무 수행으로써 추구하는 이익이 해당 법인 내부의 이익에 그치지 않고 공동체 전체의 이익에 해당하는 공익적 성격을 갖는지 여부를 중심으로 판단하되, 해당 법인의 설립근거가 되는 법률이 법인의 조직구성과 활동에 대한 행정적 관리·감독 등에서 「민법」이나 「상법」 등에 의하여 설립된 일반 법인과 달리 규율한 취지, 국가나 지방자치단체의 해당 법인에 대한 재정적 지원·보조의 유무와 그 정도, 해당 법인의 공공적 업무와 관련하여 국가기관·지방자치단체 등 다른 공공기관에 대한 정보공개청구와는 별도로 해당 법인에 대하여 직접 정보공개청구를 구할 필요성이 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여야 합니다¹⁾.

나. 질의 가에 대해

먼저 과기출연기관법은 연구기관의 설립·지원·육성과 체계적인 관리 및 책임경영에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 효과적인 국가 과학기술 혁신체제의 구축과 연구기관의 경영합리화 및 발전을 도모함을 목적으로 제정된 법률(제1조)로, 같은 법 제3조에서 같은 법에 따르지 아니하고는 연구기관을 설립하지 못한다고 규정하고 있고, 같은 법 제4조에서 연구기관은 법인으로 한다고 규정하면서, 같은 법 제8조제1항 및 별표에서는 같은 법에 따라 설립되는 연구기관으로 한국과학기술연구원 등 19개의 기관을 규정하고 있는바, 연구기관은 해당 법인의 설립 및 규율을 목적으로 제정된 특별법인 과기출연기관법에 따라 설립된 법인에 해당합니다.

그리고 연구기관의 설립 목적 및 설립·운영 재원 등에 대해 살펴보면, 과기출연기관법에 따르면 연구기관은 정부가 출연하고 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관으로서(제2조), 국가 과학기술의 혁신을 도모함으로써 국가경쟁력을 강화하려는 공익적인 취지로

1) 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008두5643 판결례 참조

설립되었고²⁾, 정부의 출연금과 그 밖의 수익금으로 운영하고 있으며(제5조제1항), 연구기관이 해산³⁾하거나 기능의 일부가 폐지⁴⁾되는 경우 남은 재산은 국고로 귀속되거나 같은 법에 따른 다른 연구기관에 출연할 수 있는 점(제17조제5항) 등을 고려할 때, 연구기관은 정부의 출연금을 바탕으로 공익적 목적을 달성하기 위하여 설립된 기관으로 공공적 역할을 수행하고 있다고 할 것입니다.

또한 연구기관에 대한 행정적 관리·감독 체계에 대해 살펴보면, 과기출연기관법에서는 과학기술정보통신부장관(이하 “과기부장관”이라 함)은 연구기관의 감독관청이 되고(제29조제1항), 연구기관을 지원·육성하고 체계적으로 관리하기 위하여 연구회를 설립하도록 규정(제18조제1항)하고 있는데, ① 연구기관의 원장은 연구회 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임면(任免)하는 점(제12조제1항), ② 연구기관은 국가의 예산이 성립되었을 때에는 해당 사업연도의 예산 및 사업계획을 연구회에 제출하고 그 승인을 받아야 하며(제13조제6항), 사업연도가 끝난 후에는 전(前) 사업연도의 결산서를 연구회에 제출하고 그 승인을 받아야 하는 점(제15조제1항), ③ 국회의 연구기관에 대한 통제를 강화하기 위하여⁵⁾ 연구회는 연구기관의 연구 실적과 경영 내용을 평가한 후 평가 결과를 과기부장관 등에게 제출하여야 하고, 과기부장관은 제출된 평가 결과를 국회 소관 상임위원회에 제출하여야 하는 점(제28조), ④ 과기부장관은 연구기관의 목적사업을 국가기관이 직접 수행하거나 해당 연구기관 외의 법인·단체 또는 개인이 수행하는 것이 바람직하다고 연구회가 인정하는 경우 등의 해산 사유가 발생하였을 때에는 연구회의 요청에 따라 연구기관의 해산을 명할 수 있는 점(제17조) 등을 종합해 보면, 과기출연기관법령에서는 연구기관의 공공성 등을 고려하여 관리·감독에 관한 사항을 「민법」 또는 「상법」에 따라 설립된 일반적인 법인과 달리 구체적으로 규정하고 있습니다.

아울러 과기출연기관법 제12조제1항 및 같은 법 시행령 제8조의2에서 연구기관의 원장이 「국가공무원법」 제33조제1호부터 제6호까지의 결격사유 중 어느 하나에 해당하게 된 경우 또는 직무 관련 여부와 상관없이 품위를 손상하는 행위를 하거나 자질이 현저히 부족하다고 판단되어 연구회의 이사장 또는 감독관청의 해임 요청이 있는 경우 등에 해당할 때에는 연구회의 이사장이 이사회의 의결을 거쳐 해당 원장을 해임할 수 있도록 규정하고 있고, 과기출연기관법 제35조에서는 연구기관의 임직원의 경우 수뢰 등의 범죄에 대해 「형법」

2) 2014. 8. 8. 의안번호 제1911347호로 발의된 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국회 미래창조과학방송통신위원회 심사보고서 참조

3) 과기출연기관법 제17조제1항 및 제2항 참조

4) 과기출연기관법 제24조제2항제4호 참조

5) 2004. 8. 4. 의안번호 제170242호로 발의된 과학기술분야정부출연연구기관등의설립·운영및육성에관한법률안에 대한 국회 과학기술정보통신위원회 심사보고서 참조

제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때 공무원으로 의제하도록 규정하고 있는 등 업무의 공적인 성격을 고려하여 연구기관의 임직원에게 높은 수준의 책임성을 요구하고 있는 점⁶⁾도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

한편 연구기관은 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 “공공기관운영법”이라 함)에 따른 공공기관에 해당하지 않으므로⁷⁾ 해당 기관을 국가기관이나 공공기관운영법상의 공공기관 등과 같이 정보공개법령에 따라 정보⁸⁾를 공개할 의무가 있는 기관에 해당한다고 보기는 어렵다는 의견이 있으나, 정보공개법 제2조제3호 및 같은 법 시행령 제2조에서는 국가기관, 지방자치단체, 공공기관운영법에 따른 공공기관과 별개로 “특별법에 따라 설립된 특수법인” 등을 정보공개법 적용 대상 기관으로 규정하고 있는 점, 연구기관은 공공기관운영법에 따른 공공기관에서 지정 해제되었더라도 여전히 정부의 출연금 등을 재원으로 하여 국가연구기관으로서의 역할을 수행하는바, 연구기관에서 보유·관리하고 있는 정보에 대해 해당 법인에 직접 정보공개를 청구할 수 있다고 해석하는 것이 공공성을 갖는 법인에 대한 국민의 알권리를 보장하려는 정보공개법령의 입법 목적에 부합하는 점을 고려할 때, 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 과기출연기관법 제8조에 따라 설립된 연구기관은 정보공개법 시행령 제2조제4호에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당합니다.

다. 질의 내에 대해

먼저 과기출연기관법은 연구기관의 설립·지원·육성과 체계적인 관리 및 책임경영에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 효과적인 국가 과학기술 혁신체제의 구축과 과학기술분야 정부출연연구기관의 경영 합리화 및 발전을 도모함을 목적으로 제정된 법률(제1조)로, 같은 법 제4조에서 같은 법에 따라 설립되는 연구회는 법인으로 한다고 규정하고, 같은 법 제18조제1항에서 과기부장관은 연구기관을 지원·육성하고 체계적으로 관리하기 위하여 연구회를 설립한다고 규정하여 연구회의 설립근거를 과기출연기관법에 두고 있는바, 연구회는 특별법인 과기출연기관법에 따라 설립된 법인에 해당합니다.

6) 2014. 8. 8. 의안번호 제1911347호로 발의된 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국회 미래창조과학방송통신위원회 심사보고서 참조

7) 연구기관은 2024년 공공기관 지정에서 제외됨(「2024년도 공공기관 지정 고시」 참조)

8) 정보공개법 제9조에 따른 비공개 대상 정보 등은 제외함

그리고 연구회의 업무 내용, 설립·운영 재원, 조직 구성 등에 대해 살펴보면, 과기출연기관법에 따르면 연구회의 사업으로 국가 과학기술분야의 혁신 및 경쟁력 강화를 위한 정책의 제언, 연구기관의 기능 조정 및 정비(연구기관의 신설·통합 및 해산을 포함함), 연구기관의 연구 실적 및 경영 내용에 대한 평가 등 공익적 성격이 강한 업무를 규정하고 있고(제21조), 연구회는 정부의 출연금과 그 밖의 수익금으로 운영하고, 정부는 연구회의 설립·운영에 드는 경비에 충당하기 위하여 예산의 범위에서 연구회에 출연금을 지급할 수 있어(제5조) 연구회의 설립·운영에 국가 재정이 투입되며, 연구회에는 이사장 1명을 포함한 20명 이내의 이사와 감사 1명을 두는데(제22조), “이사장”은 대통령령으로 정하는 이사장 추천위원회가 추천하는 사람 중에서 과기부장관의 제청으로 대통령이 임명하고, “이사”(이사장은 제외함)는 기획재정부차관·과학기술정보통신부차관 등 당연직이사와 산업계·연구계·학계 등의 추천을 받아 이사회회의 의결을 거쳐 과기부장관이 임명하는 사람이 되는 등(제23조) 연구회의 임원은 “공무원”과 “대통령 또는 과기부장관이 임명하는 사람”으로 구성되어 있는 점 등을 고려하면 연구회는 정부의 출연금을 바탕으로 공익적 목적의 사업을 수행하는 등 공공적 역할을 수행하고 있다고 할 것입니다.

또한 연구회에 대한 행정적 관리·감독 체계에 대해 살펴보면, 과기출연기관법에 따르면 연구회는 사업연도마다 다음 사업연도의 출연금 예산요구서를 과기부장관에게 제출하여야 하고, 사업연도별 사업계획 및 예산 및 사업연도별 사업실적과 공인회계사의 회계감사를 받은 사업연도별 세입·세출 결산을 과기부장관에게 보고하여야 하며(제27조), 국회의 연구회에 대한 통제를 강화하기 위하여⁹⁾ 연구회의 감독관청인 과기부장관은 연구회의 연구기관에 대한 지원·관리 및 각종 연구회의 사업 등에 대하여 평가하고 그 평가 결과를 국회 소관 상임위원회에 제출하여야 하는데(제29조), 이를 종합해 보면, 과기출연기관법령에서는 연구회의 공공성 등을 고려하여 관리·감독에 관한 사항을 「민법」 또는 「상법」에 따라 설립된 일반적인 법인과 달리 구체적으로 규정하고 있다고 할 것입니다.

아울러 과기출연기관법 제23조의2에서는 연구회의 임원(당연직이사는 제외함)이 「국가공무원법」 제33조제1호부터 제6호까지의 결격사유 중 어느 하나에 해당하게 된 경우 또는 직무 내외를 막론하고 품위를 현저히 손상하는 행위를 하거나 자질이 현저히 부족하다고 판단되는 경우 등에 해당할 때에는 임명권자가 그 임원을 해임할 수 있도록 규정하고 있고, 과기출연기관법 제35조에서는 연구회의 임직원의 경우 수뢰 등의 범죄에 대해 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때 공무원으로 의제하도록 규정하고 있는바,

9) 2004. 8. 4. 의안번호 제170242호로 발의된 과학기술분야정부출연연구기관등의설립·운영및육성에관한법률안에 대한 국회 과학기술정보통신위원회 심사보고서 참조.

업무의 공적인 성격을 고려하여 연구회의 임직원에게 높은 수준의 책임을 요구하고 있는 점¹⁰⁾도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 과기출연기관법 제18조에 따라 설립된 연구회는 정보공개법 시행령 제2조제4호에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당합니다.



관계법령

공공기관의 정보공개에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 1.·2. (생 략)
3. “공공기관”이란 다음 각 목의 기관을 말한다.
 - 가. 국가기관
 - 1) 국회, 법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회
 - 2) 중앙행정기관(대통령 소속 기관과 국무총리 소속 기관을 포함한다) 및 그 소속 기관
 - 3) 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」에 따른 위원회
 - 나. 지방자치단체
 - 다. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제2조에 따른 공공기관
 - 라. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단
 - 마. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관

공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령

제2조(공공기관의 범위) 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제3호마목에서 “대통령령으로 정하는 기관”이란 다음 각 호의 기관 또는 단체를 말한다.

1. 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」에 따른 각급 학교 또는 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 학교
2. 삭제
3. 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 출자기관 및 출연기관
4. 특별법에 따라 설립된 특수법인
5. 「사회복지사업법」 제42조제1항에 따라 국가나 지방자치단체로부터 보조금을 받는 사회복지법인과 사회복지사업을 하는 비영리법인
6. 제5호 외에 「보조금 관리에 관한 법률」 제9조 또는 「지방재정법」 제17조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국가나 지방자치단체로부터 연간 5천만원 이상의 보조금을 받는 기관 또는 단체. 다만,

10) 2014. 8. 8. 의안번호 제1911347호로 발의된 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국회 미래창조과학방송통신위원회 심사보고서 참조

정보공개 대상 정보는 해당 연도에 보조를 받은 사업으로 한정한다.

과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률

제3조(연구기관의 설립 제한) 이 법에 따르지 아니하고는 과학기술분야 정부출연연구기관(이하 “연구기관”이라 한다)을 설립하지 못한다.

제4조(법인격) 이 법에 따라 설립되는 연구기관 및 국가과학기술연구회(이하 “연구회”라 한다)는 법인으로 한다.

제8조(연구기관의 설립) ① 이 법에 따라 설립되는 연구기관은 별표와 같다.

② 연구기관은 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

③·④ (생 략)

제18조(연구회의 설립) ① 과학기술정보통신부장관은 연구기관을 지원·육성하고 체계적으로 관리하기 위하여 연구회를 설립한다.

② 연구회는 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

③ (생 략)

질의제목 6

▶ 안전번호 24-1010, 25-0223

민원인 - 「공공감사에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 지방자치단체의 자체감사 대상기관의 범위
(「공공감사에 관한 법률」 제2조제1호 등 관련)

01 질의요지

「공공감사에 관한 법률」 제2조제1호에서는 “자체감사”란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관(그 소속기관 및 소관 단체를 포함함) 및 그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제5호에서는 “자체감사기구”란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관에 설치되어 자체감사를 수행하는 기관 또는 부서를 말한다고 규정하고 있는바,

「지방공기업법」 제49조에 따른 지방공사 중 지방자치단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자한 경우로서 직원의 정원이 100명 이상인 지방공사(이하 “이 사안 지방공사”라 함) 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 출연기관(이하 “이 사안 출연기관”이라 함)이 지방자치단체의 ‘소관 단체’에 해당하여 지방자치단체의 자체감사 대상이 될 수 있는지?

02 회답

이 사안 지방공사 및 이 사안 출연기관은 지방자치단체의 자체감사 대상이 될 수 있습니다.

03 이유

「공공감사에 관한 법률」(이하 “공공감사법”이라 함) 제2조제1호에서는 “자체감사”에 대해 정의하면서, 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관(그 소속기관 및 소관 단체를 포함함) 및 그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을

조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말한다고 규정하고 있는바, 지방자치단체의 경우 자체감사는 지방자치단체의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관, 즉 해당 지방자치단체 및 그 기관에 속한 자를 대상으로 모든 업무와 활동 등에 대해 조사·점검 등을 하는 것을 의미하는데, 자체감사의 대상 기관으로 ‘그 소속되어 있는 기관’ 뒤에 괄호를 두어 그 소속기관 및 ‘소관 단체’를 포함한다고 규정하고 있는바, 어떠한 단체가 지방자치단체의 ‘소관 단체’에 해당하는지 여부는 문언의 의미, 공공감사법령의 규정 내용과 입법취지뿐만 아니라 다른 법령과의 관계 등을 종합적으로 고려하여 해석할 필요가 있습니다.

먼저 공공감사법 제2조제1호에 따라 지방자치단체의 자체감사 대상이 되는 지방자치단체의 ‘소관 단체’의 의미를 살펴보면, 일반적으로 ‘소관’¹⁾이라는 용어는 맡아 관리하는 바 또는 그 범위를 의미하므로, ‘소관 단체’란 맡아서 관리하는 단체를 의미한다 할 것인데, 공공감사법에 따른 자체감사가 대상 기관 및 그에 소속된 자의 모든 업무와 활동 등에 대한 조사·점검 등을 수행하는 업무라는 점을 고려하면, 공공감사법 제2조제1호에 따른 지방자치단체의 소관 단체란 지방자치단체가 내부통제 기능의 일환으로 법령, 자치법규 등에 근거하여 그 업무와 활동 전반을 포괄적으로 조사·점검하는 등 관리할 수 있는 단체 등을 의미한다고 볼 수 있는바, 공공감사법령에서 자체감사의 대상에 소속 기관뿐만 아니라 소관 단체까지 포함되는 것으로 규정하고 있는 것은 중앙행정기관, 지방자치단체 등에서 실시하는 감사에 대하여 감사의 대상이 행정조직 관련 법령에서 규정하고 있는 감사기관과 동일한 조직에 속하는지 여부와 관계없이 공공감사법의 규율을 받도록 하기 위한 것으로 볼 수 있는 점²⁾을 고려하면, 지방자치단체가 내부통제 차원에서 실시하는 자체감사의 범위는 반드시 지방자치단체의 자체감사기구가 소속된 기관 또는 그 기관의 하부 조직에만 한정되는 것은 아니라고 할 것입니다.

그런데 이 사안 지방공사는 「지방공기업법」 제49조에 따라 수도사업, 궤도사업, 자동차운송사업 등을 효율적으로 수행하기 위하여 지방자치단체가 같은 법 제53조에 따라 자본금의 전액을 현금 또는 현물로 출자하여 설립한 법인으로서, 같은 법 제73조에 따라 지방자치단체의 장이 그 공사의 설립·운영 등 지방공사의 업무를 전반적으로 관리·감독할 권한을 가지고 있고, 이 사안 출연기관은 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 문화, 예술 등 주민의 복리 증진이나 지역주민의 소득 증진 등에 이바지할 수 있는 사업의 효율적 수행을 위하여 지방자치단체가 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하는 등의 방법으로 설립된 기관으로서, 지방자치단체의 장은 같은 법 제25조에 따라

1) 국립국어원 표준국어대사전 참조

2) 서울고등법원 2023. 1. 10. 선고 2022누43063(확정) 판결례 참조

지방자치단체가 위탁한 사업이나 지방자치단체 소관 업무와 직접 관련된 사업 등에 대해 출자·출연기관을 지도·감독할 수 있고, 같은 법 제26조에 따라 출자·출연 기관의 업무, 회계 및 재산에 관한 검사 등의 권한을 가지고 있는바, 이 사안 지방공사와 이 사안 출연기관은 그에 대한 관리·감독 또는 지도·감독의 권한을 가지는 지방자치단체가 소관하는 단체라고 보아야 할 것입니다.

한편 이 사안 지방공사는 공공감사법 제2조제4호 및 같은 법 시행령 제3조제1항제2호에 따른 공공기관에 해당하여 공공감사법 제5조에 따라 자체감사기구를 설치해야 하는바, 이처럼 자체감사의 주체가 되는 공공기관은 이미 자체감사기구를 두고 있으므로 동시에 지방자치단체가 실시하는 자체감사의 대상이 될 수는 없다는 의견이 있습니다.

그러나 종전의 공공부문의 자체감사가 해당 기관의 자율에 맡겨져 있어 자체감사의 독립성과 전문성을 확보하기 어렵고, 적절한 감사기준과 절차가 확립되지 못하여 자의적인 감사활동과 부실감사 등의 문제가 발생함에 따라³⁾, 공공감사법을 제정하여 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 자체감사기구의 조직과 활동, 감사기구의 장의 임용 등에 대해 규율함으로써 자체감사기구의 독립성과 전문성을 확보하고 효율적인 감사 제도를 마련하게 된 것인바⁴⁾, 그 입법 취지가 종전에 공공부문에서 기관이나 단체별로 자율적으로 이루어지던 감사활동 전반을 체계적으로 규율하려는 데 있다는 점, 관리·감독 기관으로서 상급기관이 실시하는 자체감사와 지방공사가 직접 실시하는 자체감사는 감사의 목적, 필요성 및 범위가 동일하다고 보기는 어렵다는 점에 비추어 볼 때, 이 사안 지방공사가 공공감사법령에 따라 자체감사기구를 두는 공공기관에 해당하여 직접 자체감사를 실시하고 있다는 사정만으로 공공감사법 제2조제1호에 따른 지방자치단체의 자체 감사 대상인 ‘소관 단체’에서 배제된다고 보기는 어려우므로, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안 지방공사 및 이 사안 출연기관은 지방자치단체의 자체감사 대상이 될 수 있습니다.

3) 2009. 9. 30. 의안번호 제1806204호로 발의된 공공감사에 관한 법률안에 대한 국회 법제사법위원회 심사보고서 참조

4) 2010. 3. 22. 법률 제10163호로 제정된 공공감사법 제정이유 참조



관계법령

공공감사에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “자체감사”란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관(그 소속 기관 및 소관 단체를 포함한다) 및 그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말한다.
- 2.·3. (생략)
4. “공공기관”이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 지정된 기관(같은 법 제5조제4항에 따른 기타공공기관으로서 직원의 정원이 100명 미만인 기관은 제외한다)과 「감사원법」 제22조제1항 및 제23조에 따른 감사원 감사의 대상기관으로서 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체를 말한다.
5. “자체감사기구”란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관에 설치되어 자체감사를 수행하는 기관 또는 부서를 말한다.

질의제목 7

▶ 안전번호 25-0009

경찰청 - 10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회가 제출을 요구할 수 있는 자료의 범위(「10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법」 제28조 등 관련)

01 질의요지

「10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법」(이하 “이태원참사진상규명법”이라 함) 제6조제1항에서는 10·29이태원참사의 발생원인과 책임소재 등에 관한 진상을 규명하기 위하여 10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(이하 “조사위원회”라 함)를 둔다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서 조사위원회는 10·29이태원참사의 원인 및 책임소재 규명에 관한 사항(제1호) 등의 업무를 수행한다고 규정하고 있고, 같은 법 제28조제1항제3호에서는 조사위원회는 조사대상자 및 참고인, 그 밖의 관계기관·시설·단체 등에 대하여 같은 법 제6조제2항에 따른 조사위원회 업무에 필요하다고 인정되는 자료 또는 물건의 제출요구 및 제출된 자료 또는 물건의 보관의 방법으로 조사를 수행할 수 있다고 규정하고 있는바,

이태원참사진상규명법 제28조제1항제3호를 근거로 「경찰수사규칙」 제108조에 따라 불송치 결정된 사건(이하 “불송치 사건”이라 함)에 대한 수사기록을 요구할 수 있는지?

02 회답

이태원참사진상규명법 제28조제1항제3호를 근거로 불송치 사건에 대한 수사기록을 요구할 수 없습니다.

03 이유

이태원참사진상규명법 제6조제1항에서는 10·29이태원참사의 발생원인과 책임소재 등에

관한 진상을 규명하기 위하여 조사위원회를 둔다고 규정하고 있고, 같은 법 제28조제1항제3호에서는 조사위원회는 ‘조사대상자 및 참고인, 그 밖의 관계 기관·시설·단체 등에 대하여 같은 법 제6조제2항에 따른 조사위원회 업무에 필요하다고 인정되는 자료 또는 물건의 제출요구 및 제출된 자료 또는 물건의 보관’의 방법으로 조사를 수행할 수 있다고 규정하고 있는 한편, 같은 법 제28조제1항제3호와는 별개로 같은 조 제7항에서 조사위원회는 조사를 수행함에 있어서 용산 이태원 참사 진상규명과 재발방지를 위한 국정조사특별위원회의 조사를 통하여 확인된 사실(제1호) 또는 형사재판이 진행 중이거나 확정된 사건의 확인된 사실(제2호)에 대해서는 조사기록, 재판기록 및 그 밖의 기록(이하 “조사기록등”이라 함)의 열람, 등사, 사본의 제출요구 등(이하 “열람등”이라 함)을 통한 조사를 할 수 있다고 규정하고 있고, 해당 규정에서는 ‘불송치 사건에 대한 수사기록’을 조사위원회가 열람등이 가능한 대상 기록으로 규정하고 있지 않은바, 이 사안에서는 불송치 사건에 대한 수사기록이 같은 법 제28조제1항제3호의 ‘자료’에 포함된다고 보아 조사위원회가 이를 근거로 해당 수사기록을 요구할 수 있는지 여부가 문제됩니다.

먼저 이태원참사진상규명법 제28조제1항제3호는 ‘조사위원회 업무에 필요하다고 인정되는 자료’의 제출 요구 방법으로 조사를 수행할 수 있다고 하여 그 조사 대상을 포괄적으로 규정하고 있는데, 비록 행정기관이 보유하고 있는 자료가 국가의 안전보장, 질서유지 및 공공복리 등의 국가·사회적 법익의 실현을 위하여 일정한 범위에서는 다른 기관에 제공 및 이용하는 것이 가능하다 하더라도, 해당 자료의 제공 등은 그로 인한 공익적 목적의 실현과 다른 국가·사회적 법익 및 사생활의 비밀유지와 같은 기본권이 상호 조화될 수 있는 범위에서만 정당성을 가진다고 할 것¹⁾이므로, 같은 법 제28조제1항제3호에 따른 자료의 범위를 해석하는데 있어서는 개별 자료가 갖는 특성과 헌법상 개인의 사생활의 비밀과 자유의 보호, 해당 자료의 작성·수집·관리·제공의 근거가 되는 관계 법령의 취지·체계 및 이태원참사진상규명법 입법과정에서의 조문화와 관련된 입법배경 등을 종합적으로 고려해야 할 것입니다.

이와 관련하여 수사기록은 「형사소송법」 제195조, 제244조의4 및 「형사소송법」 제195조의 위임에 따라 마련된 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 등에 그 근거를 두고 있는데, 수사는 범죄혐의의 유무를 명백히 하여 공소를 제기·유지할 것인지 여부를 결정하기 위해 증거를 수집·보전하는 수사기관의 활동으로서²⁾, 수사기록에는 국가기관이 수사권을 행사하여 당해 사건과 관련된 피의자, 피해자, 증인 등 관계자에 대한 진술 및 검증, 감정 등의 내용을 수집한 증거³⁾를 비롯하여 의견서, 보고문서, 메모, 법률검토,

1) 법제처 2009. 11. 27. 회신 09-0365 해석례, 법제처 2016. 3. 29. 회신 15-0726 해석례 등 참조

2) 헌법재판소 2018. 8. 30. 선고 2014헌마843 전원재판부 결정례 참조

내사자료 등이 포함⁴⁾되어 있는바, 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제69조에서는 수사서류 등의 열람·복사에 관한 사항을 별도로 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 불송치 결정을 한 사건에 관한 기록의 전부 또는 일부의 열람·복사를 신청할 수 있는 자를 해당 사건과 관계되는 ‘피의자, 사건관계인 또는 그 변호인’으로 한정하여 규정하고 있습니다.

또한 공공기관이 보유·관리하는 정보에 대한 국민의 공개 청구 및 공공기관의 공개 의무에 관하여 규정하고 있는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에서는 모든 국민은 공공기관이 보유·관리하는 정보의 공개를 청구할 권리를 가진다고 규정하면서(제5조제1항), 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보는 공개하지 아니할 수 있다고 규정하고(제9조제1항제4호) 있는 등 수사 관련 정보의 일부에 대해서는 정보공개청구의 대상에서 제외할 수 있도록 하고 있고, 공공기록물의 안전한 보존 및 효율적 활용을 위하여 공공기록물 관리에 관한 사항을 정하고 있는 「공공기록물 관리에 관한 법률」에서는 수사 분야의 기록물을 생산하는 공공기관의 장은 특수기록관을 설치·운영할 수 있도록 하면서(제14조제1항), 수사·재판 관련 기록물의 경우 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 그 등록·분류·편철 등의 방식을 달리 정할 수 있고(제18조), 수사 분야의 기록물을 공개하려면 미리 그 기록물을 생산한 기관의 장의 의견을 들어야 하도록 규정(제35조제5항)하고 있는 등 수사 분야의 기록물에 대해서는 일반적인 기록물과는 달리 보존·관리·공개할 수 있는 방법을 마련하고 있습니다.

그리고 이태원참사진상규명법 제30조제1항에서는 조사위원회는 조사 결과 조사한 내용이 사실임이 확인되고 범죄혐의가 있다고 인정되는 경우 수사기관의 장에게 고발하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 조사위원회는 조사과정에서 범죄혐의에 대하여 상당한 개연성이 있다고 인정할 경우 수사기관에 수사를 하도록 요청할 수 있다고 규정하고 있는 등 조사위원회에서 수행하는 ‘조사’와 수사기관에서 이루어지는 ‘수사’를 구분하여 규정하고 있는바⁵⁾, 수사기록은 국가의 형벌권 행사를 위해 수사기관이 수집하여 보유하는 일련의 자료들로서 일반 행정기관 등이 수집하여 보유하는 행정자료와는 그 성격을 달리하고, 그 활용 등에 있어서도 수사기관의 직무수행에 현저한 곤란을 초래하지 않는 동시에 수사의 효율성·공정성을 담보할 수 있는 입법목적의 범위 안에서 이루어져야 할 것이며, 국가·사회적

3) 헌법재판소 1997. 11. 27. 선고 94헌마60 전원재판부 결정례 참조

4) 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017두44558 판결례 등 참조

5) 헌법재판소 2019. 9. 26. 선고 2016헌바381 결정례 참조

법익의 실현을 위해 다른 법률의 근거에 따라 해당 수사 외의 목적으로 수사기록이 제공 및 활용될 수 있다고 하더라도 이러한 수사기록이 가진 특성과 헌법상 개인의 사생활의 비밀과 자유의 보호, 「형사소송법」의 취지 등을 종합적으로 고려할 때, 이태원참사진상규명법상 제출 요구가 가능한 자료의 범위와 관련하여 수사기관이 작성·보유하고 있는 수사기록이 조사위원회에 제공되어 사건의 진상규명 등의 목적으로 활용될 수 있도록 하기 위해서는 조사위원회가 수사기록을 보유·관리하고 있는 기관에 수사기록을 요청할 수 있다는 근거가 법률에 구체적으로 규정될 필요가 있습니다.⁶⁾

그런데 이태원참사진상규명법 제28조제1항제3호의 자료제출요구 규정에서는 자료나 정보를 요구할 수 있는 대상 기관으로 수사기관을 명시하고 있지 않고, 요구할 수 있는 자료나 정보의 종류로 수사기록을 규정하고 있지도 않은 점, 같은 법 제28조제1항제3호에도 불구하고 같은 조 제7항을 별도로 규정한 것은 기존에 이미 국회, 수사기관 등 다른 기관에서 이태원참사에 관한 진상규명을 진행하여 정리·작성한 결과물인 조사기록등에 대해서는 그로 인해 이미 형성된 법률관계의 안정을 고려하여 같은 조 제1항 등에서 규정하고 있는 조사위원회의 통상적인 조사 방식과 다른 별도의 조사 방법과 절차 등을 규정한 점에 비추어 볼 때, 같은 조 제7항에서 불송치 사건에 대한 수사기록의 열람등에 대하여 구체적으로 규정하고 있지 않은 상황에서 조사위원회가 같은 조 제1항제3호의 일반적 자료제출요구 규정에 의하여 수사기관에 수사기록 제출을 요구할 수 있다고 보기는 어렵습니다.

아울러 이태원참사진상규명법 제정 당시의 입법과정을 살펴보면, 2023년 4월 20일 의안번호 2121515호로 발의된 이태원참사진상규명법안 제29조제7항(현행 제28조제7항) 제3호에서는 조사위원회가 열람등을 할 수 있는 조사기록등의 종류로 불송치 또는 수사중지된 사건을 별도로 규정하고 있었으나⁷⁾, 2024년 5월 21일 법률 제20427호로 제정된 이태원 참사진상규명법 제28조제7항에서는 국회 교섭단체 간 합의사항을 반영하여 해당 내용이 삭제되고 현행과 같이 규정된 것인바⁸⁾, 이처럼 입법과정에서 불송치 사건에 대한 수사기록은 조사위원회의 열람등이 가능한 조사기록등에서 삭제된 바가 있었다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이태원참사진상규명법 제28조제1항제3호를 근거로 불송치 사건에 대한 수사 기록을 요구할 수 없습니다.

6) 법제처 2009. 11. 27. 회신 09-0365 해석례, 법제처 2016. 3. 29. 회신 15-0726 해석례 등 참조

7) 2023. 4. 20. 의안번호 2121515호로 발의된 이태원참사진상규명법안 의안원문 참조

8) 2024. 5. 1. 의안번호 2126661호로 발의된 이태원참사진상규명법안에 대한 국회 행정안전위원회 검토보고서 참조

**10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법**

제6조(10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회의 설치) ① 10·29이태원 참사의 발생원인과 책임소재 등에 관한 진상을 규명하기 위하여 10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(이하 “조사위원회”라 한다)를 둔다.

② 조사위원회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 10·29이태원참사의 원인 및 책임소재 규명에 관한 사항
2. 10·29이태원참사와 관련한 국가 등의 재난의 예방·대비·대응 및 복구 등 전 과정의 적정성 조사에 관한 사항
3. 10·29이태원참사와 유사한 재난의 재발방지를 위한 재난 및 안전관리 관련 법령, 제도, 정책, 관행 등에 대한 개선 또는 대책 수립에 관한 사항
4. 10·29이태원참사 이후 희생자와 피해자의 권리침해 등 피해 실태 및 구제방안에 대한 조사에 관한 사항
5. 피해자 지원대책의 점검 및 개선에 관한 사항
6. 조사위원회의 운영에 관한 규칙의 제정·개정에 관한 사항
7. 그 밖에 이 법의 목적 실현을 위하여 조사위원회가 필요하다고 판단하는 사항

제28조(조사의 방법) ① 조사위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 조사를 수행할 수 있다.

1. 2. (생략)
3. 조사대상자 및 참고인, 그 밖의 관계 기관·시설·단체 등에 대하여 제6조제2항에 따른 조사위원회 업무에 필요하다고 인정되는 자료 또는 물건의 제출요구 및 제출된 자료 또는 물건의 보관
4. ~ 6. (생략)
- ② 조사위원회가 제1항에 따른 요구 등의 조치를 하는 경우 이를 요구받은 자는 지체 없이 이에 응하여야 한다.
- ③ 조사위원회가 제1항제2호에 따라 진술을 청취하는 경우 「형사소송법」 제147조부터 제149조까지 및 제244조의3을 준용한다.
- ④ 조사위원회가 제1항제3호에 따라 자료 또는 물건의 제출요구를 하는 경우 「형사소송법」 제110조부터 제112조까지, 제129조부터 제131조까지 및 제133조를 준용하되, 자료 또는 물건의 제출을 거부하는 경우 그 사유를 구체적으로 소명하여야 한다.
- ⑤ 조사위원회는 필요하다고 인정하는 경우 위원 또는 직원으로 하여금 제1항 각 호의 조치를 하게 할 수 있다.
- ⑥ 조사위원회가 제1항에 따른 권한을 행사하는 경우 그 권한을 행사하는 위원 또는 직원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 제시하여야 한다.
- ⑦ 조사위원회는 조사를 수행함에 있어서 다음 각 호에 대해서는 조사기록, 재판기록 및 그 밖의 기록(이하 이 조에서 “조사기록등”이라 한다)의 열람, 등사, 사본의 제출요구 등(이하 이 조에서

“열람등”이라 한다)을 통한 조사를 할 수 있다. 이 경우 제1항부터 제6항까지, 제29조 및 제33조부터 제37조까지는 적용하지 아니한다.

1. 용산 이태원 참사 진상규명과 재발방지를 위한 국정조사특별위원회의 조사를 통하여 확인된 사실
2. 형사재판이 진행 중이거나 확정된 사건의 확인된 사실

⑧ 조사위원회가 제7항에 따라 조사기록등의 열람등을 요구한 경우 그 요구를 받은 자는 지체 없이 이에 응하여야 한다.

질의제목 8

▶ 안전번호 25-0022

문화체육관광부 - 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」에 따라 설립된 국립대학법인 서울대학교가 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 공공법인에 해당하는지 여부(「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」 제2조 등 관련)

01 질의요지

「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」(이하 “정부광고법”이라 함) 제2조제2호에서는 “공공법인”이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 지정된 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 특별법에 따라 설립된 법인을 말한다고 정의하고 있는바,

「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」(이하 “서울대법”이라 함)에 따라 설립된 국립대학법인 서울대학교(이하 “서울대학교”라 함)가 정부광고법 제2조제2호에 따른 “특별법에 따라 설립된 법인”에 해당하는지?

02 회답

서울대법에 따라 설립된 서울대학교는 정부광고법 제2조제2호에 따른 “특별법에 따라 설립된 법인”에 해당합니다.

03 이유

정부광고법에서는 정부기관등¹⁾의 장은 정부광고의 시행에 필요한 연간 계획을 수립하고(제3조제2항), 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청해야 한다고(제5조) 규정하여, 광고의뢰 의무가 있는 자로 “정부기관” 및 “공공법인”을

1) 정부기관 또는 공공법인을 말하며(정부광고법 제2조제3호 참조), 이하 같음

규정하고 있는데, 같은 법 제2조제2호에서는 “공공법인”으로 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 지정된 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 “특별법에 따라 설립된 법인”을 규정하고 있는바, 정부광고법에 따라 광고의뢰 의무가 있는 “특별법에 따라 설립된 법인”에 해당하는지 여부는 정부광고의 효율성 및 공익성을 향상시키려는 같은 법의 입법 목적과 법인의 설립근거가 되는 법률에서 해당 법인에게 공공적 역할이나 기능을 수행하도록 하고 있는지, 조직구성이나 활동에 대한 행정적 관리·감독 등에서 「민법」이나 「상법」 등에 따라 설립된 일반 법인과 달리 규율하고 있는지, 국가나 지방자치단체의 재정적 지원 등이 있는지, 해당 법인에 대하여 광고의뢰 의무를 부여할 필요성이 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단할 필요가 있습니다²⁾.

먼저 서울대법은 서울대학교를 설립하고 그 운영 등에 관한 사항을 규정함으로써 대학의 자율성과 사회적 책무를 제고하고 교육 및 연구 역량을 향상시킴을 목적으로 하는 법률(제1조)이고, 같은 법 제3조에서는 서울대학교는 법인으로 한다고 규정하고 있어, 서울대학교는 해당 법인의 설립 및 규율을 목적으로 하는 서울대법에 따라 설립된 법인으로, 「고등교육법」 제2조에 따라 고등교육을 실시하는 학교에 해당하는데, 「교육기본법」 제9조제2항에서 학교는 공공성을 가진다고 규정하고 있으며, 서울대법 제31조에서는 국립대학의 사회적 책무를 규정하면서 같은 조 제1항에서는 서울대학교는 기초학문 등 필요한 분야의 지원·육성에 관한 4년 단위의 계획을 수립·공표하고, 매년 실행계획을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 서울대학교는 우수하고 창의적인 인재를 양성하기 위한 교육·연구 환경을 조성하고, 학비 부담을 최소화할 수 있는 장학·복지 시책을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있는바, 「교육기본법」 및 서울대법에서는 서울대학교가 고등교육을 실시하는 학교이자 국립대학으로서 공공적 역할 및 기능을 수행하도록 하고 있습니다.

또한 서울대법에서 규정하고 있는 서울대학교의 이사회 구성 및 감사에 관한 사항을 살펴보면, 총장은 이사회가 선출하여 교육부장관의 제청으로 대통령이 임명하고(제7조제1항), 이사로는 기획재정부장관이 지정하는 차관 1명 및 교육부장관이 지정하는 차관 1명을 포함하며, 이사는 이사회에서 선임하되, 교육부장관의 취임 승인을 받아야 한다고 규정하면서(제9조제1항), 이사회에서 총장의 선임에 관한 사항, 임원의 선임 및 해임에 관한 사항, 예산·결산에 관한 사항 및 정관으로 정하는 주요 조직의 설치·폐지에 관한 사항 등을 심의·의결하도록 규정하고 있고(제12조), 감사 중 상근(常勤)하는 감사 1명은 교육부장관의

2) 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008두5643 판결례, 법제처 2022. 9. 14. 회신 22-0333 해석례 및 법제처 2024. 12. 30. 회신 24-0854 해석례 참조

추천을 받아 취임한 감사로 하도록 규정하는(제13조) 등 서울대학교에 관한 중요한 사항을 심의·의결하는 과정 및 이사회 구성 등에 관한 규정을 종합해 보면, 서울대법에서는 서울대학교의 공공성 등을 고려하여 「민법」 또는 「상법」에 따라 설립된 일반법인 과 달리 그 관리·감독에 관한 사항을 구체적으로 규정하고 있다고 할 것입니다.

그리고 서울대학교는 설립 과정에서 서울대법 제22조에 따라 서울대학교 설립 당시의 서울대학교가 관리하고 있던 국유재산·공유재산을 국가·지방자치단체로부터 무상으로 양도받았고³⁾, 이처럼 국가 또는 지방자치단체로부터 무상으로 양도받은 재산을 포함한 자산의 평가액 등을 바탕으로 서울대학교의 자본금이 결정되는 점(제20조), 서울대학교 설립 이후에도 같은 법 제29조 및 제30조에 따라 매년 국가 및 지방자치단체로부터 인건비, 경상적 경비, 시설확충비 및 교육·연구 발전을 위한 지원금 등을 계속적으로 지원받게 되는 점 등을 종합해 볼 때, 서울대학교는 서울대법에 따라 그 설립 및 운영 과정에서 국가나 지방자치단체의 재정적 지원을 받고 있습니다.

아울러 정부광고법 제2조제3호에서는 “정부광고”란 정부기관 또는 공공법인이 국내외의 홍보매체에 광고, 홍보, 계도 및 공고 등을 하기 위한 모든 유료고지 행위를 말한다고 정의하고 있고, 같은 법에서는 특별법에 따라 설립된 법인을 포함한 “공공법인”에 대하여 같은 법 제5조에 따라 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하도록 의무를 부과하고 있는데, 이러한 의무 부과는 정부광고의 효율성 및 공익성을 향상시키기 위한 것인바⁴⁾, 앞에서 살펴본 것처럼 국립대학법인으로서 공공적 역할 및 기능을 수행하는 서울대학교는 정부광고법 제2조 제2호에 따른 공공법인에 해당한다고 보아 서울대학교가 정부광고를 하려는 경우에도 같은 법 제5조에 따라 미리 문화체육관광부장관에게 광고를 의뢰하도록 하는 것이 정부광고의 효율성 및 공익성 향상에 부합한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 서울대법에 따라 설립된 서울대학교는 정부광고법 제2조제2호에 따른 “특별법에 따라 설립된 법인”에 해당합니다.

3) 헌법재판소 2014. 4. 24. 결정 2011헌마612 결정례 참조

4) 법제처 2022. 9. 14. 회신 22-0333 해석례 및 법제처 2024. 12. 30. 회신 24-0854 해석례 참조



관계법령

정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “정부기관”이란 「정부조직법」에 따른 국가기관, 「지방자치법」 제2조제1항 각 호에 따른 지방자치단체 및 같은 조 제3항에 따른 특별지방자치단체, 「지방교육자치에 관한 법률」 제18조에 따른 교육감 및 같은 법 제34조에 따른 하급교육행정기관을 말한다.
2. “공공법인”이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 지정된 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 특별법에 따라 설립된 법인을 말한다.
3. “정부광고”란 정부기관 또는 공공법인(이하 “정부기관등”이라 한다)이 국내외의 홍보매체에 광고, 홍보, 계도 및 공고 등을 하기 위한 모든 유료고지 행위를 말한다.
4. (생략)

제5조(광고의뢰) 정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다.

국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률

제1조(목적) 이 법은 국립대학법인 서울대학교를 설립하고 그 운영 등에 관한 사항을 규정함으로써 대학의 자율성과 사회적 책무를 제고하고 교육 및 연구 역량을 향상시킴을 목적으로 한다.

제3조(법인격 등) ① 국립대학법인 서울대학교는 법인으로 한다.

- ② 국립대학법인 서울대학교는 주된 사무소의 소재지에 설립등기를 함으로써 설립된다.
- ③ 국립대학법인 서울대학교의 설립등기와 그 밖에 등기에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

질의제목 9

▶ 안전번호 25-0027

민원인 - 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」의 적용 대상이 되는 공공재정 지급금의 범위(「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률 시행령」 제2조제1호 등 관련)

01 질의요지

「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」(이하 “공공재정환수법”이라 함) 제2조제5호에서 공공재정지급금을 법령 또는 자치법규에 따라 공공재정¹⁾에서 제공되는 보조금·보상금·출연금이나 그 밖에 상당한 반대급부를 받지 아니하고 제공되는 금품 등²⁾으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제2조제1호에서는 공공재정지급금의 구체적인 범위로 “「보조금 관리에 관한 법률」(이하 “보조금법”이라 함) 제2조제1호 또는 「지방재정법」 제23조에 따라 교부되는 보조금 등 공익사업을 조성하거나 재정을 지원하기 위해 제공되는 금품등”을 규정하고 있는 한편,

「지방교육재정교부금법」 제5조제1항에서는 교육부장관은 기준재정수입액³⁾이 기준재정수요액⁴⁾에 미치지 못하는 지방자치단체에 대해서는 그 부족한 금액을 기준으로 하여 보통교부금을 총액으로 교부한다고 규정하고 있는바,

교육부장관이 「지방교육재정교부금법」 제5조제1항에 따라 지방자치단체에 교부한 보통교부금(이하 “이 사안 보통교부금”이라 함)은 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률 시행령」(이하 “공공재정환수법 시행령”이라 함) 제2조제1호에 따른 “보조금 등”에 해당하는지⁵⁾

- 1) 공공기관이 조성·취득하거나 관리·처분·사용하는 금품등을 말하며(공공재정환수법 제2조제4호 참조), 이하 같음
- 2) 금전, 채권, 물품, 상품권, 이용권, 그 밖에 이에 준하는 증표 중 어느 하나에 해당하는 것을 말하며(공공재정환수법 제2조제3호 참조), 이하 같음
- 3) 일반회계 전입금 등 교육·학예에 관한 지방자치단체 교육비특별회계의 수입예상액으로서 「지방교육재정교부금법」 제7조에 따라 산정한 금액을 말함
- 4) 「지방교육재정교부금법」 제6조에 따라 산정한 금액을 말함
- 5) 이 사안의 보통교부금이 공공재정환수법 시행령 제2조제1호 외의 다른 호의 적용 대상에 해당하는지 여부 및 지방자치단체가 교육부장관으로부터 교부받은 보통교부금을 재원으로 예산을 편성하여 개인 또는 단체 등에게 교부한 금품등이 “보조금 등”에 해당하는지에 대해서는 별도로 논의하지 않음

02 회답

이 사안 보통교부금은 공공재정환수법 시행령 제2조제1호에 따른 “보조금 등”에 해당하지 않습니다.

03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 할 것입니다⁶⁾.

공공재정환수법 시행령 제2조제1호에서는 공공재정지급금의 범위 중 하나로 보조금법 제2조제1호 또는 「지방재정법」 제23조에 따라 교부되는 “보조금 등” 공익사업을 조성하거나 재정을 지원하기 위해 제공되는 금품등을 규정하고 있는데, 공공재정환수법 시행령 제2조제1호에서는 “보조금 등”에 포함될 수 있는 예시사항으로 “보조금법 제2조제1호 또는 「지방재정법」 제23조에 따라 교부되는 보조금”을 규정하고 있고, 보조금법 제2조제1호에서는 “보조금”이란 국가 외의 자가 수행하는 사무 또는 사업에 대하여 국가가 이를 조성하거나 재정상의 원조를 하기 위하여 교부하는 보조금(지방자치단체에 교부하는 것과 그 밖에 법인·단체 또는 개인의 시설자금이나 운영자금으로 교부하는 것만 해당함), 부담금, 그 밖에 상당한 반대급부를 받지 아니하고 교부하는 급부금으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다고 정의하고 있으며, 「지방재정법」 제23조제1항에서는 국가는 정책상 필요하다고 인정할 때 또는 지방자치단체의 재정 사정상 특히 필요하다고 인정할 때에는 예산의 범위에서 지방자치단체에 보조금을 교부할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 「지방교육재정교부금법」에 따른 이 사안 보통교부금이 공공재정환수법의 적용 대상이 되는 같은 법 시행령 제2조제1호의 “보조금 등”에 해당하는지 여부는 보조금 등에 관한 관련 법령의 문언만으로는 명확히 구분하기 어려운 점이 있는바, 이 사안 보통교부금이 공공재정환수법의 적용 대상이 되는 “공공재정지급금”인 “보조금 등”에 해당되는지 여부를 판단하기 위해서는 공공재정환수법의

6) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

입법 취지, 보조금법 등 관계 법령의 규정 체계 등을 종합적으로 고려하여 해석해야 할 것입니다.

먼저 공공재정환수법은 공공재정에 대한 부정청구 등이 지속적으로 발생하고 있으나, 이러한 행위가 적발되더라도 경미한 제재에 그치거나 환수할 수 있는 근거 규정이 마련되어 있지 않은 경우가 많아, 고의적이고 상습적인 부정청구 등을 방지하는 데 한계가 있던 점을 고려하여 공공재정에 대한 부정청구 등을 금지하고, 부정청구로 인하여 얻은 이익을 전액 환수하도록 하는 등 부정청구 등으로 인하여 발생한 이익에 대한 환수·관리 체계를 확립하기 위하여⁷⁾ 제정된 법률로서, 같은 법 제2조제6호에서는 “부정청구등”이란 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공공재정지급금을 청구할 자격이 없는 데도 청구하는 행위(가목), 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 과다하게 공공재정지급금을 청구하는 행위(나목), 법령·자치법규나 기준에서 정한 절차에 따르지 아니하고 정해진 목적이나 용도와 달리 공공재정지급금을 사용하는 행위(다목) 등 각 목 중 어느 하나에 해당하는 행위로 공공재정에 손해를 입히거나 이익을 얻는 일체의 행위라고 규정하고 있고, 이러한 공공재정지급금의 부정청구등이 있는 경우 부정이익의 환수(제8조), 제재부가금(제9조) 등의 적용 대상이 되는 바, 공공재정환수법의 적용 대상이 되는 “공공재정지급금” 중 하나로서 같은 법 시행령 제2조제1호에 따른 “보조금 등”의 범위를 해석할 때에는 교부 상대방의 청구 행위가 있는지 여부, 사용의 목적이나 용도를 정하고 있는지 여부 등을 고려해야 할 것입니다.

그런데 보조금법에 따라 교부되는 보조금의 경우를 살펴보면, 보조금법에서는 보조금의 교부 대상이 되는 사무 또는 사업을 보조사업으로 규정하면서(제2조제2호), 보조금의 교부를 받으려는 자는 해당 보조사업의 목적과 내용, 보조사업에 드는 경비, 그 밖에 필요한 사항을 적은 신청서를 중앙관서의 장에게 제출하도록 규정하고 있고(제16조제1항), 보조사업자는 교부받은 보조금을 다른 용도에 사용하여서는 안 된다고 규정(제22조제1항)하고 있는 반면⁸⁾, 이 사안 보통교부금은 기준재정수요액과 기준재정수입액의 차이인 지방자치단체의 재정부족분을 기준으로 매년 교부되는 것으로서, 지방교육재정교부금법령에서 정하고 있는 측정항목·측정단위·산정공식 및 단위비용 등을 기준으로 재정부족분이 산정되어 교부되므로, 그 교부를 받기 위한 지방자치단체의 신청이나 청구행위가 별도로 필요하지 않고⁹⁾, 이러한 보통교부금은 지방자치단체의 일반적 사무수행경비나 운영경비를 보장하기

7) 2019. 4. 16. 법률 제16323호로 제정된 공공재정환수법 제정이유 참조

8) 「지방재정법」 제23조 및 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」에 따라 지방자치단체가 교부하는 “지방보조금”의 경우에도 「보조금 관리에 관한 법률」에 따른 ‘보조금’과 유사한 내용 및 규정 체계를 따르고 있음

9) 「지방교육재정교부금법 시행규칙」 제3조 등 참조

위해 교부하는 재원¹⁰⁾이며, 「지방교육재정교부금법」 제5조제1항에서도 이 사안 보통교부금을 “총액”으로 교부한다고 규정하여 보통교부금의 사용 목적이나 용도도 특정되지 않는바, 이 사안 보통교부금은 신청이나 청구행위를 할 수 없고 그 용도가 정해진 것도 아니어서 통상적인 보조금의 경우와는 달리 부정청구등에 해당하는 행위가 발생할 수 없다는 점에서, 공공재정환수법의 적용 대상이 되는 “공공재정지급금”인 “보조금 등”의 범위에는 포함되지 않는다고 할 것입니다.

또한 공공재정환수법 제8조 및 제9조에서는 공공재정지급금의 부정청구등이 있는 경우 그 부정이익 등의 환수, 부정이익 가액의 5배 이내에서의 제재부가금을 부과·징수하도록 하고 있고, 같은 법 제28조의2에서는 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공공재정지급금을 청구할 자격이 없는데도 공공재정지급금을 지급받은 자(제1항제1호) 등에 대해서는 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있는데, 특별한 사정이 없는 한 침익적 행정행위 등의 대상이 되는 같은 법 시행령 제2조제1호에 따른 “보조금 등”의 범위에 관하여는 그 상대방에게 불리한 방향으로 유추해석하거나 확장해석을 하여서는 안 된다고 할 것인바¹¹⁾, 교육의 균형 있는 발전을 위하여 지방자치단체가 국가로부터 용도 지정 없이 총액으로 교부받는 이 사안 보통교부금은, 명문의 규정 없이 공공재정환수법 시행령 제2조제1호에 따른 “보조금 등”의 범위에 해당한다고 해석하기는 어렵습니다.

아울러 「지방교육재정교부금법」 제8조제1항에서는 교부금이 산정자료의 착오 또는 거짓으로 인하여 부당하게 교부되었을 때에는 교육부장관은 해당 시·도가 정당하게 받을 수 있는 교부금액을 초과하는 금액을 다음에 교부할 교부금에서 감액한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 지방자치단체가 법령을 위반하여 지나치게 많은 경비를 지출하였거나 확보하여야 할 수입의 징수를 게을리 하였을 때에는 교육부장관은 그 지방자치단체에 교부할 교부금을 감액하거나 이미 교부한 교부금의 일부를 반환할 것을 명할 수 있다고 규정하고 있는 등 보통교부금의 부당한 교부 등이 발생한 경우에 이를 조정하거나 반환할 수 있는 규정이 지방교육재정교부금법령에 마련되어 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안 보통교부금은 공공재정환수법 시행령 제2조제1호에 따른 “보조금 등”에 해당하지 않습니다.

10) 「지방교육재정교부금법」 제5조 및 헌법재판소 2006. 3. 30. 결정 2005헌라1 결정례 참조

11) 대법원 2008. 2. 28. 선고 2007두13791, 13807 판결례 등 참조



관계법령

공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 4. (생 략)
5. “공공재정지급금”이란 법령 또는 자치법규에 따라 공공재정에서 제공되는 보조금·보상금·출연금이나 그 밖에 상당한 반대급부를 받지 아니하고 제공되는 금품등으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.
6. ~ 8. (생 략)

공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률 시행령

제2조(공공재정지급금의 범위) 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제5호에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 「보조금 관리에 관한 법률」 제2조제1호 또는 「지방재정법」 제23조에 따라 교부되는 보조금 등 공익사업을 조성하거나 재정을 지원하기 위해 제공되는 금품등
2. ~ 7. (생 략)

지방교육재정교부금법

제1조(목적) 이 법은 지방자치단체가 교육기관 및 교육행정기관(그 소속기관을 포함한다. 이하 같다)을 설치·경영하는 데 필요한 자원(財源)의 전부 또는 일부를 국가가 교부하여 교육의 균형 있는 발전을 도모함을 목적으로 한다.

제3조(교부금의 종류와 재원) ① 국가가 제1조의 목적을 위하여 지방자치단체에 교부하는 교부금(이하 “교부금”이라 한다)은 보통교부금과 특별교부금으로 나눈다.

- ② ~ ④ (생 략)

제5조(보통교부금의 교부) ① 교육부장관은 기준재정수입액이 기준재정수요액에 미치지 못하는 지방자치단체에 대해서는 그 부족한 금액을 기준으로 하여 보통교부금을 총액으로 교부한다.

- ② (생 략)

질의제목 10

▶ 안건번호 25-0032

민원인 - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제57조제1항에 따른 개발행위허가 신청 대리 업무가 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지 여부 (「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련)

01 질의요지

「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理) 업무를 행정사¹⁾의 업무 중 하나로 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제2조제5호에서는 같은 법 제2조제1항제5호에 따른 행정사 업무의 내용과 범위로 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일을 규정하고 있는 한편,

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 함) 제56조제1항 본문에서는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치(제1호), 토지의 형질 변경(제2호) 등에 해당하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위(이하 “개발행위”라 함)를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(이하 “시장등”이라 함)의 허가(이하 “개발행위허가”라 함)를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제57조제1항에서는 개발행위를 하려는 자는 그 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보, 위해(危害) 방지, 환경오염 방지, 경관, 조경 등에 관한 계획서를 첨부한 신청서를 개발행위허가권자에게 제출하여야 한다고 규정하고 있는바,

국토계획법 제57조제1항에 따른 개발행위허가의 신청을 대리하는 것²⁾이 「행정사법」 제2조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제2조제5호에 따른 행정사의 업무에 포함되는지³⁾

1) 「행정사법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조제1호에 따른 일반행정사를 말하며, 이하 같음

2) 국토계획법 제56조제1항제1호의 행위 중 「건축법」의 적용을 받는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치를 하려는 자에 해당하지 않으며, 국토계획법 제61조에 따른 관련 인·허가등의 의제를 받지 않는 경우를 전제함

3) 개발행위허가 신청의 대리업무가 행정사가 아닌 사람이 업으로 수행할 수 있는 ‘다른 법률에 따라 허용되는 업무’인지 여부는 별도로 논의하지 않음(「행정사법」 제3조제1항 참조)

02 회답

국토계획법 제57조제1항에 따른 개발행위허가의 신청을 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제2조제5호에 따른 행정사의 업무에 포함됩니다.

03 이유

먼저 「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 수행할 수 있는 업무의 하나로 ‘인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理)’ 업무를 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제2조제5호에서는 같은 법 제2조제1항제5호에 따라 행정사가 수행할 수 있는 업무의 내용과 범위를 ‘다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일’로 구체화하고 있습니다.

그런데 국토계획법 제56조제1항 본문에서는 개발행위를 하려는 자는 시장등의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제57조제1항에서는 개발행위를 하려는 자는 그 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보, 위해(危害) 방지, 환경오염 방지, 경관, 조경 등에 관한 계획서를 첨부한 신청서를 개발행위허가권자에게 제출하여야 한다고 규정하여 개발행위허가권자인 시장등에게 개발행위허가 신청을 하도록 규정하고 있는바, 행정기관은 일반적으로 “국가 또는 지방자치단체의 행정사무를 맡아보는 기관”⁴⁾으로서, “시장등”은 「지방자치법」에 따라⁵⁾ 지방자치단체의 행정사무를 맡아보는 집행기관으로 “행정기관”에 해당하고, 행정기관에 개발행위허가를 신청하는 것은 “허가의 신청 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하는 일”에 해당하여 국토계획법 제57조제1항에 따른 개발행위허가 신청을 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제2조제5호에 따라 다른 사람의 위임을 받아 허가의 신청 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하는 일을 대리하는 일로서 행정사의 업무에 포함된다는 점이 문언상 명확합니다.

그리고 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리 등 사인의 행정기관 상대 민원 업무를 대신하거나 도와주는

4) 국립국어원 표준국어대사전 참조

5) 「지방자치법」 제106조, 제114조 및 제116조 등 참조

일을 하는 직역으로⁶⁾ 행정사 제도는 일반적인 행정지식만으로 수행할 수 있는 기본적인 행정 사무를 분야별 전문자격자에게 맡기지 않고도 저렴한 비용으로 해당 서비스를 이용할 수 있도록 별도의 자격 제도를 마련한 것⁷⁾인바, 국토계획법령에 따른 개발행위허가 신청은 「행정사법」 제2조제1항에 해당하는 기본적인 행정사무에 해당하여 행정사의 일반적인 업무범위에 속한다는 점, 국토계획법령에는 달리 개발행위허가 신청의 대리를 특정 자격이 있는 자만 수행할 수 있도록 제한하는 규정도 없는 점 등을 고려하면 행정사가 개발행위 허가신청의 대리를 수행할 수 있다고 해석하는 것이 국민의 편의 증진을 위하여 행정사로 하여금 기본적인 행정사무를 취급할 수 있도록 하고 있는 「행정사법」의 취지에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

따라서 국토계획법 제57조제1항에 따른 개발행위허가의 신청을 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제2조제5호에 따른 행정사의 업무에 포함됩니다.



관계법령

행정사법

제2조(업무) ① 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 다음 각 호의 업무를 수행한다. 다만, 다른 법률에 따라 제한된 업무는 할 수 없다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理)
- 6.·7. (생 략)
- ② (생 략)

행정사법 시행령

제2조(업무의 내용과 범위) 「행정사법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항 각 호에 따른 행정사 업무의 내용과 범위는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 법 제2조제1항제5호의 사무: 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일
- 6.·7. (생 략)

6) 헌법재판소 2015. 3. 26. 선고 2013헌마131 결정례 참조

7) 법제처 2015. 10. 23. 회신 15-0443 해석례 참조

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제56조(개발행위의 허가) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위(이하 “개발행위”라 한다)를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가(이하 “개발행위허가”라 한다)를 받아야 한다. 다만, 도시·군계획사업(다른 법률에 따라 도시·군계획사업을 의제한 사업을 포함한다)에 의한 행위는 그러하지 아니하다.

1. 건축물의 건축 또는 공작물의 설치
2. 토지의 형질 변경(경작을 위한 경우로서 대통령령으로 정하는 토지의 형질 변경은 제외한다)
3. 토석의 채취
4. 토지 분할(건축물이 있는 대지의 분할은 제외한다)
5. 녹지지역·관리지역 또는 자연환경보전지역에 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위

② ~ ④ (생 략)

제57조(개발행위허가의 절차) ① 개발행위를 하려는 자는 그 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보, 위해(危害) 방지, 환경오염 방지, 경관, 조경 등에 관한 계획서를 첨부한 신청서를 개발행위허가권자에게 제출하여야 한다. 이 경우 개발밀도관리구역 안에서는 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보에 관한 계획서를 제출하지 아니한다. 다만, 제56조제1항제1호의 행위 중 「건축법」의 적용을 받는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치를 하려는 자는 「건축법」에서 정하는 절차에 따라 신청서류를 제출하여야 한다.

② ~ ④ (생 략)

질의제목 11

▶ 안전번호 25-0043

문화체육관광부 - 「중소기업협동조합법」에 따라 설립된 중소기업중앙회가 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 공공법인에 해당하는지 여부(「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」 제2조 등 관련)

01 질의요지

「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」(이하 “정부광고법”이라 함) 제2조 제2호에서는 “공공법인”이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 지정된 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 특별법에 따라 설립된 법인을 말한다고 정의하고 있는바,

「중소기업협동조합법」에 따라 설립된 중소기업중앙회가 정부광고법 제2조제2호에 따른 “특별법에 따라 설립된 법인”에 해당하는지?

02 회답

「중소기업협동조합법」에 따라 설립된 중소기업중앙회는 정부광고법 제2조제2호에 따른 “특별법에 따라 설립된 법인”에 해당합니다.

03 이유

정부광고법에서는 정부기관등¹⁾의 장은 정부광고의 시행에 필요한 연간 계획을 수립하고(제3조제2항), 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청해야 한다고(제5조) 규정하여, 광고의뢰 의무가 있는 자로 “정부기관” 및 “공공법인”을 규정하고 있는데, 같은 법 제2조제2호에서는 “공공법인”으로 「공공기관의 운영에 관한 법률」

1) 정부기관 또는 공공법인을 말하며(정부광고법 제2조제3호 참조), 이하 같음

제4조제1항에 따라 지정된 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 “특별법에 따라 설립된 법인”을 규정하고 있는바, 정부광고법에 따라 광고의뢰 의무가 있는 “특별법에 따라 설립된 법인”에 해당하는지 여부는 정부광고의 효율성 및 공익성을 향상시키려는 같은 법의 입법 목적과 법인의 설립근거가 되는 법률에서 해당 법인에게 공공적 역할이나 기능을 수행하도록 하고 있는지, 조직구성이나 활동에 대한 행정적 관리·감독 등에서 「민법」이나 「상법」 등에 따라 설립된 일반 법인과 달리 규율하고 있는지, 국가나 지방자치단체의 재정적 지원 등이 있는지, 해당 법인에 대하여 광고의뢰 의무를 부여할 필요성이 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단할 필요가 있습니다²⁾.

먼저 「중소기업협동조합법」은 중소기업자가 협동 사업을 추진하는 협동 조직의 설립·운영 및 육성에 관한 사항을 정하여 중소기업자의 경제적 지위의 향상과 국민경제의 균형 있는 발전을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 같은 법 제4조제1항에서 중소기업협동조합인 협동조합, 사업협동조합, 협동조합연합회와 중소기업중앙회는 법인으로 한다고 규정하고 있으므로, 중소기업중앙회는 「중소기업협동조합법」에 따라 설립된 법인에 해당합니다.

또한 「중소기업협동조합법」 제7조제1항제1호에서는 중소기업중앙회는 회원의 상호부조를 목적으로 하되, 영리를 목적으로 하지 아니할 것을 규정하고, 같은 법 제8조제1항 및 제2항에서는 중소기업중앙회는 정치에 관한 모든 행위를 할 수 없으며, 공직선거에서 특정 정당을 지지하는 행위 등을 하여서는 아니 된다고 규정하고 있는데, 이러한 규정들은 중소기업중앙회가 공공성이 매우 큰 업무를 담당하여 상당한 정도의 공익단체성, 공법인성을 가지고 있는 것³⁾을 고려한 것이라고 할 것입니다.

그리고 「중소기업협동조합법」 제9조제1항 및 제2항에서는 중소기업중앙회의 사업에 대한 정부 및 지방자치단체 등의 협력 의무를 규정하고 있고, 같은 법 제106조제1항제13호에서는 중소기업중앙회의 사업 범위로 국가 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 사업을 규정하고 있으며, 같은 법 제109조에서는 중소기업공제사업기금과 관련하여 기금의 조성에 정부의 출연금이 포함되고, 정부가 중소기업자의 중소기업공제사업기금 가입을 촉진하기 위하여 필요한 지원을 할 수 있다고 규정하고 있는바, 이처럼 국가가 그 육성을 위해 재정을 보조해주고 중소기업중앙회의 업무에 적극 협력할 의무를 부담하는 것은 중소기업중앙회가 수행하는 업무가 단순히 구성원의 이익만을 위한 것이 아니라 중소기업 전체를 위한 측면이 있고, 국가의

2) 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008두5643 판결례, 법제처 2020. 4. 21. 회신 20-0064 해석례 및 법제처 2022. 9. 14. 회신 22-0333 해석례 참조

3) 헌법재판소 2021. 7. 15. 선고 2020헌가9 결정례 참조

중소기업 관련 정책 수행을 보조하는 기능도 담당하는 등⁴⁾ 중소기업중앙회가 국민경제 및 산업에 미치는 영향이 증대하기 때문으로 보아야 할 것입니다.

더욱이 「중소기업협동조합법」은 ① 같은 법 제106조제1항에서 중소기업중앙회가 할 수 있는 사업을 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항의 사업을 추진하기 위하여 필요하면 주무관청의 승인을 받아 다른 법인에 출자할 수 있도록 하고 있고, 같은 조 제5항에서는 같은 조 제4항에 따른 정회원의 업무 및 회계에 관한 감사 결과를 주무관청에 보고하도록 하고 있으며, 같은 법 제107조제1항에서 중소기업중앙회는 사업연도 사업계획과 수지예산서를 작성하여 총회의 의결을 거쳐 주무관청에 승인을 신청하여야 한다고 규정하고 있고, ② 같은 법 제131조제1항에서는 주무관청은 상당한 이유가 있으면 중소기업중앙회로부터 그 업무나 회계에 관하여 필요한 보고를 받거나 그 업무나 회계의 상황을 검사할 수 있도록 규정하고 있으며, ③ 같은 법 제133조제1항에서는 주무관청이 중소기업중앙회에 일정한 기한을 정하여 업무의 시정과 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다고 규정하는 등 중소기업중앙회를 「민법」이나 「상법」에 따라 설립된 일반 법인과 달리 규율하고 있다고 할 것입니다.

아울러 정부광고법 제2조제3호에서는 “정부광고”란 정부기관 또는 공공법인이 국내외의 홍보매체에 광고, 홍보, 계도 및 공고 등을 하기 위한 모든 유료고지 행위를 말한다고 정의하고 있고, 같은 법에서는 특별법에 따라 설립된 법인을 포함한 “공공법인”에 대하여 같은 법 제5조에 따라 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하도록 의무를 부과하고 있는데, 이러한 의무 부과는 정부광고의 효율성 및 공익성을 향상시키기 위한 것인바⁵⁾, 공공성이 매우 큰 업무를 담당하여 상당한 정도의 공익단체성, 공법인성을 가지고 있는⁶⁾ 중소기업중앙회는 정부광고법 제2조제2호에 따른 공공법인에 해당한다고 보아 중소기업중앙회가 정부광고를 하려는 경우에도 같은 법 제5조에 따라 미리 문화체육관광부장관에게 광고를 의뢰하도록 하는 것이 정부광고의 효율성 및 공익성 향상에 부합하다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「중소기업협동조합법」에 따라 설립된 중소기업중앙회는 정부광고법 제2조제2호에 따른 “특별법에 따라 설립된 법인”에 해당합니다.

4) 헌법재판소 2021. 7. 15. 선고 2020헌가9 결정례 참조

5) 법제처 2022. 9. 14. 회신 22-0333 해석례 참조

6) 헌법재판소 2021. 7. 15. 선고 2020헌가9 결정례 참조

**정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “정부기관”이란 「정부조직법」에 따른 국가기관, 「지방자치법」 제2조제1항 각 호에 따른 지방자치단체 및 같은 조 제3항에 따른 특별지방자치단체, 「지방교육자치에 관한 법률」 제18조에 따른 교육감 및 같은 법 제34조에 따른 하급교육행정기관을 말한다.
2. “공공법인”이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 지정된 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 특별법에 따라 설립된 법인을 말한다.
3. “정부광고”란 정부기관 또는 공공법인(이하 “정부기관등”이라 한다)이 국내외의 홍보매체에 광고, 홍보, 계도 및 공고 등을 하기 위한 모든 유료고지 행위를 말한다.
4. (생 략)

제5조(광고의뢰) 정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다.

중소기업협동조합법

제1조(목적) 이 법은 중소기업자가 서로 힘을 합하여 협동 사업을 추진하는 협동 조직의 설립·운영 및 육성에 관한 사항을 정하여 중소기업자의 경제적인 기회 균등을 기하고 자주적인 경제 활동을 복돋우어 중소기업자의 경제적 지위의 향상과 국민경제의 균형 있는 발전을 꾀함을 목적으로 한다.

제3조(종류 등) ①중소기업협동조합의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 협동조합(이하 “조합”이라 한다)
2. 사업협동조합(이하 “사업조합”이라 한다)
3. 협동조합연합회(이하 “연합회”라 한다)
4. 중소기업중앙회(이하 “중앙회”라 한다)

② (생 략)

제4조(법인격과 주소) ①조합, 사업조합, 연합회와 중앙회는 법인으로 한다.

②·③ (생 략)

질의제목 12

▶ 안전번호 25-0172

민원인 - 「지방재정법」 제27조의6제1항에 따른 지방재정영향평가 시 거쳐야 하는 지방재정투자심사위원회의 심사 주체(「지방재정법」 제27조의6제1항 등 관련)

01 질의요지

「지방재정법」 제27조의6제1항 전단에서는 지방자치단체의 장은 대규모의 재정적 부담을 수반하는 국내·국제경기대회, 축제·행사, 공모사업 등의 유치를 신청하거나 응모를 하려면 미리 해당 지방자치단체의 재정에 미칠 영향을 평가하고 그 평가결과를 토대로 같은 법 제37조의3에 따른 지방재정투자심사위원회의 심사를 거쳐야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제35조의5제1항에서는 같은 법 제27조의6제1항에 따라 지방자치단체의 장이 평가하여야 하는 평가대상은 같은 영 제35조의5제1항 각 호와 같다고 규정하면서, 같은 항 제1호나목에서는 국내·국제경기대회 및 공연·축제 등의 행사성 사업으로서 시·군 및 자치구의 경우 총사업비 10억원 이상인 사업을 규정하고 있는 한편,

「지방재정법」 제37조제1항에서는 지방자치단체의 장은 재정투자사업에 관한 예산안의 편성(제1호) 등 같은 항 각 호의 사항에 대해서는 미리 그 필요성과 타당성에 대한 심사(이하 “투자심사”라 함)를 직접 하거나 행정안전부장관 또는 시·도지사에게 의뢰하여 투자심사를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제37조의3제1항 본문에서는 투자심사에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하기 위하여 지방자치단체의 장 소속으로 지방재정투자심사위원회를 둔다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제41조제2항에서는 시·군 및 자치구가 시행하는 재정투자사업에 대한 투자심사 실시 주체별 투자심사 대상을 규정하면서, 총사업비 3억원 이상 200억원 미만인 공연·축제 등 행사성 사업은 시·도지사(제2호다목)가 실시하도록 규정하고 있는바,

총사업비 10억원 이상 30억원 미만인 국내·국제경기대회 및 공연·축제 등의 행사성 사업으로서 「지방재정법」 제27조의6제1항 및 같은 법 시행령 제35조의5제1항제1호나목에 따른 시장·군수 및 자치구청장의 지방재정영향평가 대상 사업에 대하여 지방재정영향평가를 실시하는 경우, 시장·군수 및 자치구청장(이하 “시장·군수등”이라 함) 소속 지방재정투자심사위원회¹⁾의 심사를 거쳐야 하는지, 아니면 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 함) 소속 지방재정투자심사위원회의 심사를 거쳐야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 시장·군수등 소속 지방재정투자심사위원회의 심사를 거쳐야 합니다.

03 이유

「지방재정법」 제27조의6제1항 본문에서는 지방자치단체의 장은 지방재정영향평가 대상에 대하여 미리 해당 지방자치단체의 재정에 미칠 영향을 평가하고 그 평가결과를 토대로 같은 법 제37조의3에 따른 지방재정투자심사위원회의 심사를 거쳐야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제35조의5제1항에서는 각 호로 지방재정영향평가 대상 지방사업을 규정하면서, 국내·국제경기대회 및 공연·축제 등의 행사성 사업으로서 총사업비가 시·도의 경우에는 30억원 이상인 사업을(제1호가목), 시·군 및 자치구의 경우에는 10억원 이상인 사업을(제1호나목) 각각 규정하고 있는바, 이 사안과 같이 시장·군수등이 유치를 신청하거나 응모를 하려는 사업이 총사업비 10억원 이상 30억원 미만인 국내·국제경기대회 및 공연·축제 등의 행사성 사업인 경우에는 같은 영 제35조의5제1항제1호나목에 따라 지방재정영향평가 대상 사업에 해당하게 되어, 시장·군수등은 해당 지방자치단체의 재정에 미칠 영향을 평가하고 이를 토대로 지방재정투자심사위원회의 심사를 거쳐야 할 것입니다.

그런데 「지방재정법」 제27조의6에서 규정하고 있는 지방재정영향평가제도는 일부 지방자치단체에서 재정여건을 고려하지 않은 대규모 행사성 사업 등을 유치하는 등 방만한 재정운용 사례가 발생함에 따라 이러한 문제가 발생하는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로서²⁾, 같은 조 제1항 본문에서 지방자치단체의 장은 ‘해당 지방자치단체’의 재정에 미칠 영향을 평가하고 그 평가결과를 토대로 지방재정투자심사위원회의 심사를 거치도록 규정하여, 지방자치단체의 장이 대규모 재정부담을 수반하는 사업을 추진하는 경우 지방재정에 미치는 영향을 미리 평가하여 지방재정투자심사위원회의 심의를 받도록 한 것인바, 이 사안과 같이 해당 사업의 주체가 시장·군수등인 경우에는 그 행사성 사업 등의 유치에 따른 해당 시·군 및 자치구의 재정에 미칠 영향을 평가하고, 그 결과를 토대로 해당 지방자치단체의 장인 시장·군수등 소속의 지방재정투자심사위원회의 심사를 거쳐야 한다고 해석하는 것이 해당 규정의 입법취지에 부합합니다.

1) 「지방재정법」 제37조의3에 따른 지방재정투자심사위원회를 말함

2) 2013. 11. 15. 의안번호 제1907796호로 발의된 지방재정법 일부개정법률안에 대한 국회 안전행정위원회 검토보고서 참조

그리고 「지방재정법」 제37조제1항에서는 ‘투자심사’에 대해 규정하면서, 지방자치단체의 장은 재정투자사업에 대한 예산안 편성(제1호) 등 같은 항 각 호의 사항에 대해서 미리 투자심사를 ‘직접’ 하거나 ‘행정안전부장관 또는 시·도지사에게 의뢰하여’ 투자심사를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제41조제2항에서는 시·군 및 자치구가 시행하는 재정투자사업에 대한 투자심사 실시 주체를 사업의 유형 및 총사업비 등을 기준으로 구별하여 정하면서, 공연·축제 등 행사성 사업 중 총사업비 1억원 이상 3억원 미만은 시장·군수등(제1호마목)이, 총사업비 3억원 이상 200억원 미만은 시·도지사(제2호다목)가, 총사업비 200억원 이상은 행정안전부장관(제3호다목)이 투자심사를 실시하도록 규정하여 행사성 사업의 총사업비의 규모에 따라 심사 주체를 구분하여 규정하고 있는데, ‘지방재정영향평가’에 대해서는 앞에서 살펴본 바와 같이 같은 법 시행령 제35조의5제1항에서 총사업비의 규모에 따라 지방재정영향평가 대상 사업에 해당하는지 여부만을 정하고 있고, 총사업비의 규모에 따른 심사 주체를 구분하여 규정하고 있지 않은바, 이 사안과 같이 총사업비 10억원 이상 30억원 미만인 국내·국제경기대회 및 공연·축제 등의 행사성 사업의 경우, 총사업비가 3억원 이상 200억원 미만이므로 시·도지사가 투자심사를 실시하는 재정투자사업에 해당한다는 점은 별론으로 하더라도, 시장·군수등이 지방재정영향평가 대상 사업을 시행하려는 경우에는 해당 지방자치단체의 장, 즉 시장·군수등 소속 지방재정투자심사위원회의 심사를 거쳐야 한다고 해석하는 것이 지방재정영향평가와 투자심사를 구별하여 규정하고 있는 지방재정법령의 체계에 부합하는 해석입니다.

한편 「지방재정법」 제37조제1항 및 같은 법 시행령 제41조제2항제2호다목에 따라 시·군 및 자치구가 시행하는 총사업비 3억원 이상 200억원 미만인 행사성 사업의 경우 해당 시·군 및 자치구가 아닌 시·도에 의뢰하여 투자심사를 받아야 하므로, 심사의 일관성을 확보하기 위하여 투자심사의 사전 절차인 지방재정영향평가를 실시할 때에도 투자심사와 동일하게 시·도지사 소속 지방재정투자심사위원회의 심사를 거쳐야 한다는 의견이 있으나, 같은 법 제27조의6에 따른 지방재정영향평가와 같은 법 제37조에 따른 투자심사는 그 심사 대상³⁾, 실시 시기⁴⁾, 심사 기준⁵⁾ 등이 상이한 별개의 제도로써, 행사성 사업의 경우 총사업비의 규모에 따른 투자심사의 심사 주체 기준에 따라 지방재정영향평가를 심사하는 소관 지방재정투자심사위원회가 정해지는 것은 아니라는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

3) 「지방재정법 시행령」 제35조의5 및 제41조제2항 참조

4) 지방재정영향평가는 중기지방재정계획 반영 전에 실시하고, 투자심사는 지방자치단체 예산 편성 전에 실시함[「지방재정영향평가지침」(행정안전부훈령) 제7조 및 「지방재정법」 제37조, 「지방재정투자사업 심사규칙」 제4조 등 참조]

5) 「지방재정영향평가지침」(행정안전부훈령) 별표 및 「지방재정투자사업 심사규칙」 제2조 참조

따라서 이 사안의 경우, 시장·군수등 소속 지방재정투자심사위원회의 심사를 거쳐야 합니다.



관계법령

지방재정법

제27조의6(지방재정영향평가) ① 지방자치단체의 장은 대규모의 재정적 부담을 수반하는 국내·국제경기대회, 축제·행사, 공모사업 등의 유치를 신청하거나 응모를 하려면 미리 해당 지방자치단체의 재정에 미칠 영향을 평가하고 그 평가결과를 토대로 제37조의3에 따른 지방재정투자심사위원회의 심사를 거쳐야 한다. 이 경우 평가대상은 「지방자치법」 제2조에 규정된 지방자치단체의 종류, 사업의 유형과 성격, 재정부담의 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정한다
②·③ (생략)

제37조(투자심사) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 사항에 대해서는 미리 그 필요성과 타당성에 대한 심사(이하 “투자심사”라 한다)를 직접 하거나 행정안전부장관 또는 시·도지사에게 의뢰하여 투자심사를 받아야 한다.

1. 재정투자사업에 관한 예산안 편성

2. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

제37조의3(지방재정투자심사위원회) ① 투자심사에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하기 위하여 지방자치단체의 장 소속으로 지방재정투자심사위원회를 둔다. 다만, 지방재정투자심사위원회의 기능을 담당하기에 적합한 다른 위원회가 있고 그 위원회의 위원이 지방재정 또는 투자심사에 관한 학식이나 전문성을 갖춘 경우에는 조례로 정하는 바에 따라 그 위원회가 지방재정투자심사위원회의 기능을 대신할 수 있다.

② ~ ⑧ (생략)

지방재정법 시행령

제35조의5(지방재정영향평가 대상 지방사업) ① 법 제27조의6제1항 후단에 따라 지방자치단체의 장이 평가하여야 하는 평가대상은 다음 각 호와 같다.

1. 국내·국제경기대회 및 공연·축제 등의 행사성 사업으로서 총사업비가 다음 각 목의 구분에 따른 금액 이상인 사업

가. 시·도: 30억원

나. 시·군 및 자치구: 10억원

2. (생략)

② (생략)

제41조(재정투자사업에 대한 심사) ① (생 략)

② 시·군 및 자치구가 시행하는 재정투자사업에 대한 투자심사 실시 주체별 투자심사 대상은 다음 각 호와 같다.

1. (생 략)

2. 시·도지사: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업

가.·나. (생 략)

다. 총사업비 3억원 이상 200억원 미만인 공연·축제 등 행사성 사업

라. ~ 바. (생 략)

3. (생 략)

③ ~ ⑤ (생 략)

질의제목 13

▶ 안전번호 25-0182

행정안전부 - 조달청장과 계약상대자 사이에 다수공급자계약이 체결되어 지방자치단체의 장이 수요기관의 장으로서 계약상대자에게 납품을 요구한 경우 납품을 지체한 계약상대자에 대한 지연배상금(지체상금)의 부과 주체 등(「조달사업에 관한 법률」 제13조 등 관련)

01 질의요지

「조달사업에 관한 법률」(이하 “조달사업법”이라 함) 제13조제1항에서는 조달청장은 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 구매하기 위하여 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 같은 법 제12조에 따른 계약(이하 “다수공급자계약”이라 함)을 체결할 수 있다고 규정하고 있고, 「물품 다수공급자계약 특수조건」(조달청 공고) 제35조제1항 전단에서는 계약담당공무원은 계약상대자가 납품기한을 경과하여 납품하였을 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금률을 납품요구금액에 곱하여 산출한 금액을 지체상금(遲滯償金)으로 결정하고 계약상대자에게 지급될 대가에서 상계하여야 한다고 규정하고 있는 한편,

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “지방계약법”이라 함) 제30조제1항에서는 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 정당한 사유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지연배상금을 내도록 하여야 한다고 규정하고 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 함) 제26조제1항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 내도록 하여야 한다고 규정하고 있는바,

조달청장과 2인 이상의 계약상대자 사이에 다수공급자계약이 체결됨에 따라 지방자치단체의 장이 수요기관의 장으로서 계약상대자에게 납품을 요구한 경우, 정당한 사유 없이 납품을 지체한 계약상대자에게 지방자치단체의 장 또는 계약담당자가 지방계약법 제30조를 근거로 지연배상금을 부과해야 하는지, 아니면 조달청장 또는 계약담당공무원이 국가계약법 제26조 및 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제35조 등¹⁾을 근거로 지체상금을 부과해야 하는지?²⁾

1) 「용역 다수공급자계약 특수조건」 제44조 등 수요물자의 구체적인 유형에 따른 규정을 말하며, 이하 같음

02 회답

이 사안의 경우, 정당한 사유 없이 납품을 지체한 계약상대자에게 조달청장 또는 계약담당공무원이 국가계약법 제26조 및 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제35조 등을 근거로 지체상금을 부과해야 합니다.

03 이유

먼저 “다수공급자계약”이란 조달사업법 제13조에 따라 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 구매하기 위하여 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 조달청장이 체결하는 제3자를 위한 단가계약인데, 다수공급자계약이 체결되어 지방자치단체의 장이 수요기관의 장으로서 납품을 요구한 경우, 조달사업법에서 해당 계약사무의 처리와 관련하여 직접 규정하고 있지 않은 지연배상금(지체상금) 부과 등에 대해 지방계약법과 국가계약법 중 어느 법령이 적용되는지를 판단하기 위해서는 해당 계약의 당사자가 지방자치단체인지, 아니면 국가인지를 살펴보아야 합니다.

그런데 다수공급자계약의 경우, 조달청장이 2인 이상의 계약상대자와 다수공급자계약을 체결하여 나라장터³⁾ 종합쇼핑몰에 물품을 등록하면, 각 수요기관이 나라장터 종합쇼핑몰에서 등록된 물품들을 비교·검색하는 과정 등을 거쳐 직접 물품 및 납품업체를 결정하여 납품요구를 하고, 이에 따라 납품업체에서 해당 수요기관에 직접 납품하게 되는바⁴⁾, 이처럼 다수공급자계약의 당사자는 대한민국(조달청장)이고, 이후의 납품요구 관련 절차는 이미 체결된 다수공급자계약과 별도로 계약상대자와 수요기관 사이에 새로운 공급계약이 체결되는 것이 아니라 수요기관이 제3자를 위한 계약의 수익자로서 권리를 행사하는 것이라 할 것이므로⁵⁾, 이 사안에서의 계약은 국가를 당사자로 하는 계약이 체결된 것이지, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약이 체결된 것으로 보기는 어렵습니다.

2) 이 사안 해석 대상 법령 외에 다른 법령, 조달청 공고 또는 계약서에서 지연배상금(지체상금) 부과 주체 등을 별도로 정하고 있는 경우에 해당하지 않는 것으로 전제함

3) 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템을 말함

4) 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제2조제8호, 제23조 및 제26조 등 참조

5) 대법원 2019. 10. 18. 선고 2019도8374 판결례 등 참조

다음으로 지방계약법 제7조제1항에서는 지방자치단체의 장은 다른 법령에서 정한 경우 외에는 그 소관 계약사무를 처리하기 위하여 필요하다고 인정되면 그 사무의 전부 또는 일부를 중앙행정기관의 장, 다른 지방자치단체의 장 등에게 위임하거나 위탁하여 처리하게 할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제2항 단서에서는 국가계약법의 적용을 받는 중앙행정기관의 장에게 위임 또는 위탁하는 경우에는 이 법(지방계약법)에서 정하는 바에 따라 계약사무를 처리하여야 한다고 규정하고 있는바, 이 사안의 경우 지방계약법 제7조제2항 단서에 따라 같은 법 제30조(지연배상금 등)가 적용되는지 여부에 대해서 살펴볼 필요가 있습니다. 다수공급자계약은 조달청장이 수요기관으로부터 수요물자 구매에 관한 계약 체결을 요청받아 체결하는 것이 아니라 그러한 요청을 기다리지 않고 나라장터 종합쇼핑몰 운영 주체로서 고유사무로 독자적으로 체결하는 것으로, 다수공급자계약을 체결한 계약상대자가 납품을 하는 것도 다수공급자계약에 따른 의무이행으로 이루어지는 것일 뿐인바⁶⁾, 다수공급자계약은 조달청장이 수요기관인 지방자치단체의 위임이나 위탁 없이 체결한 국가를 당사자로 하는 계약에 해당하므로⁷⁾, 계약상대자에 대한 지연배상금(지체상금) 부과와 관련하여 지방계약법 제7조제2항 단서에 따라 같은 법 제30조가 적용된다고 보기도 어렵습니다.

이처럼 다수공급자계약은 국가를 당사자로 하는 계약으로서 해당 계약의 지연배상금(지체상금) 부과에 대해서는 지방계약법이 아닌 국가계약법이 적용된다고 할 것인데, 국가계약법 제11조제1항 본문에서 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 지체상금 등 같은 항 각 호의 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 한다고 규정하고 있고, 조달사업법 제13조 및 같은 법 시행령 제13조제5항의 위임에 따라 마련된 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제35조제1항에서 계약담당공무원은 계약상대자가 납품기한을 경과하여 납품하였을 때에는 매 지체일수마다 ‘계약서에서 정한 지체상금률’을 납품요구금액에 곱하여 산출된 금액을 지체상금으로 결정하고 계약상대자에게 지급될 대가에서 상계하여야 한다고 규정하고 있는바, 조달청장 또는 계약담당공무원은 특별한 사정이 없는 한 다수공급자계약의 계약서에 국가계약법령⁸⁾에 따른 지체상금률을 기재하여 계약을 체결해야 할 것이고, 계약상대자가 정당한 사유 없이 납품을 지체한 경우 조달청장 또는 계약담당공무원은 국가계약법 제26조 및 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제35조 등에 따라 지체상금을 부과해야 할 것입니다.

6) 서울고등법원 2018. 11. 14. 선고 2018누35973 판결례 및 서울고등법원 2016. 8. 30. 선고 2016누37524 판결례 등 참조

7) 대전고등법원 2019. 5. 8. 선고 2018누11591 판결례 및 서울행정법원 2016. 1. 15. 선고 2015구합56700 판결례 등 참조

8) 국가계약법 제26조, 같은 법 시행령 제74조제1항 및 같은 법 시행규칙 제75조 참조

따라서 이 사안의 경우, 정당한 사유 없이 납품을 지체한 계약상대자에게 조달청장 또는 계약담당공무원이 국가계약법 제26조 및 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제35조 등을 근거로 지체상금을 부과해야 합니다.



관계법령

조달사업법

제12조(제3자를 위한 단가계약) ① 조달청장은 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 제조·구매 및 가공하는 등의 계약을 할 때 미리 단가만을 정하여 계약(이하 “제3자를 위한 단가계약”이라 한다)을 체결할 수 있다.

②·③ (생략)

제13조(다수공급자계약) ① 조달청장은 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 구매하기 위하여 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 제12조에 따른 계약(이하 “다수공급자계약”이라 한다)을 체결할 수 있다.

② ~ ④ (생략)

조달사업법 시행령

제13조(다수공급자계약) ① ~ ④ (생략)

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 다수공급자계약의 체결 등에 관하여 필요한 사항은 조달청장이 기획재정부장관과 협의하여 정한다.

물품 다수공급자계약 특수조건(조달청 공고)

제2조(정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “다수공급자계약”이란 「조달사업법」 제13조에 따라 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 구매하기 위하여 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 물자를 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 조달청장이 체결하는 제3자를 위한 단가계약을 말한다.
2. ~ 4. (생략)
5. “계약담당공무원”이란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “국가계약법 시행규칙”이라 한다) 제2조제1호에 따른 공무원으로서, 조달청장으로부터 구매계약업무의 위임을 받은 부서의 장 또는 부서의 장으로부터 계약사무의 일부를 위임받은 자를 말한다.
6. ~ 27. (생략)

제26조(납품요구) ① 계약상대자는 수요기관의 장이 계약조건에 따라 납품수량, 납품기한, 납품장소, 인도조건, 분할납품 여부, 기타 필요한 사항 등을 분할납품요구 및 통지서(이하 납품요구서라 한다)에 명시하여 납품을 요구하는 경우 이에 응하여야 한다. 단, 최초 납품요구 시 수요기관의 장과 협의하여

계약상대자가 동의한 경우 계약기간 내에서 희망하는 납품기한을 별도로 설정할 수 있다.

② (생 략)

제35조(지체상금) ① 계약담당공무원은 계약상대자가 납품기한을 경과하여 납품하였을 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금률을 납품요구금액에 곱하여 산출한 금액을 지체상금으로 결정하고 계약상대자에게 지급될 대가에서 상계하여야 한다. (후단 생략)

② (생 략)

지방계약법

제30조(지연배상금 등) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 정당한 사유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지연배상금을 내도록 하여야 한다.

② ~ ④ (생 략)

지방계약법 시행규칙

제75조(지연배상금률) 영 제90조제1항에 따른 지연배상금률은 다음 각 호와 같다.

1. (생 략)
2. 물품의 제조·구매(영 제16조제3항에 따라 소프트웨어사업 시 물품과 용역을 한꺼번에 입찰에 부치는 경우를 포함한다): 1000분의 0.8. (단서 생략)
- 3.·4. (생 략)

국가계약법

제26조(지체상금) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 내도록 하여야 한다.

②·③ (생 략)

국가계약법 시행규칙

제75조(지체상금률) 영 제74조제1항에 따른 지체상금률은 다음 각호와 같다.

1. (생 략)
2. 물품의 제조·구매(영 제16조제3항에 따라 소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우를 포함한다. 이하 이 호에서 같다): 1천분의 0.75. (단서 생략)
3. ~ 5. (생 략)

질의제목 14

▶ 안전번호 25-0184

산업통상자원부 - 전문기업 확인신청서에 첨부해야 하는 소재·부품·장비 매출액 검토의견서에 「행정사법」에 따른 행정사가 작성한 것도 포함되는지(「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법 시행규칙」 제4조제1항제2호 관련)

01 질의요지

「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」(이하 “소재부품 장비산업법”이라 함) 제14조제1항에서는 전문기업으로 확인을 받으려는 기업은 총매출액 중 소재·부품·장비의 매출액이 차지하는 비중이 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 기업(제1호) 등 같은 항 각 호의 요건을 모두 갖추어 산업통상자원부장관에게 확인을 신청할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제23조제1항에서는 같은 법 제14조제1항에 따라 전문기업으로 확인을 받으려는 기업은 산업통상자원부장관에게 신청해야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제4조제1항에서는 같은 법 시행령 제23조제1항에 따라 전문기업 확인을 신청하려는 기업은 전문기업 확인신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 한국산업기술기획평가원장¹⁾에게 제출해야 한다고 규정하면서, 전문기업 확인신청서에 첨부해야 하는 서류의 하나로 “소재·부품·장비 매출액 검토의견서(공인회계사, 세무사 또는 「중소기업진흥에 관한 법률」 제46조에 따른 경영지도사가 작성한 것으로 한정한다)”를 규정(제2호)하고 있는바,

소재부품장비산업법 시행규칙 제4조제1항제2호에 따른 소재·부품·장비 매출액 검토의견서에 「행정사법」에 따른 행정사가 작성한 것도 포함되는지?

02 회답

소재부품장비산업법 시행규칙 제4조제1항제2호에 따른 소재·부품·장비 매출액 검토의견서에 「행정사법」에 따른 행정사가 작성한 것은 포함되지 않습니다.

1) 소재부품장비산업법 제76조제2항 및 같은 법 시행령 제82조제5항제4호에 따라 같은 법 제14조제1항에 따른 전문기업 확인 업무는 한국산업기술기획평가원에 위탁됨

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데²⁾, 소재부품장비산업법 시행규칙 제4조제1항제2호에서는 전문기업 확인신청서에 첨부해야 하는 서류로 “소재·부품·장비 매출액 검토의견서”를 규정하면서 뒤에 괄호를 두어 공인회계사, 세무사 또는 경영지도사³⁾(이하 “공인회계사등”이라 함)가 작성한 것으로 한정하고 있으므로 「행정사법」에 따른 행정사가 작성한 것은 소재부품장비산업법 시행규칙 제4조제1항제2호에 따른 소재·부품·장비 매출액 검토의견서에 포함되지 않음이 문언상 명백합니다.

그리고 소재부품장비산업법 제14조제1항제1호에서는 전문기업으로 확인을 받기 위한 요건의 하나로 총매출액 중 소재·부품·장비의 매출액이 차지하는 비중이 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 기업일 것을 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제4조제1항에서는 전문기업 확인을 신청하려는 기업은 소재·부품·장비 매출액을 증명하는 서류(제1호), 소재·부품·장비 매출액 검토의견서(제2호) 등을 첨부하여 제출하도록 규정하고 있는데, 이는 기업이 제출한 소재·부품·장비 매출액 명세 및 매출액 증명 서류를 검토하고, 해당 매출액 명세가 기업회계기준 등에 따라 적정하게 작성되었는지 확인하고 해당 서류를 바탕으로 전문기업 확인의 요건을 갖추었는지를 판단하려는 것으로 볼 수 있는바, 소재·부품·장비 매출액 검토의견서를 공인회계사등이 작성한 것으로 한정하는 것은 해당 서류의 정확성을 담보하기 위하여 일정 수준 이상의 회계 지식을 갖춘 것이 검증된 경우에만 부여되는 자격을 갖춘 사람⁴⁾이 작성한 매출액 검토의견서로 한정하려는 취지가 있다고 볼 것이므로, 소재부품장비산업법 시행규칙 제4조제1항제2호에 따른 소재·부품·장비 매출액 검토의견서에는 행정사가 작성한 소재·부품·장비 매출액 검토의견서는 포함되지 않는다고 보는 것이 타당합니다.

한편 「행정사법」에 따른 행정사는 경영기술지도사법 제2조제2항에 따른 경영지도사의 업무를 수행할 수 있고⁵⁾, 소재·부품·장비 매출액 검토의견서를 작성하는 업무도 「행정사법」 제2조제1항제1호에 따른 행정사의 업무에 해당하므로 소재부품장비산업법 시행규칙

2) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

3) 「경영지도사 및 기술지도사에 관한 법률」에 따른 경영지도사를 말하며, 이하 같음

4) 공인회계사, 세무사 및 경영지도사 모두 자격 시험 1·2차 시험과목에 회계학 과목이 포함되어 있음(「공인회계사법 시행령」 별표 1·별표 2, 「세무사법 시행령」 별표 1·별표 2 및 경영지도사법 시행령 별표 2 참조)

5) 법제처 2020. 7. 14. 회신 20-0321 해석례 참조

제4조제1항제2호에 따른 소재·부품·장비 매출액 검토의견서에 행정사가 작성한 것도 포함된다는 의견이 있으나, 소재부품장비산업법 시행규칙 제4조제1항제2호에서 소재·부품·장비 매출액 검토의견서를 공인회계사등이 작성한 것으로 한정하는 것은 해당 서류가 법령상 요건을 갖춘 첨부 서류로 인정받기 위해 충족해야 하는 요건을 정한 것으로서, 행정사가 경영기술지도사법 제2조제2항에 따른 경영지도사의 업무를 수행할 수 있다고 하여 행정사가 작성한 서류가 경영지도사가 작성하도록 한 서류와 동일하다고 볼 수는 없다는 점에서, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 소재부품장비산업법 시행규칙 제4조제1항제2호에 따른 소재·부품·장비 매출액 검토의견서에 「행정사법」에 따른 행정사가 작성한 것은 포함되지 않습니다.



관계법령

소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법

제14조(전문기업 여부에 대한 확인) ① 전문기업으로 확인을 받으려는 기업은 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 산업통상자원부장관에게 확인을 신청할 수 있다.

1. 총매출액 중 소재·부품·장비의 매출액이 차지하는 비중이 대통령령이 정하는 기준에 해당하는 기업
2. (생략)
- ② (생략)
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 전문기업의 확인 절차, 확인을 위한 조사나 사후관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법 시행령

제23조(전문기업의 확인 및 사후관리) ① 법 제14조제1항에 따라 전문기업으로 확인을 받으려는 기업은 산업통상자원부장관에게 신청해야 한다.

- ② ~ ④ (생략)
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 전문기업의 확인 및 사후관리 등에 필요한 사항은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법 시행규칙

제4조(전문기업의 확인 신청 등) ① 영 제23조제1항에 따라 전문기업 확인을 신청하려는 기업은 별지 제3호서식의 전문기업 확인신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 한국산업기술기술평가원장에게 제출해야 한다.

1. 소재·부품·장비 매출액을 증명하는 서류
2. 소재·부품·장비 매출액 검토의견서(공인회계사, 세무사 또는 「중소기업진흥에 관한 법률」 제46조에 따른 경영지도사가 작성한 것으로 한정한다)
- 3.·4. (생략)
- ② (생략)

질의제목 15

▶ 안전번호 25-0238

행정안전부 - 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의2에 따라 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가가 의제되는 사업에 대한 재해영향평가의 협의 대상 판단기준 (「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 등 관련)

01 질의요지

「자연재해대책법」 제4조제1항에서는 관계행정기관의 장¹⁾은 자연재해에 영향을 미치는 개발사업의 허가등²⁾을 하려는 경우에는 그 개발사업의 허가등을 하기 전에 행정안전부장관과 재해영향평가등³⁾에 관한 협의를 하여야 한다고 규정하고 있고, 「자연재해대책법 시행령」 제6조 및 별표 1 제2호에서는 관계행정기관의 장이 재해영향평가등의 협의를 하여야 하는 개발사업으로 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 “산업집적법”이라 함) 제13조에 따른 공장설립등[나목4)], 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용[사목8)] 등을 규정하고 있으며, 같은 표 제2호의 비고 제1호에서는 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위는 개별 법령에서 정하는 바에 따라 허가·승인 등을 하려는 개발사업의 부지면적이 5천제곱미터(산업집적법 제13조에 따른 공장설립 승인의 경우에는 1만제곱미터) 이상인 경우로 한다고 규정하고 있고, 같은 비고 제4호에서는 다른 법령에 따라 승인을 받은 것으로 의제되는 사업으로서 개발사업의 대상 규모가 비고 제1호에 따른 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위에 해당하는 경우에는 재해영향평가 협의를 하여야 한다고 규정하고 있는 한편,

산업집적법 제13조제1항에서는 공장건축면적이 5백제곱미터 이상인 공장의 신설·증설 또는 업종변경(이하 “공장설립등”이라 함)을 하려는 자는 시장·군수 또는 구청장(이하 “구청장등”이라 함)의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제13조의2제1항 제2호에서는 공장설립등의 승인을 할 때 해당 공장 및 진입로 부지에 대한 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가에 관하여 해당 구청장등이 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 본다고 규정하고 있는바,

1) 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장 및 특별지방행정기관의 장을 말함

2) 허가·인가·승인·면허·결정·지정 등을 말함

3) 재해영향성검토 및 재해영향평가를 말함

산업집적법 제13조에 따른 공장설립등의 승인을 할 때 같은 법 제13조의2제1항제2호에 따라 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가가 의제되는 경우, 그 의제되는 사업인 산지전용이 재해영향평가 협의 대상인지의 판단기준은 산업집적법 제13조에 따른 공장설립등 승인인 경우의 판단기준인 개발사업 부지면적 1만제곱미터 이상인지, 아니면 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가인 경우의 판단기준인 개발사업 부지면적 5천제곱미터 이상인지?⁴⁾

02 회답

이 사안의 경우, 그 의제되는 사업인 산지전용이 재해영향평가 협의 대상인지는 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가의 판단기준인 개발사업 부지면적이 5천제곱미터 이상인지를 기준으로 판단해야 합니다.

03 이유

먼저 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호의 비고 제1호 및 제4호에 따르면, 같은 표 제2호에 규정되어 있는 개발사업의 경우에는 개별 법령에서 정하는 바에 따라 허가 등을 하려는 경우 재해영향평가 협의 대상인지를 판단하여 그 부지면적이 협의 대상 기준에 해당하면 허가 등을 할 때 재해영향평가 협의를 하여야 하고, 그 허가 등으로 의제되는 허가 등이 있는 경우에는 의제되는 허가 등이 재해영향평가 협의 대상인지는 별도로 판단하여야 할 것입니다⁵⁾.

그렇다면 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호의 비고 제4호에 따라 의제되는 허가 등의 대상 부지면적이 같은 비고 제1호에 따른 부지면적 기준에 해당할 때 재해영향평가 협의를 해야 한다고 할 것인바, 산업집적법 제13조에 따른 공장설립등의 승인으로 같은 법 제13조의2에 따라 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가를 받은 것으로 의제되는 이 사안의 경우 의제되는 산지전용허가의 대상 부지면적이 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호의 비고 제1호에 따른 재해영향평가 협의를 해야 하는 개발사업의 범위에 해당하는 경우,

4) 본 사안에서는 재해영향평가 협의 대상인 산업집적법 제13조에 따른 공장설립등의 승인에 대해서는 별도로 논의하지 않음

5) 법제처 2016. 5. 24. 회신 16-0047 해석례 참조

그 의제되는 산지전용허가에 대하여 재해영향평가 협의를 해야 한다고 할 것입니다.

그리고 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호의 비고 제1호에서는 개발사업의 유형에 따라 원칙적으로 개별 법령에서 정하는 바에 따라 허가·승인 등을 하려는 개발사업의 부지면적이 5천제곱미터 이상인 경우에는 재해영향평가 협의를 하도록 하되, 예외적으로 ‘산업집적법 제13조에 따른 공장설립 승인의 경우에는 1만제곱미터 이상’인 경우에 재해영향평가 협의 대상으로 한정하고 있는데, 이 사안에서는 재해영향평가 협의 대상이 되는 개발사업이 산업집적법 제13조에 따른 공장설립 승인이 아니라 의제되는 허가 등에 해당하는 「산지관리법」에 따른 산지전용허가이므로, 원칙에 따라 산지전용허가를 받으려는 부지면적이 5천제곱미터 이상인 경우에는 그 산지전용허가에 대하여 재해영향평가 협의를 해야 한다고 할 것입니다⁶⁾.

또한 구 「자연재해대책법 시행령」⁷⁾에서 다른 법령에 따라 승인 등을 받은 것으로 의제되는 사업의 경우 그 규모가 ‘15만제곱미터 이상’인 경우에만 사전재해영향성 검토⁸⁾협의를 하도록 규정하고(별표 1 제2호의 비고 제4호) 있던 것을, 2014년 3월 11일 대통령령 제25248호로 일부개정된 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호의 비고 제5호에서는 동일한 사업에 대해 개별적으로 각 행정관청에 신청하여 승인 등을 받는 경우와 각 행정관청의 승인 등을 받은 것으로 일괄하여 의제되는 경우를 달리 취급할 이유가 없다는 점에서, 의제되는 사업의 경우도 같은 비고 제1호를 동일하게 적용하여 사전재해영향성 검토협의 대상 여부를 판단하도록 개정하였고⁹⁾, 그 내용이 현행까지 유지된 것인바, 다른 법령에 따라 승인 등을 받은 것으로 의제되는 사업에 대한 재해영향평가 협의 시, 동일한 사업에 대해 개별적으로 각 행정기관에 신청하여 승인 등을 받는 경우와 마찬가지로 협의 기준을 적용하려는 자연재해대책법령의 입법 취지에 비추어 보면, 이 사안의 산지전용이 재해영향평가 협의 대상인지를 판단함에 있어서 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가의 경우인 부지면적이 5천제곱미터 이상인지를 기준으로 판단해야 한다고 해석하는 것이 자연재해대책법령의 입법연혁에 부합합니다.

6) 법제처 2016. 5. 24. 회신 16-0047 해석례 참조

7) 2014. 3. 11. 대통령령 제25248호로 일부개정되기 전의 「자연재해대책법 시행령」을 말함

8) 구 「자연재해대책법」(2017. 10. 24. 법률 제14912호로 일부개정되기 전의 것)에 따른 사전재해영향성검토는 현행 「자연재해대책법」상 재해영향성검토와 재해영향평가로 나뉘어 짐

9) 법제처 2016. 5. 24. 회신 16-0047 해석례, 2014. 3. 11. 대통령령 제25248호로 일부개정된 「자연재해대책법 시행령」 조문별 제개정이유서 참조

아울러 「자연재해대책법」은 태풍, 홍수 등 자연현상으로 인한 재난으로부터 국토를 보존하고 국민의 생명·신체 및 재산과 주요 기간시설을 보호하기 위하여 자연재해의 예방·복구 및 그 밖의 대책에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 하는 법으로(제1조), 재해영향평가제도는 개발사업의 확정·허가 등을 하기 전에 재해영향의 검토에 관한 사전협의를 함으로써 각종 개발사업의 사전심의기능을 강화하여 자연재해로부터 국민의 생명·신체·재산 등을 보호하기 위한 목적에서 도입되었다는 점¹⁰⁾, 다른 법령에 따라 승인 등을 받은 것으로 의제되는 사업의 경우에도 사전심의를 통해 국민을 보호해야 할 필요성은 마찬가지임에도 불구하고 재해영향평가 협의 대상의 기준이 되는 개발사업 범위를 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가의 경우가 아닌 산업집적법 제13조에 따른 공장설립 승인의 경우에 따른 규모로 보아 합리적인 이유 없이 재해영향평가 협의 대상을 축소하는 것은 자연재해대책법령의 목적 및 취지에 부합하지 않는다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다¹¹⁾.

따라서 이 사안의 경우, 그 의제되는 사업인 산지전용이 재해영향평가 협의 대상인지는 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가의 판단기준인 개발사업 부지면적이 5천제곱미터 이상인지를 기준으로 판단해야 합니다.



관계법령

자연재해대책법

제4조(재해영향평가등의 협의) ① 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장 및 특별지방행정기관의 장(이하 “관계행정기관의 장”이라 한다)은 자연재해에 영향을 미치는 행정계획을 수립·확정(지역·지구·단지 등의 지정을 포함한다. 이하 같다)하거나 개발사업의 허가·인가·승인·면허·결정·지정 등(이하 “허가등”이라 한다)을 하려는 경우에는 그 행정계획 또는 개발사업(이하 “개발계획등”이라 한다)의 확정·허가등을 하기 전에 행정안전부장관과 재해영향성검토 및 재해영향평가(이하 “재해영향평가등”이라 한다)에 관한 협의(이하 “재해영향평가등의 협의”라 한다)를 하여야 한다.

② ~ ⑫ (생략)

제5조(재해영향평가등의 협의 대상) ① 제4조에 따라 재해영향평가등의 협의를 하여야 하는 개발계획등은 다음 각 호와 같다.

10) 법제처 2016. 5. 24. 회신 16-0047 해석례, 2004. 7. 2. 의안번호 제170119호로 발의된 자연재해대책법 전부개정법률안에 대한 국회 행정자치위원회 심사보고서 참조

11) 법제처 2024. 2. 13. 회신 23-0938 해석례 참조

1. 국토·지역 계획 및 도시의 개발
 2. 산업 및 유통 단지 조성
 3. 에너지 개발
 4. 교통시설의 건설
 5. 하천의 이용 및 개발
 6. 수자원 및 해양 개발
 7. 산지 개발 및 골재 채취
 8. 관광단지 개발 및 체육시설 조성
 9. 그 밖에 자연재해에 영향을 미치는 계획 및 사업으로서 대통령령으로 정하는 계획 및 사업
- ② (생 략)
- ③ 제1항에 따라 재해영향평가등의 협의를 하여야 할 개발계획등의 범위, 시기 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자연재해대책법 시행령

제6조(재해영향평가등의 협의 대상 및 협의 방법 등) ① 법 제5조에 따라 관계행정기관의 장이 재해영향평가등의 협의를 요청하여야 하는 개발계획등의 범위와 협의 시기는 별표 1과 같다. 다만, 행정계획의 경우 행정안전부장관이 관계행정기관의 장으로부터 관계 법령에 따른 협의 요청을 받아 해당 행정계획에 관한 재해 영향을 검토한 경우에는 재해영향성검토 협의 절차를 이행한 것으로 보고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개발사업의 경우에는 재해영향평가 협의 대상 사업에서 제외한다.

1.·2. (생 략)

② (생 략)

산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률

제13조의2(인가·허가 등의 의제) ① 제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인을 할 때 해당 공장 및 진입로 부지에 대한 다음 각 호의 허가·신고·면허·승인·해제 또는 용도폐지 등(이하 “인·허가등”이라 한다)에 관하여 해당 시장·군수 또는 구청장이 제5항 본문에 따라 관계 행정기관의 장과 협의한 사항(제5항 단서에 따라 협의가 생략되는 경우를 포함한다)에 대하여는 해당 인·허가등을 받은 것으로 본다.

1. (생 략)

2. 「산지관리법」 제14조·제15조에 따른 산지전용허가 및 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고, 같은 법 제21조에 따른 산지 전용된 토지의 용도변경 승인 및 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항·제5항에 따른 입목벌채등의 허가·신고

3. ~ 18. (생 략)

② ~ ⑧ (생 략)

질의제목 16

▶ 안전번호 25-0242

민원인 - 「협동조합 기본법」 제15조제1항에 따른 협동조합 설립 신고를 대리하는 것이 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지 여부(「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련)

01 질의요지

「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理) 업무를 행정사¹⁾의 업무로 규정하고 있는 한편, 「협동조합 기본법」 제2조제1호에서는 “협동조합”이란 재화 또는 용역의 구매·생산·판매·제공 등을 협동으로 영위함으로써 조합원의 권익을 향상하고 지역 사회에 공헌하고자 하는 사업조직을 말한다고 규정하면서, 같은 법 제4조제1항에서는 협동조합은 법인으로 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제15조제1항에서는 협동조합을 설립하려는 경우에는 5인 이상의 조합원 자격을 가진 자가 발기인이 되어 정관을 작성하고 창립총회의 의결을 거친 후 주된 사무소의 소재지를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 함)에게 신고하여야 한다고 규정하고 있는바,

「협동조합 기본법」 제15조제1항에 따른 협동조합 설립 신고를 대리하는 업무가 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지?

02 회답

「협동조합 기본법」 제15조제1항에 따른 협동조합 설립 신고를 대리하는 업무는 「행정사법」 제2조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제2조제5호에 따른 행정사의 업무에 해당합니다.

03 이유

먼저 「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 행정사가 다른 사람의 위임을 받아 수행할 수

1) 「행정사법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조제1호에 따른 일반행정사를 말하며, 이하 같음

있는 업무의 하나로 ‘인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理)’ 업무를 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제2조제5호에서는 같은 법 제2조제1항제5호에 따라 행정사가 수행할 수 있는 업무의 내용과 범위를 ‘다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관의 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일’로 구체화하고 있습니다.

그런데 「협동조합 기본법」 제15조제1항에서는 협동조합을 설립하려는 경우에는 5인 이상의 조합원 자격을 가진 자가 발기인이 되어 정관을 작성하고 창립총회의 의결을 거친 후 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시·도지사에게 신고하여야 한다고 규정하고 있는바, “행정기관”은 일반적으로 국가 또는 지방자치단체의 행정사무를 맡아보는 기관²⁾으로서, 시·도지사는 「지방자치법」에 따라³⁾ 지방자치단체의 행정사무를 맡아보는 집행기관으로 “행정기관”에 해당하고, 시·도지사에게 협동조합의 설립을 신고하는 것은 “행정기관에 신고하는 일”에 해당하므로 「협동조합 기본법」 제15조제1항에 따른 협동조합의 설립 신고를 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제2조제5호에 따라 “다른 사람의 위임을 받아 행정기관에 신고하는 일을 대리하는 일”로서 행정사의 업무에 해당한다는 점이 문언상 명확합니다.

또한 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리 등 사인의 행정기관 상대 민원 업무를 대신하거나 도와주는 일을 하는 직역으로⁴⁾, 만약 협동조합 설립 신고를 대리하는 업무를 「행정사법」에 따른 행정사가 수행할 수 없도록 배제하려는 입법의도가 있었다면 협동조합 기본법령에서 협동조합 설립 신고 대리업무를 할 수 있는 자를 특정 자격이 있는 자로 제한하는 규정을 두었을 것인데, 「협동조합 기본법」에는 달리 협동조합 설립 신고의 대리를 특정 자격이 있는 자만 수행할 수 있도록 명시적으로 제한하는 규정을 두고 있지 않은 점 등을 고려하면 행정사가 협동조합 설립 신고의 대리를 수행할 수 있다고 해석하는 것⁵⁾이 국민의 편의 증진을 위하여 행정사로 하여금 기본적인 행정사무를 취급할 수 있도록 하고 있는 「행정사법」의 취지에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

따라서 「협동조합 기본법」 제15조제1항에 따른 협동조합 설립 신고를 대리하는 업무는 「행정사법」 제2조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제2조제5호에 따른 행정사의 업무에 해당합니다.

2) 국립국어원 표준국어대사전

3) 「지방자치법」 제106조, 제114조 및 제116조 등 참조

4) 헌법재판소 2015. 3. 26. 선고 2013헌마131 결정례 참조

5) 법제처 2021. 5. 12. 회신 21-0133 해석례 참조



관계법령

행정사법

제2조(업무) ① 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 다음 각 호의 업무를 수행한다. 다만, 다른 법률에 따라 제한된 업무는 할 수 없다.

1. ~ 4. (생략)
5. 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理)
- 6.·7. (생략)
- ② (생략)

행정사법 시행령

제2조(업무의 내용과 범위) 「행정사법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항 각 호에 따른 행정사 업무의 내용과 범위는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 4. (생략)
5. 법 제2조제1항제5호의 사무: 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일
- 6.·7. (생략)

협동조합 기본법

제15조(설립신고 등) ① 협동조합을 설립하려는 경우에는 5인 이상의 조합원 자격을 가진 자가 발기인이 되어 정관을 작성하고 창립총회의 의결을 거친 후 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시·도지사에게 신고하여야 한다. 신고한 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

② ~ ⑤ (생략)

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 협동조합의 설립신고, 변경신고, 신고의 반려 또는 보완에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

질의제목 17

▶ 안건번호 25-0243

민원인 - 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제38조제1항제28호에 따른 “상시 종업원의 수”의 의미
(「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제38조제1항제28호 등 관련)

01 질의요지

「공유재산 및 물품 관리법」(이하 “공유재산법”이라 함) 제29조제1항에서는 일반재산을 대부하거나 매각하는 계약을 체결할 때에는 일반입찰에 부쳐야 하되(본문), 대통령령으로 정하는 경우에는 제한경쟁 또는 지명경쟁에 부치거나 수의계약으로 할 수 있다고 규정(단서)하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제38조제1항에서는 지방자치단체의 장은 일반재산이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약으로 매각할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 제28호에서는 지방자치단체의 장이 일반재산을 수의계약으로 매각할 수 있는 사유 중 하나로 지역경제를 활성화하기 위하여 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 적합한 시설로서 해당 지역에 거주하는 상시 종업원의 수가 30명 이상이거나 원자재의 30퍼센트 이상을 해당 지역에서 조달하려는 기업의 공장 또는 연구시설을 유치하기 위하여 매각하는 경우를 규정하고 있는바,

이미 해당 지역에 거주하는 상시 종업원의 수가 30명 이상인 공장 또는 연구시설을 가지고 있는 자로서 지방자치단체의 일반재산인 토지를 취득하여 공장 또는 연구시설을 신축 또는 증축 등을 하려는 자¹⁾에게 해당 토지를 수의계약으로 매각하고자 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」(이하 “공유재산법 시행령”이라 함) 제38조제1항제28호를 적용하려는 경우, 같은 호의 “상시 종업원의 수”는 매각에 관한 계약 체결 이후 공장 또는 연구시설에 새로 고용되는 상시 종업원의 수를 의미하는지, 아니면 매각에 관한 계약 체결 당시에 공장 또는 연구시설에 고용되어 있던 상시 종업원의 수를 의미하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 공유재산법 시행령 제38조제1항제28호의 “상시 종업원의 수”는 매각에

1) 공장이나 연구시설을 이전하는 경우가 아님을 전제함

관한 계약 체결 이후 공장 또는 연구시설에 새로 고용되는 상시 종업원의 수를 의미합니다.

03 이유

먼저 공유재산법 제29조제1항 단서의 위임에 따라 같은 법 시행령 제38조제1항 각 호에서 정한 사유에 해당하는 경우에 예외적으로 일반재산을 수의계약으로 매각할 수 있도록 한 취지는 상황상 수의계약으로 하는 것이 불가피하거나 일반재산의 위치·형태·용도 등 해당 재산의 성질상 일반입찰에 부치기 곤란한 경우에 이를 허용하기 위한 것으로²⁾, 공유재산법 시행령 제38조제1항제28호에서는 지역경제를 활성화하기 위하여 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 적합한 시설로서 해당 지역에 거주하는 상시 종업원의 수가 30명 이상이거나 원자재의 30퍼센트 이상을 해당 지역에서 조달하려는 기업의 공장 또는 연구시설을 유치하기 위하여 매각하는 경우에는 지방자치단체의 장이 일반재산을 수의계약으로 매각할 수 있다고 규정하고 있는바, 해당 규정의 취지는 공장 등의 유치를 통해 지역경제의 활성화에 기여하기 위한 목적으로 일반재산의 매각을 하려는 경우에는 수의계약으로 할 수 있도록 허용하려는 것이라 할 것입니다.

그런데 공유재산법 시행령 제38조제1항제28호의 규정을 살펴보면, “유치”란 사전적으로 사업 따위를 끌어들임을 의미하고³⁾, 원자재의 30퍼센트 이상을 해당 지역에서 “조달하려는” 기업의 공장 또는 연구시설을 유치하기 위해 일반재산을 매각하는 경우 수의계약으로 할 수 있다고 규정하여 원자재 비율은 수의계약을 통한 매각으로 달성하고자 하는 목표임을 명확하게 하고 있는바, 공유재산법 시행령 제38조제1항제28호에서 정하고 있는 상시 종업원의 수에 관한 요건도 향후 달성하고자 하는 목표로서, 해당 지역으로 공장 또는 연구시설을 유치하여 지역경제 활성화라는 목적을 얼마만큼 달성하였는지를 확인하기 위한 판단 기준으로 해석하는 것이 해당 규정의 문언 및 취지에 부합한다고 할 것입니다.

또한 공유재산법 시행령 제38조제1항은 일반재산의 대부 및 매각에 관한 수의계약 근거가 되는 같은 법 제29조제1항의 위임에 따라 마련된 것으로, 같은 항의 위임에 따라 일반재산의 대부에 관한 사항을 규정하고 있는 같은 법 시행령 제29조제1항제19호에서는 지역경제를 활성화하기 위하여 해당 지역에 거주하는 상시 종업원의 수가 10명 이상인 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설을 “유치”하기 위하여 대부하는 경우에는 일반재산을 수의계약으로

2) 법제처 2022. 8. 19. 회신 22-0484 해석례 참조

3) 국립국어원 표준국어대사전 참조

할 수 있다고 하여 같은 영 제38조제1항제28호와 유사하게 규정하면서, 대부 대상자의 세부 선정기준, 선정절차와 방법은 행정안전부장관이 정하여 고시한다고 규정하고 있는데, 그 위임에 따라 마련된 행정안전부고시인 「지방자치단체 공유재산 운영기준」 제14조제2항에서 “해당 지역 거주 상시 종업원의 수”는 유치하려는 시설의 일자리 창출 기여도를 심사하기 위한 평가요소임을 명시하고 있는 점 등을 고려할 때, 공유재산법 시행령 제38조제1항제28호의 상시 종업원의 수도 일자리 창출 정도를 확인하기 위한 것으로서 일반재산 매각 이후의 고용 증가를 살펴보기 위한 기준이라고 보는 것이 관계 조문의 체계 등을 고려할 때 타당한 해석입니다.

아울러 만일 공유재산법 시행령 제38조제1항제28호 중 “상시 종업원의 수”를 매각 계약 체결 당시 이미 고용된 상시 종업원의 수로 본다면 ① 매각 계약 체결 당시 이미 해당 지역 거주 상시 종업원이 30명을 넘기만 하면 매각 이후에는 유치에 따른 지역주민 고용 창출 효과가 없어도 되고, 나아가 매각 후에 해당 지역에 거주하는 상시 종업원 수가 오히려 감소하여 지역 경제에 부정적인 영향을 미치게 되는 경우까지 일반재산을 기업에게 수의계약으로 매각하는 것을 허용하게 되는 문제가 발생할 수 있고, ② 매각 계약 전에는 해당 지역 거주 종업원이 없으나, 계약 후 해당 지역에 신축되는 공장 또는 연구시설을 통해 해당 지역의 고용을 창출하려는 기업 등이 수의계약 대상에서 제외되어 기업 유치를 통해 고용을 창출하고자 하는 해당 규정의 취지에 부합하지 않게 되는 점 등도 함께 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 공유재산법 시행령 제38조제1항제28호의 “상시 종업원의 수”는 매각에 관한 계약 체결 이후 공장 또는 연구시설에 새로 고용되는 상시 종업원의 수를 의미합니다.

법령정비 권고사항

공유재산법 시행령 제38조제1항제28호 중 “상시 종업원의 수”가 매각에 관한 계약 체결 이후 새로 고용된 상시 종업원의 수를 의미한다는 것을 명확하게 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

공유재산 및 물품 관리법

제29조(계약의 방법) ① 일반재산을 대부하거나 매각하는 계약을 체결할 때에는 일반입찰에 부쳐야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 제한경쟁 또는 지명경쟁에 부치거나 수의계약으로 할 수 있으며, 증권의 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제9항에 따른 증권매출의 방법으로 하며, 이 법 제4조제1항제2호 및 제3호의 일반재산을 매각하는 경우에는 제76조제3항을 준용한다.

②·③ (생략)

공유재산 및 물품 관리법 시행령

제38조(수의계약으로 매각할 수 있는 경우 등) ① 지방자치단체의 장은 일반재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제29조제1항 단서에 따라 수의계약으로 매각할 수 있다.

1. ~ 27. (생략)

28. 지역경제를 활성화하기 위하여 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 적합한 시설로서 해당 지역에 거주하는 상시 종업원의 수가 30명 이상이거나 원자재의 30퍼센트 이상을 해당 지역에서 조달하려는 기업의 공장 또는 연구시설을 유치하기 위하여 매각하는 경우

29. ~ 35. (생략)

② (생략)

질의제목 18

▶ 안전번호 25-0262

교육부 - 「지방교육자치에 관한 법률」 제21조에 따른 계속 재임 3기에 해당하는지 여부(「지방교육자치에 관한 법률」 제21조 등 관련)

01 질의요지

「지방교육자치에 관한 법률」(이하 “교육자치법”이라 함) 제21조에서는 교육감의 임기는 4년으로 하며, 교육감의 계속 재임은 3기에 한정한다고 규정하고 있고, 같은 법 제43조에서는 교육감은 주민의 보통·평등·직접·비밀선거에 따라 선출한다고 규정하고 있는바,

A는 B광역시의 교육자치법 제43조에 따른 교육감선거에 연이어 출마하고 당선되어 총 8년의 임기를 마치고 바로 다음 선거에서는 낙선하였는데, 해당 선거에서 당선된 C의 임기가 개시되어 해당 교육감의 직무를 수행하던 중 당선무효가 확정됨에 따라 재선거를 실시한 결과 A가 당선된 경우, A는 교육자치법 제21조에서 규정하고 있는 계속 재임 3기에 해당하는지?

02 회답

이 사안의 경우, A는 교육자치법 제21조에서 규정하고 있는 계속 재임 3기에 해당하지 않습니다.

03 이유

교육자치법 제21조에서는 교육감의 임기는 4년으로 하며, 교육감의 계속 재임은 3기에 한정한다고 규정하고 있는바, 이는 교육감이 연속하여 당선된 경우 3기까지 계속하여 재임할 수 있으며, 3기까지 계속하여 재임한 후에 연속하여 입후보하지 않을 경우에는 다시 3기 동안 계속 재임할 수 있음을 의미¹⁾하는 것입니다.

1) 2006. 12. 6. 의안번호 제175618호로 발의된 지방교육자치에관한법률 전부개정법률안에 대한 국회 법제사법위원회 체계자구검토보고서, 헌법재판소 2006. 2. 23. 선고 2005헌마403 전원재판부 결정례, 법제처 2019. 11. 11. 화신 19-0489

즉 교육자치법 제21조는 교육감의 총 재임기간이 아니라 교육감의 연임을 제한하기 위한 것으로, 해당 규정의 입법취지는 교육감이 장기간 연속당선을 위해 엽관제적으로 인사를 운용하거나 지역 내 특정집단과의 결탁을 통해 지역발전을 저해하는 것을 방지하고, 장기집권으로 인한 부정부패를 방지하는 한편 유능한 인사가 교육감으로 진출하는 것을 확대하려는 것입니다.²⁾

그런데 이 사안의 경우 A는 연속하여 2기의 교육감선거에 당선되어 재임하였지만 바로 연속되는 다음 선거에서는 낙선하였고 그 선거에서는 C가 당선되어 재임하였는바, 재선거로 당선된 교육감의 임기가 전임자의 남은 임기라고 하더라도 그것과는 별개로 교육감의 계속 재임 여부를 판단할 때에는 교육감으로서 그 직무를 실질적으로 계속 수행했는지를 기준으로 판단³⁾해야 하는데, 종전 선거에서 C가 교육감으로 당선되어 임기가 개시됨에 따라 A의 교육감으로서의 임기는 과거 2기의 임기와 연속되지 않아, A는 3기를 연속으로 당선되어 계속하여 재임한 것이 아니므로 교육자치법 제21조에서 규정하고 있는 계속 재임 3기에 해당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, A는 교육자치법 제21조에서 규정하고 있는 계속 재임 3기에 해당하지 않습니다.



관계법령

지방교육자치에 관한 법률

제21조(교육감의 임기) 교육감의 임기는 4년으로 하며, 교육감의 계속 재임은 3기에 한정한다.

제43조(선출) 교육감은 주민의 보통·평등·직접·비밀선거에 따라 선출한다.

해석례 참조

2) 1994. 11. 21. 의안번호 제140931호로 발의된 지방자치법 일부개정법률안에 대한 국회 내무위원회 심사보고서 및 헌법재판소 2006. 2. 23. 선고 2005헌마403 전원재판부 결정례 참조

3) 대법원 2016. 9. 8. 선고 2015다39357 판결례 및 서울고등법원 2015. 6. 19. 선고 2014나47605 판결례 참조

질의제목 19

▶ 안전번호 25-0270

민원인 - 「대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법」에 따라 위로금을 지급받을 유족의 범위(「대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법」 제3조제1항 등 관련)

01 질의요지

「대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법」(이하 “강제동원조사법”이라 함) 제3조제1항에서는 이 법에서 “유족”이란 피해자, 국외강제동원 희생자, 미수금피해자 가운데 사망하거나 행방불명된 사람의 친족 중 같은 항 각 호에 해당하는 사람으로서 같은 법 제8조제3호 및 제6호에 따라 유족으로 결정을 받은 사람을 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 위로금을 지급받을 유족의 순위는 같은 조 제1항 각 호의 순위로 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항 본문에서는 같은 조 제1항 각 호의 순위에 따른 유족은 위로금을 지급받을 권리를 갖는다고 규정하고 있는바,

국외강제동원 희생자의 친족 중 강제동원조사법 제3조제1항 각 호에 해당하는 사람이 없는 경우, 국외강제동원 희생자의 “4촌 이내의 방계혈족”은 위로금을 지급받을 유족이 될 수 있는지?

02 회답

국외강제동원 희생자의 친족 중 강제동원조사법 제3조제1항 각 호에 해당하는 사람이 없는 경우, 국외강제동원 희생자의 “4촌 이내의 방계혈족”은 위로금을 지급받을 유족이 될 수 없습니다.

03 이유

강제동원조사법 제3조제1항에서는 국외강제동원 희생자의 친족 중 유족의 범위를 같은 항 각 호에 해당하는 사람으로서 유족으로 결정을 받은 사람을 말한다고 규정하면서, 같은

항 각 호에서는 배우자 및 자녀(제1호), 부모(제2호), 손자녀(제3호), 형제자매(제4호)를 각각 규정하고 있고, 같은 조 제2항 및 제3항에서는 위로금을 지급받을 유족의 순위는 같은 조 제1항 각 호의 순위로 하며 같은 조 제1항 각 호의 순위에 따른 유족은 위로금을 지급받을 권리를 갖는다고 규정하고 있는데, 같은 조 제4항에서 같은 조 제1항 각 호에 해당하는 사람이 없는 경우 근친 등이 사망자의 유골을 인수할 수 있도록 규정한 것과 달리, 위로금에 대해서는 국외강제동원 희생자의 친족 중 같은 법 제3조제1항 각 호에 해당하는 사람이 없는 경우에 그 위로금을 지급받을 권리가 있는 사람에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않은바, 위로금을 지급받을 유족의 범위는 같은 법 제3조제1항 각 호에 해당하는 사람에 한정되는 것이 문언상 분명합니다.

그리고 강제동원조사법 제3조제1항의 입법연혁을 살펴보면, 2010년 3월 22일 법률 제10143호로 강제동원조사법이 제정되기 전에 국외강제동원 희생자 등의 지원에 관해 규정하고 있던 「태평양전쟁 전후 국외 강제동원희생자 등 지원에 관한 법률」¹⁾에서도 유족의 범위를 강제동원조사법 제3조와 동일하게 규정하고 있었고, 이후 강제동원조사법을 제정하는 과정에서 유족의 범위를 「민법」 제1000조에 따른 상속인의 범위인 “4촌 이내 방계혈족”까지 확대하는 내용이 검토되었으나, 위로금은 국외강제동원 희생자나 유족들이 받은 손해를 보상하는 것이라기보다는 시혜적인 성격의 것으로서²⁾, 보상 법률은 국가의 법적 책임 차원에서 「민법」상의 재산권 상속의 범위까지 유족으로 인정하고 있는 반면³⁾, 일반적으로 지원 법률은 희생자에 대한 도의적·인도적 차원에서 위로를 목적으로 하므로, 강제동원조사법에서 유족의 범위를 보상 법률과 동일하게 규정할 경우 다른 지원 법률과의 형평성 문제가 제기될 수 있는 점 등을 고려하여⁴⁾ 유족의 범위를 현행과 같이 규정하게 된 것인바, 위로금을 지급받을 유족의 범위에 국외강제동원 희생자의 “4촌 이내의 방계혈족”은 포함되지 않는다고 해석하는 것이 해당 조문의 입법연혁 및 입법취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

따라서 국외강제동원 희생자의 친족 중 강제동원조사법 제3조제1항 각 호에 해당하는 사람이 없는 경우, 국외강제동원 희생자의 “4촌 이내의 방계혈족”은 위로금을 지급받을 유족이 될 수 없습니다.

1) 2010. 3. 22. 법률 제10143호로 강제동원조사법이 제정되면서 폐지됨

2) 헌법재판소 2015. 12. 23. 선고 2011헌바139 결정례 참조

3) 「민주화운동 관련자 명예회복 및 보상 등에 관한 법률」, 「특수임무수행자 보상에 관한 법률」 등에서는 유족의 범위를 「민법」에 따른 재산상속인으로 규정하고 있음

4) 2009. 8. 13. 의안번호 제1805697호로 발의된 태평양전쟁 전후 국외 강제동원희생자 등 지원에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 행정안전위원회 검토보고서 참조



관계법령

대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법

제3조(유족의 범위 등) ① 이 법에서 “유족”이란 피해자, 국외강제동원 희생자, 미수금피해자 가운데 사망하거나 행방불명된 사람의 친족 중 다음 각 호에 해당하는 사람으로서 제8조제3호 및 제6호에 따라 유족으로 결정을 받은 사람을 말한다.

1. 배우자 및 자녀
2. 부모
3. 손자녀
4. 형제자매

② 제4조에 따른 위로금 및 제5조에 따른 미수금 지원금을 지급받을 유족의 순위는 제1항 각 호의 순위로 한다.

③ 제1항 각 호의 순위에 따른 유족은 제4조에 따른 위로금 및 제5조에 따른 미수금 지원금을 지급받을 권리를 갖는다. 다만, 같은 순위자가 2명 이상인 경우에는 같은 지분으로 위로금 및 미수금 지원금을 지급받을 권리를 공유한다.

④ (생략)

질의제목 20

▶ 안전번호 25-0331

인천광역시 남동구 - 공공기관에 공개 청구된 정보가 제3자와 관련이 있다고 인정되는 경우로서 해당 공공기관이 공개 대상 정보로 결정하려는 경우, 제3자 통지 절차를 반드시 거쳐야 하는지 여부 (「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제11조제3항 등 관련)

01 질의요지

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 “정보공개법”이라 함) 제11조제3항에서는 공공기관은 공개 청구된 공개 대상 정보의 전부 또는 일부가 제3자와 관련이 있다고 인정할 때에는 그 사실을 제3자에게 지체 없이 통지하여야 하며, 필요한 경우에는 그의 의견을 들을 수 있다고 규정하고 있는바,

공공기관에 공개 청구된 정보가 제3자와 관련이 있다고 인정되는 경우로서 해당 공공기관이 정보공개법 제11조제1항에 따라 공개 대상 정보로 결정하려는 경우, 해당 공공기관은 공개 대상 정보에 대해 같은 조 제3항에 따른 제3자 통지(이하 “제3자 통지”라 함) 절차를 반드시 거쳐야 하는지¹⁾?

02 회답

이 사안의 경우, 공공기관은 공개 대상 정보에 대해 제3자 통지 절차를 반드시 거쳐야 합니다.

03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데²⁾, 정보공개법 제9조제1항에서는 공공기관이 보유하는 정보는 공개대상이 된다고 규정하면서(본문), 다른

1) 공개 청구된 정보가 정보공개법 제16조에 따른 즉시 처리가 가능한 정보가 아닌 경우를 전제함

2) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

법률 등에 따라 비밀이나 비공개 사항으로 규정된 정보 등은 공개하지 않을 수 있다(단서)고 규정하고 있고, 같은 법 제11조제1항에서는 공공기관은 정보공개에의 청구를 받으면 그 청구를 받은 날부터 10일 이내에 공개 여부를 결정해야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 공공기관은 공개 청구된 “공개 대상 정보”의 전부 또는 일부가 제3자와 관련이 있다고 인정할 때에는 그 사실을 제3자에게 지체 없이 통지해야 한다고 규정하고 있는바, 문언상 공공기관은 공개 청구된 정보가 제3자와 관련이 있다고 인정되는 경우로서 정보공개법 제11조제1항에 따라 “공개 대상 정보”로 결정하려는 때에는 지체 없이 공개 대상 정보에 대해 제3자 통지 절차를 거쳐야 하는 의무가 있다고 할 것입니다.

그리고 정보공개법 제11조에서는 정보공개에의 청구를 받은 공공기관이 정보공개 여부 결정에 필요한 사항을 규정하면서, 같은 법 제21조에서 이러한 공개 청구된 사실을 통지받은 제3자는 해당 공공기관에 대하여 자신과 관련된 정보를 공개하지 않을 것을 요청할 수 있고(제1항), 이러한 비공개 요청에도 불구하고 공공기관이 공개 결정을 할 때에는 공개 결정 이유와 공개 실시일을 분명히 밝혀 지체 없이 문서로 통지해야 하며(제2항), 공개 결정일과 공개실시일 간에 최소한 30일의 간격을 두도록 하는(제3항) 등 제3자 통지를 받은 자의 비공개 요청 절차를 구체적으로 규정하고 있는 한편, 정보공개법 제16조에서는 법령 등에 따라 공개를 목적으로 작성된 정보 등으로서 즉시 또는 말로 처리가 가능한 정보에 대해서는 같은 법 제11조에 따른 절차를 거치지 않고 공개해야 한다고 별도로 규정하고 있는바, 같은 법 제16조에 따른 정보에 해당하지 않는다면, 같은 법 제10조에 따라 정보공개에의 청구를 받은 공공기관은 같은 법 제11조에 따라 공개 청구된 정보가 제3자와 관련이 있다고 인정되는 경우에는 해당 공개 대상 정보에 대해 제3자 통지 절차를 거쳐야 하고, 이러한 통지를 받은 제3자가 비공개 요청을 할 수 있도록 하는 절차를 마련하고 있습니다.

이처럼 정보공개법 제11조제3항 및 제21조에서 공개 청구된 공개 대상 정보와 관련 있는 제3자에 대해 별도의 통지 절차 및 제3자의 비공개 요청 규정을 두고 있는 취지는 공공기관이 보유·관리하고 있는 제3자와 관련이 있는 정보가 공개될 경우 이와 관련된 제3자의 권익을 보호하고³⁾ 해당 정보의 공개 전에 제3자의 의견을 반영하거나 공공기관의 정보공개 결정에 대해 불복할 수 있는 기회를 보장하기 위한 것인바⁴⁾, 공공기관은 공개 청구된 정보가 제3자와 관련이 있는 경우에는 반드시 제3자에게 정보공개 청구 사실을 통지해야 한다고 해석함으로써 향후 제3자가 이에 대해 불복할 수 있는 기회를 보장받을 수 있도록 하는 것이 법령의 체계 및 규정의 취지에 부합하는 해석입니다.

3) 1996. 8. 22. 의안번호 150077호로 발의된 공공기관의정보공개에 관한 법률안에 대한 국회 행정위원회 검토보고서 참조

4) 법제처 2006. 5. 10. 회신 06-0058 해석례, 법제처 2023. 12. 27, 회신 해석례 23-0495 참조

따라서 이 사안의 경우, 공공기관은 공개 대상 정보에 대해 제3자 통지 절차를 반드시 거쳐야 합니다.



관계법령

공공기관의 정보공개에 관한 법률

제11조(정보공개 여부의 결정) ①·② (생략)

③ 공공기관은 공개 청구된 공개 대상 정보의 전부 또는 일부가 제3자와 관련이 있다고 인정할 때에는 그 사실을 제3자에게 지체 없이 통지하여야 하며, 필요한 경우에는 그의 의견을 들을 수 있다.

④·⑤ (생략)

질의제목 21

▶ 안전번호 25-0351

민원인 - 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제19조제5항에 따른 농업회사법인 설립 신고를 대리하는 것이 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지 여부(「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련)

01 질의요지

「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理) 업무를 행정사¹⁾의 업무로 규정하고 있는 한편, 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」(이하 “농어업경영체법”이라 함) 제19조제5항에서는 농업회사법인을 설립하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장(이하 “시장등”이라 함)에게 신고하여야 한다고 규정하고 있는바,

농어업경영체법 제19조제5항에 따른 농업회사법인 설립 신고를 대리하는 것이 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지?

02 회답

농어업경영체법 제19조제5항에 따른 농업회사법인 설립 신고를 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당합니다.

03 이유

먼저 「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 행정사가 다른 사람의 위임을 받아 수행할 수 있는 업무의 하나로 ‘인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리’ 업무를 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제2조제5호에서는 같은 법 제2조제1항제5호에 따라 행정사가 수행할 수 있는 업무의 내용과 범위를 ‘다른 사람의 위임을 받아

1) 「행정사법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조제1호에 따른 일반행정사를 말하며, 이하 같은

인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일'로 구체화하고 있습니다.

그런데 농어업경영체법 제19조제1항에서는 농업의 경영이나 농산물의 유통·가공·판매를 기업적으로 하려는 자나 농업인의 농작업을 대행하거나 농어촌 관광휴양사업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 농업회사법인(農業會社法人)을 설립할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제5항에서는 농업회사법인을 설립하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시장등에게 신고하여야 한다고 규정하고 있는바, 행정기관은 일반적으로 국가 또는 지방자치단체의 행정사무를 맡아보는 기관²⁾으로서, '시장등'은 「지방자치법」에 따라³⁾ 지방자치단체의 행정사무를 맡아보는 집행기관으로 행정기관에 해당하고, 시장등에게 농업회사법인의 설립을 신고하는 것은 행정기관에 신고하는 일에 해당하므로, 농어업경영체법 제19조제5항에 따른 농업회사법인의 설립 신고를 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제2조제5호에 따라 '다른 사람의 위임을 받아 행정기관에 신고하는 일을 대리하는 일'로서 행정사의 업무에 해당한다는 점이 문언상 명확합니다.

그리고 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리 등 사인의 행정기관 상대 민원 업무를 대신하거나 도와주는 일을 하는 직역으로⁴⁾, 행정사 제도는 일반적인 행정지식만으로 수행할 수 있는 기본적인 행정 사무를 분야별 전문가격자에게 맡기지 않고도 저렴한 비용으로 해당 서비스를 이용할 수 있도록 별도의 자격 제도를 마련한 것⁵⁾인바, 농어업경영체법 시행령 제19조 및 농어업경영체법 시행규칙 제10조 등에서 규정하고 있는 농어업경영체법령에 따른 농업회사법인 설립 신고는 「행정사법」 제2조제1항의 기본적인 행정사무에 해당하여 행정사의 일반적인 업무범위에 속하고, 농어업경영체법령에서는 달리 농업회사법인 설립 신고의 대리를 특정 자격이 있는 자만 수행할 수 있도록 명시적으로 제한하는 규정도 없는 점 등을 고려하면, 행정사가 농업회사법인 설립 신고의 대리 업무를 수행할 수 있다고 해석하는 것이 국민의 편의 증진을 위하여 행정사로 하여금 기본적인 행정사무를 취급할 수 있도록 하고 있는 「행정사법」의 취지에 부합하는 해석이라고 할 것⁶⁾입니다.

2) 국립국어원 표준국어대사전 참조

3) 「지방자치법」 제106조, 제114조 및 제116조 등 참조

4) 헌법재판소 2015. 3. 26. 선고 2013헌마131 결정례 참조

5) 법제처 2015. 10. 23. 회신 15-0443 해석례 참조

6) 법제처 2025. 5. 28. 회신 25-0242 해석례 및 법제처 2025. 2. 24. 회신 25-0032 해석례 참조

따라서 농어업경영체법 제19조제5항에 따른 농업회사법인 설립 신고를 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당합니다.



관계법령

행정사법

제2조(업무) ① 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 다음 각 호의 업무를 수행한다. 다만, 다른 법률에 따라 제한된 업무는 할 수 없다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理)
- 6.·7. (생 략)
- ② (생 략)

행정사법 시행령

제2조(업무의 내용과 범위) 「행정사법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항 각 호에 따른 행정사 업무의 내용과 범위는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 법 제2조제1항제5호의 사무: 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일
- 6.·7. (생 략)

농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률

제19조(농업회사법인 및 어업회사법인의 설립신고 등) ① 농업의 경영이나 농산물의 유통·가공·판매를 기업적으로 하려는 자나 농업인의 농작업을 대행하거나 농어촌 관광휴양사업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 농업회사법인(農業會社法人)을 설립할 수 있다.

- ② ~ ④ (생 략)
- ⑤ 농업회사법인 및 어업회사법인을 설립하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항이 변경되는 경우 또는 해산하는 경우에도 같은 방법으로 변경신고 또는 해산신고를 하여야 한다.
- ⑥ 시장·군수·구청장은 제5항에 따른 설립신고, 변경신고 또는 해산신고를 받은 날부터 20일 이내에 설립신고수리, 변경신고수리, 해산신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.
- ⑦·⑧ (생 략)
- ⑨ 농업회사법인 및 어업회사법인의 출자, 정관 기재사항 및 해산 등에 필요한 사항과 제5항부터 제8항까지에서 규정한 사항 외에 농업회사법인 및 어업회사법인의 설립신고, 변경신고, 해산신고, 신고의 반려 또는 보완 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑩·⑪ (생 략)

민원인 - 법률 제10441호 행정사법 전부개정법을 부칙 제3조에서 규정하고 있는 “공무원”의 범위 (법률 제10441호 행정사법 전부개정법을 부칙 제3조 관련)

01 질의요지

행정사 자격시험과 관련하여 2011년 3월 8일 법률 제10441호로 전부개정되어 2013년 1월 1일 시행된 「행정사법」(이하 “개정 「행정사법」”이라 함) 제9조제1항에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 제1차 시험을 면제한다고 규정하면서 같은 항 제1호가목에서는 경력직공무원(특정직공무원 중 대통령령으로 정하는 공무원과 기능직공무원을 제외함)으로 10년 이상 근무한 사람 중 7급 이상의 직에 근무한 사람을 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 제1차시험의 전과목과 제2차시험의 과목 중 2분의 1을 넘지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 과목을 면제한다고 규정하면서 같은 항 제1호가목·나목에서는 경력직공무원으로서 15년 이상 근무한 사람 중 7급 이상의 직에 근무한 사람과 5급 이상의 직에 5년 이상 근무한 사람을 각각 규정하고 있으며, 같은 법 부칙 제3조에서는 이 법 공포 전부터 공무원으로 재직한 사람은 제9조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따라 행정사 자격시험의 전부 또는 일부를 면제한다고 규정하고 있는바,

개정 「행정사법」 부칙 제3조의 “공무원”에 「병역법」 제5조제1호가목에 따른 징집에 의하여 입영한 병(兵)인 군인이 포함되는지?

02 회답

개정 「행정사법」 부칙 제3조의 “공무원”에는 「병역법」 제5조제1호가목에 따른 징집에 의하여 입영한 병인 군인이 포함되지 않습니다.

03 이유

구 「행정사법」(2011년 3월 8일 법률 제10441호로 전부개정되어 2013년 1월 1일 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 같음) 제6조제1항에서는 특정직공무원 중 대통령령이 정하는 공무원 등을 제외한 경력직공무원으로 5년 이상 근무한 자에 대하여는 행정사 자격시험 중 제1차 시험을 면제한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항제1호에서는 같은 조 제1항의 규정에 의한 공무원으로 10년 이상 근무한 자 등에 대하여는 시험을 전부 면제한다고 규정하고 있으며, 구 「행정사법 시행령」(2011년 11월 30일 대통령령 제23325호로 전부개정되어 2013년 1월 1일 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 같음) 제9조제1항제1호에서는 구 「행정사법」 제6조제1항의 “특정직공무원 중 대통령령이 정하는 공무원”으로 “병인 군인” 등을 규정하여, 구 행정사법령에 따른 행정사 자격시험 면제 대상 공무원의 범위에서 “병인 군인”은 제외하고 있습니다.

그리고 개정 「행정사법」 제9조제1항제1호가목에서는 특정직공무원 중 대통령령으로 정하는 공무원 등을 제외한 경력직공무원으로 10년 이상 근무한 사람 중 7급 이상의 직에 근무한 사람은 제1차 시험을 면제한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항제1호가목·나목에서는 경력직공무원¹⁾으로서 15년 이상 근무한 사람 중 7급 이상의 직에 근무한 사람과 5급 이상의 직에 5년 이상 근무한 사람을 각각 규정하고 있으며, 개정 「행정사법 시행령」(2011년 11월 30일 대통령령 제23325호로 전부개정되어 2013년 1월 1일 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제13조제1항제2호에서는 개정 「행정사법」 제9조제1항제1호가목의 “특정직공무원 중 대통령령이 정하는 공무원”으로 “지원에 의하지 아니하고 임용된 하사와 병(兵)인 군인”을 규정하여, 구 행정사법령과 마찬가지로 행정사 자격시험 면제 대상 공무원의 범위에서 병인 군인을 제외하고 있는데, 개정 「행정사법」 부칙 제3조에서는 이 법 공포 전부터 공무원으로 재직한 사람은 제9조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따라 행정사 자격시험의 전부 또는 일부를 면제한다고 규정하고 있는바, 이 사안에서는 개정 「행정사법」 부칙 제3조의 “공무원”의 범위에 행정사 자격시험 면제 대상 공무원이 아닌 “병인 군인”이 포함되는지 여부가 문제된다고 할 것입니다.

그런데 일반적으로 법령의 개정에 따라 부칙에 규정되는 경과조치는 구법질서에서 신법질서로의 이행과정에서 나타나는 제도변화와 법적 안정성을 적절히 조화시키는 한편, 특정대상에 대한 신구법령의 적용관계를 분명히 규정함으로써 법질서의 원만한 전환을

1) 개정 「행정사법」 제9조제1항제1호가목의 경력직공무원과 같이, 특정직공무원 중 대통령령으로 정하는 공무원 등은 제외함

보장하는 기능을 수행하는 것으로서²⁾, 개정 「행정사법」 부칙 제3조를 둔 취지는 개정 「행정사법」 공포 당시 근무기간이 짧아 행정사 자격시험의 면제 요건을 충족하지 못한 공무원들이 구 「행정사법」의 행정사 자격 부여제도에 대하여 가지고 있던 신뢰 등을 보호하기 위한 것³⁾임을 고려하면, 개정 「행정사법」 부칙 제3조의 “공무원”은 구 「행정사법」 제6조에 따라 근무기간이 충족되면 시험이 면제되는 공무원으로 한정하여 해석하여야 할 것이고, 「병역법」 제5조제1호가목에 따라 징집에 의하여 입영한 병인 군인은 구 「행정사법」 제6조 제1항·제2항 및 같은 법 시행령 제9조제1항제1호에 따라 시험이 면제되는 경력직공무원에 해당하지 않아 근무기간의 경과와 관련없이 시험면제 적용대상에서 제외되므로, 개정 「행정사법」 부칙 제3조의 “공무원”에 해당하지 않는다고 해석하는 것이 법체계에 부합하는 해석입니다.

또한 경과조치는 특정대상에 대한 신구법령의 적용관계를 분명하게 규정하여 종전 규정에 따라 기득권이 성립된 경우에 한정하여 예외적으로 종전 규정을 적용할 수 있도록 한 것으로, 경과조치의 적용대상을 판단할 때는 개정규정의 입법 취지를 훼손하지 않는 범위에서 엄격하게 해석⁴⁾해야 하고, 개정 「행정사법」 제9조는 일반 국민들의 행정사 자격 취득 기회를 확대하여 유능한 인재에게 기회를 부여할 수 있도록 하려는 목적에서 경력직공무원 등에 대하여 행정사 자격시험의 면제 범위를 축소하고 그 요건을 강화한 것이므로⁵⁾, 종전 규정에 따라 행정사 자격시험의 면제 범위와 요건을 완화하여 적용하게 되는 개정 「행정사법」 부칙 제3조의 “공무원”의 범위는 구 「행정사법」 제6조에 따라 근무기간이 충족되면 시험이 면제되는 공무원으로 한정하여 해석하는 것이 행정사법령의 입법연혁 및 취지에도 부합합니다.

한편 개정 「행정사법」 부칙 제3조에서는 이 법 공포 전부터 “공무원”으로 재직한 사람은 제9조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따라 행정사 자격시험의 전부 또는 일부를 면제한다고 규정하면서 “공무원”의 범위를 별도로 규정하고 있지 않으므로, 이를 통상적 의미의 공무원으로 보아 「국가공무원법」 제2조제2항제2호에 따른 특정직공무원으로서 병인 군인은 개정 「행정사법」 부칙 제3조의 “공무원”에 해당한다는 의견이 있으나, 개정 「행정사법」 부칙 제3조에 따른 경과조치는 근무기간의 양적인 차이만 존재할 뿐, 행정사 자격의 부여에

2) 법제처 2012. 4. 10. 회신 12-0075 해석례 참조

3) 헌법재판소 2016. 2. 25. 선고 전원재판부 2013헌마626 결정례 참조

4) 법제처 2021. 10. 15. 회신 21-0465 해석례 등 참조

5) 2009. 6. 10. 의안번호 제1805079호로 발의된 행정사법 일부개정법률안 및 2009. 10. 29. 의안번호 제1806388호로 발의된 행정사법 전부개정법률안에 대한 국회 안전행정위원회 검토보고서 참조

대한 기대를 가지고 근무하여 온 점에는 차이가 없는 공무원에 대한 신뢰보호를 위한 것인 점을 고려하면, 구 행정사법령에 따르더라도 근무기간에 관계없이 행정사 자격시험이 면제되지 않는 병인 군인에 대하여 행정사 자격의 부여에 대한 신뢰가 있었다고 보기는 어려운바, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 개정 「행정사법」 부칙 제3조의 “공무원”에는 「병역법」 제5조제1호가목에 따른 징집에 의하여 입영한 병인 군인이 포함되지 않습니다.



관계법령

구 행정사법(2011년 3월 8일 법률 제10441호로 전부개정되어 2013년 1월 1일 시행되기 전의 것)

제6조(시험의 면제) ① 경력직공무원(특정직공무원중 대통령령이 정하는 공무원과 기능직공무원을 제외한다. 이하 같다)으로 5년 이상 근무하거나 대통령령으로 정하는 특수경력직공무원으로 7급 이상에 상당하는 직에 5년 이상 근무한 자에 대하여는 제1차시험을 면제한다.

② 다음 각호의 1에 해당하는 자에 대하여는 시험을 전부 면제한다.

1. 제1항의 규정에 의한 공무원으로 10년 이상 근무하거나 6급(이에 상당하는 계급을 포함한다) 이상의 직에 5년 이상 근무한 자
2. 3. (생략)
- ③·④ (생략)

구 행정사법 시행령(2011년 11월 30일 대통령령 제23325호로 전부개정되어 2013년 1월 1일 시행되기 전의 것)

제9조(시험면제대상공무원의 범위) ① 법 제6조제1항에서 “특정직공무원중 대통령령이 정하는 공무원”이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 공무원을 말한다.

1. 국가공무원법 제2조제2항제2호의 규정에 의한 특정직공무원중 법관, 검사, 지원에 의하지 아니하고 임용된 하사와 병인 군인과 특수분야의 업무를 담당하는 공무원으로서 다른 법률이 특정직공무원으로 지정하는 공무원
2. (생략)
- ②·③ (생략)

개정 행정사법(2011년 3월 8일 법률 제10441호로 전부개정되어 2013년 1월 1일 시행된 것)

제9조(시험의 면제) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 제1차시험을 면제한다.

1. 공무원으로 재직한 사람 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

6) 헌법재판소 2016. 2. 25. 선고 전원재판부 2013헌마626 결정례 참조

가. 경력직공무원(특정직공무원 중 대통령령으로 정하는 공무원과 기능직공무원은 제외한다. 이하 같다)으로 10년 이상 근무한 사람 중 7급(이에 상당하는 계급을 포함한다) 이상의 직에 근무한 사람

나. (생 략)

2.·3. (생 략)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 제1차시험의 전과목과 제2차시험의 과목 중 2분의 1을 넘지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 과목을 면제한다.

1. 경력직공무원으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 15년 이상 근무한 사람 중 7급(이에 상당하는 계급을 포함한다) 이상의 직에 근무한 사람

나. 5급(이에 상당하는 계급을 포함한다) 이상의 직에 5년 이상 근무한 사람

2. ~ 4. (생 략)

③·④ (생 략)

법률 제10441호 행정사법 전부개정법을 부칙

제3조(행정사 자격시험 면제에 관한 경과조치) 이 법 공포 전부터 공무원으로 재직한 사람과 외국어 번역 업무에 종사한 사람은 제9조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따라 행정사 자격시험의 전부 또는 일부를 면제한다.

개정 행정사법 시행령(2011년 11월 30일 대통령령 제23325호로 전부개정되어 2013년 1월 1일 시행된 것)

제13조(시험면제 대상 공무원 및 면제되는 시험의 범위) ① 법 제9조제1항제1호가목에서 “특정직공무원 중 대통령령으로 정하는 공무원”이란 다음 각 호의 공무원을 말한다.

1. 법관 및 검사

2. 지원에 의하지 아니하고 임용된 하사와 병(兵)인 군인

3. (생 략)

②·③ (생 략)

병역법

제5조(병역의 종류) ① 병역은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 현역: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 징집이나 지원에 의하여 입영한 병(兵)

나. (생 략)

2. ~ 6. (생 략)

질의제목 23

▶ 안전번호 25-0399

민원인 - 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제11조제1항에 따른 토지거래계약 허가 신청을 대리하는 것이 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지 (「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련)

01 질의요지

「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理) 업무를 행정사¹⁾의 업무로 규정하고 있는 한편, 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」(이하 “부동산거래신고법”이라 함) 제11조제1항 전단에서는 허가구역²⁾에 있는 토지에 관한 소유권·지상권을 이전하거나 설정하는 계약(이하 “토지거래계약”이라 함)을 체결하려는 당사자는 공동으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있는바,

부동산거래신고법 제11조제1항 전단에 따른 토지거래계약 허가 신청을 대리하는 것이 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지?

02 회답

부동산거래신고법 제11조제1항 전단에 따른 토지거래계약 허가 신청을 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당합니다.

03 이유

먼저 「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 수행할 수

1) 「행정사법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조제1호에 따른 일반행정사를 말하며, 이하 같음

2) 토지거래계약에 관한 허가구역을 말하며(부동산거래신고법 제10조제1항 참조), 이하 같음

있는 업무의 하나로 ‘인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리’ 업무를 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제2조제5호에서는 같은 법 제2조제1항제5호에 따라 행정사가 수행할 수 있는 업무의 내용과 범위를 ‘다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관의 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일’로 구체화하고 있습니다.

그런데 부동산거래신고법 제11조제1항 전단에서는 토지거래계약을 체결하려는 당사자는 공동으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제8조에서는 같은 법 제11조제1항 전단에 따른 토지거래계약의 허가를 받으려는 자는 공동으로 신청서에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 같은 법 제11조제1항에 따른 허가권자인 허가관청에 제출하여야 한다고 규정(제1항)하고 있으며, 그 신청서를 받은 허가관청은 지체 없이 필요한 조사를 하고 신청서를 받은 날부터 15일 이내에 허가 또는 불허가 처분을 하여야 한다고 규정(제3항)하고 있는바, 행정기관은 일반적으로 국가 또는 지방자치단체의 행정사무를 맡아보는 기관³⁾으로서, ‘시장·군수 또는 구청장’은 「지방자치법」에 따라⁴⁾ 지방자치단체의 행정사무를 맡아보는 집행기관으로 행정기관에 해당하고, 시장·군수 또는 구청장에게 토지거래계약의 허가를 신청하는 것은 허가를 받기 위하여 행정기관에 하는 신청에 해당하므로, 부동산거래신고법 제11조제1항 전단에 따른 토지거래계약 허가 신청을 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제2조제5호에 따라 ‘다른 사람의 위임을 받아 행정기관에 허가의 신청 등 일정한 행위를 요구하는 일을 대리하는 일’로서 행정사의 업무에 해당한다는 점이 문언상 명확합니다.

그리고 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리 등 사인의 행정기관 상대 민원 업무를 대신하거나 도와주는 일을 하는 직역으로⁵⁾, 행정사 제도는 일반적인 행정지식만으로 수행할 수 있는 기본적인 행정사무를 분야별 전문자격자에게 맡기지 않고도 저렴한 비용으로 해당 서비스를 이용할 수 있도록 별도의 자격 제도를 마련한 것⁶⁾인바, 부동산거래신고법 시행령 제8조 등에서 규정하고 있는 토지거래계약 허가 신청은 「행정사법」 제2조제1항의 기본적인 행정사무에 해당하여 행정사의 일반적인 업무범위에 속하고, 부동산거래신고법령에서는 달리 토지거래계약 허가

3) 국립국어원 표준국어대사전

4) 「지방자치법」 제106조, 제114조 및 제116조 등 참조

5) 헌법재판소 2015. 3. 26. 선고 2013헌마131 결정례 참조

6) 법제처 2015. 10. 23. 회신 15-0443 해석례 참조

신청의 대리를 특정 자격이 있는 자만 수행할 수 있도록 명시적으로 제한하는 규정도 없는 점 등을 고려하면, 행정사가 토지거래계약 허가 신청의 대리를 수행할 수 있다고 해석하는 것이 국민의 편의 증진을 위하여 행정사로 하여금 기본적인 행정사무를 취급할 수 있도록 하고 있는 「행정사법」의 취지에 부합하는 해석이라고 할 것⁷⁾입니다.

따라서 부동산거래신고법 제11조제1항 전단에 따른 토지거래계약 허가 신청을 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당합니다.



관계법령

행정사법

제2조(업무) ① 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 다음 각 호의 업무를 수행한다. 다만, 다른 법률에 따라 제한된 업무는 할 수 없다.

1. ~ 4. (생략)
5. 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理)
- 6.·7. (생략)
- ② (생략)

행정사법 시행령

제2조(업무의 내용과 범위) 「행정사법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항 각 호에 따른 행정사 업무의 내용과 범위는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 4. (생략)
5. 법 제2조제1항제5호의 사무: 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일
- 6.·7. (생략)

부동산 거래신고 등에 관한 법률

제10조(토지거래허가구역의 지정) ① 국토교통부장관 또는 시·도지사는 국토의 이용 및 관리에 관한 계획의 원활한 수립과 집행, 합리적인 토지 이용 등을 위하여 토지의 투기적인 거래가 성행하거나 지가(地價)가 급격히 상승하는 지역과 그러한 우려가 있는 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따라 5년 이내의 기간을 정하여 제11조제1항에 따른 토지거래계약에 관한 허가구역(이하 “허가구역”이라 한다)으로 지정할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관 또는 시·도지사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 허가대상자(외국인등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다),

7) 법제처 2025. 2. 24. 회신 25-0032 해석례 참조

허가대상 용도와 지목 등을 특정하여 허가구역을 지정할 수 있다.

1. 허가구역이 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우: 국토교통부장관이 지정
2. 허가구역이 동일한 시·도 안의 일부지역인 경우: 시·도지사가 지정. 다만, 국가가 시행하는 개발사업 등에 따라 투기적인 거래가 성행하거나 지가가 급격히 상승하는 지역과 그러한 우려가 있는 지역 등 대통령령으로 정하는 경우에는 국토교통부장관이 지정할 수 있다.

② ~ ⑦ (생략)

제11조(허가구역 내 토지거래에 대한 허가) ① 허가구역에 있는 토지에 관한 소유권·지상권(소유권·지상권의 취득을 목적으로 하는 권리를 포함한다)을 이전하거나 설정(대가를 받고 이전하거나 설정하는 경우만 해당한다)하는 계약(예약을 포함한다. 이하 “토지거래계약”이라 한다)을 체결하려는 당사자는 공동으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② ~ ⑦ (생략)

제2절 공무원

질의제목 1

▶ 안전번호 24-0930

민원인 - 경력경쟁채용시험을 통해 임용된 국가공무원의 파견근무기간 동안의 직위는 「공무원임용령」 제2조제7호에 따른 “현 직위”에 해당하는지(「공무원임용령」 제2조제7호 등 관련)

01 질의요지

「공무원임용령」 제2조제7호에서는 “필수보직기간”이란 공무원이 다른 직위로 전보되기 전까지 현 직위에서 근무하여야 하는 최소기간을 말한다고 규정하고 있고, 같은 영 제45조제6항 본문에서는 임용권자 또는 임용제청권자는 「국가공무원법」 제28조에 따라 같은 항 각 호의 경력경쟁채용시험등¹⁾을 통해 채용된 공무원을 최초로 직위에 임용된 날부터 같은 항 각 호의 구분에 따른 필수보직기간이 지나야 전보할 수 있다고 규정하고 있는바,

「국가공무원법」 제28조에 따라 경력경쟁채용시험을 통해 임용된 국가공무원이 본래의 직위에서 업무를 수행하던 중 「공무원임용령」 제41조에 따라 타 기관으로 파견을 가서 본래의 직위와 직무의 유사성이 높은 직위에서 업무를 수행한 후 본래의 직위로 복귀한 경우, 파견근무기간 동안의 직위는 「공무원임용령」 제2조제7호에 따른 “현 직위”에 해당하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 파견근무기간 동안의 직위는 「공무원임용령」 제2조제7호에 따른 “현 직위”에 해당하지 않습니다.

1) 일정한 경우 경력 등 응시요건을 정하여 같은 사유에 해당하는 다수인을 대상으로 경쟁의 방법으로 채용하는 시험 등을 통한 채용을 말하며(「국가공무원법」 제28조제2항 및 「공무원임용령」 제16조제1항 참조), 이하 같음

03 이유

「공무원임용령」 제2조제7호에서는 “필수보직기간”이란 공무원이 다른 직위로 전보되기 전까지 현 직위에서 근무하여야 하는 최소기간을 말한다고 규정하고 있어, 필수보직기간은 전보²⁾라는 임용행위를 기준으로 그 기간을 산정하고 있고, 「국가공무원법」 제5조제1호에서는 “직위”란 1명의 공무원에게 부여할 수 있는 직무와 책임을 말한다고 규정하고 있는바, 이 사안에서는 본래의 직위에서 업무를 수행하던 중 파견을 가서 본래의 직위와 직무의 유사성이 높은 직위(이하 “파견 직위”라 함)에서 업무를 수행한 후 본래의 직위로 복귀한 경우 본래의 직위와 파견 직위를 하나의 동일한 직위로 보아, 파견 직위에서 근무한 기간도 「공무원임용령」 제2조제7호에 따라 “현 직위”에서 근무한 기간으로 보아 필수보직기간에 산입할 수 있는지가 문제됩니다.

먼저 「공무원임용령」 제2조제7호의 규정에 따르면 “현 직위”는 다른 직위로 전보되기 전까지의 직위를 의미하고, “전보”가 있는 경우 현 직위에서 다른 직위로 직위의 변동이 발생하게 되는바, “파견”의 경우에도 전보와 같이 현 직위에서 다른 직위로의 변동이 발생하는지를 살펴보면, 「국가공무원법」 제32조의4제1항에서는 국가기관의 장은 국가적 사업의 수행 또는 그 업무 수행과 관련된 행정 지원 등을 위하여 필요하면 소속 공무원을 다른 기관으로 파견근무하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 「공무원임용령」 제41조제5항 본문에서는 파견의 발령은 해당 공무원의 전보권 또는 전보제청권을 갖고 있는 기관의 장이 한다고 규정하고 있어, 파견은 해당 공무원의 전보권 또는 전보제청권 등 직위를 변경하는 권한이 있는 자가 행하도록 하고 있으므로 파견도 전보와 유사하게 공무원의 직위가 변동되는 효과가 발생한다고 할 것입니다.

다음으로 파견근무기간 동안 파견 직위에서 수행한 업무가 원 소속기관의 본래의 직위에서 수행하였던 업무와 유사한 직무를 수행하는 것인 경우 「공무원임용령」 제2조제7호에 따른 현 직위가 유지되는 것으로 볼 수 있는지 살펴보면, 「국가공무원법」 제5조제1호에서는 “직위(職位)”란 1명의 공무원에게 부여할 수 있는 직무와 책임을 말한다고 규정하고 있고, 「공무원임용령」 제43조제1항에서는 임용권자나 임용제청권자는 법령으로 따로 정하는 경우 외에는 소속 공무원의 직급과 직류를 고려하여 그 직급에 상응하는 일정한 직위를 부여하여야 한다고 규정하고 있을 뿐, 법령상 직위를 부여하거나 구분하는 기준에 대해서는 규정하고 있지 않은데, 일반적으로 행정기관은 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」 제4조에 따라 해당

2) 같은 직급 내에서의 보직 변경 또는 고위공무원단 직위 간의 보직변경을 말하며(「국가공무원법」 제5조제6호 참조), 이하 같음

기관의 조직과 정원을 규정하는 대통령령인 직제에서 직위와 그에 부여되는 계급 등을 정하고 있고, 직제에서는 직위를 통상 “과” 단위로 지정하고 있는 점을 고려하면, 필수보직기간의 준수 여부를 판단하기 위한 전보의 기준도 원칙적으로 부서 단위의 이동으로 보아³⁾ 부서가 변경되면 직위가 변경되는 것으로 볼 수 있다고 할 것인바, 파견의 경우 원 소속기관에서 근무하던 부서와 파견기관에서 근무하던 부서는 서로 다른 직제에 근거하고 있으므로 그 직위가 동일하다고 보기 어렵습니다.

그리고 「공무원임용령」 제45조에 따른 필수보직기간제도는 공무원 인사운영 과정에서 순환보직이 빈번하게 이루어지고 있는 관행을 개선하기 위하여 하나의 직위에서 일정기간 이상의 장기 근속을 유도하여 공무원의 전문성과 경쟁력을 강화하기 위한 것으로서⁴⁾, 같은 조 제6항에서는 경력경쟁채용시험으로 채용된 공무원의 필수보직기간을 규정하면서 같은 조 제7항에서는 직무가 동일하거나 유사성이 높은 직위로 전보하는 경우에는 필수보직기간을 단축할 수 있도록 규정하고 있을 뿐, 유사성이 높은 직위로 전보된 기간을 필수보직기간에 산입할 수 있다는 내용은 규정하지 않고 있어, 전보의 경우 직무의 유사성이 높은 직위로 전보되더라도 필수보직기간에 산입하지 않고 있는데, 파견의 경우에 직무 내용의 유사성이 높다는 이유만으로 본래의 직위에서 업무를 수행한 것으로 보아 파견근무기간을 필수보직기간에 산입할 수 있다고 해석하는 것은 필수보직기간의 규정 체계 및 제도의 취지에 부합하지 않는다고 할 것입니다.

한편 「공무원임용령」 제45조제1항 전단에서는 필수보직기간에 대하여 휴직기간, 직위해제 처분기간, 강등 및 정직 처분으로 인하여 직무에 종사하지 않은 기간은 포함하지 않는다고 규정하여 필수보직기간에 산입하지 않는 예외를 정하고 있는데, 이러한 예외 기간에 파견 직위에서 근무한 기간에 대하여는 별도로 명시하고 있지 않으므로 ‘현 직위’에서 근무한 기간에서 파견 근무기간을 제외할 수 없다는 의견이 있으나, 해당 규정은 휴직·직위해제·강등 및 정직으로 인하여 ‘직무에 종사하지 않은 기간’이 있는 경우에는 그 기간을 필수보직기간의 산정에서 제외하려는 것으로서, 이 사안과 같이 파견 직위에서 근무한 경우는 직무에 종사한 기간으로서 필수보직기간 산정 시 제외하도록 한 휴직·직위해제·강등 및 정직 처분으로 인하여 ‘직무에 종사하지 않은 기간’에는 해당하지 않는다는 점에서, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 파견근무 기간 동안 수행한 직위는 「공무원임용령」 제2조제7호에 따른 “현 직위”에 해당하지 않습니다.

3) 인사혁신처 2024 공무원 인사실무 p.138 참조

4) 2015. 9. 25. 대통령령 제26566호로 일부개정된 「공무원임용령」 개정이유 참조



관계법령

공무원임용령

제2조(정의) 이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “임용”이란 신규채용, 승진임용, 전직(轉職), 전보, 겸임, 파견, 강임(降任), 휴직, 직위해제, 정직, 강등, 복직, 면직, 해임 및 파면을 말한다.
2. ~ 6. (생략)
7. “필수보직기간”이란 공무원이 다른 직위로 전보되기 전까지 현 직위에서 근무하여야 하는 최소기간을 말한다.

제45조(필수보직기간의 준수 등) ① 임용권자 또는 임용제청권자는 소속 공무원을 해당 직위에 임용된 날부터 필수보직기간(휴직기간, 직위해제처분기간, 강등 및 정직 처분으로 인하여 직무에 종사하지 않은 기간은 포함하지 않는다. 이하 이 조에서 같다)이 지나야 다른 직위에 전보(소속 장관이 다른 기관으로 전보하는 경우는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)할 수 있다. (후단 생략)

국가공무원법

제5조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “직위(職位)”란 1명의 공무원에게 부여할 수 있는 직무와 책임을 말한다.
2. ~ 5. (생략)
6. “전보(轉補)”란 같은 직급 내에서의 보직 변경 또는 고위공무원단 직위 간의 보직 변경(제4조제2항에 따라 같은 조 제1항의 계급 구분을 적용하지 아니하는 공무원은 고위공무원단 직위와 대통령령으로 정하는 직위 간의 보직 변경을 포함한다)을 말한다.

질의제목 2

▶ 안전번호 24-0944

민원인 - 윤년인 해의 2월 29일에 출생한 교육공무원의 정년퇴직일(「교육공무원법」 제47조제1항 등 관련)

01 질의요지

「교육공무원법」 제47조제1항 본문에서 교육공무원의 정년은 62세¹⁾로 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 교육공무원²⁾은 그 정년에 이른 날이 3월에서 8월 사이에 있는 경우에는 8월 31일에, 9월에서 다음 해 2월 사이에 있는 경우에는 다음 해 2월 말일에 각각 당연히 퇴직한다고 규정하고 있는바,

윤년³⁾인 해의 2월 29일에 출생한 교육공무원의 당연퇴직일은 62세가 되는 해⁴⁾의 2월 28일인지, 아니면 8월 31일인지?

02 회답

윤년인 해의 2월 29일에 출생한 교육공무원의 당연퇴직일은 62세가 되는 해의 2월 28일입니다.

03 이유

「교육공무원법」 제47조제1항 본문에서는 교육공무원의 정년은 62세로 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 교육공무원(임기가 있는 교육공무원을 포함함)은 그 정년에 이른 날이 3월에서 8월 사이에 있는 경우에는 8월 31일에, 9월에서 다음 해 2월 사이에 있는

- 1) 「교육공무원법」에서 나이에 관하여 특별한 규정을 두고 있지 않으므로, 「행정기본법」 제7조의2에 따라 만 나이로 계산함
- 2) 임기가 있는 교육공무원을 포함함
- 3) 1년의 길이를 365.2425일로 정하는 역법체계인 그레고리력에서 여분의 하루인 2월 29일을 추가하여 1년 동안 날짜의 수가 366일이 되는 해를 말함(「천문법」 제2조제4호 및 제5호 참조)
- 4) 윤년이 아닌 해를 전제함

경우에는 다음 해 2월 말일에 각각 당연히 퇴직한다고 규정하고 있는데, 교육공무원법령에서 윤년인 해의 2월 29일에 출생한 사람에 대한 정년의 산정에 관하여는 명확히 규정하고 있지 않은 바, 이를 해석할 때에는 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 할 것입니다⁵⁾.

먼저「교육공무원법」 제47조제2항에서는 정년에 이른 날이 3월에서 8월 사이에 있는 경우에는 8월 31일에, 9월에서 다음 해 2월 사이에 있는 경우에는 다음 해 2월 말일에 당연히 퇴직하도록 규정하고 있는데, 「교육공무원법」 제2조에 따르면 교육공무원은 「초·중등교육법」 제2조의 학교에 해당하는 국립 또는 공립의 학교 등 교육기관에 근무하는 교원 등을 말하고, 「초·중등교육법」 제24조제1항 및 같은 법 시행령 제44조제1항에 따르면 학교는 3월 1일부터 다음 해 2월 말일까지를 학년도로 하여 1학기는 3월 1일부터 학교의 장이 정하는 날까지, 2학기는 1학기 종료일 다음 날부터 다음 해 2월 말일까지로 교육과정을 운영하고 있는바, 「교육공무원법」 제47조제2항에서 교육공무원의 정년으로 인한 퇴직시기를 실제 정년에 이른 날이 아니라 학년도를 중심으로 8월 31일이나 2월 말일과 같이 학기의 말일과 유사하게 정하고 있는 취지는 교육공무원이 담당하고 있는 교육이라는 직무의 계속적이고 안정적인 수행과 교육공무원 인사에 관한 행정의 편의를 도모하기 위한 것으로서⁶⁾, 이 사안 교육공무원의 경우 출생일인 2월 29일이 속한 학기의 말일인 62세가 되는 해의 2월 28일에 당연히 퇴직한다고 해석하는 것이 같은 법 제47조제2항의 취지에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

또한 교육공무원의 정년 규정에 대한 입법연혁을 살펴보면, 1963년 12월 5일 법률 제1463호로 전부개정된 「교육공무원법」에서 제52조제2항을 신설하여 교육공무원으로서 정년에 달한 자는 그 정년에 달한 날에 당연히 퇴직하도록 규정하면서 교원의 경우에는 “그 정년에 달한 날이 속하는 학기의 말일”에 당연히 퇴직하도록 규정하였고, 이후 1981년 11월 23일 법률 제3458호로 전부개정된 「교육공무원법」 제47조제2항에서는 교원을 포함한 모든 교육공무원이 “그 정년에 달한 날이 속하는 학기의 말일”에 당연히 퇴직하도록 규정하고 있던 것을, 2004년 10월 15일 법률 제7223호로 일부개정된 「교육공무원법」 제47조제2항에서 현행과 같이 “그 정년에 달한 날이 3월에서 8월 사이에 있는 경우에는 8월 31일에, 9월부터 다음 해 2월 사이에 있는 경우에는 다음 해 2월 말일”에 당연히 퇴직된다고 규정하여 학기의 말일을 각각 8월 31일과 2월 말일로 명확히 규정한 것인바, 이러한 규정의 연혁에 비추어보면,

5) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

6) 서울고등법원 2020. 5. 20. 선고 2019누52296 판결

교육공무원의 당연퇴직일은 학기를 기준으로 정하도록 한 것이고, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사안 교육공무원의 당연퇴직일은 학기가 종료되는 날인 2월 28일이라고 보아야 할 것입니다.

따라서 이 사안 교육공무원의 당연퇴직일은 62세가 되는 해의 2월 28일입니다.



관계법령

교육공무원법

제47조(정년) ① 교육공무원의 정년은 62세로 한다. 다만, 「고등교육법」 제14조에 따른 교원인 교육공무원의 정년은 65세로 한다.

② 교육공무원(임기가 있는 교육공무원을 포함한다)은 그 정년에 이른 날이 3월에서 8월 사이에 있는 경우에는 8월 31일에, 9월에서 다음 해 2월 사이에 있는 경우에는 다음 해 2월 말일에 각각 당연히 퇴직한다.

질의제목 3

▶ 안전번호 25-0198

민원인 - 일반직 지방공무원으로 임용되기 전 특정직공무원 재직기간의 근속승진기간 산입 방식
(「지방공무원 임용령」 제33조의2 등 관련)

01 질의요지

「지방공무원 임용령」 제33조에서는 승진소요 최저연수에 대해 규정하면서, 같은 조 제6항에서는 퇴직한 지방공무원 또는 국가공무원이 퇴직 당시의 계급 이하의 계급으로 임용된 경우에는 퇴직 전의 재직기간 중 재임용 당시 계급 이상의 계급으로 재직한 기간은 재임용 당시 계급의 재직연수에 포함시키되 재임용된 날부터 10년 이내의 재직기간으로 한정한다고 규정하고 있고, 같은 조 제9항에서는 지방전문경력관, 임기제공무원, 특정직공무원 및 별정직공무원이 퇴직 후 일반직공무원으로 임용된 경우에는 교육부장관 또는 행정안전부장관이 정하는 범위에서 규칙으로 정하는 바에 따라 해당 계급 상당 이상으로 재직한 기간은 승진소요 최저연수에 포함시킬 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「지방공무원 임용령」 제33조의2에서는 근속승진 임용에 대해 규정하면서, 같은 조 제3항에서는 근속승진기간에는 같은 영 제33조에 따른 승진소요 최저연수에 산입되는 기간(이하 “승진소요 최저연수 산입기간”이라 함)을 포함하며, 이 경우 퇴직한 지방공무원 또는 국가공무원이 퇴직 당시 계급 이하의 계급으로 임용된 경우에는 같은 영 제33조제6항에도 불구하고 승진후보자 명부 작성일부터 10년 전의 재직기간도 합산하고, 같은 영 제33조제9항의 경우에는 승진소요 최저연수에 포함시켜 그 최저연수를 전부 채우고도 남는 기간이 있으면 그 남는 기간의 3분의 1에 해당하는 재직기간도 추가로 합산한다고 규정하고 있는바,

특정직공무원이 퇴직 후 일반직 지방공무원으로 임용된 경우¹⁾, 특정직공무원으로 재직한 기간에 대한 근속승진기간 산정 시 「지방공무원 임용령」 제33조의2제3항 후단에 따라 승진후보자 명부 작성일부터 10년 전의 특정직공무원 재직기간도 합산하여야 하는지?²⁾

1) 특정직공무원이 퇴직 후 퇴직 당시 계급 상당 이하의 일반직 지방공무원으로 임용된 경우로서, 특정직공무원으로 재직한 기간이 일반직 지방공무원으로 재임용된 날부터 10년 이내에 해당하지 않는 경우임을 전제함

2) 지방자치단체의 조례 또는 규칙에서 근속승진기간 산정 시 승진후보자 명부 작성일부터 10년 전의 특정직공무원 재직기간도 합산한다는 내용을 별도로 규정하고 있지 않은 경우를 전제함

02 회답

이 사안의 경우, 특정직공무원으로 재직한 기간에 대한 근속승진기간 산정 시 「지방공무원 임용령」 제33조의2제3항 후단에 따라 승진후보자 명부 작성일부터 10년 전의 특정직공무원 재직기간을 합산해야 하는 것은 아닙니다.

03 이유

「지방공무원 임용령」 제33조의2제3항에서는 근속승진기간 산정 방법에 대해 정하면서, 기본적으로 승진소요 최저연수 산입기간을 근속승진기간에 포함하되(전단) 근속승진기간에 추가로 합산할 수 있는 경우를 규정하고 있는바(후단), 먼저 승진소요 최저연수 산입기간에 대해 정하고 있는 같은 영 제33조의 규정을 살펴보면, 같은 조 제6항 전단에서는 퇴직한 지방공무원 또는 국가공무원이 퇴직 당시의 “계급 이하의 계급”으로 임용된 경우에는 퇴직 전의 재직기간 중 재임용 당시 “계급 이상의 계급”으로 재직한 기간 중 승진소요 최저연수에 산입가능한 기간을, 같은 조 제9항에서는 지방전문경력관, 임기제공무원, 특정직공무원 및 별정직공무원이 퇴직 후 일반직공무원으로 임용된 경우 해당 “계급 상당 이상”으로 재직한 기간 중 승진소요 최저연수에 산입가능한 기간을 각각 구분하여 규정하고 있습니다.

그리고 근속승진기간에 추가 합산할 수 있는 기간을 정하고 있는 제33조의2제3항 후단에서는 ㉔ 퇴직한 지방공무원 또는 국가공무원이 퇴직 당시 계급 이하의 계급으로 임용된 경우에는 제33조제6항에도 불구하고 승진후보자 명부 작성일부터 10년 전의 재직기간도 합산하고, ㉕ 제33조제9항의 경우에는 승진소요 최저연수에 포함시켜 그 최저연수를 전부 채우고도 남는 기간이 있으면 그 남는 기간의 3분의 1에 해당하는 재직기간도 추가로 합산한다고 하여, 제33조제6항 및 제9항에 대한 특례를 나누어서 규정하고 있는 점을 고려하면, 같은 영 제33조의2제3항 후단 중 ‘퇴직한 지방공무원 또는 국가공무원이 퇴직 당시 계급 이하의 계급으로 임용된 경우’에 대한 부분(㉔)은 동일 계급체계로 운영되는 공무원 경력을 전제로 승진후보자 명부 작성일부터 10년 전의 재직기간도 근속승진기간에 합산한다는 의미³⁾이고, 일반직공무원과 계급체계가 다른 특정직공무원으로 퇴직 후 일반직공무원으로 임용되어 같은 영 제33조제6항이 아닌 같은 조 제9항의 적용 대상이 되는

3) 법제처 2014. 6. 11. 회신 14-0266 해석례 참조

경우까지 동일하게 승진후보자 명부 작성일부터 10년 전의 재직기간이 근속승진기간에 합산된다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

또한 「지방공무원 임용령」 제33조제9항 및 제33조의2제9항의 위임에 따라 마련된 「지방공무원 인사제도 운영지침」(행정안전부예규) 제44조에서도 근속승진기간 산정은 승진소요 최저연수 산정방식을 따르되, 퇴직하였던 지방공무원 또는 국가공무원이 퇴직 당시 계급 이하의 계급으로 임용된 경우에는 「지방공무원 임용령」 제33조제6항 전단에도 불구하고 같은 영 제33조의2제3항에 따르고(제1항), 특정직공무원 등의 경력은 당해 계급 승진소요 최저연수의 2분의 1의 범위 내에서 인정하며 잔여기간이 있는 경우에는 다시 1/3을 추가 합산한다고(제2항) 각각 규정하여, 근속승진기간 산정방법에 대해 같은 영 제33조제6항의 특례와 별도로 특정직공무원 등의 경력을 합산하는 방법을 규정하고 있다는 점에 비추어 볼 때에도, 같은 영 제33조의2제3항 후단에 따라 근속승진기간에 승진후보자 명부 작성일부터 10년 전의 특정직공무원 재직기간을 합산하기는 어렵다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 특정직공무원으로 재직한 기간에 대한 근속승진기간 산정 시 「지방공무원임용령」 제33조의2제3항 후단에 따라 승진후보자 명부 작성일부터 10년 전의 특정직공무원 재직기간을 합산해야 하는 것은 아닙니다.



관계법령

지방공무원 임용령

제33조(승진소요 최저연수) ① 공무원이 승진하려면 다음 각 호의 구분에 따른 기간 동안 해당 계급에 재직해야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 7급, 8급 및 9급: 1년 이상

② ~ ⑤ (생략)

⑥ 퇴직한 지방공무원 또는 국가공무원이 퇴직 당시의 계급 이하의 계급으로 임용된 경우에는 퇴직 전의 재직기간 중 재임용 당시 계급 이상의 계급으로 재직한 기간은 재임용 당시 계급의 재직연수에 포함시키되, 재임용된 날부터 10년 이내의 재직기간으로 한정한다. 이 경우 고위공무원이었던 사람이 퇴직 후 4급 이하 공무원으로 임용된 경우에는 고위공무원으로 재직한 기간은 재임용 당시 계급의 재직연수에 포함시킨다.

⑦·⑧ (생략)

⑨ 지방전문경력관, 임기제공무원, 특정직공무원 및 별정직공무원이 퇴직 후 일반직공무원으로 임용된 경우에는 교육부장관 또는 행정안전부장관이 정하는 범위에서 규칙으로 정하는 바에 따라

해당 계급 상당 이상으로 재직한 기간은 제1항에 따른 기간에 포함시킬 수 있다.

⑩ ~ ⑭ (생략)

제33조의2(우대승진 및 근속승진 임용) ① (생략)

② 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제27조와 「지방교육행정기관의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제17조에 따라 공무원의 정원을 통합·운영하는 경우의 승진임용대상자는 제33조에 따른 승진소요 최저연수를 경과해야 하고, 승진후보자 명부에 올라 있어야 하며, 다음 각 호의 구분에 따른 기간(이하 “근속승진기간”이라 한다) 동안 해당 계급에 재직하여야 한다.

1. 2. (생략)

3. 9급: 5년 6개월 이상

③ 우대승진기간 및 근속승진기간에는 제33조에 따른 승진소요 최저연수에 산입되는 기간을 포함한다. 이 경우 퇴직한 지방공무원 또는 국가공무원이 퇴직 당시 계급 이하의 계급으로 임용된 경우에는 제33조제6항에도 불구하고 승진후보자 명부 작성일로부터 10년 전의 재직기간도 합산하고, 제33조제9항의 경우에는 승진소요 최저연수에 포함시켜 그 최저연수를 전부 채우고도 남는 기간이 있으면 그 남는 기간의 3분의 1에 해당하는 재직기간도 추가로 합산한다.

④ ~ ⑧ (생략)

⑨ 제1항부터 제8항까지에 따른 승진임용의 방법 및 인사 운영에 필요한 사항은 교육부장관 및 행정안전부장관이 정한다.

지방공무원 인사제도 운영지침(행정안전부예규)

제43조(승진소요최저연수) ① 전문경력관, 임기제공무원, 별정직공무원 및 특정직공무원 경력의 승진소요최저연수 산입은 각 호에 따른다.

1. 임용령 제33조제9항에 따라 산입되는 전문경력관, 임기제공무원, 별정직공무원 및 특정직공무원 경력은 당해 계급 승진소요최저연수의 2분의 1의 범위 내에서 인정한다. 단, 승진소요최저연수에 산입되는 전문경력관, 임기제공무원, 별정직공무원 및 특정직공무원 경력은 일반직공무원으로 재임용된 날부터 10년 이내의 재직기간

2. 3. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

제44조(근속승진 재직기간) ① 임용령 제33조의2제2항에 따른 근속승진기간 산정은 임용령 제33조 승진소요최저연수 산정방식을 따르되, 퇴직하였던 지방공무원 또는 국가공무원이 퇴직 당시 계급 이하의 계급으로 임용된 경우에는 임용령 제33조제6항 전단에도 불구하고 임용령 제33조의2제3항에 따른다.

② 전문경력관, 임기제공무원, 별정직공무원 및 특정직공무원의 경력은 당해 계급 승진소요최저연수의 2분의 1의 범위 내에서 인정하고, 잔여기간이 있는 경우에는 다시 1/3을 추가 합산한다.

질의제목 4

▶ 안전번호 25-0261

민원인 - 「지방공무원 임용령」 제24조제2항제1호에 해당하는 사람이 임용되기 전에 같은 영 제25조제1항에 따른 실무수습 대상이 될 수 있는지 여부(「지방공무원 임용령」 제25조제1항 등 관련)

01 질의요지

「지방공무원 임용령」 제25조제1항 본문에서는 임용권자 또는 임용후보자 추천권자는 시보공무원이나 시보공무원이 될 사람을 각급 공무원교육원, 일반교육기관이나 그 밖의 행정기관에 위탁하여 일정 기간 직무수행에 필요한 교육훈련 또는 실무수습을 시킬 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「지방공무원 임용령」 제24조제2항에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시보임용을 면제한다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 승진소요 최저연수를 초과하여 재직하고 승진임용 제한사유에 해당하지 않은 사람이 승진 예정 계급에 해당하는 신규임용시험에 합격하여 임용되는 경우를 규정하고 있는바,

「지방공무원 임용령」 제24조제2항제1호에 해당하는 사람이 임용되기 전에 같은 영 제25조제1항에 따른 실무수습 대상이 될 수 있는지?

02 회답

「지방공무원 임용령」 제24조제2항제1호에 해당하는 사람은 임용되기 전에 같은 영 제25조제1항에 따른 실무수습 대상이 될 수 있습니다.

03 이유

「지방공무원법」 제28조제1항 본문에서는 공무원을 신규임용하는 경우에는 일정 기간¹⁾

1) 5급 공무원을 신규임용하는 경우에는 1년, 6급 이하 공무원을 신규임용하는 경우에는 6개월간 시보로 임용함

시보로 임용하고, 그 기간의 근무성적·교육훈련성적과 공무원으로서의 자질을 고려하여 정규 공무원으로 임용한다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 대통령령으로 정하는 경우에는 시보임용을 면제하거나 그 기간을 단축할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제24조제2항에서는 승진소요 최저연수를 초과하여 재직하고 승진임용 제한사유에 해당하지 않은 사람이 승진 예정 계급에 해당하는 신규임용시험에 합격하여 임용되는 경우(제1호) 등은 시보임용을 면제한다고 규정하고 있는 한편, 같은 영 제25조제1항 본문에서는 임용권자 등은 시보공무원이나 시보공무원이 될 사람을 각급 공무원교육원, 일반교육기관이나 그 밖의 행정 기관에 위탁하여 일정 기간 직무수행에 필요한 교육훈련 또는 실무수습을 시킬 수 있다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 시보공무원이 될 사람이 실무수습을 받기를 원하는 경우에는 실무수습을 시켜야 한다고 규정하고 있는바, 시보임용의 면제 사유에 해당하는 사람이 공무원으로 임용되기 전에 실무수습 대상이 될 수 있는지를 판단하기 위해서는 해당 문언과 함께 관계 법령의 규정체계와 내용, 제도의 취지 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 조화롭게 해석할 필요가 있습니다.

먼저 「지방공무원법」 제27조제1항 및 「지방공무원 임용령」 제11조제1항에 따르면 공무원의 신규임용은 원칙적으로 공개경쟁임용시험으로 하고, 공개경쟁신규임용시험의 합격자는 시·도지사 등에게 신규임용후보자등록을 신청하여야 하며, 「지방공무원법」 제36조제1항 및 제37조제1항에 따르면 지방자치단체의 장은 공개경쟁임용시험에 합격한 사람을 신규임용후보자 명부에 등재(登載)하여야 하고, 지방자치단체의 장은 신규임용후보자 명부에 등재된 자 중에서 공무원을 신규임용할 때에는 그 명부의 최고순위자부터 3배수의 범위에서 임명하여야 하는바, 공개경쟁임용시험에 합격한 사람은 신규임용후보자 명부에 등재되고, 「지방공무원 임용령」 제24조제2항에 따른 시보임용의 면제 사유에 해당하는지 여부와 상관없이 「지방공무원법」 제28조제1항에 따라 시보공무원 또는 정규공무원으로 임용되기 전에는 모두 신규임용후보자로서의 지위를 가진다고 할 것입니다.

그리고 「지방공무원법」 제74조제1항에서는 모든 공무원과 시보공무원이 될 사람은 직무와 관련된 학식·기술 및 응용 능력을 배양하기 위하여 법령에서 정하는 바에 따라 훈련을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제37조제6항제2호에서는 임용후보자가 같은 법 제74조에 따라 시보공무원이 될 사람에 대한 교육훈련에 따르지 아니한 경우에는 임용후보자로서의 자격을 잃는다고 규정하고 있으며, 「지방공무원 임용령」 제25조에서는 “시보공무원이나 시보공무원이 될 사람에 대한 훈련”이라는 조 제목 하에 실무수습을 규정하면서, 실무수습을 시킬 수 있는 대상으로 “시보공무원”과 “시보공무원이 될 사람”을 규정하고 있는바, 「지방공무원법」 제74조제1항에 따르면 시보공무원이나 정규공무원도 학식·기술 및 응용

능력을 배양을 위한 훈련을 받을 의무가 있는데, 훈련의 필요성이 있는 경우라면 신규임용후보자가 시보임용의 면제 사유에 해당한다고 하여 훈련 대상에서 제외되고, 시보임용의 면제 사유에 해당하지 않는 경우에만 훈련 대상에 포함된다고 보기는 어렵다는 점에 비추어 보면, 「지방공무원법」 제74조제1항 및 「지방공무원 임용령」 제25조에서 훈련(실무수습)의 대상으로 규정하고 있는 “시보공무원이 될 사람”은 시보임용의 면제 사유에 해당하는 사람을 제외하려는 취지라기 보다는 시보공무원과 정규공무원을 포함하는 공무원과는 대비되는 신규임용후보자 명부에 등재된 사람을 의미하는 것으로서, 시보임용의 면제 사유에 해당하는 사람이 포함된다고 해석하는 것이 관계 법령의 문언과 규정체계에 부합합니다.

또한 「지방공무원 임용령」 제25조제1항에 따른 시보공무원이 될 사람에 대한 실무수습은 신규임용시험에 합격하여 신규임용후보자명부에 등재된 사람에 대하여 공무원으로 임용될 때까지 공무원으로서 소양과 공직사회에서 적응력 및 업무수행능력을 배양하기 위한 ‘임용 전 교육훈련’이고²⁾, 「지방공무원법」 제28조에 따른 시보임용 제도는 공무원의 신규채용을 위한 공개경쟁시험 등의 방법이 공무원의 직무수행능력을 완전히 실증하기 어려운 점을 감안하여 실무를 통해 적격성을 갖추지 못한 것으로 판정되는 사람을 정규공무원의 임용에서 배제함으로써 능력의 실증에 의하여 공무원을 임용하기 위한 것으로서³⁾, 실무수습과 시보임용은 그 제도의 목적이 서로 다르다고 할 것인데, 이미 공무원으로서 재직한 경력이 있는 사람에 대해서는 적격성이 있는 것으로 보아 다시 신규임용되는 경우 그 시보임용을 면제하려는 취지를 업무수행능력을 배양하기 위한 실무수습까지 배제하려는 의도가 있는 것으로 해석하기는 어려운바, 이러한 시보임용과 실무수습 제도의 취지를 고려하면 「지방공무원 임용령」 제24조제2항제1호에 해당하는 사람은 임용되기 전에 같은 영 제25조제1항에 따라 실무수습을 시킬 수 있는 대상에 해당된다고 해석하는 것이 타당합니다.

따라서 「지방공무원 임용령」 제24조제2항제1호에 해당하는 사람은 임용되기 전에 같은 영 제25조제1항에 따른 실무수습 대상이 될 수 있습니다.

2) 법제처 2016. 6. 2. 회신 16-0127 해석례 참조

3) 2014. 11. 26. 의안번호 제1912663호로 발의된 「지방공무원법」 일부개정법률안에 대한 국회 안전행정위원회 검토보고서 참조

법령정비 권고사항

「지방공무원 임용령」 제24조제2항에 따른 시보임용의 면제 사유에 해당하는 사람이 임용되기 전에 같은 영 제25조제1항에 따른 실무수습 대상에 포함될 필요가 있는지를 정책적으로 검토하고, 필요한 경우 이를 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

지방공무원 임용령

제24조(시보임용의 면제 및 기간 단축) ① (생 략)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 시보임용을 면제한다.

1. 제33조의 승진소요 최저연수를 초과하여 재직하고 제34조의 승진임용 제한사유에 해당하지 않은 사람이 승진 예정 계급에 해당하는 신규임용시험에 합격하여 임용되는 경우
2. ~ 4. (생 략)

제25조(시보공무원이나 시보공무원이 될 사람에 대한 훈련) ① 임용권자 또는 임용후보자 추천권자는 시보공무원이나 시보공무원이 될 사람을 각급 공무원교육원, 일반교육기관이나 그 밖의 행정 기관에 위탁하여 일정 기간 직무수행에 필요한 교육훈련 또는 실무수습을 시킬 수 있다. 다만, 시보공무원이 될 사람이 실무수습을 받기를 원하는 경우에는 실무수습을 시켜야 한다.

②·③ (생 략)

질의제목 5

▶ 안전번호 25-0318

민원인 - 업무대행기간이 만료된 경우 「공무원임용령」 제57조의4제1항 단서에 따라 업무를 대행하는 공무원에 해당하는지(「공무원임용령」 제57조의4 등 관련)

01 질의요지

「공무원임용령」 제57조의4제1항에서는 임용권자 또는 임용제청권자는 공무원이 「국가공무원법」 제71조제1항·제2항에 따른 휴직을 하는 경우, 「국가공무원 복무규정」 제18조제1항·제2항에 따른 병가를 가는 등의 경우에는 그 공무원의 업무를 대행하기 위하여 시간선택제임기제공무원 등을 채용할 수 있다고 규정(본문)하면서, 다만 소속 공무원에게 휴직을 하거나 휴가를 가는 공무원 또는 시간선택제전환공무원의 업무를 대행하도록 명한 경우에는 그렇지 않다고 규정(단서)하고 있는바,

「공무원임용령」 제57조의4제1항 단서에 따라 시간선택제전환공무원의 업무를 대행하도록 명령¹⁾을 받은 공무원이 업무대행기간이 만료된 후 별도의 업무대행기간 연장 명령이나 업무대행 해제 명령이 없는 경우, 같은 규정에 따라 업무를 대행하는 공무원에 해당하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 「공무원임용령」 제57조의4제1항 단서에 따라 업무를 대행하는 공무원에 해당하지 않습니다.

03 이유

「공무원임용령」 제57조의4제1항에서는 임용권자²⁾는 공무원이 「국가공무원법」 제71조제1항·제2항에 따른 휴직을 하는 경우, 「국가공무원 복무규정」 제18조제1항·제2항에 따른 병가

1) 임용권자의 업무대행 인사명령(지정 명령)에 업무대행기간이 명시된 경우를 전제로 함

2) 임용제청권자를 포함하며, 이하 같음

또는 같은 규정 제20조제2항·제10항에 따른 특별휴가를 가는 경우, 시간선택제전환공무원으로 지정된 경우 등에 해당하면 그 공무원의 업무를 대행하기 위하여 시간선택제임기제공무원 등을 채용할 수 있다고 규정하면서(본문), 예외적으로 소속 공무원에게 휴직을 하거나 휴가를 가는 공무원 또는 시간선택제전환공무원의 업무를 대행하도록 명한 경우에는 그렇지 않다고 규정(단서)하고 있는데, 「국가공무원법」 제71조제1항·제2항에 따른 휴직을 하는 경우에는 같은 법 제72조에 따라 휴직의 종류에 따라 휴직 기간이 정해져 있고, 「국가공무원 복무규정」 제18조에 따른 병가나 같은 규정 제20조에 따른 특별휴가를 가는 경우 및 「공무원임용령」 제57조의3에 따른 시간선택제전환공무원으로 지정되는 경우에도 모두 일정한 기간을 정하여 병가·특별휴가를 가거나 시간선택제전환공무원으로 지정³⁾하도록 규정하고 있습니다.

이와 같은 규정들을 종합하여 보면 「공무원임용령」 제57조의4제1항에 따른 업무대행 제도는 공무원의 휴직이나 시간선택제근무 전환 등에 따라 발생하는 일정한 기간의 업무 공백을 해소하기 위한 제도로서, 「공무원임용령」 제57조의4제1항 단서에 따라 임용권자가 일정한 근무기간을 정하여 근무하는 시간선택제임기제공무원 등을 채용하거나 소속 공무원에게 그 업무를 대행하도록 명함으로써 비로소 업무를 대행하는 공무원으로서의 지위를 가지게 되는 점, 업무대행기간이 정해진 업무대행 지정 명령에 대하여 해당 기간 만료 시 업무대행기간이 자동 연장된다는 별도의 근거 규정도 없는 점 등에 비추어 보면, 「공무원임용령」 제57조의4제1항 단서에 따라 업무를 대행하는 공무원(이하 “업무대행공무원”이라 함)은 일정한 기간 동안 한시적으로 업무대행을 수행한다는 측면에서 임시적인 지위로서 업무대행 지정 명령을 받은 공무원이 업무대행기간이 만료된 후 별도의 업무대행기간 연장 명령이나 새로운 업무대행 지정 명령이 없는 경우에는 업무대행공무원으로서의 지위 또한 만료된다고 보는 것이 해당 규정의 체계와 취지에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

그리고 공무원인사관계법령에서 위임한 사항 및 그 시행에 필요한 사항을 정하고 있는 「공무원 임용규칙」(인사혁신처예규) 제115조에서는 임용권자는 업무대행공무원을 지정하는 경우 피업무대행공무원의 업무내용, 직무수행 요건 등을 종합적으로 고려해야 하고, 업무대행공무원은 실제로 업무를 대행하는 1인을 지정하는 것을 원칙으로 하되, 업무 특성상 다수인을 지정할 필요가 있는 경우에는 별도로 인원을 정하여 업무대행공무원을 지정할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 규칙 제116조에서는 임용권자는 업무대행공무원을 지정 또는 해제 명령하는 경우 피업무대행공무원, 대행기간 및 대행업무 등을 명시해야 하고, 업무대행기간의 만료, 시간선택제전환공무원의 지정 해제 등의 사유로 업무대행 필요성이

3) 「공무원 임용규칙」(인사혁신처예규) 제94조 등 참조

없어진 경우 임용권자는 그 사유가 발생한 날을 기준으로 업무대행을 해제해야 한다고 규정하고 있는바, 「공무원 임용규칙」에서는 업무대행 제도에 대하여 그 요건과 절차를 구체적으로 정하면서 업무대행 지정 명령 시 업무대행기간을 명시하도록 하고 있다는 점에서, 업무대행 명령을 받아 업무대행기간이 정해진 업무대행공무원의 경우에는 그 업무대행기간이 만료되었다면 더 이상 「공무원임용령」 제57조의4제1항 단서에 따라 업무를 대행하는 공무원에 해당한다고 보기는 어렵습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「공무원임용령」 제57조의4제1항 단서에 따른 업무를 대행하는 공무원에 해당하지 않습니다.



관계법령

공무원임용령

제57조의4(휴직자 등의 업무를 대행하는 공무원) ① 임용권자 또는 임용제청권자는 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 공무원의 업무를 대행하기 위하여 시간선택제임기제공무원 및 한시임기제공무원을 채용할 수 있다. 다만, 해당 공무원의 휴직으로 법 제43조제1항 및 제2항에 따라 결원을 보충하거나 소속 공무원에게 휴직을 하거나 휴가를 가는 공무원 또는 시간선택제전환 공무원의 업무를 대행하도록 명한 경우에는 그렇지 않다.

1. 법 제71조제1항 및 제2항에 따른 휴직을 하는 경우
2. 「국가공무원 복무규정」 제18조제1항·제2항에 따른 병가 또는 같은 규정 제20조제2항·제10항에 따른 특별휴가를 가는 경우
3. 시간선택제전환공무원으로 지정된 경우. 이 경우 그 업무를 대행하기 위하여 채용하는 시간선택제임기제공무원의 근무시간은 시간선택제전환공무원의 남은 근무시간 범위로 한정한다.

② (생략)

③ 임용권자 또는 임용제청권자는 제1항 각 호 외의 부분 단서 또는 제2항에 따라 업무를 대행하는 공무원에게 예산의 범위에서 「공무원수당 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 수당을 지급할 수 있다.

제3절 경찰·소방·국민안전

질의제목 1

▶ 안전번호 24-0864

민원인 - 길이가 2킬로미터 미만이면서 부지면적이 5천제곱미터 이상인 도로를 설치하는 도시·군계획 시설사업의 경우, 재해영향평가 협의를 요청하여야 하는 개발사업에 해당하는지 (「자연재해대책법 시행령」 별표 1 등 관련)

01 질의요지

「자연재해대책법」 제4조제1항에서는 관계행정기관의 장¹⁾은 자연재해에 영향을 미치는 행정계획을 수립·확정²⁾하거나 개발사업의 허가등³⁾을 하려는 경우에는 그 행정계획 또는 개발사업(이하 “개발계획등”이라 함)의 확정·허가등을 하기 전에 행정안전부장관과 재해영향성 검토 및 재해영향평가(이하 “재해영향평가등”이라 함)에 관한 협의(이하 “재해영향평가등의 협의”라 함)를 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제6조제1항에서는 같은 법 제5조에 따라 관계행정기관의 장이 재해영향평가등의 협의를 요청하여야 하는 개발계획등의 범위와 협의의 시기는 별표 1과 같다고 규정하고 있으며, 같은 영 별표 1 제2호가목에서는 개발사업 중 하나로 “2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조에 따른 도시·군계획 시설사업 실시계획”을 규정하면서, 같은 표 제2호의 비고 제1호 본문에서는 위 표의 개발사업 중 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위는 개별 법령에서 정하는 바에 따라 허가·승인 등을 하려는 개발사업의 부지면적이 5천제곱미터⁴⁾ 이상이거나 길이가 2킬로미터⁵⁾ 이상인 경우로 한다고 규정하고 있는바,

- 1) 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장 및 특별지방행정기관의 장을 말하며, 이하 같음
- 2) 지역·지구·단지 등의 지정을 포함하며, 이하 같음
- 3) 허가·인가·승인·면허·결정·지정 등을 말하며, 이하 같음
- 4) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위의 허가의 경우에는 같은 법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발행위허가의 규모를 초과하는 경우로 한정하며, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장설립 승인의 경우에는 1만제곱미터
- 5) 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제9조에 따른 임도 설치의 경우에는 4킬로미터

길이가 2킬로미터 미만인면서 부지면적이 5천제곱미터 이상인 도로를 설치하는 도시·군 계획시설사업⁶⁾의 경우, 재해영향평가 협의를 요청하여야 하는 개발사업에 해당하는지?

02 회답

길이가 2킬로미터 미만인면서 부지면적이 5천제곱미터 이상인 도로를 설치하는 도시·군 계획시설사업의 경우, 재해영향평가 협의를 요청하여야 하는 개발사업에 해당합니다.

03 이유

먼저 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호에서는 재해영향평가 협의 대상 개발사업을 표로 열거하면서 그 중 “국토·지역 계획 및 도시의 개발(가목)”의 한 종류로 “「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조에 따른 도시·군계획시설사업 실시계획”을 규정하고 있고, 같은 표 제2호 비고 제1호에서는 위 표의 개발사업 중 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위는 “개발사업의 부지면적이 5천제곱미터 이상이거나 길이가 2킬로미터 이상인 경우”로 한다고 규정하고 있는바, 이 때 보조사 “거나”는 일반적으로 어느 것이 선택되어도 차이가 없는 둘 이상의 일을 나열할 때 사용되므로⁷⁾, 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 비고 제1호는 부지면적이 5천제곱미터 이상인 경우와 길이가 2킬로미터 이상인 경우를 동등하게 협의 대상으로 규정하려는 것으로서, 두 가지 기준 중 어느 하나에 해당하는 개발사업은 재해영향평가 협의 대상이 된다고 해석하는 것이 문언에 부합하는 해석입니다.

또한 「자연재해대책법」에 따른 재해영향평가제도는 자연재해에 영향을 미치는 각종 개발사업으로 인한 재해 유발 요인을 조사·예측·평가하고 이에 대한 대책을 마련하는 것(제2조)으로서, 개발사업의 계획수립단계부터 사전심의기능을 강화하여 자연재해로부터 국민의 생명·신체·재산 등을 보호하기 위해 도입된 제도⁸⁾이므로, 해당 규정의 내용을 해석함에 있어서는 그 도입 취지에 맞게 재해 예방 등의 목적을 충실히 실현할 수 있는 방향으로

6) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조에 따른 도시·군계획시설사업을 말하며, 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호의 비고 제1호 단서에 해당하지 않는 사업임을 전제함

7) 국립국어원 표준국어대사전 참조

8) 법제처 2016. 5. 24. 회신 16-0047 해석례 및 2005. 1. 27. 법률 제7359호로 전부개정된 「자연재해대책법」 국회 심사보고서 참조

해석해야 할 것인데, 협의 대상 개발사업의 범위와 관련하여 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 비고 제1호와 같이 개발사업의 종류에 따라 부지면적 기준이 적용되는 경우와 길이 기준이 적용되는 경우를 구분하지 않고 “개발사업의 부지면적이 5천제곱미터 이상이거나 길이가 2킬로미터 이상인 경우”로만 규정하고 있다면, 이는 부지면적이나 길이 둘 중 어느 하나의 기준이라도 일정 규모 이상에 해당하면 재해영향평가가 필요한 경우로서 협의 대상에 포함하려는 취지로 보아야 할 것이고, 명시적 규정 없이 자연재해대책법령상 재해영향평가의 협의가 필요한 최소한의 규모 기준을 축소하여 도로를 설치하는 개발사업의 경우에 어느 하나의 기준만이 적용된다고 해석하는 것은 제도의 취지에 비추어 타당하지 않습니다.

그리고 「자연재해대책법」 제5조의2에서는 재해영향평가등의 협의를 완료한 개발계획등이 변경되는 경우에는 재해영향평가등의 협의를 다시 하여야한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제6조의2제1항에서는 재해영향평가등을 재협의하여야 하는 대상을 개발계획등의 부지면적이 30퍼센트 이상 증가하는 경우(제1호), 개발사업의 부지면적이 5만제곱미터 이상 증가하는 경우(제2호), 개발계획등에 포함된 노선의 길이, 경로등을 30퍼센트 이상 변경하는 경우(제6호) 등 각 호로 열거하면서, 이러한 “각 호의 어느 하나에 해당하는 경우”에는 협의를 다시 하여야 한다고 규정하고 있는바, 재해영향평가의 재협의의 경우에 부지면적이나 길이 기준 중 어느 하나에만 해당하더라도 그 대상으로 정하고 있는 점을 고려하면, 재해영향평가의 협의의 대상이 되는 기준도 부지면적이나 길이 둘 중 어느 하나의 기준이라도 일정 규모 이상에 해당하면 그 대상이 된다고 해석하는 것이 자연재해대책법령의 규정체계에 부합합니다.

한편 「자연재해대책법 시행령」 제6조제2항의 위임에 따라 행정안전부장관이 고시한 「재해영향평가등의 협의 실무지침」(행정안전부고시)에서는 재해영향평가 대상 지역을 면적개념과 선개념으로 구분하고⁹⁾, 소규모 재해영향평가 대상을 면적개념 사업의 경우 5천제곱미터 이상 1만제곱미터 미만으로, 선개념 사업의 경우 2킬로미터 이상 10킬로미터 미만으로 구분하여 규정¹⁰⁾하고 있으므로, 도로를 설치하는 도시·군계획시설사업과 같이 선개념 사업에 해당하는 개발사업인 경우에는 길이 기준만이 적용되어 2킬로미터 미만인 경우에는 재해영향평가 협의 대상에서 제외된다는 의견이 있습니다.

그러나 「자연재해대책법 시행령」 제6조제1항 및 별표 1에서는 재해영향평가의 협의 대상을 직접 규정하고 있고, 같은 영 제6조제2항에서는 이러한 협의 대상인 개발계획등의 특성을

9) 「재해영향평가등의 협의 실무지침」 Ⅲ. 제2장 2.3 사업 유형별 평가대상지역 설정 참조

10) 「재해영향평가등의 협의 실무지침」 Ⅳ. 제1장 사업 개요 참조

고려하여 행정계획이나 개발계획별로 중점적으로 검토·평가하여야 할 항목 및 방법 등에 관한 사항을 정하도록 한 것으로서, 자연재해대책법령에 따라 협의 대상은 정해진 것이고, 「재해영향평가등의 협의 실무지침」에서 정하는 내용은 이미 법령에 의해 정해진 협의 대상에 대해 구체적으로 평가 대상 지역을 설정하고 평가 항목 및 검토 방법을 적용하는 데 필요한 사항으로 한정된다는 점에서, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 길이 2킬로미터 미만이면서 부지면적이 5천제곱미터 이상인 도로를 설치하는 도시·군 계획시설사업의 경우, 재해영향평가 협의를 요청하여야 하는 개발사업에 해당합니다.

법령정비 권고사항

재해영향평가 협의 대상에 해당하는 개발사업의 범위를 판단할 때, 임도의 경우에만 예외적으로 면적 기준을 적용하지 않고 길이 기준만을 적용하는 것에 대하여 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호를 명확히 정비할 필요가 있습니다.



관계법령

자연재해대책법

제4조(재해영향평가등의 협의) ① 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장 및 특별지방행정기관의 장(이하 “관계행정기관의 장”이라 한다)은 자연재해에 영향을 미치는 행정계획을 수립·확정(지역·지구·단지 등의 지정을 포함한다. 이하 같다)하거나 개발사업의 허가·인가·승인·면허·결정·지정 등(이하 “허가등”이라 한다)을 하려는 경우에는 그 행정계획 또는 개발사업(이하 “개발계획등”이라 한다)의 확정·허가등을 하기 전에 행정안전부장관과 재해영향성검토 및 재해영향평가(이하 “재해영향평가등”이라 한다)에 관한 협의(이하 “재해영향평가등의 협의”라 한다)를 하여야 한다.

② ~ ⑫ (생 략)

제5조(재해영향평가등의 협의 대상) ① 제4조에 따라 재해영향평가등의 협의를 하여야 하는 개발계획등은 다음 각 호와 같다.

1. 국토·지역 계획 및 도시의 개발
- 2.·3. (생 략)
4. 교통시설의 건설
5. ~ 9. (생 략)

② (생 략)

③ 제1항에 따라 재해영향평가등의 협의를 하여야 할 개발계획등의 범위, 시기 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자연재해대책법 시행령

제6조(재해영향평가등의 협의 대상 및 협의 방법 등) ① 법 제5조에 따라 관계행정기관의 장이 재해영향평가등의 협의를 요청하여야 하는 개발계획등의 범위와 협의 시기는 별표 1과 같다. (단서 생략)

1.·2. (생 략)

② (생 략)

[별표 1]

재해영향평가등의 협의 대상 행정계획 및 개발사업의 범위 및 협의 시기

(제6조제1항 관련)

1. 행정계획

(생 략)

2. 개발사업

구분	대상 개발사업	협의 시기
가. 국토·지역 계획 및 도시의 개발	1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조(제1항제4호 및 제5호는 제외한다)에 따른 개발행위의 허가	개발행위 허가 전
	2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조에 따른 도시·군계획시설사업 실시계획	실시계획 인가 전
	3) ~ 21) (생 략)	(생 략)
나. ~ 아.	(생 략)	(생 략)

(생 략)

비고

1. 위 표의 개발사업 중 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위는 개별 법령에서 정하는 바에 따라 허가·승인 등을 하려는 개발사업의 부지면적이 5천제곱미터(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위의 허가의 경우에는 같은 법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발행위허가의 규모를 초과하는 경우로 한정하며, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장설립 승인의 경우에는 1만제곱미터) 이상이거나 길이가 2킬로미터(「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제9조에 따른 임도 설치의 경우에는 4킬로미터) 이상인 경우로 한다. 다만, 개발사업 부지의 전부가 법 제12조에 따른 자연재해위험개선지구 또는 법 제25조의3에 따른 해일위험지구에 포함되는 경우에는 모든 대상 개발사업에 대하여 재해영향평가 협의를 하여야 한다.

2. ~ 4. (생 략)

질의제목 2

▶ 안전번호 25-0011

경찰청 - 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제19조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 화약류를 적재·운반만 하는 경우, 같은 조에 따른 취급 금지 규정이 적용되는지(「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제19조 등 관련)

01 질의요지

「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」(이하 “총포화약법”이라 함) 제19조 본문에서는 18세 미만인 자¹⁾ 등 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁을 취급하여서는 아니 되며, 누구든지 그들에게 이를 취급하게 하여서는 아니 된다고 규정하면서, “취급” 뒤에 괄호를 두어 “제조·판매·수수·적재·운반·저장·소지·사용·폐기 등을 말한다”고 규정하고 있는바,

총포화약법 제19조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 화약류를 적재·운반만 하는 경우에 대해서도 같은 조에 따른 취급 금지 규정이 적용되는지?²⁾

02 회답

총포화약법 제19조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 화약류를 적재·운반만 하는 경우에 대해서도 같은 조에 따른 취급 금지 규정이 적용됩니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데³⁾, 총포화약법 제19조

- 1) 대한체육회장이거나 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도의 체육회장이 추천한 선수 또는 후보자가 사격경기용 총포나 석궁을 소지하는 경우는 제외함
- 2) 총포화약법 제3조에 따라 같은 법 제19조의 적용이 배제되는 화약류에 해당하지 않는 경우를 전제함
- 3) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

본문에서는 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 화약류를 취급(제조·판매·수수·적재·운반·저장·소지·사용·폐기 등을 말함)하여서는 아니 되며, 누구든지 그들에게 이를 취급하게 하여서는 아니 된다고 규정하고 있는바, “취급” 뒤에 괄호를 두어 제조·판매·수수·적재·운반·저장·소지·사용·폐기 등을 말한다고 명시하고 있고, ‘가운뎃점(.)’은 열거된 여러 단위가 대등하거나 밀접한 관계임을 나타낼 때 사용하는 문장부호⁴⁾라는 점을 고려하면, 총포화약법 제19조에 따라 금지되는 화약류 “취급”의 범위에 화약류 “적재·운반”이 포함되는 것이 분명하고, 별도로 제조·판매·수수·적재·운반·저장·소지·사용·폐기를 모두 행하는 경우나 화약류 사용 등 특정 행위를 한 경우에만 같은 규정이 적용되도록 한정하고 있지 않으므로, 열거된 것 중 하나의 행위만 한 경우에도 “취급”에 해당되어 화약류를 적재·운반하는 경우에 대해서도 총포화약법 제19조 본문이 적용되는 것이 문언상 명확하다고 할 것입니다.

그리고 총포화약법은 총포, 도검, 화약류 등으로 인한 위험과 재해를 미리 방지함으로써 공공의 안전을 유지하는 데 이바지함을 목적으로 제정된 법률(제1조)로, 같은 법 제19조에 총포·도검·화약류 등의 취급 금지 규정을 두어, 18세 미만인 자⁵⁾, 심신상실자, 마약·대마·향정신성의약품 또는 알코올 중독자⁶⁾, 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함함) 면제된 날부터 5년이 지나지 않은 자⁷⁾ 등에 대하여 화약류 등의 취급을 금지하고 있는데, 같은 법 제19조에 따른 “취급”에 관한 입법연혁을 살펴보면, 구 「총포화약류단속법」⁸⁾ 제13조에서는 총포, 화약류를 취급할 수 없다고만 규정하여 “취급”에 대해 별도로 설명하고 있지 않던 것을, 화약류의 제조·판매·저장·운반 기타의 취급에 따른 기술적 규제 등을 강화하고 재해와 사고를 미연에 방지하기 위하여⁹⁾ 1981년 1월 10일 법률 제3354호로 「총포화약류단속법」을 「총포·도검·화약류단속법」으로 전부개정하면서 같은 법 제17조(현행 총포화약법 제19조)에서 “취급” 뒤에 괄호를 두어 “취급”이란 제조·판매·수수·적재·운반·저장·사용·폐기 등을 말하는 것임을 명시하게 된 것인바, 화약류를 제조하거나 사용하는 경우 등 뿐만 아니라 화약류를 적재하거나 운반하는 과정에서 사람의 생명·재산 또는 공공의 안전을 해칠 수 있는 사고가 발생할 가능성이 있는 점을 고려할 때, 명문의 근거 없이 총포화약법 제19조에 따라 금지되는 화약류 취급의 범위를

4) 법제처 알기쉬운 법령 정비기준(2023) p.110 참조

5) 총포화약법 제19조제1호

6) 총포화약법 제19조제2호 및 제5조제3호

7) 총포화약법 제19조제3호 및 제13조제3호

8) 1981. 1. 10. 법률 제3354호로 전부개정되기 전의 것을 말함

9) 1981. 1. 10. 법률 제3354호로 전부개정된 「총포·도검·화약류단속법」 개정이유 참조

축소 해석하는 것은 화약류의 취급을 철저히 관리하려는 총포화약법의 입법 목적에 부합하지 않는 해석이라 할 것입니다.

또한 총포화약법 제26조제1항 본문에서 화약류를 운반하려는 사람은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 발송지를 관할하는 경찰서장에게 신고하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항 및 같은 법 시행령 제49조·제50조에서 화약류의 적재·운반 방법의 기술상의 기준을 구체적으로 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제38조제3항에서 경찰서장은 화약류운반 신고서를 접수한 때에는 그 운반의 일시·통로·방법 및 화약류의 성능과 적재방법 등을 검토하고 재해의 방지 또는 공공의 안전유지를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 화약류 운반의 제한 등 같은 법 제47조의 규정에 의한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있는바, 이와 같이 총포화약법령에서 화약류의 제조·사용 등 뿐만 아니라 화약류의 적재·운반의 안전관리에 관하여도 상세히 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때에도, 화약류를 적재·운반만 하는 것도 같은 법 제19조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자, 즉 일정한 결격 사유가 있는 자에게는 금지된다고 해석하여 공공의 안전을 확보하는 것이 총포화약법령의 전체적인 체계와 취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

따라서 제19조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 화약류를 적재·운반만 하는 경우에 대해서도 같은 조에 따른 취급 금지 규정이 적용됩니다.



관계법령

총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

제19조(취급 금지) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁을 취급(제조·판매·수수·적재·운반·저장·소지·사용·폐기 등을 말한다. 이하 같다)하여서는 아니 되며, 누구든지 그들에게 이를 취급하게 하여서는 아니 된다. 다만, 제6조의2제1항에 따른 총포·도검·분사기·전자충격기·석궁을 제12조제3항에 따라 해당 영화 또는 연극 등을 위하여 일시 소지하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 18세 미만인 자. 다만, 대한체육회장이나 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도의 체육회장이 추천한 선수 또는 후보자가 사격경기용 총포나 석궁을 소지하는 경우는 제외한다.
2. 제5조 각 호의 어느 하나(같은 조 제4호는 제외한다)에 해당하는 자
3. 제13조제1항제2호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 자

질의제목 3

▶ 안전번호 25-0033

민원인 - 특정소방대상물 중 운동시설에 고정식 의자 형태의 관람석이 있는 경우 수용인원 산정 방법
(「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 7 제2호나목 등 관련)

01 질의요지

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 “소방시설법”이라 함) 제12조제1항 전단에서는 특정소방대상물¹⁾의 관계인²⁾은 대통령령으로 정하는 소방시설을 화재안전기준에 따라 설치·관리하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제14조제1항에서는 같은 법 제12조제1항에 따라 대통령령으로 소방시설을 정할 때에는 특정소방대상물의 규모·용도·수용인원 및 이용자 특성 등을 고려하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제17조에서는 같은 법 제14조제1항에 따른 특정소방대상물의 수용인원은 별표 7에 따라 산정한다고 규정하면서, 같은 영 별표 7 제2호나목에서는 강당, 문화 및 집회시설, 운동시설, 종교시설의 수용인원 산정 방법을 ‘해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수(관람석이 있는 경우 고정식 의자를 설치한 부분은 그 부분의 의자 수로 하고, 긴 의자의 경우에는 의자의 정면너비를 0.45m로 나누어 얻은 수로 한다)’로 규정하고 있는바,

특정소방대상물 중 운동시설에 고정식 의자 형태의 관람석이 있는 경우³⁾, 해당 운동시설의 수용인원은 ‘해당 용도로 사용하는 바닥면적(고정식 의자를 설치한 부분 면적 제외)의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수에 고정식 의자 수를 합산’하여 산정해야 하는지, 아니면 ‘고정식 의자 수’만으로 산정해야 하는지?

02 회답

특정소방대상물 중 운동시설에 고정식 의자 형태의 관람석이 있는 경우, 해당 운동시설의 수용인원은 해당 용도로 사용하는 바닥면적(고정식 의자를 설치한 부분 면적 제외)의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수에 고정식 의자 수를 합산하여 산정해야 합니다.

1) 건축물 등의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 소방시설을 설치하여야 하는 소방대상물로서 소방시설법 시행령으로 정하는 것을 말하며(소방시설법 제2조제1항제3호 참조), 이하 같음

2) 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자를 말하며(소방시설법 제4조제1항 및 「소방기본법」 제2조제3호 참조), 이하 같음

3) 운동시설에 ‘긴 의자’는 없는 경우를 전제함

03 이유

먼저 법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적인 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 그 과정에서 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하여야 할 것⁴⁾인데, 소방시설법 시행령 별표 7 제2호나목에서는 특정소방대상물 중 운동시설의 수용인원 산정방법을 ‘해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수(관람석이 있는 경우 고정식 의자를 설치한 부분은 그 부분의 의자 수로 하고, 긴 의자의 경우에는 의자의 정면너비를 0.45m로 나누어 얻은 수로 한다)’로 규정하여, 운동시설에 관람석이 있는 경우 고정식 의자를 설치한 부분은 그 부분의 의자 수로 한다고 규정하고 있을 뿐, 운동시설의 용도로 사용하는 부분 전체에 대해 의자 수로 수용인원을 산정한다고 규정하고 있지 않고, 같은 표에서 운동시설에 관람석이 있는 경우 고정식 의자 수만으로 해당 시설의 수용인원을 산정한다는 내용을 별도로 규정하고 있지 않은바, 같은 표 제2호나목은 운동시설의 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수로 해당 시설의 수용인원을 산정하되, 고정식 의자 형태의 관람석이 있는 경우 그 부분에 한해서는 바닥면적을 4.6㎡로 나누어 수용인원을 계산하는 대신 의자 수로 수용인원을 계산하도록 하는 규정으로 해석하는 것이 문언의 통상적인 의미에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

그리고 소방시설법은 특정소방대상물 등에 설치하여야 하는 소방시설등의 설치·관리와 소방용품 성능관리에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 공공의 안전과 복리증진에 이바지함을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 소방시설법령에서는 수용인원이 100명 이상인 운동시설⁵⁾에 스프링클러설비를 설치하도록 하는 등 특정소방대상물의 규모·용도·수용인원 및 이용자 특성 등을 고려하여 특정소방대상물의 관계인이 설치해야 하는 소방시설의 종류를 구분하여 규정하고 있고(소방시설법 제12조, 제14조 및 같은 법 시행령 제11조, 별표 4 등 참조), 이러한 소방시설의 설치 기준은 국민의 생명·신체 및 재산을 충분히 보호할 수 있는 방향으로 해석해야 할 것인데, 같은 법 시행령 별표 7에 따른 특정소방대상물의 수용인원 산정 방법과 관련하여 만약 운동시설에 고정식 의자 형태의 관람석이 있을 때에는 고정식 의자 수로만 그 수용인원을 산정한다고 해석한다면, 해당 운동시설에 고정식 의자 형태의 관람석 외에도 운동을 하거나 의자 없이 관람할 수 있는 공간 등이 있어 사람을 추가로 수용할 수 있음에도 불구하고 고정식 의자 수만큼의 인원만 해당

4) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

5) 물놀이형 시설 및 바닥이 불연재료이고 관람석이 없는 운동시설은 제외함(소방시설법 시행령 별표 4 제1호라목 참조)

운동시설의 수용인원으로 산정하게 되어 해당 운동시설이 소방시설(스프링클러설비) 설치 대상에서 제외되는 결과가 초래될 수 있는바, 그러한 해석은 소방시설의 적절한 설치를 통해 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하려는 소방시설법령의 입법취지에 비추어 보면 타당하지 않습니다.

따라서 특정소방대상물 중 운동시설에 고정식 의자 형태의 관람석이 있는 경우, 해당 운동시설의 수용인원은 해당 용도로 사용하는 바닥면적(고정식 의자를 설치한 부분 면적 제외)의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수에 고정식 의자 수를 합산하여 산정해야 합니다.



관계법령

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률

제12조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등) ① 특정소방대상물의 관계인은 대통령령으로 정하는 소방시설을 화재안전기준에 따라 설치·관리하여야 한다. 이 경우 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 장애인등이 사용하는 소방시설(경보설비 및 피난구조설비를 말한다)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인등에 적합하게 설치·관리하여야 한다.

② ~ ⑦ (생략)

제14조(특정소방대상물별로 설치하여야 하는 소방시설의 정비 등) ① 제12조제1항에 따라 대통령령으로 소방시설을 정할 때에는 특정소방대상물의 규모·용도·수용인원 및 이용자 특성 등을 고려하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령

제11조(특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설) ① 법 제12조제1항 전단에 따라 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류는 별표 4와 같다.

② (생략)

제17조(특정소방대상물의 수용인원 산정) 법 제14조제1항에 따른 특정소방대상물의 수용인원은 별표 7에 따라 산정한다.

[별표 4]

특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

(제11조 관련)

1. 소화설비

가. ~ 다. (생략)

라. 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물(위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 및 지하구는 제외한다)은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

1)·2) (생략)

3) 문화 및 집회시설(동·식물원은 제외한다), 종교시설(주요구조부가 목조인 것은 제외한다), 운동시설(물놀이형 시설 및 바닥이 불연재료이고 관람석이 없는 운동시설은 제외한다)로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 모든 층

가) 수용인원이 100명 이상인 것

나) ~ 라) (생략)

4) ~ 14) (생략)

2. ~ 5. (생략)

[별표 7]

수용인원의 산정 방법(제17조 관련)

1. (생략)

2. 제1호 외의 특정소방대상물

가. (생략)

나. 강당, 문화 및 집회시설, 운동시설, 종교시설: 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 4.6㎡로 나누어 얻은 수(관람석이 있는 경우 고정식 의자를 설치한 부분은 그 부분의 의자 수로 하고, 긴 의자의 경우에는 의자의 정면너비를 0.45m로 나누어 얻은 수로 한다)

다. (생략)

비고

1. (생략)

2. 계산 결과 소수점 이하의 수는 반올림한다.

질의제목 4

▶ 안전번호 25-0235

민원인 - 주유취급소의 캐노피를 증설하는 경우가 「위험물안전관리법」 제6조제1항 후단에 따른 변경허가의 대상인지(「위험물안전관리법」 제6조제1항 및 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 1의2 등 관련)

01 질의요지

「위험물안전관리법」(이하 “위험물관리법”이라 함) 제6조제1항 전단에서는 제조소등¹⁾을 설치하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 바에 따라 그 설치장소를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 함)의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 후단에서는 제조소등의 위치·구조 또는 설비 가운데 행정안전부령이 정하는 사항을 변경하고자 하는 때에도 또한 같다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제8조 및 별표 1의2에서는 제조소등의 변경허가를 받아야 하는 경우를 정하면서 같은 표 제10호마목에서는 주유취급소의 경우, “건축물의 벽·기둥·바닥·보 또는 지붕을 증설 또는 철거하는 경우”를, 같은 호 바목에서는 “담 또는 캐노피(기둥으로 받치거나 매달아 놓은 덮개)를 신설 또는 철거(유리를 부착하기 위하여 담의 일부를 철거하는 경우를 포함한다)하는 경우”를 규정하고 있는바,

주유취급소의 캐노피를 증설하는 경우가 「위험물안전관리법 시행규칙」(이하 “위험물관리법 시행규칙”이라 함) 별표 1의2 제10호마목에 따른 건축물의 지붕을 증설하는 경우에 해당하여, 위험물관리법 제6조제1항 후단에 따른 변경허가의 대상이 되는지²⁾

02 회답

주유취급소의 캐노피를 증설하는 경우는 위험물관리법 시행규칙 별표 1의2 제10호마목에 해당하지 않으므로, 위험물관리법 제6조제1항 후단에 따른 변경허가의 대상이 아닙니다.

1) 제조소·저장소 및 취급소를 말하며(위험물관리법 제2조제1항제6호 참조), 이하 같음

2) 위험물관리법 시행규칙 별표 1의2 제10호 다목·라목·파목 등 다른 목에 따른 변경사항은 없는 경우를 전제로 함

03 이유

법 해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 그러기 위해서는 가능한 한 법령에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하면서도, 법령의 입법 취지와 연혁 및 다른 법령과의 관계 등을 고려한 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원하여 타당한 해석을 하여야 할 것인바³⁾, 주유취급소의 캐노피를 증설하는 경우가 위험물관리법 시행규칙 별표 1의2 제10호마목에 따른 건축물의 지붕을 증설하는 경우에 해당하는지를 판단하기 위해서는 해당 법령의 규정 체계, 입법 취지와 연혁, 규율 대상 등을 종합적으로 살펴보아야 합니다.

먼저 위험물관리법 시행규칙 별표 1의2 제10호에서는 주유취급소의 변경허가 대상으로 “건축물의 벽·기둥·바닥·보 또는 지붕을 증설 또는 철거하는 경우(마목)”와 “담 또는 캐노피를 신설 또는 철거하는 경우(바목)”를 구분하여 규정하고 있고, 같은 규칙 별표 13에서는 주유취급소의 위치·구조 및 설비의 기준을 표지 및 계시판, 탱크, 고정주유설비, 건축물, 담 또는 벽, 캐노피 등 설치 대상별로 나누어 규정하면서, 건축물의 설치 시 준수해야 하는 기준(V·VI)과 캐노피의 설치 시 준수해야 하는 기준(VIII)을 구분하여 규정하고 있으며, 그 기준의 내용에 있어서도 건축물의 경우에는 벽·기둥·바닥·보 및 지붕을 내화구조 또는 불연재료로 할 것⁴⁾ 등을 규정하고 있는데 반해, 캐노피의 경우에는 캐노피 외부의 배관이 일광열의 영향을 받을 우려가 있는 경우 단열재로 피복할 것⁵⁾ 등을 규정하여 양자 간 차이를 두고 있는바, 캐노피를 증설하는 경우는 같은 규칙 별표 1의2 제10호마목에 따른 건축물의 지붕을 증설하는 경우와는 구분되는 별개의 변경사항이라고 보는 것이 건축물과 캐노피를 별도로 규정하고 있는 해당 법령의 규정 체계에 부합합니다.

그리고 행정처분 외에 형벌까지 부과되는 경우 관련 규정의 해석은 엄격하여야 하고, 명문규정의 의미를 당사자에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석하는 것은 죄형법정주의 원칙에 어긋나는 것으로서 허용되지 않는다고 할 것⁶⁾인데, 위험물관리법 제6조제1항 후단에 따른 변경허가를 받지 아니하고 제조소등의 위치·구조 또는 설비를 변경한 자는 허가의 취소나 사용정지 명령(제12조제1호), 1천500만원 이하의 벌금(제36조제2호) 부과 대상이 되는바, 위험물관리법 시행규칙 별표 1의2 제10호바목에서 캐노피의 변경

3) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 판결례 참조

4) 위험물관리법 시행규칙 별표 13 VI 제1호가목 1) 본문 참조

5) 위험물관리법 시행규칙 별표 13 VIII 다목 참조

6) 대법원 2005. 11. 24. 선고 2004도4758 판결례 등 참조

사항 중 변경허가를 받아야 하는 대상을 캐노피를 “신설 또는 철거”하는 경우로만 한정하여 규정하고 있는 경우, 법령의 명시적인 근거 없이 캐노피를 “증설”하는 경우가 같은 규칙 별표 1의2 제10호마목에 따른 건축물의 지붕 등을 증설하는 경우에 해당하여 변경허가의 대상이 된다고 해석하는 것은 명문규정의 의미를 당사자에게 불리한 방향으로 확장해석하는 것으로서 타당하지 않다고 할 것입니다.

아울러 위험물관리법 시행규칙 별표 1의2의 입법연혁을 살펴보면, 별표 1의2의 신설 당시⁷⁾부터 제10호에서는 “건축물의 벽·기둥·바닥·보 또는 지붕을 신설·증설·교체 또는 철거하는 경우(마목)”와 “캐노피를 신설 또는 철거하는 경우(바목)”를 구분하여 규정하고 있었는데, 만일 캐노피의 경우에도 같은 호 마목에 따른 건축물의 지붕과 동일하게 증설이나 교체에 대해서도 해당 규제를 적용하려는 취지가 있었다면 같은 호 마목과 바목을 별도로 구분하여 규정할 필요가 없었을 것이므로, 이와 같이 규정한 것은 캐노피의 경우 신설·철거 시에만 변경허가를 받도록 하기 위한 것으로 보이는 점, 같은 법 제31조제2호에 따르면 같은 법 제6조제1항에 따른 제조소등의 설치 또는 변경의 허가를 받으려는 자는 일정 금액의 수수료를 납부하여야 하는데, 같은 별표의 신설 당시에는 제10호마목에서 “건축물의 벽·기둥·바닥·보 또는 지붕을 신설·증설·교체 또는 철거하는 경우”를 변경허가 대상으로 규정하였던 것을, 2009년 9월 15일 행정안전부령 제105호로 일부개정된 위험물관리법 시행규칙 별표 1의2 제10호마목에서 “건축물의 벽·기둥·바닥·보 또는 지붕을 증설 또는 철거하는 경우”로 개정하여 변경허가의 대상 범위를 축소⁸⁾한바 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 주유취급소의 캐노피를 증설하는 경우는 위험물관리법 시행규칙 별표 1의2 제10호마목에 해당하지 않으므로, 위험물관리법 제6조제1항 후단에 따른 변경허가의 대상이 아닙니다.

7) 2006. 8. 3. 행정자치부령 제340호로 일부개정된 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 1의2 제10호마목 참조

8) 2009. 9. 15. 행정안전부령 제105호로 일부개정된 「위험물안전관리법 시행규칙」 개정이유 및 주요내용 참조



관계법령

위험물안전관리법

제6조(위험물시설의 설치 및 변경 등) ① 제조소등을 설치하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 바에 따라 그 설치장소를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)의 허가를 받아야 한다. 제조소등의 위치·구조 또는 설비 가운데 행정안전부령이 정하는 사항을 변경하고자 하는 때에도 또한 같다.

②·③ (생 략)

위험물안전관리법 시행규칙

제8조(제조소등의 변경허가를 받아야 하는 경우) 법 제6조제1항 후단에서 “행정안전부령이 정하는 사항”이라 함은 별표 1의2에 따른 사항을 말한다.

[별표 1의2]

제조소등의 변경허가를 받아야 하는 경우(제8조 관련)

제조소등의 구분	변경허가를 받아야 하는 경우
1. ~ 9. (생 략)	
10. 주유 취급소	가. ~ 라. (생 략) 마. 건축물의 벽·기둥·바닥·보 또는 지붕을 증설 또는 철거하는 경우 바. 담 또는 캐노피(기둥으로 받치거나 매달아 놓은 덮개)를 신설 또는 철거(유리를 부착하기 위하여 담의 일부를 철거하는 경우를 포함한다)하는 경우 사. ~ 하. (생 략)
11.·12. (생 략)	

질의제목 5

▶ 안전번호 25-0268

해양경찰청 - 「유선 및 도선 사업법」 제24조의2제1항에 따른 비상상황 대비훈련 실시 대상 유·도선의 범위(「유선 및 도선 사업법」 제24조의2제1항 등 관련)

01 질의요지

「유선 및 도선 사업법」(이하 “유·도선법”이라 함) 제24조의2제1항에서는 유·도선사업자는 유·도선에 승선하는 같은 항 각 호의 사람(「선원법」 제15조제1항에 따라 비상시에 대비한 훈련을 받은 사람은 제외함)에 대하여 비상상황 대비훈련(이하 “유·도선법 제24조의2제1항에 따른 비상훈련”이라 함)을 실시하여야 한다고 규정하고 있는 한편,

「선원법」 제15조제1항에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박의 선장은 선박에 있는 사람에게 소방훈련, 구명정훈련 등 비상시에 대비한 훈련(이하 “「선원법」 제15조제1항에 따른 비상훈련”이라 함)을 실시하여야 한다고 규정하고 있는바,

유·도선법 제24조의2제1항에 따른 비상훈련 실시 대상 유·도선에는 「선원법」 제15조제1항 각 호에 따른 선박¹⁾이 포함되는지?

02 회답

유·도선법 제24조의2제1항에 따른 비상훈련 실시 대상 유·도선에는 「선원법」 제15조제1항 각 호에 따른 선박이 포함됩니다.

03 이유

먼저 유·도선법 제24조의2제1항에서는 유·도선사업자는 유·도선에 승선하는 선원 및 그 밖의 종사자 등 같은 항 각 호의 사람에 대하여 비상훈련을 실시하여야 한다고 규정하면서,

1) 「선원법」 제15조제1항 각 호에 따른 선박 중 유·도선법의 적용을 받는 유·도선만을 의미하는 것으로 전제함

각 호의 사람 뒤에 괄호를 두어 「선원법」 제15조제1항에 따른 비상훈련을 ‘받은 사람’은 비상훈련 실시 대상에서 제외한다고 규정하고 있고, 「선원법」 제15조제1항에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박에 있는 사람을 비상훈련 실시 대상으로 규정하고 있는바, 이를 종합하여 보면 「선원법」 제15조제1항 각 호에 따른 선박에 승선하는 선원 및 그 밖의 종사자의 경우에는 「선원법」 제15조제1항에 따른 비상훈련을 받았는지 여부를 확인하여, 이를 이미 ‘받은 사람’에 대해서는 유·도선법 제24조의2제1항에 따른 비상훈련을 추가적으로 실시하지 않아도 되도록 하고, 「선원법」 제15조제1항에 따른 비상훈련을 ‘받지 아니한 사람’에 대해서는 그가 승선하는 선박이 「선원법」 제15조제1항 각 호에 따른 선박이라 하더라도 유·도선법 제24조의2제1항에 따른 비상훈련 실시 대상에서 제외되는 것으로 보기는 어렵다고 할 것입니다.

그리고 유·도선법에 따른 비상훈련과 「선원법」에 따른 비상훈련의 실시 주체, 대상 및 종류 등을 비교하여 보면, 유·도선법 제24조의2제1항에서는 ‘유·도선사업자’가 ‘선원 및 그 밖의 종사자’에 대하여 훈련을 실시하도록 규정하고 있는 반면, 「선원법」 제15조제1항에서는 ‘선장’이 같은 항 각 호에 따른 ‘선박에 있는 사람’에 대하여 훈련을 실시하도록 규정하고 있고, 유·도선법 제24조의2의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제19조의2제1항 및 별표 4에서는 비상훈련의 내용을 선내숙지 훈련, 퇴선 훈련, 기름유출대응, 소화훈련, 인명구조, 추락 및 충돌·좌초사고대응 훈련, 침수 및 추진기관 사고대응 훈련 등으로 세분화하고 그 실시 주기를 매월 또는 6개월로 규정하고 있는 반면, 「선원법」 제15조의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제7조제2항에서는 소방훈련·구명정훈련 등의 비상훈련을 매월 1회(여객선의 경우에는 10일, 국내항과 외국항을 운항하는 여객선은 7일마다) 실시하도록 규정하고 있는 등 두 법률에 따른 비상훈련은 실시 주체 및 대상, 실시 주기 등 여러 사항에서 차이가 있는바, 유·도선법과 「선원법」은 그 입법목적이 서로 다르고, 두 법률 간의 적용관계에 대하여 명시적으로 규정하고 있지 않아 어느 한 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 볼 수 없다는 점을 고려하면, 유·도선에 대해서는 두 법률이 모두 적용되는 것이므로²⁾, 「선원법」 제15조제1항 각 호에 따른 선박이라 하더라도 해당 선박이 유·도선법의 적용을 받는 유·도선인 경우에는 유·도선법 제24조의2제1항에 따른 비상훈련 실시 대상 유·도선에서 제외된다고 볼 수는 없습니다.

또한 유·도선법의 적용을 받는 유·도선에는 「선원법」의 적용을 받지 않는 호수, 강 또는 항내(港內)만을 항행하는 선박(같은 법 제3조제1항제2호)이나 「선박안전법」의 적용을 받지

2) 대법원 1995. 1. 12. 선고 94누3216 판결례, 법제처 2021. 9. 8. 회신 21-0335 해석례 참조

않는 노, 상앗대, 페달 등을 이용하여 인력만으로 운전하는 선박(같은 법 제3조제1항제2호) 등이 포함될 수 있고, 「선원법」이나 「선박안전법」의 적용을 받는 선박에는 유·도선법의 적용을 받지 않는 선박도 포함될 수 있는 등 각각의 법률은 적용 범위에서 차이가 있는데, 유·도선법 제11조 및 제20조에서는 유·도선 중 「선박안전법」을 적용받지 아니하는 유·도선에 대하여 승선 정원 및 안전검사를 규정하고 있는 등 유·도선법에서는 필요한 경우 해당 규정의 적용 대상이 되는 유·도선의 범위를 「선박안전법」의 적용을 받지 아니하는 유·도선」으로 명시적으로 제한하여 규정하고 있는 반면, 유·도선법 제24조의2제1항에서는 이러한 제한 없이 ‘유·도선」으로만 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 같은 법 제24조의2제1항은 유·도선법의 적용을 받는 모든 유·도선에 대하여 비상훈련을 실시하도록 한 것이라고 해석하는 것이 유·도선법의 규정 체계 및 관련 법률과의 관계에도 부합하는 해석입니다.

따라서 유·도선법 제24조의2제1항에 따른 비상훈련 실시 대상 유·도선에는 「선원법」 제15조제1항 각 호에 따른 선박이 포함됩니다.



관계법령

유선 및 도선 사업법

제24조의2(선원 등의 비상상황 대비훈련) ① 유·도선사업자는 유·도선에 승선하는 다음 각 호의 사람(「선원법」 제15조제1항에 따라 비상시에 대비한 훈련을 받은 사람은 제외한다)에 대하여 비상상황 대비훈련을 실시하여야 한다.

1. 선원
 2. 그 밖의 종사자
- ② (생략)

선원법

제15조(비상배치표 및 훈련 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박의 선장은 비상시에 조치하여야 할 해원의 임무를 정한 비상배치표를 선내의 보기 쉬운 곳에 걸어두고 선박에 있는 사람에게 소방훈련, 구명정훈련 등 비상시에 대비한 훈련을 실시하여야 한다. 이 경우 해원은 비상배치표에 명시된 임무대로 훈련에 임하여야 한다.

1. 총톤수 500톤 이상의 선박. 다만, 평수구역을 항행구역으로 하는 선박을 제외한다.
 2. 「선박안전법」 제2조제10호에 따른 여객선(이하 “여객선”이라 한다)
- ② ~ ④ (생략)

질의제목 6

▶ 안전번호 25-0273

민원인 - 「경찰공무원법」 제13조에 따른 시보임용이 예정된 사람을 대상으로 하여 실시하는 신임교육훈련을 이수한 기간이 「청원경찰법 시행령」 제11조제1항에 따른 보수 산정시의 경력에 산입되는지(「청원경찰법 시행령」 제11조제1항 등 관련)

01 질의요지

「청원경찰법 시행령」 제11조제1항에서는 청원경찰의 보수산정에 관하여 그 배치된 사업장의 취업규칙에 특별한 규정이 없는 경우에는 같은 항 각 호의 경력을 봉급 산정의 기준이 되는 경력에 산입하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 제4호에서는 국가기관 또는 지방자치단체에서 근무하는 청원경찰에 대해서는 국가기관 또는 지방자치단체에서 상근으로 근무한 경력을 규정하고 있는 한편,

「경찰공무원 임용령」 제21조, 「경찰공무원 교육훈련규정」 제4조제2항 및 별표 1에서는 「경찰공무원법」 제13조에 따른 시보임용(이하 “시보임용”이라 함)이 예정된 사람을 대상으로 하여 신임교육훈련을 실시할 수 있도록 규정하고 있는바,

시보임용이 예정된 사람을 대상으로 하여 「경찰공무원 교육훈련규정」 제4조제2항 및 별표 1에 따라 실시하는 신임교육훈련을 이수한 기간이 「청원경찰법 시행령」 제11조제1항제4호에 따른 “국가기관에서 상근으로 근무한 경력”에 해당되는지?

02 회답

시보임용이 예정된 사람을 대상으로 하여 「경찰공무원 교육훈련규정」 제4조제2항 및 별표 1에 따라 실시하는 신임교육훈련을 이수한 기간은 「청원경찰법 시행령」 제11조제1항제4호에 따른 “국가기관에서 상근으로 근무한 경력”에 해당되지 않습니다.

03 이유

먼저 「청원경찰법 시행령」 제11조제1항제4호에서는 청원경찰의 보수 산정에 관하여 봉급 산정의 기준이 경력에 산입되는 경력 중 하나로 국가기관 또는 지방자치단체에 근무하는 청원경찰에 대해서는 국가기관 또는 지방자치단체에서 상근으로 근무한 경력을 규정하고 있는데, “국가기관 또는 지방자치단체에서 상근으로 근무한 경력”은 그 문언체계상 일정한 절차에 따라 공무원 또는 그 밖의 직원으로 임용 또는 채용되어 상시적·계속적인 근로관계에 기초하여 복무 또는 근무하는 경우를 의미한다고 보는 것이 상당하다고 할 것¹⁾입니다.

그런데 「경찰공무원법」에 따르면 경찰청장 또는 해양경찰청장은 신규채용시험에 합격한 사람을 성적 순위에 따라 채용후보자 명부에 등재하도록 하면서, 경찰공무원의 신규채용은 채용후보자 명부의 등재 순위에 따르도록 규정하고 있고(제12조), 경정 이하의 경찰공무원을 신규 채용할 때에는 1년간 시보(試補)로 임용하고 그 기간이 만료된 다음 날에 정규 경찰공무원으로 임용하도록 규정하고(제13조) 있으므로, 경찰공무원의 신규채용시험에 합격한 사람은 채용후보자 지위를 거쳐 시보임용 후 정규 경찰공무원으로 임용되게 됩니다.

그렇다면 「경찰공무원법」에 따라 시보임용 전 채용후보자라는 지위는 시보임용이 예정된 사람을 의미하는 것으로서, 일정한 절차에 따라 공무원 또는 그 밖의 직원으로 임용 또는 채용되어 상시적·계속적인 근로관계에 기초하여 복무 또는 근무하는 경우라고 보기는 어려우므로, 경찰공무원으로 임용될 사람에 대한 교육훈련을 관장하는 경찰교육훈련기관에서 시보임용이 예정된 사람을 대상으로 하여 「경찰공무원 교육훈련규정」 제4조제2항 및 별표 1에 따라 실시하는 신입교육훈련을 채용후보자의 지위에서 수료한 기간은 「청원경찰법 시행령」 제11조제1항제4호에 따른 “국가기관 또는 지방자치단체에서 상근으로 근무한 경력”에 포함되는 것으로 볼 수는 없다고 할 것입니다.

그리고 「청원경찰법 시행령」 제11조제1항에 따른 보수 산정시의 유사경력 인정 규정은 입법정책적 측면에서 청원경찰로 임용되기 전의 동일하거나 유사한 경력을 청원경찰로서의 경력으로 인정하여 그 보수를 지급할 수 있도록 하는 예외적 성격의 규정으로서 해당 규정은 제한적으로 해석하는 것이 타당하다고 할 것²⁾이므로, 실제 경찰의 업무에 종사하지 않은 채 경찰공무원으로 임용되기 전에 받은 교육기간까지 “상근으로 근무한 경력”에 포함된다고 보기는 어렵습니다.

1) 법제처 2013. 12. 16. 회신 13-0525 해석례 참조

2) 법제처 2013. 12. 16. 회신 13-0525 해석례 참조

한편 「공무원보수규정」 별표 16 제2호나목3)에서는 공무원의 보수와 관련하여 일반직 공무원 등의 경력환산 시 국가 및 지방자치단체 등 근무경력에 대하여 시보임용 전 이수한 교육훈련 경력 중 인사혁신처장이 인정하는 경력은 100퍼센트 인정한다고 규정하고 있고, 「2025 공무원보수 등의 업무지침」(인사혁신처예규)에서는 해당 경력을 “임용예정직급에 상응하는 교육훈련을 이수하고 해당직급에 임용된 경우의 시보임용 전 교육 훈련경력”으로 명시하고 있는바, 이에 따르면 시보임용이 예정된 사람을 대상으로 하여 「경찰공무원 교육훈련규정」 제4조2항 및 별표 1에 따라 실시하는 신입교육훈련이 경찰공무원으로서의 경력에 산입되므로 이를 청원경찰의 봉급 산정의 기준이 되는 경력 중 “국가기관 또는 지방자치단체에서 상근으로 근무한 경력”에 해당되는 것으로 볼 수 있다는 의견이 있습니다.

그러나 「청원경찰법 시행령」 제11조제1항은 예외적으로 청원경찰의 봉급 산정 시 산입해야 할 근무경력을 정한 것으로서 해당 규정은 제한적으로 해석해야 한다는 점, 경찰공무원의 시보임용 전 교육훈련 경력의 경력 산입은 경찰공무원의 보수산정을 위한 경력 산입의 기준일 뿐 경찰공무원과는 다른 지위를 갖는 청원경찰의 보수 산정 기준에 그대로 적용할 수는 없다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 시보임용이 예정된 사람을 대상으로 하여 「경찰공무원 교육훈련규정」 제4조제2항 및 별표 1에 따라 실시하는 신입교육훈련을 이수한 기간은 「청원경찰법 시행령」 제11조제1항제4호에 따른 “국가기관에서 상근으로 근무한 경력”에 해당되지 않습니다.



관계법령

청원경찰법 시행령

제11조(보수 산정 시의 경력 인정 등) ① 청원경찰의 보수 산정에 관하여 그 배치된 사업장의 취업규칙에 특별한 규정이 없는 경우에는 다음 각 호의 경력을 봉급 산정의 기준이 되는 경력에 산입(算入)하여야 한다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 국가기관 또는 지방자치단체에서 근무하는 청원경찰에 대해서는 국가기관 또는 지방자치단체에서 상근(常勤)으로 근무한 경력

②·③ (생 략)

질의제목 7

▶ 안전번호 25-0280

소방청 - 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」 제2조제2호가목의 요건의 판단 기준(「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」 제2조제2호가목 등 관련)

01 질의요지

「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」(이하 “초고층재난관리법”이라 함) 제2조제2호 본문에서는 “지하연계 복합건축물”이란 지하부분이 지하역사 또는 지하도상가와 연결된 건축물로서 같은 호 각 목의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다고 규정하고 있고, 같은 호 가목에서는 층수가 11층 이상이거나 용도별 바닥면적 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 산정기준(이하 “산정기준”이라 함)에 따른 수용인원이 5천명 이상인 건축물을 규정하고 있는바,

① 층수가 11층 이상이면서 산정기준에 따른 수용인원이 5천명 미만인 건축물 및 ② 층수가 11층 미만이면서 산정기준에 따른 수용인원이 5천명 이상인 건축물의 경우¹⁾, 초고층재난관리법 제2조제2호의 “지하연계 복합건축물”에 해당하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 초고층재난관리법 제2조제2호의 “지하연계 복합건축물”에 해당합니다.

03 이유

먼저 초고층재난관리법 제2조제2호 본문에서는 “지하연계 복합건축물”이란 지하부분이 지하역사 또는 지하도상가와 연결된 건축물로서 같은 호 각 목의 요건을 모두 갖춘 것을

1) 지하부분이 지하역사 또는 지하도상가와 연결된 건축물로서, 초고층재난관리법 제2조제2호나목의 요건을 갖춘 건축물이고, 같은 법 제2조제2호 단서의 건축물(화재 발생 시 열과 연기의 배출이 쉬운 구조를 갖춘 건축물로서 같은 법 시행령 제2조제1항에 따른 건축물)에 해당하지 않는 경우를 전제함

말한다고 규정하면서, 같은 호 가목에서는 층수가 11층 이상이거나 산정기준에 따른 수용인원이 5천명 이상인 건축물을 규정하고 있는데, “거나”는 어느 것이 선택되어도 차이가 없는 둘 이상의 일을 나열할 때 쓰는 보조사로서²⁾, 부사인 “또는”과 동일한 의미로 사용된다는 점³⁾, 만약 지하연계 복합건축물이 “층수가 11층 이상”인 요건과 “산정기준에 따른 수용인원이 5천명 이상”인 요건을 모두 충족해야 한다는 취지였다면, 같은 호 가목에서 “그리고”의 의미를 갖는 “~과” 등의 표현⁴⁾을 사용했을 것이라는 점 등을 고려하면, 문언상 초고층재난관리법 제2조제2호가목의 층수가 11층 이상이거나 산정기준에 따른 수용인원이 5천명 이상인 건축물은 층수가 11층 이상인 건축물 “또는” 산정기준에 따른 수용인원이 5천명 이상인 건축물을 의미한다고 할 것입니다.

그리고 초고층재난관리법은 초고층 및 지하연계 복합건축물과 그 주변지역의 재난관리를 위하여 재난의 예방·대비·대응 및 지원 등에 필요한 사항을 정하여 재난관리체제를 확립함으로써 국민의 생명, 신체, 재산을 보호하고 공공의 안전에 이바지함을 목적으로 하는 법으로서(제1조), 지하층의 경우 밀폐공간으로서 구조가 복잡하고 피난이 어렵다는 점을 고려하여⁵⁾ “지하연계 복합건축물”에 해당하는 경우 해당 건물의 관리주체로 하여금 그 건축물등에 대한 재난을 예방하고 피해를 경감하기 위한 계획을 수립·시행하도록 하고(제9조), 총괄재난관리자를 두며(제12조), 관계인, 상시근무자 및 거주자에게 재난 및 테러 등에 대한 교육·훈련을 실시하도록 하는 등(제14조)의 규정을 두고 있는바, 초고층재난관리법은 그 취지에 따라 국민의 안전 확보 목적을 충실히 실현할 수 있는 방향으로 해석할 필요가 있다고 할 것입니다⁶⁾.

그런데 초고층재난관리법 제2조제2호나목에 따라 지하역사 또는 지하도상가와 연결되어 있으면서 건축물 안에 「건축법」 제2조제2항에 따른 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 업무시설 등이 하나 이상 있고 ① 층수가 11층 이상이면서 산정기준에 따른 수용인원이 5천명 미만인 건축물 또는 ② 층수가 11층 미만이면서 산정기준에 따른 수용인원이 5천명 이상인 건축물에 해당하는 경우에는, 다수의 인원이 이용할 것이 예상될 뿐만 아니라, 대형화·복합화·밀폐화된 공간으로서 구조가 복잡하고 거대한 공간 내부에 불특정 다수인이 출입하는 시설물인 경우가 많아 이용객들이 자신의 위치를 파악하지 못하여 위급상황 시

2) 국립국어원 표준국어대사전 참조

3) 법제처, 알기 쉬운 법령 정비기준 열 번째판(2023), 150p 참조

4) 법제처, 알기 쉬운 법령 정비기준 열 번째판(2023), 152p 참조

5) 2009. 3. 31. 의안번호 제1804323호로 발의된 초고층재난관리법안에 대한 국회 행정안전위원회 심사보고서 참조

6) 법제처 2018. 12. 7. 회신 18-0702 해석례 참조

피난대피에 어려움을 겪는 경우가 발생할 수 있다는 점에서 재난관리체제를 마련할 필요성이 크다고 할 것인바, 이 사안의 경우 초고층재난관리법 제2조제2호의 “지하연계 복합건축물”에 해당한다고 보아 지하역사 또는 지하도상가와 연결된 복합건축물에 대한 종합적인 재난 예방 및 피해경감 대책을 수립하도록 하는 것이 국민의 생명, 신체, 재산을 보호하고 공공의 안전에 이바지하려는 초고층재난관리법의 취지에 부합한다고 할 것입니다.

따라서 ① 층수가 11층 이상이면서 산정기준에 따른 수용인원이 5천명 미만인 건축물 및 ② 층수가 11층 미만이면서 산정기준에 따른 수용인원이 5천명 이상인 건축물의 경우, 초고층재난관리법 제2조제2호의 “지하연계 복합건축물”에 해당합니다.



관계법령

초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법

제1조(목적) 이 법은 초고층 및 지하연계 복합건축물과 그 주변지역의 재난관리를 위하여 재난의 예방·대비·대응 및 지원 등에 필요한 사항을 정하여 재난관리체제를 확립함으로써 국민의 생명, 신체, 재산을 보호하고 공공의 안전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. (생 략)
2. “지하연계 복합건축물”이란 지하부분이 지하역사 또는 지하도상가와 연결된 건축물로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 다만, 화재 발생 시 열과 연기의 배출이 쉬운 구조를 갖춘 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물은 제외한다.
 - 가. 층수가 11층 이상이거나 용도별 바닥면적 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 산정기준에 따른 수용인원이 5천명 이상인 건축물
 - 나. 건축물 안에 「건축법」 제2조제2항제5호에 따른 문화 및 집회시설, 같은 항 제7호에 따른 판매시설, 같은 항 제8호에 따른 운수시설, 같은 항 제14호에 따른 업무시설, 같은 항 제15호에 따른 숙박시설, 같은 항 제16호에 따른 위락(慰樂)시설 중 유원시설업(遊園施設業)의 시설 또는 대통령령으로 정하는 용도의 시설이 하나 이상 있는 건축물
3. ~ 8. (생 략)

CHAPTER

6

농림축산·산림·해양수산

제1절 농림·축산

제2절 산림

제3절 해양수산

제1절 농림·축산

질의제목 1

▶ 안전번호 24-0856

농림축산식품부 - 「농업협동조합법」 제51조제7항에서 규정하고 있는 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력은 같은 법 제49조제1항에서 규정하고 있는 임원의 결격사유에 해당하는 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력으로 한정되는지(「농업협동조합법」 제51조제7항 등 관련)

01 질의요지

「농업협동조합법」 제49조제1항제8호에서는 지역농협의 임원의 결격사유 중 하나로 “같은 법 제172조 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제58조(매수 및 이해유도죄)·제59조(기부행위의 금지·제한 등 위반죄)·제61조(허위사실 공표죄)부터 제66조(각종 제한규정 위반죄)까지에 규정된 죄를 범하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받고 4년이 지나지 아니한 사람”을 규정하고 있고, 「농업협동조합법」 제51조제7항에서는 같은 조 제4항에 따라 지역농협의 조합장 선거를 수탁·관리하는 구·시·군선거관리위원회는 해당 지역농협의 주된 사무소의 소재지를 관할하는 검찰청의 장에게 조합장 선거 후보자의 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력(실효된 형을 포함하며, 이하 이 조에서 “전과기록”이라 함)을 조회할 수 있으며, 해당 검찰청의 장은 지체 없이 그 전과기록을 회보하여야 한다고 규정하고 있는바,

「농업협동조합법」 제51조제7항에서 규정하고 있는 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력은 같은 법 제49조제1항에서 규정하고 있는 임원의 결격사유에 해당하는 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력으로 한정되는지?

02 회답

「농업협동조합법」 제51조제7항에서 규정하고 있는 벌금 100만원 이상의 형의 범죄 경력은

같은 법 제49조제1항에서 규정하고 있는 임원의 결격사유에 해당하는 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력으로 한정되지 않습니다.

03 이유

「농업협동조합법」 제51조제7항 전단에서는 지역농협의 조합장 선거를 수탁·관리하는 구·시·군선거관리위원회는 조합장 선거 후보자의 ‘벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력¹⁾’을 조회할 수 있다고 규정하면서, ‘벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력’에 대해 같은 법 제49조제1항에서 규정하고 있는 임원의 결격사유에 해당하는 경우로 한정하는 등 그 범죄경력의 유형 등에 대해서는 규정하고 있지 않습니다.

그런데 「농업협동조합법」 제51조제7항은 범죄경력 유무 확인을 통해 공명하고 깨끗한 선거문화를 정착시키기 위한 취지로 도입된 것으로서²⁾, 「농업협동조합법」 제49조제1항에 따르면 임원의 결격사유는 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람(제5호) 등 대부분 형이 실효된 경우는 제외하는 형태로 규정³⁾하고 있는 반면, 같은 법 제51조제7항에 따라 조회의 대상이 되는 범죄경력도 실효된 형을 포함한다고 명시하고 있어 같은 법 제49조제1항에 따른 결격사유와 같은 법 제51조제7항에 따른 조회 대상인 범죄경력의 범위가 동일하다고 보기 어렵고, 범죄경력조회를 규정하고 있는 「모자보건법」 등 다른 법률의 규정⁴⁾을 살펴보면 대상자가 ‘결격사유’에 해당하는지를 확인하기 위하여 범죄경력조회를 할 수 있다고 규정하고 있는데 반해, 「농업협동조합법」 제51조제7항에서는 별도로 규정하고 있지 않다는 점 등을 종합적으로 고려하면, 명시적인 규정이 없음에도 불구하고 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력이 같은 법 제49조제1항에서 규정하고 있는 임원의 결격사유에 해당하는 벌금 100만원 이상의 범죄경력으로 한정된다고 해석하는 것은 타당하지 않습니다.

1) 실효된 형을 포함하며, 이하 같음

2) 2009. 12. 16. 의안번호 제1807020호로 발의된 농업협동조합법 일부개정법률안에 대한 국회 농림수산식품위원회 검토보고서, 2024. 1. 8. 의안번호 제2126227호로 발의된 공공단체등 위탁선거에 관한 법률 일부개정법률안 의안원문 참조

3) 3년을 초과하는 징역·금고는 10년, 3년 이하의 징역·금고는 5년, 벌금은 2년이 경과한 때에 그 형이 실효됨(「형의 실효 등에 관한 법률」 제7조제1항 참조)

4) 「모자보건법」 제15조의19(산후조리도우미의 자격) 제3항, 「경비업법」 제17조(결격사유 확인을 위한 범죄경력조회 등) 제1항·제2항 등 참조

아울러 「농업협동조합법」 제51조제7항과 유사하게 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력(실효된 형을 포함함)을 조회할 수 있도록 하고 있는 「공직선거법」의 규정을 살펴보면, 「공직선거법」 제19조에서는 피선거권이 없는 자에 대해 규정하면서 같은 조 제4호가목에서는 「국회법」 제166조의 죄를 범한 자로서 500만원 이상의 벌금형의 선고를 받고 그 형이 확정된 후 5년이 경과되지 아니한 자를 규정하고 있고, 「공직선거법」 제49조제10항 전단에서 후보자가 되고자 하는 자 또는 정당은 본인 또는 후보자가 되고자 하는 소속 당원의 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력(실효된 형을 포함하며, 이하 “전과기록”이라 함)을 국가경찰관서의 장에게 조회할 수 있으며 그 요청을 받은 국가경찰관서의 장은 지체 없이 그 전과기록을 회보하여야 한다고 규정하고 있는데, 「공직선거법」 제49조제10항에 따라 조회할 수 있는 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력을 같은 법 제19조에서 규정하고 있는 피선거권 결격 여부와는 별개로 보고 있는 점도⁵⁾ 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「농업협동조합법」 제51조제7항에서 규정하고 있는 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력에는 같은 법 제49조제1항에서 규정하고 있는 임원의 결격사유에 해당하는 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력으로 한정되지 않습니다.



관계법령

농업협동조합법

제49조(임원의 결격사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 지역농협의 임원이 될 수 없다. 다만, 제10호와 제12호는 조합원인 임원에게만 적용한다.

1. ~ 7. (생략)

8. 제172조 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제58조(매수 및 이해유도죄)·제59조(기부행위의 금지·제한 등 위반죄)·제61조(허위사실 공표죄)부터 제66조(각종 제한규정 위반죄)까지에 규정된 죄를 범하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받고 4년이 지나지 아니한 사람

9. 이 법에 따른 임원 선거에서 당선되었으나 제173조제1항제1호 또는 「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」 제70조(위탁선거범죄로 인한 당선무효)제1호에 따라 당선이 무효로 된 사람으로서 그 무효가 확정된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람

10. ~ 12. (생략)

②·③ (생략)

5) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다34521 판결례 참조

제51조(조합선거관리위원회의 구성·운영 등) ① ~ ③ (생략)

④ 지역농협은 제45조제5항제1호 및 제2호에 따라 선출하는 조합장 선거의 관리에 대하여는 정관으로 정하는 바에 따라 그 주된 사무소의 소재지를 관할하는 「선거관리위원회법」에 따른 구·시·군선거관리위원회(이하 “구·시·군선거관리위원회”라 한다)에 위탁하여야 한다.

⑦ 제4항에 따라 지역농협의 조합장 선거를 수탁·관리하는 구·시·군선거관리위원회는 해당 지역농협의 주된 사무소의 소재지를 관할하는 검찰청의 장에게 조합장 선거 후보자의 벌금 100만원 이상의 형의 범죄경력(실효된 형을 포함하며, 이하 이 조에서 “전과기록”이라 한다)을 조회할 수 있으며, 해당 검찰청의 장은 지체 없이 그 전과기록을 회보하여야 한다.

⑧ 제7항에 따른 조합장 선거를 제외한 임원 선거의 후보자가 되고자 하는 자는 전과기록을 본인의 주소지를 관할하는 국가경찰관서의 장에게 조회할 수 있으며, 해당 국가경찰관서의 장은 지체 없이 그 전과기록을 회보하여야 한다. 이 경우 회보받은 전과기록은 후보자등록 시 함께 제출하여야 한다.

질의제목 2

▶ 안전번호 24-0911

민원인 - 벼를 건조·저장하는 시설이 「농지법 시행령」 제29조제2항제1호에 따라 농업진흥구역에 설치할 수 있는 시설인 “농수산물의 가공·처리 시설”에 해당하는지(「농지법 시행령」 제29조제2항제1호 등 관련)

01 질의요지

「농지법」 제32조제1항 본문에서는 농업진흥구역에서는 농업 생산 또는 농지 개량과 직접적으로 관련된 행위로서 대통령령으로 정하는 행위 외의 토지이용행위를 할 수 없다고 규정하고 있고, 같은 항 단서에서는 같은 항 각 호의 토지이용행위는 그러하지 아니하다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서 “대통령령으로 정하는 농수산물¹⁾의 가공·처리 시설의 설치”를 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제29조제2항제1호에서는 같은 법 제32조제1항제1호에 따른 “대통령령으로 정하는 농수산물의 가공·처리 시설” 중 하나로서 “다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 농수산물의 가공·처리 시설(「건축법 시행령」 별표 1 제4호너목에 따른 제조업소 또는 같은 표 제17호에 따른 공장에 해당하는 시설을 말하며, 그 시설에서 생산된 제품을 판매하는 시설을 포함함)”을 규정하고 있는 한편,

「건축법 시행령」 별표 1 제4호너목에서는 “제조업소”를 규정하면서 “물품의 제조·가공 등을 위한 시설”을, 같은 표 제17호에서는 “공장”을 규정하면서 “물품의 제조·가공²⁾에 계속적으로 이용되는 건축물”을 규정하고 있는바,

벼를 건조·저장하는 시설이 「농지법 시행령」 제29조제2항제1호에 따라 농업진흥구역에 설치할 수 있는 시설인 “농수산물의 가공·처리 시설”에 해당하는지³⁾?

1) 농산물·임산물·축산물·수산물을 말하며, 이하 같음

2) 염색·도장(塗裝)·표백·재봉·건조·인쇄 등을 포함하며, 이하 같음

3) 「농지법 시행령」 제29조제5항제1호에 따른 ‘농업인 또는 농업법인이 자기가 생산한 농산물을 건조·보관하기 위하여 설치하는 시설’에 해당하지 않는 사안임을 전제함

02 회답

벼를 건조·저장하는 시설은 「농지법 시행령」 제29조제2항제1호에 따라 농업진흥구역에 설치할 수 있는 시설인 “농수산물의 가공·처리 시설”에 해당하지 않습니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것⁴⁾인데, 「농지법 시행령」 제29조제2항제1호에서는 농업진흥구역에 예외적으로 설치할 수 있는 농수산물의 가공·처리 시설을 규정하면서 “「건축법 시행령」 별표 1 제4호너목에 따른 제조업소 또는 같은 표 제17호에 따른 공장에 해당하는 시설을 말한다”고 규정하고 있고, 「건축법 시행령」 별표 1 제4호너목에서는 “제조업소”를 “물품의 제조·가공 등을 위한 시설”이라고 규정하고 있으며, 같은 표 제17호에서는 “공장”을 “물품의 제조·가공에 계속적으로 이용되는 건축물”이라고 규정하고 있는바, 사전적으로 “제조”는 공장에서 큰 규모로 물건을 만들 또는 원료에 인공을 가하여 정교한 제품을 만들이라는 의미이고, “가공”은 원자재나 반제품을 인공적으로 처리하여 새로운 제품을 만들거나 제품의 질을 높임이라는 의미인 점⁵⁾을 고려할 때, 벼를 건조·저장하는 시설은 벼를 “제조”하거나 “가공”하는 시설에 해당하지 않으므로 “「건축법 시행령」 별표 1 제4호너목에 따른 제조업소 또는 같은 표 제17호에 따른 공장에 해당하는 시설”에 해당하지 않고, 따라서 「농지법 시행령」 제29조제2항제1호에 따라 농업진흥구역에 설치할 수 있는 시설인 “농수산물의 가공·처리 시설”에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다.

그리고 농지를 효율적으로 이용·보전함으로써 농업의 생산성을 향상시키기 위한 「농지법」의 목적과 농업진흥구역의 농지를 보전하기 위해 농업진흥구역에서 행위제한을 규정하고 있는 같은 법 제32조제1항의 취지⁶⁾, 같은 법 제32조제1항 본문에서 농업진흥구역에서 농업 생산 또는 농지 개량과 직접적으로 관련된 행위로서 대통령령으로 정하는 행위 외의 토지이용행위를 원칙적으로 금지하면서, 농업진흥구역에서 예외적으로

4) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

5) 국립국어원 표준국어대사전 참조

6) 법제처 2022. 8. 19. 회신 22-0461 해석례 참조

허용되는 토지이용행위를 같은 항 각 호 및 같은 법 시행령 제29조에서 구체적으로 명시하고 있는 해당 규정의 조문 체계 등을 종합적으로 고려하면, 「농지법」 제32조제1항 각 호 및 같은 법 시행령 제29조의 규정에 따라 농업진흥구역에서 허용되는 토지이용행위는 한정적·열거적인 것으로 보아야 할 것인데⁷⁾, 같은 법 제32조제1항제3호에서는 “대통령령으로 정하는 농업인 주택, 어업인 주택, 농업용 시설, 축산업용 시설 또는 어업용 시설의 설치”를 농업진흥구역에서 허용되는 토지이용행위 중 하나로 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제29조제5항제1호에서는 “농업인 또는 농업법인이 자기가 생산한 농산물을 건조·보관하기 위하여 설치하는 시설”을 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 같은 법 시행령 제29조제2항제1호에 따른 “농수산물의 가공·처리 시설”과 “건조·보관 시설”은 별개의 시설로서 이를 설치·생산하는 주체나 업종이 구분된다고 할 것인바, 벼를 건조·저장하는 시설은 「농지법」 제32조제1항제3호의 “농업용 시설”에 해당할 뿐 같은 조 제1항제1호에 따른 “농수산물의 가공·처리 시설”에는 해당하지 않는다고 해석하는 것이 해당 규정의 체계에 부합한다고 할 것입니다.

아울러 입법연혁적으로 구 「농지법 시행령」⁸⁾ 제29조제2항제1호에서 “농수산물의 가공·처리 시설”을 규정하면서 “해당 시설에서 생산된 제품을 판매하는 시설을 포함한다”는 내용 외에는 그 시설의 범위에 대해 별도로 규정하지 않고 있던 것을, 2016년 1월 19일 대통령령 제26903호로 일부개정된 「농지법 시행령」 제29조제2항제1호에서 “농수산물의 가공·처리시설” 뒤에 괄호를 두어 “「건축법 시행령」 별표 1 제4호너목에 따른 제조업소 또는 같은 표 제17호에 따른 공장에 해당하는 시설을 말한다”고 규정한 것인바, 이는 “농수산물 가공·처리 시설”의 범위를 괄호 부분에서 규정한 것과 같이 “「건축법 시행령」 별표 1 제4호너목에 따른 제조업소 또는 같은 표 제17호에 따른 공장에 해당하는 시설”만으로 한정하려는 취지로 볼 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 벼를 건조·저장하는 시설은 「농지법 시행령」 제29조제2항제1호에 따라 농업진흥구역에 설치할 수 있는 시설인 “농수산물의 가공·처리 시설”에 해당하지 않습니다.

7) 법제처 2019. 7. 25. 회신 18-0799 해석례 참조

8) 2016. 1. 19. 대통령령 제26903호로 일부개정되기 전의 것을 말함

법령정비 권고사항

「농지법 시행령」 제29조제5항제1호에 따른 시설 외에 벼를 건조·저장하는 시설을 농업진흥구역에 설치할 수 있는 시설에 포함시킬 필요가 있는지를 정책적으로 검토하고, 필요하다고 판단되는 경우 이를 농지법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

농지법

제32조(용도구역에서의 행위 제한) ①농업진흥구역에서는 농업 생산 또는 농지 개량과 직접적으로 관련된 행위로서 대통령령으로 정하는 행위 외의 토지이용행위를 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 토지이용행위는 그러하지 아니하다.

1. 대통령령으로 정하는 농수산물(농산물·임산물·축산물·수산물을 말한다. 이하 같다)의 가공·처리 시설의 설치 및 농수산업(농업·임업·축산업·수산업을 말한다. 이하 같다) 관련 시험·연구 시설의 설치
2. ~ 9. (생략)
- ② ~ ④ (생략)

농지법 시행령

제29조(농업진흥구역에서 할 수 있는 행위) ① (생략)

② 법 제32조제1항제1호에서 “대통령령으로 정하는 농수산물(농산물·임산물·축산물·수산물을 말한다. 이하 같다)의 가공·처리 시설 및 농수산업(농업·임업·축산업·수산업을 말한다. 이하 같다) 관련 시험·연구 시설”이란 다음 각 호의 시설을 말한다.

1. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 농수산물의 가공·처리 시설(「건축법 시행령」 별표 1 제4호너목에 따른 제조업소 또는 같은 표 제17호에 따른 공장에 해당하는 시설을 말하며, 그 시설에서 생산된 제품을 판매하는 시설을 포함한다)
 - 가. 국내에서 생산된 농수산물(「농업·농촌 및 식품산업 기본법 시행령」 제5조제1항 및 제2항에 따른 농수산물을 말하며, 임산물 중 목재와 그 가공품 및 토석은 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 및 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 농수산물가공품을 주된 원료로 하여 가공하거나 건조·절단 등 처리를 거쳐 식품을 생산하기 위한 시설일 것
 - 나. 농업진흥구역 안의 부지 면적이 1만5천제곱미터[미곡의 건조·선별·보관 및 가공시설(이하 “미곡종합처리장”이라 한다)의 경우에는 3만제곱미터] 미만인 시설(판매시설이 포함된 시설의 경우에는 그 판매시설의 면적이 전체 시설 면적의 100분의 20 미만인 시설에 한정한다)일 것

2. ~ 3. (생 략)

③ ~ ⑦ (생 략)

건축법 시행령

[별표 1]

용도별 건축물의 종류(제3조의5 관련)

1. ~ 3. (생 략)

4. 제2종 근린생활시설

가. ~ 거. (생 략)

너. 제조업소, 수리점 등 물품의 제조·가공·수리 등을 위한 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만이고, 다음 요건 중 어느 하나에 해당하는 것

1) 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상이 아닌 것

2) 「물환경보전법」 제33조제1항 본문에 따라 폐수배출시설의 설치 허가를 받거나 신고해야 하는 시설로서 발생하는 폐수를 전량 위탁처리하는 것

더. ~ 머. (생 략)

5. ~ 16. (생 략)

17. 공장

물품의 제조·가공[염색·도장(塗裝)·표백·재봉·건조·인쇄 등을 포함한다] 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설, 자원순환 관련 시설 등으로 따로 분류되지 아니한 것

18. ~ 29. (생 략)

비고

(생 략)

질의제목 3

▶ 안전번호 25-0015

농림축산식품부 - 판매할 목적이 아닌 반려·자가소비 등의 목적으로 가축을 사육하거나 젖·알·꿀을 생산하는 경우에도 「축산법」 제2조제8호에 따른 가축사육업에 해당하는지 여부(「축산법」 제2조제8호 등)

01 질의요지

「축산법」 제2조제8호에서는 “가축사육업”이란 판매할 목적으로 가축을 사육하거나 젖·알·꿀을 생산하는 업을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제22조제1항제4호에서는 가축 종류 및 사육시설 면적이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 가축사육업을 경영하려는 자는 해당 영업장을 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 허가를 받아야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제1항제4호에 해당하지 않는 가축사육업을 경영하려는 자는 해당 영업장을 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 등록하여야 한다고 규정하고 있는바¹⁾,

판매할 목적이 아닌 반려·자가소비 등의 목적으로 가축을 사육하거나 젖·알·꿀을 생산하는 경우가 「축산법」 제2조제8호에 따른 가축사육업에 해당하는지?

02 회답

판매할 목적이 아닌 반려·자가소비 등의 목적으로 가축을 사육하거나 젖·알·꿀을 생산하는 경우에는 「축산법」 제2조제8호에 따른 가축사육업에 해당하지 않습니다.

03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데²⁾, 「축산법」 제2조제8호에서는

1) 2016년 2월 23일 이후 사육시설 면적이 50제곱미터를 초과하는 소·돼지·닭 또는 오리 사육업은 가축사육업 허가 대상이고, 그 외는 가축사육업 등록 대상임(「축산법 시행령」 제13조제3호 참조)

“가축사육업”이란 판매할 목적으로 가축을 사육하거나 젖·알·꿀을 생산하는 업을 말한다고 정의하고 있어, 가축사육업은 가축을 사육하거나 젖·알·꿀을 생산하는 것과 더불어 판매할 목적이 있어야 한다는 점을 명시하고 있고, 판매할 목적이 아닌 경우로서 예외적으로 가축사육업에 해당할 수 있는 경우에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않으므로, 판매할 목적이 아닌 경우로서 가축을 사육하거나 젖·알·꿀을 생산하는 경우는 가축사육업에 해당하지 않는다는 것이 문언상 분명합니다.

그리고 「축산법」 제2조제8호의 입법연혁을 살펴보면, 2012년 2월 22일 법률 제11359호로 일부개정된 「축산법」에서 가축사육업의 정의 규정을 신설하면서, “가축사육업”이란 가축을 사육하여 판매하거나 젖·알·꿀을 생산하는 업을 말한다고 규정하였는데, 이후 2018년 12월 31일 법률 제16126호로 일부개정된 「축산법」에서 “가축사육업”이란 판매할 목적으로 가축을 사육하거나 젖·알·꿀을 생산하는 업을 말한다고 현행과 같이 규정하여, 가축사육업에는 판매할 목적이 있어야 한다는 점을 명시하였고, 「축산법」 제22조에 따라 허가 등을 받아야 하는 종축업, 부화업, 정액등처리업 등 다른 축산업의 경우에도 같은 법 제2조제5호부터 제7호까지의 규정에서 이를 모두 “판매하는 업”으로 정의하고 있는바, 이러한 입법연혁 및 규정체계에 비추어 볼 때, 「축산법」 제2조제8호에 따른 가축사육업은 가축의 사육이나 젖·알·꿀의 생산을 통해 이를 판매할 것을 목적으로 하고 있다고 할 것입니다.

또한 국민의 권리를 제한하는 법규정은 가급적 엄격하게 해석해야 할 것인데³⁾, 「축산법」 제22조에 따라 가축사육업 허가를 받으려는 자 또는 등록을 하려는 자는 배출시설, 살처분·소각 및 매몰 등에 필요한 매몰지, 축사, 악취저감 장비·시설 등을 갖춰야 하고(제22조제2항·제4항), 결격사유에 해당하지 않아야 하며(제23조), 교육과정을 이수하여야 하는(제33조의2) 한편, 같은 법 제22조에 따라 가축사육업 허가를 받은 자 또는 등록을 한 자는 기르는 가축 및 축사를 위생적으로 관리하는 등 일정한 준수사항을 지켜야 하고(제26조), 점검 등을 받을 수 있으며(제28조), 가축사육업 허가 또는 등록 없이 가축사육업을 경영한 자는 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금(제53조제1호) 또는 500만원 이하의 과태료 부과(제56조제2항 제2호)의 대상이 되는바, 명시적 규정 없이 판매할 목적이 아닌 반려·자가소비 등의 목적으로 가축을 사육하거나 젖·알·꿀을 생산하는 경우도 「축산법」 제2조제8호에 따른 가축사육업에 해당한다고 확장해석하는 것은 타당하지 않습니다.

2) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

3) 법제처 2012. 9. 12. 회신 12-0442 해석례 참조

따라서 판매할 목적이 아닌 반려·자가소비 등의 목적으로 가축을 사육하거나 젖·알·꿀을 생산하는 경우에는 「축산법」 제2조제8호에 따른 가축사육업에 해당하지 않습니다.



관계법령

축산법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 7. (생 략)
8. “가축사육업”이란 판매할 목적으로 가축을 사육하거나 젖·알·꿀을 생산하는 업을 말한다.
- 8의2. ~ 10의2. (생 략)

제22조(축산업의 허가 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 축산업을 경영하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 영업장을 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항 중 가축의 종류 등 농림축산식품부령으로 정하는 중요한 사항을 변경할 때에도 또한 같다.

1. 종축업
2. 부화업
3. 정액등처리업
4. 가축 종류 및 사육시설 면적이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 가축사육업

② (생 략)

③ 제1항제4호에 해당하지 아니하는 가축사육업을 경영하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 영업장을 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 등록하여야 한다.

④ ~ ⑧ (생 략)

질의제목 4

▶ 안전번호 25-0016

농림축산식품부 - 「민사조정법」 제28조에 따른 조정의 성립을 통해 축산업을 양도받은 자는 「축산법」 제24조제1항에 따라 그 영업자의 지위를 승계하는지(「축산법」 제24조 등)

01 질의요지

「축산법」 제24조제1항에서는 같은 법 제22조제1항에 따라 축산업의 허가를 받거나 같은 조 제3항에 따라 가축사육업의 등록을 한 자가 사망하거나 영업을 양도한 때 또는 법인의 합병이 있는 때에는 그 상속인, 양수인 또는 합병 후에 존속하는 법인이나 합병에 의하여 설립된 법인은 그 영업자의 지위를 승계한다고 규정하고 있는 한편,

「민사조정법」 제28조에서는 조정은 당사자 사이에 합의된 사항을 조서에 기재함으로써 성립한다고 규정하고 있고, 같은 법 제29조에서는 조정은 재판상 화해와 동일한 효력이 있다고 규정하고 있는바,

「축산법」 제22조제1항에 따라 축산업의 허가를 받거나 같은 조 제3항에 따라 가축사육업 등록을 한 자로부터 「민사조정법」 제28조에 따른 조정의 성립을 통해 그 축산업을 양도받은 자는 「축산법」 제24조제1항에 따라 그 영업자의 지위를 승계하는지¹⁾?

02 회답

「축산법」 제22조제1항에 따라 축산업 허가를 받거나 같은 조 제3항에 따라 가축사육업 등록을 한 자로부터 「민사조정법」 제28조에 따른 조정의 성립을 통해 그 축산업을 양도받은 자는 「축산법」 제24조제1항에 따라 그 영업자의 지위를 승계합니다.

1) 축산업 허가 또는 가축사육업 등록 양도에 대해 「민사조정법」 제28조에 따라 조정이 성립된 경우로서 양수인이 「축산법」 제23조에 따른 결격사유에 해당하지 않는 경우를 전제로 함

03 이유

「축산법」 제24조제1항에서는 같은 법 제22조제1항에 따라 축산업의 허가를 받거나 같은 조 제3항에 따라 가축사육업의 등록을 한 자가 ① 사망하거나 ② 영업을 양도한 때 또는 ③법인의 합병이 있는 때에는 그 상속인, 양수인 또는 합병 후에 존속하는 법인이나 합병에 의하여 설립된 법인은 그 영업자의 지위를 승계한다고 규정하고 있어, 영업자의 지위 승계 사유 중 하나로 영업의 양도를 규정하고 있습니다.

그런데 「축산법」 제24조제1항에 따라 영업을 양도받은 양수인이 그 영업자의 지위를 승계하는 것은 일반적으로 영업의 양도·양수에 관한 계약이 성립한 경우로, 이러한 계약이 성립하려면 당사자 사이에 의사합치가 있을 것이 요구되는데²⁾, 「민사조정법」에 따른 조정은 당사자 사이에 합의된 사항을 조서에 기재함으로써 성립하고(제28조), 조정은 재판상의 화해와 동일한 효력이 있으며(제29조), 「민사소송법」 제220조에서는 화해를 조서에 적은 때에는 확정판결과 같은 효력을 가지는 것으로 규정하고 있는바, 결국 조정 조서는 재판상의 화해 조서와 같이 확정판결과 같은 효력이 있고, 당사자 사이에 조정이 성립하면 종전의 다툼 있는 법률관계를 바탕으로 한 권리·의무관계는 소멸하고 조정의 내용에 따른 새로운 권리·의무관계가 성립하는 것으로서³⁾, 당사자 사이에는 조정 조서에 대한 기판력이 생겨 확정판결의 당연무효 등의 사유가 없는 한 그 조정 조서의 효력은 유지되는바⁴⁾, 축산업의 양도에 관한 사항을 조서에 기재함으로써 「민사조정법」 제28조에 따른 조정이 성립된 경우 당사자 사이에 영업의 양도·양수에 관한 의사의 합치가 존재하는 것으로 보아야 할 것이므로⁵⁾, 「축산법」 제24조제1항에 따른 지위 승계 사유인 영업의 양도에는 양도·양수에 관한 계약뿐만 아니라 「민사조정법」 제28조에 따른 조정이 성립된 경우도 포함된다고 보아야 할 것입니다.

그리고 「축산법」 제24조의 영업자 지위 승계 규정은 2002년 12월 26일 법률 제6821호로 일부개정된 「축산법」에서 축산업이 규모화되어 밀집사육이 늘어남에 따라 농가의 가축질병예방과 축산물의 위생관리를 강화하기 위해 축산업 등록제를 도입하면서 신설된 것으로서⁶⁾, 일반적으로 영업자 지위 승계 규정을 두는 취지는 새로운 영업자가 다시 영업허가를 받아야 하는 번잡함을 덜어주거나 종전의 영업자에 대한 행정처분의 효과가

2) 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000다51650 판결례 참조

3) 대법원 2007. 4. 26. 선고 2006다78732 판결례 참조

4) 대법원 2014. 3. 27. 선고 2009다104960, 104977 판결례 참조

5) 서울행정법원 2018. 5. 11. 선고 2017구합83430 판결례 참조

6) 2003. 12. 26. 법률 제6821호로 일부개정된 「축산법」 개정이유 및 주요내용 참조

새로운 영업자에게 승계되도록 하기 위한 것⁷⁾인바, 「축산법」 제24조제1항에 따른 영업의 양도를 반드시 계약에 의한 영업의 양도·양수만으로 제한하여 해석하는 것은 영업자의 승계 규정을 둔 입법 취지에도 부합하지 않는다고 할 것입니다.

따라서 「축산법」 제22조제1항에 따른 축산업 허가를 받거나 같은 조 제3항에 따라 가축사육업 등록을 한 자로부터 「민사조정법」 제28조에 따른 조정의 성립을 통해 그 축산업을 양도받은 자는 「축산법」 제24조제1항에 따라 그 영업자의 지위를 승계합니다.



관계법령

축산법

- 제24조(영업의 승계) ① 제22조제1항에 따라 축산업의 허가를 받거나 같은 조 제3항에 따라 가축사육업의 등록을 한 자가 사망하거나 영업을 양도한 때 또는 법인의 합병이 있는 때에는 그 상속인, 양수인 또는 합병 후에 존속하는 법인이나 합병에 의하여 설립된 법인은 그 영업자의 지위를 승계한다.
- ② 제1항에 따라 그 영업자의 지위를 승계한 자는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 승계한 날부터 30일 이내에 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 승계에 관하여는 제23조를 준용한다.

민사조정법

제28조(조정 of 성립) 조정은 당사자 사이에 합의된 사항을 조서에 기재함으로써 성립한다.

제29조(조정의 효력) 조정은 재판상의 화해와 동일한 효력이 있다.

민사소송법

제220조(화해, 청구의 포기·인낙조서의 효력) 화해, 청구의 포기·인낙을 변론조서·변론준비기일조서에 적은 때에는 그 조서는 확정판결과 같은 효력을 가진다.

7) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.112 참조

질의제목 5

▶ 안전번호 25-0088

민원인 - 「농지법」 제34조제2항제1호의2에 따른 농지의 소유자가 농업법인인 경우, 해당 농지를 전용하여 수행할 수 있는 사업이 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제19조의4에 따른 사업인 경우에 한해서만 농지전용협의를 대한 동의가 가능한지(「농지법」 제34조제2항 및 「농지법 시행령」 제34조 등 관련)

01 질의요지

「농지법」 제34조제2항에서는 주무부장관이나 지방자치단체의 장은 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 농림축산식품부장관과 미리 농지전용에 관한 협의(이하 “농지전용협의”라 함)를 하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 제1호의2에서는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 함)에 따른 계획관리지역에 지구단위계획구역을 지정할 때에 해당 구역 예정지에 농지가 포함되어 있는 경우를 그 중 하나로 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「농지법 시행령」 제34조제2항에서는 농림축산식품부장관은 주무부장관 또는 지방자치단체의 장의 농지전용협의 요청이 있으면 같은 영 제33조제1항 각 호의 사항에 대한 심사를 한 후 그 동의 여부를 결정하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 농림축산식품부장관은 같은 영 제33조제1항 각 호의 심사기준에 적합하지 아니한 경우에는 동의를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 같은 영 제33조제1항 각 호에서는 “농지를 전용하려는 자가 그 전용목적사업을 수행하는 것이 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」(이하 “농어업경영체법”이라 함) 등 관련 법령에 저촉되지 않을 것(제8호)”, “농지를 전용하려는 자가 농지 소유자로부터 사용권을 제공받은 경우에는 그 사용권 제공이 농어업경영체법 등 관련 법령에 저촉되지 않을 것(제9호)” 등을 심사기준으로 규정하고 있는 한편,

농어업경영체법 제19조의4제1항에서는 농업법인¹⁾은 그 목적을 달성하기 위하여 농업의 경영, 농산물의 공동 출하·유통·가공 등 대통령령으로 정하는 사업을 영위할 수 있다고 규정하고 있는바,

「농지법」 제34조제2항제1호의2에서 규정한 국토계획법에 따른 계획관리지역에 지구단위 계획구역을 지정할 때에 해당 구역 예정지에 농지가 포함되어 있는 경우로서 해당 농지의

1) 농어업경영체법 제2조제2호에 따른 농업법인을 말하며, 이하 같음

소유자가 농업법인인 경우, 지구단위계획에 따라 해당 농지를 전용하여 수행할 수 있는 사업이 농어업경영체법 제19조의4에 따른 사업인 경우에 한해서만 농림축산식품부장관 (해당 권한이 위임된 경우에는 위임받은 자를 말하며, 이하 같음)의 농지전용협의를 대한 동의가 가능한지?

02 회답

이 사안의 경우, 지구단위계획에 따라 해당 농지를 전용하여 수행할 수 있는 사업이 농어업경영체법 제19조의4에 따른 사업인 경우에 한해서만 농지전용협의를 대한 동의가 가능합니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데²⁾, 「농지법」 제34조제2항 제1호의2에서는 국토계획법에 따른 계획관리지역에 지구단위계획구역을 지정할 때에 해당 구역 예정지에 농지가 포함되어 있는 경우에는 지방자치단체의 장 등과 농림축산식품부장관이 미리 농지전용협의를 하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「농지법 시행령」 제34조제2항 및 제3항에서는 지방자치단체의 장 등으로부터 농지전용협의요청을 받은 농림축산식품부장관은 같은 영 제33조제1항 각 호의 사항에 대한 심사를 한 후 농지전용협의요청에 대한 동의 여부를 결정하여야 하고, 같은 항 각 호의 심사기준에 적합하지 아니한 경우에는 동의를 하여서는 아니 된다고 규정하면서, 같은 영 제33조제1항 각 호의 사항 중 적용 예외사유를 규정하고 있지도 않은바, 이 사안의 농지전용협의를 이루어지기 위해서는 같은 영 제33조제1항제1호부터 제9호까지의 규정에 따른 심사기준에 적합하여야 하는 것이 문언상 명백하므로, 이 사안의 농지전용협의 시 농림축산식품부장관은 같은 영 제33조제1항제8호 및 제9호에 따라 농지전용에 관한 사항이 농어업경영체법에 저촉되는지 여부를 함께 심사하여야 합니다.

2) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

그런데 농어업경영체법 제19조의4제1항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제20조의5제1항에서는 농업법인이 영위할 수 있는 사업의 범위를 농업의 경영(제1호), 농산물의 출하·유통·가공·판매 및 수출(제2호), 농작업의 대행(제3호), 농어촌관광휴양사업(제4호) 등으로 한정적으로 열거하면서, 농어업경영체법 제20조의3제2항제3호에서는 시장·군수·구청장은 같은 법 제19조의4제1항에 따른 사업범위에서 벗어난 사업을 하는 농업법인에 대하여 법원에 해산을 청구할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 법 제19조의5에서는 농업법인은 농지를 활용 또는 전용하여 부동산업³⁾을 영위할 수 없다고 규정하면서, 이를 위반하여 부동산 개발 및 공급업 등을 영위한 농업법인에 대해서는 과징금을 부과하고(제20조의4제1항), 이를 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다고(제31조) 규정하고 있는바, 이와 같이 농어업경영체법에서 농업법인의 사업범위를 한정적으로 열거하고 이를 위반하는 경우 제재하도록 규정하고 있는 것은 농업인이 아닌 농업법인도 농지를 소유할 수 있도록 한 점을 악용하여 부동산업 등을 통해 부당이익을 얻는 문제를 방지하기 위한 것⁴⁾이므로, 이러한 농어업경영체법령의 취지를 고려할 때, 「농지법」 제34조제2항제1호의2에 따른 지구단위 계획구역 예정지에 포함되어 있는 농지의 소유자가 농업법인인 경우라면, 해당 농지를 전용하여 수행할 수 있는 사업이 농어업경영체법 제19조의4에 따른 사업인 경우에 한해서만 농지전용협의를 대한 동의가 가능하다고 보는 것이 타당할 것입니다.

아울러 「농지법」은 농지를 효율적으로 이용·관리하여 농업인의 경영 안정과 농업 생산성을 향상시키는 것을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 농지가 국민에게 식량을 공급하고 국토 환경을 보전(保全)하기 위한 기반이며 농업과 국민경제의 조화로운 발전에 영향을 미치는 한정된 귀중한 자원이라는 점을 고려하여, 농지의 소유·이용 및 보전 등 농지에 관한 권리의 행사에 대해 일반 토지보다 강한 제한과 의무를 부과⁵⁾하고 있는바, 농지전용협의를 마친 농지에 대해서는 같은 법 제6조에 따른 농지 소유 제한, 같은 법 제34조에 따른 농지전용허가 등 농지법상 일부 규정에 대한 적용이 완화되거나 제외된다는 점을 고려할 때, 농림축산식품부장관이 농지전용협의를 대한 동의 여부를 판단하기 위한 기준에 대해서는 엄격하게 해석할 필요가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

한편 농지전용협의를 「농지법」 제34조제1항에 따른 농지전용허가와 달리 “농지를 전용하려는 자”가 아닌 “주무부장관이나 지방자치단체의 장”이 협의의 주체가 되므로,

3) 「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 부동산업을 말하며, 농어업경영체법 제2조제8호에 따른 농어촌 관광휴양사업을 영위하는 경우는 제외함

4) 2021. 8. 17. 법률 제18400호로 일부개정된 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 개정이유 및 주요내용 참조

5) 법제처 2021. 5. 12. 회신 21-0147 해석례 참조

「농지법 시행령」 제33조제1항제8호 및 제9호의 사항은 “농지를 전용하려는 자”에 관한 사항을 판단하도록 하려는 것으로서, 이 사안의 농지전용협의를 대해서는 같은 항 제8호 및 제9호의 사항이 적용되지 않는다고 보아야 한다는 의견이 있으나, 비록 농지전용협의 시점에는 지구단위계획구역 예정지 안 농지 소유자의 농지전용의사 여부가 구체적·개별적·확정적으로 표시되지는 않는다고 하더라도⁶⁾, 향후 지구단위계획을 통해 결정되는 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보 등을 위해 해당 농지를 전용하여야 할 필요가 있을 수 있으므로, 「농지법」 제34조제2항제1호의2에서는 이를 전제로 미리 지방자치단체의 장 등과 농림축산식품부장관 간 농지의 “전용”에 관한 협의를 하도록 규정한 것인 점, 농지전용협의 제도는 개발 용도로 토지이용계획을 수립하는 경우 해당 지역 전체를 대상으로 일괄하여 농지전용협의를 하도록 함으로써 행정절차를 간소화하려는 취지⁷⁾인바, 농지를 전용한다는 점에 있어서는 농지전용허가 제도와 실질적인 차이가 있는 것은 아니라는 점 등에 비추어 볼 때, 「농지법 시행령」 제33조제1항 각 호의 심사기준은 같은 영 제34조에 따라 농지전용협의 시에 그 기준을 적용할 때에는 같은 영 제33조제1항제8호 및 제9호의 규정 중 “농지를 전용하려는 자” 부분을 제외한 나머지 실질적 요건 부분, 즉 “전용목적사업을 수행하는 것이 농어업경영체법 등 관련 법령에 저촉되지 않을 것” 및 “농지 소유자의 사용권 제공이 농어업경영체법 등 관련 법령에 저촉되지 않을 것”이라는 요건을 충족하는지를 판단하도록 규정한 것으로 보는 것이 타당할 것인바, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 지구단위계획에 따라 해당 농지를 전용하여 수행할 수 있는 사업이 농어업경영체법 제19조의4에 따른 사업인 경우에 한해서만 농지전용협의를 대한 동의가 가능합니다.

6) 대법원 1996. 3. 26. 선고 95누15933 판결례 참조

7) 농림축산식품부 농지업무편람(2023), p. 315 참조



관계법령

농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률

제19조의4(농업법인 및 어업법인의 사업범위) ① 농업법인은 그 목적을 달성하기 위하여 농업의 경영, 농산물의 공동 출하·유통·가공 등 대통령령으로 정하는 사업을 영위할 수 있다.

② (생략)

농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행령

제20조의5(농업법인 및 어업법인의 사업범위) ① 법 제19조의4제1항에서 “농업의 경영, 농산물의 공동 출하·유통·가공 등 대통령령으로 정하는 사업”이란 다음 각 호의 사업을 말한다.

1. 농업의 경영
2. 농산물의 출하·유통·가공·판매 및 수출
3. 농작업의 대행
4. 농어촌관광휴양사업
5. 「농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 농촌융복합산업(농촌융복합산업 사업자로서 수행하는 경우만 해당한다)
6. 다음 각 목의 부대 사업
 - 가. 영농에 필요한 자재의 생산 및 공급사업
 - 나. 영농에 필요한 종자생산 및 종균배양사업
 - 다. 농산물의 구매 및 비축사업
 - 라. 농업기계나 그 밖의 장비의 임대·수리 및 보관사업
 - 마. 소규모 관개시설(灌漑施設)의 수탁 및 관리사업
 - 바. 농업과 관련된 공동이용시설의 설치·운영

② (생략)

농지법

제34조(농지의 전용허가·협의) ① (생략)

② 주무부장관이나 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 농림축산식품부장관과 미리 농지전용에 관한 협의를 하여야 한다.

1. (생략)

1의2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 계획관리지역에 지구단위계획구역을 지정할 때에 해당 구역 예정지에 농지가 포함되어 있는 경우

2. (생략)

농지법 시행령

제33조(농지전용허가의 심사) ①시장·군수 또는 자치구구청장은 제32조제1항에 따라 농지전용허가 신청서 등을 제출받은 때에는 다음 각 호의 심사기준에 따라 심사한 후 농림축산식품부령으로 정하는 서류를 첨부하여 그 제출받은 날(제3항에 따라 신청서류의 보완 또는 보정을 요구한 경우에는 그 보완 또는 보정이 완료된 날을 말한다)부터 10일 이내에 시·도지사에게 보내야 하며, 시·도지사는 10일 이내에 이에 대한 종합적인 심사의견서를 첨부하여 농림축산식품부장관에게 제출해야 한다.

1. ~ 7. (생 략)

8. 농지를 전용하려는 자가 그 전용목적사업을 수행하는 것이 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 등 관련 법령에 저촉되지 않을 것

9. 농지를 전용하려는 자가 농지 소유자로부터 사용권을 제공받은 경우에는 그 사용권 제공이 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 등 관련 법령에 저촉되지 않을 것

② ~ ④ (생 략)

제34조(농지의 전용에 관한 협의 등) ①주무부장관 또는 지방자치단체의 장이 법 제34조제2항에 따라 농지의 전용에 관하여 협의(다른 법률에 따라 농지전용허가가 의제되는 협의를 포함한다)하려는 경우에는 농지전용협의요청서에 농림축산식품부령으로 정하는 서류를 첨부하여 농림축산식품부장관에게 제출하여야 한다.

② 농림축산식품부장관은 제1항에 따른 농지의 전용에 관한 협의요청이 있으면 제33조제1항 각 호의 사항에 대한 심사를 한 후 그 동의 여부를 결정하여야 한다.

③ 농림축산식품부장관은 제33조제1항 각 호의 심사기준에 적합하지 아니한 경우에는 동의를 하여서는 아니 된다.

질의제목 6

▶ 안전번호 25-0186, 25-0256

농촌진흥청 - 시·군 농업산·학협동심의회 의원 구성 요건(「농업산·학협동심의회 규정」 제6조의2 제2항 등 관련)

01 질의요지

「농업산·학협동심의회 규정」 제2조에서는 농업산·학협동에 관한 주요 시책과 그 운용에 관한 사항을 심의하게 하기 위하여 농업기술센터가 설치된 특별시·광역시·특별자치시·시·군(이하 “시·군”이라 함)에 시·군 농업산·학협동심의회(이하 “시·군 심의회”라 함)를 둘 수 있다고 규정하고 있고, 같은 영 제6조의2제1항에서는 시·군 심의회는 위원장, 부위원장 각 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 시·군 심의회의 위원장은 농업기술센터 소장이 되고, 부위원장은 위원 중에서 호선(互選)하며, 위원은 위원장이 위촉하는 같은 항 각 호의 사람이 된다고 규정하면서, 같은 항 제4호에서는 “같은 항 제3호 외의 농업단체 대표 7명 이내”, 같은 항 제5호에서는 “그 밖에 과학영농을 선도하는 농업인 등 농업에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람 5명 이내” 등을 규정하고 있는바,

「농업산·학협동심의회 규정」 제6조의2제2항제4호·제5호의 어느 하나에 해당하는 사람이 없는 경우, 해당 호에 해당하는 사람을 제외하고 시·군 심의회를 구성할 수 있는지?

02 회답

「농업산·학협동심의회 규정」 제6조의2제2항제4호·제5호의 어느 하나에 해당하는 사람이 없는 경우, 해당 호에 해당하는 사람을 제외하고 시·군 심의회를 구성할 수 있습니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데¹⁾, 「농업산·학협동심의회

규정」 제6조의2제2항제4호·제5호에서는 시·군 심의회의 위원장이 위촉하는 위원의 수를 각각 “7명 이내”, “5명 이내”라는 범위를 정하여 규정하고 있고, 일반적으로 “이내”는 일정한 범위나 한도의 안을 의미하는 것²⁾으로서 그 기준이 수량인 경우에는 해당 수량이 범위에 포함되면서 그 아래인 경우를 말하는 것인바³⁾, 문언상 같은 항 제4호·제5호는 시·군 심의회의 위원을 해당 규정에서 정한 인원수 또는 그보다 적은 인원수로 구성하도록 규정한 것으로 보아야 할 것이므로, 가능하다면 같은 항 각 호에 해당하는 사람을 골고루 위촉하는 것이 바람직하나, 같은 항 제4호·제5호에 해당하는 사람을 현실적으로 위촉할 수 없는 등의 경우에는 같은 항 제4호·제5호 중 어느 하나에 해당하는 사람을 위원으로 위촉하지 않을 수도 있다고 할 것입니다.

또한 「농업산·학협동심의회 규정」 제6조의2제2항에서는 시·군 심의회의 위원 구성을 산업계·학계·관(官)계 등에 속한 사람들로 균형있게 구성할 수 있도록 규정하되, 같은 항 제1호·제4호·제5호에서는 인원 범위의 상한만을 규정하고 있는 점, 같은 항 제5호에서는 “그 밖에 과학영농을 선도하는 농업인 등 농업에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람”이라고 규정하여 같은 항 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 사람 외에 농업에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람을 위원으로 위촉할 필요가 있다고 인정되는 경우에 그 사람을 위원으로 위촉할 수 있도록 하는 취지라는 점, 같은 영 제9조제2항에서는 시·군 심의회가 분야별로 둘 수 있는 전문위원회의 경우 전문위원을 “5명 이상 8명 이하”로 구성하도록 규정하여 그 상한과 하한을 모두 규정하고 있는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 같은 영 제6조의2제2항제4호·제5호의 어느 하나에 해당하는 사람을 위원으로 위촉할 수 없는 경우에는 해당 호에 해당하는 사람을 제외하고 시·군 심의회를 구성할 수 있다고 해석하는 것이 규정 체계에 부합하는 해석일 것입니다.

따라서 「농업산·학협동심의회 규정」 제6조의2제2항제4호·제5호의 어느 하나에 해당하는 사람이 없는 경우, 해당 호에 해당하는 사람을 제외하고 시·군 심의회를 구성할 수 있습니다.

1) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

2) 국립국어원 표준국어대사전 참조

3) 법제처 2020. 9. 28. 회신 20-0363 해석례 참조



관계법령

농업산·학협동심의회 규정

제2조(설치) 농업산·학협동에 관한 주요 시책과 그 운용에 관한 사항을 심의하게 하기 위하여 도·특별자치도(이하 “도”라 한다)에 도 농업산·학협동심의회(이하 “도 심의회”라 한다)를, 농업기술센터가 설치된 특별시·광역시·특별자치시·시·군(이하 “시·군”이라 한다)에 시·군 농업산·학협동심의회(이하 “시·군 심의회”라 한다)를 둘 수 있다.

제6조의2(시·군 심의회의 구성) ① 시·군 심의회는 위원장, 부위원장 각 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.

② 시·군 심의회의 위원장은 농업기술센터 소장이 되고, 부위원장은 위원 중에서 호선(互選)하며, 위원은 위원장이 위촉하는 다음 각 호의 사람이 된다.

1. 위원장의 요청에 따라 해당 기관의 장이 지정하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 4명 이내(제2호의 위원이 없는 시·군의 경우에는 5명 이내)

가. 해당 지역에 있는 농학계열 대학의 교수 또는 지역 연고가 있는 농학계열 대학의 교수

나. 해당 지역에 있는 농업계열 고등학교의 교원

다. 시·군의 농업 관련 업무를 담당하는 과장

라. 시·군의 농업 연구·지도 업무를 담당하는 공무원

2. 도 농업기술원 지역특화작목시험장의 장(지역특화작목시험장이 설치된 경우만 해당한다)

3. 농업협동조합중앙회의 시·군을 관할구역으로 하는 지사무소의 장, 시·군을 관할구역으로 하는 지역산림조합의 조합장 각 1명

4. 제3호 외의 농업단체 대표 7명 이내

5. 그 밖에 과학영농을 선도하는 농업인 등 농업에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람 5명 이내

③ (생략)

질의제목 7

▶ 안전번호 25-0266

전라남도 담양군 - 「농지법」 개정 전에 농지전용허가를 받지 않고 농지를 전용하였고 개정 「농지법」의 시행 이후에도 무허가 농지전용이 계속되고 있는 경우, 해당 농지의 소유자·점유자 또는 관리자는 개정 「농지법」 제42조제1항제1호에 따라 원상회복을 명할 수 있는 대상에 해당하는지(「농지법」 제42조제1항제1호 등 관련)

01 질의요지

「농지법」에서 농지전용허가를 받지 아니하고 농지를 전용한 경우에 해당하면 그 행위를 한 자에게 농림축산식품부장관, 시장·군수 또는 자치구구청장이 기간을 정하여 원상회복을 명할 수 있도록 규정하고 있던 것¹⁾을 개정 「농지법」(2024년 1월 2일 법률 제19877호로 일부개정되어 2025년 1월 3일 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제42조제1항에서 농지전용허가를 받지 아니하고 농지를 전용한 경우(제1호)에 해당하면 그 행위를 한 자뿐만 아니라 해당 농지의 소유자·점유자 또는 관리자(이하 “소유자등”이라 함)에게도 원상회복을 명할 수 있도록 규정하였는바, 개정 「농지법」이 시행되기 전에 행위자가 농지전용허가를 받지 않고 농지를 전용하였고 개정 「농지법」 시행 이후에도 해당 농지에 대한 무허가 농지전용이 계속되고 있는 경우(이하 “이 사안 농지전용의 경우”라 함), 해당 농지의 소유자등은 개정 「농지법」 제42조제1항제1호에 따라 원상회복을 명할 수 있는 대상에 해당하는지?

02 회답

이 사안 농지전용의 경우, 해당 농지의 소유자등은 개정 「농지법」 제42조제1항제1호에 따라 원상회복을 명할 수 있는 대상에 해당합니다.

1) 해당 내용은 1994. 12. 22. 법률 제4817호로 제정된 「농지법」 제44조에서 규정하고 있다가 2007. 4. 11. 법률 제8352호로 전부개정하면서 제42조로 이동하였음

03 이유

종전에는 「농지법」에서 농지전용허가를 받지 아니하고 농지를 전용한 경우에 해당하면 그 행위를 한 자에게 농림축산식품부장관, 시장·군수 또는 자치구구청장이 기간을 정하여 원상회복을 명할 수 있도록 규정하고 있던 것을 개정 「농지법」 제42조제1항에서 농지전용허가를 받지 아니하고 농지를 전용한 경우(제1호)에 해당하면 그 행위를 한 자뿐만 아니라 해당 농지의 소유자등에게도 원상회복을 명할 수 있도록 규정하면서, 해당 개정 규정에 관한 경과조치 등의 부칙 규정은 두지 않았는바, 이 사안 농지전용의 경우 해당 농지의 소유자등이 개정 「농지법」 제42조제1항제1호에 따라 원상회복을 명할 수 있는 대상에 해당하는지가 문제됩니다.

행정처분은 그 근거 법령이 개정된 경우에도 경과규정에서 달리 정함이 없다면 원칙적으로 처분 당시의 법령과 그에 정해진 기준에 따라야 하고, 개정 법령이 기존의 사실 또는 법률관계를 적용대상으로 하면서 국민의 재산권과 관련하여 종전보다 불리한 법률효과를 규정하고 있는 경우라도 그러한 사실 또는 법률관계가 개정 법령이 시행되기 이전에 이미 완성되거나 종결된 것이 아니라면 개정 법령을 적용하는 것이 헌법상 금지되는 소급입법에 의한 재산권 침해라고 할 수는 없으며²⁾, 다만 개정 전 법령의 존속에 대한 국민의 신뢰가 개정 법령의 적용에 관한 공익상의 요구보다 더 보호가치가 있다고 인정되는 경우에 그러한 국민의 신뢰를 보호하기 위하여 그 적용이 제한될 수 있는 여지가 있을 뿐이므로³⁾, 이 사안의 경우 「농지법」이 개정되기 전에 행위자가 농지전용허가를 받지 않고 농지를 전용한 이후 개정 「농지법」 시행 이후에도 법률 위반 상태가 계속되고 있는바, 개정 법률을 적용하여 소유자등에게 원상복구를 명하는 것은 위반행위 그 자체가 아닌 농지전용허가 없이 전용되고 있는 농지에 관한 ‘계속되는 사실’을 적용대상으로 하는 것으로서 소급입법 금지의 원칙에 반하지 않습니다⁴⁾.

그리고 개정 「농지법」 제42조제1항은 농지전용허가를 받지 않고 농지를 전용한 행위자의 사망 또는 소유권 변동 등에 따라 행위자를 찾지 못하는 경우에는 원상회복 명령을 내리기가 어려워 불법 전용농지가 복구되지 않고 방치되는 문제를 개선하기 위하여 행위자뿐만 아니라 소유자등에게도 원상회복을 명할 수 있는 근거를 마련함으로써 농지의 조속한 원상회복을 도모하려는 취지⁵⁾에서 개정된 것으로, 이 사안 농지전용의 경우에 소유자등은 원상회복

2) 대법원 2014. 4. 24. 선고 2013두26552 판결례, 법제처 2018. 5. 4. 회신 18-0099 해석례 참조

3) 대법원 2014. 4. 24. 선고 2013두26552 판결례 참조

4) 의정부지방법원 2024. 1. 10. 선고 2023구단6449 판결례, 수원지방법원 2024. 11. 27. 선고 2023구단4906 판결례 참조

5) 2023. 4. 13. 의안번호 제2121356호로 발의된 농지법 일부개정법률안에 대한 국회 농림축산식품해양수산위원회 검토보고서 참조

명령의 대상이 아니라고 해석하게 되면 이러한 입법 목적을 달성할 수 없게 된다는 점에서 개정 규정을 적용하여 소유자등이 원상회복을 할 수 있도록 하는 것이 이 규정의 개정 취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

따라서 이 사안 농지전용의 경우, 해당 농지의 소유자등은 개정 「농지법」 제42조제1항 제1호에 따라 원상회복을 명할 수 있는 대상에 해당합니다.



관계법령

농지법

제34조(농지의 전용허가·협의) ① 농지를 전용하려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 농림축산식품부장관의 허가(다른 법률에 따라 농지전용허가가 의제되는 협의를 포함한다. 이하 같다)를 받아야 한다. 허가받은 농지의 면적 또는 경계 등 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

1. ~ 4. (생 략)

② (생 략)

제42조(원상회복 등) ① 농림축산식품부장관, 시장·군수 또는 자치구구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 행위를 한 자, 해당 농지의 소유자·점유자 또는 관리자에게 기간을 정하여 원상회복을 명할 수 있다.

1. 제34조제1항에 따른 농지전용허가 또는 제36조에 따른 농지의 타용도 일시사용허가를 받지 아니하고 농지를 전용하거나 다른 용도로 사용한 경우

2. ~ 6. (생 략)

② 농림축산식품부장관, 시장·군수 또는 자치구구청장은 제1항에 따른 원상회복명령을 위반하여 원상회복을 하지 아니하면 대집행(代執行)으로 원상회복을 할 수 있다.

③ 제2항에 따른 대집행의 절차에 관하여는 「행정대집행법」을 적용한다.

질의제목 8

▶ 안전번호 25-0283, 25-0296

농촌진흥청 - 도 농업산·학협동심의회 의원 구성 요건(「농업산·학협동심의회 규정」 제5조제2항 등 관련)

01 질의요지

「농업산·학협동심의회 규정」 제2조에서는 농업산·학협동에 관한 주요 시책과 그 운용에 관한 사항을 심의하게 하기 위하여 도·특별자치도(이하 “도”라 함)에 도 농업산·학협동심의회(이하 “도 심의회”라 함)를 둘 수 있다고 규정하고 있고, 같은 영 제5조제1항에서는 도 심의회는 위원장, 부위원장 각 1명을 포함한 14명 이내의 위원으로 구성한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 도 심의회의 위원장은 해당 도 농업 기술원장이 되고, 부위원장은 해당 도 또는 해당 도에 인접한 특별시·광역시·특별자치시에 있는 국공립 농학계열 대학의 학장 중에서 도 심의회의 위원장이 지정하는 사람이 되며, 그 밖의 위원은 같은 항 각 호의 사람이 된다고 규정하면서, 같은 항 제3호에서는 “농업에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 도지사가 위촉하는 사람 4명 이내”, 같은 항 제4호에서는 “농업에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위원장이 지정하는 사람 2명 이내” 등을 규정하고 있는바,

「농업산·학협동심의회 규정」 제5조제2항제3호·제4호의 어느 하나에 해당하는 사람을 현실적으로 위촉하거나 지정할 수 없는 등의 예외적인 경우, 해당 호에 해당하는 사람을 제외하고 도 심의회를 구성할 수 있는지?

02 회답

「농업산·학협동심의회 규정」 제5조제2항제3호·제4호의 어느 하나에 해당하는 사람을 현실적으로 위촉하거나 지정할 수 없는 등의 예외적인 경우, 해당 호에 해당하는 사람을 제외하고 도 심의회를 구성할 수 있습니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데¹⁾, 「농업산·학협동심의회 규정」 제5조제2항제3호·제4호에서는 도 심의회의 위원의 수를 각각 “4명 이내”, “2명 이내”라는 범위를 정하여 규정하고 있고, 일반적으로 “이내”는 일정한 범위나 한도의 안을 의미하는 것²⁾으로서 그 기준이 수량인 경우에는 해당 수량이 범위에 포함되면서 그 아래인 경우를 말하는 것인바³⁾, 문언상 같은 항 제3호·제4호는 도 심의회의 위원을 해당 규정에서 정한 인원수 또는 그보다 적은 인원수로 구성하도록 규정한 것으로 보아야 할 것이므로, 가능하다면 같은 항 각 호의 전문가를 골고루 구성하는 것이 바람직하나, 같은 항 제3호·제4호에 해당하는 사람을 현실적으로 위촉하거나 지정할 수 없는 등의 예외적인 경우에는 같은 항 제3호·제4호 중 어느 하나에 해당하는 사람을 위원으로 구성하지 않을 수도 있다고 할 것입니다.

또한 「농업산·학협동심의회 규정」 제5조제2항제1호·제2호에서는 도, 도 교육위원회 및 도 농업기술원 소속의 국장 또는 4급 이상 공무원 중에서 해당 기관의 장이 지정하는 직위에 있는 사람 각 1명(도 농업기술원의 경우에는 2명), 농업협동조합중앙회 및 산림조합중앙회의 도를 관할구역으로 하는 지사무조의 장 각 1명을 위원으로 구성하도록 규정하고 있는 것과 달리, 같은 항 제3호·제4호에서는 인원 범위의 상한을 규정하여 해당 범위 내에서는 위원의 수를 달리 정할 수 있도록 재량을 부여하고 있는 점, 같은 영 제9조제2항에서는 각급 심의회가 분야별로 둘 수 있는 전문위원회의 경우 전문위원을 “5명 이상 8명 이하”로 구성하도록 규정하여 그 상한과 하한을 모두 규정하고 있는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 같은 영 제5조제2항제3호·제4호의 어느 하나에 해당하는 사람을 위원으로 위촉하거나 지정할 수 없는 경우에는 해당 호에 해당하는 사람을 제외하고 도 심의회를 구성할 수 있다고 해석하는 것이 규정 체계에 부합하는 해석일 것입니다.

아울러 「농업산·학협동심의회 규정」 제5조제2항제3호·제4호의 어느 하나에 해당하는 사람을 위원으로 위촉하거나 지정할 수 없는 경우에 도 심의회의 구성 자체가 불가능하다고 해석하게 된다면, 도 심의회를 통해 농업 관련 산·학협동에 관한 주요 시책과 그 운용에 관한

1) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

2) 국립국어원 표준국어대사전 참조

3) 법제처 2020. 9. 28. 회신 20-0363 해석례 참조

사항 등을 심의할 수 없게 되는바, 해당 호의 전문가를 현실적으로 위촉하거나 지정할 수 없는 등 극히 예외적인 경우에는 해당 호에 해당하는 사람을 제외하고 도 심의회를 구성할 수 있다고 해석하는 것이 농업 관련 산업계·학계·관(官)계 및 연구기관의 협동체제를 구현함으로써 농업과학기술의 효율적인 개발과 국제경쟁력 향상을 도모하려는 「농업산·학협동심의회 규정」의 입법 목적(제1조)에 부합할 것이라는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「농업산·학협동심의회 규정」 제5조제2항제3호·제4호의 어느 하나에 해당하는 사람을 현실적으로 위촉하거나 지정할 수 없는 등의 예외적인 경우, 해당 호에 해당하는 사람을 제외하고 도 심의회를 구성할 수 있습니다.



관계법령

농업산·학협동심의회 규정

제2조(설치) 농업산·학협동에 관한 주요 시책과 그 운용에 관한 사항을 심의하게 하기 위하여 도·특별자치도(이하 “도”라 한다)에 도 농업산·학협동심의회(이하 “도 심의회”라 한다)를, 농업기술센터가 설치된 특별시·광역시·특별자치시·시·군(이하 “시·군”이라 한다)에 시·군 농업산·학협동심의회(이하 “시·군 심의회”라 한다)를 둘 수 있다.

제5조(도 심의회의 구성) ① 도 심의회는 위원장, 부위원장 각 1명을 포함한 14명 이내의 위원으로 구성한다.

② 도 심의회의 위원장은 해당 도 농업기술원장이 되고, 부위원장은 해당 도 또는 해당 도에 인접한 특별시·광역시·특별자치시에 있는 국공립 농학계열 대학의 학장 중에서 도 심의회의 위원장이 지정하는 사람이 되며, 그 밖의 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.

1. 도, 도 교육위원회 및 도 농업기술원 소속의 국장 또는 4급 이상 공무원 중에서 해당 기관의 장이 지정하는 직위에 있는 사람 각 1명(도 농업기술원의 경우에는 2명)
2. 농업협동조합중앙회 및 산림조합중앙회의 도를 관할구역으로 하는 지사무소의 장 각 1명
3. 농업에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 도지사가 위촉하는 사람 4명 이내
4. 농업에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위원장이 지정하는 사람 2명 이내

③ (생략)

제2절 산림

질의제목 1

▶ 안전번호 24-0913

민원인 - 법률 제19873호 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」 제20조제1항제2호의3에 따라 준보전국유림을 공유림등과 교환할 수 있는 시기(「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」 제20조제1항제2호의3 등 관련)

01 질의요지

구 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」(2024년 1월 2일 법률 제19873호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 “구 국유림법”이라 함) 제20조제1항 본문에서는 산림청장은 준보전국유림¹⁾이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 매각 또는 교환할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 단서에서 같은 항 제2호의2 및 제2호의3 본문의 경우에는 교환만 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 항 제2호의3 본문에서는 같은 법 제21조제1항에 따라 5만제곱미터 이내의 면적으로 대부받은 자가 5년 이상 사용하고 있는 국유림을 공유림등²⁾과 교환하려는 경우를 규정하면서, 같은 호 단서 및 가목에서는 같은 법 제26조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공유림등과 교환할 수 없다고 규정하고 있었는데,

2024년 1월 2일 법률 제19873호로 일부개정된 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」(이하 “개정 국유림법”이라 함)에서는 제20조제1항제2호의3가목에 단서를 신설하여 같은 법 제26조제1항제2호, 제3호 또는 제5호에 해당하는 경우로서 대부등³⁾의 취소사유를 해소하고 이를 관계공무원이 확인한 날부터 5년이 경과한 경우는 제외한다고 규정하면서, 같은 법 부칙 제1조에서는 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다고 규정하고 있는바,

1) 보전국유림 외의 국유림을 말하며(개정 국유림법 제16조제1항제2호 참조), 이하 같음

2) 공유림 또는 사유림 그 밖의 토지를 말하며(개정 국유림법 제18조제2항 참조), 이하 같음

3) 대부 또는 사용허가를 말하며(개정 국유림법 제9조제2항 참조), 이하 같음

5만제곱미터 이내의 면적으로 준보전국유림을 대부 받아 사용하고 있는 자가 구 국유림법 제26조제1항제2호, 제3호 또는 제5호에 해당하였으나, 개정 국유림법 시행일 전에 그 취소사유를 해소하고 이를 관계공무원이 확인한 경우⁴⁾, 개정 국유림법 제20조제1항제2호의3가목 단서에 따른 “5년”의 기산점은 개정 국유림법의 시행일인지 아니면 관계공무원이 확인한 시점인지?

02 회답

이 사안의 경우, 개정 국유림법 제20조제1항제2호의3가목 단서에 따른 “5년”의 기산점은 관계공무원이 확인한 시점입니다.

03 이유

먼저 법령이 개정되는 경우 구법령과 신법령의 적용상 혼란을 방지하기 위해, 신법 조항이 어떤 사람 또는 사항에 대하여 적용되는지 적용관계를 규정하는 적용례를 두거나 법령이 개정되어 새로운 법질서가 마련된 경우에 제도의 변화와 법적 안정성을 조화시키기 위하여 일정한 사람이나 사항에 대하여 구법의 규정을 적용하도록 하는 경과조치를 둘 수 있는데, 법령이 개정된 경우에 적용례 또는 경과조치에서 달리 정함이 없는 한, 개정 법령의 시행일 이후에는 개정 법령과 그에서 정한 기준에 따르는 것이 원칙인바⁵⁾, 법령을 개정하면서 별도의 적용례나 경과조치를 두지 않았다면 신법령 시행 당시에 진행 중인 사실관계나 법률관계에 대해서는 원칙적으로 신법령이 적용된다고 할 것입니다⁶⁾.

그런데 개정 국유림법 제20조제1항제2호의3가목 단서와 관련하여 개정 국유림법 부칙에서는 그 시행일만 규정하고 있을 뿐 별도의 경과조치 등을 두지 않았고, 같은 법 시행일 전에 5만제곱미터 이내의 면적으로 준보전국유림을 대부 받아 사용하고 있는 자가 같은 법 제26조제1항제2호, 제3호 또는 제5호에 해당하였으나, 그 취소사유를 해소하고 이를 관계공무원이 확인한 날부터 5년이 경과한 경우 해당 준보전국유림의 대부 계약관계가

4) 해당 취소사유를 해소한 이후 별도로 취소사유에 해당하지 않음을 전제로 함

5) 대법원 2001. 10. 12. 선고 2001두274 판결례 참조

6) 법제처 2023. 12. 4. 회신 23-1040 해석례 참조

유지되고 있어, 개정 국유림법 시행일 이후에도 계속 진행 중인 사실관계나 법률관계에 해당하는바, 이 사안의 경우 원칙적으로 개정규정이 적용된다고 할 것이므로, 개정 국유림법 제20조제1항제2호의3가목 단서에 따른 “5년”의 기산점은 관계공무원이 확인한 시점으로 보아야 합니다.

또한 개정 국유림법 제20조제1항제2호의3가목 단서는 대부료의 미납 또는 보증금 미예치 등 경제적 사유로 인해 일시적으로 대부등의 취소사유에 해당하였다가 연체금 납부 등 취소사유를 해소한 경우에 대해서도 영구적으로 공유림등과의 교환을 금지하는 것은 과도한 제한이라는 지적에 따라 신설된 규정인바⁷⁾, 이 사안과 같이 구 국유림법 제26조제1항제2호, 제3호 또는 제5호에 해당하였으나, 개정 국유림법 시행일 전에 그 취소사유를 해소하고 이를 관계공무원이 확인한 경우라면 개정 국유림법 제20조제1항제2호의3가목 단서에 따른 “5년”의 기산점은 관계공무원이 확인한 시점으로 보는 것이 준보전국유림과 공유림등의 교환 제한을 완화하려는 규정의 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 준보전국유림을 공유림등과 교환하는 계약은 국가가 사경제주체로서 상대방과 대등한 위치에서 행하는 사법상 계약⁸⁾으로 사적 자치와 계약자유 원칙 등 사법상 원리가 그대로 적용되는 것이 원칙⁹⁾인 점을 고려할 때, 개정 국유림법에 따라 준보전국유림과 공유림등의 교환을 제한하는 경우 그 제한은 입법 목적 달성을 위한 최소한의 범위에서 행해져야 하는바¹⁰⁾, 준보전국유림과 공유림등의 교환 제한 사유에 해당하는지 여부는 엄격하게 해석하여 할 필요가 있다는 점¹¹⁾도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 개정 국유림법 제20조제1항제2호의3가목 단서에 따른 “5년”의 기산점은 관계공무원이 확인한 시점입니다.

7) 2022. 12. 30. 의안번호 2119264호로 발의된 국유림법 일부개정법률안에 대한 국회 농림축산식품해양수산위원회 검토보고서 참조

8) 대법원 2002. 9. 27. 선고 2000다27411 판결례 및 법제처 2019. 5. 24. 회신 18-0765 해석례 참조

9) 대법원 2012. 9. 20. 결정 2012마1097 결정례 및 법제처 2019. 5. 24. 회신 18-0765 해석례 참조

10) 헌법재판소 2015. 12. 23. 선고 2013헌바117 결정례 참조

11) 법제처 2019. 5. 24. 회신 18-0765 해석례 참조



관계법령

국유림의 경영 및 관리에 관한 법률(2024. 1. 2. 법률 제19873호로 일부개정되어 2024. 7. 3. 시행된 것)

제20조(준보전국유림의 매각 및 교환) ① 산림청장은 준보전국유림이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 매각 또는 교환할 수 있다. 다만, 제2호의2 및 제2호의3 본문의 경우에는 교환만 할 수 있다.

1. ~ 2의2. (생략)

2의3. 제21조제1항에 따라 5만제곱미터 이내의 면적으로 대부를 받은 자가 5년 이상 사용하고 있는 국유림을 공유림등과 교환하려는 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공유림등과 교환할 수 없다.

가. 제26조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우. 다만, 같은 항 제2호, 제3호 또는 제5호에 해당하는 경우로서 대부등의 취소사유를 해소하고 이를 관계공무원이 확인한 날부터 5년이 경과한 경우는 제외한다.

나. (생략)

3. (생략)

②·③ (생략)

법률 제19873호 국유림의 경영 및 관리에 관한 법률 일부개정법률 부칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

질의제목 2

▶ 안전번호 25-0055

민원인 - 「산지관리법」 제25조의4에 따라 토석채취제한지역에서 예외적으로 토석채취를 할 수 있는 경우, 해당 토석채취제한지역에서 노천채굴을 위한 산지일시사용허가를 할 수 있는지(「산지관리법」 제15조의2제1항 등 관련)

01 질의요지

「산지관리법」 제15조의2제1항 본문에서는 「광업법」에 따른 광물의 채굴, 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」에 따른 광해방지사업, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목에 따른 태양에너지발전설비의 설치, 그 밖에 대통령령으로 정하는 용도로 산지일시사용을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 “산림청장등”이라 함)의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 「산지관리법」 제15조의2제5항에서는 같은 조 제1항에 따른 산지일시사용허가의 절차, 기준, 조건, 기간·기간연장, 대상시설, 행위의 범위, 설치지역 및 설치조건 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제18조의2제3항 및 별표 3의2 제1호가목의 설치지역란 본문에서는 산지전용·일시사용제한지역 및 토석채취제한지역이 아닌 산지에서 노천채굴을 위한 산지일시사용허가를 할 수 있는 것으로 규정하고 있는 한편,

「산지관리법」 제25조의3제1항에서는 공공의 이익증진을 위하여 보전이 특히 필요하다고 인정되는 같은 항 각 호의 산지는 토석채취제한지역으로 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제25조의4 본문에서는 토석채취제한지역에서는 토석채취를 할 수 없다고 규정하면서, 같은 조 단서에서는 공용·공공용 사업을 위하여 필요한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우(제3호), 공공시설 등의 관리자 또는 소유자의 동의를 받은 경우 등 대통령령으로 정하는 경우(제4호) 등 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 토석채취를 할 수 있다고 규정하고 있는바,

「산지관리법」 제25조의4에 따라 토석채취제한지역에서 예외적으로 토석채취를 할 수 있는 경우 같은 법 제15조의2제1항에 따라 해당 토석채취제한지역에서 노천채굴¹⁾을 위한 산지일시사용허가를 할 수 있는지?

1) 해당 노천채굴이 ① 「산지관리법 시행령」 별표 3의2 제1호가목 설치지역란 단서에 따른 “고령토의 굴취·채취” 및 ② 같은 별표 비고 제7호에 따라 산지일시사용허가를 할 수 있는 경우에 해당하지 않음을 전제로 함

02 회답

「산지관리법」 제25조의4에 따라 토석채취제한지역에서 예외적으로 토석채취를 할 수 있는 경우라도 해당 토석채취제한지역에서 노천채굴을 위한 산지일시사용허가를 할 수 없습니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데²⁾, 「산지관리법」 제15조의2제5항에서는 산지일시사용허가의 절차, 기준, 조건, 기간·기간연장, 대상시설, 행위의 범위, 설치지역 및 설치조건 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제18조의2제3항 및 별표 3의2 제1호가목에서는 산지일시사용허가 대상 중 하나로 노천채굴에 관한 사항을 정하면서, 같은 목 설치지역란 본문에서는 산지전용·일시사용제한지역 및 토석채취제한지역이 아닌 산지에서 노천채굴을 위한 산지일시사용허가를 할 수 있는 것으로 규정하여, 같은 법 제25조의4 각 호에 따른 토석채취제한지역에서의 행위제한의 예외에 해당하는 경우인지 여부와 관계없이 ‘토석채취제한지역’이라면 노천채굴을 위한 산지일시사용허가를 할 수 없도록 규정하고 있고, 또한 같은 표 제1호가목 설치지역란 단서에서는 고령토의 굴취·채취는 토석채취제한 지역인 산지 중 일부에서 할 수 있다고 규정하여, 같은 란 본문에서 원칙적으로 토석채취제한 지역에서 노천채굴을 위한 산지일시사용허가를 할 수 없는 것으로 규정한 것에 대한 예외를 규정하고 있는바, 해당 단서 규정에서는 고령토의 경우 외에 토석채취제한지역에서 노천채굴을 위한 산지일시사용허가를 할 수 있도록 하는 예외적인 경우는 별도로 규정하고 있지 않으므로, 토석채취제한지역에서는 노천채굴을 위한 산지일시사용허가를 할 수는 없다고 할 것입니다.

그리고 「산지관리법 시행령」 별표 3의2 비고 제7호에서는 대통령령 제22513호 산지관리법 시행령 일부개정령 시행 당시 토석채취제한지역에서 종전의 규정에 따라 노천채굴을 위한 허가를 받아 그 허가 기간이 만료되지 않은 자가 그 허가받은 지역에 연접하여 노천채굴을 하려는 경우에는 해당 연접지역이 토석채취제한지역이더라도 그 지역을 ‘토석채취제한 지역이 아닌 산지로 보아’ 같은 별표 제1호가목의 기준에 따라 산지일시사용허가를 할 수

2) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

있다고 규정하고 있는바, 이는 광산업자의 기득권 보호, 한정된 광물자원 활용 등을 목적으로 예외적으로 토석채취제한지역임에도 불구하고 다른 요건이 충족되면 노천채굴을 위한 산지일시사용허가를 받을 수 있도록 한 것으로³⁾, 이처럼 토석채취제한지역에서 노천채굴을 위한 산지일시사용을 예외적으로 허용하는 경우에는 명시적 규정을 두어 한정적인 범위에서 일시적·제한적으로만 허용하는 점을 고려할 때, 명문의 근거 없이 토석채취제한지역에서 행위제한의 예외로 토석채취를 할 수 있다는 것만으로 노천채굴을 위한 산지일시사용허가를 받을 수 있다고 해석하기는 어렵습니다.

또한 「산지관리법」 제2조제2호에서는 산지전용(山地轉用)이란 산지를 ‘같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도 외’로 사용하거나 이를 위하여 산지의 형질을 변경하는 것이라고 정의하고 있는데, 같은 호 나목에서는 토석 등 임산물의 채취를 규정하고 있어, ‘토석의 채취’는 임산물 채취의 하나이므로 산지를 전용하는 것에 해당하지 않고, 같은 조 제3호가목에서는 산지일시사용이란 산지를 복구할 것을 조건으로 산지를 같은 조 ‘제2호가목부터 다목까지의 어느 하나에 해당하는 용도 외의 용도’로 일정기간 사용하거나 이를 위하여 산지의 형질을 변경하는 것이라고 정의하여, 토석의 채취는 산지일시사용에도 해당하지 않는바, 이러한 토석의 채취 행위는 산지일시사용허가 대상인 ‘광물의 채굴’ 등 산지를 본래의 용도 외의 용도로 사용하는 행위와 구별되는 행위로서, 같은 법 제25조, 제25조의3 및 제25조의4에 따른 토석채취허가, 토석채취제한지역 및 그 토석채취제한지역에서의 예외적 토석채취의 허용은 광물의 채굴 등을 위한 산지일시사용허가와 별개의 제도이므로, 이 사안과 같이 토석채취제한지역에서의 예외사유에 해당하여 토석채취를 할 수 있다는 것만으로 토석채취제한지역에서 노천채굴을 위한 산지일시사용허가를 할 수 있는 것으로 보는 것은 타당하지 않습니다.

아울러 「산지관리법 시행령」 별표 3의2 제1호에서 규정하고 있는 광물의 채굴 방법 중 갱도를 만들어 광물을 채굴하는 ‘굴진채굴’과는 달리 갱도 없이 표토만 제거하고 바로 채굴을 하는 ‘노천채굴’은 채굴 방법의 특성상 산림의 훼손이 더욱 과다하게 발생⁴⁾할 우려가 있고, 같은 표에서 노천채굴의 경우에만 산지일시사용허가를 받을 수 있는 지역으로 ‘토석채취제한지역이 아닌 산지’를 명시하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사안과 같이 토석채취제한지역에서 예외적으로 토석채취를 할 수 있는 사유에 해당한다는 것만으로는 노천채굴을 위한 산지일시사용을 허가할 수 없다고 해석하는 것이, 산지를 합리적으로 보전하고 이용하여 산림의 공익기능을 증진시키려는 「산지관리법」의 목적에 부합한다는 점도 이 사안을 해석할

3) 법제처 2013. 6. 4. 회신 13-0174 해석례 참조

4) 수원지방법원 2015. 12. 16. 선고 2015구합65446 판결례 참조

때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「산지관리법」 제25조의4에 따라 토석채취제한지역에서 예외적으로 토석채취를 할 수 있는 경우라도 해당 토석채취제한지역에서 노천채굴을 위한 산지일시사용허가를 할 수 없습니다.



관계법령

산지관리법

제15조의2(산지일시사용허가·신고) ① 「광업법」에 따른 광물의 채굴, 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」에 따른 광해방지사업, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목에 따른 태양에너지발전설비(이하 “산지태양광발전설비”라 한다)의 설치, 그 밖에 대통령령으로 정하는 용도로 산지일시사용을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장등의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. (단서 생략)

② ~ ④ (생 략)

⑤ 제1항 및 제4항에 따른 산지일시사용허가·신고의 절차, 기준, 조건, 기간·기간연장, 대상시설, 행위의 범위, 설치지역 및 설치조건 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑥ ~ ⑨ (생 략)

산지관리법 시행령

제18조의2(산지일시사용허가) ①·② (생 략)

③ 법 제15조의2제5항에 따른 산지일시사용허가의 대상시설·행위의 범위, 설치지역 및 설치조건·기준은 별표 3의2와 같다.

[별표 3의2]

산지일시사용허가의 대상시설·행위의 범위, 설치지역 및 설치조건·기준

(제18조의2제3항 관련)

1. 광물의 채굴 및 광해방지사업의 경우

대상시설·행위의 범위	설치지역	설치조건·기준
가. 노천채굴	산지전용·일시사용제한지역 및 토석채취제한지역이 아닌 산지. (단서 생략)	1) ~ 4) (생 략)

질의제목 3

▶ 안전번호 25-0161

민원인 - 「산림보호법」 제21조의9제4항제2호에 따른 산림이 아닌 지역의 수목을 대상으로 하는 산림 병해충 방제사업을 지방자치단체가 시행하는 경우 나무병원이 수행하도록 할 수 있는지(「산림보호법」 제21조의9제4항 관련)

01 질의요지

「산림보호법」 제21조의9제4항 본문에서는 나무병원¹⁾의 등록을 하지 아니하고는 같은 항 각 호의 수목을 대상으로 수목진료²⁾를 할 수 없다고 규정하면서, 같은 항 제2호에서는 산림이 아닌 지역의 수목을 규정하고 있고, 같은 항 단서에서는 국가 또는 지방자치단체가 산림병해충 방제사업을 시행하거나, 국가·지방자치단체 또는 수목의 소유자가 직접 수목진료를 하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바,

지방자치단체가 「산림보호법」 제21조의9제4항제2호에 따른 산림이 아닌 지역의 수목을 대상으로 하는 산림병해충 방제사업(이하 “이 사안 산림병해충 방제사업”이라 한다)을 시행하는 경우 나무병원이 수행³⁾하도록 할 수 있는지?

02 회답

지방자치단체가 이 사안 산림병해충 방제사업을 시행하는 경우 나무병원이 수행하도록 할 수 있습니다.

1) 수목진료 사업을 하려는 자로서 「산림보호법」 제21조의9제2항에 따라 등록증을 발급받은 자를 말하며(「산림보호법」 제2조제6호의5 참조), 이하 같음

2) 수목의 피해를 진단·처방하고, 그 피해를 예방하거나 치료하기 위한 모든 활동을 말하며(「산림보호법」 제2조제6호의2 참조), 이하 같음

3) 행정권한의 위임 또는 위탁이 아닌 용역계약을 체결하여 사업을 수행하는 경우를 전제로 함

03 이유

먼저 「산림보호법」 제2조에 따르면 “방제”는 산림병해충이 발생하지 않도록 예방하거나 이미 발생한 산림병해충을 약화시키거나 제거하는 모든 활동을 의미하고(제5호), “수목진료”는 수목의 피해를 진단·처방하고 그 피해를 예방하거나 치료하기 위한 모든 활동을 의미하므로(제6호의2) 산림병해충 방제는 수목진료의 행위 형태 중 하나에 해당⁴⁾합니다.

그런데 「산림보호법」 제21조의9제4항 본문에서는 나무병원의 등록을 하지 아니하고는 같은 항 각 호의 수목을 대상으로 수목진료를 할 수 없다고 규정하고 있고, 같은 항 단서에서는 국가 또는 지방자치단체가 산림병해충 방제사업을 시행하거나, 국가·지방자치단체 또는 수목의 소유자가 직접 수목진료를 하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바, 일반적으로 법령의 단서는 본문의 규정을 전제로 본문의 주된 내용에 대한 예외를 인정하거나 규율 대상 중 일부에 대해 달리 정할 필요가 있을 때 두는 것으로서⁵⁾ 단서의 의미를 해석할 때에는 본문의 내용을 바탕으로 그 의미를 파악해야 할 것이고, 「산림보호법」 제21조의9제4항 본문에서 수목진료를 할 수 있는 주체를 “나무병원”으로 한정하면서, 같은 항 단서에서 본문에 대한 예외로 나무병원의 등록을 하지 아니한 자도 수목진료의 한 형태인 산림병해충 방제사업을 할 수 있는 경우를 정하고 있는 것이므로, 이러한 「산림보호법」 제21조의9제4항의 규정 체계에 비추어 보면, 국가 또는 지방자치단체가 이 사안 산림병해충 방제사업을 시행하는 경우에 나무병원이 해당 사업을 수행하는 것을 배제하려는 의미로 해석하기는 어렵습니다.

그리고 「산림보호법」 제21조의9제1항에서는 수목진료 사업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 나무병원의 종류별 기술수준·자본금 등의 등록기준을 갖추어 시·도지사⁶⁾에게 등록해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항 본문에서는 나무병원의 등록을 하지 않고는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 산림, 산림이 아닌 지역의 수목을 대상으로 수목진료를 할 수 없다고 규정하여, 원칙적으로 산림 등에 대한 수목진료를 할 수 있는 주체를 나무병원으로 정하고 있는데, 이러한 나무병원제도는 전문화된 수목진료체계를 마련함으로써 국민들의 건강과 직결되는 생활권역의 산림병해충 관리를 안전하게 수행하고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위하여 도입된 것으로⁷⁾, 나무의사나 수목치료기술자 등 전문인력을 보유하고 있는 나무병원이 수목진료를 수행하도록 하여 체계적인 수목피해의

4) 법제처 2019. 7. 30. 회신 19-0163 해석례 참조

5) 법제처 2022. 2. 8. 회신 21-0887 해석례 참조

6) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사를 말하며, 이하 같음

7) 2016. 12. 27. 법률 제14519호로 일부개정된 「산림보호법」 개정이유 및 주요내용 참조

예방·진단·치료가 이루어질 수 있도록 한 것⁸⁾인바, 이와 같은 제도의 취지 등을 고려하면 지방자치단체가 시행하는 이 사안 산림병해충 방제사업의 경우 수목진료에 전문성을 갖추고 있는 나무병원이 이를 수행할 수 있다고 보는 것이 타당합니다.

아울러 「산림보호법」에 따른 산림병해충의 예방 및 방제를 위하여 시행하는 사업은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」(이하 “산림자원법”이라 함) 제2조제3호 및 같은 법 시행령 제2조제2항제5호에 따라 “산림사업”에 해당하는데, 산림자원법 제24조제1항에서는 산림사업을 하려는 자는 일정한 요건을 갖추어 산림사업의 종류별로 시·도지사에게 등록을 신청하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제7항제6호에서는 같은 조 제1항에도 불구하고 「산림보호법」 제21조의9에 따라 나무병원의 등록을 한 자(수목을 대상으로 하는 산림병해충 방제사업을 하는 경우에 한정한다)는 산림사업을 시행하는 법인(이하 “산림사업법인”이라 한다)의 등록을 하지 아니하고 산림사업을 할 수 있다고 규정하고 있는바, 나무병원의 경우 산림자원법에 따른 산림사업을 하기 위한 요건인 산림사업법인 등록을 하지 아니하고도 산림사업의 한 종류인 산림병해충 방제사업을 할 수 있도록⁹⁾ 관계 법령에서 규정하고 있는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 지방자치단체가 이 사안 산림병해충 방제사업을 시행하는 경우 나무병원이 수행하도록 할 수 있습니다.



관계법령

산림보호법

제21조의8(나무병원의 등록) ① ~ ③ (생 략)

④ 나무병원의 등록을 하지 아니하고는 다음 각 호의 수목을 대상으로 수목진료를 할 수 없다. 다만, 국가 또는 지방자치단체가 산림병해충 방제사업을 시행하거나, 국가·지방자치단체 또는 수목의 소유자가 직접 수목진료를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 산림(이하 이 항에서 “산림”이라 한다)에 서식하고 있는 수목
2. 산림이 아닌 지역의 수목(「농어업재해대책법」 제2조제4호에 따른 농작물은 제외한다)

⑤·⑥ (생 략)

8) 2016. 9. 23. 의안번호 제2002460호로 발의된 산림보호법 일부개정법률안에 대한 국회 농림축산식품해양수산위원회 심사보고서 참조

9) 2019. 1. 8. 법률 제16198호로 일부개정된 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 개정이유 및 주요내용 참조

질의제목 4

▶ 안전번호 25-0358

민원인 - 개인이 조성하는 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」 제4조제2항제6호에 따른 주제정원이 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 별표 1 제1호아목나)에 따라 개발제한구역에 설치할 수 없는 민간정원에 해당하는지(「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조 등 관련)

01 질의요지

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」(이하 “개발제한구역법”이라 함) 제12조제1항에서는 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치 등을 할 수 없다고 규정하면서(본문), 다만 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(이하 “시장·군수·구청장”이라 함)의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다고 규정하고(단서) 있고, 같은 항 제1호에서는 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 공작물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경을 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제13조제1항 및 별표 1에서는 같은 법 제12조제1항제1호에 따른 건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위를 규정하면서, 같은 영 별표 1 제1호아목나)에서는 개발제한구역의 보전 및 관리에 도움이 될 수 있는 시설로서 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」(이하 “수목원정원법”이라 함) 제2조제1호에 따른 수목원 및 같은 조 제1호의2에 따른 정원(같은 법 제4조제2항제3호의 민간정원은 제외함)과 그 안에 설치하는 시설을 말한다고 규정하고 있는 한편,

수목원정원법 제4조제2항에서는 정원은 조성·운영주체, 기능 및 주제에 따라 같은 항 각 호와 같이 구분한다고 규정하면서, 같은 항 각 호에서는 국가정원(제1호), 지방정원(제2호), 민간정원(제3호), 공동체정원(제4호), 생활정원(제5호), 주제정원(제6호)을 규정하고 있는바,

개인이 조성하는 수목원정원법 제4조제2항제6호에 따른 주제정원은 개발제한구역법 시행령 별표 1 제1호아목나)에 따라 개발제한구역에 설치할 수 없는 민간정원에 해당하는지?

02 회답

개인이 설치하는 수목원정원법 제4조제2항제6호에 따른 주제정원은 개발제한구역법 시행령 별표 1 제1호아목나)에 따라 개발제한구역에 설치할 수 없는 민간정원에 해당합니다.

03 이유

개발제한구역법 시행령 별표 1 제1호아목나)에서는 개발제한구역에 시장·군수·구청장의 허가를 받아 설치할 수 있는 시설로서 수목원정원법 제2조제1호의2에 따른 정원을 규정하되, 같은 법 제4조제2항제3호의 민간정원은 제외한다고 규정하고 있는바, 개인이 조성하는 수목원정원법 제4조제2항제6호에 따른 주제정원의 경우 주제정원임과 동시에 같은 항 제3호에 따른 민간정원으로 구분되어 개발제한구역에 설치할 수 없는 것인지 여부가 문제됩니다.

먼저 수목원정원법 제4조제2항에서는 정원은 조성·운영 주체, 기능 및 주제에 따라 같은 항 각 호와 같이 구분한다고 규정하면서 같은 항 제3호에서는 민간정원은 법인·단체 또는 개인이 조성·운영하는 정원이라고 규정하고 있고, 같은 항 제6호에서는 주제정원을 규정하면서 같은 호 각 목에서는 교육정원, 치유정원, 실습정원, 모델정원 등 주제정원의 세부 종류를 정하고 있는바, 개인이 조성·운영하는 수목원정원법 제4조제2항제6호에 따른 주제정원은 정원의 조성·운영의 주체 측면에서 민간정원으로서의 성격을 가지고, 정원의 기능 및 주제 측면에서 주제정원으로서의 성격을 갖고 있는데, 민간정원과 주제정원은 서로 배타적인 개념이 아니라 하나의 정원에 동시에 적용될 수 있는 개념이므로, 개인이 조성·운영하는 수목원정원법 제4조제2항제6호에 따른 주제정원은 수목원정원법 제4조제2항제3호에 따른 민간정원에도 해당된다고 할 것입니다.

그리고 종전에는 정원의 구분을 조성 및 운영주체에 따라서만 구분하고 있던 것을 2020년 12월 22일 법률 제17723호로 일부개정된 수목원정원법에서 정원 분야를 신산업으로 육성하여 부가가치를 창출하고, 국민들의 정원문화활동 참여를 확대하기 위하여 정원의 조성 및 운영주체뿐만 아니라 기능 및 주제에 따라 구분하면서 생활정원과 주제정원을 신설하여 정원의 종류를 확대한 것으로¹⁾, 정원은 어느 하나의 기능이나 성격만을 가진 것이 아니라 여러

1) 2020. 12. 22. 법률 제17723호로 일부개정되어 2021. 6. 23. 시행된 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」 개정이유

기능과 성격을 중첩적으로 가지고 있는 것이 일반적인 점²⁾, 종전에는 개발제한구역에 설치할 수 있는 시설인 개발제한구역의 존치 및 보전관리에 도움이 될 수 있는 시설로 수목원정원법 제2조제1호에 따른 수목원만 규정하고 있던 것을 2021년 5월 11일 대통령령 제31683호로 일부개정된 개발제한구역법 시행령 별표 1 제1호아목나)에서 수목원정원법 제2조제1호의2에 따른 정원까지 포함시키면서도, 개발제한구역의 관리를 위하여 민간정원은 제외한 점³⁾ 등을 고려하면, 하나의 정원이 그 기능이나 주제에 따라 주제정원에 해당하더라도 그 정원의 조성·운영주체가 법인·단체 또는 개인이라면 해당 정원은 동시에 민간정원에도 해당하므로 개발제한구역에 설치할 수 없다고 해석하는 것이 수목원정원법령 및 개발제한구역법령의 입법연혁 및 취지에 부합하는 해석입니다.

또한 개발제한구역법은 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하는 것을 목적으로 하는 법(제1조)으로서, 개발제한구역에서의 건축행위 및 용도변경 등의 행위를 원칙적으로 금지하면서 법령에서 정한 일정한 요건과 기준을 충족하는 행위에 대해서는 예외적이고 제한적으로 시장·군수·구청장의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있도록 규정(제12조)하고 있고, 이러한 예외적인 허용행위는 엄격하고 제한적으로 해석해야 하는데⁴⁾, 개발제한구역법 제12조제1항제1호가목 및 같은 법 시행령 제13조제1항 및 별표 제1호아목나)에서는 시장·군수·구청장의 허가를 받아 개발제한구역의 존치 및 보전관리에 도움이 될 수 있는 시설로서 예외적으로 개발제한구역에 설치할 수 있는 시설의 하나로 수목원정원법 제2조제1호의2에 따른 정원을 규정하되, 같은 법 제4조제2항제3호의 민간정원은 제외한다고 규정하고 있는바, 만약 수목원정원법 제4조제2항제6호에 따른 주제정원에 해당한다는 이유만으로 개인이 설치하는 주제정원을 민간정원에 해당하지 않는다고 해석한다면, 명문의 규정 없이 예외사유를 확대하여 해석하는 것으로 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 개인이 설치하는 수목원정원법 제4조제2항제6호에 따른 주제정원은 개발제한구역법 시행령 별표 1 제1호아목나)에 따라 개발제한구역에 설치할 수 없는 민간정원에 해당됩니다.

및 주요내용 참조

2) 2020. 6. 23. 의안번호 제2100856호로 발의된 수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 농림축산식품해양수산위원회 심사보고서

3) 2021. 5. 11. 대통령령 제31683호로 일부개정된 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」에 대한 입법예고안 참조

4) 법제처 2016. 7. 27. 회신 16-0203 해석례 참조



관계법령

개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법

제12조(개발제한구역에서의 행위제한) ① 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목(竹木)의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업(이하 “도시·군계획사업”이라 한다)의 시행을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(이하 “시장·군수·구청장”이라 한다)의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 공작물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경
 - 가. 공원, 녹지, 실외체육시설, 시장·군수·구청장이 설치하는 노인의 여가활용을 위한 소규모 실내 생활체육시설 등 개발제한구역의 존치 및 보전관리에 도움이 될 수 있는 시설
 - 나. 도로, 철도 등 개발제한구역을 통과하는 선형(線形)시설과 이에 필수적으로 수반되는 시설
 - 다. 개발제한구역이 아닌 지역에 입지가 곤란하여 개발제한구역 내에 입지하여야만 그 기능과 목적이 달성되는 시설
 - 라. 국방·군사에 관한 시설 및 교정시설
 - 마. 개발제한구역 주민과 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업의 추진으로 인하여 개발제한구역이 해제된 지역 주민의 주거·생활편익·생업을 위한 시설

1의2. ~ 9. (생략)

② ~ ⑪ (생략)

개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령

제13조(허가 대상 건축물 또는 공작물의 종류 등) ① 법 제12조제1항제1호에 따른 건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위는 별표 1과 같다.

② ~ ③ (생략)

[별표 1]

건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위(제13조제1항 관련)

시설의 종류	건축 또는 설치의 범위
1. 개발제한구역의 보전 및 관리에 도움이 될 수 있는 시설	
가. ~ 사.	(생략)
아. 휴양림, 산림욕장, 치유의 숲, 수목원, 정원 및 유아숲체험원	가) 「산림문화·휴양에 관한 법률」에 따른 자연휴양림, 산림욕장 및 치유의 숲과 그 안에 설치하는 시설(산림욕장의 경우 체육시설)

	은 제외한다)을 말한다. 나) 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 수목원 및 같은 조 제1호의2에 따른 정원(같은 법 제4조제2항제3호의 민간정원은 제외한다)과 그 안에 설치하는 시설을 말한다. 다)·라) (생략)
자. ~ 버.	(생략)
2. ~ 5.	(생략)

수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률

제4조(수목원 및 정원의 구분) ① (생략)

② 정원은 조성·운영 주체, 기능 및 주제에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 국가정원: 국가가 조성·운영하는 정원
2. 지방정원: 지방자치단체가 조성·운영하는 정원
3. 민간정원: 법인·단체 또는 개인이 조성·운영하는 정원
4. 공동체정원: 국가 또는 지방자치단체와 법인, 마을·공동주택 또는 일정지역 주민들이 결성한 단체 등(이하 “공동체”라 한다)이 공동으로 조성·운영하는 정원
5. 생활정원: 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로서 대통령령으로 정하는 기관이 조성·운영하는 정원으로서 휴식 또는 재배·가꾸기 장소로 활용할 수 있도록 유휴공간에 조성하는 개방형 정원
6. 주제정원
 - 가. 교육정원: 학생들의 교육 및 놀이를 목적으로 조성하는 정원
 - 나. 치유정원: 정원치유를 목적으로 조성하는 정원
 - 다. 실습정원: 정원 설계, 조성 및 관리 등을 통하여 전문인력 양성을 목적으로 조성하는 정원
 - 라. 모델정원: 정원산업 진흥을 위하여 새롭게 도입되는 정원 관련 기술을 활용하여 조성하는 정원
 - 마. 그 밖에 지방자치단체의 조례로 정하는 정원

③ 제2항 각 호에 따른 정원이 갖추어야 하는 시설의 종류 및 기준 등은 대통령령으로 정한다.

제3절 해양수산

질의제목 1

▶ 안전번호 24-0995

민원인 - 낚시 대상 수산동물을 낚기 위해 낚시도구를 물 속에 넣어 놓는 행위가 「낚시 관리 및 육성법」 제2조제1호에 따른 “낚시”에 해당하는지 여부(「낚시 관리 및 육성법」 제2조제1호 등 관련)

01 질의요지

「낚시 관리 및 육성법」(이하 “낚시관리법”이라 함) 제2조제1호에서는 “낚시”란 낚싯대와 낚싯줄·낚싯바늘 등 도구(이하 “낚시도구”라 함)를 이용하여 어류·패류·갑각류, 그 밖에 대통령령으로 정하는 수산동물(이하 “낚시 대상 수산동물”이라 함)을 낚는 행위를 말한다고 규정하고 있는바,

낚시 대상 수산동물을 낚기 위해 낚시도구를 물 속에 넣어 놓는 행위가 낚시관리법 제2조제1호에 따른 “낚시”에 해당하는지?

02 회답

낚시 대상 수산동물을 낚기 위해 낚시도구를 물 속에 넣어 놓는 행위는 낚시관리법 제2조제1호에 따른 “낚시”에 해당합니다.

03 이유

먼저 낚시관리법 제2조제1호에서는 “낚시”란 낚시도구를 이용하여 낚시 대상 수산동물을

낚는 행위를 말한다고 규정하고 있는데, 낚시도구를 물 속에 넣어 놓는 행위가 낚시 대상 수산동물을 낚기 위한 의도에서 비롯된 것이라면 이는 낚시 대상 수산동물이 낚이기를 기다리는 상황이라고 보는 것이 합리적일 것이고, 그렇다면 해당 행위는 낚시 대상 수산동물을 최종적으로 낚는 행위에 필수적으로 수반되는 행위로서 낚시의 전체 과정 중 일부에 해당한다고 보아야 할 것인바, ‘낚시도구를 물 속에 넣어 놓는 행위’와 ‘낚시 대상 수산동물을 최종적으로 낚는 행위’를 분리하여 후자에 해당하는 경우에만 같은 규정에 따른 “낚시”에 해당한다고 볼 수는 없을 것입니다.

그리고 낚시관리법 제5조제1항에서는 해양수산부장관은 수생태계와 수산자원의 보호 등을 위하여 낚시로 잡을 수 없는 수산동물의 종류·마릿수·체장(體長)·체중 등과 수산동물을 잡을 수 없는 낚시 방법·도구 및 시기 등에 관한 기준을 정할 수 있다고 규정하여, 낚시의 최종적 결과물인 수산동물에 대한 제한기준뿐만 아니라 낚시의 방법이나 도구 등 낚시의 과정에 대한 제한기준도 정할 수 있도록 하고 있고, 같은 법 제7조의2에서는 누구든지 “낚시로 포획한” 수산동물을 타인에게 판매하거나 판매할 목적으로 저장·운반 또는 진열하여서는 아니 된다고 규정하여, 낚시의 최종적 결과물로서 낚시 대상 수산동물을 낚은 경우에 대해서는 “포획”이라는 용어를 별도로 사용하고 있는바, 같은 법 제2조제1호에 따른 “낚시”는 낚시 대상 수산동물을 낚은 결과만을 의미하는 것이 아니라 낚시 대상 수산동물을 낚기 위한 전체 과정의 행위를 모두 포괄하는 것이라고 보는 것이 해당 법령의 문언 및 체계에 부합합니다.

또한 낚시관리법은 낚시로 인한 수산자원 남획과 환경오염 및 낚시인의 안전사고 등을 방지하기 위해 유해 낚시도구의 제조 등의 금지, 낚시인의 안전관리를 위한 조치명령 등을 정하여 낚시 관련 제도를 체계화하고 낚시를 건전한 국민레저 활동으로 육성하여 농어촌의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 기여하기 위해 제정된 법률¹⁾로서, 같은 법 제8조제1항 본문에서는 누구든지 수생태계와 수산자원의 보호에 지장을 주거나 수산물의 안전성을 해칠 수 있는 유해 낚시도구를 사용 또는 판매 등을 하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 같은 법 제40조제1항에서는 해양수산부장관은 미끼의 안전성 확보를 위해 미끼의 종류별로 특정물질의 함량기준(이하 “미끼기준”이라 함)을 설정할 수 있도록 규정하고 있는바, 낚시 대상 수산동물을 최종적으로 낚지 않은 경우라 하더라도 만일 유해 낚시도구 또는 미끼기준에 미달하는 미끼를 이용한 낚시도구를 물 속에 넣어 놓는다면 이로 인해 수생태계가 파괴되거나 인체의 건강에 위험을 미칠 우려가 있는 점, 같은 법 제9조제1항에서는 시장·군수·구청장 또는 관할 해양경찰서장은 낚시인의 생명과 신체의 안전을 확보하기 위해 기상악화 등의

1) 2011. 3. 9. 법률 제10458호로 제정된 「낚시 관리 및 육성법」 제정이유 참조

경우에는 낚시인에게 안전한 장소로의 이동, 위험지역의 출입금지 등의 조치를 명할 수 있다고 규정하고 있는바, 이러한 조치명령은 위험하거나 격리된 장소에서 낚시를 할 경우 기상변동 등에 따른 사고발생의 우려가 크기 때문에 이를 방지하기 위해 도입²⁾된 규정임을 고려할 때, 낚시 대상 수산동물을 낚기 위해 낚시도구를 물 속에 넣어 놓기만 하는 경우에도 해당 규정이 동일하게 적용되는 것으로 보아야 낚시인의 안전을 효과적으로 관리할 수 있을 것이라는 점 등을 종합적으로 고려해보면, 낚시관리법은 낚시의 최종적인 결과로서 낚시 대상 수산동물을 낚은 행위만을 규율대상으로 하는 것이 아니라, 낚시도구를 물 속에 넣어 놓는 행위를 포함하여 낚시 대상 수산동물을 낚기 위한 과정의 모든 행위를 규율대상으로 한다고 보아야 할 것입니다.

따라서 낚시 대상 수산동물을 낚기 위해 낚시도구를 물 속에 넣어 놓는 행위는 낚시관리법 제2조제1호에 따른 “낚시”에 해당합니다.



관계법령

낚시 관리 및 육성법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “낚시”란 낚시대와 낚시줄·낚시바늘 등 도구(이하 “낚시도구”라 한다)를 이용하여 어류·패류·갑각류, 그 밖에 대통령령으로 정하는 수산동물을 낚는 행위를 말한다.
2. ~ 10. (생략)

2) 2010. 2. 5. 의안번호 제1807552호로 발의된 낚시 관리 및 육성법안에 대한 국회 농림수산식품위원회 검토보고서 참조

질의제목 2

▶ 안전번호 25-0282

충청남도 - 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제53조제1항제1호에 따라 공유수면 매립면허의 효력이 상실되면 해당 매립예정지별 매립계획도 해제된 것으로 보아야 하는지(「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제25조 등 관련)

01 질의요지

「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」(이하 “공유수면법”이라 함) 제25조제1항에서는 매립면허를 받으려는 자는 같은 법 제24조와 제26조에 따라 수립·고시된 매립예정지별 매립계획에 따라 5년 이내에 제28조에 따른 매립면허를 받아야 한다고 규정하면서, 같은 법 제25조제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 기간 내에 매립면허를 받지 아니한 경우에는 그 기간이 지난 다음 날부터 해당 매립예정지별 매립계획이 해제된 것으로 본다고 규정하고 있는 한편, 같은 법 제53조제1항제1호에서는 공유수면 매립면허를 받은 날부터 1년 이내에(연장 시 2년) 매립실시계획의 승인을 받지 아니한 경우에 매립면허는 그 효력을 상실한다고 규정하고 있는바,

공유수면법 제28조제1항에 따라 취득한 공유수면 매립면허가 같은 법 제53조제1항제1호에 따라 그 효력이 상실된 경우, 매립면허의 효력이 상실된 날이 매립예정지별 매립계획의 고시일부터 5년이 경과된 후라면 같은 법 제25조제2항¹⁾에 따라 매립예정지별 매립계획이 해제된 것으로 보아야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 매립면허의 효력이 상실된 날이 매립예정지별 매립계획의 고시일부터 5년이 경과된 후라면 공유수면법 제25조제2항에 따라 매립예정지별 매립계획이 해제된 것으로 볼 수는 없습니다.

1) 공유수면법 제53조제3항에 따른 매립면허의 효력 회복 기간(매립면허의 효력이 상실된 날부터 3개월)을 경과한 경우를 전제로 함

03 이유

이 사안은 이미 취득한 공유수면 매립면허가 매립예정지별 매립계획의 고시일부터 5년이 지난 후 공유수면법 제53조제1항에 따라 그 매립면허의 효력이 상실되는 경우에 이를 공유수면법 제25조제2항에 따른 “매립면허를 받지 아니한 경우”에 해당하는 것으로 보아 매립예정지별 매립계획이 해제된 것으로 보아야 하는지 여부에 관한 것입니다.

먼저 공유수면법 제53조에서는 매립면허의 효력 상실에 대해 규정하면서, 같은 조 제1항에서는 매립면허의 효력이 상실되는 사유를 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 매립면허관청은 매립면허취득자의 귀책사유가 아닌 천재지변이나 불가항력 등으로 같은 조 제1항 각 호에 해당하게 되어 매립면허의 효력이 상실되는 경우에는 효력이 상실된 매립면허를 효력이 상실된 날부터 3개월 이내에 소급하여 회복시킬 수 있도록 규정하고 있는데, 이처럼 매립면허의 효력 회복에 관한 규정을 둔 것은 매립면허의 효력이 상실되더라도 매립예정지별 매립계획이 유효하게 존재하고 있음을 전제한 것으로 보이는바²⁾, 같은 조 제1항에 따라 면허의 효력이 상실되는 경우에 당연히 매립예정지별 매립계획이 해제된다고 보기는 어렵습니다.

또한 공유수면법 제54조제1항에서는 공유수면의 원상회복 의무에 대해 규정하면서 원상회복 의무가 있는 자로 ‘매립면허를 받지 아니하고’ 공유수면을 매립한 자(제1호)와 자기의 귀책사유로 ‘매립면허가 실효(失効)·소멸되거나 취소’된 자(제2호)를 별도의 호로 각각 구분하여 규정하고 있는데, 이러한 규정 체계를 고려하면 “매립면허를 받지 아니한 경우”에 이미 획득한 매립면허의 효력이 상실된 경우가 당연히 포함된다고 해석하기도 어려운바, 이미 획득한 매립면허의 효력이 매립예정지별 매립계획의 고시일부터 5년이 경과된 후 상실된 경우에 공유수면법 제25조제2항이 적용되어 매립예정지별 매립계획이 해제된 것으로 해석하기는 어렵습니다.

그리고 공유수면법 제25조에서는 매립면허를 받으려는 자는 매립예정지별 매립계획에 따라 5년 이내에 매립면허를 받아야 한다고 규정하면서, 해당 기간 내에 매립면허를 받지 아니한 경우에는 그 기간이 지난 다음 날부터 해당 매립예정지별 매립계획이 해제된 것으로 본다³⁾고 규정하고 있어, 공유수면법 제25조제1항에서는 일정한 기간 안에 매립면허를 받아야 한다는 의무만을 규정하고 있을 뿐, 해당 기간이 도과한 이후에도 이미 획득한 매립면허가 유지되어야 한다는 의무에 대해서는 규정하고 있지 않고, 매립예정지별 매립계획의

2) 법제처 2019. 10. 7. 회신 19-0085 해석례 참조

고시일부터 5년이 지난 후 같은 법 제53조에 따라 매립면허가 실효되는 경우라도 해당 매립계획의 고시일부터 5년이 되는 시점에서는 매립면허가 유효하였으므로 공유수면법 제25조제2항이 적용되기는 어려운 점, 같은 법 제25조제2항에 따라 매립계획이 해제되게 되면 매립계획을 새로 마련해야 하고 이를 위한 상당한 비용과 기간이 소요되므로 매립계획의 해제의 요건에 대해서는 엄격하게 해석할 필요가 있는 점 등을 고려하면, 같은 법 제28조에 따라 이미 획득한 매립면허의 효력이 상실된 경우를 해당 매립예정지별 매립계획이 해제된 것으로 보는 것은 타당하지 않습니다.³⁾

아울러 공유수면법 제27조제1항에서는 해양수산부장관은 매립기본계획의 타당성을 5년마다 검토하고, 검토 결과 매립예정지별 매립계획의 추가 또는 해제 등의 사유가 있으면 매립기본계획의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항에도 불구하고 해양수산부장관이 공유수면의 매립과 관련한 산업의 발전, 법령에 따라 수립된 계획의 변경, 그 밖에 주변여건의 변화 등으로 인하여 필요한 경우에는 직권으로 매립기본계획을 변경할 수 있도록 규정하고 있는바, 매립계획의 해제가 필요한 경우 해양수산부장관이 매립기본계획의 변경을 통해 매립예정지별 매립계획의 해제가 가능하다는 점, 매립예정지별 매립계획의 해제 등에 관하여 규정하고 있는 공유수면법 제25조의 입법 취지는 기득권 확보를 목적으로 일단 공유수면 매립기본계획에 반영시킨 후 실제로는 매립면허를 받지 아니하는 폐단을 방지하기 위한 것으로서⁴⁾, 공유수면법 제28조에 따라 이미 공유수면 매립면허를 받았으나 같은 법 제53조제1항제1호의 요건을 충족하지 못하여 매립면허의 효력이 상실되는 경우에까지 같은 법 제25조를 적용하려는 취지는 아닌 것으로 보이는 점 등도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 매립면허의 효력이 상실된 날이 매립예정지별 매립계획의 고시일부터 5년이 경과된 후라면 공유수면법 제25조제2항에 따라 매립예정지별 매립계획이 해제된 것으로 볼 수는 없습니다.

3) 대법원 2011. 8. 25. 선고 2011도7725 판결례 참조

4) 2007. 12. 27. 법률 제8820호로 일부개정된 「공유수면매립법」 개정이유 및 주요내용 참조

**공유수면 관리 및 매립에 관한 법률**

제25조(매립예정지별 매립계획의 해제 등) ① 매립면허를 받으려는 자는 제24조와 제26조에 따라 수립·고시된 매립예정지별 매립계획에 따라 5년 이내에 제28조에 따른 매립면허를 받아야 한다.

② 제1항에 따른 기간 내에 매립면허를 받지 아니한 경우에는 그 기간이 지난 다음 날부터 해당 매립예정지별 매립계획이 해제된 것으로 본다.

③ (생략)

제38조(공유수면매립실시계획의 승인) ① 매립면허취득자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공유수면매립실시계획(이하 “매립실시계획”이라 한다)을 수립하여 매립면허관청의 승인을 받아야 한다. 승인받은 내용을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② (생략)

③ 매립면허취득자는 매립면허를 받은 날부터 1년 이내에 매립실시계획의 승인을 받아야 한다. 다만, 천재지변 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있으면 매립면허관청으로부터 1년의 범위에서 한 번만 그 기간을 연장받아 승인을 받을 수 있다.

④·⑤ (생략)

제53조(매립면허의 효력 상실 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 매립면허는 그 효력을 상실한다.

1. 제38조제3항에 따른 기간 내에 매립실시계획의 승인을 받지 아니한 경우
2. 매립실시계획에서 정한 공사착공일에 매립공사를 착수하지 아니한 경우
3. 매립실시계획에서 정한 기간 내에 매립공사를 준공하지 아니한 경우

② (생략)

③ 매립면허관청은 매립면허취득자의 귀책사유가 아닌 천재지변이나 불가항력 등으로 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 같은 항에 따라 효력이 상실된 매립면허를 효력이 상실된 날부터 3개월 이내에 소급하여 회복시킬 수 있다.

④ 매립면허관청은 제1항제3호에 해당되어 매립면허의 효력이 상실된 자가 대통령령으로 정하는 공정 이상 매립공사를 시행한 경우에는 같은 항에 따라 효력이 상실된 매립면허를 효력이 상실된 날부터 1년 이내에 소급하여 회복시킬 수 있다.

⑤ (생략)

CHAPTER

7

보건복지·식품의약품

제1절 보건복지
제2절 식품의약품

제1절 보건복지

질의제목 1

▶ 안전번호 24-0855

보건복지부 - 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제35조제1항에 따른 지역사회보장계획이 「사회보장기본법」 제19조제1항에 따른 지역계획에 해당하는지(「사회보장기본법」 제19조 및 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제35조 등 관련)

01 질의요지

「사회보장기본법」 제3조제1호에서는 “사회보장”이란 출산, 양육, 실업, 노령, 장애, 질병, 빈곤 및 사망 등의 사회적 위험으로부터 모든 국민을 보호하고 국민 삶의 질을 향상시키는데 필요한 소득·서비스를 보장하는 사회보험, 공공부조, 사회서비스를 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제19조제1항에서는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사·시장¹⁾·군수·구청장²⁾은 관계 법령으로 정하는 바에 따라 사회보장에 관한 지역계획(이하 “지역계획”이라 함)을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있으며, 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」(이하 “사회보장급여법”이라 함) 제35조제1항 전단에서는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 함) 및 시장·군수·구청장은 지역사회보장에 관한 계획(이하 “지역사회보장계획”이라 함)을 4년마다 수립하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제37조제1항에서는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 지역사회보장계획을 시행하여야 한다고 규정하고 있는바,

사회보장급여법 제35조제1항에 따른 지역사회보장계획이 「사회보장기본법」 제19조제1항에 따른 지역계획에 해당하는지?

1) 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제11조제1항에 따른 행정시장을 포함함

2) 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음

02 회답

사회보장급여법 제35조제1항에 따른 지역사회보장계획은 「사회보장기본법」 제19조제1항에 따른 지역계획에 해당합니다.

03 이유

「사회보장기본법」 제19조제1항에서는 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 관계 법령으로 정하는 바에 따라 지역계획을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있고, 사회보장급여법 제35조제1항 전단 및 같은 법 제37조제1항에서는 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 지역사회보장계획을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있는데, 「사회보장기본법」 제19조제1항에 따른 지역계획과 사회보장급여법 제35조제1항에 따른 지역사회보장계획의 관계에 관해서는 「사회보장기본법」 및 사회보장급여법에서 명시적으로 규정하고 있지 않은바, 이를 판단하기 위해서는 두 법률의 체계 및 규율대상, 입법 취지와 연혁 등을 종합적으로 살펴보아야 합니다.

먼저 「사회보장기본법」은 사회보장에 관한 국민의 권리와 국가 및 지방자치단체의 책임을 정하고 사회보장정책의 수립·추진과 관련 제도에 관한 기본적인 사항을 규정하는 법률(제1조)로서, 여러 법령에서 규정하고 있는 사회보장과 관련된 사항의 기본 원칙 및 정책 방향 등을 규정한 ‘기본법’의 성격을 가지고 있다고 할 것³⁾이고, 사회보장급여법은 「사회보장기본법」에 따른 사회보장급여의 이용 및 제공에 관한 기준과 절차 등을 규정하는 법률로서⁴⁾, 「사회보장기본법」에서 규정한 기본적인 원칙과 정책 방향에 부합되도록 사회보장급여의 신청, 조사, 결정·지급, 사후관리에 이르는 복지대상자 선정과 지원에 필요한 일련의 절차 및 방법 등에 관한 사항을 구체적으로 정하고 있는 것⁵⁾인바, 이러한 두 법률 간의 관계를 고려할 때 사회보장급여법 제35조 및 제37조에 따라 수립·시행하는 지역사회보장계획은 「사회보장기본법」 제19조에서 “관계 법령에서 정하는 바에 따라” 수립·시행하도록 규정한 지역계획에 해당한다고 할 것이고, 그 수립·시행 및 절차 등에 관한 사항을 사회보장급여법 및 그 하위법령에서 세부적으로 규정하고 있는 것으로 보는 것이 합리적인 해석입니다.

3) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.727 참조

4) 사회보장급여법 제1조 참조

5) 2014. 12. 30. 법률 제12935호로 제정되어 2015. 7. 1. 시행된 사회보장급여법 제정이유 참조

특히 「사회보장기본법」 및 사회보장급여법의 규정 체계를 구체적으로 살펴보면, 「사회보장기본법」 제19조제1항에서는 ‘시·도지사 및 시장·군수·구청장’은 관계 법령으로 정하는 바에 따라 지역계획을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 지역계획은 ‘기본계획과 연계’되어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제40조에서는 국가와 지방자치단체는 국민생활에 중대한 영향을 미치는 사회보장 계획 및 정책을 수립하려는 경우 공청회 및 정보통신망 등을 통하여 ‘국민과 관계 전문가의 의견을 충분히 수렴’하여야 한다고 규정하고 있는데, 사회보장급여법 제35조제1항 전단 및 같은 법 제37조제1항에서는 ‘시·도지사 및 시장·군수·구청장’은 지역사회보장계획을 수립·시행하여야 한다고 규정하면서, 같은 법 제35조제1항 후단에서 지역사회보장계획을 수립하는 경우 「사회보장기본법」 제16조에 따른 ‘기본계획과 연계’되도록 하여야 한다고 규정하고 있으며, 사회보장급여법 제35조제2항 및 제4항에서는 지역사회보장계획은 ‘지역주민 등 이해관계인의 의견’을 들은 후 수립하여야 한다고 규정하고 있는바, 「사회보장기본법」 제19조제1항에 따른 지역계획과 사회보장급여법 제35조제1항에 따른 지역사회보장계획은 그 계획의 수립 주체, 「사회보장기본법」 제16조에 따른 기본계획과의 연계 의무 및 의견청취 의무를 동일하게 규정하고 있는 등 두 계획이 실질적으로 차이가 있다고 보기 어렵고, 다만 사회보장급여법에서는 「사회보장기본법」 제19조에서 규정한 지역계획의 수립·시행 등에 관한 사항에 더하여 해당 계획의 내용(제36조), 변경(제38조), 시행결과의 평가(제39조) 등 세부적인 사항에 대하여 구체적으로 규정한 것이라고 할 것입니다.

더욱이 「사회보장기본법」 제19조는 2012년 1월 26일 법률 제11238호로 전부개정된 「사회보장기본법」에서 신설된 규정으로, 여러 부처에서 사회보장정책을 관장함에 따라 일관성 있고 효과적인 정책 수립 및 집행에 한계가 있다는 점을 보완하기 위해 같은 법에 따라 사회보장제도를 확대·재정립⁶⁾하면서, 사회보장에 관한 기본계획(제16조), 연도별 시행계획(제18조), 지역계획(제19조)으로 구성된 체계의 일환으로 규정된 것이고, 사회보장급여법은 이러한 「사회보장기본법」에 따른 맞춤형 사회보장제도를 실현하기 위한 세부적인 실행방안과 절차가 미비한 점을 보완하기 위해 제정된 법률로서⁷⁾, 사회보장급여법 제35조는 주민에게 다양한 사회보장급여를 제공하기 위해 시·도지사 및 시장·군수·구청장으로 하여금 「사회보장기본법」 제16조에 따른 사회보장에 관한 기본계획과 연계된 지역사회보장계획을 수립·시행하도록 하기 위하여 마련된 규정인바⁸⁾, 「사회보장기본법」에서 도입한 지역계획의

6) 2012. 1. 26. 법률 제11238호로 전부개정된 「사회보장기본법」 개정이유 및 주요내용 참조

7) 2014. 12. 30. 법률 제12935호로 제정된 사회보장급여법 제정이유 참조

8) 2014. 12. 30. 법률 제12935호로 제정된 사회보장급여법 주요내용 참조

세부적 사항에 대한 규정이 미비했던 것을 사회보장급여법에서 「사회보장기본법」에 따른 기본계획과 연계된 지역사회보장계획으로 규정한 것이라고 해석하는 것이 해당 법령의 입법 취지 및 연혁에 부합하는 해석입니다.

따라서 사회보장급여법 제35조제1항에 따른 지역사회보장계획은 「사회보장기본법」 제19조제1항에 따른 지역계획에 해당합니다.

법령정비 권고사항

사회보장급여법 제35조제1항에 따른 지역사회보장계획과 「사회보장기본법」 제19조제1항에 따른 지역계획의 관계를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

사회보장기본법

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “사회보장”이란 출산, 양육, 실업, 노령, 장애, 질병, 빈곤 및 사망 등의 사회적 위험으로부터 모든 국민을 보호하고 국민 삶의 질을 향상시키는 데 필요한 소득·서비스를 보장하는 사회보험, 공공부조, 사회서비스를 말한다.
2. ~ 6. (생략)

제19조(사회보장에 관한 지역계획의 수립·시행 등) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사·시장(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제11조제1항에 따른 행정시장을 포함한다)·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관계 법령으로 정하는 바에 따라 사회보장에 관한 지역계획(이하 “지역계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

②·③ (생략)

사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률

제35조(지역사회보장에 관한 계획의 수립) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 및 시장·군수·구청장은 지역사회보장에 관한 계획(이하 “지역사회보장계획”이라 한다)을 4년마다 수립하고, 매년 지역사회보장계획에 따라 연차별 시행계획을 수립하여야 한다. 이 경우 「사회보장기본법」 제16조에 따른 사회보장에 관한 기본계획과 연계되도록 하여야 한다.

② ~ ⑨ (생략)

제37조(지역사회보장계획의 시행) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 지역사회보장계획을 시행하여야 한다.

② (생략)

질의제목 2

▶ 안전번호 25-0075

보건복지부 - 「실종아동등의 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조제1호나목의 「장애인복지법」 제2조의 장애인 중 지적장애인, 자폐성장애인 또는 정신장애인은 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록한 장애인으로 한정되는지(「실종아동등의 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조제1호나목 등 관련)

01 질의요지

「실종아동등의 보호 및 지원에 관한 법률」(이하 “실종아동법”이라 함) 제2조제1호나목에서는 “아동등”에 해당하는 사람으로 「장애인복지법」 제2조의 장애인 중 지적장애인, 자폐성장애인 또는 정신장애인을 규정하고 있고, 「장애인복지법」 제2조제1항에서는 “장애인”이란 신체적·정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 자를 말한다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서 「장애인복지법」을 적용받는 장애인은 같은 조 제1항에 따른 장애인 중 주요 외부 신체 기능의 장애, 내부기관의 장애 등 신체적 장애(제1호), 발달장애 또는 정신 질환으로 발생하는 정신적 장애(제2호) 중 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 자로서 대통령령으로 정하는 장애의 종류 및 기준에 해당하는 자를 말한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제32조제1항에서는 장애인, 그 법정대리인 또는 대통령령으로 정하는 보호자(이하 “법정대리인등”이라 함)는 장애 상태와 그 밖에 보건복지부령이 정하는 사항을 시장·군수등¹⁾에게 등록하여야 한다고 규정하고 있는바,

실종아동법 제2조제1호나목의 「장애인복지법」 제2조의 장애인 중 지적장애인, 자폐성장애인 또는 정신장애인은 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록한 장애인으로 한정되는지?

02 회답

실종아동법 제2조제1호나목의 「장애인복지법」 제2조의 장애인 중 지적장애인, 자폐성장애인 또는 정신장애인은 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록한 장애인으로 한정되지 않습니다.

1) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장을 말하며(「장애인복지법」 제32조제1항 참조), 이하 같음

03 이유

실종아동법 제2조제1호나목에서는 「장애인복지법」 제2조의 장애인 중 지적장애인, 자폐성장애인 또는 정신장애인(이하 “지적장애인등”이라 함)을 “아동등”에 해당하는 사람으로 규정하고 있는데, 「장애인복지법」의 장애인의 의미에 대해 살펴보면, 「장애인복지법」 제2조제1항에서 “장애인”이란 신체적·정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 자를 말한다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서 같은 법을 적용받는 장애인은 제1항에 따른 장애인 중 주요 외부 신체 기능의 장애, 내부기관의 장애 등을 말하는 신체적 장애(제1호), 발달장애 또는 정신 질환으로 발생하는 장애를 말하는 정신적 장애(제2호) 중 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 자로서 대통령령으로 정하는 장애의 종류 및 기준에 해당하는 자를 말한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제2조 및 별표 1에서는 지체장애인(제1호), 뇌병변장애인(제2호), 지적장애인(제6호), 자폐성장애인(제7호), 정신장애인(제8호) 등 장애의 종류 및 기준에 대해서 규정하고 있는바, 실종아동법 제2조제1호나목에서는 “아동등”에 대해 「장애인복지법」 제2조에 따른 지적장애인등으로만 규정하고 있을 뿐, 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록(이하 “장애인등록”이라 함)한 장애인이어야 한다는 내용은 별도로 규정하고 있지 않습니다.

그런데 실종아동법은 실종아동등의 발생을 예방하고 조속한 발견과 복귀를 도모하며 복귀 후의 사회 적응을 지원함으로써 실종아동등과 가정의 복지증진에 이바지함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 매년 평균 3천여명의 아동과 지적장애인등이 실종되는 상황에서 이들의 미귀가가 장기화되는 경우 가정해체 등 심각한 문제가 초래되므로 아동등의 실종으로 인한 본인 및 그 가족의 신체적·정신적·경제적 고통을 경감하고 가정해체에 따른 사회적·국가적 손실을 방지하기 위하여 국가 차원에서 체계적이고 효율적인 실종아동 관련 시스템을 마련하려는 취지에서 제정²⁾된 것인바, 실종아동법의 보호 대상인 “아동등”에 「장애인복지법」에 따른 장애인등록이 된 사람만이 포함된다고 명시적으로 규정하고 있지 않은 이상, 「장애인복지법」 제2조의 장애인 중 지적장애인, 자폐성장애인 또는 정신장애인에 해당한다면 장애인등록 여부와 관계 없이 실종아동법의 보호 대상에 포함되는 것으로 보아 이들이 실종된 경우 조속한 발견과 복귀를 도모할 수 있도록 하는 것이 실종아동법의 규정 체계 및 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

2) 2005년 5월 31일 법률 제7560호로 제정된 실종아동법 제정이유 참조

또한 「장애인복지법」은 장애인의 자립생활·보호 및 수당지급 등에 관하여 필요한 사항을 정하여 장애인의 생활안정에 기여하는 등 장애인의 복지와 사회활동 참여를 증진하기 위한 법률로서, 같은 법 제32조제1항에서 법정대리인등은 장애 상태와 그 밖에 보건복지부령이 정하는 사항을 시장·군수등에게 등록하여야 한다고 규정하고 있고, 이에 따라 장애인등록을 하면 같은 법 제49조에 따른 장애수당 지급 등의 혜택을 받을 수 있게 되며, 같은 법 시행규칙 제3조제2항에 따르면 장애인등록 신청에 대해 장애유형별 해당 전문의가 있는 의료기관에 장애 진단을 의뢰할 수 있도록 규정하고 있어, 장애인등록 신청을 하더라도 그 등록 요건에 해당하는 자만이 장애인으로 등록할 수 있는데, 「장애인복지법」에 따른 장애인의 복지와 사회활동 참여증진을 위해 필요한 장애인등록을 하지 않았다는 이유로, 실종아동의 조속한 발견과 복귀를 목적으로 하는 실종아동법에서 규정하고 있는 지적장애인등에 해당하지 않는 것으로 보아 실종아동법의 보호 대상에서 제외하는 것은 타당하지 않습니다.

따라서 실종아동법 제2조제1호나목의 지적장애인등은 장애인등록을 한 장애인으로 한정되지 않습니다.



관계법령

실종아동등의 보호 및 지원에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “아동등”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.
 - 가. 실종 당시 18세 미만인 아동
 - 나. 「장애인복지법」 제2조의 장애인 중 지적장애인, 자폐성장애인 또는 정신장애인
 - 다. 「치매관리법」 제2조제2호의 치매환자
2. “실종아동등”이란 약취(略取)·유인(誘引) 또는 유기(遺棄)되거나 사고를 당하거나 가출하거나 길을 잃는 등의 사유로 인하여 보호자로부터 이탈(離脫)된 아동등을 말한다.
3. ~ 7. (생 략)

장애인복지법

제2조(장애인의 정의 등) ① “장애인”이란 신체적·정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 자를 말한다.

② 이 법을 적용받는 장애인은 제1항에 따른 장애인 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장애가 있는 자로서 대통령령으로 정하는 장애의 종류 및 기준에 해당하는 자를 말한다.

1. “신체적 장애”란 주요 외부 신체 기능의 장애, 내부기관의 장애 등을 말한다.
2. “정신적 장애”란 발달장애 또는 정신 질환으로 발생하는 장애를 말한다.

③·④ (생 략)

제32조(장애인 등록) ① 장애인, 그 법정대리인 또는 대통령령으로 정하는 보호자(이하 “법정대리인등”이라 한다)는 장애 상태와 그 밖에 보건복지부령이 정하는 사항을 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 등록하여야 하며, 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 등록을 신청한 장애인이 제2조에 따른 기준에 맞으면 장애인등록증(이하 “등록증”이라 한다)을 내주어야 한다.

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항에 따른 장애인 등록 및 제3항에 따른 장애 상태의 변화에 따른 장애 정도를 조정함에 있어 장애인의 장애 인정과 장애 정도 사정이 적정한지를 확인하기 위하여 필요한 경우 대통령령으로 정하는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관에 장애 정도에 관한 정밀심사를 의뢰할 수 있다.

⑦·⑧ (생 략)

⑨ 제1항, 제3항, 제5항, 제6항 및 제8항에서 규정한 사항 외에 장애인의 등록, 등록증의 발급, 장애 진단 및 장애 정도에 관한 정밀심사, 등록증의 진위 또는 유효 여부 확인 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

질의제목 3

▶ 안전번호 25-0192

전라남도 함평군 - 사원 소유의 정원·산림·경작지 및 초지로서 해당 사원과 지리적·공간적으로 관련성이 없는 경우에도 「장사 등에 관한 법률 시행령」 별표 4 제3호마목1)에서 규정하고 있는 사원 경내에 해당하는지(「장사 등에 관한 법률 시행령」 별표 4 제3호마목 등 관련)

01 질의요지

「장사 등에 관한 법률 시행령」(이하 “장사법 시행령”이라 함) 별표 4 제3호마목에서는 종교단체가 조성하는 자연장지¹⁾에는 관리사무실, 유족편의시설, 공동분향단, 그 밖의 필요한 시설과 폭 5미터 이상의 진입로 및 주차장(이하 “편의시설”이라 함)을 마련하여야 하고, 다만 편의시설이 갖추어진 기존의 사원²⁾ 경내에 자연장지를 조성하는 경우에는 이러한 시설을 따로 설치하지 아니할 수 있다[같은 목 1)]고 규정하고 있는바,

사원 소유의 정원·산림·경작지 및 초지로서 해당 사원과 지리적·공간적으로 관련성이 없는 경우에도 장사법 시행령 별표 4 제3호마목1)에서 규정하고 있는 사원 경내(이하 “사원경내”라 함)에 해당하는지?

02 회답

사원 소유의 정원·산림·경작지 및 초지로서 해당 사원과 지리적·공간적으로 관련성이 없는 경우에는 사원경내에 해당하지 않습니다.

03 이유

「장사 등에 관한 법률」(이하 “장사법”이라 함) 제16조제1항에서는 국가, 시·도지사 또는

1) 화장한 유골의 골분(骨粉)을 수목·화초·잔디 등의 밑이나 주변에 묻거나 해양 등에 뿌려 장사하는 자연장으로 장사할 수 있는 구역을 말하며(「장사 등에 관한 법률」 제2조제3호 및 제13호 참조), 이하 같음

2) 이 사안은 「전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률」상 전통사찰로 등록된 기존의 사원인 경우를 전제로 함

시장·군수·구청장이 아닌 자는 같은 항 각 호의 구분에 따라 수목장림이나 그 밖의 자연장지(이하 “사설자연장지”라 함)를 조성할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제9항에서는 사설자연장지의 종류별 면적, 자연장지에 설치하는 표지의 규격, 사설자연장지에 설치가 허용되는 편의시설의 종류 및 설치기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제21조제1항에서는 같은 법 제16조제9항에 따른 사설자연장지³⁾의 종류별 면적, 표지의 규격, 편의시설의 종류 및 설치기준은 별표 4와 같다고 규정하면서, 같은 영 별표 4 제3호마목 본문에서는 종교단체가 조성하는 자연장지에는 편의시설을 마련하여야 하고, 같은 목 단서 및 1)에서는 다만 편의시설이 갖추어진 기존의 사원 경내에 자연장지를 조성하는 경우에는 이러한 시설을 따로 설치하지 아니할 수 있다고 규정하고 있는데, 장사법령에서는 사원경내의 의미에 대해서는 규정하고 있지 않은바, 사원 소유의 정원·산림·경작지 및 초지로서 해당 사원과 지리적·공간적으로 관련성이 없는 경우라도 사원경내에 해당하는지가 문제됩니다.

먼저 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데⁴⁾, 장사법 시행령 별표 4 제3호마목에서는 종교단체가 조성하는 자연장지에는 편의시설을 마련하여야 한다는 원칙을 규정하면서, ‘편의시설이 갖추어진 기존의 사원 경내’에 자연장지를 조성하는 경우를 편의시설을 따로 설치하지 않을 수 있는 예외로 규정하고 있고, 경내란 ‘일정한 지역의 안’을 의미하므로⁵⁾, 사원경내는 편의시설의 이용과 관련하여 지리적·공간적으로 해당 사원의 일정한 지역 범위 안이어야 할 것인바, 지리적·공간적으로 관련성이 있는지와 관계 없이 정원·산림·경작지 및 초지가 단지 사원 소유이기만 하면 사원경내에 해당하는 것으로 보아 같은 표 제3호마목 단서에 따른 예외규정의 적용을 받는다고 볼 수는 없을 것입니다.

그리고 장사법 제7조제2항 및 같은 법 시행령 제6조제1호에서는 누구든지 화장시설 외의 시설 또는 장소에서 화장을 하여서는 아니 된다고 규정하면서 ‘사찰 경내’에서 다비의식으로 화장을 하는 경우로서 보건위생상의 위해가 없는 경우를 예외로 규정하고 있고, 장사법 제17조제2호에서는 묘지·화장시설·봉안시설 또는 자연장지를 설치·조성할 수 없는 지역으로 「수도법」 제7조제1항에 따른 상수원보호구역을 규정하면서 기존의 ‘사원 경내’에 설치하는 봉안시설을 예외로 규정하고 있는바, 장사법령에서는 의무규정이 적용되는 사항의

3) 사설수목장림은 제외함(장사법 시행령 제21조제1항)

4) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례, 대법원 2020. 2. 6. 선고 2019두43474 판결례 참조

5) 국립국어원 표준대사전 참조

예외 요건으로서 ‘경내’일 것을 요구하는 경우를 규정하고 있는데, 만약 이를 사원의 소유이기만 하면 된다는 의미로 해석하면 사원경내의 범위가 기존의 사원과 지리적·공간적 관련성이 없는 경우까지 제한 없이 확대될 수도 있으므로, 이러한 경우까지 의무규정의 예외가 인정된다면 보건위생상의 위해를 방지하고 공공복리 증진에 이바지하려는 장사법령의 목적(제1조) 및 체계에 부합하지 않는다고 할 것입니다.

아울러 유족 및 조문객들이 장례의식에 이용할 물품을 갖추어 자연장지에까지 이르기 위해서는 승용차 내지 대형차를 이용하는 것이 일반적인 것이어서 자연장지에의 접근가능성 및 용이성을 확보하는 것이 반드시 필요한데⁶⁾, 장사법 시행령 별표 4 제3호마목1)에서 자연장지가 사원경내에 조성되는 경우에는 기존 사원이 갖추고 있는 편의시설을 함께 이용할 수 있어 편의시설을 따로 설치하지 않아도 되도록 규정한 것으로 보이는바, 해당 사원과 지리적·공간적으로 관련성이 없어도 사원의 소유이기만 하면 사원경내에 해당한다고 보아 기존 사원의 편의시설을 이용할 수 없음에도 편의시설을 설치하지 않게 되면, 자연장지를 방문하는 유족 및 조문객들의 접근가능성과 이용 편의를 보장하기 어렵다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 사원 소유의 정원·산림·경작지 및 초지로서 해당 사원과 지리적·공간적으로 관련성이 없는 경우에는 사원경내에 해당하지 않습니다.



관계법령

장사 등에 관한 법률

제16조(자연장지의 조성 등) ① 국가, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 아 닌 자는 다음 각 호의 구분에 따라 수목장림이나 그 밖의 자연장지(이하 “사설자연장지”라 한다)를 조성할 수 있다.

1. 개인·가족자연장지: 면적이 100제곱미터 미만인 것으로서 1구의 유골을 자연장하거나 「민법」에 따라 친족관계였던 자의 유골을 같은 구역 안에 자연장할 수 있는 구역
2. 종중·문중자연장지: 종중이나 문중 구성원의 유골을 같은 구역 안에 자연장할 수 있는 구역
3. 법인등자연장지: 법인이나 종교단체가 불특정 다수인의 유골을 같은 구역 안에 자연장할 수 있는 구역

② ~ ⑧ (생 략)

⑨ 제1항에 따른 사설자연장지의 종류별 면적, 제8항에 따라 자연장지에 설치하는 표지의 규격, 사설자연장지에 설치가 허용되는 편의시설의 종류 및 설치기준 등에 관하여 필요한 사항은

6) 인천지방법원 2015. 6. 26. 선고 2014구합3161 판결례, 2008. 5. 26. 대통령령 제20791호로 전부개정된 「전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률 시행령」 개정이유 참조

대통령령으로 정한다.

⑩·⑪ (생 략)

장사 등에 관한 법률 시행령

제21조(사설자연장지 등의 설치기준) ① 법 제16조제9항에 따른 사설자연장지(사설수목장림은 제외한다)의 종류별 면적, 표지의 규격, 편의시설의 종류 및 설치기준은 별표 4와 같다.

② 법 제16조제9항에 따른 사설수목장림의 면적, 표지의 규격, 편의시설의 종류 및 설치기준은 별표 5와 같다.

[별표 4]

사설자연장지의 설치기준(제21조제1항 관련)

1. ~ 2. (생 략)
3. 종교단체가 조성하는 자연장지
 - 가. 재단법인이 아닌 종교단체가 신도 및 그 가족관계에 있었던 자를 대상으로 조성하려 하는 자연장지는 1개소에 한하여 조성할 수 있으며, 그 면적은 4만제곱미터 이하여야 한다.
 - 나. 자연장지는 지형·배수·토양·경사도 등을 고려하여 붕괴·침수의 우려가 없는 곳에 조성하여야 한다.
 - 다. 급경사지에 유골을 묻어서는 아니 된다. 다만, 기존의 묘지에 자연장지를 조성하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 라. 표지는 개별 또는 공동으로 하되, 개별표지의 면적은 250제곱센티미터 이하, 공동표지의 면적은 안치 구수 및 안치예정 구수를 고려하여 알맞은 크기로 주위환경과 조화를 이루도록 하여야 한다.
 - 마. 관리사무실, 유족편의시설, 공동분향단, 그 밖의 필요한 시설과 폭 5미터 이상의 진입로 및 주차장을 마련하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본문에 따른 시설을 따로 설치하지 아니할 수 있다.
 - 1) 본문에 따른 시설이 갖추어진 기존의 사원 경내에 자연장지를 조성하는 경우
 - 2) 2천제곱미터 이하의 자연장지를 조성하는 경우
4. (생 략)

질의제목 4

▶ 안전번호 25-0341

민원인 - 법률 제13102호 노인복지법 일부개정법을 시행 이후 건축허가 등이 취소되고 다시 건축허가 등을 받은 노인복지주택을 개정 전 「노인복지법」 제32조제1항제3호에 따라 분양할 수 있는지(「노인복지법」 제32조제1항제3호 등 관련)

01 질의요지

구 「노인복지법」(2015년 1월 28일 법률 제13102호로 일부개정되어 2015년 7월 29일 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 같음) 제32조제1항제3호에서는 노인주거복지시설 중 노인복지주택은 노인에게 주거시설을 ‘분양 또는 임대’하여 주거의 편의 등을 제공함을 목적으로 하는 시설을 말한다고 규정하고 있었는데, 2015년 1월 28일 법률 제13102호로 일부개정되어 2015년 7월 29일 시행된 「노인복지법」(이하 “개정 「노인복지법」”이라 함) 제32조제1항제3호에서는 노인복지주택은 노인에게 주거시설을 ‘임대’하여 주거의 편의 등을 제공함을 목적으로 하는 시설이라고 규정하면서, 같은 법 부칙 제2조에서는 이 법 시행 전에 「건축법」에 따라 허가받거나 「주택법」에 따라 사업계획이 승인된 노인복지주택은 제32조제1항제3호 등의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다고 규정하고 있는 한편,

2010년 3월 16일 국토해양부령 제230호로 일부개정되어 2010년 9월 17일 시행된 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」(이하 “개정 도시계획시설규칙”이라 함) 제107조 본문에서는 “사회복지시설”이란 「사회복지사업법」 제34조에 따라 설치하는 사회복지시설을 말한다고 규정하면서, 같은 규칙 제107조에 단서를 신설하여 해당시설의 주요부분을 분양 또는 임대할 목적으로 설치하는 사회복지시설은 제외한다고 규정하고 있고, 같은 규칙 부칙 제2조에서는 제107조의 개정규정 시행 당시 도시계획시설결정을 위하여 도시관리계획의 입안을 제안하였거나 도시관리계획을 입안 중이거나 도시관리계획의 결정을 신청한 사회복지시설에 대하여는 제107조의 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 따른다고 규정하고 있는바,¹⁾

1) 개정 도시계획시설규칙 시행 당시 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 각각 도시관리계획, 도시계획시설, 도시계획시설결정 등으로 정의하고 있었으나, 해당 법률이 개정된 것을 반영하여 2012년 6월 28일 국토해양부령 제490호 도시계획시설규칙 일부개정령에서 해당 용어를 각각 도시·군관리계획, 도시·군계획시설, 도시·군계획시설결정 등으로 개정함.

분양 목적의 「노인복지법」 제32조제1항제3호에 따른 노인복지주택(이하 “노인복지주택”이라 함)을 건축하기 위해 개정 도시계획시설규칙 시행 전에 도시계획시설 중 사회복지시설 설치에 관한 도시관리계획 입안을 제안하여 사회복지시설을 설치하는 것으로 도시계획시설결정이 이루어진 부지에 개정 노인복지법 시행일인 2015년 7월 29일 전에 사회복지시설 중 노인복지주택의 건축에 관한 「건축법」에 따른 허가 또는 「주택법」에 따른 사업계획승인(이하 “건축허가등”이라 함)을 받았으나 2015년 7월 29일 이후에 해당 건축허가등이 취소된 경우,

해당 노인복지주택에 관한 건축허가등을 다시 받으면 개정 「노인복지법」 부칙 제2조 및 구 「노인복지법」 제32조제1항제3호를 적용받아 그 노인복지주택을 분양할 수 있는지?

02 회답

이 사안의 경우, 해당 노인복지주택은 개정 「노인복지법」 부칙 제2조 및 구 「노인복지법」 제32조제1항제3호를 적용받아 분양할 수 있는 노인복지주택이 아닙니다.

03 이유

「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」(이하 “도시계획시설규칙”이라 함)에서는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 함) 및 같은 법 시행령에 따른 도시·군계획시설²⁾의 결정·구조 및 설치의 기준과 기반시설의 세분 및 범위에 관한 사항을 규정하고 있는데, 구 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」(2010년 3월 16일 국토해양부령 제230호로 일부개정되어 2010년 9월 17일 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 “구 도시계획시설규칙”이라 함) 제107조에서는 도시계획시설로서의 “사회복지시설”을 「사회복지사업법」 제34조에 따라 설치하는 사회복지시설을 말한다고 규정하고 있었으나, 개정 도시계획시설규칙 제107조에서는 단서를 신설하여 해당시설의 주요부분을 분양 또는 임대할 목적으로 설치하는 사회복지시설은 제외하도록 규정하는 한편, 개정 도시계획시설규칙 부칙 제2조에서는 제107조의 개정규정 시행 당시 도시계획시설결정을 위하여 도시관리계획의 입안을 제안한 사회복지시설에 대하여는 제107조의 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 따른다고 규정하고 있는바, 이 사안의 부지는 도시관리계획에 따라

2) 기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설을 말하며(국토계획법 제2조제7호), 이하 같음

기반시설 중 하나인 사회복지시설을 설치하는 것이 예정되어 있고, 개정 도시계획시설규칙의 시행일인 2010년 9월 17일 전에 도시관리계획의 입안을 제안하였으므로, 개정 도시계획시설규칙 부칙 제2조에 따라 구 도시계획시설규칙 제2조가 적용되어 분양 또는 임대 목적의 사회복지시설을 설치할 수 있게 됩니다.

그리고 도시계획시설규칙 제107조 본문에서는 “사회복지시설”이란 「사회복지사업법」 제34조에 따른 사회복지시설을 말한다고 규정하고 있는데, 같은 법 제2조제1호에서는 사회복지사업을 「노인복지법」(다목) 등에 따른 복지에 관한 사업 등 각종 복지사업과 이에 관련된 복지시설의 운영 등을 목적으로 하는 사업으로 규정하고 있고, 「사회복지사업법」 제2조제4호에서는 사회복지시설을 사회복지사업을 할 목적으로 설치된 시설로 규정하고 있으며, 같은 법 제34조에서는 국가나 지방자치단체는 사회복지시설을 설치·운영할 수 있고, 국가나 지방자치단체가 아닌 자는 시장·군수·구청장에게 신고 후 시설을 설치·운영할 수 있도록 규정하고 있는바, 이 사안의 노인복지주택은 「노인복지법」에 따른 노인복지시설 중 노인주거복지시설의 한 유형(「노인복지법」 제31조·제32조)으로서 「노인복지법」에 따라 노인복지사업을 위하여 설치된 시설에 해당하므로, 도시계획시설규칙 제107조 본문에 따른 사회복지시설에 포함되고, 이에 따라 이 사안의 부지에는 국토계획법 및 도시계획시설규칙에 따라 사회복지시설 중 하나인 노인복지주택을 설치할 수 있다고 할 것입니다.

그런데 구 「노인복지법」 제32조제1항제3호에서는 노인주거복지시설 중 노인복지주택은 노인에게 주거시설을 분양 또는 임대하여 주거의 편의 등을 제공함을 목적으로 하는 시설을 말한다고 규정하고 있었는데, 개정 「노인복지법」에서는 제32조제1항제3호를 개정하여 노인복지주택은 노인에게 주거시설을 임대하여 주거의 편의 등을 제공함을 목적으로 하는 시설이라고 규정하면서, 같은 법 부칙 제2조에서는 이 법 시행 전에 건축허가등을 받은 노인복지주택은 개정 「노인복지법」 제32조제1항제3호 등의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다고 규정하여, 구 「노인복지법」 제32조제1항제3호의 적용을 받으면 분양 목적의 노인복지주택을 건축할 수 있게 되고, 개정 「노인복지법」 제32조제1항제3호의 적용을 받으면 분양 목적의 노인복지주택을 건축할 수 없게 되는바, 이 사안은 국토계획법 및 도시계획시설규칙에 따라 분양 및 임대 목적의 사회복지시설을 설치하는 것이 허용된 부지에서 노인복지주택을 설치하려는 경우로서 개정 「노인복지법」 시행 전에 건축허가등을 받았으나 개정 「노인복지법」 시행 후에 그 건축허가등이 취소되어 건축허가등을 다시 받은 노인복지주택의 경우 개정 「노인복지법」 부칙 제2조에 따라 구 「노인복지법」 제32조제1항제3호를 적용하여 분양 목적으로 건축하는 것이 가능한지에 관한 것입니다.

먼저 이 사안과 같이 노인복지주택에 관한 건축허가등이 개정 「노인복지법」 시행일인 2015년 7월 29일 이후에 취소되고 이후 건축허가등을 다시 받는다면, 기존 건축허가등은 취소되어 그 효력이 상실된 것이고, 다시 받은 건축허가등은 그 건축허가등에 관한 신청 사실이 당시의 법령상 기준 및 요건에 부합하는지 등을 검토한 후 이루어진 건축허가등으로서 기존에 취소된 건축허가등과는 구분되는 별개의 건축허가등인 점, 건축법령이나 주택법령 등에서 건축허가등이 취소된 후 다시 건축허가등을 받았을 때 다시 받은 건축허가를 취소된 건축허가와 동일하게 보도록 하는 규정을 두고 있지 않은 점 등을 고려할 때, 이 사안과 같이 개정 「노인복지법」 시행 이후 새롭게 건축허가등을 받은 노인복지주택은 개정 「노인복지법」 부칙 제2조의 적용 대상이 되는 “이 법 시행 전에 건축허가등을 받은 노인복지주택”에 포함된다고 볼 수 없으므로, 이 사안의 노인복지주택에 대해 구 「노인복지법」 제32조제1항제3호를 적용하여 분양할 수는 없다고 할 것입니다.

특히 허가 등 행정처분은 처분 당시에 시행 중인 법령과 그에 따른 허가 등의 기준에 따라 하는 것이 원칙이고,³⁾ 예외적으로 관계 법령이 개정·시행되면서 종전 규정에 따른 행정처분이 있을 것이라는 신뢰를 보호할 필요가 있다고 판단되는 일정한 경우에 한하여 종전의 법령에 규정되어 있던 기준이 적용되도록 부칙에 경과규정을 두게 되는데,⁴⁾ 개정 「노인복지법」 부칙 제2조에서 이 법 시행 전에 건축허가등을 받은 노인복지주택에 대해 경과조치를 둔 것도 종전의 규정에 따라 개정 「노인복지법」 시행 전에 분양을 목적으로 건축허가등을 받은 노인복지주택에 대해서 분양에 관한 신뢰이익이 있었다고 보아⁵⁾ 그 신뢰를 보호하는 차원에서 개정규정에 적합하지 아니하게 되었더라도 종전 규정에 따라 분양을 할 수 있도록 제한적으로 허용해준 것으로서, 이는 개정 「노인복지법」 시행 전에 받은 건축허가등이 유효한 것을 전제로 그 신뢰이익을 보호하려는 것인바, 이 사안과 같이 개정 「노인복지법」 시행 전에 받은 건축허가등이 취소되었다면 그 건축허가 등은 더 이상 유효하지 않으므로 개정 「노인복지법」 부칙 제2조 및 구 「노인복지법」 제32조제1항제3호 규정의 적용 대상에 해당되지 않는다고 해석하는 것이 타당합니다.

또한 개정 「노인복지법」 제32조제1항제3호에서 노인복지주택을 임대로만 설치·운영하도록 제한한 것은 노인의 주거안정 지원과 일상생활의 편의를 제공하기 위한 노인복지주택은 일반 공동주택에 비하여 완화된 시설기준을 적용받는⁶⁾ 등 각종 보조와 혜택이 주어지므로,

3) 「행정기본법」 제14조 참조

4) 법제처 2012. 11. 13. 회신 12-0564 해석례 참조

5) 2015. 1. 28. 법률 제13102호로 일부개정되어 같은 날 시행된 「노인복지법」 개정이유 및 주요내용 참조

6) 「노인복지법」 제32제3항 등 참조

노인복지주택이 과다 공급됨에 따라 일부 노인복지주택이 입소자격자가 아닌 자에게도 분양되는 사례가 나타나, 노인복지주택이 공동주택처럼 거래된 후 입소부적격자에게 분양·임대되어 선의의 피해자가 발생하는 문제를 해결하기 위한 것인바,⁷⁾ 이 사안과 같이 개정 「노인복지법」 시행 전에 받은 건축허가등이 개정 「노인복지법」 시행 이후 취소되어 그 후에 다시 건축허가를 받은 노인복지주택까지 개정 「노인복지법」 부칙 제2조가 적용될 수 있다고 해석하는 것은 개정 「노인복지법」 시행 이후에는 노인복지주택의 분양을 금지하고자 하는 개정 「노인복지법」 제32조제1항제3호의 입법 취지에도 부합하지 않습니다.

한편 이 사안과 같이 도시계획시설규칙 부칙 제2조에 따라 구 도시계획시설규칙 제107조가 적용되면 해당시설의 주요부분을 분양 또는 임대할 목적으로 사회복지시설을 설치할 수 있으므로 사회복지시설에 해당하는 노인복지주택의 분양도 가능하다는 의견이 있으나, 입법 목적 등을 달리하는 법령들이 일정한 행위에 관한 요건을 각각 정하고 있는 경우에 어느 법령이 다른 법령에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 이상 그 행위에 관하여 각 법령의 규정을 각각 적용받아야 하는바,⁸⁾ 국토계획법은 국토의 이용·개발과 보전을 위한 계획의 수립 및 집행 등에 필요한 사항을 정하여 공공복리를 증진시키고 국민의 삶의 질을 향상시키는 것을 목적으로 하고 있고,⁹⁾ 도시계획시설규칙은 국토계획법의 위임에 따라 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치의 기준 등을 규정하는 것을 목적으로 하고 있는 반면,¹⁰⁾ 「노인복지법」은 노인의 질환상태에 따른 적절한 치료·요양으로 심신의 건강을 유지하며, 노후의 생활안정을 위하여 필요한 조치를 강구함으로써 노인의 보건복지증진에 기여함을 목적으로 하고 있어, 도시계획시설규칙과 노인복지법은 입법 목적 등이 다른 법령으로서, 노인복지법령이나 국토계획법령에서는 법령의 적용 관계에 대한 특별한 규정도 두고 있지 않으므로, 이 사안과 같이 도시계획시설규칙에 따르면 분양 목적의 사회복지시설을 도시계획시설로서 설치할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 「노인복지법」에 따라 분양이 금지된 노인복지주택의 분양까지 허용될 수 있다고 해석하기는 어렵다는 점에서 이러한 의견은 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 노인복지주택은 개정 「노인복지법」 부칙 제2조 및 구 「노인복지법」 제32조제1항제3호를 적용받아 분양할 수 있는 노인복지주택이 아닙니다.

7) 2013년 3월 25일 의안번호 1904248호로 의원발의된 노인복지법 일부개정법률안(윤후덕의원 등 10인) 국회 보건복지위원회 검토보고서 참조

8) 대법원 1995. 1. 12. 선고 94누3216 판결, 대법원 1998. 3. 27. 선고 96누19772 판결 등 참조

9) 국토계획법 제1조

10) 도시계획시설규칙 제1조

**구 노인복지법(2015년 1월 28일 법률 제13102호로 일부개정되어 2015년 7월 29일 시행되기 전의 것)**

제32조(노인주거복지시설) ① 노인주거복지시설은 다음 각 호의 시설로 한다.

1. 2. (생략)
3. 노인복지주택 : 노인에게 주거시설을 분양 또는 임대하여 주거의 편의·생활지도·상담 및 안전관리 등 일상생활에 필요한 편의를 제공함을 목적으로 하는 시설
- ②·③ (생략)

개정 노인복지법(2015년 1월 28일 법률 제13102호로 일부개정되어 2015년 7월 29일 시행된 것)

제32조(노인주거복지시설) ① 노인주거복지시설은 다음 각 호의 시설로 한다.

1. 2. (생략)
3. 노인복지주택 : 노인에게 주거시설을 임대하여 주거의 편의·생활지도·상담 및 안전관리 등 일상생활에 필요한 편의를 제공함을 목적으로 하는 시설
- ②·③ (생략)

법률 제13102호 노인복지법 일부개정법률 부칙

제2조(분양형 노인복지주택에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 「건축법」에 따라 허가받거나 「주택법」에 따라 사업계획이 승인된 노인복지주택은 제32조제1항제3호, 같은 조 제2항, 제33조의2제2항부터 제4항까지, 제33조의3, 제56조제1항, 제56조의2 및 제62조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

구 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙(2010년 3월 16일 국토해양부령 제230조로 일부개정되어 9월 17일 시행되기 전의 것)

제107조(사회복지시설) 이 절에서 “사회복지시설”이라 함은 「사회복지사업법」 제34조의 규정에 의하여 설치하는 사회복지시설을 말한다.

개정 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙(2010년 3월 16일 국토해양부령 제230호로 일부개정되어 9월 17일 시행된 것)

제107조(사회복지시설) 이 절에서 “사회복지시설”이란 「사회복지사업법」 제34조에 따라 설치하는 사회복지시설을 말한다. 다만, 해당시설의 주요부분을 분양 또는 임대할 목적으로 설치하는 사회복지시설은 제외한다.

국토해양부령 제230호 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 일부개정령 부칙

제2조(사회복지시설에 관한 경과조치) 부칙 제1조 단서에 따른 제107조의 개정규정 시행 당시 도시계획시설결정을 위하여 도시관리계획의 입안을 제안하였거나 도시관리계획을 입안 중이거나 도시관리계획의 결정을 신청한 사회복지시설에 대하여는 제107조의 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 따른다.

제2절

식품의약품

질의제목 1

▶ 안전번호 24-0793

민원인 - 자연 상태에서 존재하는 물질을 물리적으로 추출·정제한 것은 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제3조제1호에 따른 “화학물질”에서 제외되는지 여부(「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제3조 등 관련)

01 질의요지

「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」(이하 “화학제품안전법”이라 함) 제3조제1호에서는 “화학물질”이란 원소·화합물 및 그에 인위적인 반응을 일으켜 얻은 물질과 자연 상태에서 존재하는 물질을 화학적으로 변형시키거나 추출 또는 정제한 것을 말한다고 정의하고 있는바,

자연 상태에서 존재하는 물질을 물리적으로 추출하거나 물리적으로 정제한 것은 화학제품안전법 제3조제1호에 따른 “화학물질”에서 제외되는지?

02 회답

자연 상태에서 존재하는 물질을 물리적으로 추출하거나 물리적으로 정제한 것은 화학제품안전법 제3조제1호에 따른 “화학물질”에서 제외되지 않습니다.

03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 할 것인데¹⁾, 화학제품안전법 제3조제1호에서는 “화학물질”이란 원소·화합물 및 그에 인위적인 반응을 일으켜 얻은 물질과 자연 상태에서 존재하는 물질을 화학적으로 변형시키거나 추출 또는 정제한 것을 말한다고 정의하고 있어 같은 호의 “화학적으로”가 “추출 또는 정제한 것”까지 수식하는지 여부가 문언상 명확하지 않습니다.

그런데 “화학물질”의 정의규정에 대한 입법연혁을 살펴보면, ① 2013년 6월 4일 법률 제11862호로 전부개정되기 전의 「유해화학물질 관리법」 제2조제1호에서는 “화학물질”이란 “원소·화합물 및 그에 인위적인 반응을 일으켜 얻어진 물질과 자연 상태에서 존재하는 물질을 추출(抽出)하거나 정제(精製)한 것을 말한다”고 규정하고 있었는데, ② 2013년 5월 22일 법률 제11789호로 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」이 제정되고, 그에 따라 2013년 6월 4일 법률 제11862호로 「화학물질관리법」이 전부개정²⁾되면서, 두 법률의 “화학물질” 정의규정에 “화학적으로 변형”이라는 표현이 추가되었고, ③ 이러한 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제2조제1호의 “화학물질” 정의규정을 참고하여 해당 표현 그대로³⁾ 2018년 3월 20일 법률 제15511호로 제정된 화학제품안전법 제3조제1호로 “화학물질” 정의규정이 신설된 것인바, 이러한 “화학물질” 정의규정의 입법연혁을 고려할 때, “화학적으로”라는 표현은 “변형”과 함께 추가된 것이고, “추출”과 “정제”는 그 전부터 이미 화학물질의 정의규정에 있었던 표현이므로, “화학적으로”는 “변형”만 수식한다고 보아야 하고, “추출”과 “정제”까지 수식한다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

그리고 2013년 5월 22일 법률 제11789호로 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」을 제정하여 화학물질을 함유한 제품에 대하여 관리할 수 있는 근거를 마련하면서⁴⁾, 앞에서

1) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

2) 「유해화학물질 관리법」은 2013. 6. 4. 법률 제11862호로 전부개정되면서 「화학물질관리법」으로 제명이 변경됨

3) 2017. 8. 16. 의안번호 제2008531호로 발의된 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률안(대안반영폐기)에 대한 환경노동위원회 검토보고서 참조

4) 2012. 9. 28. 의안번호 제1902053호로 발의된 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률안(대안반영폐기)에 대한

살펴본 바와 같은 입법연혁에 따라 “화학물질”의 정의규정에 “화학적으로 변형”이라는 표현을 추가한 것이고, 특히 생활화학제품 및 살생물제 등 화학물질을 함유한 제품에 대하여 체계적인 안전관리 등을 하기 위하여 2018년 3월 20일 법률 제15511호로 화학제품안전법을 제정한 것인데⁵⁾, “화학적으로 변형시키거나 추출 또는 정제한 것”이라는 표현을 반대해석하여 자연 상태에서 존재하는 물질을 “물리적으로 추출 또는 정제한 것”은 오히려 “화학물질”에서 제외된다고 해석하는 것은 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 및 화학제품안전법을 제정하면서 “화학물질”을 함유한 제품에 대한 규율을 강화하여 온 입법취지에 부합하지 않습니다.

또한 화학제품안전법 제3조제1호를 살펴보면, “화학물질”이란 ① 원소·화합물 및 그에 인위적인 반응을 일으켜 얻은 물질과 ② 자연 상태에서 존재하는 물질을 화학적으로 변형시키거나 추출 또는 정제한 것을 말한다고 정의하고 있으므로, “자연 상태에서 존재하는 물질을 화학적으로 변형시키거나 추출 또는 정제한 것”에 해당하지 않는다고 하더라도 “원소·화합물 및 그에 인위적인 반응을 일으켜 얻은 물질”에 해당한다면 여전히 같은 호의 “화학물질”에 해당할 수 있는바⁶⁾, 자연 상태에서 존재하는 물질을 물리적으로 추출 또는 정제한 것이라는 이유로 그 물질이 같은 법 제3조제1호의 “화학물질”에서 제외된다고 보기도 어렵다고 할 것입니다.

아울러 화학제품안전법 제3조제1호의 “화학물질”의 정의를 바탕으로 같은 조 제3호에서는 생활화학제품을 정의하고 있고, 같은 법 제8조제3항에서는 환경부장관이 같은 조 제1항에 따른 위해성평가를 한 결과 위해성이 있다고 인정하는 경우 관리위원회의 심의를 거쳐 해당 생활화학제품을 안전확인대상생활화학제품으로 지정·고시하여야 한다고 규정하고 있으며, 이러한 안전확인대상생활화학제품을 제조 또는 수입하려는 자에 대해서는 같은 법 제10조에 따라 안전기준의 적합여부 확인(제1항), 제품정보·성분 및 함량 등의 신고(제4항) 등의 의무를 부과하고 있는데, 만약 자연 상태에서 존재하는 물질을 물리적으로 추출 또는 정제한 것이 “화학물질”에서 제외된다고 해석한다면, 해당 물질을 포함하여 제조한 제품이 생활화학제품 및 안전확인대상생활화학제품에서 제외되어 화학제품안전법에 따른 규율 대상에서 제외되게 되는 결과가 초래되는바, 위해성 있는 화학물질이 포함된 생활화학제품으로부터 국민의 건강을 보호하기 위하여 제정된 화학제품안전법의 목적을 달성하기 어렵게 된다는 점도 이

환경노동위원회 심사보고서 및 2013. 5. 22. 법률 제11789호로 제정되어 2015. 1. 1. 시행된 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제정이유 참조

5) 2018. 3. 20. 법률 제15511호로 제정되어 2019. 1. 1. 시행된 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제정이유 참조

6) 참고로, 1996. 12. 30. 법률 제5221호로 「유해화학물질관리법」이 전부개정되기 전까지 「유해화학물질 관리법」에서는 “화학물질”을 “원소 및 화학반응에 의하여 생성되는 물질”로만 정의하고 있었음

사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 자연 상태에서 존재하는 물질을 물리적으로 추출하거나 물리적으로 정제한 것은 화학제품안전법 제3조제1호에 따른 “화학물질”에서 제외되지 않습니다.

법령정비 권고사항

「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제3조제1호에 따른 “화학물질”의 범위를 화학물질 관련 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “화학물질”이란 원소·화합물 및 그에 인위적인 반응을 일으켜 얻은 물질과 자연 상태에서 존재하는 물질을 화학적으로 변형시키거나 추출 또는 정제한 것을 말한다.
2. “위해성”이란 화학물질 또는 살생물물질이 노출될 경우 사람의 건강이나 환경에 피해를 줄 수 있는 정도를 말한다.
3. “생활화학제품”이란 가정, 사무실, 다중이용시설 등 일상적인 생활공간에서 사용되는 화학제품으로서 사람이나 환경에 화학물질의 노출을 유발할 가능성이 있는 것을 말한다.
4. “안전확인대상생활화학제품”이란 환경부장관이 제8조제1항에 따른 위해성평가를 한 결과 위해성이 있다고 인정되어 같은 조 제3항 본문에 따라 지정·고시한 생활화학제품을 말한다.
5. 6. (생 략)
7. “살생물물질”이란 유해생물을 제거, 무해화(無害化) 또는 억제(이하 “제거등”이라 한다)하는 기능으로 사용하는 화학물질, 천연물질 또는 미생물을 말한다.
8. ~ 13. (생 략)

제8조(위해성평가 등) ① 환경부장관은 생활화학제품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 생활화학제품에 대하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 위해성평가를 할 수 있다.

1. 제7조제1항에 따른 실태조사를 한 결과 생활화학제품의 위해성이 우려되는 경우
2. 생활화학제품에 들어있는 화학물질의 위해성이 크다는 우려가 국내외에서 제기되는 경우
- ② 환경부장관은 제1항에 따른 위해성평가를 한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장에게 그 결과를 통지하여야 한다.
- ③ 환경부장관은 제1항에 따른 위해성평가를 한 결과 위해성이 있다고 인정하는 경우에는 관계

중앙행정기관의 장과 협의하고 관리위원회의 심의를 거쳐 해당 생활화학제품을 안전확인대상생활화학제품으로 지정·고시하여야 한다. 다만, 제20조제1항에 따라 환경부장관의 승인을 받은 살생물제품은 안전확인대상생활화학제품에서 제외한다.

④ 환경부장관은 제1항에 따른 위해성평가를 한 결과 위해성이 매우 커서 그 위해를 막기 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 생활화학제품을 제3항 본문에 따라 안전확인대상 생활화학제품으로 지정·고시하기 전에 그 제품의 제조 또는 수입의 금지를 명할 수 있다.

⑤ 환경부장관은 위해성평가를 마친 경우 해당 제품의 명칭, 위해성, 그 밖에 환경부령으로 정하는 사항을 공개할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 위해성평가의 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.

질의제목 2

▶ 안전번호 25-0039

민원인 - 시장 등이 일본뇌염, 말라리아를 예방하기 위한 소독을 실시하는 경우, 반드시 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 6 제3호가목에 따른 물리적·환경적 방법을 포함한 방법으로 소독을 해야 하는지(「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제51조제1항 등 관련)

01 질의요지

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」(이하 “감염병예방법”이라 함) 제51조제1항에서는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 “시장등”이라 함)은 감염병을 예방하기 위하여 청소나 소독을 실시하거나 쥐, 위생해충 등의 구제조치(이하 “소독”이라 함)를 하여야 한다(전단)고 규정하면서, 이 경우 소독은 사람의 건강과 자연에 유해한 영향을 최소화하여 안전하게 실시하여야 한다(후단)고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 소독의 기준과 방법은 보건복지부령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제36조제3항에서는 같은 법 제51조제1항에 따른 소독의 방법은 같은 규칙 별표 6과 같다고 규정하고 있고, 같은 규칙 별표 6 제3호에서는 질병매개곤충 방제(防除) 방법으로서 물리적·환경적 방법(가목), 화학적 방법(나목) 및 생물학적 방법(다목)을 규정하고 있는바,

시장등이 감염병예방법 제51조제1항에 따라 일본뇌염, 말라리아를 예방하기 위하여 소독을 실시하는 경우, 반드시 같은 법 시행규칙 별표 6 제3호가목에 따른 물리적·환경적 방법(이하 “물리적·환경적 방법”이라 함)을 포함한 방법으로 소독을 해야 하는지?

02 회답

시장등이 감염병예방법 제51조제1항에 따라 일본뇌염, 말라리아를 예방하기 위하여 소독을 실시하는 경우, 반드시 물리적·환경적 방법을 포함한 방법으로 소독을 해야 하는 것은 아닙니다.

03 이유

먼저 감염병예방법 제51조제1항에서는 감염병을 예방하기 위한 시장등의 소독 의무를 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 별표 6 제3호에서는 소독의 방법 중 질병매개곤충의 방제 방법을 규정하면서 물리적·환경적 방법(가목), 화학적 방법(나목) 및 생물학적 방법(다목)을 병렬적으로 규정하고 있는데, 감염병예방법령에서는 소독의 방법으로 같은 규칙 별표 6 제3호가목부터 다목까지의 규정 모두를 적용하여야 한다거나 그 중 어느 하나를 반드시 포함하여 적용하여야 한다거나 어느 하나를 우선하여 적용하여야 한다는 등의 내용은 규정하고 있지 않은바, 같은 법 제51조제1항 및 같은 규칙 별표 6 제3호가목부터 다목까지의 규정은 질병매개곤충에 대한 방제 방법의 종류를 열거하여 일본뇌염, 말라리아를 예방하기 위해 시장등이 소독을 하는 경우에 모기 등 질병매개곤충의 종류, 서식환경, 개체의 밀도 등을 종합적으로 고려하여 적합한 방제 방법을 선택할 수 있도록 한 취지의 규정이라고 할 것입니다.

그리고 소독의 방법 등에 관한 감염병예방법령의 입법 연혁을 살펴보면, 구「전염병예방법」¹⁾ 제정 당시부터 특별시장 등의 서족(鼠族)²⁾ 및 곤충 등에 대한 구제조치 의무를 규정하고 있었고, 그 구제조치의 방법으로는 서식 장소를 완전하게 제거하여 산란 또는 성충등이 서식하지 못하게 할 것, 유충 또는 성충등의 발생이나 출입을 못하도록 적절한 시설을 갖추 것, 구서·구충용 방제약제를 사용하여 말살 또는 방제할 것, 서족 또는 해충의 먹이가 되는 음식물의 찌꺼기 등을 제거할 것 등을 열거하여 규정하고 있었는데³⁾, 이후 「전염병예방법」의 제명이 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」로 변경되는 등⁴⁾ 해당 법령이 여러 차례 개정되는 과정에서 질병매개곤충의 방제와 쥐의 방제가 구분되고 그 방제 방법 또한 점차 세분화되어, 현행과 같이 질병매개곤충의 방제에 대해서는 물리적·환경적 방법, 화학적 방법, 생물학적 방법으로 구분하여 규정하게 된 것인바⁵⁾, 이러한 소독 방법 등에 관한 개정 과정을 종합해 보면, 이는 소독이나 방제에 관한 사항을 보다 체계적으로 규정하기 위한 것으로서, 시장등이 반드시 특정한 방법을 포함하여 소독을 하도록 하려는 입법 취지가 있었다고 보기는 어렵다고

1) 1954. 2. 2. 법률 제308호로 제정된 「전염병예방법」을 말함

2) 쥐를 의미함

3) 1977. 8. 19. 보건사회부령 제570호로 제정된 「전염병예방법시행규칙」 제19조제2항 등 참조

4) 「전염병예방법」과 「기생충질환 예방법」을 통합하여 법 제명을 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」로 바꾸고, 전염병이라는 용어를 사람들 사이에 전파되지 않는 질환을 포괄할 수 있는 감염병이라는 용어로 정비하였음(2009. 12. 29. 법률 제9837호로 전부개정된 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 개정이유 참조)

5) 1984. 9. 3. 보건사회부령 제753호로 일부개정된 「전염병예방법시행규칙」 별표 3 제3호, 2006. 1. 17. 보건복지부령 제345호로 일부개정된 감염병예방법 시행규칙 별표 3 제3호 및 제4호 등 참조

할 것입니다.

한편 감염병예방법 제51조제1항 후단에서는 시장등이 감염병 예방을 위한 소독을 하는 경우 사람의 건강과 자연에 유해한 영향을 최소화하여 안전하게 실시하여야 한다고 규정하고 있고, 이 규정은 모기 방역을 할 때 인체에 유해한 화학성분을 지닌 방역약품을 과도하게 사용하는 문제를 개선하기 위하여 신설된 규정⁶⁾이므로, 시장등이 일본뇌염, 말라리아 예방을 위한 소독을 하는 경우에는 반드시 물리적·환경적 방법을 포함한 방법으로 소독을 해야 한다는 의견이 있습니다.

그러나 감염병예방법 제51조제1항 후단은 살충제 등 소독에 사용되는 약품의 경우 그 특성상 사람 및 환경에 대해 완전히 무해할 수는 없으므로, 방역 행정에 차질이 가해지지 않도록 하기 위해 사람의 건강과 자연에 유해한 영향을 ‘최소화’하여 안전하게 실시하여야 한다는 내용으로 개정된 것으로⁷⁾, 해당 규정이 물리적·환경적 방법을 반드시 우선하여 사용하도록 의무화하고 있다고 보기는 어려운바, 시장등이 같은 법 제51조제1항에 따른 소독 의무를 이행하는 경우에도 반드시 물리적·환경적 방법만을 사용해야 하는 것은 아니고, 같은 법 시행규칙 별표 6 제3호가목부터 다목까지의 규정에 따른 소독 방법에 대해 선택할 수 있는 재량권이 부여된 것으로 해석하는 것이 타당할 것입니다.

아울러 감염병예방법 시행규칙 별표 6 제5호에서는 살충 등의 소독에 사용하는 약품은 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제3조제4호에 따른 안전확인대상생활화학제품 또는 같은 조 제8호에 따른 살생물제품으로서 환경부장관의 승인을 받은 제품을 용법·용량에 따라 안전하게 사용해야 한다고 규정하고 있으므로, 물리적·환경적 방법 외의 방법으로 소독을 실시한다고 하더라도 관련 법령에 따라 사람의 건강과 자연에 관한 안전성을 확보할 수 있는 장치가 마련되어 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 감염병예방법 제51조제1항에 따라 시장등이 일본뇌염, 말라리아를 예방하기 위하여 소독을 실시하는 경우, 반드시 물리적·환경적 방법을 포함한 방법으로 소독을 해야 하는 것은 아닙니다.

6) 2019. 9. 4. 의안번호 제22328호로 발의된 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 보건복지위원회 검토보고서 참조

7) 2019. 9. 4. 의안번호 제22328호로 발의된 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 보건복지위원회 검토보고서 참조

**감염병의 예방 및 관리에 관한 법률**

제51조(소독 의무) ① 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병을 예방하기 위하여 청소나 소독을 실시하거나 쥐, 위생해충 등의 구제조치(이하 “소독”이라 한다)를 하여야 한다. 이 경우 소독은 사람의 건강과 자연에 유해한 영향을 최소화하여 안전하게 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 소독의 기준과 방법은 보건복지부령으로 정한다.

③·④ (생 략)

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙

제36조(방역기동반의 운영 및 소독의 기준 등) ①·② (생 략)

③ 법 제51조제1항 및 제4항 단서에 따른 소독의 방법은 별표 6과 같다.

④ (생 략)

[별표 6]

소독의 방법(제35조제2항, 제36조제3항 및 제40조제1항 관련)

1.·2. (생 략)

3. 질병매개곤충 방제(防除)

가. 물리적·환경적 방법

- 1) 서식 장소를 완전히 제거하여 질병매개곤충이 서식하지 못하게 한다.
- 2) 질병매개곤충의 발생이나 유입을 막기 위한 시설을 설치해야 한다.
- 3) 질병매개곤충의 종류에 따른 적절한 덮을 사용하여 밀도를 낮추어야 한다.

나. 화학적 방법

- 1) 질병매개곤충에 맞는 곤충 성장 억제제 또는 살충제를 사용하여 유충과 성충을 제거해야 한다.
- 2) 잔류성 살충제를 사용하여 추가적인 유입을 막아야 한다.
- 3) 살충제 처리가 된 창문스크린이나 모기장을 사용해야 한다.

다. 생물학적 방법

- 1) 모기 방제를 위하여 유충을 잡아먹는 천적(미꾸라지, 송사리, 잠자리 유충 등)을 이용한다.
- 2) 모기유충 서식처에 미생물 살충제를 사용한다.

4.·5. (생 략)

질의제목 3

▶ 안전번호 25-0074

식품의약품안전처 - 다른 품목에 대하여 다른 날에 같은 매체에 한 부당한 광고가 둘 이상 적발된 경우에 대한 행정처분 일반기준 적용(「식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙」 별표 7 등 관련)

01 질의요지

「식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙」 별표 7 I 제1호에서는 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가장 무거운 정지처분 기간에 나머지 각각의 정지처분 기간의 2분의 1을 더하여 처분한다”고 규정하고 있고, 같은 표 I 제2호에서는 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 그 위반행위가 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지에 해당하는 경우에는 각각의 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지 처분기간을 제1호 일반기준에 따라 산정한 후 다음 각 목의 구분에 따라 처분한다”고 규정하고 있으며, 같은 표 I 제3호에서는 “같은 날 제조·가공한 같은 품목에 대하여 같은 위반사항이 적발된 경우에는 같은 위반행위로 본다. 다만 부당한 광고는 같은 품목에 대하여 같은 날에 같은 매체로 광고한 경우 같은 위반행위로 본다”고 규정하고 있는바,

다른 품목에 대하여 다른 날에 같은 매체에 한 부당한 광고가 둘 이상 적발된 경우¹⁾가 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙」 별표 7 I 제1호 및 제2호의 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우”에 해당하는지?

02 회답

다른 품목에 대하여 다른 날에 같은 매체에 한 부당한 광고가 둘 이상 적발된 경우는 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙」 별표 7 I 제1호 및 제2호의 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우”에 해당합니다.

1) 다른 품목에 대하여 다른 날에 같은 매체에 부당한 광고를 한 둘 이상의 같은 위반사항을 행정청이 하나의 위반사항으로 보아 1건만 적발할 수 있는지 여부는 별론으로 함

03 이유

먼저 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데²⁾, 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙」 별표 7 I 제3호 단서에서는 “부당한 광고는 같은 품목에 대하여 같은 날에 같은 매체로 광고한 경우 같은 위반행위로 본다”고 규정하고 있고, 이는 “같은 품목에 대하여 같은 날에 같은 매체로” 한 복수의 부당한 광고가 적발된 경우에는 하나의 위반행위로 보아 영업정지, 품목 또는 품목류 제조정지 처분기간을 가중하지 않도록 하여 과도한 제재를 방지³⁾하기 위한 취지의 규정인바, 같은 호 단서의 문언에 대한 반대해석상 같은 품목에 대하여 같은 날에 같은 매체로 한 경우가 아닌 부당한 광고가 둘 이상 적발되었다면 하나의 위반행위로 보기 어렵다고 할 것이므로, 이 사안과 같이 다른 품목에 대하여 다른 날에 같은 매체에 한 부당한 광고가 둘 이상 적발된 경우는 하나의 위반행위가 아니라 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우에 해당한다고 할 것입니다.

또한 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙」 별표 7 I의 일반기준의 규정체계를 살펴보면, 제1호부터 제3호까지는 ‘둘 이상의 위반행위가 적발된 경우’에 대한 행정처분 일반기준을 규정하고 있고, 그중 제3호는 적발된 둘 이상의 위반행위를 예외적으로 하나의 위반행위로 간주하는 경우를 규정하고 있는 것⁴⁾인데, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 되고 엄격하게 해석할 필요가 있으며⁵⁾, 이에 따라 제3호의 적용 대상이 아니라면 원칙적으로 제1호 및 제2호의 적용대상이 된다고 할 것이고, 같은 표 I 제1호 및 제2호의 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우”란 위반행위의 종류와 관계없이 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우를 의미하는바⁶⁾, 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우에도 같은 표 I 제1호 및 제2호의 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우”에 해당한다는 점에 비추어 보면, 이 사안과 같이 다른 품목에 대하여 다른 날에 같은 매체에 한 부당한 광고가 둘 이상 적발된 경우는 같은 표 I 제1호 및 제2호의 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우”에 해당한다고 보는 것이 같은 표 I 일반기준의 규정체계에 부합하는

2) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

3) 법제처 2015. 2. 17. 회신 15-0016 해석례, 법제처 2024. 11. 8. 회신 24-0652 해석례, 법제처 2024. 11. 27. 회신 24-0858 해석례 참조

4) 법제처 2024. 11. 8. 회신 24-0652 해석례, 법제처 2024. 11. 27. 회신 24-0858 해석례 참조

5) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례, 법제처 2024. 11. 8. 회신 24-0652 해석례 참조

6) 법제처 2024. 3. 20. 회신 23-1079 해석례 참조

해석입니다.

한편 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙」 별표 7 I 제3호 단서에 따른 ‘같은 품목에 대하여 같은 날에 같은 매체로 부당한 광고를 한 경우’에 해당하지 않는다는 이유만으로 이 사안의 경우를 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로 보아 행정처분을 한다면, 같은 내용의 광고가 지속적으로 반복되어 매체에 노출되는 광고의 특성을 고려할 때 영업자에게 과도한 처분이 될 수 있으므로 같은 호의 취지를 고려하여 이 사안에서도 하나의 위반행위로 보아야 한다는 의견이 있으나, 원칙적으로 행정처분의 실효성을 확보하기 위해서 위반행위가 둘 이상이라면 각각의 위반행위에 대해 제재처분을 내릴 필요가 있다고 할 것이고⁷⁾, 이러한 원칙의 예외를 인정하기 위해서는 명시적인 예외규정이 필요하다는 점을 고려할 때 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 다른 품목에 대하여 다른 날에 같은 매체에 한 부당한 광고가 둘 이상 적발된 경우는 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙」 별표 7 I 제1호 및 제2호의 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우”에 해당합니다.



관계법령

식품 등의 표시·광고에 관한 법률

제16조(영업정지 등) ① 식품의약품안전처장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 영업자 중 허가를 받거나 등록을 한 영업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 6개월 이내의 기간을 정하여 그 영업의 전부 또는 일부를 정지하거나 영업허가 또는 등록을 취소할 수 있다.

1. (생략)
2. 제8조제1항을 위반하여 표시 또는 광고를 한 경우
3. ~ 6. (생략)

② ~ ④ (생략)

⑤ 제1항 및 제3항에 따른 행정처분의 기준은 그 위반행위의 유형과 위반의 정도 등을 고려하여 총리령으로 정한다.

식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙

제16조(행정처분의 기준) 법 제14조부터 제17조까지의 규정에 따른 행정처분의 기준은 별표 7과 같다.

7) 대법원 1995. 1. 24. 선고 94누6888판결례, 법제처 2018. 1. 16. 회신 17-0655 해석례 참조

[별표 7]

행정처분 기준(제16조 관련)

I. 일반기준

1. 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가장 무거운 정지처분 기간에 나머지 각각의 정지처분 기간의 2분의 1을 더하여 처분한다.
 - 가. 영업정지에만 해당하는 경우
 - 나. 한 품목 또는 품목류(식품등의 기준 및 규격 중 같은 기준 및 규격을 적용받아 제조·가공되는 모든 품목을 말한다. 이하 같다)에 대하여 품목 또는 품목류 제조정지에만 해당하는 경우
2. 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 그 위반행위가 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지에 해당하는 경우에는 각각의 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지 처분기간을 제1호 일반기준에 따라 산정한 후 다음 각 목의 구분에 따라 처분한다.
 - 가. 영업정지 기간이 품목 또는 품목류 제조정지 기간보다 길거나 같으면 영업정지 처분만 할 것
 - 나. 영업정지 기간이 품목 또는 품목류 제조정지 기간보다 짧으면 그 영업정지 처분과 그 초과기간에 대한 품목 또는 품목류 제조정지 처분을 함께 부과할 것
 - 다. 품목류 제조정지 기간이 품목 제조정지 기간보다 길거나 같으면 품목류 제조정지 처분만 할 것
 - 라. 품목류 제조정지 기간이 품목 제조정지 기간보다 짧으면 그 품목류 제조정지 처분과 그 초과기간에 대한 품목 제조정지 처분을 함께 부과할 것
3. 같은 날 제조·가공한 같은 품목에 대하여 같은 위반사항이 적발된 경우에는 같은 위반행위로 본다. 다만, 부당한 광고는 같은 품목에 대하여 같은 날에 같은 매체로 광고한 경우 같은 위반행위로 본다.
4. ~ 16. (생 략)

II.·III. (생 략)

질의제목 4

▶ 안전번호 25-0378

민원인 - 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제51조제3항에 따른 소독의 방법(「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제51조 및 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 6 제3호가목 등 관련)

01 질의요지

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」(이하 “감염병예방법”이라 함) 제51조제3항에서는 공동주택, 숙박업소 등 여러 사람이 거주하거나 이용하는 시설 중 대통령령으로 정하는 시설(이하 “소독의무대상시설”이라 함)을 관리·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 감염병 예방에 필요한 소독을 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항 본문에서는 소독의무대상시설의 관리·운영자는 같은 법 제52조제1항에 따라 소독업의 신고를 한 자(이하 “소독업자”라 함)에게 소독하게 하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제40조제1항 및 별표 6에서는 소독의 방법을 규정하면서, 같은 표 제3호에서는 질병매개곤충 방제(防除) 방법으로서 물리적·환경적 방법(가목), 화학적 방법(나목) 및 생물학적 방법(다목)을 규정하고 있는바,

감염병예방법 제51조제3항 및 제4항에 따라 소독의무대상시설을 관리·운영하는 자가 모기 등 질병매개곤충의 방제를 위하여 소독업자에게 해당 시설에 대한 소독을 하게 하는 경우, 소독업자는 반드시 같은 법 시행규칙 별표 6 제3호가목에 따른 물리적·환경적 방법(이하 “물리적·환경적 방법”이라 함)을 포함한 방법으로 소독을 해야 하는지?

02 회답

감염병예방법 제51조제3항 및 제4항에 따라 소독의무대상시설을 관리·운영하는 자가 모기 등 질병매개곤충의 방제를 위하여 소독업자에게 해당 시설에 대한 소독을 하게 하는 경우, 소독업자는 반드시 물리적·환경적 방법을 포함한 방법으로 소독을 해야 하는 것은 아닙니다.

03 이유

먼저 감염병예방법 제51조제3항에서는 공동주택, 숙박업소 등 여러 사람이 거주하거나 이용하는 시설인 소독의무대상시설을 관리·운영하는 자의 소독 의무를 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 소독의무대상시설의 관리·운영자는 소독업자에게 해당 소독을 하게 하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 별표 6 제3호에서는 소독업자의 소독 방법 중 질병매개곤충의 방제 방법을 규정하면서 물리적·환경적 방법(가목), 화학적 방법(나목) 및 생물학적 방법(다목)을 규정하고 있는데, 감염병예방법령에서는 소독업자가 질병매개곤충의 방제를 위한 소독을 하는 경우에 같은 규칙 별표 6 제3호가목부터 다목까지의 방법 중 어느 하나를 반드시 포함하여 적용하여야 한다거나 어느 하나를 우선하여 적용하여야 한다는 등의 내용은 규정하고 있지 않은바, 같은 법 제51조제3항·제4항 및 같은 규칙 별표 6 제3호가목부터 다목까지의 규정은 소독업자로 하여금 소독의무대상시설의 특성, 질병매개곤충의 종류와 서식환경, 개체의 밀도 등을 종합적으로 고려하여 적합한 방제 방법을 선택할 수 있도록 하는 취지의 규정으로 보아야 할 것¹⁾입니다.

또한 소독업자의 소독의 방법을 규정하고 있는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 6의 규정 체계를 살펴보면, 같은 표 제2호에서는 소독을 소각, 증기소독, 끓는 물 소독, 약물소독, 일광소독으로 나누어 규정하고 있고, 같은 표 제3호에서는 질병매개곤충의 방제를 물리적·환경적 방법, 화학적 방법, 생물학적 방법으로 나누어 규정하고 있는데, 같은 표 제2호 각 목에서 개별적·구체적인 상황에 따라 적합한 세부 방법을 선택적으로 적용하도록 규정하고 있는 것과 마찬가지로, 같은 표 제3호 각 목에 따른 질병매개곤충 방제의 세부 방법 또한 소독이 필요한 개별적·구체적인 상황에 따라 소독업자가 선택할 수 있도록 한 것으로서, 명문의 근거 없이 질병매개곤충 방제에 대해서만 반드시 물리적·환경적 방법을 포함한 방법으로 소독을 해야 한다고 해석하는 것은 이와 같이 소독의 세부 방법을 병렬적으로 나열하고 있는 해당 규정의 체계에 부합하지 않는다고 할 것입니다.

따라서 감염병예방법 제51조제3항 및 제4항에 따라 소독의무대상시설을 관리·운영하는 자가 모기 등 질병매개곤충의 방제를 위하여 소독업자에게 해당 시설에 대한 소독을 하게 하는 경우, 소독업자는 반드시 물리적·환경적 방법을 포함한 방법으로 소독을 해야 하는 것은 아닙니다.

1) 법제처 2025. 4. 7. 회신 25-0039 해석례 참조



관계법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

제51조(소독 의무) ①·② (생 략)

③ 공동주택, 숙박업소 등 여러 사람이 거주하거나 이용하는 시설 중 대통령령으로 정하는 시설을 관리·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 감염병 예방에 필요한 소독을 하여야 한다.

④ 제3항에 따라 소독을 하여야 하는 시설의 관리·운영자는 제52조제1항에 따라 소독업의 신고를 한 자에게 소독하게 하여야 한다. 다만, 「공동주택관리법」 제2조제1항제15호에 따른 주택관리업자가 제52조제1항에 따른 소독장비를 갖추었을 때에는 그가 관리하는 공동주택은 직접 소독할 수 있다.

제52조(소독업의 신고 등) ① 소독을 업으로 하려는 자(제51조제4항 단서에 따른 주택관리업자는 제외한다)는 보건복지부령으로 정하는 시설·장비 및 인력을 갖추어 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② (생 략)

③ 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 소독업의 신고를 한 자(이하 “소독업자”라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 소독업 신고가 취소된 것으로 본다.

1. ~ 3. (생 략)

④ (생 략)

제54조(소독의 실시 등) ① 소독업자는 보건복지부령으로 정하는 기준과 방법에 따라 소독하여야 한다.

② (생 략)

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙

제40조(소독의 기준 및 소독에 관한 사항의 기록 등) ① 법 제54조제1항에 따른 소독의 기준과 방법은 각각 별표 5 및 별표 6과 같다.

②·③ (생 략)

[별표 6]

소독의 방법(제35조제2항, 제36조제3항 및 제40조제1항 관련)

1.·2. (생 략)

3. 질병매개곤충 방제(防除)

가. 물리적·환경적 방법

- 1) 서식 장소를 완전히 제거하여 질병매개곤충이 서식하지 못하게 한다.
- 2) 질병매개곤충의 발생이나 유입을 막기 위한 시설을 설치해야 한다.
- 3) 질병매개곤충의 종류에 따른 적절한 닧을 사용하여 밀도를 낮추어야 한다.

나. 화학적 방법

- 1) 질병매개곤충에 맞는 곤충 성장 억제제 또는 살충제를 사용하여 유충과 성충을 제거해야 한다.
- 2) 잔류성 살충제를 사용하여 추가적인 유입을 막아야 한다.
- 3) 살충제 처리가 된 창문스크린이나 모기장을 사용해야 한다.

다. 생물학적 방법

- 1) 모기 방제를 위하여 유충을 잡아먹는 천적(미꾸라지, 송사리, 잠자리 유충 등)을 이용한다.
- 2) 모기유충 서식처에 미생물 살충제를 사용한다.

4.·5. (생 략)

CHAPTER

8

환경·고용노동

제1절 환경
제2절 고용노동

제1절 환경

질의제목 1 ▶ 안전번호 24-0811

환경부 - 수경시설 수질 검사 주기 15일의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일까지 수질검사를 실시해도 되는지(「물환경보전법 시행규칙」 별표 19의2 제1호나목 등 관련)

01 질의요지

「물환경보전법」 제61조의2제4항에서는 같은 조 제1항에 따라 물놀이형 수경시설¹⁾을 운영하는 자는 환경부령으로 정하는 수질 기준 및 관리 기준을 지켜야 하며 환경부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 수질 검사를 받아야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 별표 19의2 제1호나목2) 본문에서는 수경시설의 가동 개시일을 기준으로 운영 기간 동안 15일마다 1회 이상 검사를 실시하여야 하며, 검사 시료는 가급적 이용자가 많은 날에 채수하도록 한다고 규정하면서, 같은 목 2) 단서에서는 천재지변, 강우 또는 그 밖의 부득이한 사유로 수질 검사주기를 초과한 경우에는 검사주기 초과사유 및 조치계획을 물놀이형 수경시설 관리카드의 수질검사 조치사항 항목에 기재해야 한다고 규정하고 있는바,

「물환경보전법 시행규칙」 별표 19의2 제1호나목2) 본문에서 규정하고 있는 15일의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일까지 수질검사를 실시해도 되는지?

1) 수돗물, 지하수 등을 인위적으로 저장 및 순환하여 이용하는 분수, 연못, 폭포, 실개천 등의 인공시설물 중 일반인에게 개방되어 이용자의 신체와 직접 접촉하여 물놀이를 하도록 설치하는 시설로서 「물환경보전법」 제2조제19호 단서에서 규정하는 시설을 제외한 시설을 말하며, 이하 같음

02 회답

「물환경보전법 시행규칙」 별표 19의2 제1호나목2) 본문에서 규정하고 있는 15일의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우에도 말일까지 수질검사를 실시해야 합니다.

03 이유

먼저 「물환경보전법 시행규칙」 별표 19의2 제1호나목2)에서 수경시설의 수질 검사를 수경시설의 가동 개시일을 기준으로 ‘운영 기간 동안 15일마다 1회 이상’ 검사를 실시하여야 한다고 규정하면서, 천재지변, 강우 또는 그 밖의 부득이한 사유를 수질 검사주기의 초과 사유로 한정하고 있는데, ‘마다’는 사건이나 시점과 결합하여 해당 사건이나 시점에 반복적으로 특정 의무가 발생함을 표현하기 위한 것인바, 15일을 주기로 15일 중 어떤 날이든 최소한 한 번 이상 수질 검사를 실시해야 하고 천재지변, 강우 또는 그 밖의 부득이한 사유가 발생한 경우에만 검사주기를 초과할 수 있다는 의미이므로, 이 사안의 경우에는 15일의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일까지 수질검사를 실시해도 된다고 보기는 어렵습니다.

그리고 「물환경보전법」은 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 하려는 목적(제1조)으로 제정된 법률로서, 같은 법 제61조의2는 이용자의 신체와 직접 접촉하여 물놀이를 하게 되는 물놀이형 수경시설이 증가하는 추세이나 관리가 미흡하여 수인성 질환 및 안전사고가 발생할 가능성이 있어 이러한 물놀이형 수경시설에 대한 관리를 강화하기 위하여 물놀이형 수경시설을 설치·운영하려는 자로 하여금 환경부장관 등에게 신고하고 수질 기준 및 관리 기준을 준수하도록 신설된 것²⁾이고, 같은 법 시행규칙 별표 19의2 제2호나목3)에서는 물놀이형 수경시설에 사용되는 물을 1일 1회 이상 여과기를 통과하게 하는 방법으로 관리하도록 규정하고 있고, 같은 호 바목 전단에서는 운영기간 중 물놀이형 수경시설의 수질이 제1호가목에 따른 기준을 초과하는 경우에는 지체 없이 물놀이형 수경시설의 개방을 중지하고, 소독 또는 청소·용수 교체 등의 조치를 완료한 후 수질을 재검사하여 같은 표 제1호가목에 따른 기준을 충족하는지 여부를 확인한 후 물놀이형 수경시설을 재개방하여야 한다고 규정하고 있는 점을 고려하면, 「물환경보전법 시행규칙」에서는 물놀이형 수경시설의 수질 기준 및 관리 기준과 관련하여

2) 2015. 10. 21. 의안번호 제1917305호로 발의된 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국회 농림축산식품해양수산위원회 심사보고서 참조

토요일 또는 공휴일 여부와 상관없이 가급적 자주 수질을 검사·관리하여 수질 기준을 충족하지 않는 상태에서 물놀이형 수경시설이 운영되는 것을 방지하도록 규정하고 있는바, 「물환경보전법 시행규칙」 별표 19의2 제1호나목2) 본문에서 규정하고 있는 15일의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우에도 15일의 말일까지 수질검사를 실시해야 한다고 보는 것이 물환경보전법령의 입법취지 및 규정 체계에 부합하는 해석입니다.

아울러 「물환경보전법 시행규칙」 별표 19의2 제1호나목2) 본문에서는 검사 시료를 가급적 이용자가 많은 날에 채수하도록 한다고 규정하고 있는데 물놀이형 수경시설은 주로 토요일이나 공휴일에 이용자가 많다는 점, 같은 목 1)에서 「먹는물관리법」 제43조에 따른 먹는물 수질검사기관에만 수질 검사를 의뢰하도록 규정하고 있었는데 검사기관의 수를 늘리고 토요일 및 공휴일 검사가 용이하도록 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조제1항에 따른 수질오염물질 측정대행업자에게도 수질 검사를 의뢰할 수 있도록 개정³⁾된 것이라는 점, 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 익일까지 수질검사를 실시해 된다고 해석하면 ‘15일마다’가 16일 이상으로 늘어나 그 주기가 늦춰지게 되어 법적 안정성이 저해될 수 있다는 점 등도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「물환경보전법 시행규칙」 별표 19의2 제1호나목2) 본문에서 규정하고 있는 15일의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우에도 말일까지 수질검사를 실시해야 합니다.

법령정비 권고사항

「물환경보전법 시행규칙」 별표 19의2 제1호나목2) 본문에서 규정하고 있는 15일의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일로 만료하는 것이 아니라는 점을 해당 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

3) 2019. 10. 17. 환경부령 제829호로 일부개정된 「물환경보전법 시행규칙」 별표 19의2 제1호나목1)에 수질오염물질 측정대행업자가 추가되었으며, 물놀이형 수경시설 운영·관리 가이드라인(2021) 76p 참조



관계법령

물환경보전법

제61조의2(물놀이형 수경시설의 신고 및 관리) ① 물놀이형 수경시설로서 다음 각 호의 시설을 설치·운영하려는 자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관 또는 시·도지사에게 신고하여야 한다. 환경부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

1. 국가·지방자치단체, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다)이 설치·운영하는 물놀이형 수경시설(민간사업자 등에게 위탁하여 운영하는 시설도 포함한다)
2. 공공기관 이외의 자가 설치·운영하는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설에 설치하는 물놀이형 수경시설
 - 가. 「공공보건의료에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 공공보건의료 수행기관
 - 나. 「관광진흥법」 제2조제6호 및 제7호에 따른 관광지 및 관광단지
 - 다. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 도시공원
 - 라. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 체육시설
 - 마. 「어린이놀이시설 안전관리법」 제2조제2호에 따른 어린이놀이시설
 - 바. 「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택
 - 사. 「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모점포
 - 아. 그 밖에 환경부령으로 정하는 시설

②·③ (생략)

④ 제1항에 따라 물놀이형 수경시설을 운영하는 자는 환경부령으로 정하는 수질 기준 및 관리 기준을 지켜야 하며, 환경부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 수질 검사를 받아야 한다.

물환경보전법 시행규칙

제89조의3(물놀이형 수경시설의 수질·관리 기준) 법 제61조의2제4항에 따른 물놀이형 수경시설의 수질 기준 및 관리 기준은 별표 19의2와 같다.

[별표 19의2]

물놀이형 수경시설의 수질 기준 및 관리 기준(제89조의3 관련)

1. 수질 기준

- 가. 측정항목별 수질 기준

검사항목	수질기준
1) 수소이온농도	5.8 ~ 8.6
2) 탁도	4NTU 이하
3) 대장균	200(개체수/100mL) 미만
4) 유리잔류염소(염소소독을 실시하는 경우만 해당한다)	0.4 ~ 4.0mg/L

나. 검사 방법 및 주기

- 1) 가목의 측정 항목에 대하여 「먹는물관리법」 제43조에 따른 먹는물 수질검사기관 또는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조제1항에 따른 수질오염물질 측정대행업자에게 수질 검사를 의뢰하여야 하며, 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 환경오염공정시험기준에 따라 검사하여야 한다.
- 2) 시설의 가동 개시일을 기준으로 운영 기간 동안 15일마다 1회 이상 검사를 실시하여야 하며, 검사 시료는 가급적 이용자가 많은 날에 채수하도록 한다. 다만, 천재지변, 강우 또는 그 밖의 부득이한 사유로 수질 검사주기를 초과한 경우에는 검사주기 초과사유 및 조치계획을 별지 제40호의5서식의 물놀이형 수경시설 관리카드의 수질검사 조치사항 항목에 기재해야 한다.

2. (생 략)

질의제목 2

▶ 안전번호 24-0951

민원인 - 반도체 제조시설 중 산처리시설이 「대기환경보전법 시행령」 제17조제5항 및 별표 3 제1호러목4)의 굴뚝 자동측정기기를 부착하여야 하는 배출시설에 해당하는지 여부(「대기환경보전법 시행령」 제17조제5항 등 관련)

01 질의요지

「대기환경보전법」 제2조제11호에서는 “대기오염물질배출시설”이란 대기오염물질을 대기에 배출하는 시설물, 기계, 기구 그 밖의 물체로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제5조 및 별표 3에서는 대기오염물질배출시설(이하 “배출시설”이라 함)을 구체적으로 규정하면서, 같은 표 제2호나목28)에서는 반도체 제조시설을 규정하고 있고, 같은 목 28)다)1)다)에서는 표면 처리시설로서 용적이 1세제곱미터 이상인 산·알칼리 처리시설을 규정하고 있으며,

「대기환경보전법」 제32조제1항 본문에서는 사업자¹⁾는 배출시설에서 나오는 대기오염물질(이하 “오염물질”이라 함)이 같은 법 제16조와 제29조제3항에 따른 배출허용기준에 맞는지를 확인하기 위해 측정기기를 부착하는 등의 조치를 하여 배출시설이 적정하게 운영되도록 하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제17조제1항에서는 배출시설을 운영하는 사업자는 오염물질배출량과 배출허용기준의 준수 여부를 확인할 수 있는 굴뚝 자동측정기기(제2호) 등 같은 항 각 호의 측정기기를 부착해야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제5항에서는 굴뚝 자동측정기기의 부착대상 배출시설, 측정항목, 부착 면제, 부착 시기 및 부착 유예는 별표 3과 같다고 규정하고 있고, 같은 표 제1호러목에서는 조립 금속제품·기계·기기·장비·운송장비·가구 제조시설(이하 “조립금속제품 등 제조시설”이라 함)을 규정하면서, 같은 목 4)에서는 산처리시설²⁾로 배출구별 배기가스량이 시간당 10,000표준세제곱미터 이상인 시설을, 같은 목 6)에서는 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 증착시설 및 식각시설³⁾로 배출구별 배기가스량이 시간당 10,000표준세제곱미터 이상인 시설을 각각 규정하고 있는바,

1) 「대기환경보전법」 제23조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 배출시설의 설치 허가·변경허가를 받은 자 또는 신고·변경신고를 한 자를 말하며(「대기환경보전법」 제26조 참조), 이하 같음

2) 염산 및 염화수소 사용시설로서 연속식의 경우에만 해당하며, 이하 같음

3) 염산 및 염화수소 사용시설로서 연속식의 경우에만 해당하며, 이하 같음

「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3 제2호나목28)의 반도체 제조시설(이하 “반도체 제조시설”이라 함) 중 산처리시설⁴⁾이 「대기환경보전법 시행령」 제17조제5항 및 별표 3 제1호러목4)의 굴뚝 자동측정기기를 부착하여야 하는 배출시설인 산처리시설에 해당하는지?

02 회답

반도체 제조시설 중 산처리시설은 「대기환경보전법 시행령」 제17조제5항 및 별표 3 제1호러목4)의 굴뚝 자동측정기기를 부착하여야 하는 배출시설인 산처리시설에 해당합니다.

03 이유

「대기환경보전법」 제2조제11호 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 별표 3에서는 배출시설을 구체적으로 규정하고 있는데, 같은 표 제2호나목 1)부터 37)까지에서 배출시설과 대상배출시설을 분류하여 규정하면서, 같은 목 24)에서는 금속가공제품·기계·기기·장비·운송장비·가구 제조시설을, 같은 목 28)에서는 반도체 제조시설을 각각 규정하고 있고, 「대기환경보전법」 제32조제1항 본문에서는 사업자는 배출시설에서 나오는 오염물질이 배출허용기준에 맞는지를 확인하기 위해 측정기기를 부착하는 등의 조치를 하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제17조제1항제2호에서는 부착하여야 하는 측정기기 중 하나로 굴뚝 자동측정기기를 규정하고 있고, 같은 조 제5항 및 별표 3에서는 굴뚝 자동측정기기를 부착하여야 하는 배출시설을 구체적으로 규정하면서, 같은 표 제1호러목에서는 조립금속제품 등 제조시설을 규정하고 있고, 같은 목 4)에서는 산처리시설을, 같은 목 6)에서는 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 증착시설 및 식각시설을 규정하고 있는바, 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3 제2호나목28)의 반도체 제조시설 중 산처리시설은 「대기환경보전법 시행령」 제17조제5항 및 별표 3 제1호러목4)의 굴뚝 자동측정기기를 부착하여야 하는 배출시설인 산처리시설에 해당하는지가 문제됩니다.

4) 이 사안 산처리시설은 「대기환경보전법 시행령」 별표 1의3에 따른 1종부터 3종까지의 사업장에 해당하며, 같은 영 별표 3 제1호러목4)에 따른 염산 및 염화수소 사용시설로서 연속식으로, 배출구별 배기가스량이 시간당 10,000표준세제곱미터 이상인 시설에 해당하는 경우를 전제로 함

먼저 「대기환경보전법 시행령」 별표 3 제1호의 문언을 살펴보면, 같은 호 러목에서 조립금속제품 등 제조시설을 규정하면서 그 분류 중 하나로 같은 목 6)에서는 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 증착시설 및 식각시설을 규정하고 있으므로, 같은 호 러목의 조립금속제품 등 제조시설에는 반도체 및 기타 전자부품 제조시설이 포함되는 것으로 보아야 할 것인데, 같은 목 6)의 증착시설 및 식각시설은 반도체 및 기타 전자부품 제조시설의 경우에만 굴뚝 자동측정기기 부착 대상 배출시설에 해당한다고 규정되어 있는 반면, 같은 목 4) 산처리시설은 반도체 및 기타 전자부품 제조시설로만 한정하고 있지 않으므로 반도체 및 기타 전자부품 제조시설을 포함한 모든 조립금속제품 등 제조시설 중 산처리시설은 굴뚝 자동측정기기 부착 대상 배출시설에 해당한다고 보아야 할 것인바, 반도체 제조시설 중 산처리시설도 「대기환경보전법 시행령」 별표 3 제1호러목에 따라 굴뚝 자동측정기기를 부착하여야 하는 배출시설인 산처리시설에 해당한다고 할 것입니다.

그리고 굴뚝 자동측정기기를 부착하여야 하는 배출시설 등에 관해 규정하고 있는 「대기환경보전법 시행령」 별표 3의 입법연혁을 살펴보면, 2005년 4월 15일 대통령령 제18788호로 「대기환경보전법 시행령」이 일부개정되면서 종전에는 사업자가 부착하여야 하는 측정기기의 종류 등을 환경부장관이 고시하도록 하던 것을, 오염물질 발생량이 많은 배출시설을 체계적으로 관리하고 행정의 투명성을 확보하기 위해 측정기기의 종류를 적산전력계와 굴뚝 자동측정기기로 명확히 규정하면서, 오염물질 발생량이 연간 10톤 이상인 사업자의 열처리시설 등에 대하여 굴뚝 자동측정기기를 부착하도록 규정⁵⁾하였고, 2008년 1월 15일 대통령령 제20547호로 「대기환경보전법 시행령」이 일부개정되면서 산업시설에서 배출하는 오염물질에 대한 관리를 강화하기 위해 유해물질을 많이 배출하는 반도체 및 그 밖의 전자부품 제조시설을 굴뚝 자동측정기기 부착 대상 배출시설에 추가하면서⁶⁾, 같은 영 별표 3 제1호다목에서 반도체 및 그 밖의 전자부품 제조시설의 증착시설 및 식각시설을 규정하였으며, 2010년 3월 26일 대통령령 제22100호로 일부개정된 「대기환경보전법 시행령」에서는 같은 법 시행규칙 별표 3에서 정하고 있는 배출시설 분류체계에 맞추어 굴뚝 자동측정기기 부착 대상 배출시설 분류체계를 정비하면서⁷⁾ 현행 「대기환경보전법 시행령」 별표 3 제1호러목과 같이 규정하게 된 것인데, 당시 2010년 1월 6일 환경부령 제358호로 일부개정된 「대기환경보전법 시행규칙」 제5조 및 별표 3에서는 반도체 및 기타 전자부품 제조시설이 같은 표 제2호나목21)의 조립금속제품 등 제조시설에 포함되어 있었던바, 이러한

5) 2005. 4. 15. 대통령령 제18788호로 일부개정된 「대기환경보전법 시행령」 개정이유 및 주요내용 참조

6) 2008. 1. 15. 대통령령 제20547호로 일부개정된 「대기환경보전법 시행령」 개정이유 및 주요내용 참조

7) 2010. 3. 26. 대통령령 제22100호로 일부개정된 「대기환경보전법 시행령」 개정이유 및 주요내용 참조

입법연혁과 개정취지를 고려하면 반도체 제조시설은 「대기환경보전법 시행령」 별표 3 제1호러목의 조립금속제품 등 제조시설에 포함된 것으로서, 반도체 제조시설 중 산처리시설은 굴뚝 자동측정기기 부착 대상 배출시설인 러목의 조립금속제품 등 제조시설의 산처리시설에 해당한다고 해석하는 것이 타당합니다.

또한 「대기환경보전법」은 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리·보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 같은 법 시행령 제17조제1항제2호 및 같은 조 별표 3에 따른 굴뚝 자동측정기기 부착 의무는 굴뚝 자동측정기기를 통해 배출시설의 배출구(굴뚝)에서 나오는 오염물질을 실시간으로 관리·확인하여 대기오염사고를 사전에 예방하고 오염물질 관리의 투명성을 확보하기 위한 것이고⁸⁾, 모든 조립금속제품 등 제조시설의 산처리시설에 굴뚝 자동측정기기를 부착하도록 하고 있는 점 등을 고려할 때, 반도체 제조시설 중 산처리시설은 조립금속제품 등 제조시설의 산처리시설에 해당하여 굴뚝 자동측정기기를 부착할 의무가 있다고 보는 것이 규정취지에도 부합한다고 할 것입니다.

한편 「대기환경보전법」 제2조제11호 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 별표 3에서는 배출시설을 구체적으로 규정하고 있는데, 같은 표 제2호나목 1)부터 37)까지에서 배출시설과 대상배출시설을 분류하여 규정하면서, 같은 목 24)에서 금속가공제품·기계·기기·장비·운송장비·가구 제조시설을, 같은 목 28)에서 반도체 제조시설을 각각 규정하고 있으므로, 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 3의 배출시설의 분류체계에 비추어 보면 「대기환경보전법 시행령」 별표 3 제1호러목의 조립금속제품 등 제조시설에는 반도체 제조시설이 포함되지 않는다는 의견이 있으나, 배출시설과 굴뚝 자동측정기기를 부착하여야 하는 배출시설은 별개의 사항으로 배출시설 분류체계와 반드시 동일할 필요는 없다는 점을 고려할 때, 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 반도체 제조시설 중 산처리시설은 「대기환경보전법 시행령」 제17조제5항 및 별표 3 제1호러목4)의 굴뚝 자동측정기기를 부착하여야 하는 배출시설인 산처리시설에 해당합니다.

8) 2008. 9. 10. 환경부 보도자료, 2024. 6. 27. 환경부 보도자료 참조

법령정비 권고사항

대기환경보전법 시행령」별표 3의 굴뚝 자동측정기기의 부착대상 배출시설 규정체계와 같은 법 시행규칙 별표 3의 배출시설 규정체계가 일치하지 않아 해석상 혼란이 발생할 수 있으므로, 관련 내용을 명확하게 규정하는 방안을 검토할 필요가 있습니다.



관계법령

대기환경보전법

제32조(측정기기의 부착 등) ① 사업자는 배출시설에서 나오는 오염물질이 제16조와 제29조제3항에 따른 배출허용기준에 맞는지를 확인하기 위하여 측정기기를 부착하는 등의 조치를 하여 배출시설과 방지시설이 적정하게 운영되도록 하여야 한다. 다만, 사업자가 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업인 경우에는 환경부장관 또는 시·도지사가 사업자의 동의를 받아 측정기기를 부착·운영하는 등의 조치를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 조치의 유형과 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ ~ ⑩ (생략)

대기환경보전법 시행령

제17조(측정기기의 부착대상 사업장 및 종류 등) ① 배출시설을 운영하는 사업자는 법 제32조제1항 및 제2항에 따라 오염물질배출량과 배출허용기준의 준수 여부 및 방지시설의 적정 가동 여부를 확인할 수 있는 다음 각 호의 측정기기를 제4항부터 제6항까지에서 정하는 바에 따라 부착해야 한다.

1. (생략)

2. 굴뚝 자동측정기기{유량·유속계(流量·流速計), 온도측정기 및 자료수집기를 포함한다. 이하 같다}

3. (생략)

② ~ ④ (생략)

⑤ 제1항제2호에 따라 굴뚝 자동측정기기를 부착하여야 하는 사업장은 별표 1의3에 따른 1종부터 3종까지의 사업장으로 하며, 굴뚝 자동측정기기의 부착대상 배출시설, 측정 항목, 부착 면제, 부착 시기 및 부착 유예(猶豫)는 별표 3과 같다.

⑥ · ⑦ (생략)

[별표 3]

굴뚝 자동측정기기의 부착대상 배출시설, 측정 항목, 부착 면제,**부착 시기 및 부착 유예(제17조제5항 관련)**

1. 굴뚝 자동측정기기 부착대상 배출시설 및 측정항목

부착대상 배출시설	측정항목
가. ~ 더. (생 략)	(생 략)
러. 조립금속제품·기계·기기·장비·운송장비·가구 제조시설 1) 전기로(아크로만 해당한다) - 배출구별 배기가스량이 시간당 10,000표준세제곱미터 이상인 시설	먼지
2) 가열로 - 배출구별 배기가스량이 시간당 50,000표준세제곱미터 이상인 시설	먼지, 질소산화물, 황산화물
3) 전로, 용융·용해로 - 배출구별 배기가스량이 시간당 50,000표준세제곱미터 이상인 시설	먼지, 황산화물
4) 산처리시설(염산 및 염화수소 사용시설로서 연속식의 경우에만 해당한다) - 배출구별 배기가스량이 시간당 10,000표준세제곱미터 이상인 시설	염화수소
5) 주물사(鑄物砂) 처리시설(연속식만 해당한다) - 배출구별 배기가스량이 시간당 100,000표준세제곱미터 이상인 시설	먼지
6) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 증착시설 및 식각시설(염산 및 염화수소 사용시설로서 연속식만 해당한다) - 배출구별 배기가스량이 시간당 10,000표준세제곱미터 이상인 시설	염화수소
머. ~ 처. (생 략)	(생 략)

비고 (생 략)

2.·3. (생 략)

대기환경보전법 시행규칙

제5조(대기오염물질배출시설) 법 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설(이하 “배출시설”이라 한다)은 별표 3과 같다.

[별표 3]

대기오염물질배출시설(제5조 관련)

1. (생 략)

2. 2020년 1월 1일부터 적용되는 대기오염물질배출시설

가. (생 략)

나. 배출시설의 분류

배출시설	대상 배출시설
1) ~ 27) (생 략)	(생 략)
28) 반도체 제조시설	가) 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 증착시설 (2) 식각시설 나) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설 (1) 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로(유도로를 포함한다) (2) 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로 (3) 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 (4) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 전로 (나) 정련로 (다) 용융·용해로 (라) 가열로(연소시설을 포함한다) (마) 열처리로(소둔로·소려로를 포함한다) (바) 전해로 (사) 건조로 다) 표면 처리시설 (1) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 도금시설 (나) 탈지시설 (다) 산·알칼리 처리시설 (라) 화성처리시설 (2) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속의 표면처리용 건조시설(수세 후 건조시설은 제외한다)
29) ~ 37) (생 략)	(생 략)

비고 (생 략)
다.·라. (생 략)

질의제목 3

▶ 안전번호 24-0987

환경부 - 「폐기물관리법」에 따라 건설폐기물 중간처리업 허가를 받은 자의 사업장 부지 면적 요건에 대하여 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 부칙 제4조 단서가 적용되는지(법률 제11879호 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제4조 등 관련)

01 질의요지

2003년 12월 31일 법률 제7043호로 제정된 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」(이하 “제정 건설폐기물법”이라 함)에서는 「폐기물관리법」(2003년 12월 30일 법률 제7022호로 일부개정된 것을 말하며, 이하 “구 「폐기물관리법」”이라 함)에서 규정하고 있던 건설폐기물 관련 사항을 규정하면서, 제정 건설폐기물법 제21조제1항에서는 건설폐기물 중간처리업의 허가기준이 되는 시설·장비·기술능력·자본금 및 사업장 부지의 규모 등에 관하여 필요한 세부사항은 환경부령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙(이하 “제정 건설폐기물법 시행규칙”이라 함) 별표 2 제2호에서는 건설폐기물 중간처리업의 허가기준으로 탈수·건조시설, 수집·운반차량 등의 시설 및 장비 등을 갖추도록 규정하면서, 같은 호 라목에서는 3,300제곱미터 이상의 사업장 부지를 갖추도록 하여 사업장 부지에 관한 허가기준을 신설하였으며, 제정 건설폐기물법 부칙 제2조제1항에서는 이 법 시행 당시 구 「폐기물관리법」 제26조제3항의 규정에 의하여 폐기물의 처리에 관한 수집·운반업 또는 중간처리업 허가를 받은 자는 제정 건설폐기물법 제21조제4항의 규정에 의한 수집·운반업 또는 중간처리업 허가를 받은 것으로 본다고 규정하되, 같은 법 부칙 제2조제2항에서는 같은 조 제1항의 규정에 의한 건설폐기물처리업자는 이 법 시행 후 1년 6개월 이내에 제21조제1항의 규정에 의한 허가기준에 적합한 시설 및 장비를 갖추어 제22조의 규정에 의한 변경허가를 받아야 한다고 규정하고 있으며,

이후 2013년 6월 12일 법률 제11879호로 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」(이하 “개정 건설폐기물법”이라 함)이 일부개정되면서, 같은 법 제21조제3항에서는 건설폐기물 처리업¹⁾을 하려는 자가 건설폐기물 처리 사업계획이 적합하다는 통보를 받은 경우에는 같은 항 각 호의 기준을 갖추어 시·도지사²⁾의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 항

1) 건설폐기물의 수집·운반업 또는 중간처리업을 말하며, 이하 같음

2) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사를 말하며, 이하 같음

제2호에서는 환경부령으로 정하는 시설, 장비, 기술능력, 자본금 및 사업장 부지와 그 밖에 필요한 사항을 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙(이하 “개정 건설폐기물법 시행규칙”이라 함) 제12조제5항 및 별표 2 제2호라목에서는 제정 건설폐기물법 시행규칙에서와 같이 사업장 부지는 3,300제곱미터 이상일 것을 규정하고 있고, 개정 건설폐기물법 부칙 제4조 본문에서는 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 허가된 건설폐기물 처리업은 제21조제3항의 개정규정에 따라 허가를 받은 것으로 본다고 규정하면서, 같은 법 부칙 제4조 단서에서는 제21조제3항의 개정규정에 따른 요건을 갖추지 아니한 건설폐기물 처리업자는 2016년 1월 1일까지 같은 개정규정에 따른 요건을 갖추어 변경허가를 받아야 한다고 규정하고 있는바,

구 「폐기물관리법」 제26조제3항에 따른 건설폐기물 중간처리업 허가를 받은 자로서 제정 건설폐기물법 부칙 제2조제1항에 따라 같은 법 제21조제3항에 따른 건설폐기물 중간처리업 허가를 받은 것으로 보는 자가 사업장 부지 면적이 3,300제곱미터 미만인 경우³⁾, 사업장 부지 면적에 대해서 개정 건설폐기물법 부칙 제4조 단서가 적용되는지?

02 회답

이 사안의 경우, 사업장 부지 면적에 대해서 개정 건설폐기물법 부칙 제4조 단서가 적용되지 않습니다.

03 이유

건설폐기물처리업의 허가 기준에 관하여 규정하고 있던 제정 건설폐기물법 제21조제1항의 내용은 법률이 개정되면서 개정 건설폐기물법 제21조제3항에서 규정하고 있는데, 개정 건설폐기물법 제21조제3항에서는 사업계획이 적합하다는 통보를 받은 자는 같은 항 각 호의 기준을 갖추어 시·도지사의 허가를 받아야 한다고 규정하면서, 같은 항에 제1호를 신설하여 “「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호가목에 해당하는 지역으로부터 환경부령으로 정하는 일정거리 이내에 위치한 처리시설을 설치·운영하는 경우 환경부령으로 정하는 바에 따른 비산먼지·침출수·악취를 방지하는 건물 또는 시설”을 규정하고 있고, 개정

3) 제정 건설폐기물법 시행 이후 사업장 부지 면적이 변경 없이 3,300제곱미터 미만인 경우를 전제로 함

건설폐기물법 제21조제3항제2호에서는 종전의 규정 내용과 동일하게 “환경부령으로 정하는 시설, 장비, 기술능력, 자본금 및 사업장 부지와 그밖에 필요한 사항”을 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 개정 건설폐기물법 시행규칙 별표 2 제2호라목에서는 종전과 동일하게 사업장 부지는 3,300제곱미터 이상일 것을 규정하고 있는 한편, 개정 건설폐기물법 부칙 제4조 본문에서는 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 허가된 건설폐기물 중간처리업은 제21조제3항의 개정규정에 따라 허가를 받은 것으로 본다고 규정하면서, 같은 법 부칙 제4조 단서에서는 제21조제3항의 개정규정에 따른 요건을 갖추지 아니한 건설폐기물 중간처리업자는 2016년 1월 1일까지 같은 개정규정에 따른 요건을 갖추어 변경허가를 받아야 한다고 규정하고 있는바, 구 「폐기물관리법」 제26조제3항에 따라 건설폐기물 중간처리업 허가를 받은 자로서 사업장 부지 면적이 3,300제곱미터 미만인 경우에는 개정 건설폐기물법 제21조제3항에 따른 허가기준 중 종전과 동일한 사업장 부지의 면적 요건(3,300제곱미터 이상일 것)에 대해서도 같은 법 부칙 제4조 단서가 적용되는지 문제됩니다.

일반적으로 법령의 개정에 따라 부칙에 규정되는 경과조치는 구법질서에서 신법질서로의 이행과정에서 나타나는 제도변화와 법적 안정성을 적절히 조화시키는 한편, 특정대상에 대한 신구법령의 적용관계를 분명히 규정함으로써 법질서의 원만한 전환을 보장하는 기능을 수행한다고 할 것인데⁴⁾, 개정 건설폐기물법 부칙 제4조의 취지는 이미 건설폐기물 중간처리업 허가를 받아 영위하던 자가 법령의 개정으로 인하여 입게 되는 불이익을 방지하기 위해 개정 건설폐기물법에 따른 별도의 허가 절차 없이 개정 건설폐기물법에 편입되게 함으로써 건설폐기물 중간처리업자의 기득권을 보호하면서, 종전의 건설폐기물 중간처리업자가 개정 건설폐기물법에서 신설되거나 개정된 허가요건을 갖추 수 있도록 필요한 유예기간을 주어 새로운 법질서로 원만하게 전환할 수 있도록 하려는 것인바, 개정 건설폐기물법의 시행으로 새로운 허가기준이 추가되는 등 건설폐기물 처리업의 허가기준이 강화되었으나, 건설폐기물 중간처리업의 사업장 부지의 면적 요건은 개정 건설폐기물법의 시행 전과 달라진 사항이 없고, 개정 건설폐기물법과 관련하여 당초 발의된 건설폐기물법 일부개정법률안⁵⁾에서도 사업장 부지 면적 요건에 관해서는 별도로 규정하고 있지 않은 점에 비추어 보면, 이 사안의 경우 개정 건설폐기물법의 시행 전과 동일하게 규정하고 있는 사업장 부지 면적에 대해서는 개정 건설폐기물법 부칙 제4조 단서가 적용되지 않는다고 할 것입니다.

4) 법제처 2012. 4. 10. 회신 12-0075 해석례 참조

5) 2012. 11. 22. 의안번호 제1902750호로 발의된 건설폐기물법 일부개정법률안 및 2012. 12. 21. 의안번호 제1903110호로 발의된 건설폐기물법 일부개정법률안 참조

특히 개정 건설폐기물법 제21조제3항에서 규정하고 있는 건설폐기물 처리업 허가기준의 입법연혁을 살펴보면, 종전에는 건설폐기물 처리업 허가기준으로 환경부령으로 정하는 시설, 장비, 기술능력, 자본금 및 사업장 부지와 그 밖에 필요한 사항만 규정하고 있었으나, 건설폐기물 처리시설이 주거 및 유동인구 밀집지역 인근에 위치하게 되면 비산먼지·소음·진동으로 인해 인근 주민의 건강에 위해가 발생할 우려가 있어 건설폐기물 처리시설이 주거지역으로부터 1킬로미터 이내에 위치한 경우에는 중간처리시설 전체를 옥내화하거나 중간처리시설 공정에 덮개를 설치하도록 하는 등 같은 항에 제1호의 기준을 신설하여 건설폐기물 처리업 허가기준을 강화한 것인바⁶⁾, 개정 건설폐기물법 부칙 제4조 단서에 따른 변경허가 대상은 같은 법 제21조제3항의 허가기준 중 신설된 기준과 같이 실제 변경이 있는 사항만 해당한다고 할 것이고, 변경된 사항이 없는 사업장 부지 면적에 관해서는 개정 건설폐기물법 부칙 제4조 단서가 적용되지 않는다고 해석하는 것이 해당 규정의 입법연혁과 경과조치의 취지에 부합하는 해석입니다.

그리고 건설폐기물 중간처리업자에 대한 사업장 부지 면적 요건은 제정 건설폐기물법 제21조제1항에서 신설된 규정으로서, 그 위임에 따라 제정 건설폐기물법 시행규칙 별표 2 제2호라목에서 건설폐기물 중간처리업자에 대한 사업장 부지 면적 요건을 3,300제곱미터 이상으로 신설하게 된 것인데, 제정 건설폐기물법 부칙 제2조제2항에 따른 변경허가의 대상은 허가기준 중 시설 및 장비에 한정되므로, 구 「폐기물관리법」 제26조제3항에 따라 건설폐기물 중간처리업 허가를 받은 자로서 사업장 부지 면적이 3,300제곱미터 미만인 경우에는 제정 건설폐기물법 부칙 제2조에 따라 사업장 부지 면적 요건을 갖추지 않아도 같은 법에 따른 건설폐기물 중간처리업자로서의 지위를 인정받으며 허가기준에 미달된다고 볼 수 없었는데⁷⁾, 만약 개정 건설폐기물법 부칙 제4조 단서에 따라 사업장 부지 면적 요건을 갖추어 변경허가를 받아야 한다고 본다면, 개정 건설폐기물법 시행으로 인해 건설폐기물 중간처리업의 사업장 부지 면적 요건은 변경이 없음에도 불구하고 오히려 구 「폐기물관리법」 제26조제3항에 따라 이미 건설폐기물 중간처리업 허가를 받은 자에 대한 허가기준이 강화되는 결과가 초래되어 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 사업장 부지 면적에 대해서 개정 건설폐기물법 부칙 제4조 단서가 적용되지 않습니다.

6) 2012. 11. 22. 의안번호 제1902750호로 발의된 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 환경노동위원회 검토보고서 및 2013. 12. 13. 환경부령 제529호로 일부개정된 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 개정이유 및 주요내용 참조

7) 법제처 2012. 4. 10. 회신 12-0075 해석례 참조



건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률(2003. 12. 31. 법률 제7043호로 제정되어 2005. 1. 1. 시행된 것)

제21조(건설폐기물처리업의 허가 등) ① 수집·운반업과 중간처리업의 허가기준이 되는 시설·장비·기술능력·자본금(개인의 경우에는 자산평가액을 말한다. 이하 같다) 및 사업장 부지의 규모 등에 관하여 필요한 세부사항은 환경부령으로 정한다.

②·③ (생 략)

④ 제3항의 규정에 의하여 적정 통보를 받은 자는 제1항의 규정에 의한 시설·장비·기술능력 및 자본금 그 밖에 필요한 사항을 갖추어 시·도지사의 허가를 받아야 한다. 이 경우 시·도지사는 허가를 함에 있어 대통령령이 정하는 바에 따라 필요한 조건을 붙일 수 있다.

⑤ (생 략)

법률 제7043호 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 부칙

제2조(건설폐기물처리업자에 관한 경과조치) ① 이 법 시행 당시 폐기물관리법 제26조제3항의 규정에 의하여 폐기물의 처리에 관한 수집·운반업 또는 중간처리업 허가를 받은 자는 제21조제4항의 규정에 의한 수집·운반업 또는 중간처리업 허가를 받은 것으로 본다.

② 제1항의 규정에 의한 건설폐기물처리업자는 이 법 시행 후 1년 6월 이내에 제21조제1항의 규정에 의한 허가기준에 적합한 시설 및 장비를 갖추어 제22조의 규정에 의한 변경허가를 받아야 한다.

건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙(2005. 1. 19. 환경부령 제169호로 제정되어 같은 날 시행된 것)

제12조 (건설폐기물처리업의 허가 등) ① 법 제21조제1항의 규정에 의한 건설폐기물수집·운반업 및 중간처리업의 허가기준은 별표 2와 같다.

② ~ ⑤ (생 략)

[별표 2]

건설폐기물 수집·운반업 및 중간처리업의 허가기준(제12조제1항관련)

1. (생 략)

2. 중간처리업의 허가기준

가. ~ 다. (생 략)

라. 사업장 부지 : 3,300제곱미터 이상(순환아스팔트콘크리트 전용생산시설의 경우 2,000제곱미터 이상)

3. (생 략)

건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률(2013. 6. 12. 법률 제11879호로 일부개정되어 2014. 6. 13. 시행된 것)

제21조(건설폐기물 처리업의 허가 등) ①·② (생 략)

③ 제2항에 따라 사업계획이 적합하다는 통보를 받은 자는 다음 각 호의 기준을 갖추어 시·도지사의 허가를 받아야 한다. 이 경우 시·도지사는 제2항에 따라 사업계획의 적합 통보를 받은 자가 해당 사업계획에 따라 시설, 장비, 기술능력 등의 요건을 갖추어 허가신청을 한 경우에는 지체 없이 허가하여야 한다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호가목에 해당하는 지역으로부터 환경부령으로 정하는 일정거리 이내에 위치한 처리시설을 설치·운영하는 경우 환경부령으로 정하는 바에 따른 비산먼지·침출수·악취를 방지하는 건물 또는 시설
2. 환경부령으로 정하는 시설, 장비, 기술능력, 자본금(개인인 경우에는 자산평가액을 말한다. 이하 같다) 및 사업장 부지와 그 밖에 필요한 사항

④ ~ ⑥ (생 략)

법률 제11879호 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 일부개정법을 부칙

제4조(건설폐기물 처리업 허가에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 허가된 건설폐기물 처리업은 제21조제3항의 개정규정에 따라 허가를 받은 것으로 본다. 다만, 제21조제3항의 개정규정에 따른 요건을 갖추지 아니한 건설폐기물 처리업자는 2016년 1월 1일까지 같은 개정규정에 따른 요건을 갖추어 변경허가를 받아야 한다.

건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙(2013. 12. 13. 환경부령 제529호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것)

제12조(건설폐기물 처리업의 허가 등) ① 삭제

②·③ (생 략)

⑤ 법 제21조제3항제2호에 따른 시설, 장비, 기술능력, 자본금 및 사업장 부지와 그 밖에 필요한 사항은 별표 2와 같다.

⑥ ~ ⑧ (생 략)

[별표 2]

건설폐기물 수집·운반업 및 중간처리업의 허가기준(제12조제1항관련)

1. (생 략)
2. 중간처리업의 허가기준
 - 가. ~ 다. (생 략)
 - 라. 사업장 부지 : 3,300제곱미터 이상(순환아스팔트콘크리트 전용생산시설의 경우 2,000제곱미터 이상)
3. (생 략)

질의제목 4

▶ 안전번호 25-0018

경기도 남양주시 - 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조제3항제2호에 따른 수변구역 지정 해제의 예외 사유에 해당하는지 여부(「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조제3항제2호 등 관련)

01 질의요지

「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」(이하 “한강수계법”이라 함) 제4조제1항에서는 환경부장관은 한강수계의 수질보전을 위하여 팔당호, 한강, 북한강, 경안천의 양안(兩岸) 중 같은 항 각 호에 해당되는 지역으로서 필요하다고 인정하는 지역을 수변구역(이하 “수변구역”이라 함)으로 지정·고시한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 환경부장관은 수변구역을 지정·고시하려면 「하수도법」 제2조제15호에 따른 하수처리구역(제4호) 등에 해당하는 지역은 수변구역에서 제외하여야 한다고 규정하고 있는 한편,

한강수계법 제4조제3항 본문에서는 환경부장관은 수변구역이 같은 조 제2항제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 절차에 따라 수변구역 지정을 해제하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제3항 단서 및 제2호에서는 수변구역으로 지정된 지역이 관할 지방자치단체의 장이 수질개선 등을 위하여 수변구역 지정을 해제하지 아니할 것을 조건으로 수변구역의 일부에 공공하수처리시설을 설치한 것을 사유로 「하수도법」 제2조제15호에 따른 하수처리구역(이하 “하수처리구역”이라 함)으로 편입된 경우에는 한강수계법 제4조제2항에도 불구하고 수변구역 지정을 해제하지 아니한다고 규정하고 있는바,

수변구역 일부에 설치된 하수관로가 수변구역 외의 지역에 설치된 공공하수처리시설에 연결된 경우로서 관할 지방자치단체의 장이 수질개선 등을 위하여 수변구역 지정을 해제하지 아니할 것을 조건으로 수변구역 내외의 지역이 하나의 하수처리구역으로 편입된 경우, 환경부장관은 한강수계법 제4조제3항 단서에 따라 수변구역 지정을 해제하지 않아야 하는지, 아니면 같은 항 본문에 따라 수변구역 지정을 해제하여야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 환경부장관은 한강수계법 제4조제3항 단서에 따라 수변구역 지정을 해제하지 않아야 합니다.

03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 할 것인바¹⁾, 이 사안과 같이 수변구역 일부에 설치된 하수관로가 수변구역 외의 지역에 설치된 공공하수처리시설에 연결된 경우로서 관할 지방자치단체의 장이 수변구역 지정을 해제하지 아니할 것을 조건으로 수변구역 내외의 지역이 하나의 하수처리구역으로 편입된 경우 한강수계법 제4조제3항에 따라 수변구역 지정을 해제해야 하는지 여부를 판단하기 위해서는 법령의 문언 및 체계와 함께 그 제·개정 연혁, 입법 취지와 목적, 법질서 전체와의 조화 등을 종합적으로 고려해야 할 것입니다.

먼저 한강수계법 제4조에 따르면 환경부장관은 한강수계의 수질 보전을 위하여 팔당호, 한강 등의 양안 중 필요하다고 인정하는 지역을 수변구역으로 지정·고시하고(제1항), 하수처리구역 등은 수변구역에서 제외하여야 하며(제2항), 하수처리구역 등에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 절차에 따라 수변구역 지정을 해제하여야 하나(제3항 본문), 수변구역으로 지정된 지역이 같은 조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 ‘하수처리구역’으로 편입되는 경우에는 수변구역 지정을 해제하지 아니한다고 규정하면서(제3항 단서), 같은 항 제2호에서는 지정 해제의 예외 사유로 ‘관할 지방자치단체의 장이 수변구역 지정을 해제하지 아니할 것을 조건으로 수변구역의 일부에 공공하수처리시설을 설치한 경우’를 규정하고 있는바, 한강수계법 제4조제2항·제3항에서 수변구역의 지정 해제 및 그 해제의 예외는 모두 ‘하수처리구역’을 대상으로 하고 있는 점에 비추어 보면, 한강수계법 제4조제3항 단서 및

1) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

제2호에 따른 수변구역 지정 해제의 예외 사유를 해석할 때에도 하수처리구역 편입 여부를 중요한 기준으로 하면서 그 지정 해제의 예외 사유를 둔 입법 취지까지 고려하여 판단할 필요가 있습니다.

그런데 한강수계법 제4조에 따른 수변구역의 지정 및 해제에 관한 입법연혁을 살펴보면, 공공하수처리시설이 설치된 하수처리구역은 환경기반시설이 갖추어진 지역이므로 수변구역 지정이 적절하지 않은 점을 고려하여²⁾ 한강수계법 제정 당시부터 수변구역을 지정하려는 때에는 하수처리구역은 수변구역에서 제외하여야 하고, 수변구역이 하수처리구역에 해당하는 때에는 수변구역 지정을 해제하여야 한다고 규정하고 있었는데³⁾, 이후 2007년 8월 3일 법률 제8614호로 일부개정된 한강수계법에서 수변구역에 주민지원사업으로 공공하수처리시설이 설치되어 하수처리구역으로 편입된 경우에는 수변구역 지정을 해제하지 않는다는 규정을 신설하여, 상수원관리지역의 주민을 위해서 주민지원사업으로 오염물질 정화 등을 위한 공공하수처리시설을 설치하는 경우는 수변구역 지정 해제의 예외를 두었으며, 2014년 1월 28일 법률 제12369호로 일부개정된 한강수계법에서 수변구역 지정 해제의 예외 사유를 추가하여, 수변구역이 하수처리구역으로 편입되지 않아 수변구역 내 주민이 직접 개인오수처리시설을 설치·처리하고 비용을 부담하는 등의 불편이 발생함에 따라 이를 개선하기 위해 수변구역 지정을 해제하지 않을 것을 조건으로 공공하수처리시설을 수변구역에 설치하는 경우에 수변구역의 제한을 그대로 적용할 수 있도록 한 것인바⁴⁾, 이러한 한강수계법 제4조제3항의 입법연혁 및 취지를 고려하면, 이 사안의 경우 수변구역 일부가 편입된 하수처리구역을 기준으로 해당 하수처리구역에 설치된 공공하수처리시설에서 그 수변구역에서 발생하는 하수를 처리하고 있다는 점에서 한강수계법 제4조제3항제2호의 경우와 달리 볼 것은 아니라고 할 것입니다.

그리고 공공하수처리시설의 설치 및 하수처리구역의 편입에 대해서는 하수도법령에서 규정하고 있는데, 「하수도법」 제2조에 따르면 “하수관로”란 하수를 공공하수처리시설 등으로 이송하거나 하천 등으로 유출시키기 위하여 지방자치단체가 설치·관리하는 관로와 그 부속시설을(제6호), “공공하수처리시설”이란 하수를 처리하여 하천 등에 방류하기 위하여 지방자치단체가 설치·관리하는 처리시설과 이를 보완하는 시설을(제9호), “하수처리구역”이란 하수를 공공하수처리시설에 유입하여 처리할 수 있는 지역으로서 같은 법 제15조에 따라 공고된 구역을(제15호) 각각 의미하고, 같은 법 제15조제2항에서는 하수처리구역은

2) 상생의 강으로 화합의 강으로 - 4대강물관리대책 수립에서 특별법 제정까지(환경부, 2002년) 참조

3) 1999. 2. 8. 법률 제5932호로 제정된 한강수계법 제4조 참조

4) 2012. 12. 21. 의안번호 제1903111호로 발의된 한강수계법 일부개정법률안에 대한 국회 환경노동위원회 검토보고서 참조

하수관로로부터 직선거리 300미터의 범위에서 정할 수 있다고 규정하고 있는바, 하수는 오염도를 낮추고 수질을 적정하게 유지·관리하기 위하여 그 이송부터 처리, 방류에 이르기까지 일련의 단계를 이루어 관리되고 있고⁵⁾, 하수처리구역은 하수관로로부터 일정 거리 내의 지역을 하수처리구역으로 지정함으로써 그 구역 안의 하수를 미리 정해진 공공하수처리시설에 유입하여 처리하게 하는 지역적 범위를 설정하는 데에 그 본질이 있는 점⁶⁾ 등에 비추어 보면, 이 사안과 같이 수변구역 일부에 설치된 하수관로를 통해 수변구역 외의 지역에 설치된 공공하수처리시설로 하수가 이송되면서, 관할 지방자치단체의 장이 수질개선 등을 위하여 수변구역 지정을 해제하지 아니할 것을 조건으로 그 하수관로와 공공하수처리시설이 하나의 하수처리구역으로 편입된 경우에는 한강수계법 제4조제3항 단서에 따른 수변구역 지정 해제의 예외에 해당한다고 보는 것이 한강수계법령과 하수도법령의 규정 체계에 부합하는 해석입니다.

또한 한강수계법은 상수원을 적절하게 관리하고 상수원 상류지역의 수질개선 및 주민지원 사업을 효율적으로 추진하여 상수원의 수질을 개선함을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 한강수계의 수질 보전을 위하여 수변구역을 지정하고(제4조), 누구든지 수변구역에서는 단독주택, 공동주택, 식품접객업을 영위하는 시설이나 공장 등을 새로 설치(용도변경을 포함함)하여서는 아니 되는 등 일정한 행위제한을 규정하고 있는바(제5조제1항), 수변구역의 지정·관리와 수변구역에서의 행위제한 등을 통해 상수원을 적절하게 관리하려는 한강수계법령의 취지를 고려하면, 수변구역의 지정 및 해제와 관련해서는 상수원의 수질 개선 및 국민의 환경권⁷⁾을 최대한 보장할 수 있는 방향으로 해석해야 할 것인데, 수변구역 지정을 해제하지 아니할 것을 조건으로 수변구역 내외의 지역이 하나의 하수처리구역으로 편입된 이상 공공하수처리시설이 설치된 지역이 수변구역의 일부인지 수변구역 외의 지역인지에 따라 상수원의 관리나 수질 개선의 측면에서 양자를 다르게 보기 어렵다는 점에서도 수변구역 일부에 하수관로와 함께 공공하수처리시설이 설치된 경우에만 한정하여 수변구역 지정 해제의 예외에 해당한다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 환경부장관은 한강수계법 제4조제3항 단서에 따라 수변구역 지정을 해제하지 않아야 합니다.

5) 헌법재판소 2021. 3. 25. 선고 2018헌바375 결정례 참조

6) 서울고등법원 2017. 8. 18. 선고 2017누32847 판결례 참조

7) 「대한민국헌법」 제35조제1항 참조



관계법령

한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률

제4조(수변구역의 지정·해제 등) ① (생 략)

② 환경부장관은 제1항에 따른 수변구역(이하 “수변구역”이라 한다)을 지정·고시하려면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역은 수변구역에서 제외하여야 한다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 「하수도법」 제2조제15호에 따른 하수처리구역

5. 6. (생 략)

③ 환경부장관은 수변구역이 제2항제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 절차에 따라 수변구역 지정을 해제하여야 한다. 다만 제1항에 따라 수변구역으로 지정된 지역이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 사유로 「하수도법」 제2조제15호에 따른 하수처리구역으로 편입되는 경우에는 제2항에도 불구하고 수변구역 지정을 해제하지 아니한다.

1. (생 략)

2. 관할 지방자치단체의 장이 수질개선 등을 위하여 수변구역 지정을 해제하지 아니할 것을 조건으로 수변구역의 일부에 공공하수처리시설을 설치한 경우

④·⑤ (생 략)

질의제목 5

▶ 안전번호 25-0079

환경부 - 폐기물처리업자가 설치한 폐기물처리시설에서 음식물류폐기물을 가축의 먹이로 생산하여 사용할 수 있는지 여부(「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3 등 관련)

01 질의요지

「폐기물관리법」 제13조의2제1항에서는 누구든지 같은 항 각 호를 위반하지 아니하는 경우에는 폐기물을 재활용할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 제5호에서는 그 밖에 환경부령으로 정하는 재활용의 기준을 준수할 것을 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제14조의3제1항 및 별표 5의3 제2호에서는 폐기물의 재활용 기준으로 유형별 재활용의 세부기준을 규정하면서, 같은 호 다목1)다)(3)에서 농업이나 토질개선을 위하여 재활용하는 유형 중 자가 사육하는 가축(지렁이는 제외함)의 먹이나 자가 농경지 또는 초지의 퇴비로 사용하는 유형(R-5-4 유형)의 재활용 기준으로 가축전염병이 발생하였거나 발생할 우려가 있어 농림축산식품부장관이 환경부장관에게 음식물류폐기물의 가축 먹이 사용금지를 요청한 경우에는 음식물류폐기물을 해당 가축의 먹이로 직접 생산하여 사용해서는 안 된다고 규정하면서, 예외적으로 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설 설치승인을 받거나 설치신고를 한 폐기물처리시설에서 생산하는 경우는 제외한다고 규정하고 있는바,

「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3 제2호다목1)다)(3)에 따라 농림축산식품부장관이 환경부장관에게 음식물류폐기물의 가축 먹이 사용금지를 요청한 경우, 「폐기물관리법」 제25조제3항에 따른 폐기물처리업¹⁾의 허가를 받은 자(이하 “폐기물처리업자”라 한다)가 설치한 폐기물처리시설에서 음식물류폐기물을 자가(自家) 사육하는 가축의 먹이로 생산하여 사용²⁾할 수 있는지?

1) 「폐기물관리법」 제25조제5항제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하는 폐기물 중간·최종·종합재활용업으로 음식물류 폐기물을 재활용하는 경우로 한정함

2) 가축을 자가(自家) 사육하는 자가 동시에 폐기물처리업자인 경우로서, 폐기물처리업자의 폐기물처리시설에서 해당 가축의 먹이를 생산하여 사용하는 경우를 전제로 함

02 회답

「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3 제2호다목1)다)(3)에 따라 농림축산식품부장관이 환경부장관에게 음식물류폐기물의 가축 먹이 사용금지를 요청한 경우, 폐기물처리업자가 설치한 폐기물처리시설에서 음식물류폐기물을 자가 사육하는 가축의 먹이로 생산하여 사용할 수 있습니다.

03 이유

「폐기물관리법 시행규칙」 제14조의3제1항 및 별표 5의3 제2호에서는 폐기물의 재활용 기준 중 유형별 재활용의 세부기준을 규정하면서, 같은 호 다목1)다)(3)에서는 가축전염병이 발생하였거나 발생할 우려가 있어 농림축산식품부장관이 환경부장관에게 음식물류폐기물의 가축 먹이 사용금지를 요청한 경우에는 음식물류폐기물을 해당 가축의 먹이로 직접 생산하여 사용하는 것은 금지하되, 예외적으로 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설 설치승인을 받거나 설치신고를 한 폐기물처리시설에서 생산하는 경우는 제외한다고 규정하고 있는바, 폐기물처리업자가 설치한 폐기물처리시설에서 음식물류폐기물을 가축의 먹이로 직접 생산하여 사용한 경우가 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3 제2호다목1)다)(3)에서 규정하고 있는 “음식물류폐기물의 가축 먹이 사용금지”에 해당하는지 여부는 폐기물처리업의 법적 성격뿐만 아니라 음식물류폐기물을 가축의 먹이로 “직접 생산”하는 경우에 해당하는지, 예외규정이 적용되는 대상에 해당하는지 등을 종합적으로 고려하여 판단할 필요가 있습니다.

먼저 「폐기물관리법」 제25조에서는 “폐기물처리업”을 폐기물의 수집·운반, 재활용 또는 처분을 업으로 하는 것으로 규정하면서 폐기물처리업을 하려는 자는 허가를 받아야 한다고 규정하고 있는데, 이는 폐기물 관련 영업에 관한 허가로, 가축을 자가(自家) 사육하는 자가 음식물류폐기물을 자가 사육하는 가축의 먹이 등으로 직접 생산하여 사용하기 위하여 설치하는 폐기물처리시설에 대하여 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 설치승인을 받거나 설치신고를 하는 경우와는 성격이 다르므로, 폐기물처리업자가 설치한 폐기물처리시설에서 생산한 먹이의 사용은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3 제2호다목1)다)(3)에 따라 먹이 사용이 금지되는 “직접 생산”하여 사용하는 경우에 해당한다고 보기는 어렵습니다.

그리고 「폐기물관리법」 제29조제2항에서는 같은 법 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 ‘받았거나 받으려는 자 외의 자’가 폐기물처리시설을 설치하려면 환경부장관의 승인을 받아야 한다고 하여 폐기물처리업자와 폐기물처리시설의 설치·운영자를 명확히 구별하면서³⁾, 같은 법 제25조의3제1항에서 폐기물처리업자에 대해서는 대통령령으로 정하는 업종별 적합성확인⁴⁾의 유효기간이 경과할 때마다 폐기물처리업을 계속 수행할 수 있는 적합성을 갖추었음을 확인 받아야 한다고 규정하여 폐기물처리업자가 폐기물처리업을 계속 수행하려는 경우 허가권자에게 적합성확인을 받을 의무를 부과하면서, 같은 법 제64조제8호의2에서 이러한 의무를 위반하여 적합성확인을 받지 아니하고 폐기물처리업을 계속한 자에게 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있는 반면, 같은 법 제31조제1항에서 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자에 대해서는 환경부령으로 정하는 관리기준에 따라 그 시설을 유지·관리하여야 한다고 규정하여 폐기물처리시설의 설치·운영자에게 일정한 관리기준에 따른 시설 유지·관리의무를 부과하면서, 같은 법 제66조제13호에서 이러한 의무를 위반하여 관리기준에 적합하지 아니하게 폐기물처리시설을 유지·관리하여 주변환경을 오염시킨 자에게 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있는 점 등을 고려하면, 폐기물관리법령에서의 폐기물처리업자와 폐기물처리시설의 설치·운영자는 각각 영업 인·허가와 시설 설치 인·허가로서의 취지가 다르고, 영업자로서 부여받는 의무도 다른 별개의 지위라 할 것입니다.

그런데 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3 제2호다목1)다)(3)에서 가축 먹이로의 사용을 제한하면서 그 예외로 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설⁵⁾을 규정하고 있고, 같은 법 제25조에 따르면 폐기물처리업자가 설치한 폐기물처리시설이 시설 설치, 장비 및 기술능력의 확보계획을 포함한 재활용대상 폐기물의 재활용계획서를 포함한 폐기물처리 사업계획서를 제출(제1항)하여 적합성을 통보받고(제2항), 환경부령으로 정하는 기준에 따른 시설·장비 및 기술능력을 갖추어 시·도지사의 허가(제3항)를 받을 뿐만 아니라, 앞에서 살펴본 것처럼 일정 기간이 경과할 때마다 적합성확인을 받을 의무를 부과 받는 등 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설보다 더 엄격한 법령상 요건을 충족해야 함에도 불구하고 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3 제2호다목1)다)(3)에서 그 예외로 “법 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설 설치승인을 받거나 설치신고를 한 폐기물처리시설에서 생산하는 경우”만을 규정한 것은, 해당 규정은 폐기물처리업자가 설치한 폐기물처리시설에서 생산한 경우는 제외하고 자가 사육 농가에서 설치한 폐기물처리시설에서 생산한 경우에만 적용하는 것을 전제하고 있다고 보아야 할 뿐만 아니라, 음식물류폐기물을 직접 생산하는 경우 중 같은

3) 대법원 2017. 11. 14. 선고 2017도7492 판결례 참조

법 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설 설치승인을 받거나 설치신고를 한 폐기물처리시설에서 생산하는 경우에 대해 가축전염병이 발생하였거나 발생할 우려가 있어 농림축산식품부장관이 환경부장관에게 음식물류폐기물의 가축 먹이 사용금지를 요청한 경우에도 예외를 인정하여 가축의 먹이로 사용할 수 있도록 한 점에 비추어 볼 때, 폐기물처리업자가 보다 엄격한 법령상 요건과 설치기준에 따라 설치한 폐기물처리시설에서 생산하는 경우를 가축 먹이 사용금지의 예외에서 제외하려는 의도가 있다고 보기는 어렵습니다.

따라서 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3 제2호다목1)다)(3)에 따라 농림축산식품부장관이 환경부장관에게 음식물류폐기물의 가축 먹이 사용금지를 요청한 경우, 폐기물처리업자가 설치한 폐기물처리시설에서 음식물류폐기물을 자가 사육하는 가축의 먹이로 생산하여 사용할 수 있습니다.



관계법령

폐기물관리법

제13조의2(폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항) ① 누구든지 다음 각 호를 위반하지 아니하는 경우에는 폐기물을 재활용할 수 있다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 그 밖에 환경부령으로 정하는 재활용의 기준을 준수할 것

제25조(폐기물처리업) ①·② (생 략)

③ 제2항에 따라 적합통보를 받은 자는 그 통보를 받은 날부터 2년(제5항제1호에 따른 폐기물 수집·운반업의 경우에는 6개월, 폐기물처리업 중 소각시설과 매립시설의 설치가 필요한 경우에는 3년) 이내에 환경부령으로 정하는 기준에 따른 시설·장비 및 기술능력을 갖추어 업종, 영업대상 폐기물 및 처리분야별로 지정폐기물을 대상으로 하는 경우에는 환경부장관의, 그 밖의 폐기물을 대상으로 하는 경우에는 시·도지사의 허가를 받아야 한다. 이 경우 환경부장관 또는 시·도지사는 제2항에 따라 적합통보를 받은 자가 그 적합통보를 받은 사업계획에 따라 시설·장비 및 기술인력 등의 요건을 갖추어 허가신청을 한 때에는 지체 없이 허가하여야 한다.

④ ~ (17) (생 략)

제29조(폐기물처리시설의 설치) ① (생 략)

② 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받았거나 받으려는 자 외의 자가 폐기물처리시설을 설치하려면 환경부장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 제1호의 폐기물처리시설을 설치하는 경우는 제외하며, 제2호의 폐기물처리시설을 설치하려면 환경부장관에게 신고하여야 한다.

1. 학교·연구기관 등 환경부령으로 정하는 자가 환경부령으로 정하는 바에 따라 시험·연구목적으로 설치·운영하는 폐기물처리시설

2. 환경부령으로 정하는 규모의 폐기물처리시설

③ ~ ⑥ (생 략)

폐기물관리법 시행규칙

제14조의3(폐기물의 재활용 기준 및 준수사항 등) ① 법 제13조의2제1항제5호에서 “환경부령으로 정하는 재활용의 기준”이란 별표 5의3에 따른 폐기물의 재활용 기준을 말한다.

② ~ ⑤ (생 략)

[별표 5의3]

폐기물의 재활용 기준(제14조의3제1항 관련)

1. (생 략)

2. 유형별 재활용의 세부기준

가. 나. (생 략)

다. 농업이나 토질개선을 위하여 재활용하는 유형

1) R-5 유형의 재활용 기준

가. 나. (생 략)

다) R-5-4 유형의 재활용 기준

(1)·(2) (생 략)

(3) 가축전염병이 발생하였거나 발생할 우려가 있어 농림축산식품부장관이 환경부장관에게 음식물류폐기물의 가축 먹이 사용금지를 요청한 경우에는 음식물류폐기물을 해당 가축의 먹이로 직접 생산(법 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설 설치승인을 받거나 설치신고를 한 폐기물처리시설에서 생산하는 경우는 제외한다)하여 사용해서는 안 된다. 이 경우 환경부장관은 금지 사실 및 금지 시작일을 관보에 고시하고, 필요한 경우 환경부 인터넷 홈페이지에 게시하거나 신문 또는 방송 등의 방법으로 알려야 한다.

(4) (생 략)

2) (생 략)

라. ~ 바. (생 략)

제2절 고용노동

질의제목 1

▶ 안전번호 25-0058

민원인 - 「산업재해보상보험법」 제51조제1항에 따른 재요양 대상자 해당 여부(「산업재해보상보험법」 제51조제1항 등 관련)

01 질의요지

「산업재해보상보험법」(이하 “산재보험법”이라 함) 제40조제1항에서는 요양급여는 근로자¹⁾가 업무상의 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 경우에 그 근로자에게 지급한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 요양급여는 같은 법 제43조제1항에 따른 산재보험 의료기관(이하 “산재보험 의료기관”이라 함)에서 요양을 하게 하되(본문), 다만 부득이한 경우에는 요양을 갈음하여 요양비를 지급할 수 있다(단서)고 규정하고 있는 한편,

산재보험법 제51조제1항에서는 같은 법 제40조에 따른 요양급여를 받은 사람이 치유²⁾ 후 요양의 대상이 되었던 업무상의 부상 또는 질병이 재발하거나 치유 당시보다 상태가 악화되어 이를 치유하기 위한 적극적인 치료가 필요하다는 의학적 소견이 있으면 다시 제40조에 따른 요양급여(이하 “재요양”이라 함)를 받을 수 있다고 규정하고 있는바,

근로자가 업무상의 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸려 산재보험 의료기관이 아닌 의료기관에서 요양을 하고 3년이 경과한 후 산재보험법 제41조에 따라 요양급여를 신청하여 근로복지공단(이하 “공단”이라 함)으로부터 요양급여 승인 결정의 통지를 받았으나, 같은 법 제112조제1항제1호에 따른 소멸시효가 완성되어 요양비를 지급받지 못한 경우, 같은 법 제51조제1항에 따른 재요양을 받을 수 있는 사람에 해당되는지?

1) 「근로기준법」에 따른 근로자를 말하며(산재보험법 제5조제2호 참조), 이하 같음

2) 부상 또는 질병이 완치되거나 치료의 효과를 더 이상 기대할 수 없고 그 증상이 고정된 상태에 이르게 된 것을 말하며, (산재보험법 제5조제4호 참조), 이하 같음

02 회답

이 사안의 경우, 산재보험법 제51조제1항에 따른 재요양을 받을 수 있는 사람에 해당되지 않습니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데,³⁾ 산재보험법 제40조제1항에서는 요양급여는 근로자가 업무상의 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 경우에 그 근로자에게 지급한다고 규정하면서, 같은 법 제51조제1항에서는 재요양 대상자와 관련하여 같은 법 제40조에 따른 요양급여를 받은 사람이 치유 후 요양의 대상이 되었던 업무상의 부상 또는 질병이 재발하거나 치유 당시보다 상태가 악화되어 이를 치유하기 위한 적극적인 치료가 필요하다는 의학적 소견이 있으면 재요양을 받을 수 있다고 규정하고 있는 한편, 같은 법 제40조제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 요양급여는 산재보험 의료기관에서 요양을 하게 하되(본문), 다만 부득이한 경우에는 요양을 갈음하여 요양비를 지급할 수 있다(단서)고 규정하여 산재보험법에 따른 요양급여의 지급 방법 등을 구체적으로 한정하고 있는바, 이때 같은 법 제51조제1항에 따라 재요양을 받을 수 있는 사람은 업무상의 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 근로자로서 같은 법 제40조에 따른 “요양급여를 받은 사람”, 즉 재요양 신청 전에 같은 법에 따라 산재보험 의료기관에서 요양을 하였거나, 요양을 갈음하여 요양비를 지급받았던 사람을 의미한다고 봄이 타당하므로, 같은 법 제41조에 따라 요양급여를 신청하여 공단으로부터 요양급여 승인 결정의 통지만을 받았을 뿐, 실제 산재보험 의료기관에서 요양을 하지 않았거나, 요양을 갈음하여 공단으로부터 요양비를 지급받은 바가 없다면 문언상 같은 법 제51조제1항에 따른 재요양을 받을 수 있는 사람에 해당된다고 보기 어렵습니다.

그리고 산재보험법 제36조제1항제1호에서는 보험급여의 종류 중 하나로 ‘요양급여’를 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 보험급여는 같은 법 제40조 등에 따른 보험급여를 ‘받을 수 있는’ 사람의 청구에 따라 지급한다고 규정하고 있고, 같은 법

3) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

제82조제1항에서는 보험급여는 지급 결정일부터 14일 이내에 지급하여야 한다고 규정하고 있는 점, 같은 법 제41조제1항 전단에서는 같은 법 제40조제1항에 따른 요양급여⁴⁾를 ‘받으려는’ 사람은 소속 사업장, 재해발생 경위, 그 재해에 대한 의학적 소견, 그 밖에 고용노동부령으로 정하는 사항을 적은 서류를 첨부하여 공단에 요양급여의 신청을 하여야 한다고 규정하면서, 같은 법 제41조의2제1항에서는 같은 법 제40조제1항에 따른 요양급여를 ‘받은’ 사람은 자신이 부담한 비용이 같은 조 제5항에 따라 요양급여의 범위에서 제외되는 비용인지 여부에 대하여 공단에 확인을 요청할 수 있다고 규정하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 산재보험법에서는 요양급여의 지급 결정 절차와 이에 따른 지급 절차를 나누어 규정하고 있는 한편, 요양급여를 ‘받을 수 있는’ 사람 또는 이를 ‘받으려는’ 사람과 요양급여를 ‘받은’ 사람을 각각 구별하면서 이 중 요양급여를 ‘받은’ 사람의 경우에는 요양급여의 신청에 대한 공단의 지급결정에 따라 실제 요양급여가 지급된 사안에 대해 적용하면서 이를 재요양 대상자의 요건으로도 규정하고 있는바, 이 사안의 경우 해당 근로자를 같은 법 제51조제1항에 따른 재요양을 받을 수 있는 사람에 해당된다고 보기는 어렵습니다.

또한 ① 산재보험법에 의한 ‘재요양’은 일단 요양이 종결된 후에 당해 상병이 재발하거나 또는 당해 상병에 기인한 합병증에 대하여 실시하는 요양으로서,⁵⁾ 여기서의 재요양은 산재보험법에 따른 최초 요양의 실시 및 그 종결을 전제로 하는 점, ② 산재보험법 제51조제2항에서 재요양의 요건과 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제48조제1항에서는 같은 법 제51조에 따른 재요양은 업무상 부상 또는 질병에 대하여 요양급여를 받은 경우로서 같은 법 시행령 제48조제1항 각 호의 요건 모두에 해당하는 경우에 인정한다고 규정하여 어떠한 업무상 부상 또는 질병에 대하여 요양급여 등을 받은 경우를 재요양의 요건으로 명시하고 있는 점 등을 고려하면, 공단으로부터 요양급여 승인 결정의 통지를 받아 최초 요양급여의 지급 대상임을 확인하는데 그친 이 사안의 경우에는 재발되거나 악화된 업무상 부상 또는 질병에 대하여 산재보험법상 관련 요건을 충족할 경우 같은 법 제40조에 따른 최초 요양급여의 대상으로 볼 수 있는지 여부는 별론으로 하더라도, 같은 법 제51조제1항에 따른 재요양의 대상에 해당된다고 보기는 어렵습니다.

아울러 산업재해보상보험제도는 재해근로자와 그 가족의 생활을 보장하기 위하여 국가가 책임을 지는 의무보험으로, 원래 사용자의 「근로기준법」상 재해보상책임을 보장하기 위하여 국가가 사업주로부터 소정의 보험료를 징수하여 그 기금(재원)으로 사업주를 대신하여

4) 진폐에 따른 요양급여는 제외하며, 이하 같은 조에서 같음

5) 대법원 2002. 4. 26. 선고 2002두1762 판결례 참조

재해근로자에게 보상을 해주는 제도로써,⁶⁾ 입법정책상 새로운 보험급여의 신설 등을 통해 그 혜택의 범위를 확대시키는 것과는 별개로 산업재해보상보험제도의 원활하고 안정적인 운영 및 건전한 재정 관리를 위해서는 현행 산재보험법에 따른 재요양 등 관련 지급 대상 및 조건에 대하여 엄격히 해석해야 한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 산재보험법 제51조제1항에 따른 재요양을 받을 수 있는 사람에 해당되지 않습니다.



관계법령

산업재해보상보험법

제40조(요양급여) ① 요양급여는 근로자가 업무상의 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 경우에 그 근로자에게 지급한다.

② 제1항에 따른 요양급여는 제43조제1항에 따른 산재보험 의료기관에서 요양을 하게 한다. 다만, 부득이한 경우에는 요양을 같음하여 요양비를 지급할 수 있다.

③ ~ ⑥ (생략)

제51조(재요양) ① 제40조에 따른 요양급여를 받은 사람이 치유 후 요양의 대상이 되었던 업무상의 부상 또는 질병이 재발하거나 치유 당시보다 상태가 악화되어 이를 치유하기 위한 적극적인 치료가 필요하다는 의학적 소견이 있으면 다시 제40조에 따른 요양급여(이하 “재요양”이라 한다)를 받을 수 있다.

② 재요양의 요건과 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

산업재해보상보험법 시행령

제48조(재요양의 요건 및 절차) ① 법 제51조에 따른 재요양(이하 “재요양”이라 한다)은 업무상 부상 또는 질병에 대하여 요양급여(요양급여를 받지 아니하고 장해급여를 받는 부상 또는 질병의 경우에는 장해급여)를 받은 경우로서 다음 각 호의 요건 모두에 해당하는 경우에 인정한다.

1. 치유된 업무상 부상 또는 질병과 재요양의 대상이 되는 부상 또는 질병 사이에 상당인과관계가 있을 것
2. 재요양의 대상이 되는 부상 또는 질병의 상태가 치유 당시보다 악화된 경우로서 나이나 그 밖에 업무 외의 사유로 악화된 경우가 아닐 것
3. 재요양의 대상이 되는 부상 또는 질병의 상태가 재요양을 통해 호전되는 등 치료효과를 기대할 수 있을 것

② 재요양을 받으려는 사람은 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 공단에 재요양을 신청하여야 한다.

6) 헌법재판소 2013. 9. 26. 선고 2012헌가16 결정례 참조

질의제목 2

▶ 안전번호 25-0068, 25-0145

고용노동부 - 구직촉진수당의 수급자격의 판단 기준이 되는 “수당을 마지막으로 받은 날”의 의미 등
(「구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률」 제7조제3항제5호 등 관련)

01 질의요지

「구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률」(이하 “구직자취업촉진법”이라 함) 제7조제3항에서는 고용노동부장관은 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 구직촉진수당 수급자격을 인정하지 아니할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 제5호에서는 국가 또는 지방자치단체가 구직활동에 필요한 비용을 지원하는 수당 중 대통령령으로 정하는 수당¹⁾을 받고 있거나 수당을 마지막으로 받은 날의 다음 날부터 6개월이 지나지 아니한 사람을 규정하고 있는 한편,

구직자취업촉진법 제29조제1항제9호 및 같은 법 시행규칙 제20조제2항제3호에서는 고용노동부장관은 같은 법 제7조제3항제5호에 따른 수당을 받게 된 경우 그 수당을 처음 받는 날부터 수급자에 대한 해당 취업지원서비스의 제공 또는 구직촉진수당의 지급을 하지 아니한다고 규정하고 있는바,

구직자취업촉진법 제7조제3항제5호에 따른 수당 중 지급기간이 정해져 있고 해당 지급기간 중 일정 주기로 지급일이 정해지는 수당(이하 “이 사안 수당”이라 함)의 경우,

가. 구직자취업촉진법 제7조제3항제5호에 따른 “수당을 마지막으로 받은 날”은 해당 수당 지급기간의 종기(終期)에 해당하는 날을 의미하는지, 아니면 해당 수당을 실제 지급받은 날 중에서 마지막 날을 의미하는지?

나. 구직자취업촉진법 시행규칙 제20조제2항제3호에 따른 “수당을 처음 받는 날”은 해당 수당 지급기간의 시기(始期)에 해당하는 날을 의미하는지, 아니면 해당 수당을 실제 지급받은 날 중에서 첫 날을 의미하는지?

1) 구직자취업촉진법 시행령 제5조제3항 참조

02 회답

가. 질의 가에 대해

이 사안 수당의 경우, 구직자취업촉진법 제7조제3항제5호에 따른 “수당을 마지막으로 받은 날”은 해당 수당 지급기간의 종기(終期)에 해당하는 날을 의미합니다.

나. 질의 나에 대해

이 사안 수당의 경우, 구직자취업촉진법 시행규칙 제20조제2항제3호에 따른 “수당을 처음 받는 날”은 해당 수당 지급기간의 시기(始期)에 해당하는 날을 의미합니다.

03 이유

가. 질의 가 및 질의 나의 공통사항

구직자취업촉진법 제18조제1항에서는 고용노동부장관은 같은 법 제10조에 따라 구직촉진수당 수급자격을 인정받은 사람이 취업활동계획 수립에 참여하여 그 계획 수립이 완료되거나 취업지원·구직활동지원 프로그램²⁾을 이행하는 경우에는 구직활동 및 생활안정에 소요되는 비용을 지원하기 위한 구직촉진수당을 지급한다고 규정하고 있고, 같은 법 제19조제2항에서는 구직촉진수당의 지급액은 월(月) 단위로 정한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제20조제1항에서는 구직촉진수당은 취업지원 신청인이 제10조제1항에 따라 수급자격의 인정 통지를 받은 날부터 6개월이 되는 날까지 취업지원·구직활동지원 프로그램을 이행한 것에 대하여 지급한다고 규정하고 있고, 같은 법 제20조제4항에서는 구직촉진수당의 지급주기는 1개월로 한다고 규정하고 있는바, 이에 따르면 구직촉진수당은 일정 지급기간을 정하고 해당 기간 중 구직을 위한 노력 여부를 확인하여 지급이 이루어지는 수당이라고 할 것입니다.

그리고 구직자취업촉진법 제7조제3항제5호에서는 국가 또는 지방자치단체가 구직활동에 필요한 비용을 지원하는 수당 중 대통령령으로 정하는 수당을 받고 있거나 수당을 마지막으로 받은 날의 다음 날부터 6개월이 지나지 아니한 사람은 수급자격을 인정하지 않을 수 있도록

2) 구직자취업촉진법 제13조제1항에 따른 취업지원 프로그램 및 같은 법 제14조제1항에 따른 구직활동지원 프로그램을 말함

규정하고 있는 한편, 같은 법 제29조제1항제9호 및 같은 법 시행규칙 제20조제2항제3호에서는 고용노동부장관은 같은 법 제7조제3항제5호에 따른 수당을 받게 된 경우 그 수당을 처음 받는 날부터 수급자에 대한 해당 취업지원서비스의 제공 또는 구직촉진수당의 지급을 하지 아니한다고 규정하고 있어, 구직자취업촉진법에 따른 구직촉진수당 외에 다른 구직촉진 관련 수당을 마지막으로 받은 날 이후로 일정 기간이 도과해야만 구직촉진수당을 받을 수 있는 자격을 갖출 수 있게 되고, 다른 구직촉진 관련 수당을 받게 되는 경우에는 구직촉진수당의 지급이 종료되는바, 구직촉진수당의 지급 요건으로서 다른 구직촉진 관련 수당을 “마지막으로 받은 날” 또는 “처음 받는 날”의 해석에 따라 구직촉진수당의 수급자격 인정 시기 및 구직촉진수당의 지급 종료 시기가 정해진다고 할 것입니다.

나. 질의 가에 대해

먼저 구직자취업촉진법 제18조에 따르면 구직촉진수당은 구직활동 및 생활안정에 소요되는 비용을 지원하기 위한 것으로, 같은 법 제7조제3항에서는 구직촉진수당의 수급자격과 관련하여 같은 항 제5호에 따른 수당을 받은 사람 외에도 「국민기초생활 보장법」에 따른 생계급여 수급자(제2호), 「고용보험법」에 따른 구직급여를 마지막으로 받은 날의 다음 날부터 6개월이 지나지 아니한 사람(제3호), 「고용정책 기본법」에 따른 재정지원 일자리사업 중 대통령령으로 정하는 사업에 참여하고 있거나 참여기간의 마지막 날의 다음 날부터 6개월이 지나지 아니한 사람(제4호)에 대해서도 구직촉진수당의 수급자격을 인정하지 않을 수 있다고 규정하고 있는바, 위와 같은 사항을 종합하여 보면 구직촉진수당은 구직활동 및 생활안정에 소요되는 비용을 지원하기 위한 것으로 이와 유사한 목적의 금전이나 서비스의 지원을 받은 경우에는 중복을 방지하기 위해 수급자격을 인정하지 않고 있다고 할 것입니다.

특히 구직자취업촉진법령에서 일정기간 지원 유예기간을 두는 등 구직촉진수당의 수급자격을 인정하지 않을 수 있는 근거를 마련한 것은 국가 및 지방자치단체 등으로부터 구직활동에 필요한 수당 등을 지원받고 있는 사람이 수당의 수급을 목적으로 참여를 반복하지 않도록 하기 위해서인 점³⁾을 고려할 때, 동일한 목적으로 지원받은 수당이 있다면 해당 수당을 통한 지원이 종료된 후 6개월이 지났을 때 구직촉진수당의 수급자격이 있다고 보는 것이 입법 취지를 고려하면 타당한 해석입니다.

그렇다면 이 사안 수당과 같이 지급기간이 정해져 있는 경우에는 어떠한 주기로 금전을 지급받았는지 여부와 관계없이 해당 지급기간 동안 취업지원의 목적으로 수당을 지급한

3) 2019. 9. 16. 의안번호 제2022464호로 발의된 구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률안 국회 환경노동위원회 검토보고서 참조

것으로 보아야 할 것인바, 결과적으로 이 사안 수당을 통한 지원의 효과는 지급기간 동안 지속되는 것이고 지급기간이 종료된 때에 비로소 지원이 끝났다고 볼 수 있으므로, 앞서 살펴본 사항을 종합하여 보면 구직자취업촉진법 제7조제3항제5호에 따른 “수당을 마지막으로 받은 날”은 이 사안 수당이 목적하고 있는 구직활동 등의 지원 효과가 종료되는 날인 해당 수당 지급기간의 종기(終期)에 해당하는 날을 의미한다고 할 것입니다.

아울러 구직자취업촉진법 제7조제3항제5호에 따른 “수당을 마지막으로 받은 날”을 해당 수당을 실제 지급받은 날 중에서 마지막 날로 본다면, 동일한 지급기간을 설정하고 있는 같은 호에 따른 수당인 경우에도 지급주기를 어떻게 정하는지, 실제 지급일이 언제인지 등에 따라 구직촉진수당의 수급자격을 인정받을 수 있는 시기가 달라지게 될 수 있어 수급자격 인정 시기의 일관성을 저해할 우려가 있는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안 수당의 경우, 구직자취업촉진법 제7조제3항제5호에 따른 “수당을 마지막으로 받은 날”은 해당 수당 지급기간의 종기(終期)에 해당하는 날을 의미합니다.

법령정비 권고사항

구직자취업촉진법 제7조제3항제5호에 따른 “수당을 마지막으로 받은 날”의 경우에는 해당 수당의 지급기간의 종기(終期)와 실제 지급을 받은 마지막 날이 다른 경우에 어떤 날로 볼 것인지에 대하여 해석상 혼란이 발생할 수 있는바, 같은 항 제4호의 규정 등을 고려하여 이를 명확하게 규정할 필요가 있습니다.

다. 질의 내에 대해

구직자취업촉진법 제18조에 따르면 구직촉진수당은 구직활동 및 생활안정에 소요되는 비용을 지원하기 위한 것으로, 구직촉진수당의 지급 종료와 관련하여 같은 법 제29조제1항에서는 취업지원서비스기간 중 취업 또는 창업한 경우 그 일자리에 취업한 날 또는 영리 목적으로 사업을 하기 시작한 날(제2호), 「국민기초생활 보장법」에 따른 생계급여 수급자로 선정된 날(제4호) 등의 시점부터 구직촉진수당의 지급을 종료하도록 규정하고 있고, 같은 항 제9호 및 구직자취업촉진법 시행규칙 제20조제2항제7호에서는 「고용보험법」에 따른 구직급여를 받게 된 경우에는 구직급여 수급자격의 인정을 받은 날부터 구직촉진수당의 지급을 종료하도록 하고 있는바, 위와 같은 사항을 종합하여 보면 구직촉진수당은 구직활동 및

생활안정에 소요되는 비용을 지원하기 위한 것으로 이와 유사한 목적의 금전이나 서비스의 지원을 받은 경우에는 중복을 방지하기 위해 구직촉진수당의 지급을 하지 않도록 규정하고 있다고 할 것입니다.

특히 구직자취업촉진법령에서 일정기간 지원 유예기간을 두는 등 구직촉진수당의 수급자격을 인정하지 않을 수 있도록 근거를 마련한 것은 국가 및 지방자치단체 등으로부터 구직활동에 필요한 수당 등을 지원받고 있는 사람이 수당의 수급을 목적으로 참여를 반복하지 않도록 하기 위해서인 점⁴⁾을 고려할 때, 구직촉진수당 지급의 종료 역시 동일한 목적으로 수당을 지원받게 된 경우 해당 수당을 통한 지원이 시작되는 시점부터 구직촉진수당의 지급이 종료된다고 해석하는 것이 구직촉진수당의 지급 종료 규정의 취지를 고려하면 타당한 해석입니다.

그렇다면 이 사안 수당과 같이 지급기간이 정해져 있는 경우에는 어떠한 주기로 금전을 지급받았는지 여부와 관계없이 해당 지급기간 동안 취업지원의 목적으로 수당을 지급한 것으로 보아야 할 것인바, 결과적으로 이 사안 수당을 통한 지원의 효과는 지급기간 동안 지속적으로 이루어지는 것이고, 구직자취업촉진법 제7조제3항제5호에 따른 수당의 지급기간이 시작된 때에 지원이 시작되었다고 볼 수 있으므로, 앞서 살펴본 사항을 종합하여 보면 구직자취업촉진법 시행규칙 제20조제2항제3호에 따른 “수당을 처음 받는 날”은 이 사안 수당이 목적하고 있는 구직활동 등의 지원 효과가 시작되는 날인 해당 수당 지급기간의 시기(始期)에 해당하는 날을 의미한다고 할 것입니다.

아울러 구직자취업촉진법 시행규칙 제20조제2항제3호에 따른 “수당을 처음 받는 날”을 해당 수당을 실제 지급받은 날 중에서 첫 날로 본다면, 동일한 지급기간을 설정하고 있는 같은 호에 따른 수당인 경우에도 지급주기를 어떻게 정하는지, 실제 지급일이 언제인지 등에 따라 구직촉진수당의 지급 여부가 달라지게 될 수 있어 수급자격 인정 시기의 일관성을 저해할 우려가 있는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안 수당의 경우, 구직자취업촉진법 시행규칙 제20조제2항제3호에 따른 “수당을 처음 받는 날”은 해당 수당 지급기간의 시기(始期)에 해당하는 날을 의미합니다.

4) 2019년 9월 16일 의안번호 제2022464호로 정부제출된 구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률안 국회 환경노동위원회 검토보고서 참조

법령정비 권고사항

구직자취업촉진법 시행규칙 제20조제2항제3호에 따른 “수당을 처음 받는 날”의 경우에는 해당 수당의 지급기간의 시기(始期)와 실제 지급을 받는 첫 날이 다른 경우에 어떤 날로 볼 것인지에 대하여 해석상 혼란이 발생할 수 있는바, 같은 법 제29조제1항제7호의 규정 등을 고려하여 이를 명확하게 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률

제7조(구직촉진수당의 수급 요건) ①·② (생 략)

③ 고용노동부장관은 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 구직촉진수당 수급자격을 인정하지 아니할 수 있다.

1. ~ 4.. (생 략)

5. 국가 또는 지방자치단체가 구직활동에 필요한 비용을 지원하는 수당 중 대통령령으로 정하는 수당을 받고 있거나 수당을 마지막으로 받은 날의 다음 날부터 6개월이 지나지 아니한 사람

6.·7. (생 략)

④ (생 략)

제20조(지급기간 및 지급절차) ① 구직촉진수당은 취업지원 신청인이 제10조제1항에 따라 수급자격의 인정 통지를 받은 날부터 6개월이 되는 날까지 취업지원·구직활동지원 프로그램을 이행한 것에 대하여 지급한다.

②·③ (생 략)

④ 구직촉진수당의 지급주기는 1개월로 한다.

⑤ ~ ⑧ (생 략)

제29조(취업지원 종료 등) ① 고용노동부장관은 다음 각 호의 구분에 따른 시점부터 수급자에 대한 해당 취업지원서비스의 제공 또는 구직촉진수당의 지급을 하지 아니한다.

1. ~ 8. (생 략)

9. 그 밖에 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우로서 고용노동부령으로 정하는 경우: 해당 경우에 따라 고용노동부령으로 정하는 날

② ~ ④ (생 략)

구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률 시행규칙

제20조(취업지원 종료일 등) ① (생 략)

② 법 제29조제1항제9호에서 “고용노동부령으로 정하는 경우” 및 “해당 경우에 따라 고용노동부령으로 정하는 날”이란 다음 각 호의 구분에 따른 경우 및 날을 말한다.

1.·2. (생략)

3. 법 제7조제3항제5호에 따른 수당을 받게 된 경우: 수당을 처음 받는 날

4. 삭제

5. ~ 8. (생략)

③·④ (생략)

질의제목 3

▶ 안전번호 25-0109

민원인 - 이직일 이전 18개월 중 실업상태의 기간이 있는 경우로서 그 실업상태의 기간 중에 질병·부상 등의 사유로 인하여 근로를 할 수 없는 상태가 지속된 경우, 「고용보험법」 제40조제2항제1호에 따른 기준기간 가산 규정의 적용을 받는지(「고용보험법」 제40조제2항 등 관련)

01 질의요지

「고용보험법」 제40조제1항 본문에서는 구직급여는 이직한 근로자인 피보험자가 같은 항 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에 지급한다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 ‘같은 조 제2항에 따른 기준기간(이하 “기준기간”이라 함) 동안의 피보험 단위기간¹⁾이 합산하여 180일 이상일 것’을 요건 중 하나로 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 기준기간은 이직일 이전 18개월로 하되, 근로자인 피보험자가 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항 각 호의 구분에 따른 기간을 기준기간으로 한다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 이직일 이전 18개월 동안에 질병·부상, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 계속하여 30일 이상 보수의 지급을 받을 수 없었던 경우에는 ‘18개월에 그 사유로 보수를 지급 받을 수 없었던 일수를 가산한 기간²⁾’을 기준기간으로 한다고 규정하고 있는바,

이직일 이전 18개월 중 실업상태의 기간이 있는 경우로서 그 실업상태의 기간 중에 질병·부상 등의 사유로 인하여 30일 이상 근로를 할 수 없는 상태가 지속된 경우, 「고용보험법」 제40조제2항제1호에 따른 기준기간 가산 규정의 적용을 받는지?

02 회답

이 사안의 경우, 「고용보험법」 제40조제2항제1호에 따른 기준기간 가산 규정의 적용을 받지 않습니다.

1) 「고용보험법」 제41조에 따른 피보험 단위기간을 말함

2) 3년을 초과할 때에는 3년으로 함

03 이유

먼저 「고용보험법」 제40조제2항제1호에서는 구직급여의 기준기간 연장사유로서 ‘이직한 근로자인 피보험자’가 이직일 이전 18개월 동안에 질병·부상 등의 사유로 계속하여 30일 이상 ‘보수’의 지급을 받을 수 없었던 경우를 규정하고 있는데, ‘이직한 근로자인 피보험자’란 이직 전 피보험자 자격을 유지하고 있던 근로자를 의미하고, 같은 법 제2조제5호 본문에서는 ‘보수’란 「소득세법」 제20조에 따른 ‘근로소득’에서 대통령령으로 정하는 금품을 뺀 금액을 말한다고 규정하고 있는 점, 「고용보험법」의 제정 당시 질병·부상 등의 사유로 ‘임금’의 지급을 받을 수 없었던 경우를 기준기간 연장사유로 규정³⁾하였던 것을, 이후 고용보험을 포함한 4대 사회보험의 보험료 산정기준을 소득세 과세대상 근로소득으로 통일하기 위하여 질병·부상 등의 사유로 ‘보수’의 지급을 받을 수 없었던 경우로 개정⁴⁾한 것인 점 등에 비추어 볼 때, 「고용보험법」 제40조제2항제1호는 그 제정 당시부터 현행에 이르기까지 근로자인 피보험자가 사업주와 고용관계를 유지하고 있는 경우를 전제로 하여, 질병·부상 등의 사유로 계속하여 30일 이상 임금 또는 보수를 지급받지 못하는 경우를 의미한다고 보는 것이 타당합니다.

또한 「고용보험법」 제40조제2항제1호의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제60조에서는 질병·부상 외에 기준기간이 연장되는 사유로 사업장의 휴업(제1호), 임신·출산·육아에 따른 휴직(제2호), 휴직이나 그 밖에 이와 유사한 상태로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사유(제3호)를 규정하고 있는데, 이와 같은 사유는 휴업이나 휴직 등으로 인해 근로자인 피보험자가 일시적으로 보수를 지급받지 못하는 경우에 해당하는 것이고, 그렇다면 같은 법 제40조제2항제1호는 근로자인 피보험자가 사업주와 고용관계를 유지하고 있음에도 불구하고 휴업이나 휴직 등의 불가피한 사정으로 피보험 단위기간 요건을 충족하지 못하는 경우에 구직급여 기준기간을 연장해 줌으로써, 구직급여 수급에 불이익을 받지 않도록 하려는 취지의 규정이라고 보는 것이 합리적일 것인바, 이 사안의 경우에는 실업상태의 기간 중에 질병·부상 등의 사유로 인하여 근로를 할 수 없는 상태가 지속된 것이므로 「고용보험법」 제40조제2항제1호에 따른 기준기간 가산 규정의 적용은 받지 않는다고 해석하는 것이 해당 법령의 취지에 부합합니다.

3) 1993. 12. 27. 법률 제4644호로 제정된 「고용보험법」 제31조제2항 참조

4) 2010. 1. 27. 법률 제9990호로 일부개정된 「고용보험법」 개정이유 및 주요내용 참조

더욱이 실업급여를 포함한 고용보험제도는 개개인의 특수한 사정이나 선택에 의하여 보험관계가 설정되는 사보험이 아니라 보험의 내용이 모두 법률에 의하여 강제되거나 확정되는 공적보험에 해당하는 것으로서⁵⁾, 피보험자가 납부하는 보험료와 국고부담을 재원(「고용보험법」 제5조 및 제6조)으로 하고 있고, 고용보험제도의 합리적 운영과 보험기금의 건전성을 고려하여 「고용보험법」 제40조제2항에서 구직급여의 기준기간을 원칙적으로 이직일 이전 18개월로 하되, 일정한 경우에 한해서만 예외적으로 연장하도록 규정하고 있는 것인바, 「고용보험법」 제40조제2항제1호에 따른 “보수의 지급을 받을 수 없었던 경우”를 이미 실업상태에 있는 경우로서 그 기간 도중에 질병·부상 등의 사유로 인하여 근로를 할 수 없는 상태가 지속된 경우까지 포함된다고 보아 구직급여를 지급받을 수 있는 대상을 확대하려는 취지가 있었다고 보기는 어렵습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「고용보험법」 제40조제2항제1호에 따른 기준기간 가산 규정의 적용을 받지 않습니다.



관계법령

고용보험법

제40조(구직급여의 지급 요건) ① 구직급여는 이직한 근로자인 피보험자가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에 지급한다. 다만, 제5호와 제6호는 최종 이직 당시 일용근로자였던 사람만 해당한다.

1. 제2항에 따른 기준기간(이하 “기준기간”이라 한다) 동안의 피보험 단위기간(제41조에 따른 피보험 단위기간을 말한다. 이하 같다)이 합산하여 180일 이상일 것

2. ~ 6. (생 략)

② 기준기간은 이직일 이전 18개월로 하되, 근로자인 피보험자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 기준기간으로 한다.

1. 이직일 이전 18개월 동안에 질병·부상, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 계속하여 30일 이상 보수의 지급을 받을 수 없었던 경우: 18개월에 그 사유로 보수를 지급 받을 수 없었던 일수를 가산한 기간(3년을 초과할 때에는 3년으로 한다)

2. (생 략)

5) 헌법재판소 2018. 6. 29. 선고 2017헌마238 전원재판부 결정례 참조

질의제목 4

▶ 안전번호 25-0134

민원인 - 구직자의 정신질환을 확인하기 위한 의사소견서나 건강진단확인서가 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 채용서류에 해당하는지(「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제2조제6호 등 관련)

01 질의요지

「채용절차의 공정화에 관한 법률」(이하 “채용절차법”이라 함) 제2조제6호에서는 “채용서류”란 기초심사자료, 입증자료, 심층심사자료를 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3호에서부터 제5호까지에서는 “기초심사자료”란 구직자¹⁾의 응시원서, 이력서 및 자기소개서를, “입증자료”란 학위증명서, 경력증명서, 자격증명서 등 기초심사자료에 기재한 사항을 증명하는 모든 자료를, “심층심사자료”란 작품집, 연구실적물 등 구직자의 실력을 알아볼 수 있는 모든 물건 및 자료를 말한다고 규정하고 있는바,

구직자가 밝힌 정신질환²⁾을 확인하기 위한 의사소견서나 건강진단확인서(이하 “건강진단 확인서등”이라 함)가 채용절차법 제2조제6호에 따른 채용서류에 해당하는지?

02 회답

구직자가 밝힌 정신질환을 확인하기 위한 건강진단확인서등은 채용절차법 제2조제6호에 따른 채용서류에 해당하지 않습니다.

03 이유

채용절차법 제2조제6호에서는 채용서류를 기초심사자료, 입증자료, 심층심사자료로

- 1) 직업을 구하기 위하여 구인자의 채용광고에 응시하는 사람을 말하며(채용절차법 제2조제2호 참조), 이하 같음
- 2) 정신질환이 이 사안 업무 수행과 직접적으로 관련되지 않고, 법령에서 해당 업무에 대해 필수적 고용요건으로 정신질환 관련 내용을 규정하고 있지 않은 경우를 전제함

정의하면서, 같은 조 제3호에서 기초심사자료를 응시원서, 이력서 및 자기소개서라고 규정하고 있는데, 해당 자료에 구체적으로 포함될 내용은 직종의 성격이나 구인의 목적 등에 따라 달라질 수 있으나, 같은 법 제4조의3에서는 구인자³⁾는 구직자에 대하여 ‘그 직무의 수행에 필요하지 아니한’ 구직자 본인의 용모·키·체중 등의 신체적 조건(제1호) 등을 기초심사자료에 기재하도록 요구하거나 입증자료로 수집하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 같은 법 제5조에 따라 고용노동부장관이 정한 표준 이력서 및 자기소개서의 내용을 살펴보면 주요 경력사항, 자격증 및 특기사항, 연구실적 등 구인자가 개별적으로 파악하기 어려운 구직자의 정보를 기재하도록 하고 있으며, 같은 법 제2조제4호·제5호에서는 ‘입증자료’ 및 ‘심층심사자료’를 각각 ‘기초심사자료에 기재한 사항을 증명하는 모든 자료’, ‘작품집, 연구실적물 등 구직자의 실력을 알아볼 수 있는 모든 물건 및 자료’로 규정하고 있는바, 채용서류는 구직자가 직업을 구하기 위하여 구인자의 채용광고에 응시하면서 작성·제출하는 서류로서 채용 과정에서 구인자가 채용하려는 직무에 적합한 학위나 자격, 실력 등을 구직자가 갖추고 있는지 조사하여 판단하기 위한 자료라고 보아야 하는데, 응시원서, 이력서, 자기소개서 등 기초심사자료에 기재되지 않은 정신질환 병력에 대한 건강진단확인서등은 기초심사자료에 대한 입증자료에 해당하지 않고, 구직자의 정신질환 병력 관련 자료는 구직자의 실력을 알아볼 수 있는 모든 물건 및 자료인 심층심사자료에도 해당하지 않는바, 이 사안의 경우에는 채용절차법 제2조제6호에 따른 채용서류에 해당하지 않는다고 보는 것이 합리적입니다.

그리고 채용절차법은 채용절차에서의 최소한의 공정성을 확보하기 위한 사항을 정함으로써 구직자의 부담을 줄이고 권익을 보호하는 것을 목적(제1조)으로 제정된 법률로서, 채용시장에서 구직자가 각종 채용서류의 제출을 위해 경제적·시간적 부담을 감내하고 있는 상황에서 불합리한 관행을 개선하여 구직자의 개인정보를 보호하고 구직비용을 절감할 수 있도록 하려는 것이 입법 취지⁴⁾이고, 채용절차법 제9조 본문에서는 구인자로 하여금 채용심사를 목적으로 구직자에게 채용서류 제출에 드는 비용 이외의 어떠한 금전적 비용도 부담시키지 못하도록 규정하고 있는 점에 비추어 보면, 구직자가 밝힌 정신질환을 확인하기 위한 건강진단확인서등을 채용서류에 해당하는 것으로 보는 것은 채용절차법의 취지에 부합하지 않습니다.

아울러 「고용정책 기본법」 제7조제1항에서 사업주는 근로자를 모집·채용할 때에 합리적인 이유 없이 혼인·임신 또는 ‘병력’ 등을 이유로 차별을 하여서는 아니 되며 균등한 취업기회를

3) 구직자를 채용하려는 자를 말하며(채용절차법 제2조제1호 참조), 이하 같음

4) 2012. 9. 4. 의안번호 제1901543호로 발의된 채용절차의 공정화에 관한 법률안에 대한 국회 환경노동위원회 심사보고서 참조

보장하여야 한다고 규정하고 있는 점, 「개인정보 보호법」 제23조에 따라 건강에 관한 정보는 민감정보로서 그 처리가 제한되는 점, 채용절차법 제17조제2항제3호에서는 같은 법 제4조의3을 위반하여 그 직무의 수행에 필요하지 아니한 개인정보를 기초심사자료에 기재하도록 요구하거나 입증자료로 수집한 구인자에게 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있는 점 등을 고려할 때, 구직자가 제출하는 채용서류의 범위를 이 사안의 건강진단확인서등이 포함되는 것으로 확대 해석하는 것은 타당하지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 구직자가 밝힌 정신질환을 확인하기 위한 건강진단확인서등은 채용절차법 제2조제6호에 따른 채용서류에 해당하지 않습니다.



관계법령

채용절차의 공정화에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “구인자”란 구직자를 채용하려는 자를 말한다.
2. “구직자”란 직업을 구하기 위하여 구인자의 채용광고에 응시하는 사람을 말한다.
3. “기초심사자료”란 구직자의 응시원서, 이력서 및 자기소개서를 말한다.
4. “입증자료”란 학위증명서, 경력증명서, 자격증명서 등 기초심사자료에 기재한 사항을 증명하는 모든 자료를 말한다.
5. “심층심사자료”란作品集, 연구실적물 등 구직자의 실력을 알아볼 수 있는 모든 물건 및 자료를 말한다.
6. “채용서류”란 기초심사자료, 입증자료, 심층심사자료를 말한다.

제4조의3(출신지역 등 개인정보 요구 금지) 구인자는 구직자에 대하여 그 직무의 수행에 필요하지 아니한 다음 각 호의 정보를 기초심사자료에 기재하도록 요구하거나 입증자료로 수집하여서는 아니 된다.

1. 구직자 본인의 용모·키·체중 등의 신체적 조건
2. 구직자 본인의 출신지역·혼인여부·재산
3. 구직자 본인의 직계 존비속 및 형제자매의 학력·직업·재산

제9조(채용심사비용의 부담금지) 구인자는 채용심사를 목적으로 구직자에게 채용서류 제출에 드는 비용 이외의 어떠한 금전적 비용(이하 “채용심사비용”이라고 한다)도 부담시키지 못한다. 다만, 사업장 및 직종의 특수성으로 인하여 불가피한 사정이 있는 경우 고용노동부장관의 승인을 받아 구직자에게 채용심사비용의 일부를 부담하게 할 수 있다.

제17조(과태료) ① 제4조의2를 위반하여 채용강요 등의 행위를 한 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다. 다만, 「형법」 등 다른 법률에 따라 형사처벌을 받은 경우에는 과태료를 부과하지 아니하며, 과태료를 부과한 후 형사처벌을 받은 경우에는 그 과태료 부과를 취소한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

1.·2. (생 략)

3. 제4조의3을 위반하여 그 직무의 수행에 필요하지 아니한 개인정보를 기초심사자료에 기재하도록 요구하거나 입증자료로 수집한 구인자

③·④ (생 략)

질의제목 5

▶ 안전번호 25-0155

민원인 - 「고용보험법 시행령」 제95조의3제1항에서 규정하고 있는 ‘출생 후 18개월’은 출생일을 산입하여 계산하는지 여부(「고용보험법 시행령」 제95조의3제1항 등 관련)

01 질의요지

「고용보험법 시행령」 제95조의3제1항에서는 같은 영 제95조제1항 및 제95조의2제1항·제2항에도 불구하고 같은 자녀에 대하여 자녀의 출생 후 18개월이 될 때까지 피보험자¹⁾인 부모가 모두 육아휴직을 하는 경우²⁾ 그 부모인 피보험자의 육아휴직 급여의 월별 지급액 산정 방법을 규정하고 있는바,

「고용보험법 시행령」 제95조의3제1항에서 규정하고 있는 ‘출생 후 18개월’은 출생일을 산입하여 계산하는지?

02 회답

「고용보험법 시행령」 제95조의3제1항에서 규정하고 있는 ‘출생 후 18개월’은 출생일을 산입하여 계산합니다.

03 이유

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 “남녀고용평등법”이라 함) 제19조제1항에서는 사업주는 임신 중인 여성 근로자가 모성을 보호하거나 근로자가 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀³⁾를 양육하기 위하여 육아휴직을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다고 규정하고 있고, 「고용보험법」 제70조제1항에서는 고용노동부장관은

1) 「고용보험법」 제2조제1호에 따른 피보험자를 말하며, 이하 같음.

2) 부모의 육아휴직기간이 전부 또는 일부 겹치지 않은 경우를 포함하며, 이하 같음.

3) 입양한 자녀를 포함하며, 이하 같음

남녀고용평등법 제19조에 따른 육아휴직을 30일⁴⁾이상 부여받은 피보험자 중 육아휴직을 시작한 날 이전에 「고용보험법」 제41조에 따른 피보험 단위기간이 합산하여 180일 이상인 피보험자에게 육아휴직 급여를 지급한다고 규정하고 있으며, 「고용보험법 시행령」 제95조의3제1항에서는 같은 영 제95조제1항 및 제95조의2제1항·제2항에도 불구하고 같은 자녀에 대하여 자녀의 출생 후 18개월이 될 때까지 피보험자인 부모가 모두 육아휴직을 하는 경우 그 부모인 피보험자의 육아휴직 급여의 월별 지급액은 같은 영 제95조의3제1항 각 호의 구분에 따라 산정한 금액으로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 ‘자녀의 출생 후 18개월’을 계산할 때 출생일을 산입해야 하는지 여부가 문제됩니다.

먼저 남녀고용평등법 제19조제1항에서는 육아휴직의 요건 중 하나로 자녀의 나이 요건(8세 이하)을 규정하고 있고, 「고용보험법」 제70조에 따른 육아휴직 급여는 남녀고용평등법 제19조에 따른 육아휴직을 일정 기간 이상 부여받은 피보험자를 대상으로 하고 있어, 남녀고용평등법 제19조에 따른 육아휴직과 「고용보험법」 제70조에 따른 육아휴직 급여가 서로 연계되어 육아휴직 제도가 운영되고 있다고 할 것인바, 「고용보험법 시행령」 제95조의3제1항에서 규정하고 있는 육아휴직 급여의 특례 요건인 ‘자녀의 출생 후 18개월이 될 때까지 부모가 모두 육아휴직을 하는 경우’를 해석할 때에도 남녀고용평등법 제19조에 따른 육아휴직의 요건이 자녀의 나이를 기준으로 하고 있는 점을 고려하여 해석할 필요가 있습니다.

그런데 행정에 관한 나이 계산 및 표시에 관한 일반 원칙과 기준⁵⁾을 규정하고 있는 「행정기본법」 제7조의2 본문에서는 행정에 관한 나이는 다른 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 출생일을 산입하여 만(滿) 나이로 계산하고, 연수(年數)로 표시한다고 규정하고 있는바, 육아휴직 요건이 자녀의 나이를 기준으로 하고 있는 점을 고려하면 「고용보험법 시행령」 제95조의3제1항에서 규정하고 있는 ‘자녀의 출생 후 18개월’을 계산할 때에도 출생일이 산입된다고 보아야 할 것입니다.

그리고 「고용보험법 시행령」 제95조의3의 입법연혁을 살펴보면, 2021년 12월 31일 대통령령 제32301호로 일부개정된 「고용보험법 시행령」에서는 부모의 양육이 절실한 생후 12개월 이내의 영아기에 부모 모두의 육아휴직 사용을 촉진하기 위하여 같은 자녀에 대하여 자녀의 출생 후 12개월이 될 때까지 피보험자인 부모가 모두 육아휴직을 하는 경우 최초 3개월의 육아휴직 급여는 각 피보험자의 월 통상임금에 해당하는 금액을 지급하도록 하는

4) 「근로기준법」 제74조에 따른 출산전후휴가기간과 중복되는 기간은 제외함

5) 2022. 12. 27. 법률 제19148호로 일부개정된 「행정기본법」 개정이유 및 주요내용 참조

육아휴직 급여의 특례 규정을 신설하였고⁶⁾, 2023년 12월 26일 대통령령 제34048호로 일부개정된 「고용보험법 시행령」에서는 부모 공동 육아휴직을 장려하기 위하여 특례 규정의 적용 대상이 되는 자녀의 나이를 ‘출생 후 12개월 이내의 자녀’에서 현행과 같이 ‘출생 후 18개월 이내의 자녀’로 확대한 것⁷⁾인 점을 고려하면, 같은 영 제95조의3제1항의 ‘출생 후 18개월’을 계산할 때에는 나이를 계산하는 경우와 같이 출생일이 산입된다고 보는 것이 해당 규정의 취지에도 부합한다고 할 것입니다.

한편 「고용보험법 시행령」 제95조의3제1항의 ‘출생 후 18개월’은 육아휴직 급여의 특례를 적용받기 위한 요건이므로 기간을 계산할 때와 같이 「민법」 제157조에 따라 출생일을 산입하지 않고 계산하여야 한다는 의견이 있으나, 「고용보험법 시행령」 제95조의3에서는 조의 제목을 ‘출생 후 18개월 이내의 자녀에 대한 육아휴직 급여 등의 특례’로 하면서 같은 조 제1항에서는 육아휴직 급여의 특례 적용 기준을 ‘자녀의 출생 후 18개월이 될 때까지’ 피보험자인 부모가 모두 육아휴직을 하는 경우로 규정하고 있으므로, 이는 남녀고용평등법상 육아휴직 대상 판단기준인 자녀의 나이 요건을 의미하는 것으로 보이는 점, 근로자의 일과 가정의 양립을 지원하는 육아휴직 제도의 취지상 자녀 양육의 필요성은 출생일부터 발생하는 점 등을 고려하면, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 「고용보험법 시행령」 제95조의3제1항에서 규정하고 있는 ‘출생 후 18개월’은 출생일을 산입하여 계산합니다.



관계법령

고용보험법 시행령

제95조의3(출생 후 18개월 이내의 자녀에 대한 육아휴직 급여 등의 특례) ① 제95조제1항 및 제95조의2제1항·제2항에도 불구하고 같은 자녀에 대하여 자녀의 출생 후 18개월이 될 때까지 피보험자인 부모가 모두 육아휴직을 하는 경우(부모의 육아휴직기간이 전부 또는 일부 겹치지 않은 경우를 포함한다) 그 부모인 피보험자의 육아휴직 급여의 월별 지급액은 다음 각 호의 구분에 따라 산정한 금액으로 한다.

1.·2. (생 략)

②·③ (생 략)

6) 2021. 12. 31. 대통령령 제32301호로 일부개정된 「고용보험법 시행령」 주요내용 참조

7) 2023. 12. 26. 대통령령 제34048호로 일부개정된 「고용보험법 시행령」 개정이유 및 주요내용 참조

CHAPTER

9

국토교통

제1절 국토개발·건축·건설

제2절 주택관리·부동산

제3절 도로·교통

제1절 국토개발·건축·건설

질의제목 1 ▶ 안전번호 24-0716

민원인 - 시장 등이 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 부동산개발에 해당하는 건축허가의 신청을 받은 경우, 그 건축허가 시 부동산개발업 등록 여부를 심사하여 서류 등의 보완을 요구할 수 있는지(「건축법」 제11조 및 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제4조 등 관련)

01 질의요지

「건축법」 제11조제1항에서는 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 “시장등”이라 함)의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」(이하 “부동산개발업법”이라 함) 제4조제1항에서는 타인에게 공급할 목적으로 건축물의 연면적¹⁾이 2천제곱미터 또는 연간 5천제곱미터 이상이거나 토지의 면적이 3천제곱미터 또는 연간 1만제곱미터 이상으로서 대통령령으로 정하는 규모 이상의 부동산개발을 업으로 영위하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 함)에게 등록을 하여야 한다고 규정하고 있는바,

시장등이 「건축법」 제11조에 따른 건축허가 신청을 받은 경우로서 해당 건축행위가 부동산개발업법 제4조제1항에 따른 부동산개발에 해당하는 경우, 그 건축허가 시 부동산개발업 등록 여부를 심사하여 서류 등의 보완을 요구할 수 있는지?

1) 「건축법」 제84조에 따른 연면적을 말한다.

02 회답

이 사안의 경우, 「건축법」 제11조에 따른 건축허가 시 부동산개발업 등록 여부를 심사하여 서류 등의 보완을 요구할 수 있습니다.

03 이유

「건축법」 제11조제1항에서는 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 시장등의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제5항 각 호에 따른 허가 등을 받기 위하여 관계 법령에서 제출하도록 의무화하고 있는 신청서 및 구비서류를 첨부하여 허가권자에게 제출하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제5항에서는 건축허가를 받으면 허가 등을 받은 것으로 의제되는 경우를 각 호로 규정하고 있는데, 「건축법」 제11조제5항 각 호에서는 부동산개발업법 제4조에 따른 부동산개발업의 등록에 관하여는 규정하고 있지 않습니다.

그리고 「건축법」 제12조제1항에서는 허가권자는 같은 법 제11조에 따라 허가를 하려면 해당 건축물을 건축하려는 대지에 건축하는 것이 국토계획법의 규정과 대통령령으로 정하는 관계 법령의 규정에 맞는지를 확인하기 위해 건축복합민원 일괄협의회를 개최하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제10조제1항에서는 “대통령령으로 정하는 관계 법령의 규정”을 각 호로 규정하고 있는데, 같은 항 각 호에서는 부동산개발업법 제4조에 따른 부동산개발업의 등록에 관해 규정하고 있지 않은바, 이 사안에서는 건축법령에서 건축허가를 신청한 자에게 제출하도록 하거나 건축허가권자가 심사할 것으로 규정한 내용에 부동산개발업의 등록에 관한 사항을 규정하고 있지 않음에도, 시장등이 부동산개발업법 제4조제1항에 따른 부동산개발에 해당하는 건축허가 신청을 받은 경우 그 건축허가 시 부동산개발업 등록 여부를 심사하여 서류 등의 보완을 요구할 수 있는지가 문제됩니다.

이와 관련하여 건축허가권자는 건축허가 신청이 「건축법」 등 관계 법규에서 정하는 어떠한 제한에 배치되지 않는 이상 건축허가를 하여야 할 것이나, 중대한 공익상의 필요가 있는 경우에는 이와 달리 판단할 여지가 있다고 할 것인바²⁾, 부동산개발업법상 부동산개발업

2) 대법원 2009. 9. 24. 선고 2009두8946 판결례 참조

등록제도는 일정 규모 이상의 부동산개발을 업으로 영위하려는 자에게 일정한 등록기준을 갖추도록 함으로써 영세하고 전문성이 부족한 부동산개발업자의 난립과 사기분양, 거짓 광고 등으로 발생하는 소비자의 피해를 방지하기 위해 도입된 것으로³⁾, 부동산개발업의 등록은 원칙적으로 개발행위에 대한 인허가를 받기 전에 이루어져야 하는 것⁴⁾인데, 부동산개발업 등록대상에 해당하는 규모의 부동산개발 행위에 대해 건축허가 단계에서 부동산개발업 등록 여부에 대한 별도의 확인 및 보완 없이 건축허가가 이루어질 경우, 등록요건을 갖추지 않은 부실한 사업자에 의한 개발행위 및 부동산 공급과정에서 허위광고나 사기분양 등의 소비자 피해가 발생할 수 있고, 부동산개발업법은 주로 등록사업자 대상의 관리·조사·시정조치 등의 제도를 두고 있어⁵⁾ 미등록 사업자에 대한 규율이 어려워 건축허가 단계에서 이를 확인하지 않는다면 사실상 부동산개발업 등록제도가 유명무실하게 될 수 있는바, 건축허가 단계에서 부동산개발업 등록 여부를 심사하여 필요 시 서류를 보완하도록 할 공익상 필요가 있다고 할 것입니다.

더욱이 부동산개발업법 제6조에서는 부동산개발업 등록의 결격사유로 같은 조 제3호가목에서 「건축법」 등에서 정한 죄를 범하여 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료되거나 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 자 등을 규정하여, 부동산개발업 등록 시 건축법령을 준수할 것을 요구하고 있는 점, 부동산개발업 등록대상에 해당하는 부동산개발 행위는 대규모의 건축행위로서 이러한 건축물의 건축이 자본금, 전문인력 등의 등록요건을 갖추지 못한 자에 의해 이루어지는 경우 건축법령에 적합하지 않은 부실한 건축물이 건축될 가능성이 높아질 수 있는 점 등을 고려하면, 건축허가 단계에서 부동산개발업의 등록 여부를 심사함으로써 건축물이 건축법령 등에 따라 안전하게 건축될 수 있도록 할 공익상 필요도 있다고 볼 것입니다.

또한 입법목적 등을 달리하는 법률들이 일정한 행위에 관한 요건을 각기 정하고 있는 경우, 그 중 하나의 인허가에 관한 행위가 다른 법령에 의하여 절대적으로 금지되고 있어 그것이 객관적으로 불가능한 것이 명백한 경우 등에는 그러한 요건을 고려하여 인허가 여부를 결정할 수 있다고 할 것인데⁶⁾, 건축법령에 따른 건축허가 요건과 부동산개발업법령에 따른 부동산개발업 등록 요건은 해당 법령에서 각각 규정하고 있으나, 부동산개발업법 제2조제1호에서는 “부동산개발”을 건축물을 건축하는 행위(나목) 등으로 규정하는 등

3) 2007. 5. 17. 법률 제8480호로 제정된 부동산개발업법 제정이유 참조

4) 법제처 2014. 5. 9. 회신 14-0051 해석례 참조

5) 부동산개발업법 제17조(등록사업자의 보고의무 등), 제18조(부동산개발업자의 실태조사 등) 등 참조

6) 대법원 2002. 1. 25. 선고 2000두5159 판결례 참조

부동산개발업법에 따른 “부동산개발”을 하기 위해서는 건축법령 등에 따른 허가 절차를 거쳐야만 하고, 부동산개발 행위를 하기 위해서는 부동산개발업법 제4조제2항의 요건을 갖추어 부동산개발 행위 전에 부동산개발업의 등록을 하여야 하며, 부동산개발업을 등록하지 않은 자는 부동산개발 행위로서 건축물을 건축하여 타인에게 공급할 수 없는바⁷⁾, 건축법령상 건축허가 대상 건축행위가 부동산개발업법상 부동산개발업 등록이 필요한 부동산개발 행위임에도 불구하고 부동산개발업 등록이 되어 있지 않은 경우 그 부동산개발 행위로서의 건축행위는 부동산개발업법에 따라서는 가능하지 않으므로, 시장등 건축허가권자는 부동산개발업 등록대상 부동산개발 행위에 해당하는 건축허가를 신청받는 경우에는 부동산개발업 등록을 하지 않은 자에 의해 건축물이 건축되어 타인에게 공급되지 않도록 건축허가 단계에서 타인 공급 목적 등 부동산개발업 등록대상 여부를 확인할 필요가 있으며, 이를 위해 관련 서류를 제출받고 필요 시 보완을 요구할 수 있다고 할 것입니다.

아울러 부동산개발업의 등록은 시·도지사에게 하여야 하나 부동산개발 관련 건축허가는 「건축법」에 따라 시장등에게 받아야 하므로, 건축허가권자인 시장등이 건축허가 단계에서 부동산개발업 등록 여부를 별도로 심사하지 않을 경우 부동산개발업 미등록자에 의한 부동산개발 행위를 사전에 방지하기 어려운 점, 건축허가 신청자가 허가 신청 후에 부동산개발업법령에 따른 부동산개발업 등록을 하여야 한다는 사실을 알게된 경우, 만약 건축허가 단계에서 이를 보완할 수 없다면, 건축허가 신청자는 이미 신청한 건축허가 신청을 철회하고 부동산개발업 등록 후 다시 건축허가를 신청하여야 하는 점 등을 고려하면, 건축허가 단계에서 부동산개발업 등록 여부를 심사하도록 함으로써 불필요한 행정력 낭비 및 신청인의 불이익을 줄일 수 있다는 점⁸⁾도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「건축법」 제11조에 따른 건축허가 시 부동산개발업 등록 여부를 심사하여 서류 등의 보완을 요구할 수 있습니다.

7) 법제처 2014. 5. 9. 회신 14-0051 해석례 참조

8) 대법원 1995. 7. 28. 선고 94누13497 판결, 1998. 3. 27. 선고 96누19772 판결 등 참조

법령정보 권고사항

「건축법」 제11조 등에 따른 건축허가 단계에서 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 부동산개발업의 등록여부를 확인해야 한다면 이를 명확하게 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

건축법

제11조(건축허가) ① 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. 다만, 21층 이상의 건축물 등 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려면 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다.

② (생략)

③ 제1항에 따라 허가를 받으려는 자는 허가신청서에 국토교통부령으로 정하는 설계도서와 제5항 각 호에 따른 허가 등을 받거나 신고를 하기 위하여 관계 법령에서 제출하도록 의무화하고 있는 신청서 및 구비서류를 첨부하여 허가권자에게 제출하여야 한다. 다만, 국토교통부장관이 관계 행정기관의 장과 협의하여 국토교통부령으로 정하는 신청서 및 구비서류는 제21조에 따른 착공신고 전까지 제출할 수 있다.

④ (생략)

⑤ 제1항에 따른 건축허가를 받으면 다음 각 호의 허가 등을 받거나 신고를 한 것으로 보며, 공장건축물의 경우에는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의2와 제14조에 따라 관련 법률의 인·허가등이나 허가등을 받은 것으로 본다.

1. 제20조제3항에 따른 공사용 가설건축물의 축조신고

2. 제83조에 따른 공작물의 축조신고

3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가

4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조제5항에 따른 시행자의 지정과 같은 법 제88조제2항에 따른 실시계획의 인가

5. ~ 23. (생략)

⑥ ~ ⑪ (생략)

부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률

제4조(부동산개발업의 등록 등) ① 타인에게 공급할 목적으로 건축물의 연면적(「건축법」 제84조에 따른 연면적을 말한다)이 2천제곱미터 또는 연간 5천제곱미터 이상이거나 토지의 면적이 3천제곱미터 또는 연간 1만제곱미터 이상으로서 대통령령으로 정하는 규모 이상의 부동산개발을 업으로

영위하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)에게 등록을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. ~ 5. (생 략)

② 제1항에 따라 등록하는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다. 이 경우 등록절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

1. 자본금이 3억원(개인인 경우에는 영업용자산평가액이 6억원) 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상일 것

2. 대통령령으로 정하는 시설 및 부동산개발 전문인력을 확보할 것

③ ~ ⑥ (생 략)

질의제목 2

▶ 안전번호 24-0791

민원인 - 개발사업의 준공인가 후 개발사업이 취소된 경우 개발부담금의 부과 종료 시점(「개발이익 환수에 관한 법률」 제9조 등 관련)

01 질의요지

「개발이익 환수에 관한 법률」(이하 “개발이익환수법”이라 함) 제8조에서는 개발부담금의 부과 기준은 부과 종료 시점의 부과 대상 토지의 가액에서 부과 개시 시점의 부과 대상 토지의 가액(제1호), 부과 기간의 정상지가상승분(제2호), 같은 법 제11조에 따른 개발비용(제3호)을 뺀 금액으로 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제9조제3항 본문에서는 부과 종료 시점은 관계 법령에 따라 국가나 지방자치단체로부터 개발사업의 준공인가 등을 받은 날로 한다고 규정하고 있으며, 같은 항 단서에서는 부과 대상 토지의 전부 또는 일부가 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하면 해당 토지에 대하여는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날을 부과 종료 시점으로 한다고 규정하면서 각 호에서는 관계 법령에 따라 부과 대상 토지의 일부가 준공된 경우(제1호), 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우(제3호) 등을 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제10조제3항에서는 같은 법 제9조제3항제3호에서 “그 밖에 대통령령으로 정하는 경우”란 개발사업을 시작한 후 개발사업에 대한 인가등¹⁾이 해당 법률에서 정하는 바에 따라 취소된 경우(제1호) 등에 해당하는 사유가 발생한 경우를 말한다고 규정하고 있는바,

개발사업의 준공인가 후 개발사업과 관련된 위법행위로 인하여 개발사업의 허가가 취소된 경우, 해당 개발사업에 적용되는 개발부담금의 부과 종료 시점은 개발사업의 준공인가를 받은 날인지, 아니면 개발사업에 대한 허가가 취소된 날인지?

02 회답

개발사업의 준공인가 후 개발사업과 관련된 위법행위로 인하여 개발사업의 허가가 취소된 경우, 해당 개발사업에 적용되는 개발부담금의 부과 종료 시점은 개발사업의 준공인가를 받은 날입니다.

1) 국가나 지방자치단체로부터 받는 인가·허가·면허 등을 말하며(개발이익환수법 제2조제2호 참조), 이하 같음

03 이유

먼저 개발이익환수법 제9조제3항 본문에서는 개발부담금의 부과 종료 시점은 관계 법령에 따라 국가나 지방자치단체로부터 개발사업의 준공인가 등을 받은 날로 한다고 규정하고 있고, 같은 항 단서에서는 부과 대상 토지의 전부 또는 일부에 대해 부과 종료 시점을 달리 정할 수 있는 사유들을 각 호로 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제10조에서는 조 제목을 “개발사업의 준공 전 부과 종료 시점”으로 규정하면서 같은 조 제3항 각 호에서는 부과 종료 시점을 준공인가일과 달리 정할 수 있는 사유들에 대하여 규정하고 있는바, 개발이익환수법 제9조제3항 및 같은 법 시행령 제10조의 규정 체계와 조 제목 등에 비추어보면 개발부담금의 부과 종료 시점을 준공인가일과 달리 정할 수 있는 경우는 개발사업의 준공 전에 해당 사유가 발생한 경우로 한정된다고 할 것이고²⁾, 이 사안과 같이 개발사업의 준공인가 후에 개발사업의 허가가 취소된 경우의 개발부담금의 부과 종료 시점은 개발이익환수법 제9조제3항 본문에 따라 개발사업의 준공인가를 받은 날이라고 해석하는 것이 규정 체계에 부합한다고 할 것입니다.

그리고 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데³⁾, 개발이익환수법 제9조제3항에서는 부과 종료 시점은 원칙적으로 관계 법령에 따라 국가나 지방자치단체로부터 개발사업의 준공인가 등을 받은 날로 한다고 규정하면서(본문), 개발사업이 취소되거나 개발사업이 파산되거나 중단되어 사업을 끝낼 수 없게 된 경우 등 개발사업의 준공인가를 받기 곤란하거나 불합리한 경우 등에는 예외적으로 부과 대상 토지의 전부 또는 일부에 대해 부과 종료 시점을 달리 정할 수 있도록 규정하고(단서) 있는바, 이미 개발사업의 준공인가를 받아 원칙적인 개발부담금의 부과 종료 시점에 따라 개발부담금을 부과할 수 있는 경우라면 그 부과 종료 시점은 개발사업의 준공인가를 받은 날로 해석해야 할 것이지, 준공인가 후에 개발사업의 허가가 취소되었다는 이유로 그 허가가 취소된 날을 부과 종료 시점으로 해석하는 것은 합리적인 이유 없이 예외규정의 의미를 확대하여 해석하는 것으로서 타당하지 않습니다.

따라서 개발사업의 준공인가 후 개발사업과 관련된 위법행위로 인하여 개발사업의 허가가 취소된 경우, 해당 사업에 적용되는 개발부담금의 부과 종료 시점은 준공인가를 받은 날입니다.

2) 대법원 1993. 5. 24. 선고 93누4069 판결례 참조

3) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례 참조

법령정비 권고사항

개발사업의 준공인가를 받은 후 개발사업의 허가가 취소된 경우, 그 개발부담금의 부과 종료 시점에 대하여 개발이익환수법령에서 명확하게 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

개발이익 환수에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “개발이익”이란 개발사업의 시행이나 토지이용계획의 변경, 그 밖에 사회적·경제적 요인에 따라 정상지가(正常地價)상승분을 초과하여 개발사업을 시행하는 자(이하 “사업시행자”라 한다)나 토지 소유자에게 귀속되는 토지 가액의 증가분을 말한다.
2. “개발사업”이란 국가나 지방자치단체로부터 인가·허가·면허 등(신고를 포함하며, 이하 “인가등”이라 한다)을 받아 시행하는 택지개발사업이나 산업단지개발사업 등 제5조에 따른 사업을 말한다.
3. “정상지가상승분”이란 금융기관의 정기예금 이자율 또는 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 조사한 평균지가변동률(그 개발사업 대상 토지가 속하는 해당 시·군·자치구의 평균지가변동률을 말한다) 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 산정한 금액을 말한다.
4. “개발부담금”이란 개발이익 중 이 법에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 “시장·군수·구청장”이라 한다)이 부과·징수하는 금액을 말한다

제8조(부과 기준) 개발부담금의 부과 기준은 부과 종료 시점의 부과 대상 토지의 가액(이하 “종료시점지가”라 한다)에서 다음 각 호의 금액을 뺀 금액으로 한다.

1. 부과 개시 시점의 부과 대상 토지의 가액(이하 “개시시점지가”라 한다)
2. 부과 기간의 정상지가상승분
3. 제11조에 따른 개발비용

제9조(기준 시점) ① 부과 개시 시점은 사업시행자가 국가나 지방자치단체로부터 개발사업의 인가등을 받은 날로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그에 해당하는 날을 부과 개시 시점으로 한다.

1. 인가등을 받기 전 5년 이내에 대통령령으로 정하는 토지 이용 계획 등이 변경된 경우로서 그 토지 이용 계획 등이 변경되기 전에 취득한 토지의 경우에는 취득일. 다만, 그 취득일부터 2년 이상이 지난 후 토지 이용 계획 등이 변경된 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 날로 한다.
2. 인가등의 변경으로 부과 대상 토지의 면적이 변경된 경우에는 대통령령으로 정하는 시점

- ② 제1항에 따른 개발사업의 인가등을 받은 날과 취득일은 대통령령으로 정한다.
- ③ 부과 종료 시점은 관계 법령에 따라 국가나 지방자치단체로부터 개발사업의 준공인가 등을 받은 날로 한다. 다만, 부과 대상 토지의 전부 또는 일부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 해당 토지에 대하여는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날을 부과 종료 시점으로 한다.
 - 1. 관계 법령에 따라 부과 대상 토지의 일부가 준공된 경우
 - 2. 납부 의무자가 개발사업의 목적 용도로 사용을 시작하거나 타인에게 분양하는 등 처분하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
 - 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우
- ④ 제3항 각 호 외의 부분 본문에 따른 개발사업의 준공인가 등을 받은 날은 대통령령으로 정한다.

개발이익 환수에 관한 법률 시행령

제10조(개발사업의 준공 전 부과 종료 시점) ① ~ ② (생 략)

- ③ 법 제9조제3항제3호에서 “그 밖에 대통령령으로 정하는 경우”란 개발사업을 시작한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우를 말한다.
 - 1. 개발사업에 대한 인가등이 해당 법률에서 정하는 바에 따라 취소된 경우
 - 2. 사업시행자의 파산이나 그 밖의 사유로 개발사업의 시행이 중단되어 사업을 끝낼 수 없게 된 경우
- ④ (생 략)

질의제목 3

▶ 안전번호 24-0893

민원인 - 착공일부터 3년이 경과하여 준공인가를 받은 후 재건축사업의 토지를 양도한 경우, 양수인의 재건축사업 조합원 자격 취득 여부(「도시 및 주거환경정비법 시행령」 제37조제3항제3호 등 관련)

01 질의요지

「도시 및 주거환경정비법」(이하 “도시정비법”이라 함) 제39조제1항 본문에서는 같은 법 제25조에 따른 정비사업의 조합원¹⁾은 토지등소유자²⁾로 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제39조제2항 본문에서는 「주택법」 제63조제1항에 따른 투기과열지구(이하 “투기과열지구”라 함)로 지정된 지역에서 재건축사업을 시행하는 경우에는 조합설립인가 후 해당 정비사업의 건축물 또는 토지를 양수³⁾한 자는 도시정비법 제39조제1항에도 불구하고 조합원이 될 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항 단서에서는 양도인이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 양도인으로부터 그 건축물 또는 토지를 양수한 자는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고, 같은 항 제7호에서는 양수인이 조합원이 될 수 있는 예외적인 경우의 하나로 “그 밖에 불가피한 사정으로 양도하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우”를 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제37조제3항제3호에서는 대통령령으로 정하는 경우의 하나로 “착공일부터 3년 이상 준공되지 않은 재개발사업·재건축사업의 토지를 3년 이상 계속하여 소유하고 있는 경우”를 규정하고 있는바,

착공일부터 3년이 경과하여 준공인가⁴⁾를 받은 후 이전고시⁵⁾가 있기 전에 그 재건축사업의 토지를 양도한 경우⁶⁾에 해당 양도인으로부터 토지를 양수한 자는 해당 재건축사업의 조합원 자격이 있는지?

- 1) 사업시행자가 신탁업자인 경우에는 위탁자를 말하며, 이하 이 조에서 같음
- 2) 도시정비법 제2조제9호에 따른 토지등소유자를 말하며(재건축사업의 경우에는 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자), 재건축사업의 경우에는 재건축사업에 동의한 자만 해당함
- 3) 매매·증여 그 밖의 권리의 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속·이혼으로 인한 양도·양수의 경우는 제외하며, 이하 이 조에서 같음
- 4) 도시정비법 제83조에 따른 준공인가를 말하며, 이하 같음
- 5) 도시정비법 제86조에 따른 이전고시를 말하며, 이하 같음.
- 6) 투기과열지구로 지정된 지역에서 시행되는 재건축사업의 토지가 양도된 경우로서 양도인이 양도 시점에 해당 재건축사업의 토지를 3년 이상 계속하여 소유하고 있는 경우임을 전제함

02 회답

착공일부터 3년이 경과하여 준공인가를 받은 후 이전고시가 있기 전에 그 재건축사업의 토지를 양도한 경우에 해당 양도인으로부터 토지를 양수한 자는 해당 재건축사업의 조합원 자격이 없습니다.

03 이유

도시정비법 제39조제2항 본문에서는 원칙적으로 투기과열지구로 지정된 지역에서 시행되는 재건축사업의 건축물 또는 토지를 조합설립인가 후에 양수한 자에 대해 조합원 자격을 취득할 수 없도록 하면서, 같은 항 단서 및 같은 법 시행령 제37조제3항제3호에서는 예외적으로 양도인이 “착공일부터 3년 이상 준공되지 않은 재개발사업·재건축사업의 토지를 3년 이상 계속하여 소유하고 있는 경우”에는 그 양수인이 조합원 자격을 취득할 수 있도록 규정하고 있는데, “착공일부터 3년 이상 준공되지 않은” 상태가 해당 토지의 양도일까지 유지되어야 하는지에 대해서는 명확히 규정하고 있지 않은바, 이 사안의 경우 해당 토지를 양수한 자가 조합원 자격이 있는지는 해당 규정의 문언, 조합설립인가 후 조합원 자격 취득 제한 제도를 규정한 취지 및 그 예외사유 중 하나로 “착공일부터 3년 이상 준공되지 않은 경우”를 규정한 취지 등을 종합적으로 고려하여 해석할 필요가 있습니다.

먼저 도시정비법 시행령 제37조제3항제3호에서는 예외적으로 조합원 자격을 취득할 수 있는 요건으로 준공 관련 요건과 소유기간 요건을 모두 갖추도록 하면서, 각각 착공일부터 3년 이상 “준공되지 않은” 재건축사업의 토지와 해당 토지를 양도인이 3년 이상 계속하여 “소유하고 있는 경우”를 규정하여 모두 현재 시점을 기준으로 표현하고 있는데, 이는 양도인이 해당 토지의 양도일 현재 조합원 지위를 양도하기 위해 갖추어야 하는 요건을 규정한 것으로 보아야 할 것인바, 해당 규정 중 “착공일부터 3년 이상 준공되지 않은 재건축사업의 토지”는 “착공일부터 3년 이상” 준공인가가 없었을 뿐만 아니라 “양도일 현재”에도 준공인가가 없는 경우를 동시에 규정하고 있다고 할 것입니다.

그리고 도시정비법 제39조제2항 본문에서는 투기과열지구에서 재건축사업이 시행되는 경우 투기가 성행할 우려가 있으므로 투기수요를 차단하기 위해 투기과열지구에서 재건축사업을 시행하는 경우 조합설립인가 후에 해당 정비사업의 토지를 양수한 자는 조합원

자격을 취득할 수 없도록 하였고⁷⁾, 다만 투기수요 차단이라는 입법목적을 달성하면서도 재산권 침해를 최소화하여 공익과 사익의 조화를 도모하기 위하여 같은 항 단서에서 근무상 사정 또는 생업상 사정(제1호) 등 같은 항 각 호에서 정하는 불가피한 사유로 양도가 이루어지는 경우에는 양수인이 조합원 자격을 취득할 수 있도록 그 예외를 규정하고 있으며⁸⁾, 같은 항 제7호의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제37조제3항제3호에서는 사업이 장기간 지연되는 경우에 관한 예외사유의 하나로 “착공일부터 3년 이상 준공되지 않은 재개발사업·재건축사업의 토지를 3년 이상 계속하여 소유하고 있는 경우”를 규정하고 있는바⁹⁾, 이러한 규정의 취지에 비추어 보면, 조합원 자격취득 제한의 예외로 인정되는 경우는 양도일 당시에도 준공인가를 받지 못하여 사업지연이 계속되고 있는 경우로서 해당 토지에 대한 양도·양수가 투기수요에 따른 것으로 보기 어려운 경우로 한정된다고 보아야 할 것이고, 양도시점에 이미 준공인가가 있었다면 더 이상 사업이 지연되고 있다고 보기는 어려울 것인데, 그럼에도 불구하고 이러한 경우를 “착공일부터 3년 이상 준공되지 않은 재개발사업·재건축사업의 토지”에 해당된다고 보는 것은 투기수요 차단을 목적으로 하는 같은 법 시행령 제37조제3항의 입법취지에 부합하지 않습니다.

한편 도시정비법 시행령 제37조제3항제1호·제2호에서는 양수인이 예외적으로 조합원의 자격을 인정받을 수 있는 경우를 각각 사업시행인가 신청 전에 양도하는 경우와 착공 전에 양도하는 경우로 한정하여 규정하였는데, 같은 항 제3호에서만 이와 달리 양도의 시점에 대해 준공 전으로 한정하는 문구를 두지 아니하고 있는 관련 규정의 체계에 비추어 볼 때, 같은 항 제3호에 해당하기 위해서 반드시 준공인가를 받기 전에 양도를 해야 하는 것은 아니라는 의견이 있습니다.

그러나 도시정비법 시행령 제37조제3항제1호·제2호는 구 도시정비법 시행령(2017년 9월 29일 대통령령 제28351호로 일부개정되기 전의 것을 말함) 제30조제3항제1호·제2호에서 각각 “조합설립인가일부터 2년 이내에 사업시행인가 신청이 없는 주택재건축사업의 건축물을 2년 이상 계속하여 소유하고 있는 경우”, “사업시행인가일부터 2년 이내에 착공하지 못한 주택재건축사업의 토지 또는 건축물을 2년 이상 계속하여 소유하고 있는 경우”로 규정하고 있던 것을 개정한 것인데, 사업지연기간과 소유기간을 각각 2년에서 3년으로 확대하고 “사업시행인가 신청 전 양도” 및 “착공 전 양도”라는 문언을 각각 추가하면서도, 개정

7) 2003. 12. 31. 법률 제7056호로 일부개정되어 같은 날 시행된 도시정비법 제·개정이유 및 주요내용 참조

8) 법제처 2021. 9. 29. 회신 21-0408 해석례, 법제처 2019. 7. 25. 회신 19-0241 해석례, 2003. 12. 31. 법률 제7056호로 일부개정된 도시정비법 제·개정이유 및 주요내용 참조

9) 2005. 5. 18. 대통령령 제18830호로 일부개정된 도시정비법 시행령 입법예고문 참조

당시의 부칙¹⁰⁾에서는 기간 요건을 강화한 부분에 대해서만 경과규정을 두고 “사업시행인가 신청 전 양도” 및 “착공 전에 양도”라는 문언을 각각 추가하여 규정한 부분에 대해서는 별도의 경과규정을 두지 않았다는 점에 비추어 볼 때, “사업시행인가 신청 전에 양도하는 경우” 및 “착공 전에 양도”를 규정한 것은 종전의 규정의 의미를 더욱 명확하게 하기 위한 확인적 차원의 개정으로 보는 것이 타당하다고 할 것이고¹¹⁾, 도시정비법 시행령 제37조제3항제3호의 경우 양도의 시점을 준공 전으로 명시하여 규정하고 있지는 않으나, 착공일부터 3년 이상 준공이 지연된 경우에만 사업시행인가(제1호)나 착공(제2호)이 지연된 경우와 다르게 준공인가를 받은 후에 양도 받은 양수인에게까지 조합원 지위를 인정하기 위하여 특별히 양도 시점을 명시하지 않은 것으로 보기는 어려운바, 앞에서 살펴본 바와 같이 같은 항 제3호의 경우도 준공인가 전에 양도하는 경우를 의미하는 것으로 보아야 할 것이므로, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 착공일부터 3년이 경과하여 준공인가를 받은 후 이전고시가 있기 전에 그 재건축사업의 토지를 양도한 경우에 해당 양도인으로부터 토지를 양수한 자는 해당 재건축사업의 조합원 자격이 없습니다.

법령정비 권고사항

도시정비법 제39조제2항 단서 및 제7호와 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제37조제3항제3호에 따라 투기과열지구에서 양수인이 재건축사업 조합원 자격을 취득하기 위해서는 준공인가 전에 해당 토지가 양도되어야 한다는 점을 명확히 규정할 필요가 있습니다.

10) 대통령령 제28351호 도시 및 주거환경정비법 시행령 일부개정령 부칙 제3조 참조

11) 법제처 2022. 3. 18. 화신 21-0708 해석례 등 참조

**도시 및 주거환경정비법**

제39조(조합원의 자격 등) ① 제25조에 따른 정비사업의 조합원(사업시행자가 신탁업자인 경우에는 위탁자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)은 토지등소유자(재건축사업의 경우에는 재건축사업에 동의한 자만 해당한다)로 하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 여러 명을 대표하는 1명을 조합원으로 본다. <단서 생략>

1. ~ 3. (생 략)

② 「주택법」 제63조제1항에 따른 투기과열지구(이하 “투기과열지구”라 한다)로 지정된 지역에서 재건축사업을 시행하는 경우에는 조합설립인가 후, 재개발사업을 시행하는 경우에는 제74조에 따른 관리처분계획의 인가 후 해당 정비사업의 건축물 또는 토지를 양수(매매·증여, 그 밖의 권리의 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속·이혼으로 인한 양도·양수의 경우는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)한 자는 제1항에도 불구하고 조합원이 될 수 없다. 다만, 양도인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 양도인으로부터 그 건축물 또는 토지를 양수한 자는 그러하지 아니하다.

1. ~ 6. (생 략)

7. 그 밖에 불가피한 사정으로 양도하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

③ (생 략)

도시 및 주거환경정비법 시행령

제37조(조합원) ① (생 략)

② (생 략)

③ 법 제39조제2항제7호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 조합설립인가일부터 3년 이상 사업시행인가 신청이 없는 재건축사업의 건축물을 3년 이상 계속하여 소유하고 있는 자(소유기간을 산정할 때 소유자가 피상속인으로부터 상속받아 소유권을 취득한 경우에는 피상속인의 소유기간을 합산한다. 이하 제2호 및 제3호에서 같다)가 사업시행인가 신청 전에 양도하는 경우

2. 사업시행계획인가일부터 3년 이내에 착공하지 못한 재건축사업의 토지 또는 건축물을 3년 이상 계속하여 소유하고 있는 자가 착공 전에 양도하는 경우

3. 착공일부터 3년 이상 준공되지 않은 재개발사업·재건축사업의 토지를 3년 이상 계속하여 소유하고 있는 경우

4. ~ 6. (생 략)

질의제목 4

▶ 안전번호 24-0895

민원인 - 도시·군계획시설사업의 사업시행대상지역 전체가 아닌 일부 지역에 대해 민간사업자를 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정할 수 있는지 여부(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조제5항 등 관련)

01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 함) 제86조제5항에서는 같은 조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 도시·군계획시설사업¹⁾의 시행자가 될 수 있는 자²⁾ 외의 자(이하 “민간사업자”라 함)는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관, 시·도지사³⁾, 시장 또는 군수로부터 시행자로 지정을 받아 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다고 규정하고 있는바,

국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 국토계획법 제86조제5항에 따라 사업시행대상지역 전체가 아닌 일부 지역에 대해서 민간사업자를 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정할 수 있는지?

02 회답

국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 국토계획법 제86조제5항에 따라 사업시행대상지역 전체가 아닌 일부 지역에 대해서는 민간사업자를 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정할 수 없습니다.

1) 국토계획법 제2조제10호에 따른 도시·군계획시설사업을 말하며, 이하 같음

2) 국토교통부장관, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사, 시장 또는 군수 등을 말함

3) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사를 말하며, 이하 같음

03 이유

국토계획법 제86조에 따르면 도시·군계획시설사업은 원칙적으로 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수 등 행정청이 시행하지만(제1항부터 제4항까지), 예외적으로 민간사업자도 행정청의 지정을 받아 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다고 규정하면서(제5항)⁴⁾, 같은 조 제7항에서는 민간사업자 등이 같은 조 제5항에 따라 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정을 받으려면 도시·군계획시설사업의 대상인 토지⁵⁾의 소유 면적 및 토지 소유자의 동의비율에 관하여 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제96조제2항에서는 도시계획시설사업의 대상인 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지를 소유하고, 토지소유자 총수의 2분의 1 이상에 해당하는 자의 동의를 얻도록 하는 등 구체적인 지정 요건 등을 규정하고 있는바, 국토계획법령에서는 일정한 요건을 갖춘 민간사업자에 한정하여 국토교통부장관 등의 지정을 받아 예외적으로 도시·군계획시설사업의 시행자가 될 수 있도록 규정하고 있을 뿐, 사업시행대상지역 전체가 아닌 일부 지역에 대해 민간사업자를 사업시행자로 지정할 수 있는지에 대해서는 규정하고 있지 않습니다.

그런데 국토계획법에 따르면 도시·군계획시설사업은 도시 형성이나 주민 생활에 필수적인 기반시설 중 도시·군관리계획으로 체계적인 배치가 결정된 시설을 설치·정비 또는 개량하는 사업(제2조제6호·제7호 및 제10호)으로서 공공복리의 실현과 밀접한 관련이 있는 공공성이 인정되는 사업이고, 민간사업자 등이 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정받으려는 경우 토지 소유의 요건(제86조제7항) 등을 정하고 있는 취지는 사인(私人)이 시행하는 도시·군계획시설사업의 공공성을 보완하려는 것으로서⁶⁾, 이러한 토지 소유의 요건 등을 갖춘 민간사업자가 사업시행자로 지정받게 되면 해당 사업에 필요한 경우 토지 등을 수용하거나 사용할 수 있는 권한을 부여(제95조)하고 있는데⁷⁾, 만약 사업시행대상지역을 분할하여 그 일부 지역에 대해 민간사업자를 사업시행자로 지정할 수 있다고 본다면 토지 소유 요건이 완화되어 적용되는 결과를 초래할 수도 있는바, 이는 민간사업자를 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정하기 위해서는 일정 면적 이상의 토지를 소유해야 하는 등 지정 요건을 갖추도록 하고 있는 국토계획법령의 취지에 부합하지 않는다고 할 것입니다.

4) 법제처 2022. 6. 10. 회신 21-0759 해석례 참조

5) 국공유지는 제외함

6) 대법원 2017. 7. 11. 선고 2016두35120 판결례 참조

7) 법제처 2021. 10. 20. 회신 21-0591 해석례 참조

그리고 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데⁸⁾, 국토계획법 제86조에서는 도시·군계획시설사업은 원칙적으로 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수 등 행정청이 시행하도록 하면서, 도시·군계획시설사업의 공공성을 고려하여 일정한 요건⁹⁾을 갖춘 민간사업자의 경우 예외적으로 행정청의 지정을 받아 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있도록 규정하고 있는바, 국토계획법령에서 예외적으로 허용하고 있는 민간사업자의 사업시행자 지정을 통한 도시·군계획시설사업 시행에 관한 규정을 명문의 규정 없이 사업시행대상지역을 분할하여 일부 지역에 대해서 민간사업자를 사업시행자로 지정할 수 있다고 확대해석하는 것은, 도시·군계획시설사업의 공공성과 체계적 추진이 필요하다는 점을 고려하면 타당하지 않다고 할 것입니다.

아울러 만약 사업시행대상지역의 전체가 아닌 분할된 일부 지역에 대해서 민간사업자를 사업시행자로 지정할 수 있다고 본다면, 사업시행대상지역별로 도시·군계획시설사업의 진행 속도나 완성도 등에 차이가 발생할 수 있고, 분할된 일정 지역의 사업이 장기간 진행되지 않는 경우 전체 도시·군계획시설사업이 장기화되는 등 안정적인 도시·군계획시설의 설치 등을 담보할 수 없게 되어, 도시의 효율적이고 체계적인 관리를 도모하고자 하는 도시·군계획시설사업의 취지에 부합하지 않게 될 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

한편 국토계획법 제87조에서는 도시·군계획시설사업의 시행자는 도시·군계획시설사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정되면 사업시행대상지역 또는 대상시설을 둘 이상으로 분할하여 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다고 규정하고 있어, 사업시행대상지역 전체가 아닌 일부 지역에 대해서도 민간사업자를 사업시행자로 지정할 수 있다는 의견이 있으나, 국토계획법 제87조는 같은 법 제86조제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 이미 도시·군계획시설사업의 시행자의 지위를 가진 행정청 또는 민간사업자가 사업의 효율적 추진을 위하여 필요한 경우 사업을 분할하여 시행할 수 있다는 것으로서, 이 사안과 같이 사업시행대상지역의 일부 지역에 대한 사업시행자를 지정하려는 경우와는 다르다고 할 것인바, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

8) 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조

9) 국토계획법 제86조제7항 및 같은 법 시행령 제96조제2항 등 참조

따라서 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 국토계획법 제86조제5항에 따라 사업시행대상지역 전체가 아닌 일부 지역에 대해서는 민간사업자를 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정할 수 없습니다.

법령정비 권고사항

국토계획법 제86조제5항에 따라 사업시행대상지역 전체가 아닌 일부 지역에 대하여 민간사업자를 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정할 수 있는지 여부를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제86조(도시·군계획시설사업의 시행자) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 관할 구역의 도시·군계획시설사업을 시행한다.

② 도시·군계획시설사업이 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역에 걸쳐 시행되게 되는 경우에는 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 서로 협의하여 시행자를 정한다.

③ 제2항에 따른 협의가 성립되지 아니하는 경우 도시·군계획시설사업을 시행하려는 구역이 같은 도의 관할 구역에 속하는 경우에는 관할 도지사가 시행자를 지정하고, 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸치는 경우에는 국토교통부장관이 시행자를 지정한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 국토교통부장관은 국가계획과 관련되거나 그 밖에 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있으며, 도지사는 광역도시계획과 관련되거나 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 시행자가 될 수 있는 자 외의 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수로부터 시행자로 지정을 받아 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.

⑥·⑦ (생략)

제87조(도시·군계획시설사업의 분할 시행) 도시·군계획시설사업의 시행자는 도시·군계획시설사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정되면 사업시행대상지역 또는 대상시설을 둘 이상으로 분할하여 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.

질의제목 5

▶ 안전번호 24-0904

민원인 - 방화구획의 설치기준이 되는 바닥면적의 산정 기준(「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조제1항 관련)

01 질의요지

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」(이하 “건축물방화구조규칙”이라 함) 제14조제1항에서는 건축물¹⁾에 설치하는 방화구획(防火區劃)²⁾은 같은 항 각 호의 기준에 적합해야 한다고 규정하면서, 같은 항제1호에서는 “10층 이하의 층은 바닥면적³⁾ 1천제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 바닥면적 3천제곱미터)이내마다 구획할 것”을 규정하고 있고, 같은 항 제2호 본문에서는 “매층마다 구획할 것”을 규정하고 있는바,

건축물방화구조규칙 제14조제1항제1호에 따라 10층 이하의 층의 방화구획 설치의 기준이 되는 바닥면적은 “각 층별 바닥면적”을 의미하는지, 아니면 “10층 이하의 층의 바닥면적을 모두 합한 면적”을 의미하는지?

02 회답

건축물방화구조규칙 제14조제1항제1호에 따라 10층 이하의 층의 방화구획 설치의 기준이 되는 바닥면적은 “각 층별 바닥면적”을 의미합니다.

- 1) 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 1천 제곱미터를 넘는 것을 말하며(「건축법 시행령」 제46조제1항 참조), 이하 같음
- 2) 내화구조로 된 바닥 및 벽, 「건축법 시행령」 제64조제1항제1호·제2호에 따른 방화문 또는 자동방화셔터(국토교통부장관이 정하는 기준에 적합한 자동방화셔터를 포함함)로 구획하는 것을 말하며(「건축법 시행령」 제46조제1항 참조), 이하 같음
- 3) 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적을 의미하며(「건축법 시행령」 제119조제1항제3호 참조), 이하 같음.

03 이유

먼저 건축물방화구조규칙 제14조제1항에서는 방화구획의 설치기준을 정하면서, 같은 항 제1호에서는 10층 이하의 층은 “바닥면적 1천제곱미터⁴⁾ 이내마다” 구획하도록 하고, 같은 항 제2호에서는 “매층마다” 구획하도록 규정하고 있으며, 같은 항 제3호에서는 11층 이상의 층은 “바닥면적 200제곱미터⁵⁾ 이내마다” 구획하도록 규정하고 있는데, 이러한 규정 체계에 따르면 건축물에 설치하는 방화구획은 매층마다 구획하되, 각 층마다 해당 층의 내부를 다시 바닥면적에 따라 나누어 구획하도록 한 것으로, 10층 초과 여부를 기준으로 하여 10층 이하의 층은 같은 항 제1호 및 제2호가 함께 적용되고, 11층 이상의 층은 같은 항 제2호 및 제3호가 함께 적용되어, 이 사안과 같이 10층 이하의 층에 대해서는 같은 항 제2호에 따라 각 층마다 방화구획을 설치하되, 각 층의 바닥면적이 1천제곱미터⁶⁾를 넘는 경우에는 같은 항 제1호에 따라 각 층의 내부를 다시 바닥면적에 따라 나누어 방화구획을 설치해야 할 것입니다.

그리고 건축법령 및 그 위임에 따라 마련된 건축물방화구조규칙에서 일정 규모 및 용도의 건축물에 내화구조로 된 바닥 및 벽 등으로 방화구획을 설치하도록 한 취지는 방화구획을 설치함으로써 건축물 내부에 화재로 인한 화염 및 연기의 확산을 방지하기 위한 것으로⁷⁾, 건축물방화구조규칙 제14조제1항에서는 10층 이하의 층은 바닥면적 1천제곱미터 이내마다(제1호), 11층 이상의 층은 바닥면적 200제곱미터 이내마다(제3호) 각각 방화구획을 설치하도록 규정하면서, 스프링클러 기타 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 10층 이하의 층은 바닥면적 3천제곱미터, 11층 이상의 층은 바닥면적 600제곱미터 이내마다 구획하도록 규정하여 방화구획을 설치하여야 하는 바닥면적의 기준을 3배까지 완화하고 있는데, 자동식 소화설비를 설치한 경우 같은 층 내에서는 해당 소화설비의 기능이 미칠 수 있는 점을 고려하면, 같은 규칙 제14조제1항제1호 및 제3호에서는 자동식 소화설비를 설치한 경우 “같은 층의 바닥면적 기준”을 완화한 것으로 볼 수 있는바, 이러한 제14조제1항의 취지 및 체계에 비추어보면, 같은 항 제1호에서 규정하고 있는 바닥면적 기준은 “각 층의 바닥면적”을 의미한다고 해석하는 것이 타당하다고 할 것입니다.

따라서 건축물방화구조규칙 제14조제1항제1호에 따라 10층 이하의 층의 방화구획 설치의 기준이 되는 바닥면적은 “각 층별 바닥면적”을 의미합니다

4) 스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 바닥면적 3천제곱미터

5) 스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 600제곱미터

6) 스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 바닥면적 3천제곱미터

7) 2019. 8. 6. 국토교통부령 제641호로 일부개정된 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 개정이유 참조



관계법령

건축법

제49조(건축물의 피난시설 및 용도제한 등) ① (생 략)

② 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물의 안전·위생 및 방화(防火) 등을 위하여 필요한 용도 및 구조의 제한, 방화구획(防火區劃), 화장실의 구조, 계단·출입구, 거실의 반자 높이, 거실의 채광·환기, 배연설비와 바닥의 방습 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. 다만, 대규모 창고시설 등 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물에 대해서는 방화구획 등 화재 안전에 필요한 사항을 국토교통부령으로 별도로 정할 수 있다.

③ ~ ⑤ (생 략)

건축법 시행령

제46조(방화구획 등의 설치) ① 법 제49조제2항 본문에 따라 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 1천 제곱미터를 넘는 것은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 다음 각 호의 구조물로 구획(이하 “방화구획”이라 한다)을 해야 한다. 다만, 「원자력안전법」 제2조제8호 및 제10호에 따른 원자로 및 관계시설은 같은 법에서 정하는 바에 따른다.

1. 내화구조로 된 바닥 및 벽
2. 제64조제1항제1호·제2호에 따른 방화문 또는 자동방화셔터(국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)

② ~ ⑦ (생 략)

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙

제14조(방화구획의 설치기준) ① 영 제46조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 건축물에 설치하는 방화구획은 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 10층 이하의 층은 바닥면적 1천제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 바닥면적 3천제곱미터)이내마다 구획할 것
2. 매층마다 구획할 것. 다만, 지하 1층에서 지상으로 직접 연결하는 경사로 부위는 제외한다.
3. 11층 이상의 층은 바닥면적 200제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 600제곱미터)이내마다 구획할 것. 다만, 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 바닥면적 500제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 1천500제곱미터)이내마다 구획하여야 한다.

4. (생 략)

② ~ ⑥ (생 략)

질의제목 6

▶ 안전번호 24-0906

민원인 - 건축사사무소개설자가 건축사사무소 개설신고를 한 사무소 외에 다른 사무소를 두어 영업활동을 할 수 있는지(「건축사법」 제23조제7항 등 관련)

01 질의요지

「건축사법」 제23조제1항에서는 같은 법 제18조에 따른 자격등록을 한 건축사가 건축사업을 하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사¹⁾에게 건축사사무소의 개설신고(이하 “건축사사무소개설신고”라고 함)를 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제7항에서는 건축사사무소개설자²⁾는 1개의 사무소만 설치할 수 있다고 규정하고 있는바,

건축사사무소개설자가 건축사사무소 개설신고를 한 사무소 외에 다른 사무소를 두어 영업활동³⁾을 할 수 있는지?

02 회답

건축사사무소개설자는 건축사사무소 개설신고를 한 사무소 외에 다른 사무소를 두어 영업활동을 할 수 없습니다.

03 이유

먼저 「건축사법」 제23조제1항에서는 자격등록을 한 건축사가 건축사업을 하려면 시·도지사에게 건축사사무소의 개설신고를 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제7항에서는 건축사사무소개설자는 1개의 사무소만 설치할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 제24조제5호에서는 둘 이상의 건축사사무소를 개설하려는 사람은 건축사사무소 개설신고를

1) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사를 말하며(「건축사법」 제17조 참조), 이하 같음

2) 건축사사무소개설신고를 한 건축사를 말하며(「건축사법」 제23조제4항 전단), 이하 같음

3) 설계 또는 공사감리의 용역계약 체결 등 영업행위가 독자적으로 이루어지는 경우임을 전제함

할 수 없다고 규정하고 있는바, 「건축사법」에서는 개설신고 대상 또는 설치 대상 사무소의 수를 하나로 제한하고 있는 것이 문언상 명확합니다.

그리고 건축사법령에서 건축사사무소개설자의 사무소의 수를 하나로 제한하고 있는 취지는 건축사사무소개설자가 「건축사법」 제19조에 따른 업무를 직접 수행할 수 있는 장소적 범위에서 사무소 설치를 허용하여 건축사가 아닌 자에 의하여 건축사사무소가 관리되는 것을 사무소 설치단계에서 방지함으로써 해당 지역에서 충실하게 건축사사무소가 운영될 수 있게 하려는 것으로 볼 수 있고⁴⁾, 이에 따라 「건축사법」 제23조제7항을 위반한 경우에는 건축사사무소개설신고의 효력상실처분 또는 1년 이내의 업무정지(제28조제1항제6호)를 명할 수 있으며, 건축사를 징계할 수 있다고(제30조의3제1항제8호) 규정하는 등 건축사사무소개설자가 1개의 사무소만 설치하도록 엄격히 관리하고 있는데, 현행 법령에 분사무소 등의 설치근거나 기준에 관하여 규정하고 있지 않음에도 불구하고 건축사사무소개설자가 신고한 사무소 외에 다른 사무소를 두어 영업활동을 할 수 있다고 해석하는 것은, 건축사사무소가 건축사사무소개설자에 의해 충실하게 운영되도록 하기 위하여 「건축사법」 제23조제7항을 규정한 취지에 비추어 타당하지 않습니다.

따라서 건축사사무소개설자는 건축사사무소 개설신고를 한 사무소 외에 다른 사무소를 두어 영업활동을 할 수 없습니다.



관계법령

건축사법

제23조(건축사사무소개설신고 등) ① 제18조에 따른 자격등록을 한 건축사가 건축사업을 하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 건축사사무소의 개설신고(이하 “건축사사무소개설신고”라 한다)를 하여야 한다.

②·③ (생략)

④ 건축사사무소에는 건축사사무소개설신고를 한 건축사(이하 “건축사사무소개설자”라 한다)의 업무를 보조하는 소속 건축사, 건축사보 및 실무수련자(제13조에 따른 실무수련을 받고 있는 사람을 말한다. 이하 같다)를 둘 수 있다. 이 경우 소속 건축사는 제18조에 따른 자격등록을 한 사람이어야 하고, 건축사사무소개설자는 소속 건축사가 아닌 사람으로 하여금 건축사업무를 보조하게 하여서는 아니 된다.

⑤·⑥ (생략)

4) 법제처 2020. 12. 30. 회신 20-0615 해석례, 서울행정법원 2024. 11. 29. 선고 2024구합58739 판결례 참조

⑦ 건축사사무소개설자는 1개의 사무소만 설치할 수 있고, 건축사, 건축사보 및 실무수련자는 1개의 건축사사무소에만 소속될 수 있다.

⑧ 건축사사무소개설신고의 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑨·⑩ (생략)

질의제목 7

▶ 안전번호 24-0931, 24-0996, 24-0997, 24-0998

부산광역시 북구·민원인 - 사업시행구역의 면적 증가를 위한 조합설립변경인가 또는 조합설립변경신고 시 「도시 및 주거환경정비법」 제35조제3항 또는 제4항에 따른 조합설립 동의를 충족해야 하는지(「도시 및 주거환경정비법」 제35조제5항 등 관련)

01 질의요지

「도시 및 주거환경정비법」(이하 “도시정비법”이라 함) 제35조제3항에서는 재건축사업의 추진위원회가 조합을 설립하려는 때에는 주택단지의 공동주택의 각 동별 구분소유자의 과반수 동의와 주택단지의 전체 구분소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 4분의 3 이상의 토지소유자의 동의를 받아 같은 조 제2항 각 호의 사항을 첨부하여 시장·군수등¹⁾의 인가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 같은 조 제3항에도 불구하고 주택단지가 아닌 지역이 정비구역에 포함된 때에는 주택단지가 아닌 지역의 토지 또는 건축물 소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다고 규정하고 있는 한편,

도시정비법 제35조제5항에서는 같은 조 제3항에 따라 설립된 조합이 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에는 총회에서 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하고, 같은 조 제2항 각 호의 사항을 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다고 규정하면서(본문), 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 때에는 총회의 의결 없이 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있다고 규정하고 있으며(단서), 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제31조제8호 본문에서는 “대통령령으로 정하는 경미한 사항”의 하나로 같은 법 제16조에 따른 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 변경되어야 하는 사항을 규정하면서, 같은 호 단서에서는 정비구역 면적이 10퍼센트 이상의 범위에서 변경되는 경우는 제외한다고 규정하고 있는바,

가. 도시정비법 제16조에 따라 정비구역 면적이 10퍼센트 이상의 범위에서 확대지정되어 같은 법 제35조제3항에 따라 설립된 재건축사업 조합이 사업시행구역의 면적을 증가시키는 내용으로 같은 법 제35조제5항 본문에 따라 조합설립변경인가를 받으려는

1) 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 자치구의 구청장을 말하며(도시정비법 제2조제2호나목 참조), 이하 같음

경우, 같은 조 제5항 본문에 따라 총회에서 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하기만 하면 되는지, 아니면 같은 조 제3항 및 제4항에 따른 토지등소유자의 조합설립 동의율도 충족해야 하는지?

나. 도시정비법 제16조에 따라 정비구역 면적이 10퍼센트 미만의 범위에서 확대지정되어 같은 법 제35조제3항에 따라 설립된 재건축사업 조합이 사업시행구역의 면적을 증가시키는 내용으로 같은 법 제35조제5항 단서에 따라 조합설립변경신고를 하려는 경우, 같은 조 제5항 단서에 따라 신고하기만 하면 되는지, 아니면 같은 조 제3항 및 제4항에 따른 토지등소유자의 조합설립 동의율도 충족해야 하는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

이 사안의 조합설립변경인가의 경우, 도시정비법 제35조제3항 및 제4항에 따른 토지등소유자의 조합설립 동의율도 충족해야 합니다.

나. 질의 나에 대해

이 사안의 조합설립변경신고의 경우, 도시정비법 제35조제3항 및 제4항에 따른 토지등소유자의 조합설립 동의율도 충족해야 합니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

먼저 도시정비법 제2조제9호나목에서는 재건축사업의 “토지등소유자”를 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자로 규정하고 있고, 같은 조 제1호에서는 “정비구역”을 정비사업을 계획적으로 시행하기 위하여 같은 법 제16조에 따라 지정·고시된 구역을 말한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제35조제1항 본문에서는 시장·군수등, 토지주택공사등 또는 지정개발자가 아닌 자가 정비사업을 시행하려는 경우에는 “토지등소유자로 구성된 조합”을 설립하여야 한다고 규정하고 있는바, 도시정비법령에 따르면 지정·고시된 정비구역 안에

위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자인 토지등소유자의 동의로 조합이 설립되는 것이므로, 지정된 정비구역의 범위와 조합은 서로 불가분의 관계를 가지는 것으로 보이는바²⁾, 이 사안과 같이 정비구역이 확대지정되어 같은 법 제35조제3항에 따라 설립된 재건축사업의 조합이 인가받은 사항 중 사업시행구역의 면적을 증가시키려는 경우에는 일반적으로 사업시행구역에 새로 편입되는 토지 등을 소유하고 있는 새로운 토지등소유자가 발생하여 토지등소유자의 수가 증가하게 되고, 사업시행을 위한 조합은 사업시행구역 전체를 대상으로 하여 설립하여야 하므로, 사업시행구역의 면적이 증가하는 경우에 그 사업시행을 위한 조합은 기존 사업시행구역의 토지등소유자 뿐만 아니라 새로 편입되는 사업시행구역의 토지등소유자로 구성해야 할 것입니다.

그런데 사업시행구역의 면적 증가에 따라 새로 편입되는 사업시행구역의 토지등소유자는 조합설립변경인가 전에는 해당 사업시행을 위한 조합의 조합원이 아니므로, 도시정비법 제35조제5항에 따른 조합설립변경인가 요건인 조합 총회에서의 조합원의 3분의 2 이상의 찬성 의결에 참여할 수 없어 조합설립변경인가 동의 여부에 관한 의사를 반영할 수 없는데³⁾, 만약 조합원인 기존 토지등소유자의 의사만으로 편입되는 사업시행구역에 관한 의사결정을 한다면 편입되는 사업시행구역 토지등소유자의 의사를 반영하지 못한 채 재산권이 제한되는 결과를 초래할 수 있는바, 재건축사업의 추진에 관한 의사결정 과정에 기존 토지등소유자와 편입되는 토지등소유자의 의사를 함께 반영하기 위해서는 사업시행구역의 면적을 증가시키는 조합설립변경인가 시 같은 법 제35조제3항 및 제4항에 따른 토지등소유자의 조합설립 동의율을 충족해야 한다고 보아야 합니다⁴⁾.

또한 조합설립인가 및 조합설립변경인가의 신청서 서식을 규정하고 있는 도시정비법 시행규칙 제8조제1항 및 별지 제5호서식에 따르면 조합설립변경인가를 받으려는 경우에도 그 신청서에 “토지등소유자 수 및 동의율”을 기재하도록 규정하고 있는데, 이는 도시정비법 제35조제3항에 따라 조합설립인가를 받은 이후 사업시행구역 면적 변경으로 토지등소유자의 수가 변경되는 경우에는 토지등소유자의 조합설립에 대한 동의율이 변경될 수 있다는 점을 고려하여, 전체 사업시행구역에 대해서도 기존에 설립된 조합의 지위를 유지할 수 있는지 여부를 판단하기 위한 것으로 보아야 할 것인바⁵⁾, 같은 조 제3항에 따라 설립된 조합이 사업시행구역의 면적을 증가시키는 변경인가를 받고자 하는 때에는 조합 총회에서의

2) 법제처 2013. 12. 16. 회신 13-0559 해석례 참조

3) 법제처 2023. 11. 3. 회신 23-0769 해석례 참조

4) 법제처 2023. 11. 3. 회신 23-0769 해석례 참조

5) 법제처 2023. 11. 3. 회신 23-0769 해석례 참조

조합원의 3분의 2 이상의 찬성 의결뿐만 아니라 같은 조 제3항 및 제4항에 따른 조합설립 동의율을 갖추어야 한다고 보는 것이 타당합니다.

아울러 도시정비법 제35조제3항에 따라 설립된 재건축사업 조합이 사업시행구역 면적을 증가하는 내용으로 조합설립변경인가를 받으려는 경우, 기존 사업시행구역에 설립된 조합의 조합원 총회 의결 요건만 갖추면 되고, 같은 조 제3항 및 제4항에 따른 조합설립 동의율은 갖추지 않아도 되는 것으로 본다면, 소규모의 면적만으로 최초의 사업시행구역을 설정하여 조합설립인가를 받은 후 변경인가를 통해 점진적으로 사업시행구역의 면적을 증가할 수 있게 되어, 만약 당초부터 증가된 면적을 포함한 사업시행구역 전체를 대상으로 조합설립인가 신청을 하였더라면 갖추었어야 하는 조합설립 동의율을 회피할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 조합설립변경인가의 경우, 도시정비법 제35조제3항 및 제4항에 따른 토지등소유자의 조합설립 동의율도 충족해야 합니다.

나. 질의 내에 대해

먼저 도시정비법령에서 조합설립변경인가사항과 조합설립변경신고사항을 구분하는 이유는 변경 대상의 중요도에 따라 처분의 형식을 달리하려는 것인데⁶⁾, 이 사안과 같이 정비구역이 확대지정되어 도시정비법 제35조제3항에 따라 설립된 재건축사업의 조합이 인가받은 사항 중 사업시행구역 면적을 증가시키려는 경우에는 일반적으로 해당 사업시행 구역에 새로 편입되는 토지 등을 소유하고 있는 새로운 토지등소유자가 발생하여 토지등 소유자의 수가 증가하게 되고, 정비구역 면적이 10퍼센트 미만의 범위에서 증가하는 경우도 정비구역의 면적 증가에 따라 토지등소유자의 수가 증가할 수 있다는 점은 동일하므로, 정비구역 면적이 10퍼센트 미만의 범위에서 변경되어 조합설립변경신고를 하는 경우에 토지등소유자의 조합설립동의율을 갖추어야 하는지 여부는 정비구역 면적이 10퍼센트 이상의 범위에서 변경되어 조합설립변경인가를 신청하는 경우와 동일하게 판단해야 할 것입니다.

그렇다면 사업시행을 위한 조합은 사업시행구역 전체를 대상으로 하여 설립하여야 하므로, 이 사안과 같이 정비구역 면적이 10퍼센트 미만으로 증가하더라도 사업시행구역의 면적이 증가하는 경우에 그 사업시행을 위한 조합은 기존 사업시행구역의 토지등소유자 뿐만 아니라

6) 대법원 2014. 5. 29. 선고 2011두33051 판결례 참조

새로 편입되는 사업시행구역의 토지등소유자로 구성해야 할 것이고, 만약 조합원인 기존 토지등소유자의 의사만으로 편입되는 사업시행구역에 관한 의사결정을 한다면 편입되는 사업시행구역 토지등소유자의 의사를 반영하지 못한 채 재산권이 제한되는 결과를 초래할 수 있는바, 재건축사업의 추진에 관한 의사결정 과정에 기존 토지등소유자와 편입되는 토지등소유자의 의사를 함께 반영하기 위해서는 사업시행구역의 면적을 증가시키는 조합설립변경신고 시 같은 법 제35조제3항 및 제4항에 따른 토지등소유자의 조합설립 동의율을 충족해야 한다고 보아야 합니다.⁷⁾

아울러 도시정비법 제35조제3항에 따라 설립된 재건축사업 조합이 사업시행구역 면적을 증가하는 내용으로 조합설립변경신고를 하려는 경우, 같은 조 제3항 및 제4항에 따른 조합설립 동의율은 갖추지 않아도 되는 것으로 본다면, 소규모의 면적만으로 최초의 사업시행구역을 설정하여 조합설립인가를 받은 후 변경신고를 통해 점진적으로 사업시행구역의 면적을 증가할 수 있게 되어, 만약 당초부터 증가된 면적을 포함한 사업시행구역 전체를 대상으로 조합설립인가 신청을 하였더라면 갖추었어야 하는 조합설립 동의율을 회피할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 조합설립변경신고의 경우, 도시정비법 제35조제3항 및 제4항에 따른 토지등소유자의 조합설립 동의율도 충족해야 합니다.

법령정비 권고의견

「도시 및 주거환경정비법」 제35조에 따라 설립된 조합이 인가받은 사항을 변경하려는 내용이 사업시행구역의 면적 증가인 경우, 전체 사업시행구역을 대상으로 같은 조 제3항 및 제4항에 따른 조합설립 동의율을 갖추어야 하는지 여부를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

7) 법제처 2023. 11. 3. 회신 23-0769 해석례 참조

**도시 및 주거환경정비법**

제35조(조합설립인가 등) ① (생략)

② 재개발사업의 추진위원회(제31조제4항에 따라 추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아 다음 각 호의 사항을 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

1. 정관
2. 정비사업비와 관련된 자료 등 국토교통부령으로 정하는 서류
3. 그 밖에 시·도조례로 정하는 서류

③ 재건축사업의 추진위원회(제31조제4항에 따라 추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려는 때에는 주택단지의 공동주택의 각 동(복리시설의 경우에는 주택단지의 복리시설 전체를 하나의 동으로 본다)별 구분소유자의 과반수 동의(공동주택의 각 동별 구분소유자가 5 이하인 경우는 제외한다)와 주택단지의 전체 구분소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 4분의 3 이상의 토지소유자의 동의를 받아 제2항 각 호의 사항을 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

④ 제3항에도 불구하고 주택단지가 아닌 지역이 정비구역에 포함된 때에는 주택단지가 아닌 지역의 토지 또는 건축물 소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.

⑤ 제2항 및 제3항에 따라 설립된 조합이 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에는 총회에서 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하고, 제2항 각 호의 사항을 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 때에는 총회의 의결 없이 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있다.

⑥ ~ ⑩ (생략)

질의제목 8

▶ 안전번호 24-0942

전라남도 여수시 - 도시개발사업에 따라 조성된 주차장 부지가 무상귀속 대상인 공공시설인지(「도시개발법」 제66조제1항 등)

01 질의요지

「도시개발법」 제2조제2항에서는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 함)에서 사용하는 용어는 「도시개발법」으로 특별히 정하는 경우 외에는 같은 법에서 이를 적용한다고 규정하여 「도시개발법」의 경우 국토계획법상의 정의 규정을 따르도록 하고 있고, 국토계획법 제2조제13호에서는 “공공시설”이란 도로·공원·철도·수도, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공용 시설을 말한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제4조제2호에서는 “행정청이 설치하는 시설로서 주차장”을 공공시설 중 하나로 규정하고 있고,

「도시개발법」 제66조제1항에서는 같은 법 제11조제1항제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 도시개발사업의 시행자가 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」 등에도 불구하고 종전의 공공시설은 시행자에게 무상으로 귀속되고, 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 행정청(이하 “관리청”이라 함)에 무상으로 귀속된다고 규정하고 있는바,

도시개발사업에 따라 조성된 주차장 부지¹⁾(이하 “이 사안 주차장 부지”라 함)가 「도시개발법」 제66조제1항에 따라 관리청에 무상으로 귀속되는 새로 설치된 공공시설에 해당하는지?²⁾

02 회답

이 사안 주차장 부지는 「도시개발법」 제66조제1항에 따라 관리청에 무상으로 귀속되는 새로 설치된 공공시설에 해당하지 않습니다.

- 1) 도시개발사업의 실시계획에 주차장 부지 조성에 관한 사항만 규율되어 있을 뿐, 이후 주차장 설치에 관한 사항은 포함하고 있지 않음을 전제함.
- 2) 지방자치단체가 다른 법령이나 계약에 따라 주차장 부지를 매입하거나 기부채납받는 것은 별론으로 하고, 이 사안에서는 주차장 부지만 조성된 경우 그 주차장 부지가 도시개발법 제66조에 따라 무상귀속되는 공공시설에 해당하는지 여부에 대해서만 해석함

03 이유

먼저 이 사안 주차장 부지가 「도시개발법」 제66조제1항에 따라 관리청에 무상으로 귀속되는 공공시설에 해당하기 위해서는 그 자체로 공공시설 중 하나인 주차장에 해당해야 하는데, 「도시개발법」 및 국토계획법에서는 주차장에 관하여 별도의 정의 규정을 두고 있지 않은바, 이러한 경우 법령의 전반적인 체계나 관련 법령 등을 종합적으로 고려하여 “주차장”의 의미를 해석하여야 할 것³⁾입니다.

그런데 주차장에 관한 일반적인 사항을 규정하고 있는 「주차장법」 제2조제1호 각 목 외의 부분에서는 주차장을 자동차의 주차를 위한 시설로 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙에서는 노외주차장⁴⁾의 경우 일정한 기준에 맞는 차로를 설치(제6조제1항제3호)하도록 하며, 너비 3.5미터 이상의 출입구를 설치(제6조제1항제4호)하도록 하는 등 주차장의 설치기준 및 구조·설비 기준을 주차장의 종류에 따라 구체적으로 규율⁵⁾하고 있는데, 이를 종합하여 보면 “주차장”이란 주차를 위한 시설로서 일정한 부지에 일반의 이용에 제공하기 위하여 일정한 기준에 맞는 설비 등이 갖추어진 장소를 의미하는 것인바, 이 사안 주차장 부지는 주차장의 설치를 위한 장소에 불과하고 주차장으로서 기능할 수 있는 설비 등을 갖춘 상태는 아니므로 그 자체로 주차장이라고 보기는 어렵습니다.

그리고 「도시개발법」 제66조제1항에 따라 관리청에 무상귀속되는 대상은 “설치된 공공시설”이라 할 것인데, 이 사안과 같이 공공시설의 설치가 되지 않은 경우 그 설치가 예정된 부지만이 관리청에 무상귀속된다고 보기 어렵고⁶⁾, 「도시개발법」 제66조제1항과 같은 공공시설의 무상귀속 규정은 도시개발사업으로 공공시설이 설치되면 그 준공검사와 동시에 공공시설을 구성하는 토지와 시설물의 소유권이 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 귀속되도록 하는 것으로⁷⁾, 새로 설치된 공공시설의 소유권 변동의 효과가 개별적인 법률행위를 통해서가 아니라 개발사업의 준공시점에 법률 규정에 의해서 직접 발생하도록 하고 있는바⁸⁾, 이처럼 국민의 권리를 제한할 수 있는 법 규정은 원칙적으로 엄격하게 해석해야

3) 대법원 2010. 6. 24. 선고 2010두3978 판결례 참조

4) 도로의 노면 및 교통광장 외의 장소에 설치된 주차장으로서 일반의 이용에 제공되는 것(「주차장법」 제2조제1호나목)을 말하며, 이하 같음

5) 제4조(노상주차장의 구조·설비기준), 제5조(노외주차장의 설치에 대한 계획기준), 제6조(노외주차장의 구조·설비기준), 제11조(부설주차장의 구조·설비기준), 제16조의2(기계식주차장의 설치기준) 등

6) 대법원 2023. 7. 27. 선고 2019다210307 판결례, 대법원 2020. 11. 26. 선고 2019다209611 판결례 참조

7) 대법원 1999. 4. 15. 선고 96다24897 판결례 등 참조

8) 대법원 2023. 7. 27. 선고 2019다210307 판결례 참조

한다는 점⁹⁾ 등을 고려하면 이 사안 주차장 부지는 같은 항에 따라 관리청에 무상으로 귀속되는 공공시설에 해당한다고 보기 어렵습니다.

한편 도시개발사업 시행자가 주차장 부지만을 조성하는 방식으로 도시개발사업을 수행함으로써 「도시개발법」 제66조제1항에 따라 무상귀속되는 것을 회피할 수 있는 점을 고려하여 이 사안 주차장 부지를 무상으로 귀속되는 공공시설로 보아야 한다는 의견도 있으나, 「도시개발법」 제5조제1항에서는 지정권자¹⁰⁾가 수립하는 도시개발사업의 개발계획에 토지이용계획(제7호), 교통처리계획(제8호), 도로 등 주요 기반시설의 설치계획(제11호) 등을 포함하도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제38조제1항에서는 실시계획은 위 개발계획에 맞게 작성하도록 규정하고 있으며, 도시개발법령의 위임에 따라¹¹⁾ 마련된 도시개발업무지침(국토교통부훈령)에서는 실시계획 인가 신청을 할 때 공공시설물 및 토지의 무상귀속 등에 관한 계획을 함께 제출하도록 규정하고 있고, 「도시개발법」 제17조제2항에서는 도시개발사업의 시행자가 실시계획에 관하여 지정권자의 인가를 받도록 규정하고 있는바, 지정권자는 무상귀속이 되는 공공시설의 종류 및 내용에 대해 사전에 검토하여 인가할 수 있는 점을 고려할 때 이러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안 주차장 부지는 「도시개발법」 제66조제1항에 따라 관리청에 무상으로 귀속되는 새로 설치된 공공시설에 해당하지 않습니다.



관계법령

도시개발법

제17조(실시계획의 작성 및 인가 등) ① 시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 도시개발사업에 관한 실시계획(이하 “실시계획”이라 한다)을 작성하여야 한다. 이 경우 실시계획에는 지구단위계획이 포함되어야 한다.

② 시행자(지정권자가 시행자인 경우는 제외한다)는 제1항에 따라 작성된 실시계획에 관하여 지정권자의 인가를 받아야 한다.

③ ~ ⑤ (생략)

제66조(공공시설의 귀속 등) ① 제11조제1항제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 시행자가 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」과

9) 법제처 2012. 9. 12. 회신 12-0442 해석례 참조

10) 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사 등 「도시개발법」 제3조에 따라 도시개발구역에 지정하는 자를 말하며, 이하 같음.

11) 「도시개발법」 제17조제1항 및 같은 법 시행령 제38조제3항 참조

「공유재산 및 물품 관리법」 등에도 불구하고 종전의 공공시설은 시행자에게 무상으로 귀속되고, 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 행정청(이하 이 조 및 제67조에서 “관리청”이라 한다)에 무상으로 귀속된다.

② ~ ⑦ (생략)

질의제목 9

▶ 안전번호 24-0981

국토교통부 - 공연장 등을 지하층에 설치하는 경우 천장이 개방된 외부 공간을 설치해야 하는 요건이 되는 바닥면적의 합계 산정 시 부속용도의 바닥면적이 포함되는지 여부(「건축법 시행령」 제37조 등 관련)

01 질의요지

「건축법 시행령」 제37조에서는 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 공연장·집회장·관람장 또는 전시장을 지하층에 설치하는 경우에는 각 실에 있는 자가 지하층 각 층에서 건축물 밖으로 피난하여 옥외 계단 또는 경사로 등을 이용하여 피난층으로 대피할 수 있도록 천장이 개방된 외부 공간(이하 “개방공간”이라 함)을 설치하여야 한다고 규정하고 있는바,

「건축법 시행령」 제37조에 따라 개방공간을 설치해야 하는지 여부를 판단할 때, 공연장·집회장·관람장 또는 전시장의 부속용도¹⁾ 바닥면적을 포함하여 “바닥면적의 합계”를 산정해야 하는지?²⁾

02 회답

「건축법 시행령」 제37조에 따라 개방공간을 설치해야 하는지 여부를 판단할 때, 공연장·집회장·관람장 또는 전시장의 부속용도 바닥면적을 포함하여 “바닥면적의 합계”를 산정해야 합니다.

03 이유

먼저 「건축법 시행령」 제37조에서는 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 공연장·집회장·관람장 또는 전시장을 지하층에 설치하는 경우에는 각 실에 있는 자가 지하층 각 층에서

- 1) 건축물의 주된 용도의 기능에 필수적인 용도로서 건축물의 설비, 대피, 위생, 그 밖에 이와 비슷한 시설의 용도, 사무, 작업, 집회, 물품저장, 주차, 그 밖에 이와 비슷한 시설의 용도 등의 용도를 말하며(「건축법 시행령」 제2조제13호), 이하 같음
- 2) 공연장·집회장·관람장 또는 전시장의 부속용도 면적만을 한정할 수 있는 경우를 전제함

건축물 밖으로 피난하여 옥외 계단 또는 경사로 등을 이용하여 피난층으로 대피할 수 있도록 개방공간을 설치하여야 한다고 규정하고 있는데, 「건축법」 제2조제1항제3호에서는 “건축물의 용도”란 건축물의 종류를 유사한 구조, 이용 목적 및 형태별로 묶어 분류한 것을 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 건축물의 세부 용도를 대통령령으로 정하도록 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제3조의5 및 별표 1에서는 건축물의 세부 용도를 규정하면서, 같은 표에서 공연장(제4호가목 및 제5호가목), 집회장(제4호나목, 제5호나목 및 제6호가목), 관람장(제5호다목) 및 전시장(제5호라목)을 각각 건축물의 용도로 규정하고 있는 한편, 같은 영 제2조제13호에서는 “부속용도”를 건축물의 주된 용도의 기능에 필수적인 용도로 정의하고 있어, 부속용도는 주된 용도에 부수되는 개념으로서 별도의 용도를 구성하지 않고 주된 용도를 따르게 된다고 할 것인바³⁾, 이를 종합하여보면 「건축법 시행령」 제37조는 건축물의 세부 용도로서 공연장·집회장·관람장 또는 전시장을 바닥면적 합계가 3천 제곱미터 이상으로 지하층에 설치하는 경우에는 개방공간을 설치하도록 규정하면서, 바닥면적을 산정할 때 주된 용도로만 한정하는 특별한 규정도 없으므로, 개방공간 설치의 요건인 “바닥면적 합계” 산정 시 부속용도의 바닥면적까지 포함하는 의미로 해석하는 것이 건축법령의 규정체계에 부합한다고 할 것입니다.

또한 「건축법」은 건축물의 대지·구조·설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 제49조제1항에서는 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물과 그 대지에는 복도, 계단, 출입구, 그 밖의 피난시설과 저수조(貯水槽), 대지 안의 피난과 소화에 필요한 통로를 설치하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령에서 피난시설 등에 관한 세부적인 사항을 규정하면서, 같은 영 제37조에서는 지하층과 피난층 사이의 개방공간 설치에 대해 구체적으로 규정하고 있는 것인데, 이는 일정 규모 이상의 지하층을 공연장 등의 용도로 사용하는 경우 개방공간을 설치하도록 규정함으로써 건축물을 이용하는 사람 등이 건축물 밖으로 신속하게 이동하여 피난할 수 있도록 안전을 확보하려는 취지인바, 개방공간을 설치해야 하는지를 판단하기 위해 바닥면적의 합계를 산정하는 경우에는 그 부속용도를 포함한 전체 용도의 바닥면적을 기준으로 하여 산정하는 것이 건축물의 안전을 담보하려는 건축법령의 목적 및 해당 조문의 입법 취지에 부합한다고 할 것입니다.

3) 법제처 2021. 11. 18. 회신 21-0640 해석례, 법제처 2018. 6. 21. 회신 18-0197 해석례 참조

따라서 「건축법 시행령」 제37조에 따라 개방공간을 설치해야 하는지 여부를 판단할 때, 공연장·집회장·관람장 또는 전시장의 부속용도 바닥면적을 포함하여 “바닥면적의 합계”를 산정해야 합니다.



관계법령

건축법 시행령

제37조(지하층과 피난층 사이의 개방공간 설치) 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 공연장·집회장·관람장 또는 전시장을 지하층에 설치하는 경우에는 각 실에 있는 자가 지하층 각 층에서 건축물 밖으로 피난하여 옥외 계단 또는 경사로 등을 이용하여 피난층으로 대피할 수 있도록 천장이 개방된 외부 공간을 설치하여야 한다.

질의제목 10

▶ 안전번호 24-0989

민원인 - 「건축법」 제70조제3호에 따라 특별건축구역에서 건축기준 등의 특례사항을 적용하여 건축할 수 있는 건축물의 의미(「건축법」 제70조제3호 등 관련)

01 질의요지

「건축법」 제2조제18호에서는 “특별건축구역”이란 조화롭고 창의적인 건축물의 건축을 통하여 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상 및 건축 관련 제도개선을 도모하기 위하여 이 법 또는 관계 법령에 따라 일부 규정을 적용하지 아니하거나 완화 또는 통합하여 적용할 수 있도록 특별히 지정하는 구역을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제70조 각 호 외의 부분에서는 특별건축구역에서 같은 법 제73조에 따라 건축기준 등의 특례사항을 적용하여 건축할 수 있는 건축물은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어야 한다고 규정하면서, 같은 법 제70조제3호에서는 “그 밖에 대통령령으로 정하는 용도·규모의 건축물로서 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상 및 건축 관련 제도개선을 위하여 특례 적용이 필요하다고 허가권자가 인정하는 건축물”을 규정하고 있는바,

「건축법」 제70조제3호에 따라 특별건축구역에 건축할 수 있는 건축물에 해당하기 위해서는 허가권자가 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상, 건축 관련 제도개선 중 어느 하나를 위하여 특례 적용이 필요하다고 인정하면 되는지, 아니면 허가권자가 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상, 건축 관련 제도개선 모두를 위하여 특례 적용이 필요하다고 인정해야 하는지?

02 회답

「건축법」 제70조제3호에 따라 특별건축구역에 건축할 수 있는 건축물에 해당하기 위해서는 허가권자가 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상, 건축 관련 제도개선 중 어느 하나를 위하여 특례 적용이 필요하다고 인정하면 됩니다.

03 이유

「건축법」 제70조에서는 특별건축구역에서 건축기준 등의 특례사항을 적용하여 건축할 수 있는 건축물을 정하면서, 같은 조 제3호에서는 “그 밖에 대통령령으로 정하는 용도·규모의 건축물로서 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상 및 건축 관련 제도개선을 위하여 특례 적용이 필요하다고 허가권자가 인정하는 건축물”을 규정하고 있는데, 이 때 “및”은 ‘그리고’, ‘그 밖에’, ‘또’의 뜻으로, 문장에서 같은 종류의 성분을 연결할 때 쓰는 말로서¹⁾, “및”이 문장에서 같은 종류의 성분을 연결하는 경우에는 열거된 성분 모두를 공동으로 언급하는 의미뿐만 아니라 단순히 열거된 성분들을 각자 나열하는 의미로 쓰일 수 있는바²⁾, 문장의 전체적인 문맥 및 규정 취지 등을 고려하여 그 의미를 개별적으로 판단할 필요가 있습니다.³⁾

그런데 「건축법」 제2조제18호에서는 “특별건축구역”이란 조화롭고 창의적인 건축물의 건축을 통하여 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상 및 건축 관련 제도개선을 도모하기 위하여 지정하는 구역이라고 정의하고 있고, 이러한 정의규정상 특별건축구역의 목적을 「건축법」 제70조제3호에 따라 특별건축구역에 건축할 수 있는 건축물 규정에 그대로 두고 있는 것으로 보이는데, ① 정의규정상 ‘도시경관의 창출, 건설기술 수준향상 및 건축 관련 제도개선’이라는 문언은 특별건축구역 제도를 통하여 달성하고자 하는 목적을 열거한 것으로 보이는 점, ② 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상, 건축 관련 제도개선이라는 세 가지 목적은 다소 추상적이고, 그 목적이 각각 경관·기술 및 제도라는 서로 관련성이 크지 않은 영역에 대한 것들이어서 반드시 동시에 추구해야 할 사항으로 보기 어려운 점 등을 고려하면 허가권자가 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상, 건축 관련 제도개선 중 어느 하나를 위하여 특례 적용이 필요하다고 인정하는 경우에는 「건축법」 제70조제3호에 따라 특별건축구역에 건축할 수 있는 건축물에 해당한다고 보아야 할 것입니다.

아울러 특별건축구역은 조화롭고 창의적인 건축물의 건축을 통하여 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상 및 건축 관련 제도개선을 도모하기 위하여 도입된 것으로, 「건축법」 제70조제3호에 따라 공공건축물 외에 민간건축물의 경우에도 특별건축구역에 건축할 수 있게 되는데⁴⁾, 만일 그 건축물이 「건축법」 제70조제3호에 해당하기 위해서는 “① 도시경관의 창출, ② 건설기술 수준향상, ③ 건축 관련 제도개선”이라는 목적을 모두 추구해야만 한다고

1) 국립국어원 표준국어대사전 참조

2) 법제처 2016. 3. 7. 회신 15-0867 해석례 등 참조

3) 법제처 2018. 11. 26. 회신 18-0656 해석례 참조

4) 2007. 3. 10. 제176252호로 발의된 건축법 일부개정법률안 국회 건설교통위원회 검토보고서 참조

엄격하게 해석하는 경우 민간에 의한 조화롭고 창의적인 건축물의 건축이 제한될 수 있어 결과적으로 창의적인 건축물의 건축을 통해 도시경관을 조화롭게 하고 미적 수준을 제고하려는 규정의 취지에 어긋날 우려가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「건축법」 제70조제3호에 따라 특별건축구역에 건축할 수 있는 건축물에 해당하기 위해서는 허가권자가 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상, 건축 관련 제도개선 중 어느 하나를 위하여 특례 적용이 필요하다고 인정하면 됩니다.



관계법령

건축법

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 17. (생략)

18. “특별건축구역”이란 조화롭고 창의적인 건축물의 건축을 통하여 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상 및 건축 관련 제도개선을 도모하기 위하여 이 법 또는 관계 법령에 따라 일부 규정을 적용하지 아니하거나 완화 또는 통합하여 적용할 수 있도록 특별히 지정하는 구역을 말한다.

19. ~ 21. (생략)

② (생략)

제70조(특별건축구역의 건축물) 특별건축구역에서 제73조에 따라 건축기준 등의 특례사항을 적용하여 건축할 수 있는 건축물은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어야 한다.

1. 국가 또는 지방자치단체가 건축하는 건축물
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관이 건축하는 건축물
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 용도·규모의 건축물로서 도시경관의 창출, 건설기술 수준향상 및 건축 관련 제도개선을 위하여 특례 적용이 필요하다고 허가권자가 인정하는 건축물

질의제목 11

▶ 안전번호 24-0991

민원인 - 대수선이 「건축법」 제22조제1항에 따른 사용승인 대상인지(「건축법」 제22조제1항 등 관련)

01 질의요지

「건축법」 제22조제1항에서는 건축주가 같은 법 제11조·제14조 또는 제20조제1항에 따라 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료¹⁾한 후 그 건축물을 사용하려면 같은 법 제25조제6항에 따라 공사감리자가 작성한 감리완료보고서²⁾와 국토교통부령으로 정하는 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 한다고 규정하고 있는바,

건축주가 건축물의 대수선을 완료한 후 그 건축물을 사용하려는 경우, 같은 법 제22조제1항에 따라 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 하는지?

02 회답

건축주가 건축물의 대수선을 완료한 후 그 건축물을 사용하려는 경우, 「건축법」 제22조제1항에 따라 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 합니다.

03 이유

「건축법」 제2조제1항제8호에서는 “건축”이란 건축물을 신축·증축·개축·재축(再築)하거나 건축물을 이전하는 것을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제2조제1항제9호에서는 “대수선”이란 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제3조의2에서는 같은 법 제2조제1항제9호에서 “대통령령으로 정하는

1) 하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 동(棟)별 공사를 완료한 경우를 포함함

2) 「건축법」 제25조제1항에 따른 공사감리자를 지정한 경우만 해당됨

것”이란 기둥을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것 등에 해당하는 것으로서 증축·개축 또는 재축에 해당하지 아니하는 것을 말한다고 규정하고 있는바, 이 사안의 경우와 같이 대수선이 「건축법」 제22조제1항에 따른 같은 법 제11조·제14조 또는 제20조제1항에 따라 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 “건축공사”에 해당하여 사용승인 대상인지 여부는 해당 문언 외에도 관계 법령의 일반적인 의미, 대수선의 성격, 사용승인 제도의 취지 등을 종합적으로 고려하여 해석할 필요가 있습니다³⁾.

먼저 「건축법」 제22조제1항에서는 건축주가 “제11조·제14조 또는 제20조제1항에 따라 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사”를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 공사감리자가 작성한 감리완료보고서와 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 한다고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 같은 법 제11조에서는 “건축허가”라는 조 제목 하에 같은 조 제1항 본문에서 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 “시장·군수등”이라 함)의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제14조에서는 “건축신고”라는 조 제목 하에 같은 조 제1항에서 연면적이 200제곱미터 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선(제3호), 주요구조부의 해체가 없는 등 대통령령으로 정하는 대수선(제4호) 등의 경우에는 같은 법 제11조에 해당하는 허가 대상 건축물이라 하더라도 미리 시장·군수등에게 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다고 규정하고 있는바, 이를 종합하면 같은 법 제11조에 따른 건축허가나 같은 법 제14조에 따른 건축신고 대상에는 대수선이 포함되어 있으므로, 같은 법 제22조제1항에 따른 사용승인 대상인 “같은 법 제11조·제14조 또는 제20조제1항에 따라 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사”에는 대수선이 포함된다고 할 것입니다.

또한 「건축법」 제22조제2항에서는 허가권자는 같은 조 제1항에 따른 사용승인신청을 받은 경우 사용승인을 신청한 건축물이 같은 법에 따라 허가 또는 신고한 설계도서대로 시공되었는지의 여부(제1호) 등에 대한 검사를 실시하고, 검사에 합격된 건축물에 대하여 사용승인서를 내주어야 한다고 규정하고 있는바, 이러한 허가권자의 검사 항목에 비추어 보면, 사용승인 대상인 “건축공사”는 건축물의 시공, 즉 공사의 시행과 관련한 행위가 있어야 할 것인데, 같은 법 제2조제1항제9호 및 같은 법 시행령 제3조의2에서는 “대수선”이란 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 것으로서, 건축법령상 대수선을 수행하기 위해서는 건축물의 구조나 외부 형태를 대상으로 하는 시공 행위가 반드시 수반된다는 점에서, 대수선을 같은 법 제22조제1항에 따른 사용승인 대상인

3) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 판결례

“건축공사”에서 제외되는 것으로 보기는 어렵습니다.

그리고 「건축법」 제11조 및 제14조에서 건축물을 대수선하려는 자는 허가권자의 허가를 받거나 미리 신고하도록 규정하고 있는데, 이는 건축법령상 대수선에 해당하는 행위는 건축물의 주요구조부와 밀접한 관련이 있으므로 건축물의 구조안전을 해치지 않는 경우에만 제한적으로 대수선을 허용함으로써 건축물로부터 발생하는 위험을 방지하여⁴⁾ 건축물의 안전을 확보하려는 것이고, 건축물의 사용승인제도는 건축허가를 받거나 건축신고를 하고 공사를 완료한 건축물이 허가 또는 신고한 내용과 같이 건축행정목적에 적합하게 건축되었는지의 여부를 확인하는 것⁵⁾으로서, 건축법령상 대수선이 시공 이전 단계에서 건축허가나 건축신고의 대상에 해당한다면, 시공 이후 단계에서도 허가권자의 검토가 이루어질 수 있도록 대수선을 사용승인 대상으로 보는 것이, 대수선의 성격, 사용승인제도의 취지 및 건축물의 안전을 확보하려는 건축법령의 입법목적에 부합한다고 할 것입니다.

아울러 「건축법 시행규칙」에서는 사용승인을 받으려는 자가 제출해야 하는 사용승인 신청서 서식(별지 제17호서식)을 규정하고 있는데, 해당 서식에서는 ‘대수선 행위에 대한 사용승인을 신청하는 경우’의 작성방법을 규정하고 있고, 허가권자가 사용승인을 위한 검사 실시 후 합격된 건축물에 대하여 발급하는 사용승인서 서식(별지 제18호서식)에서는 ‘건축·대수선 또는 용도변경한 (가설)건축물의 사용승인서를 교부합니다’라고 규정하고 있는바, 사용승인 신청서 및 사용승인서에서는 각각 사용승인 대상으로 ‘대수선 행위’를 명시적으로 기재하고 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 건축주가 건축물의 대수선을 완료한 후 그 건축물을 사용하려는 경우, 「건축법」 제22조제1항에 따라 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 합니다.

4) 대법원 2016. 12. 15. 선고 2015도10671 판결례 참조

5) 대법원 2007. 7. 27. 선고 2005도1722 판결례 참조



관계법령

건축법

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 8의2. (생 략)
9. “대수선”이란 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.
10. ~ 21. (생 략)
- ② (생 략)

제11조(건축허가) ① 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. (단서 생략)

- ② ~ ⑪ (생 략)

제14조(건축신고) ① 제11조에 해당하는 허가 대상 건축물이라 하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

1. ~ 5. (생 략)
- ② ~ ⑤ (생 략)

제22조(건축물의 사용승인) ① 건축주가 제11조·제14조 또는 제20조제1항에 따라 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료[하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 동(棟)별 공사를 완료한 경우를 포함한다]한 후 그 건축물을 사용하려면 제25조제6항에 따라 공사감리자가 작성한 감리완료보고서(같은 조 제1항에 따른 공사감리자를 지정한 경우만 해당된다)와 국토교통부령으로 정하는 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 한다.

- ② 허가권자는 제1항에 따른 사용승인신청을 받은 경우 국토교통부령으로 정하는 기간에 다음 각 호의 사항에 대한 검사를 실시하고, 검사에 합격된 건축물에 대하여는 사용승인서를 내주어야 한다. (단서 생략)

1. 사용승인을 신청한 건축물이 이 법에 따라 허가 또는 신고한 설계도서대로 시공되었는지의 여부
2. 감리완료보고서, 공사완료도서 등의 서류 및 도서가 적합하게 작성되었는지의 여부

- ③ ~ ⑥ (생 략)

질의제목 12

▶ 안전번호 25-0005, 25-0144

민원인 - 도로점용허가를 받은 진입로·출입로 설치의 개발행위허가 대상 여부 등(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제1항제1호 등 관련)

01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 함) 제56조제1항에서는 공작물의 설치(제1호), 토지의 형질 변경(제2호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위(이하 “개발행위”라 함)를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(이하 “시장·군수등”이라 함)의 허가(이하 “개발행위허가”라 함)를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제58조제1항제1호에서는 시장·군수등은 개발행위허가의 신청 내용이 용도지역별 특성을 고려하여 대통령령으로 정하는 개발행위의 규모에 적합한 경우(본문)에 개발행위허가 또는 변경허가를 하여야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제55조제1항에서는 같은 법 제58조제1항제1호 본문에서 “대통령령으로 정하는 개발행위의 규모”란 다음 각 호에 해당하는 토지의 형질변경면적을 말한다고 규정하고 있는 한편,

「도로법」 제61조제1항에서는 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함함)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제55조에서는 도로점용허가를 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류로 전봇대(제1호), 수도관(제2호), 같은 조 제1호부터 제10호까지의 규정에 따른 공작물·물건 및 시설의 설치를 위하여 일시적으로 설치하는 공사장, 그 밖에 이와 유사한 것과 이를 위한 진입로 및 출입로(제11호) 등을 규정하고 있는바,

도시·군계획시설¹⁾ 부지에서 토지의 형질변경이 수반되는 진입로·출입로 및 이에 따른 공작물을 설치²⁾하기 위하여 「도로법」 제61조제1항 및 같은 법 시행령 제55조제11호·제12호에 따른 도로점용허가를 받은 경우³⁾,

1) 국토계획법 제2조제7호에 따른 도시·군계획시설을 말하며, 이하 같음

2) 설치 공사를 마치는 경우 「도로법」 제62조제2항 전단에 따라 도로관리청의 준공확인을 받아야 하는 설치 공사를 전제로 함

가. 해당 진입로·출입로 및 이에 따른 공작물의 설치(이하 “이 사안 진출입로등 설치”라 함)는 국토계획법 제56조제1항제1호·제2호 및 같은 법 시행령 제51조제1항제2호·제3호에 따른 개발행위허가 대상인지⁴⁾?

나. 이 사안 진출입로등 설치를 위하여 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용허가를 받은 면적⁵⁾은 개발행위허가의 기준이 되는 국토계획법 시행령 제55조제1항 본문에 따른 토지의 형질변경면적에 포함되는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

이 사안 진출입로등 설치는 국토계획법 제56조제1항제1호·제2호 및 같은 법 시행령 제51조제1항제2호·제3호에 따른 개발행위허가 대상입니다.

나. 질의 나에 대해

이 사안 진출입로등 설치를 위하여 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용허가를 받은 면적은 개발행위허가의 기준이 되는 국토계획법 시행령 제55조제1항 본문에 따른 토지의 형질변경면적에 포함됩니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

입법목적을 달리하는 법률들이 일정한 행위에 관한 요건을 각각 규정하고 있는 경우에는 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 이상 어떤 행위가 둘 이상의 법률의 요건에 모두 해당한다면 둘 이상의 법률이 모두 적용된다고 할 것입니다.⁶⁾

3) 도로점용허가 부지는 도시·군계획시설 부지에 해당하고, 도시·군계획시설 부지와 연접한 사유지에 건축물을 건축하면서 진입로·출입로 및 이에 따른 공작물을 설치하기 위한 경우로서 도시·군계획시설부지 및 연접한 사유지에서의 공사 주체는 동일하고, 두 부지는 서로 연접한 두 개의 필지인 것을 전제로 함

4) 국토계획법 제56조제1항 단서 및 같은 조 제4항에는 해당하지 않는 것을 전제로 함

5) 이 사안 진출입로등 설치를 위하여 도로점용허가를 받은 면적과 토지의 형질변경이 수반되는 면적이 동일한 것을 전제로 함

먼저 국토계획법 제56조에 따른 개발행위허가제는 이웃 토지와 연접되어 있는 어느 한 토지의 이용이 인접 토지의 이용과 부조화를 발생시킬 수 있고 사적인 개발행위가 도·시군관리계획 등 각종 계획과 상충할 수 있으므로, 이러한 문제점을 사전에 예방하고 계획적 개발을 유도하여 국토를 효율적·합리적으로 이용하고 체계적으로 관리하기 위하여 기반시설의 확보 여부, 주변 환경과의 조화 등을 사전에 검토하여 허가를 받도록 하는 제도⁷⁾인 반면, 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용은 일반공중의 교통에 사용되는 도로에 대하여 이러한 일반사용과는 별도로 도로의 특정부분을 유형적·고정적으로 특정한 목적을 위하여 사용할 수 있도록 한 것인바⁸⁾, 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가제와 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용허가제는 그 입법목적이 다르고, 국토계획법이나 「도로법」에서는 도시·군계획시설부지나 도로구역에서의 개발행위에 관하여 「도로법」에 따른 도로점용허가를 받은 경우에는 국토계획법 제56조제3항과 같이 국토계획법이 아니라 「도로법」을 따르도록 하는 규정을 두고 있지도 않습니다.

그렇다면 이 사안 진출입로등 설치를 위해서는 국토계획법과 「도로법」의 규정에 따른 요건을 모두 갖추어야 한다고 할 것인데, 이 사안 진출입로등 설치에 국토계획법 제56조제1항에 따른 공작물의 설치(제1호) 및 토지의 형질 변경(제2호)에 해당하여 개발행위허가를 받아야 하는 개발행위에 해당하는바, 「도로법」에 따른 도로점용허가 외에도 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가를 별도로 받아야 한다고 할 것입니다.

특히 이 사안과 같이 도시·군계획시설 부지에서의 개발행위의 경우 국토계획법 제64조 제1항에서 시장·군수등은 도시·군계획시설의 설치 장소로 결정된 지상·수상·공중·수중 또는 지하는 그 도시·군계획시설이 아닌 건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허가하여서는 아니된다고 규정하면서(본문), 예외적으로 국토계획법 시행령 제61조 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고(단서), 같은 영 제61조제3호에서는 「도로법」 등 도시·군계획시설의 설치 및 관리에 관하여 규정하고 있는 다른 법률에 의하여 점용허가를 받아 건축물 또는 공작물을 설치하는 경우를 규정하고 있어, 도시·군계획시설 부지에서 다른 법률에 의하여 점용허가를 받아 건축물 또는 공작물을 설치하는 경우에는 개발행위를 허가할 수 있도록 규정하고 있는바, 이 사안 진출입로등 설치와 같이 도시·군계획시설 부지에서 「도로법」상 도로점용허가를 받아 공작물 등을 설치하는 경우는 국토계획법 제64조제1항 단서에 따라 국토계획법상 개발행위에 대한 허가를 받아야 할 것입니다.

6) 대법원 1995. 1. 12. 선고 94누3216 판결례 참조

7) 헌법재판소 2013. 10. 24. 선고 2012헌바241 결정례 및 법제처 2018. 3. 8. 회신 18-0052 해석례 참조

8) 대법원 2002. 10. 25. 선고 2002두5795 판결례 및 법제처 2018. 3. 8. 회신 18-0052 해석례 참조

한편 이 사안 진출입로등 설치를 위한 부지는 도시·군계획시설 부지이자 「도로법」 제2조제6호에 따른 도로구역으로서, 당초의 도로공사 시행 시 「도로법」 제29조제1항제4호에 따라 도로구역을 결정하면 국토계획법에 따른 개발행위의 허가가 의제된 것이므로, 해당 부지에 이 사안 진출입로등 설치를 하는 경우에는 해당 도로구역을 관리하기 위한 「도로법」만 적용되고 별도로 국토계획법에 따른 개발행위허가를 받아야 하는 것은 아니라는 의견이 있으나, 국토계획법이나 「도로법」에서는 도로구역 결정 이후의 개발행위에 대하여 국토계획법의 적용을 배제하는 규정을 두고 있지 않고, 당초의 도로공사 시행 시 국토계획법에 따라 개발행위허가를 받거나 「도로법」 제29조제1항제4호에 따라 도로구역을 결정으로 개발행위허가가 의제되었다 하더라도 이는 해당 도로공사에 한정된다고 할 것이어서, 당초의 도로공사가 있는 후 도로구역에서 이루어지는 이 사안 진출입로등 설치의 이와는 별개의 개발행위라고 할 것인바, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안 진출입로등 설치의 국토계획법 제56조제1항제1호·제2호 및 같은 법 시행령 제51조제1항제2호·제3호에 따른 개발행위허가 대상입니다.

나. 질의 내에 대해

먼저 국토계획법 제58조제1항제1호 본문에서는 시장·군수등은 개발행위허가의 신청 내용이 용도지역별 특성을 고려하여 대통령령으로 정하는 개발행위의 규모에 적합한 경우에만 개발행위허가를 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제55조제1항에서는 같은 법 제58조제1항제1호 본문에서 “대통령령으로 정하는 개발행위의 규모”란 도시지역(제1호), 관리지역(제2호) 등 각 호에 해당하는 토지의 형질변경면적을 말한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제58조제1항제1호 단서에서는 해당 개발행위가 「농어촌정비법」 제2조제4호에 따른 농어촌정비사업으로 이루어지는 경우 등에는 개발행위 규모의 제한을 받지 아니한다고 규정하고 있는데, 국토계획법 제58조제1항제1호 본문 및 같은 법 시행령 제55조제1항에서는 개발행위허가를 할 수 있는 개발행위의 규모 기준으로 토지의 형질변경면적을 규정하고 있고, 국토계획법령에서는 「도로법」에 따른 도로점용허가 부지의 면적을 국토계획법 시행령 제55조제1항에 따른 토지의 형질변경면적에서 제외하는 취지의 규정을 두고 있지도 않은바, 이를 종합해 보면 토지의 형질변경이 이루어지는 면적이라면, 해당 면적에 대하여 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용허가를 받았더라도 국토계획법 시행령 제55조제1항 본문에 따른 토지의 형질변경면적에 포함된다고 할 것입니다.

또한 국토계획법 시행령 제55조제1항 및 제2항에서 개발행위가 허용되는 토지의 형질변경면적을 제한하고 있는 것은 개발행위를 제한하여 자연환경이나 농지 및 산림을

보전하고 무분별한 난개발을 방지하며 국토를 효율적으로 이용·개발·보전하기 위하여 형질변경이 이루어지는 면적을 일정 범위로 제한하려는 취지⁹⁾라고 할 것인데, 토지의 형질변경이 수반되는 이 사안 진출입로등 설치의 국토계획법령에 따라 별도의 개발행위허가를 받아야 하는 행위로서, 이러한 행위가 「도로법」에 따른 도로점용허가를 받은 부지에서 있는 경우에도 자연환경 등을 보전하고 무분별한 난개발을 방지할 필요성에 차이가 있는 것은 아니라고 할 것인바, 이 사안 진출입로등 설치와 같이 토지의 형질변경이 수반되는 개발행위의 경우에는 그 개발행위가 일어나는 도로점용허가 부지 면적도 국토계획법 시행령 제55조제1항에 따른 형질변경면적에 포함된다고 해석하는 것이 해당 규정의 입법취지에 부합하는 해석입니다.

따라서 이 사안 진출입로등 설치를 위하여 「도로법」 제61조제1항에 따른 도로점용허가를 받은 면적은 개발행위허가의 기준이 되는 국토계획법 시행령 제55조제1항 본문에 따른 토지의 형질변경면적에 포함됩니다.



관계법령

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제56조(개발행위의 허가) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위(이하 “개발행위”라 한다)를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가(이하 “개발행위허가”라 한다)를 받아야 한다. 다만, 도시·군계획사업(다른 법률에 따라 도시·군계획사업을 의제한 사업을 포함한다)에 의한 행위는 그러하지 아니하다.

1. 건축물의 건축 또는 공작물의 설치
2. 토지의 형질 변경(경작을 위한 경우로서 대통령령으로 정하는 토지의 형질 변경은 제외한다)
3. ~ 5. (생 략)
- ② ~ ④ (생 략)

제58조(개발행위허가의 기준) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발행위허가의 신청 내용이 다음 각 호의 기준에 맞는 경우에만 개발행위허가 또는 변경허가를 하여야 한다.

1. 용도지역별 특성을 고려하여 대통령령으로 정하는 개발행위의 규모에 적합할 것. 다만, 개발행위가 「농어촌정비법」 제2조제4호에 따른 농어촌정비사업으로 이루어지는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 개발행위 규모의 제한을 받지 아니한다.
2. ~ 5. (생 략)
- ②·③ (생 략)

9) 대법원 2006. 11. 23. 선고 2006두13954 판결례 참조

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령

제51조(개발행위허가의 대상) ①법 제56조제1항에 따라 개발행위허가를 받아야 하는 행위는 다음 각 호와 같다.

- 1.·2. (생 략)
3. 토지의 형질변경: 절토(땅깎기)·성토(흙쌓기)·정지(땅고르기)·포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위와 공유수면의 매립(경작을 위한 토지의 형질변경을 제외한다)
4. ~ 6. (생 략)
- ② (생 략)

제55조(개발행위허가의 규모) ①법 제58조제1항제1호 본문에서 “대통령령으로 정하는 개발행위의 규모”란 다음 각호에 해당하는 토지의 형질변경면적을 말한다. 다만, 관리지역 및 농림지역에 대하여는 제2호 및 제3호의 규정에 의한 면적의 범위안에서 당해 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 도시·군계획조례로 따로 정할 수 있다.

1. 도시지역
 - 가. 주거지역·상업지역·자연녹지지역·생산녹지지역 : 1만제곱미터 미만
 - 나. 공업지역 : 3만제곱미터 미만
 - 다. 보전녹지지역 : 5천제곱미터 미만
2. ~ 4. (생 략)
- ②·③ (생 략)

도로법

제61조(도로의 점용 허가) ① 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경(허가받은 사항 외에 도로 구조나 교통안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위를 포함한다)하려는 때에도 같다.

- ② (생 략)
- ③ 제1항에 따라 허가를 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류와 허가의 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ④·⑤ (생 략)

도로법 시행령

제55조(점용허가를 받을 수 있는 공작물 등) 법 제61조제3항에 따라 도로점용허가(법 제107조에 따라 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 사업에 관계되는 점용인 경우에는 협의 또는 승인을 말한다)를 받아 도로를 점용할 수 있는 공작물·물건, 그 밖의 시설의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 10. (생 략)
11. 제1호부터 제10호까지의 규정에 따른 공작물·물건 및 시설의 설치를 위하여 일시적으로

설치하는 공사장, 그 밖에 이와 유사한 것과 이를 위한 진입로 및 출입로

12. 제1호부터 제11호까지에서 규정한 것 외에 도로관리청이 도로구조의 안전과 교통에 지장이 없다고 인정한 공작물·물건(식물을 포함한다) 및 시설로서 국토교통부령 또는 해당 도로관리청이 속해 있는 지방자치단체의 조례로 정한 것

질의제목 13

▶ 안전번호 25-0012

경기도 김포시 - 공익사업이 변경된 사실을 환매권자에게 통지해야 하는 사업시행자(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제91조제6항 등 관련)

01 질의요지

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “토지보상법”이라 함) 제91조제6항 전단에서는 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관(이하 “국가등”이라 함)이 사업인정을 받아 공익사업에 필요한 토지를 협의취득하거나 수용한 후 해당 공익사업이 토지보상법 제4조제1호부터 제5호까지에 규정된 다른 공익사업¹⁾으로 변경된 경우 같은 법 제91조제1항 및 제2항에 따른 환매권 행사기간은 관보에 해당 공익사업의 변경을 고시한 날부터 기산(起算)한다고 규정하고 있고, 같은 조 제6항 후단에서는 국가등은 공익사업이 변경된 사실을 대통령령으로 정하는 바에 따라 환매권자²⁾에게 통지하여야 한다고 규정하고 있는바,

토지보상법 제91조제6항 후단에 따라 공익사업이 변경된 사실을 환매권자에게 통지해야 하는 자는 변경되기 전 공익사업을 시행한 국가등인지 아니면 변경된 공익사업을 시행하려는자인지?

02 회답

토지보상법 제91조제6항 후단에 따라 공익사업이 변경된 사실을 환매권자에게 통지해야 하는 자는 변경되기 전 공익사업을 시행한 국가등입니다.

1) 토지보상법 별표에 따른 사업이 같은 법 제4조제1호부터 제5호까지에 규정된 공익사업에 해당하는 경우를 포함함

2) 토지의 협의취득일 또는 수용의 개시일 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인을 말하며(토지보상법 제91조제1항 참조), 이하 같음.

03 이유

먼저 토지보상법 제91조제6항 전단에서는 같은 항의 적용을 받는 공익사업의 변경으로 인정되기 위해서는 국가등이 당초 사업인정을 받아 공익사업에 필요한 토지를 협의취득하거나 수용한 경우로서 그 종전의 공익사업이 같은 법 제4조제1호부터 제5호까지에 규정된 다른 공익사업으로 변경된 경우여야 한다고 규정하고 있고, 이 때 변경된 공익사업의 주체는 문언상 변경되기 전 공익사업과 같이 그 사업의 주체가 국가등으로 제한되지 않게 되는데,³⁾ 토지보상법 제91조제6항 후단에서는 공익사업이 변경된 사실을 대통령령으로 정하는 바에 따라 환매권자에게 통지해야 하는 주체를 “국가등”으로 명시하고 있는바, 만일 변경된 공익사업의 주체가 국가등이 아닌 사업시행자라면 토지보상법 제91조제6항 후단에 따른 통지의 주체가 사실상 없게 될 수 있음을 고려할 때 토지보상법 제91조제6항 후단에서는 공익사업이 변경된 사실을 환매권자에게 통지해야 하는 주체는 변경되기 전 종전의 공익사업을 시행한 국가등으로 보아야 할 것입니다.

그리고 토지보상법 제91조제5항에서는 같은 조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 환매권은 「부동산등기법」에서 정하는 바에 따라 공익사업에 필요한 토지의 협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다고 규정하여 종전의 사업시행자로부터 제3자에게 토지의 소유권이 이전된 경우 그 제3자는 환매의 상대방이 아님을 전제로 환매권자의 대항력을 규정하고 있는데,⁴⁾ 변경된 공익사업의 사업시행자가 그 토지의 소유권을 취득하는 경우가 발생한다 하더라도 그 변경된 공익사업의 사업시행자는 환매권 행사에 관하여는 그 행사에 대항할 수 없는 제3자에 해당하고⁵⁾, 환매권자가 소유하고 있던 토지를 협의취득 또는 수용한 자는 변경되기 전 공익사업을 시행한 국가등이었으므로 특별한 사정이 없는 한 환매의 상대방은 변경되기 전 공익사업의 사업시행자가 된다는 점⁶⁾ 등에 비추어 보면, 환매권자의 토지를 협의취득 또는 수용을 한 주체인 변경되기 전 공익사업의 사업시행자가 공익사업이 변경된 시점을 통지해야 한다고 보는 것이 해당 규정의 체계에 부합하는 해석입니다.

아울러 토지보상법 제91조제6항은 종전의 공익사업이 공익성의 정도가 높은 다른 공익사업으로 변경되고 그 다른 공익사업을 위하여 토지를 계속 이용할 필요가 있을 경우에는

3) 대법원 2015. 8. 19. 선고 2014다201391 판결례 참조

4) 춘천지방법원 원주지원 2007. 2. 8. 선고 2005가합1090 판결례 참조

5) 법제처 2011. 11. 4. 회신 11-0381 해석례 등 참조

6) 법제처 2011. 11. 4. 회신 11-0381 해석례 등 참조

환매권의 행사를 인정한 다음 다시 협의취득이나 수용 등의 방법으로 그 토지를 취득하는 번거로운 절차를 되풀이하지 않게 하기 위하여 이른바 ‘공익사업의 변환’을 인정함으로써 환매권의 행사를 제한하려는 규정⁷⁾으로, 같은 항 전단에서는 국가등이 사업인정을 받아 공익사업에 필요한 토지를 협의취득하거나 수용한 후 해당 공익사업이 제4조제1호부터 제5호까지에 규정된 다른 공익사업으로 변경된 경우 “환매권 행사기간은 관보에 해당 공익사업의 변경을 고시한 날부터 기산(起算)한다”고 규정하고 있어 공익사업의 변환은 토지를 재수용하는 것이 아니라 환매권 행사 시점을 연기하는 효과를 발생시킨다는 점⁸⁾에서, 공익사업의 변경 시점에 환매권자 및 환매권에 관한 제반 사정을 잘 알고 있는 변경되기 전 공익사업의 사업시행자를 통지 주체로 보는 것이 합리적이라는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 토지보상법 제91조제6항 후단에 따라 공익사업이 변경된 사실을 환매권자에게 통지해야 하는 자는 변경되기 전 공익사업을 시행한 국가등입니다.



관계법령

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률

제91조(환매권) ① ~ ⑤ (생략)

⑥ 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관이 사업인정을 받아 공익사업에 필요한 토지를 협의취득하거나 수용한 후 해당 공익사업이 제4조제1호부터 제5호까지에 규정된 다른 공익사업(별표에 따른 사업이 제4조제1호부터 제5호까지에 규정된 공익사업에 해당하는 경우를 포함한다)으로 변경된 경우 제1항 및 제2항에 따른 환매권 행사기간은 관보에 해당 공익사업의 변경을 고시한 날부터 기산(起算)한다. 이 경우 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관은 공익사업이 변경된 사실을 대통령령으로 정하는 바에 따라 환매권자에게 통지하여야 한다.

7) 대법원 2019. 11. 14. 선고 2019다233072 판결례, 대법원 1994. 1. 25. 선고 93다11760, 11777, 11784 판결례 참조

8) 헌법재판소 2012. 11. 29. 선고 2011헌바49 결정례 참조

질의제목 14 ▶ 안전번호 25-0061

민원인 - 제1종일반주거지역 안에서 같은 건축물에 주택과 주택 외의 용도로 쓰는 부분을 복합 건축하려는 경우 적용되는 층수 제한(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제71조제1항제3호 및 별표 4 등 관련)

01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 함) 제76조제1항에서는 같은 법 제36조에 따라 지정된 용도지역에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한에 관한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제71조제1항제3호 및 별표 4 제1호에서는 제1종일반주거지역 안에서 건축할 수 있는 건축물은 4층 이하의 건축물만 해당한다고 규정하면서, ‘4층 이하’ 뒤에 괄호를 두어 「주택법 시행령」 제10조제1항제3호에 따른 단지형 다세대주택¹⁾인 경우에는 5층 이하를 말하며, 단지형 다세대주택의 1층 바닥면적의 2분의 1 이상을 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 층수에서 제외한다고 규정하고 있는바,

제1종일반주거지역 안에서 같은 건축물에 주택과 주택 외의 용도로 쓰는 부분을 복합하여 건축하려는 경우로서, 1층 전체를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고, 주택 외의 용도로 쓰는 부분을 지하층에 위치하게 하면서 2층 이상의 층은 모두 주택의 용도로 건축하려는 경우,²⁾ 국토계획법 시행령 제71조제1항제3호 및 별표 4 제1호의 단지형 다세대주택에 대한 규정을 적용하여 필로티 구조인 1층을 층수에서 제외할 수 있는지?

02 회답

이 사안의 경우, 국토계획법 시행령 제71조제1항제3호 및 별표 4 제1호의 단지형 다세대주택에 대한 규정을 적용할 수 없어 필로티 구조인 1층을 층수에 포함해야 합니다.

- 1) 「주택법」 제2조제20호 및 같은 법 시행령 제10조제1항제3호에 따라 300세대 미만의 국민주택규모에 해당하는 주택으로서, 국토계획법 제36조제1항제1호에 따른 도시지역에 건설하는 다세대주택을 말하며, 이하 같음
- 2) 「건축법」 제4조에 따른 건축위원회의 심의를 받지 않은 경우로서, 해당 건축물의 지하층에 주택 외의 용도로 사무소가 위치한 경우임을 전제함

03 이유

먼저 국토계획법 제36조제1항에 따른 용도지역을 세분하여 규정하고 있는 같은 법 시행령 제30조제1항제1호나목(1)에서는 제1종일반주거지역을 ‘저층주택’을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역으로 규정하고 있고, 같은 영 제71조제1항제3호 및 별표 4 제1호에서는 제1종일반주거지역 안에서 건축할 수 있는 건축물의 층수를 4층 이하로 제한하되, 단지형 다세대주택의 1층 바닥면적의 2분의 1 이상을 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 층수에서 제외하도록 규정하고 있을 뿐, 문언상 필로티 전체를 주차장으로 사용하고 지하층에 주택 외의 용도로 쓰는 부분이 위치하는 경우를 층수 제한 예외 규정의 적용 대상으로는 규정하고 있지 않습니다.

그리고 국토계획법 시행령 별표 4 제1호에서는 제1종일반주거지역 안에서 건축하는 건축물의 층수 제한을 규정하면서 그 층수 제한 원칙에 대한 예외도 같이 규정하고 있는데, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 확장해석하거나 유추해석해서는 안 되고 그 문언과 취지에 따라 엄격하게 해석할 필요가 있는바,³⁾ 같은 호에 따른 제1종일반주거지역 안에서의 층수 제한은 건축물 전체의 층수에 대한 것이므로, 하나의 건축물 안에 여러 용도가 함께 건축되어 있어 각 용도에 대해 적용되는 건축물 층수 제한이 다른 경우라면 그 중 더 엄격한 것을 적용해야 할 것입니다.⁴⁾

그런데 국토계획법 시행령 별표 4 제1호에서는 단지형 연립주택과 단지형 다세대주택에 대해서만 필로티 구조인 1층에 대해 층수에서 제외하는 규정을 두고 있고 그 밖의 용도로 사용되는 건축물에 대해서는 4층 이하의 층수 제한을 적용하도록 규정하고 있는바, 주택과 주택 외의 용도로 쓰는 부분이 같은 건축물 내에 있다면, 주택 외의 용도로 쓰는 부분이 해당 건축물의 어디에 위치해 있는지 여부와 관계없이 이를 전체 건축물이 단지형 다세대주택인 경우와 같다고 할 수는 없는바,⁵⁾ 단지형 다세대주택을 대상으로 하는 층수 제한 예외 규정이 동일하게 적용될 수 없으므로, 이 사안의 경우 일반적으로 적용되는 4층 이하의 층수 제한이 적용된다고 보는 것이 법령의 규정체계에 부합하는 해석입니다.

3) 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조

4) 법제처 2021. 7. 20. 회신 21-0347 해석례 참조

5) 다만, 이와 같이 보는 경우에도 국토계획법 시행령 별표 4 제1호에서 단지형 다세대주택의 1층 바닥면적의 2분의 1 이상을 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 층수에서 제외한다고 규정하고 있으므로, 주택 외의 용도로 쓰는 부분이 해당 기준을 충족하여 건축물의 1층의 일부에 위치하는 경우에 한해 예외적으로 그 건축물 전체를 단지형 다세대주택에 해당하는 것으로 보고 필로티 구조의 1층을 층수 산정에서 제외할 수 있음.

또한 국토계획법 시행령 별표 4 제1호에서 단지형 다세대주택 등에 대해 층수 제한을 완화하여 규정한 취지⁶⁾는, 주택법령에서 건축위원회 심의를 거친 단지형 다세대주택에 대해 5층까지 건축할 수 있도록 규정하였으나, 국토계획법령상 제1종일반주거지역에서는 층수가 4층으로 제한되어 있어 이를 적용하기 곤란하였던 문제를 해결하고, 1층 바닥면적의 2분의 1 이상을 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 해당 층을 층수에서 제외하도록 하여, 쾌적하고 저렴한 소형주택을 공급하기 위하여 도입된 도시형 생활주택의 신속하고 원활한 입지가 이루어질 수 있도록 하려는 데에 있는바, 이러한 입법취지에 비추어 보면 같은 호에 명시적인 규정이 없음에도 ‘주택의 공급’과 관련이 없는 주택 외의 용도로 쓰는 부분을 같은 건축물에 주택과 복합하여 건축하려는 경우까지 층수 제한의 완화를 적용받을 수 있다고 해석하는 것은 타당하지 않습니다.

한편 「건축법 시행령」 별표 1 제2호 단서에 따라 다세대주택의 층수 산정 시 지하층이 주택의 층수에서 제외되므로 건축물의 층수와 관련이 없는 지하층에 주택 외의 용도로 쓰는 부분을 둔 이 사안의 경우에는 국토계획법 시행령 별표 4 제1호에 따라 필로티 구조의 주차장으로 사용된 1층을 해당 건축물의 층수에서 제외할 수 있다는 의견이 있으나, 「건축법 시행령」 별표 1 제2호 단서에 따라 다세대주택의 층수 산정 시 지하층이 주택의 층수에서 제외되는 것과 별개로 건축물의 전체 용도를 판단하는데 있어 지하층의 용도를 따로 제외하고 판단해야 하는 것은 아닌 점, 종전에는 다세대주택의 층수 산정 시 ‘1층 전부’를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에 필로티 부분을 층수에서 제외하도록 규정하고 있었는데, 대지활용률이 떨어지고 1층 필로티 주차장을 장려하려는 정책의 실효성이 낮아지는 문제가 있어 이를 해결하기 위해⁷⁾ 2007년 2월 28일 대통령령 제19920호로 일부개정된 「건축법 시행령」 별표 1 제2호 단서에서 다세대주택의 1층이 필로티 구조의 주차장으로 사용됨을 전제로 ‘그 1층’의 일부에 한해 주택 외 용도의 사용을 예외적으로 허용한 것인바, 이를 넘어 건축물의 1층이 아닌 지하층에 주택 외의 용도로 쓰는 부분을 두는 경우까지 해당 층수 완화에 관한 규정을 적용하겠다는 취지로 보기는 어려운 점⁸⁾ 등을 고려할 때, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우 국토계획법 시행령 제71조제1항제3호 및 별표 4 제1호의 단지형 다세대주택에 대한 규정을 적용할 수 없어 필로티 구조인 1층을 층수에 포함해야 합니다.

6) 2009. 5. 13. 대통령령 제21488호로 일부개정된 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 개정이유 참조

7) 2007. 2. 28. 대통령령 제19920호로 일부개정된 「건축법 시행령」 개정이유 참조

8) 「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 개정 내용은 이후 2009. 5. 13. 대통령령 제21488호로 일부개정된 국토계획법 시행령 별표 4 제1호에 반영되었음.

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률**

제36조(용도지역의 지정) ① 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도지역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정한다.

1. 도시지역: 다음 각 목의 어느 하나로 구분하여 지정한다.

가. 주거지역: 거주와 안녕과 건전한 생활환경의 보호를 위하여 필요한 지역

나. ~ 라. (생략)

2. ~ 4. (생략)

② 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항 각 호 및 같은 항 각 호 각 목의 용도지역을 도시·군관리계획결정으로 다시 세분하여 지정하거나 변경할 수 있다.

제76조(용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축 제한 등) ① 제36조에 따라 지정된 용도지역에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

② ~ ⑥ (생략)

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령

제30조(용도지역의 세분) ① 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시의 시장(이하 “대도시 시장”이라 한다)은 법 제36조제2항에 따라 도시·군관리계획결정으로 주거지역·상업지역·공업지역 및 녹지지역을 다음 각 호와 같이 세분하여 지정할 수 있다.

1. 주거지역

가. (생략)

나. 일반주거지역: 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역

(1) 제1종일반주거지역: 저층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역

(2) 제2종일반주거지역: 중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역

(3) 제3종일반주거지역: 중고층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역

다. (생략)

2. ~ 4. (생략)

② (생략)

제71조(용도지역안에서의 건축제한) ① 법 제76조제1항에 따른 용도지역안에서의 건축물의 용도·종류 및 규모 등의 제한(이하 “건축제한”이라 한다)은 다음 각 호와 같다.

1. 2. (생략)

3. 제1종일반주거지역안에서 건축할 수 있는 건축물: 별표 4에 규정된 건축물

4. ~ 21. (생략)

②·③ (생 략)

[별표 4]

제1종일반주거지역안에서 건축할 수 있는 건축물
(제71조제1항제3호관련)

1. 건축할 수 있는 건축물[4층 이하(「주택법 시행령」 제10조제1항제2호에 따른 단지형 연립주택 및 같은 항 제3호에 따른 단지형 다세대주택인 경우에는 5층 이하를 말하며, 단지형 연립주택의 1층 전부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 필로티 부분을 층수에서 제외하고, 단지형 다세대주택의 1층 바닥면적의 2분의 1 이상을 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 층수에서 제외한다. 이하 이 호에서 같다)의 건축물만 해당한다. 다만, 4층 이하의 범위에서 도시·군계획조례로 따로 층수를 정하는 경우에는 그 층수 이하의 건축물만 해당한다]
 - 가. 「건축법 시행령」 별표 1 제1호의 단독주택
 - 나. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택(아파트를 제외한다)
 - 다. 「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설
 - 라. 「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 중 유치원·초등학교·중학교 및 고등학교
 - 마. 「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설

주택법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “주택”이란 세대(世帶)의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속토지를 말하며, 단독주택과 공동주택으로 구분한다.
2. ~ 19. (생 략)
20. “도시형 생활주택”이란 300세대 미만의 국민주택규모에 해당하는 주택으로서 대통령령으로 정하는 주택을 말한다.
21. ~ 29. (생 략)

주택법 시행령

제10조(도시형 생활주택) ① 법 제2조제20호에서 “대통령령으로 정하는 주택”이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호에 따른 도시지역에 건설하는 다음 각 호의 주택을 말한다.

1. 아파트형 주택: 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 아파트
 - 가. 세대별로 독립된 주거가 가능하도록 욕실 및 부엌을 설치할 것
 - 나. 지하층에는 세대를 설치하지 않을 것
2. 단지형 연립주택: 연립주택. 다만, 「건축법」 제5조제2항에 따라 같은 법 제4조에 따른 건축위원회의

심의를 받은 경우에는 주택으로 쓰는 층수를 5개층까지 건축할 수 있다.

3. 단지형 다세대주택: 다세대주택. 다만, 「건축법」 제5조제2항에 따라 같은 법 제4조에 따른 건축위원회의 심의를 받은 경우에는 주택으로 쓰는 층수를 5개층까지 건축할 수 있다.

②·③ (생략)

건축법

제2조(정의) ① (생략)

② 건축물의 용도는 다음과 같이 구분하되, 각 용도에 속하는 건축물의 세부 용도는 대통령령으로 정한다.

1. 단독주택
2. 공동주택
3. ~ 29. (생략)

건축법 시행령

제3조의5(용도별 건축물의 종류) 법 제2조제2항 각 호의 용도에 속하는 건축물의 종류는 별표 1과 같다.

[별표 1]

용도별 건축물의 종류(제3조의5 관련)

1. (생략)
2. 공동주택[공동주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센터·공동육아나눔터·작은도서관·노인복지시설(노인복지주택은 제외한다) 및 「주택법 시행령」 제10조제1항제1호에 따른 원룸형 주택을 포함한다]. 다만, 가목이나 나목에서 층수를 산정할 때 1층 전부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 필로티 부분을 층수에서 제외하고, 다목에서 층수를 산정할 때 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외하며, 가목부터 라목까지의 규정에서 층수를 산정할 때 지하층을 주택의 층수에서 제외한다.
 - 가. 아파트: 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택
 - 나. 연립주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다) 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택
 - 다. 다세대주택: 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하이고, 층수가 4개 층 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다)
 - 라. (생략)
3. ~ 29. (생략)

질의제목 15

▶ 안전번호 25-0066, 25-0125

경기도 평택시 - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제4항제2호에 따라 개발행위허가를 받지 않고 할 수 있는 행위의 범위(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제4항 등 관련)

01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 함) 제56조제1항 본문에서는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치(제1호), 토지의 형질 변경¹⁾(제2호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위(이하 “개발행위”라 함)를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가(이하 “개발행위허가”라 함)를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항 본문에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 같은 조 제1항에도 불구하고 개발행위허가를 받지 아니하고 할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제4항제2호에서 개발행위허가를 받지 않고 할 수 있는 행위의 하나로 “「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축·증축 또는 재축과 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경(도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하고 있는 도시·군계획시설의 부지인 경우만 가능하다)”을 규정하고 있는바,

「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축·증축 또는 재축을 하려는 경우²⁾, 국토계획법 제56조제4항제2호 괄호 부분에 따른 도시·군계획시설사업이 시행되지 않고 있는 도시·군계획시설의 부지인 경우에만 개발행위허가를 받지 않고 할 수 있는지?

02 회답

「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축·증축 또는 재축을 하려는 경우, 국토계획법 제56조제4항제2호에 따라 도시·군계획시설사업이 시행되지 않고 있는 도시·군계획시설의 부지인 경우에만 개발행위허가를 받지 않고 할 수 있습니다.

1) 경작을 위한 경우로서 대통령령으로 정하는 토지의 형질 변경은 제외함

2) 도시·군계획사업(다른 법률에 따라 도시·군계획사업을 의제한 사업을 포함함)에 의한 행위가 아닌 경우를 전제함(국토계획법 제56조제1항 단서)

03 이유

먼저 국토계획법 제56조제4항제2호에서는 예외적으로 허가 없이 할 수 있는 개발행위로서 「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축·증축 또는 재축과 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경을 규정하면서, 괄호를 두어 “도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하고 있는 도시·군계획시설의 부지인 경우만 가능하다”고 규정하고 있는데, 같은 호에 따라 개발행위허가를 받지 않고 할 수 있는 토지의 형질 변경은 “「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축·증축 또는 재축”에 필요한 범위, 즉 이에 부수되는 토지의 형질 변경의 경우로 한정되는 것임이 문언상 분명하고, 그렇다면 “이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경”은 “「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축·증축 또는 재축”에 부수되는 개발행위로서 「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축·증축 또는 재축과는 불가분의 관계에 있다고 할 것이므로, 국토계획법 제56조제4항제2호 괄호 부분은 같은 호에 따른 “「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축·증축 또는 재축” 및 “이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경” 모두에 적용되는 것으로 봄이 타당한바, 국토계획법 제56조제4항제2호에 따라 개발행위허가를 받지 않고 할 수 있는 개발행위는 모두 도시·군계획시설사업이 시행되지 않고 있는 도시·군계획시설의 부지에서 이루어지는 개발행위만을 의미한다고 보아야 합니다.

그리고 도시·군계획시설 부지에서의 개발행위에 대해 정하고 있는 국토계획법 제64조제1항 본문에서는 원칙적으로 도시·군계획시설의 설치 장소로 결정된 지상·수상 등에는 그 도시·군계획시설이 아닌 건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허가하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 그 예외로 일정 기간 해당 도시·군계획시설의 설치에 관한 사업이 시행되지 않은 시설 중 그 단계별 집행계획이 수립되지 않은 도시·군계획시설의 부지 등에 대해서는 건축물의 개축 또는 재축과 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경(제3호) 등 같은 항 각 호의 개발행위를 허가할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 제3호에서는 다시 괄호를 두어 같은 법 제56조제4항제2호에 해당하는 경우는 개발행위 허가대상에서 제외하도록 규정하고 있는바, 이는 같은 법 제56조제4항제2호가 개발행위허가 자체를 받지 않고도 할 수 있는 개발행위 중 하나로 “도시·군계획시설사업이 시행되지 않고 있는 도시·군계획시설 부지”에서의 건축물의 건축 또는 토지의 형질변경 행위에 대해 규정하고 있어, 이러한 “도시·군계획시설사업이 시행되지 않고 있는 도시·군계획시설 부지”에 적용되는 개발행위허가 관련 규정을 명확하게 구분하려는 것이라 할 것이므로, 이상의 사항을 종합하면 같은 법 제56조제4항제2호는 “도시·군계획시설사업이 시행되지 않고 있는

도시·군계획시설의 부지”인 경우, 해당 부지에서 개발행위허가 없이도 할 수 있는 개발행위를 규정한 것으로 보는 것이 국토계획법령의 체계에 부합하는 해석입니다.

또한 국토계획법 제56조제1항에 따르면 개발행위를 하려는 자는 원칙적으로 허가를 받아야 하나, 같은 조 제4항에서는 그 예외로서 허가받지 않고 할 수 있는 개발행위를 각 호로 규정하면서, 그 중 제2호는 도시·군계획시설사업이 시행되지 않고 있는 미집행 부지에서 토지소유자 등의 재산권 제한을 최소화하기 위해 소규모 건축행위와 그에 부수되는 토지형질변경을 허가 없이 허용하려는 것으로³⁾, 만약 같은 호에 따른 “「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축·증축 또는 재축”을 같은 호 괄호 부분에 따른 “도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하고 있는 도시·군계획시설의 부지”에 해당하지 않는 경우에도 개발행위허가를 받지 않고 할 수 있는 것으로 본다면, 해당 개발행위의 경우 어떠한 장소이든 제한 없이 할 수 있게 되어, 주변지역의 토지이용실태 또는 토지이용계획 그리고 주변 경관 및 환경과의 조화와 관계없이 무분별하게 이루어지는 결과를 초래할 수 있는바, 이는 개발행위가 도시계획사업 등 각종 계획과 상충할 수 있는 문제점을 사전에 예방하고 계획적 개발을 유도하려는 개발행위허가제도의 취지⁴⁾ 및 국토의 계획적·체계적인 이용을 통해 난개발을 방지하려는 국토계획법령의 입법 목적에 부합하지 않는다고 할 것입니다.

따라서 「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축·증축 또는 재축을 하려는 경우, 국토계획법 제56조제4항제2호에 따라 도시·군계획시설사업이 시행되지 않고 있는 도시·군계획시설의 부지인 경우에만 개발행위허가를 받지 않고 할 수 있습니다.



관계법령

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제56조(개발행위의 허가) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위(이하 “개발행위”라 한다)를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가(이하 “개발행위허가”라 한다)를 받아야 한다. 다만, 도시·군계획사업(다른 법률에 따라 도시·군계획사업을 의제한 사업을 포함한다)에 의한 행위는 그러하지 아니하다.

1. 건축물의 건축 또는 공작물의 설치
2. 토지의 형질 변경(경작을 위한 경우로서 대통령령으로 정하는 토지의 형질 변경은 제외한다)
3. 토석의 채취

3) 도시업무편람(2023. 국토교통부) 참조

4) 헌법재판소 2013. 10. 24. 선고 2012헌바241 결정례, 법제처 2024. 9. 13. 회신 24-0614 해석례 참조

4. 토지 분할(건축물이 있는 대지의 분할은 제외한다)
 5. 녹지지역·관리지역 또는 자연환경보전지역에 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위
- ②·③ (생 략)
- ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 제1항에도 불구하고 개발행위허가를 받지 아니하고 할 수 있다. 다만, 제1호의 응급조치를 한 경우에는 1개월 이내에 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 신고하여야 한다.
1. 재해복구나 재난수습을 위한 응급조치
 2. 「건축법」에 따라 신고하고 설치할 수 있는 건축물의 개축·증축 또는 재축과 이에 필요한 범위에서의 토지의 형질 변경(도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하고 있는 도시·군계획시설의 부지인 경우만 가능하다)
 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경미한 행위

질의제목 16

▶ 안전번호 25-0091

민원인 - 공장설립등의 승인을 받은 자가 용도지역·지구의 지정 또는 변경이 있더라도 제한받지 않고 계속할 수 있는 공사 또는 사업의 범위(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의3제2항 등 관련)

01 질의요지

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 “산업집적법”이라 함) 제13조제1항 본문에서는 공장건축면적이 500제곱미터 이상인 공장의 신설·증설 또는 업종변경(이하 “공장설립등”이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제13조의3제2항 전단에서는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역 및 지구(이하 “용도지역·지구”라 함) 등의 지정·변경에 관한 도시·군관리계획 등의 결정·고시 당시 해당 용도지역·지구 등에서 산업집적법 제13조에 따른 공장설립등의 승인을 받은 자는 승인을 받은 후에 용도지역·지구의 지정 또는 변경이 있더라도 해당 행위를 제한받지 아니하고 그 공사 또는 사업을 계속할 수 있다고 규정하고 있는바,

산업집적법 제13조에 따른 공장의 설립 승인을 받아 공장건설에 착수하였으나, 공장의 설립이 제한되는 용도지역·지구로 지정 또는 변경된 후에 공장의 설립을 완료하여 가동 중인 공장의 업종을, 설립 당시 승인사항에 포함되지 않은 다른 업종으로 변경하려는 경우, 해당 업종변경이 같은 법 제13조의3제2항 전단에 따라 용도지역·지구의 지정 또는 변경이 있더라도 제한받지 않고 계속할 수 있는 “공사 또는 사업”에 해당하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 해당 업종변경은 산업집적법 제13조의3제2항 전단에 따라 용도지역·지구의 지정 또는 변경이 있더라도 제한받지 않고 계속할 수 있는 “공사 또는 사업”에 해당하지 않습니다.

03 이유

먼저 산업집적법 제13조제1항 본문에서는 공장건축면적이 500제곱미터 이상인 공장의 신설·증설 또는 업종변경을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제19조제1항 전단에서는 공장설립등의 승인을 받으려는 자는 공장설립승인신청서에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수 또는 구청장에게 제출해야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제6조제1항에 따라 공장설립등의 승인을 받기 위해 제출해야 하는 별지 제5호 서식의 공장설립등의 승인신청서에는 공장의 업종, 첨단업종 해당 여부 등을 기재하도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제19조제2항에서는 시장·군수 또는 구청장은 공장설립등의 승인신청을 받은 경우 그 신청이 산업집적법령 및 관계 법령에 적합한지를 검토하여 승인 여부를 결정하여야 한다고 규정하고 있습니다.

그런데 공장설립등의 승인에 대한 특례를 규정한 산업집적법 제13조의3제2항 전단에서는 ‘용도지역 및 지구 등의 지정·변경에 관한 도시·군관리계획 등의 결정·고시 당시 해당 용도지역·지구 등에서 산업집적법 제13조에 따른 공장설립등의 승인을 받은 자는 승인을 받은 후에 용도지역·지구의 지정 또는 변경이 있더라도 해당 행위를 제한받지 아니하고 그 공사 또는 사업을 계속할 수 있다’고 규정하고 있는바, 이는 산업집적법 제13조에 따른 공장설립등의 승인을 받은 경우 그 승인과 직접 관련된 공사 또는 사업 관련 행위는 용도지역·지구의 지정 또는 변경에 따른 행위 제한 없이 계속할 수 있게 함으로써 공장설립등을 하려는 자가 공장설립등을 위한 승인을 받을 당시 예측할 수 없었던 행위 제한을 받지 않도록 하려는 취지인데¹⁾, 그렇다면 산업집적법 제13조의3제2항 전단에 따라 용도지역·지구의 지정 또는 변경에 따른 행위 제한을 받지 않고 계속할 수 있는 “공사 또는 사업”의 범위는 같은 법 제13조에 따른 공장설립등의 승인을 받기 위해 시장·군수 또는 구청장에게 제출한 공장설립등의 신청서에 기재되고 승인받은 내용과 직접 관련된 행위로 한정된다고 할 것이므로²⁾, 당초 공장설립등의 승인에 포함되어 있지 않은 업종변경은 같은 법 제13조의3제2항 전단에서 규정하고 있는 해당 행위를 제한받지 아니하고 계속할 수 있는 “공사 또는 사업”에 해당하지 않는다고 보는 것이 타당합니다.

1) 법제처 2019. 12. 5. 회신 19-0548 해석례 참조

2) 서울고등법원 2015. 3. 24. 선고 2014누66436 판결례 및 법제처 2019. 12. 5. 회신 19-0548 해석례 참조

또한 일반적으로 특례 규정은 법령을 제정 또는 개정할 때 정책적인 관점 또는 특수한 상황을 전제로 하여 한정된 기간 또는 한정된 대상에 대하여 예외적으로 일반 규정의 내용과 다른 제도를 도입하여 운용할 필요가 있을 때에 두는 것으로서 그 성격상 제한적으로 해석하여야 할 것인바³⁾, 이 사안과 같이 공장의 설립이 제한되는 용도지역·지구로 지정 또는 변경되어 같은 법 제13조의3제2항에 따른 특례를 적용받아 당초 승인받은 내용대로 공장설립등을 완료한 공장의 경우, 재차 해당 특례를 적용하여 당초 승인받지 않은 업종변경까지 할 수 있는 것으로 보는 것은, 특례의 적용 범위를 명시적인 근거규정 없이 확대해석 하는 것으로서 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 업종변경은 산업집적법 제13조의3제2항 전단에 따라 용도지역·지구의 지정 또는 변경이 있더라도 제한받지 않고 계속할 수 있는 “공사 또는 사업”에 해당하지 않습니다.



관계법령

산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률

제13조(공장설립등의 승인) ① 공장건축면적이 500제곱미터 이상인 공장의 신설·증설 또는 업종변경(이하 “공장설립등”이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 승인을 받아야 하며, 승인을 받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 승인을 받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 한다.

② ~ ⑦ (생 략)

제13조의3(공장설립등의 승인에 대한 특례) ① (생 략)

② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역 및 지구 등의 지정·변경에 관한 도시·군관리계획 등의 결정·고시 당시 해당 용도지역·지구 등에서 제13조에 따른 공장설립등의 승인을 받은 자는 승인을 받은 후에 용도지역·지구의 지정 또는 변경이 있더라도 해당 행위를 제한받지 아니하고 그 공사 또는 사업을 계속할 수 있다. 이 경우 각 해당 법령에 따른 인·허가권자는 공장설립등에 필요한 인·허가를 할 수 있다.

③ (생 략)

3) 법제처 2017. 3. 30. 회신 17-0011 해석례 참조

질의제목 17

▶ 안전번호 25-0119

민원인 - 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제24조제12항에 따른 방화유리창호의 설치 기준(「건축법」 제52조제4항 등 관련)

01 질의요지

「건축법」 제52조제4항에서는 대통령령으로 정하는 용도 및 규모에 해당하는 건축물 외벽에 설치되는 창호(窓戶)는 방화에 지장이 없도록 인접 대지와 이격거리를 고려하여 방화성능 등이 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」(이하 “건축물방화구조규칙”이라 함) 제24조제12항에서는 「건축법」 제52조제4항에 따라 같은 법 시행령 제61조제2항 각 호에 해당하는 건축물의 인접대지경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창호와 인접대지경계선 간의 거리가 1.5미터 이내인 경우 해당 창호는 방화유리창호¹⁾로 설치해야 하되(본문), 스프링클러 또는 간이 스프링클러의 헤드가 창호로부터 60센티미터 이내에 설치되어 건축물 내부가 화재로부터 방호되는 경우에는 방화유리창호로 설치하지 않을 수 있다(단서)고 규정하고 있는바,

건축물²⁾의 인접대지경계선에 접하는 외벽에 창호 설치 시³⁾, 스프링클러의 헤드가 창호로부터 60센티미터를 초과하여 설치되었으나 스프링클러 헤드의 유효살수반경⁴⁾ 안에 해당 창호가 있는 경우, 해당 창호를 건축물방화구조규칙 제24조제12항에 따라 방화유리창호로 설치해야 하는지?

1) 한국산업표준 KS F 2845(유리구획 부분의 내화 시험방법)에 규정된 방법에 따라 창틀과 유리 등으로 구성된 유리구획을 시험한 결과 비차열 20분 이상의 성능이 있는 것으로 한정하며, 이하 같음

2) 「건축법 시행령」 제61조제2항 각 호에 해당하는 건축물임을 전제로 함

3) 건축물의 인접대지경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창호와 그 인접대지경계선 간의 거리가 1.5미터 이내임을 전제로 함

4) 일반적으로 스프링클러가 물을 분사하는 경우 충분한 살수밀도를 통해 화재를 유효하게 진압할 수 있는 범위를 말하며, 「스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」(소방청고시) 제15조에서 규정하고 있는 ‘유효살수반경’을 의미함

02 회답

이 사안의 경우, 해당 창호를 건축물방화구조규칙 제24조제12항에 따라 방화유리창호로 설치해야 합니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데,⁵⁾ 「건축법」 제52조제4항에서는 건축물 외벽에 설치되는 창호는 방화에 지장이 없도록 인접 대지와의 이격거리를 고려하여 방화성능 등이 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합하여야 한다고 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 건축물방화구조규칙 제24조제12항에서는 방화유리창호의 설치기준과 관련하여 같은 법 제52조제4항에 따라 건축물의 인접대지경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창호와 인접대지경계선 간의 거리가 1.5미터 이내인 경우 해당 창호는 방화유리창호로 설치해야 하되(본문), 스프링클러 또는 간이 스프링클러의 헤드가 창호로부터 60센티미터 이내에 설치되어 건축물 내부가 화재로부터 방호되는 경우에는 방화유리창호로 설치하지 않을 수 있다(단서)고 명시적으로 규정하고 있으며, 별도로 해당 창호와 인접대지경계선 간의 거리가 1.5미터 이내이고, 스프링클러의 헤드가 그 창호로부터 60센티미터를 초과하여 설치된 경우에 있어 해당 창호를 방화유리창호로 설치하지 않을 수 있도록 하는 규정을 두고 있지 않은바, 이 사안의 경우 해당 창호를 건축물방화구조규칙 제24조제12항에 따른 방화유리창호로 설치해야 한다고 보는 것이 문언상 타당합니다.

또한 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데,⁶⁾ 건축물방화구조규칙 제24조제12항 본문에서 건축물의 인접대지경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창호와 인접대지경계선 간의 거리가 1.5미터 이내인 경우에는 원칙적으로 해당 창호를 방화유리창호로 설치하도록 규정하면서, 같은 항 단서에서 예외적으로 스프링클러의 헤드가 창호로부터 60센티미터 이내에 설치되어 건축물 내부가 화재로부터 방호되는 경우에 한해 해당 창호를 방화유리창호로

5) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

6) 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조

설치하지 않을 수 있도록 규정하고 있는바, 이처럼 스프링클러의 헤드와 창호 사이의 ‘60센티미터 이내’라는 설치 기준은 같은 항 단서의 “건축물 내부가 화재로부터 방호되는 경우”의 전제 조건이자, 같은 항 단서에 따라 예외적으로 해당 창호를 방화유리창호로 설치하지 않는 데에 있어 반드시 준수해야 할 요건으로서 문언에 따라 엄격히 해석해야 할 것입니다.

더욱이 「건축법」 제52조제4항을 규정한 취지는 화재로 인한 대형 인명사고가 지속적으로 발생함에 따라 화재안전 관련 주요 건축자재에 대한 품질관리를 강화하기 위한 것으로서⁷⁾, 이에 따라 건축물방화구조규칙 제24조제12항(당시 제24조제9항)을 신설하여 창호를 통한 건축물 화재확산의 방지 및 대형 화재사고의 예방을 통해 인명피해를 경감하려는 것이고⁸⁾, 건축법령은 건축물의 대지·구조·설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전·기능 등을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있는 점(「건축법」 제1조 등)을 고려해 볼 때, 이 사안의 경우 해당 창호는 건축물방화구조규칙 제24조제12항에 따라 방화유리창호로 설치해야 한다고 해석하는 것이 건축물의 화재안전성 확보라는 입법 취지 및 목적에도 부합합니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 창호를 건축물방화구조규칙 제24조제12항에 따라 방화유리창호로 설치해야 합니다.



관계법령

건축법

제52조(건축물의 마감재료 등) ① ~ ③ (생 략)

④ 대통령령으로 정하는 용도 및 규모에 해당하는 건축물 외벽에 설치되는 창호(窓戶)는 방화에 지장이 없도록 인접 대지와 이격거리를 고려하여 방화성능 등이 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합하여야 한다.

건축법 시행령

제61조(건축물의 마감재료 등) ① (생 략)

② 법 제52조제2항에서 “대통령령으로 정하는 건축물”이란 다음 각 호의 건축물을 말한다.

1. 상업지역(근린상업지역은 제외한다)의 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

7) 2020. 12. 22. 법률 제17733호로 일부개정된 「건축법」 개정이유 및 주요내용 참조

8) 2021. 7. 5. 국토교통부령 제868호 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 일부개정령안 조문별 제·개정이유서 참조

가. 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운동시설 및 위락시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 2천제곱미터 이상인 건축물

나. 공장(국토교통부령으로 정하는 화재 위험이 적은 공장은 제외한다)의 용도로 쓰는 건축물로부터 6미터 이내에 위치한 건축물

2. ~ 5. (생 략)

③ 법 제52조제4항에서 “대통령령으로 정하는 용도 및 규모에 해당하는 건축물”이란 제2항 각 호의 건축물을 말한다.

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙

제24조(건축물의 마감재료 등) ① ~ ⑪ (생 략)

⑫ 법 제52조제4항에 따라 영 제61조제2항 각 호에 해당하는 건축물의 인접대지경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창호(窓戶)와 인접대지경계선 간의 거리가 1.5미터 이내인 경우 해당 창호는 방화유리창호[한국산업표준 KS F 2845(유리구획 부분의 내화 시험방법)에 규정된 방법에 따라 창틀과 유리 등으로 구성된 유리구획을 시험한 결과 비차열 20분 이상의 성능이 있는 것으로 한정한다]로 설치해야 한다. 다만, 스프링클러 또는 간이 스프링클러의 헤드가 창호로부터 60센티미터 이내에 설치되어 건축물 내부가 화재로부터 방호되는 경우에는 방화유리창호로 설치하지 않을 수 있다.

질의제목 18

▶ 안전번호 25-0120

민원인 - 지적측량수행자가 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제24조제2항에 따라 지적측량을 하는 경우, 「지적재조사에 관한 특별법」 제14조에 따른 경계설정의 기준이 적용되는지(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제24조제2항 등 관련)

01 질의요지

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」(이하 “공간정보관리법”이라 함) 제24조 제1항에서는 토지소유자 등 이해관계인은 같은 법 제23조제1항제1호 및 제3호부터 제5호까지의 사유로 지적측량을 할 필요가 있는 경우에는 지적측량수행자¹⁾에게 지적측량을 의뢰하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제24조제2항에서는 지적측량수행자는 같은 조 제1항에 따른 지적측량 의뢰를 받으면 지적측량을 하여 그 측량성과를 결정하여야 한다고 규정하고 있는 한편,

「지적재조사에 관한 특별법」(이하 “지적재조사법”이라 함) 제14조제1항에서는 지적소관청은 지상경계에 대하여 다툼이 없는 경우 토지소유자가 점유하는 토지의 현실경계(제1호), 지상경계에 대하여 다툼이 있는 경우 등록할 때의 측량기록을 조사한 경계(제2호), 지방관습에 의한 경계(제3호)의 순위로 지적재조사를 위한 경계를 설정하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 지적소관청은 같은 조 제1항 각 호의 방법에 따라 지적재조사를 위한 경계설정을 하는 것이 불합리하다고 인정하는 경우에는 토지소유자들이 합의한 경계를 기준으로 지적재조사를 위한 경계를 설정할 수 있다고 규정하고 있는바,

지적측량수행자가 공간정보관리법 제24조제2항에 따라 지적측량을 하는 경우, 지적재조사법 제14조에 따른 경계설정의 기준이 적용되는지?

1) 공간정보관리법 제24조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말하며, 이하 같음

02 회답

지적측량수행자가 공간정보관리법 제24조제2항에 따라 지적측량을 하는 경우, 지적재조사법 제14조에 따른 경계설정의 기준이 적용되지 않습니다.

03 이유

먼저 공간정보관리법 제2조제4호에서는 “지적측량”이란 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위하여 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 정하는 측량을 말하며 지적재조사측량을 포함한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4호의3에서는 “지적재조사측량”이란 지적재조사법에 따른 지적재조사사업에 따라 토지의 표시를 새로 정하기 위하여 실시하는 지적측량을 말한다고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 지적재조사법 제2조제2호에서는 “지적재조사사업”이란 지적공부의 등록사항을 조사·측량하여 기존의 지적공부를 디지털에 의한 새로운 지적공부로 대체함과 동시에 지적공부의 등록사항이 토지의 실제 현황과 일치하지 아니하는 경우 이를 바로 잡기 위하여 실시하는 국가사업을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제3조제1항에서는 이 법은 지적재조사사업에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 지적재조사사업을 시행할 때 이 법에서 규정하지 아니한 사항에 대하여는 공간정보관리법에 따른다고 규정하고 있는바, 지적재조사법은 지적측량 중에서 지적재조사사업을 시행하기 위하여 이루어지는 측량인 지적재조사측량을 규율 대상으로 하여 공간정보관리법에 대해 우선 적용되는 특별법의 지위에 있으므로, 지적재조사측량이 아닌 지적측량과 관련한 사항은 지적재조사법이 아니라 공간정보관리법에 따른다고 할 것입니다.

그리고 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데²⁾, 지적재조사법 제14조제1항에서는 지적소관청은 같은 항 각 호의 순위로 ‘지적재조사를 위한’ 경계를 설정하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 각 호에서는 경계설정 방법의 순위를 현실경계(제1호), 도상경계³⁾(제2호), 관습경계(제3호) 순으로 열거하고 있고, 같은 조 제2항에서는 지적소관청은

2) 대법원 2009. 4. 2.3 선고 2006다81035 판결례 참조

3) 2016년 10월 31일 의안번호 2003113호로 발의된 지적재조사에 관한 특별법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 검토보고서 참조

같은 조 제1항 각 호의 방법에 따라 경계설정을 하는 것이 불합리하다고 인정하는 경우에는 토지소유자들이 합의한 경계를 기준으로 ‘지적재조사를 위한’ 경계를 설정할 수 있는 것으로 규정하고 있는바, 지적재조사법 제14조에 따른 경계설정의 기준은 ‘지적재조사를 위한’ 지적측량, 즉 지적재조사측량의 경우에만 적용되는 것이 문언상 분명할 뿐만 아니라, 공간정보관리법령에서 지적재조사측량 외의 지적측량의 경우에도 지적재조사법 제14조의 규정이 준용되는 것으로 별도로 규정하고 있지 않으므로, 이 사안과 같이 공간정보관리법에 따라 지적재조사측량이 아닌 지적측량을 하는 경우에는 지적재조사법 제14조에 따른 경계설정의 기준이 적용되지 않는다는 것이 문언상 명확합니다.

더욱이 지적재조사법에서 경계와 관련하여 규정하고 있는 일련의 절차를 살펴보면, 지적소관청은 토지의 실제 현황과 기존의 지적공부상의 경계가 일치하지 않는 경우 토지소유자가 점유하는 현실경계 등에 의하여 지적재조사를 위한 경계를 설정하고(제14조), 경계를 설정하면 지체 없이 임시경계점표지를 설치하고 지적재조사측량을 실시하여야 하며(제15조), 경계결정위원회의 의결을 거쳐 경계를 결정하되(제16조), 토지소유자나 이해관계인은 경계결정에 불복하는 경우 이의신청을 할 수 있고(제17조), 이의신청을 하지 아니하거나 이의신청에 대한 결정에 불복의사를 표명하지 않은 때에는 경계가 확정된다고 규정하고 있는바(제18조), 이는 부정확한 지적공부를 정비하는 지적재조사사업의 추진과정에서 경계의 확정에 관한 절차를 법에 명시함으로써 토지소유권의 범위와 한계를 정하는 중요한 사항인 토지의 경계⁴⁾와 관련하여 발생하는 분쟁을 효율적으로 해결하고 국민의 재산권 보호에 기여하려는 취지라 할 것인데(제1조), 이러한 지적재조사측량에 관한 절차 중 하나인 ‘경계의 설정’에 관한 지적재조사법 제14조의 규정이 지적재조사측량이 아닌 지적측량에까지 적용된다고 볼 수는 없습니다.

따라서 지적측량수행자가 공간정보관리법 제24조제2항에 따라 지적측량을 하는 경우, 지적재조사법 제14조에 따른 경계설정의 기준이 적용되지 않습니다.



관계법령

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률

제24조(지적측량 의뢰 등) ① 토지소유자 등 이해관계인은 제23조제1항제1호 및 제3호(자목은 제외한다)부터 제5호까지의 사유로 지적측량을 할 필요가 있는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에

4) 대법원 2001. 6. 26. 선고 2000다24207 판결례 참조

해당하는 자(이하 “지적측량수행자”라 한다)에게 지적측량을 의뢰하여야 한다.

1. 제44조제1항제2호의 지적측량업의 등록을 한 자
2. 「한국국토정보공사법」 제3조제1항에 따라 설립된 한국국토정보공사(이하 “한국국토정보공사”라 한다)
 - ② 지적측량수행자는 제1항에 따른 지적측량 의뢰를 받으면 지적측량을 하여 그 측량성과를 결정하여야 한다.
 - ③ 제1항 및 제2항에 따른 지적측량 의뢰 및 측량성과 결정 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

지적재조사에 관한 특별법

제14조(경계설정의 기준) ① 지적소관청은 다음 각 호의 순위로 지적재조사를 위한 경계를 설정하여야 한다.

1. 지상경계에 대하여 다툼이 없는 경우 토지소유자가 점유하는 토지의 현실경계
 2. 지상경계에 대하여 다툼이 있는 경우 등록할 때의 측량기록을 조사한 경계
 3. 지방관습에 의한 경계
- ② 지적소관청은 제1항 각 호의 방법에 따라 지적재조사를 위한 경계설정을 하는 것이 불합리하다고 인정하는 경우에는 토지소유자들이 합의한 경계를 기준으로 지적재조사를 위한 경계를 설정할 수 있다.
- ③ 지적소관청은 제1항과 제2항에 따라 지적재조사를 위한 경계를 설정할 때에는 「도로법」, 「하천법」 등 관계 법령에 따라 고시되어 설치된 공공용지의 경계가 변경되지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 해당 토지소유자들 간에 합의한 경우에는 그러하지 아니하다.

질의제목 19

▶ 안전번호 25-0126

민원인 - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제1항제3호에 따른 개발행위허가 대상의 범위(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제1항제3호 등 관련)

01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 함) 제56조제1항 본문에서는 토석의 채취(제3호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위(이하 “개발행위”라 함)를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(이하 “시장·군수등”이라 함)의 허가(이하 “개발행위허가”라 함)를 받아야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제51조제1항 제4호에서는 같은 법 제56조제1항에 따라 개발행위허가를 받아야 하는 행위인 ‘토석채취’를 흙·모래·자갈·바위 등의 토석을 채취하는 행위로 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제56조제1항 및 별표 1의2 제2호다목 본문에서는 토석채취의 허가기준으로 지하자원의 개발을 위한 토석의 채취허가는 시가화대상이 아닌 지역으로서 인근에 피해가 없는 경우에 한하도록 하되, 구체적인 사항은 도시·군계획조례가 정하는 기준에 적합할 것을 규정하면서, 같은 목 단서에서는 국민경제상 중요한 광물자원의 개발을 위한 경우로서 인근의 토지이용에 대한 피해가 최소한에 그치도록 하는 때에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바,

‘국민경제상 중요한 광물자원의 개발을 위한 경우로서 인근의 토지이용에 대한 피해가 최소한에 그치도록 하는 때’는 국토계획법 제56조제1항제3호에 따른 토석채취 개발행위허가 대상에서 제외되는지?

02 회답

‘국민경제상 중요한 광물자원의 개발을 위한 경우로서 인근의 토지이용에 대한 피해가 최소한에 그치도록 하는 때’는 국토계획법 제56조제1항제3호에 따른 토석채취 개발행위허가 대상에서 제외되지 않습니다.

03 이유

먼저 국토계획법 제56조제1항에서는 토석의 채취(제3호) 등 개발행위를 하려는 자는 개발행위허가를 받도록 규정(본문)하면서, 도시·군계획사업에 의한 행위는 개발행위허가 대상에서 제외하고(단서) 있고, 같은 조 제3항에서는 보전관리지역 등의 산림에서의 토석의 채취 행위 등에 대해서는 같은 조 제1항에도 불구하고 「산지관리법」 등을 따르도록 규정하고 있으며, 같은 조 제4항에서는 재난수습을 위한 응급조치(제1호) 등의 행위는 같은 조 제1항에도 불구하고 개발행위허가를 받지 않고 할 수 있다고 규정하여, 개발행위를 하려는 경우 국토계획법 제56조에 따라 허가를 받아야 하는 경우와 허가를 받지 않아도 되는 경우를 나누어 규정하고 있고, 국토계획법 제58조제1항에서는 시장·군수등은 개발행위허가의 신청 내용이 같은 항 각 호의 기준에 맞는 경우에만 개발행위허가 또는 변경허가를 하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제1항에 따라 허가할 수 있는 경우 그 허가의 기준은 지역의 특성, 지역의 개발상황, 기반시설의 현황 등을 고려하여 같은 항 각 호의 구분¹⁾에 따라 대통령령으로 정하도록 규정하고 있는 한편, 같은 법 시행령 제51조에서는 같은 법 제56조제1항에 따라 개발행위허가의 대상이 되는 개발행위에 대하여 구체적으로 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제56조제1항 및 별표 1의2에서는 같은 법 제58조제3항에 따른 개발행위허가의 기준을 세부적으로 규정하고 있습니다.

그리고 국토계획법 시행령 별표 1의2 제2호다목에서는 토석채취의 원칙적 허가기준으로 지하자원의 개발을 위한 토석의 채취허가는 시가화대상이 아닌 지역으로서 ‘인근에 피해가 없는 경우’에 한하도록 하되, 구체적인 사항은 도시·군계획조례가 정하는 기준에 적합할 것(본문)을 규정하면서, 예외적으로 국민경제상 중요한 광물자원의 개발을 위한 경우로서 ‘인근의 토지이용에 대한 피해가 최소한에 그치도록 하는 때’에는 그러하지 아니하다(단서)고 규정하고 있는바, 국토계획법 시행령 별표 1의2 제2호다목 단서에서는 토석채취의 원칙적 허가기준에 대한 예외를 규정하고 있습니다.

이러한 국토계획법령의 규정을 종합해 보면, 일정한 행위가 개발행위허가 대상에 해당하는지 여부는 국토계획법 제56조의 규정에 따르고, 개발행위허가 대상에 해당하는 경우에는 같은 법 제58조 및 같은 법 시행령 별표 1의2에 따른 개발행위허가 기준을 적용하여 허가 여부를 판단하는 것인바, 같은 표 제2호다목 단서에 따른 ‘국민경제상 중요한 광물자원의 개발을 위한 경우로서 인근의 토지이용에 대한 피해가 최소한에 그치도록 하는 때’는

1) 시가화 용도, 유보 용도, 보전 용도로 구분됨

국토계획법 제56조제1항제3호에 따른 토석채취 개발행위허가의 대상에 해당하는 것을 전제로 개발행위허가의 기준을 정한 것이고, 이에 따라 국민경제상 중요한 광물자원의 개발을 위한 경우에는 인근의 토지이용에 대한 피해가 발생하더라도 그 피해가 최소한에 그치도록 하는 때에는 개발행위허가를 할 수 있다는 의미이지, 국토계획법 제56조제1항제3호에 따른 토석채취 개발행위허가 대상에서 제외된다는 의미는 아닙니다.

아울러 개발행위허가제는 이웃 토지와 연접되어 있는 어느 한 토지의 이용이 인접 토지의 이용과 부조화를 발생시킬 수 있는 등 문제점이 발생할 수 있으므로 이를 사전에 예방하고 국토를 효율적·합리적으로 이용·관리하기 위하여 기반시설의 확보 여부, 주변 환경과의 조화 등을 사전에 검토하여 허가를 받도록 하는 제도²⁾인데, 국토계획법 시행령 별표 1의2 제2호다목 단서는 ‘국민경제상 중요한 광물자원’의 개발을 위한 경우로서 인근의 토지이용에 대한 피해가 최소한에 그치도록 하는 때에는 예외적으로 토석채취 개발행위 허가를 할 수 있도록 한 것으로 해석하는 것이 주변 환경을 고려하여 개발행위를 허가함으로써 국토를 효율적으로 관리하려는 개발행위허가제의 입법취지에 부합한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 ‘국민경제상 중요한 광물자원의 개발을 위한 경우로서 인근의 토지이용에 대한 피해가 최소한에 그치도록 하는 때’는 국토계획법 제56조제1항제3호에 따른 토석채취 개발행위허가 대상에서 제외되지 않습니다.



관계법령

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제56조(개발행위의 허가) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위(이하 “개발행위”라 한다)를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가(이하 “개발행위허가”라 한다)를 받아야 한다. 다만, 도시·군계획사업(다른 법률에 따라 도시·군계획사업을 의제한 사업을 포함한다)에 의한 행위는 그러하지 아니하다.

- 1.·2. (생략)
3. 토석의 채취
- 4.·5. (생략)
- ② ~ ④ (생략)

2) 법제처 2018. 3. 8. 회신 18-0052 해석례 참조

제58조(개발행위허가의 기준) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발행위허가의 신청 내용이 다음 각 호의 기준에 맞는 경우에만 개발행위허가 또는 변경허가를 하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

② (생략)

③ 제1항에 따라 허가할 수 있는 경우 그 허가의 기준은 지역의 특성, 지역의 개발상황, 기반시설의 현황 등을 고려하여 다음 각 호의 구분에 따라 대통령령으로 정한다.

1. 시가화 용도: 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역의 제한에 따라 개발행위허가의 기준을 적용하는 주거지역·상업지역 및 공업지역

2.·3. (생략)

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령

제51조(개발행위허가의 대상) ①법 제56조제1항에 따라 개발행위허가를 받아야 하는 행위는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 3. (생략)

4. 토석채취: 흙·모래·자갈·바위 등의 토석을 채취하는 행위. 다만, 토지의 형질변경을 목적으로 하는 것을 제외한다.

5.·6. (생략)

② (생략)

제56조(개발행위허가의 기준) ①법 제58조제3항에 따른 개발행위허가의 기준은 별표 1의2와 같다.

② ~ ④ (생략)

[별표 1의2]

개발행위허가기준(제56조 관련)

1. 분야별 검토사항
(생략)

2. 개별행위별 검토사항

검토분야	허가기준
가·나 (생략)	(생략)
다. 토석채취	지하자원의 개발을 위한 토석의 채취허가는 시가화대상이 아닌 지역으로서 인근에 피해가 없는 경우에 한하도록 하되, 구체적인 사항은 도시·군계획조례가 정하는 기준에 적합할 것. <u>다만, 국민경제상 중요한 광물자원의 개발을 위한 경우로서 인근의 토지이용에 대한 피해가 최소한에 그치도록 하는 때에는 그러하지 아니하다.</u>
라·마 (생략)	(생략)

3. 용도지역별 검토사항
(생략)

질의제목 20

▶ 안전번호 25-0132

민원인 - 법률 제20044호 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 일부개정법을 부칙 제3조제2항에서 규정하고 있는 “이 법 시행 당시 종전의 규정에 따른 유지관리업자”의 의미(법률 제20044호 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 일부개정법을 부칙 제3조 등 관련)

01 질의요지

2024년 1월 16일 법률 제20044호로 일부개정되어 2024년 7월 17일 시행된 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하 “개정 시설물안전법”이라 함) 제26조제1항에서는 관리주체는 안전점검 및 긴급안전점검을 국토안전관리원, 안전진단전문기관 또는 안전점검 전문기관¹⁾에 대행하게 할 수 있다고 규정하면서, 같은 법 부칙 제3조제1항에서 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검을 대행할 수 있는 유지관리업자²⁾는 같은 법 제28조의2의 개정규정에 따른 안전점검전문기관으로 등록한 것으로 본다고 규정하고 있고, 같은 부칙 제3조제2항에서 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따른 유지관리업자는 이 법 시행 전에 체결한 시설물의 안전점검, 긴급안전점검 또는 유지관리의 대행계약에 한정하여 해당 업무를 계속할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

구 「건설산업기본법 시행령」(2020년 12월 29일 대통령령 제31328호로 일부개정되어 2022년 1월 1일 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 부칙 제2조에서는 시설물유지관리업의 업무내용, 등록기준 등을 규정하고 있는 별표 1 제2호거목 및 별표 2 제2호거목의 개정규정은 2023년 12월 31일까지 효력을 가진다고 규정하고 있고, 같은 부칙 제7조에서는 종전 시설물유지관리업자³⁾가 원칙적으로 같은 법 시행령 별표 1의 개정규정에 따른 종합공사나 전문공사를 시공하는 업종 중 일부로 전환할 수 있도록 하는 시설물유지관리업의 업종전환에 관한 특례에 대하여 규정하고 있으며⁴⁾, 같은 부칙 제10조제3항에서는 같은 부칙 제2조에 따른 시설물유지관리업의 유효기간 만료일 이후 다른 법령에서 “유지관리업자”를 인용하고

1) 개정 시설물안전법 제28조의2에 따른 안전점검전문기관을 의미하며, 이하 같음

2) 「건설산업기본법」 제9조에 따라 등록된 유지관리업자를 의미하며, 이하 같음

3) 2020년 9월 16일 전에 시설물유지관리업을 등록했거나 등록 신청한 자로서 종전의 별표 2에 따른 시설물유지관리업의 등록기준을 갖춘 자를 말하며, 이하 같음

4) 전환한 건설업종에 대하여는 2026년 12월 31일 또는 2029년 12월 31일까지 별표 2의 개정규정에 따른 등록기준을 갖춰야 함(구 「건설산업기본법 시행령」 부칙 제7조제1항 및 제3항)

있는 경우에는 같은 부칙 제7조에 따라 업종을 전환하여 등록한 건설사업자를 인용한 것으로 본다고 규정하고 있는바,

개정 시설물안전법 부칙 제3조제2항에서 규정하고 있는 “이 법 시행 당시 종전의 규정에 따른 유지관리업자”는 구 「건설산업기본법 시행령」 부칙 제7조에 따라 업종을 전환하여 등록한 건설사업자(이하 “업종전환 유지관리업자”라 함)를 의미하는지, 아니면 업종을 전환하여 등록하지 않은 유지관리업자(이하 “업종미전환 유지관리업자”라 함)를 의미하는지?

02 회답

개정 시설물안전법 부칙 제3조제2항에서 규정하고 있는 “이 법 시행 당시 종전의 규정에 따른 유지관리업자”는 업종미전환 유지관리업자를 의미합니다.

03 이유

종전 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(2024년 1월 16일 법률 제20044호로 일부개정되어 2024년 7월 17일 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 “종전 시설물안전법”이라 함) 제26조제1항에서는 관리주체는 안전점검 및 긴급안전점검을 국토안전관리원, 안전진단전문기관⁵⁾ 또는 “유지관리업자”에게 대행하게 할 수 있다고 규정하고 있었는데, 구 「건설산업기본법 시행령」 부칙 제2조에서 시설물유지관리업이 2023년 12월 31일까지 효력을 가진다고 규정하면서 같은 부칙 제10조제3항에서 같은 부칙 제2조에 따른 시설물유지관리업의 유효기간 만료일 이후 다른 법령에서 “유지관리업자”를 인용하고 있는 경우에는 같은 부칙 제7조에 따른 “업종전환 유지관리업자”를 인용한 것으로 본다고 규정하고 있어, “업종전환 유지관리업자”가 종전 시설물안전법 제26조제1항 등에 따라 안전점검 및 긴급안전점검을 대행할 수 있게 되었는바, 이 사안에서는 개정 시설물안전법 부칙 제3조제2항에서 이 법 시행 전에 체결한 시설물의 안전점검, 긴급안전점검 또는 유지관리의 대행계약에 한정하여 해당 업무를 계속할 수 있는 자로 규정하고 있는 “이 법 시행 당시 종전의 규정에 따른 유지관리업자”가 업종전환 유지관리업자를 의미하는지, 아니면 업종미전환 유지관리업자를 의미하는지가 문제됩니다.

5) 종전 시설물안전법 제28조에 따라 등록된 안전진단전문기관을 의미하며, 이하 같음

먼저 개정 시설물안전법 부칙 제3조제1항 본문에서는 같은 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검을 대행할 수 있는 유지관리업자에 대하여 제28조의2의 개정규정에 따른 안전점검전문기관으로 등록한 것으로 본다고 규정하여, 개정 시설물안전법 시행 이후에도 원칙적으로 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검 대행계약을 새롭게 체결할 수 있도록 정하고 있는 반면, 같은 법 부칙 제3조제2항에서는 같은 조 제1항과 달리 안전점검을 대행할 수 있는 유지관리업자가 아니라 같은 법 시행 당시 종전의 규정에 따른 유지관리업자에 대하여 같은 법 시행 전에 체결한 시설물의 안전점검, 긴급안전점검 또는 유지관리의 대행계약에 한정하여 해당 업무를 계속할 수 있다고 규정하여, 개정 시설물안전법 시행 이후에는 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검 대행계약을 새롭게 체결할 수 없도록 정하고 있는바, 개정 시설물안전법 부칙 제3조제1항 및 제2항에서 규정하고 있는 유지관리업자는 개정 시설물안전법 시행 전후로 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검을 대행할 수 있는지 여부에 관하여 차이가 있으므로, 각각 서로 다른 유지관리업자를 지칭하고 있다 할 것입니다.

그런데 시설물안전법령에서 유지관리업자를 「건설산업기본법」 제9조에 따라 등록한 유지관리업자로 정의하고 있었고, 구 「건설산업기본법 시행령」 부칙 제2조에서는 시설물 유지관리업의 업무내용, 등록기준 등을 규정하고 있는 별표 1 제2호거목 및 별표 2 제2호거목의 개정규정이 2023년 12월 31일까지 효력을 가진다고 규정하면서 같은 부칙 제7조에서는 종전 시설물유지관리업의 업종전환 특례⁶⁾를 규정하고 있으며, 같은 부칙 제10조제3항에서는 같은 부칙 제2조에 따른 시설물유지관리업의 유효기간 만료일 이후 다른 법령에서 “유지관리업자”를 인용하고 있는 경우에는 부칙 제7조에 따른 “업종전환 유지관리업자”를 인용한 것으로 본다고 규정하고 있는데, 그 유효기간 만료일인 2023년 12월 31일 이후에도 시행되던 종전 시설물안전법 제26조에서 관리주체는 안전점검 및 긴급안전점검을 국토안전관리원, 안전진단전문기관 또는 “유지관리업자”에게 대행하게 할 수 있다고 규정하여 여전히 유지관리업자를 인용하고 있으므로, 같은 규정에 따라 2023년 12월 31일 이후 업종전환 유지관리업자는 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검을 대행할 수 있으나, 업종미전환 유지관리업자는 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검을 대행할 수 없다고 할 것입니다.

결국 개정 시설물안전법 부칙 제3조제1항에서 규정하고 있는 유지관리업자는 같은 법 시행

6) 종전 시설물유지관리업자는 2023년 12월 31일까지 별표 1의 개정규정에 따른 종합공사를 시공하는 업종 중 건축공사업 또는 토목공사업으로 전환하거나, 같은 개정규정에 따른 전문공사를 시공하는 업종 중 일부로 전환하여 건설업 등록관청에 등록 신청할 수 있도록 하고, 건설업 등록관청은 업종을 전환하여 등록 신청한 자가 그 기준을 갖춘 경우에는 별표 2의 개정규정에 따른 등록기준을 갖춘 것으로 보아 해당 업종을 등록하도록 함

당시인 2024년 7월 17일 종전 시설물안전법 제26조에 따라 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검을 대행할 수 있는 업종전환 유지관리업자를 의미한다고 할 것이고, 이와 달리 개정 시설물안전법 부칙 제3조제2항에서 규정하고 있는 유지관리업자는 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 안전점검 등을 대행할 수 있는 유지관리업자로 규정되어 있지 않고, 이 법 시행 전에 체결한 시설물의 안전점검, 긴급안전점검 대행계약에 한정하여 해당 업무를 계속할 수 있도록 규정하고 있어 같은 조 제1항의 유지관리업자와 구분되는 자로 같은 법 시행 당시인 2024년 7월 17일 종전 시설물안전법 제26조에 따라 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검을 대행할 수 없는 업종미전환 유지관리업자를 의미한다고 할 것입니다.

또한 일반적으로 경과조치는 새로 제정되거나 개정된 법령에 의한 기득권 침해 방지 등의 정책적 필요에 의해 두는 것인데⁷⁾, 업종전환 유지관리업자는 구 「건설산업기본법 시행령」 부칙 제7조에 따른 신청 및 등록을 하여 개정 시설물안전법 시행 당시에도 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검을 대행할 수 있었던 자이므로, 개정 시설물안전법 부칙 제3조제1항에 따라 같은 법 제28조의2의 안전점검전문기관으로 등록한 것으로 보아 원칙적으로 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검 대행계약을 새롭게 체결할 수 있도록 하고, 업종미전환 유지관리업자는 구 「건설산업기본법 시행령」 부칙 제7조에 따른 신청 및 등록을 하지 않아 개정 시설물안전법 시행 당시 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검을 대행할 수 없었던 자로 개정 시설물안전법 부칙 제3조제2항에 따라 같은 법 시행 전에 체결한 시설물의 안전점검, 긴급안전점검 대행계약에 한정하여 해당 업무를 계속할 수 있도록 해석하는 것이 경과조치의 취지에도 부합한다고 할 것입니다.

한편 구 「건설산업기본법 시행령」 부칙 제10조제3항 및 개정 시설물안전법 부칙 제3조제2항의 문언 등에 따라 같은 항에 따른 유지관리업자는 업종전환 유지관리업자를 의미한다고 보는 의견이 있으나, 만약 업종전환 유지관리업자가 같은 항의 유지관리업자에 해당한다고 보아, 같은 법 시행 후에도 같은 법 시행 전에 체결한 시설물의 안전점검, 긴급안전점검 또는 유지관리의 대행계약에 한정하여 해당 업무를 계속할 수 있다고 해석하게 된다면, ① 업종전환 유지관리업자가 안전점검전문기관으로 등록한 것으로 보아 같은 법 시행 후에도 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검 대행계약을 새롭게 체결할 수 있도록 정하고 있는 같은 법 부칙 제3조제1항의 내용과 같은 조 제2항의 내용이 서로 모순되고, ② 업종전환 유지관리업자는 원칙적으로 구 「건설산업기본법 시행령」 부칙 제7조에 따라 건축공사업, 토목공사업 등으로 전환하여 등록한 건설사업자로⁸⁾ 개정 시설물안전법 시행 후 같은 법

7) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.643 참조

8) 다만 전환한 건설업종에 대하여 2026년 12월 31일 또는 2029년 12월 31일까지 해당 건설업종에 대하여 별표 2의 개정규정에

제39조제2항에 따라 새롭게 유지관리의 대행계약을 체결할 수 있다는 점⁹⁾과도 모순된다는 점에서, 조문의 체계적 해석상 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 시설물안전법 부칙 제3조제2항에서 규정하고 있는 “이 법 시행 당시 종전의 규정에 따른 유지관리업자”는 업종미전환 유지관리업자를 의미합니다.



관계법령

구 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(2024년 1월 16일 법률 제20044호로 일부개정되어 2024년 7월 17일 시행되기 전의 것)

제10조(설계도서 등의 열람) ① 제28조에 따라 등록한 안전진단전문기관(이하 “안전진단전문기관”이라 한다), 「국토안전관리원법」에 따른 국토안전관리원(이하 “국토안전관리원”이라 한다) 또는 「건설산업기본법」제9조에 따라 등록한 유지관리업자(이하 “유지관리업자”라 한다)는 안전점검·정밀안전진단 또는 긴급안전점검(이하 “안전점검등”이라 한다)이나 유지관리 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우 관리주체에게 해당 시설물의 설계·시공 및 감리와 관련된 서류의 열람이나 그 사본의 교부를 요청할 수 있다. 다만, 국방이나 그 밖의 보안상 비밀유지가 필요한 시설물은 관리주체나 관련 기관의 동의를 받아 이를 열람할 수 있다.

제26조(안전점검등의 대행) ① 관리주체는 안전점검 및 긴급안전점검을 국토안전관리원, 안전진단전문기관 또는 유지관리업자에게 대행하게 할 수 있다.

② ~ ④ (생 략)

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(2024년 1월 16일 법률 제20044호로 일부개정되어 2024년 7월 17일 시행된 것)

제26조(안전점검등의 대행) ① 관리주체는 안전점검 및 긴급안전점검을 국토안전관리원, 안전진단전문기관 또는 안전점검전문기관에 대행하게 할 수 있다.

② ~ ④ (생 략)

법률 제20044호 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 일부개정법률부칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 (생 략)

다른 등록기준을 갖춰야 함(구 「건설산업기본법 시행령」 부칙 제7조제1항 및 제3항 참조)
9) 헌법재판소 2023. 7. 20. 선고 2021헌마358 결정례 참조

제3조(유지관리업자에 관한 경과조치) ① 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검을 대행할 수 있는 유지관리업자는 제28조의2의 개정규정에 따른 안전점검 전문기관으로 등록한 것으로 본다. 다만, 이 법 시행일부터 1년 이내에 제28조의2의 개정규정에 따른 등록기준을 갖추어 새로이 등록하여야 한다.

② 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따른 유지관리업자는 이 법 시행 전에 체결한 시설물의 안전점검, 긴급안전점검 또는 유지관리의 대행계약에 한정하여 해당 업무를 계속할 수 있다.

③ 이 법 시행 전에 종전의 규정에 따라 시설물의 안전점검 또는 긴급안전점검을 대행할 수 있는 유지관리업자가 행한 행위 또는 해당 유지관리업자에 대하여 행하여진 행위는 이 법 시행 이후 제28조의2의 개정규정에 따라 등록한 안전점검전문기관이 행한 행위 또는 해당 안전점검전문기관에 대하여 행하여진 행위로 본다.

제4조 (생 략)

구 건설산업기본법 시행령(2020년 12월 29일 대통령령 제31328호로 일부개정되어 2022년 1월 1일 시행된 것)

[별표 1]

건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용(제7조 관련)

1. (생 략)

2. 전문공사를 시공하는 업종, 업무분야 및 업무내용

건설업종	업무분야	업무내용	건설공사의 예시
가. 지반조성·포장공사업	1) 토공사	땅을 굴착하거나 토사 등으로 지반을 조성하는 공사	굴착·성토(흙쌓기)·절토(흙깎기)·흙막이공사·철도도상자갈공사, 폐기물매립지에서의 굴착·선별·성토공사 등
(생 략)	(생 략)	(생 략)	(생 략)
거. 시설물유지관리업		시설물의 완공 이후 그 기능을 보전하고 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 시설물에 대하여 일상적으로 점검·정비하고 개량·보수·보강하는 공사로서 다음의 공사를 제외한 공사 가) 건축물의 경우 증축·개축·재축 및 대수선 공사 나) 건축물을 제외한 그 밖의 시설물의 경우 증설·확장공사 및 주요 구조부를 해체한 후 보수·보강 및 변경하는 공사 다) 전문건설업종 중 1개 업종의 업무내용만으로 행하여지는 건축물의 개량·보수·보강공사	

대통령령 제31328호 건설산업기본법 시행령 부칙

제1조(시행일) 이 영은 2022년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(시설물유지관리업의 유효기간) 별표 1 제2호거목 및 별표 2 제2호거목의 개정규정은 2023년 12월 31일까지 효력을 가진다.

제7조(시설물유지관리업의 업종전환에 관한 특례) ① 종전 시설물유지관리업자는 2023년 12월 31일까지 별표 1의 개정규정에 따른 종합공사를 시공하는 업종 중 건축공사업 또는 토목공사업으로 전환하거나, 같은 개정규정에 따른 전문공사를 시공하는 업종 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종(최대 3개까지로 한정한다)으로 전환하여 건설업 등록관청에 등록 신청할 수 있다.

1. ~ 6. (생 략)

② (생 략)

③ 건설업 등록관청은 제1항에 따라 업종을 전환하여 등록 신청한 자가 다음의 기준을 갖춘 경우에는 별표 2의 개정규정에 따른 등록기준을 갖춘 것으로 보아 해당 업종을 등록한다. 이 경우 업종을 전환하여 등록한 자(이하 “업종전환 시설물유지관리업자”라 한다)는 전환한 건설업종에 대하여 2026년 12월 31일(같은 법 제23조에 따라 공시된 시공능력 평가액이 해당 업종 사업자 평균액 미만인 경우 등 국토교통부장관이 정하여 고시하는 요건에 해당하는 업종전환 시설물유지관리업자의 경우는 2029년 12월 31일까지로 함)까지 해당 건설업종에 대하여 별표 2의 개정규정에 따른 등록기준을 갖춰야 한다.

제10조(다른 법령과의 관계)

①·② (생 략)

③ 부칙 제2조에 따른 시설물유지관리업의 유효기간 만료일 이후 다른 법령에서 「건설산업기본법」 제9조에 따라 등록한 유지관리업자를 인용하고 있는 경우에는 부칙 제7조에 따라 업종을 전환하여 등록한 건설사업자를 인용한 것으로 본다.

질의제목 21

▶ 안건번호 25-0141, 25-0295

민원인 - 가로주택정비사업의 사업시행자인 신탁업자는 「건축법」상 건축협정을 체결할 수 있는 소유자나 지상권자에 해당하는지(「건축법 시행령」 제110조의3제1항 등 관련)

01 질의요지

「건축법」 제77조의4제1항에서는 토지 또는 건축물의 소유자, 지상권자 등 대통령령으로 정하는 자(이하 “소유자등”이라 함)는 전원의 합의로 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 지구단위계획구역(제1호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역 또는 구역에서 건축물의 건축·대수선 또는 리모델링에 관한 협정을 체결할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제110조의3제1항에서는 소유자등을 각 호로 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 토지 또는 건축물의 소유자를, 같은 항 제2호에서는 토지 또는 건축물의 지상권자를 각각 규정하고 있는 한편,

「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」(이하 “소규모주택정비법”이라 함) 제19조제1항에서는 시장·군수등¹⁾은 가로주택정비사업²⁾의 조합설립을 위하여 같은 법 제23조에 따른 조합설립 동의요건 이상에 해당하는 자가 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 신탁업자를 사업시행자³⁾로 지정하는 것에 동의하는 때에는 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 신탁업자를 사업시행자로 지정하여 해당 사업을 시행하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제29조제1항 본문에서는 사업시행자는 소규모주택정비사업을 시행하는 경우에는 같은 법 제30조에 따른 사업시행계획서(이하 “사업시행계획서”라 함)에 정관등⁴⁾과 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수등에게 제출하고 사업시행계획인가를 받아야 한다고 규정하고 있는바,

소규모주택정비법 제19조제1항에 따라 가로주택정비사업의 사업시행자로 지정된 신탁업자인 사업시행자⁵⁾가 같은 법 제29조제1항에 따른 사업시행계획인가(이하 “사업시행계획인가”라 함)를 받은 경우로서 사업시행구역에 인접한 토지 또는 건축물의 소유자등과 「건축법」

1) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음

2) 소규모주택정비법에 따른 소규모주택정비사업의 한 유형으로, 가로(街路)구역에서 종전의 가로를 유지하면서 소규모로 주거환경을 개선하기 위한 사업을 말하며(소규모주택정비법 제2조제1항제3호나목 참조), 이하 같음

3) 소규모주택정비사업을 시행하는 자를 말하며(소규모주택정비법 제2조제1항제5호 참조), 이하 같음

4) 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제11호에 따른 정관등을 말함

5) 신탁계약 등에 따라 신탁업자인 사업시행자에게 건축협정을 체결할 수 있는 권리에 관한 사항까지 위탁된 것은 아님을 전제함

제77조의4에 따른 건축협정(이하 “건축협정”이라 함)을 체결하려는 경우,⁶⁾

가. 신탁업자인 사업시행자는 건축협정을 체결할 수 있는 자인 「건축법 시행령」 제110조의3 제1항제1호의 소유자에 해당하는지?

나. 신탁업자인 사업시행자는 건축협정을 체결할 수 있는 자인 「건축법 시행령」 제110조의3 제1항제2호의 지상권자에 해당하는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

이 사안의 경우, 신탁업자인 사업시행자는 건축협정을 체결할 수 있는 자인 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제1호의 소유자에 해당하지 않습니다.

나. 질의 나에 대해

이 사안의 경우, 신탁업자인 사업시행자는 건축협정을 체결할 수 있는 자인 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제2호의 지상권자에 해당하지 않습니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

먼저 「건축법」 제77조의4에 따르면 건축물의 건축·대수선 또는 리모델링에 관한 건축협정은 해당 구역에 속한 토지 또는 건축물의 소유자등 전원의 합의로 자율적인 주택정비 등을 위해 체결하는 것으로서,⁷⁾ 「건축법」 제77조의10제1항에 따르면 건축협정이 체결된 지역 또는 구역에서 건축물의 건축·대수선 또는 리모델링 등을 하려는 소유자등은 그 건축협정에 따라야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제77조의13에 따르면 건축협정을 체결한 경우 지하층의 설치나 건폐율 등을 개별 건축물마다 적용하지 아니하고 통합적용하는 등의

6) 「건축법」 제77조의4제1항 각 호의 구역에 해당하는지 여부 등 건축협정 체결에 관한 다른 요건은 충족됨을 전제함

7) 법제처 2023. 2. 20. 회신 23-0090 해석례 참조

특례를 적용받을 수 있게 되는데, 이를 종합하여 보면 건축협정은 건축·대수선 또는 리모델링 등 실질적인 건축행위에 직접적인 영향을 미치게 되고, 건축협정을 체결한 자가 이를 따라야 하는 법적 의무가 발생하는 등의 효과를 수반하므로, 「건축법 시행령」 제110조의3제1항 제1호에 따라 건축협정을 체결할 수 있는 주체가 되는 “소유자”는 해당 구역에서 건축이나 대수선 등의 행위를 할 수 있는 실질적인 권리를 가지며, 건축이나 대수선 등의 행위를 통한 이익과 비용이 최종적으로 귀속되는 자를 의미한다고 할 것입니다.

그리고 소규모주택정비법 제2조제1항제6호 단서에 따르면 소규모주택정비법상 신탁업자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 함) 제8조제7항에 따른 신탁업자를 의미하고, 자본시장법 제6조제9항 및 제9조제24항에 따르면 신탁업은 「신탁법」 제2조의 신탁을 영업으로 하는 금융투자업을 의미하므로, 소규모주택정비법에 따른 신탁업자인 사업시행자는 그 위탁자인 토지등소유자⁸⁾와 「신탁법」 제2조에 따른 신탁관계를 형성하게 되고, 이에 따라 신탁의 목적과 그 법률관계의 명확성을 위해 그 소유권이 수탁자인 사업시행자(신탁업자)에게 이전되는 한편, 수탁자가 대내외적으로 신탁재산에 대한 관리권을 가지게 됩니다.⁹⁾

그런데 「신탁법」에 따르면 수탁자는 누구의 명의(名義)로도 신탁재산을 고유재산으로 하거나 신탁재산에 관한 권리를 고유재산에 귀속시키지 못하고(제34조제1항제1호), 신탁재산을 수탁자의 고유재산과 구별하여 관리(제37조제1항)해야 하는 등 신탁재산의 권리·의무관계에 관하여 수탁자의 고유재산과 구분하여 규정하고 있는바, 비록 「신탁법」에 따른 신탁관계에 의해 신탁재산이 수탁자의 소유라 하더라도 그에 관한 권리관계를 수탁자의 고유재산과 동일하게 취급할 수는 없고¹⁰⁾, 「신탁법」은 신탁에 관한 사법(私法)적 법률관계를 규정하는 것을 목적으로 하는 법률인 반면, 「건축법」은 건축물의 대지·구조·설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적으로 하는 법률로서 두 법률은 그 입법목적이 다른바, 「건축법」에 따른 소유관계가 「신탁법」에 따른 사법(私法)관계와 동일하게 볼 수는 없다는 점¹¹⁾ 등을 종합하여 보면, 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제1호에 따라 건축협정을 체결할 수 있는 주체가 되는 “소유자”를 판단할 때에는 건축이나 대수선 등의 행위를 할 수 있는 실질적인 권리를 가지는지 여부, 해당 행위를 통한 이익과 비용이 최종적으로 귀속되는 자인지 여부 등을

8) 소규모주택정비법 제2조제1항제6호에 따른 토지등소유자를 말하며, 이하 같음.

9) 법제처 2021. 5. 12. 화신 21-0186 해석례 참조

10) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013두15262 판결례 참조

11) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013두15262 판결례 및 법제처 2021. 9. 14. 화신 21-0428 해석례 등 참조

종합적으로 고려해야 할 것입니다.

이 경우 이 사안의 신탁업자인 사업시행자는 가로주택정비사업의 추진을 위해 토지 또는 건축물의 소유자등으로부터 소규모주택정비법에 따라 신탁을 받은 것인데, 소규모주택정비법 제2조제1항제6호 본문에서는 “토지등소유자”란 같은 호 각 목에서 정하는 자를 말한다고 규정하면서, 같은 호 단서에서는 신탁업자가 사업시행자로 지정된 경우 토지등소유자가 가로주택정비사업 등 소규모주택정비사업을 목적으로 신탁업자에게 신탁한 토지 또는 건축물에 대하여는 위탁자를 토지등소유자로 본다고 규정하고 있는바, 해당 규정은 당초 도시정비법에서 신탁업자를 사업시행자로 지정할 수 있도록 하는 제도를 신설하면서, 정비사업에 대한 실질적인 이해관계인인 위탁자의 의사가 반영되어야 한다는 점을 고려하여 수탁자를 소유권자로 보는 통상적인 신탁관계와 달리 ‘정비사업에 관한 부동산의 신탁관계’에서는 위탁자를 ‘토지등소유자’로 보도록 하였고¹²⁾, 이후 소규모주택정비법이 도시정비법으로부터 분리되어 별도의 법률로 제정되면서 이러한 취지의 규정이 그대로 포함된 것인 점,¹³⁾ 가로주택정비사업은 주민합의체를 구성(제22조)하거나 조합설립인가를 신청(제23조)하는 경우 및 사업시행계획인가를 신청(제29조)하는 경우 등 사업 추진 과정에서 일정 비율 이상 토지등소유자의 동의를 받도록 규정하고 있는바, 이는 ‘직접적인 이해관계’가 있는 자가 가로주택정비사업을 추진하도록 하고 이해관계인의 의견을 사업에 반영하려는 취지로 보이는 점¹⁴⁾ 등을 고려하면 이 사안과 같이 소규모주택정비법에 따른 가로주택정비사업을 건축협정을 통한 자율적 주택정비와 함께 추진하는 경우에도 가로주택정비사업에서와 같이 직접적인 이해관계가 있는 자, 즉 건축협정을 통한 자율적 주택정비에 따른 이익과 비용이 최종적으로 귀속되는자인 ‘위탁자’의 의사가 반영될 수 있어야 할 것입니다.

또한 ① 건축협정은 건축협정이 체결된 구역을 하나의 필지로 보아 건축을 할 수 있도록 하는 등 특례¹⁵⁾를 부여하는 것으로,¹⁶⁾ 건축협정이 체결되면 주로 가로주택정비사업의 사업시행구역과 그 외의 토지를 합쳐 건축협정구역으로 하고, 이를 통할하여 유기적으로 건축이나 대수선 등이 이루어지도록 하고 있는바, 이에 따라 가로주택정비사업의 사업시행구역 내의 토지 또는 건축물을 위탁한 토지등소유자는 건축협정구역에서 이루어지는 건축이나 대수선 등의 영향을 직접적으로 받게 되는 점, ② 토지등소유자가 신탁업자인 사업시행자에게

12) 2014. 11. 27. 의안번호 1912721호로 발의된 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안에 대한 국토교통위원회 심사보고서 참조

13) 2017. 2. 8. 법률 제14569호로 제정된 소규모주택정비법 제정이유 참조

14) 법제처 2023. 9. 7. 회신 23-0538 해석례 등 참조

15) 건축법 제77조의13

16) 2013. 1. 18. 의안번호 제1903351호로 발의된 건축법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 검토보고서 참조

토지 또는 건축물을 신탁한 것은 토지등소유자의 의사에 기하여 추진되는 가로주택정비사업의 시행을 위한 수단이라 할 것이므로,¹⁷⁾ 신탁재산의 처분이나 사용 등은 사업시행구역에서 이루어지는 가로주택정비사업의 추진으로 한정되는데, 신탁업자인 사업시행자가 건축협정을 임의로 체결할 수 있게 되면 이는 사실상 토지등소유자가 신탁업자인 사업시행자에게 신탁한 업무 범위를 벗어나게 될 수도 있다는 점, ③ 소규모주택정비법 제19조제1항에서는 같은 법 제23조에 따라 토지등소유자의 10분의 8 이상 및 토지면적의 3분의 2 이상의 토지소유자 동의를 받았을 때 신탁업자를 사업시행자로 지정할 수 있도록 하고 있어 신탁업자가 토지등소유자 전체의 동의를 받지 않더라도 사업시행자가 될 수 있도록 하고 있는 반면, 「건축법」 제77조의4제1항에서는 소유자등 전원의 합의가 있을 때 건축협정을 체결할 수 있도록 규정하고 있는바, 그렇다면 신탁업자인 사업시행자가 사업시행구역 내 토지등소유자의 전원의 동의를 받지 않은 경우도 있을 수 있음에도 불구하고 이러한 사업시행자가 소유자등 전원의 합의를 필요로 하는 건축협정의 체결 주체가 될 수 있다고 보는 것은 불합리한 점 등도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 신탁업자인 사업시행자는 건축협정을 체결할 수 있는 자인 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제1호의 소유자에 해당하지 않습니다.

나. 질의 내에 대해

먼저 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제2호에 따른 지상권자는 문언상 실제 해당 토지의 지상권을 가지는 자를 의미한다는 것이 명확한데, 지상권은 「민법」 제279조에 따르면 타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리로서 부동산의 사용가치를 독점적으로 지배하는 것을 내용으로 하는 용익물권¹⁸⁾을 의미하는바,¹⁹⁾ 이러한 지상권은 「민법」 제187조에 따라 상속, 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득이 있을 때 법정지상권으로서 등기가 없더라도 취득될 수 있으나, 일반적인 경우에는 「민법」 제186조에 따라 지상권설정계약과 그 등기가 필요합니다.

그런데 신탁업자인 사업시행자가 소규모주택정비법 제29조에 따라 사업시행계획인가를 받게 된다고 하더라도 이러한 인가는 행정처분에 해당하므로 민법상 계약 중 하나인 지상권설정계약을 체결하거나 그 설정 등기를 한 것으로 보이지 않고, 소규모주택법령에서는

17) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013두15262 판결례 참조

18) 타인의 토지나 건물 등 부동산을 일정의 목적에 사용·수익하는 권리 중 물권에 관한 것을 가리킴

19) 법제처 2020. 5. 11. 회신 20-0111 해석례 참조

사업시행계획인가를 받았을 때 지상권설정계약 및 그 등기를 한 것으로 보는 명시적인 규정이 있거나 이 사안의 사업시행계획인가를 받았다고 하여 법정지상권이 설정되는 효과가 있는 것도 아닌바, 이 사안과 같이 신탁업자인 사업시행자가 소규모주택정비법 제29조에 따라 사업시행계획인가를 받게 되더라도 그 인가를 받았다는 사실만으로 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제2호에 따른 지상권자에 해당하지는 않는다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 신탁업자인 사업시행자는 건축협정을 체결할 수 있는 자인 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제2호의 지상권자에 해당하지 않습니다.



관계법령

건축법

제77조의4(건축협정의 체결) ① 토지 또는 건축물의 소유자, 지상권자 등 대통령령으로 정하는 자(이하 “소유자등”이라 한다)는 전원의 합의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역 또는 구역에서 건축물의 건축·대수선 또는 리모델링에 관한 협정(이하 “건축협정”이라 한다)을 체결할 수 있다.

1. ~ 5. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

건축법 시행령

제110조의3(건축협정의 체결) ① 법 제77조의4제1항 각 호 외의 부분에서 “토지 또는 건축물의 소유자, 지상권자 등 대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 자를 말한다.

1. 토지 또는 건축물의 소유자(공유자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)

2. 토지 또는 건축물의 지상권자

3. 그 밖에 해당 토지 또는 건축물에 이해관계가 있는 자로서 건축조례로 정하는 자 중 그 토지 또는 건축물 소유자의 동의를 받은 자

② (생략)

빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 5. (생략)

6. “토지등소유자”란 다음 각 목에서 정하는 자를 말한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항에 따른 신탁업자(이하 “신탁업자”라 한다)가 사업시행자로 지정된 경우 토지등소유자가 소규모주택정비사업을 목적으로 신탁업자에게 신탁한 토지 또는 건축물에 대하여는 위탁자를 토지등소유자로 본다.

가. 자율주택정비사업, 가로주택정비사업 또는 소규모재개발사업은 사업시행구역에 위치한 토지 또는 건축물의 소유자, 해당 토지의 지상권자

나. 소규모재건축사업은 사업시행구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자

7. ~ 9. (생략)

② (생략)

제19조(소규모주택정비사업의 지정개발자 지정) ① 시장·군수등은 가로주택정비사업, 소규모재건축사업 또는 소규모재개발사업의 조합설립을 위하여 제23조에 따른 조합설립 동의요건 이상에 해당하는 자가 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 신탁업자(이하 “지정개발자”라 한다)를 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때에는 지정개발자를 사업시행자로 지정하여 해당 사업을 시행하게 할 수 있다.

② ~ ④ (생략)

제29조(사업시행계획인가) ① 사업시행자(사업시행자가 시장·군수등인 경우는 제외한다)는 소규모주택정비사업을 시행하는 경우에는 제30조에 따른 사업시행계획서(이하 “사업시행계획서”라 한다)에 정관등과 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수등에게 제출하고 사업시행계획인가를 받아야 하며, 인가받은 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다.

② ~ ⑦ (생략)

질의제목 22

▶ 안전번호 25-0146, 25-0240

인천광역시 남동구 - 「건축법」에 따른 이행강제금 부과 시 법령 등에서 정한 감경비율 이상 감경하거나 감경사유 외의 사유로 감경할 수 있는지 등(「건축법」 제80조의2 등 관련)

01 질의요지

「건축법」 제80조제1항 본문에서는 허가권자¹⁾는 같은 법 제79조제1항에 따라 시정명령을 받은 후 시정기간 내에 시정명령을 이행하지 않은 건축주등²⁾에 대해서는 그 시정명령의 이행에 필요한 상당한 이행기한을 정하여 그 기한까지 시정명령을 이행하지 않으면 같은 법 제80조제1항 각 호의 이행강제금을 부과한다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 연면적(공동주택의 경우에는 세대 면적을 기준으로 함)이 60제곱미터 이하인 주거용 건축물과 같은 항 제2호 중 주거용 건축물로서 대통령령으로 정하는 경우에는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액의 2분의 1의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 금액을 부과한다고 규정하고 있고,

「건축법」 제80조의2제1항 본문 및 제2호에서는 허가권자는 같은 법 제80조에 따른 이행강제금을 위반 동기, 위반 범위 및 위반 시기 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우(같은 법 제80조제2항에 해당하는 경우는 제외함)에는 100분의 75의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율을 감경할 수 있다고 규정하고 있는바,

가. 「건축법」 제80조에 따른 이행강제금의 부과금액 또는 감경비율과 관련하여, 허가권자는

- ① 같은 법 제80조제1항 단서에 따른 경우³⁾에 대하여 같은 항 단서 및 해당 지방자치단체의 조례로 정한 금액 이하의 이행강제금을 부과하거나(같은 법 제80조의2에 따라 감경하는 경우는 제외함), ② 같은 법 제80조의2제1항제2호에 따른 경우⁴⁾에 대하여 같은 호에 따른 비율⁵⁾ 이상 감경할 수 있는지?

1) 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장을 말하며(「건축법」 제4조의4제1항 참조), 이하 같음

2) 건축물의 건축주·공사시공자·현장관리인·소유자·관리자 또는 점유자를 말하며(「건축법」 제79조제1항 참조), 이하 같음

3) 「건축법」 제80조제1항 단서 및 같은 법 시행령 제115조의2제1항(같은 항 제5호의 위임에 따른 건축조례를 포함함)에서 정하는 경우를 의미하며, 이하 같음

4) 「건축법」 제80조의2제1항제2호의 위임에 따른 「건축법 시행령」 제115조의4제1항(같은 항 제7호의 위임에 따른 건축조례를 포함함)에서 정하는 경우를 의미하며, 이하 같음

나. 「건축법」 제80조에 따른 이행강제금의 감경사유 등과 관련하여, 허가권자는 같은 조 제1항 단서에 따른 경우 또는 같은 법 제80조의2에 따른 경우⁶⁾ 등 법령 등⁷⁾에서 정한 사유에 해당하지 않더라도 같은 법 제80조제1항 각 호의 이행강제금보다 낮은 금액을 부과할 수 있는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

허가권자는 ① 「건축법」 제80조제1항 단서에 따른 경우에 대하여 이행강제금을 부과할 때, 같은 법 제80조의2에 따라 감경하는 경우를 제외하고는 같은 법 제80조제1항 단서 및 해당 지방자치단체의 조례로 정한 금액 이하의 이행강제금을 부과할 수 없으며, ② 같은 법 제80조의2제1항제2호에 따른 경우에 대하여 이행강제금을 감경하려는 때에도 같은 호에 따른 비율 이상 감경할 수 없습니다.

나. 질의 나에 대해

허가권자는 「건축법」 제80조에 따른 이행강제금을 부과할 때, 같은 조 제1항 단서에 따른 경우 또는 같은 법 제80조의2에 따른 경우 등 법령 등에서 정한 사유에 해당하지 않는 경우에는 같은 법 제80조제1항 각 호의 이행강제금보다 낮은 금액을 부과할 수 없습니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

먼저 ① 「건축법」 제80조제1항 단서에서는 연면적이 60제곱미터 이하인 주거용 건축물 등 특정한 경우에 대하여 같은 항 각 호의 구분에 따른 이행강제금의 2분의 1의 범위에서 해당

5) 「건축법」 제80조의2제1항제2호의 위임에 따른 「건축법 시행령」 제115조의4제2항(같은 항 제2호의 위임에 따른 건축조례를 포함함)에서 정하는 비율을 의미하며, 이하 같음

6) 「건축법」 제80조의2제1항제2호의 위임에 따른 「건축법 시행령」 제115조의4제1항(같은 항 제7호의 위임에 따른 건축조례를 포함함)에서 정하는 경우를 포함하며, 이하 같음

7) 법률 및 그 위임에 따른 하위법령·조례를 의미하며, 이하 같음

지방자치단체의 조례로 정하는 금액을 부과하도록 정하고 있고, ② 같은 법 제80조의2제1항제2호 및 그 위임에 따른 같은 법 시행령 제115조의4제2항에서는 이행강제금 감경 대상이 되는 위반행위를 유형별로 구분하고 각각에 대한 감경비율을 특정하여 정하고 있는 점 등 관련 규정의 문언, 체계 및 내용에 비추어 보면, 「건축법」 및 그 위임에 따른 대통령령·조례에서 정한 이행강제금의 산정 및 감경기준은 각 위반행위 유형별로 계산된 특정한 금액 및 특정한 감경비율을 규정한 것이므로, 허가권자에게 이와 다른 이행강제금 부과금액이나 감경비율을 결정할 재량권은 없다고 보아야 할 것입니다.⁸⁾

그리고 「건축법」상 이행강제금 산정 및 감경기준에 관한 입법연혁과 취지를 살펴보면, 종전에는 건폐율이나 용적률을 초과하여 건축된 경우 또는 허가를 받지 않거나 신고를 하지 않고 건축한 경우에 대해서는 허가권자가 일정한 상한기준 내에서 위반내용에 따라 이행강제금을 부과할 수 있도록 재량을 부여했으나⁹⁾, 실제로 대부분의 지방자치단체에서 합리적인 감경부과기준을 마련하지 못하거나 이행강제금의 차등 부과 시 민원이 제기될 가능성 등을 우려해 법령에서 정한 상한기준에 해당하는 금액을 일률적으로 적용하여 부과하는 문제가 발생함에 따라, 2015년 8월 11일 법률 제13471호로 「건축법」을 일부개정하여 위반내용에 따른 이행강제금의 구체적인 산정기준을 대통령령으로 정하도록 위임하고(법 제80조제1항제1호 개정), 위반 동기·내용·시기·규모 등을 고려하여 이행강제금 부과에 관한 감경 특례를 두되 구체적인 감경비율은 법률 및 그 위임에 따른 대통령령·건축조례에서 직접 정하도록 함(법 제80조의2 신설)으로써 이행강제금 제도 운영의 현실적인 문제점을 시정하려 한 점,¹⁰⁾ 이후 2024년 3월 26일 법률 제20424호로 「건축법」을 다시 개정하여 위반동기, 위반범위 및 위반시기 등을 고려해 이행강제금을 감경하는 경우의 감경비율 상한을 2분의 1에서 100분의 75로 상향(법 제80조의2제1항제2호 개정)한 사실¹¹⁾ 등을 알 수 있는바, 허가권자가 이행강제금을 부과할 때 법령상 명시적인 근거가 없더라도 ① 법령 등에서 정한 금액 이하로 부과하거나 ② 법령 등에서 정한 비율 이상으로 감경하여 부과할 수 있다고 보는 것은 이행강제금의 구체적인 산정기준 및 감경비율을 법령 등에서 직접 정하게 하고, 감경비율의 상향이 필요한 경우에는 법령 등을 개정함으로써 상향한 「건축법」상 이행강제금 제도의 입법연혁 및 취지에 비추어 타당하지 않습니다.

8) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두8653 판결례 및 대법원 2014. 12. 24. 선고 2011두23580 판결례 등 참조

9) 구 「건축법」 (2015. 8. 11. 법률 제13471호로 개정되기 전의 것) 제80조제1항제1호 참조

10) 2015. 8. 11. 법률 제13471호로 일부개정된 「건축법」 개정이유 및 주요내용, 2016. 2. 12. 대통령령 제26974호로 일부개정된 「건축법 시행령」 개정이유 및 주요내용, 2014. 8. 21. 의안번호 제1911440호로 발의된 주택법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 및 2013. 11. 7. 의안번호 제1907645호로 발의된 건축법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

11) 2024. 3. 26. 법률 제20424호로 일부개정된 「건축법」 개정이유 및 주요내용 참조

아울러 이행강제금은 일정한 기한까지 의무를 이행하지 않을 때에는 일정한 금전적 부담을 과할 뜻을 미리 제고함으로써 의무자에게 심리적 압박을 주어 장래에 그 의무를 이행하게 하려는 행정상 간접강제 수단의 하나로, 이행강제금이 실효성을 가지기 위해서는 의무불이행자가 위법한 상태를 유지하는 것을 단념하고 의무를 이행하게 할 수 있는 적정한 수준의 금액으로 부과될 필요가 있는바,¹²⁾ 법령 등에서 정한 적정 수준의 금액 또는 비율 이상 이행강제금을 감경하는 것은 이행강제금의 부과 목적을 형해화할 우려가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 허가권자는 ① 「건축법」 제80조제1항 단서에 따른 경우에 대하여 이행강제금을 부과할 때, 같은 법 제80조의2에 따라 감경하는 경우를 제외하고는 같은 법 제80조제1항 단서 및 해당 지방자치단체의 조례로 정한 금액 이하의 이행강제금을 부과할 수 없으며, ② 같은 법 제80조의2제1항제2호에 따른 경우에 대하여 이행강제금을 감경하려는 때에도 같은 호에 따른 비율 이상 감경할 수 없습니다.

나. 질의 내에 대해

법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 된다고 할 것인데,¹³⁾ 「건축법」에서는 허가권자로 하여금 같은 법 제79조제1항에 따라 시정명령을 받은 후 시정기간 내에 시정명령을 이행하지 않은 건축주 등에 대하여 같은 법 제80조제1항 본문에 따라 같은 항 각 호의 이행강제금을 부과하게 하는 것을 원칙으로 하고, 다만 같은 항 단서에 따른 경우에는 같은 항 각 호의 이행강제금의 2분의 1의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 금액을 부과하도록 예외를 정하고 있으며, 다시 같은 법 제80조의2에 따라 같은 법 제80조에 따른 이행강제금을 감경할 수 있는 예외를 정하고 있는바, 건축법령에서는 이행강제금의 원칙적인 금액과 예외적으로 이행강제금을 감경하려는 경우 그 감경사유 및 비율을 규정하고 있으므로, 예외적으로 이행강제금을 감경하는 경우에 감경사유에 해당하지 않더라도 법령상 근거 없이 낮은 금액을 부과하는 것은 명확한 기준이나 합리적인 이유 없이 감경사유를 확대하여 해석하는 것으로서 타당하지 않다고 할 것입니다.

특히 「건축법」에서는 같은 법 제80조제1항 각 호의 이행강제금보다 낮은 금액을 부과하거나 감경할 수 있는 위반행위를 유형별로 특정하여 연면적이 60제곱미터 이하인

12) 헌법재판소 2011. 10. 25. 선고 2009헌바140 결정례 참조

13) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

주거용 건축물 등인 경우(법 제80조제1항 단서), 축사 등 농업용·어업용 시설로서 500제곱미터¹⁴⁾ 이하인 경우(법 제80조의2제1항제1호), 위반 동기, 위반 범위 및 위반 시기 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우(법 제80조의2제1항제2호) 등으로 제한적으로 열거하고 있고, 그에 따른 감경금액이나 감경비율 또한 특정하여 규정하고 있는바, 이와 같은 관련 규정의 문언, 체계 및 내용에 비추어 보면 허가권자에게 이행강제금을 법령 등에서 정한 금액과 달리 부과할 수 있는 예외사유를 추가할 재량권은 없다고 보아야 할 것입니다.¹⁵⁾

그리고 「건축법」상 이행강제금 산정·감경기준에 관한 입법연혁 및 취지를 살펴보면, 종전에는 건폐율이나 용적률을 초과하여 건축된 경우 또는 허가를 받지 않거나 신고를 하지 않고 건축한 경우에 대해서는 허가권자가 일정한 상한기준 내에서 위반내용에 따라 이행강제금을 부과할 수 있도록 재량을 부여했으나¹⁶⁾, 실제로 대부분의 지방자치단체에서 합리적인 감경부과기준을 마련하지 못하거나 이행강제금의 차등 부과 시 민원이 제기될 가능성 등을 우려해 법령에서 정한 상한기준에 해당하는 금액을 일률적으로 적용하여 부과하는 문제가 발생함에 따라, 2015년 8월 11일 법률 제13471호로 「건축법」을 일부개정하여 위반내용에 따른 이행강제금의 구체적인 산정기준을 대통령령으로 정하도록 위임하고(법 제80조제1항제1호 개정), 위반 동기·내용·시기·규모 등을 고려하여 이행강제금 부과에 관한 감경 특례를 두되 구체적인 감경비율은 법률 및 그 위임에 따른 대통령령·건축조례에서 직접 정하도록 함(법 제80조의2 신설)으로써 이행강제금 제도 운영의 현실적인 문제점을 시정하려 한 점,¹⁷⁾ 이에 따라 2016년 2월 11일 대통령령 제26974호로 일부개정된 「건축법 시행령」에서 이행강제금을 감경할 수 있는 사유를 위반행위 후 소유권이 변경된 경우나 임차인이 있어 현실적으로 임대기간 중 위반내용을 시정하기 어려운 특수한 사정이 있는 경우 등으로 규정하였고¹⁸⁾, 이후 2018년 9월 4일 대통령령 제29136호로 「건축법 시행령」을 다시 개정하여 이행강제금을 감경할 수 있는 사유에 무허가·무신고 가축분뇨 배출시설의 설치자가 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」에 따라 허가신청을 하거나 신고한 경우를 추가한 사실(영 제115조의4제1항제6호의2 신설)¹⁹⁾ 등을 알 수 있는바,

14) 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권 외의 지역에서는 1천제곱미터

15) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두8653 판결례 및 대법원 2014. 12. 24. 선고 2011두23580 판결례 등 참조

16) 구 「건축법」 (2015. 8. 11. 법률 제13471호로 일부개정되기 전의 것) 제80조제1항제1호 참조

17) 2015. 8. 11. 법률 제13471호로 일부개정된 「건축법」 개정이유 및 주요내용, 2016. 2. 12. 대통령령 제26974호로 일부개정된 「건축법 시행령」 개정이유 및 주요내용, 2014. 8. 21. 의안번호 제1911440호로 발의된 주택법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 및 2013. 11. 7. 의안번호 제1907645호로 발의된 건축법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

18) 2016. 2. 11. 대통령령 제26974호로 개정되어 2016. 2. 12. 시행된 「건축법 시행령」 개정이유 및 주요내용 참조

19) 2018. 9. 4. 대통령령 제29136호로 일부개정된 「건축법 시행령」 개정이유 및 주요내용 참조

허가권자가 이행강제금을 부과할 때 법령 등에서 정한 명시적인 사유가 없더라도 「건축법」 제80조제1항 각 호의 이행강제금보다 낮은 금액을 부과할 수 있다고 보는 것은 위반내용에 따른 이행강제금의 구체적인 산정기준 및 감경사유를 법령 등에서 직접 정하게 하고, 감경사유의 추가가 필요한 경우에는 법령 등을 개정함으로써 추가한 「건축법」상 이행강제금 제도의 입법연혁 및 취지에 비추어 타당하지 않습니다.

아울러 이행강제금은 일정한 기한까지 의무를 이행하지 않을 때에는 일정한 금전적 부담을 과할 뜻을 미리 제고함으로써 의무자에게 심리적 압박을 주어 장래에 그 의무를 이행하게 하려는 행정상 간접강제 수단의 하나로, 이행강제금이 실효성을 가지기 위해서는 의무불이행자가 위법한 상태를 유지하는 것을 단념하고 의무를 이행하게 할 수 있는 적절한 수준의 금액으로 부과될 필요가 있는바,²⁰⁾ 법령 등에서 정한 적정 수준의 금액 또는 비율 이상 이행강제금을 감경하는 것은 이행강제금의 부과 목적을 형해화할 우려가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 허가권자는 「건축법」 제80조에 따른 이행강제금을 부과할 때, 같은 조 제1항 단서에 따른 경우 또는 같은 법 제80조의2에 따른 경우 등 법령 등에서 정한 사유에 해당하지 않는 경우에는 같은 법 제80조제1항 각 호의 이행강제금보다 낮은 금액을 부과할 수 없습니다.



관계법령

건축법

제80조(이행강제금) ① 허가권자는 제79조제1항에 따라 시정명령을 받은 후 시정기간 내에 시정명령을 이행하지 아니한 건축주등에 대하여는 그 시정명령의 이행에 필요한 상당한 이행기한을 정하여 그 기한까지 시정명령을 이행하지 아니하면 다음 각 호의 이행강제금을 부과한다. 다만, 연면적(공동주택의 경우에는 세대 면적을 기준으로 한다)이 60제곱미터 이하인 주거용 건축물과 제2호 중 주거용 건축물로서 대통령령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액의 2분의 1의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 금액을 부과한다.

1. 건축물이 제55조와 제56조에 따른 건폐율이나 용적률을 초과하여 건축된 경우 또는 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축된 경우에는 「지방세법」에 따라 해당 건축물에 적용되는 1제곱미터의 시가표준액의 100분의 50에 해당하는 금액에 위반면적을 곱한 금액 이하의 범위에서 위반 내용에 따라 대통령령으로 정하는 비율을 곱한 금액
2. 건축물이 제1호 외의 위반 건축물에 해당하는 경우에는 「지방세법」에 따라 그 건축물에 적용되는 시가표준액에 해당하는 금액의 100분의 10의 범위에서 위반내용에 따라 대통령령으로 정하는

20) 헌법재판소 2011. 10. 25. 선고 2009헌바140 결정례 참조

금액

② 허가권자는 영리목적을 위한 위반이나 상습적 위반 등 대통령령으로 정하는 경우에 제1항에 따른 금액을 100분의 100의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 가중하여야 한다.

③ ~ ⑦ (생략)

제80조의2(이행강제금 부과에 관한 특례) ① 허가권자는 제80조에 따른 이행강제금을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 감경할 수 있다. 다만, 지방자치단체의 조례로 정하는 기간까지 위반내용을 시정하지 아니한 경우는 제외한다.

1. 축사 등 농업용·어업용 시설로서 500제곱미터(「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권 외의 지역에서는 1천제곱미터) 이하인 경우는 5분의 1을 감경
2. 그 밖에 위반 동기, 위반 범위 및 위반 시기 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우(제80조제2항에 해당하는 경우는 제외한다)에는 100분의 75의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율을 감경

② 허가권자는 법률 제4381호 건축법개정법률의 시행일(1992년 6월 1일을 말한다) 이전에 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 주거용 건축물에 관하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제80조에 따른 이행강제금을 감경할 수 있다.

건축법 시행령

제115조의2(이행강제금의 부과 및 징수) ① 법 제80조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 법 제22조에 따른 사용승인을 받지 아니하고 건축물을 사용한 경우
2. 법 제42조에 따른 대지의 조경에 관한 사항을 위반한 경우
3. 법 제60조에 따른 건축물의 높이 제한을 위반한 경우
4. 법 제61조에 따른 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한을 위반한 경우
5. 그 밖에 법 또는 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우(별표 15 위반 건축물란의 제1호의2, 제4호부터 제9호까지의 규정에 해당하는 경우는 제외한다)로서 건축조례로 정하는 경우

②·③ (생략)

제115조의4(이행강제금의 감경) ① 법 제80조의2제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 위반행위 후 소유권이 변경된 경우
2. 임차인이 있어 현실적으로 임대기간 중에 위반내용을 시정하기 어려운 경우(법 제79조제1항에 따른 최초의 시정명령 전에 이미 임대차계약을 체결한 경우로서 해당 계약이 종료되거나 갱신되는 경우는 제외한다) 등 상황의 특수성이 인정되는 경우
3. 위반면적이 30제곱미터 이하인 경우(별표 1 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 건축물로 한정하며, 「집합건축물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 적용을 받는 집합건축물은 제외한다)
4. 「집합건축물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 적용을 받는 집합건축물의 구분소유자가 위반한 면적이 5제곱미터 이하인 경우(별표 1 제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 건축물로 한정한다)
5. 법 제22조에 따른 사용승인 당시 존재하던 위반사항으로서 사용승인 이후 확인된 경우

6. 법률 제12516호 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제9조에 따라 같은 조 제1항 각 호에 따른 기간(같은 조 제3항에 따른 환경부령으로 정하는 규모 미만의 시설의 경우 같은 항에 따른 환경부령으로 정하는 기한을 말한다) 내에 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제11조에 따른 허가 또는 변경허가를 받거나 신고 또는 변경신고를 하려는 배출시설(처리시설을 포함한다)의 경우

6의2. 법률 제12516호 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제10조의2에 따라 같은 조 제1항에 따른 기한까지 환경부장관이 정하는 바에 따라 허가신청을 하였거나 신고한 배출시설(개 사육시설은 제외하되, 처리시설은 포함한다)의 경우

7. 그 밖에 위반행위의 정도와 위반 동기 및 공중에 미치는 영향 등을 고려하여 감경이 필요한 경우로서 건축조례로 정하는 경우

② 법 제80조의2제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 비율”이란 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 말한다. 다만, 법 제80조제1항 각 호 외의 부분 단서에 해당하는 경우에는 같은 항 각 호 외의 부분 단서에 따른 금액의 100분의 50을 말한다.

1. 제1항제1호부터 제6호까지 및 제6호의2의 경우: 100분의 75

2. 제1항제7호의 경우: 건축조례로 정하는 비율

③ 법 제80조의2제2항에 따른 이행강제금의 감경 비율은 다음 각 호와 같다.

1. 연면적 85제곱미터 이하 주거용 건축물의 경우: 100분의 80

2. 연면적 85제곱미터 초과 주거용 건축물의 경우: 100분의 60

질의제목 23

▶ 안전번호 25-0158

민원인 - 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제85조제7항제1호 또는 제2호에 따라 용적률을 완화 받을 수 있는 범위(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제85조제7항 등 관련)

01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 함) 제78조제4항에서는 건축물의 주위에 공원·광장·도로·하천 등의 공지가 있거나 이를 설치하는 경우에는 같은 조 제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군(이하 “시·도”라 함)의 조례로 용적률을 따로 정할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제85조제7항에서는 준주거지역¹⁾ 안의 건축물로서 같은 항 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 경관·교통·방화 및 위생상 지장이 없다고 인정되는 경우에는 같은 조 제1항 각 호의 규정에 의한 해당 용적률의 120퍼센트 이하의 범위 안에서 시·도의 도시·군계획조례가 정하는 비율로 할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제7항제1호에서는 ‘공원·광장²⁾·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물’을, 같은 항 제2호에서는 ‘너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물’을 규정하고 있는바,

건축물이 있는 대지가 너비 25미터 미만인 도로에 20미터 이상 접하고 있고, 그 도로가 해당 대지의 전면도로가 아닌 경우, 해당 대지안의 건축물에 국토계획법 시행령 제85조제7항제1호 또는 제2호가 적용되어 용적률을 완화 받을 수 있는지?

02 회답

건축물이 있는 대지가 너비 25미터 미만인 도로에 20미터 이상 접하고 있고, 그 도로가 해당 대지의 전면도로가 아닌 경우, 해당 대지안의 건축물에 국토계획법 시행령 제85조제7항제1호 및 제2호가 모두 적용되지 않아 용적률을 완화 받을 수 없습니다.

1) 준주거지역·중심상업지역·일반상업지역·근린상업지역·전용공업지역·일반공업지역 또는 준공업지역을 말함

2) 교통광장을 제외하며, 이하 같음

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데³⁾, 국토계획법 시행령 제85조제7항에서는 용적률을 완화 받을 수 있는 대상을 각 호로 정하면서 제1호에서는 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물(A)이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물(B)을, 제2호에는 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물(C)로 각각 열거하고 있는바, 이 사안과 같이 건축물이 있는 대지가 너비 25미터 미만인 도로에 20미터 이상 접하고 있고, 그 도로가 해당 대지의 전면도로가 아닌 경우, 해당 대지안의 건축물은 같은 항 제1호에서 규정하고 있는 대상 중 하나인 ‘공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물(A)’에 해당하지 않고, 같은 항 제2호에 따른 ‘너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물(C)’에도 해당하지 않는다는 것이 문언상 분명합니다.

그리고 이 사안 대지안의 건축물이 용적률 완화를 받을 수 있는 다른 경우인 국토계획법 시행령 제85조제7항제1호의 나머지 경우(B)에 해당하는지를 살펴보면, 국토계획법 시행령 제85조제7항에 따라 용적률 완화를 받기 위해 대지가 접하여야 하는 공지 중 하나인 “도로”의 요건에 대해서는, 대지와 접한 도로가 건축이 금지된 공지에 접한 전면도로이거나(제1호), 아니면 도로의 너비가 25미터 이상이면서 대지와 20미터 이상 접하고 대지안 건축물의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 경우(제2호) 각각 용적률을 완화 받을 수 있는 것으로 규정하고 있는바, 같은 항에서 함께 규정하고 있는 다른 종류의 공지인 공원·광장·하천과는 달리, “도로”의 경우에만 대지와 도로가 접하는 경우 용적률을 완화 받을 수 있는 요건으로 도로의 종류나 도로의 규모 등을 세부적으로 제한하여 규정하고 있는 점에 비추어 보면, 같은 항 제1호에 따라 건축물이 있는 대지가 20미터 이상 접한 경우 용적률을 완화 받을 수 있는 “그 밖에 건축이 금지된 공지”에는 도로는 포함되지 않는 것으로 보는 것이 해당 규정의 체계에 부합하는바, 이 사안 대지안의 건축물의 용적률 완화와 관련해서는 국토계획법 시행령 제85조제7항제1호의 나머지 경우(B)에도 해당하지 않는다고 할 것입니다.

또한 국토계획법 제78조는 용도지역의 특성을 고려하여 건축물의 밀도를 조절함으로써 국토의 효율적인 이용이 가능하도록 용도지역별로 건축물에 적용되는 용적률 상한과 관련한

3) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

사항을 정하고 있는 규정으로, 그 중 같은 조 제4항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제85조제7항은 용적률의 상한을 완화하는 규정으로서 원칙에 대한 예외규정인 만큼 합리적 이유 없이 확대하여 해석해서는 안 될 것인데⁴⁾, 이와 관련하여 같은 법 시행령 제85조제7항제1호 및 제2호에서는 대지가 ‘도로’와 접하는 경우 용적률을 완화 받을 수 있는 요건을 명시적으로 규정하고 있음에도 불구하고, 그 밖에 추가적으로 같은 항 제1호에 따라 대지가 20미터 이상 접한 경우 용적률을 완화 받을 수 있는 ‘그 밖에 건축이 금지된 공지’에 도로가 포함되는 것으로 보는 것은, 합리적 이유 없이 용적률 완화의 요건을 확대하여 해석하는 것으로서, 이는 건축물의 밀도를 관리하기 위해 엄격하게 용적률 상한을 규율하고 있는 용적률 제도의 취지⁵⁾에 부합하지 않습니다.

아울러 만약 국토계획법 시행령 제85조제7항제1호에 따라 건축물이 있는 대지가 20미터 이상 접한 경우 용적률을 완화 받을 수 있는 ‘그 밖에 건축이 금지된 공지’의 범위에 ‘도로’가 포함되는 것으로 본다면, 건축물이 있는 대지가 도로와 20미터 이상 접하는 경우이기만 하면, 해당 도로가 전면도로이면서 동시에 다른 공지와 접하고 있는지 여부 또는 해당 도로와 접하는 대지안 건축물의 건축면적과는 무관하게 용적률을 완화 받을 수 있게 되어, 도로와 관련하여 용적률을 완화 받을 수 있는 요건을 정하고 있는 같은 항 제1호 및 제2호의 규정을 둔 실익이 없게 된다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 건축물이 있는 대지가 너비 25미터 미만인 도로에 20미터 이상 접하고 있고, 그 도로가 해당 대지의 전면도로가 아닌 경우, 해당 대지안의 건축물에 국토계획법 시행령 제85조제7항제1호 및 제2호가 모두 적용되지 않아 용적률을 완화 받을 수 없습니다.

4) 법제처 2021. 4. 21. 회신 21-0142 해석례 참조

5) 법제처 2021. 4. 21. 회신 21-0142 해석례 참조



관계법령

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제78조(용도지역에서의 용적률) ① 제36조에 따라 지정된 용도지역에서 용적률의 최대한도는 관할 구역의 면적과 인구 규모, 용도지역의 특성 등을 고려하여 다음 각 호의 범위에서 대통령령으로 정하는 기준에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정한다.

1. 도시지역

가. 주거지역: 500퍼센트 이하

나. 상업지역: 1천500퍼센트 이하

다. 공업지역: 400퍼센트 이하

라. 녹지지역: 100퍼센트 이하

2. ~ 4. (생 략)

②·③ (생 략)

④ 건축물의 주위에 공원·광장·도로·하천 등의 공지가 있거나 이를 설치하는 경우에는 제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 용적률을 따로 정할 수 있다.

⑤ ~ ⑦ (생 략)

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령

제85조(용도지역 안에서의 용적률) ① ~ ⑥ (생 략)

⑦ 법 제78조제4항의 규정에 의하여 준주거지역·중심상업지역·일반상업지역·근린상업지역·전용공업지역·일반공업지역 또는 준공업지역안의 건축물로서 다음 각호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 경관·교통·방화 및 위생상 지장이 없다고 인정되는 경우에는 제1항 각호의 규정에 의한 해당 용적률의 120퍼센트 이하의 범위안에서 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 도시·군계획조례가 정하는 비율로 할 수 있다.

1. 공원·광장(교통광장을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물

2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

⑧ ~ ⑫ (생 략)

질의제목 24

▶ 안전번호 25-0174

민원인 - 「도시개발법 시행령」 제35조제2호에 따라 총회의 의결을 거쳐야 하는 사항의 범위(「도시개발법 시행령」 제35조 등 관련)

01 질의요지

「도시개발법」 제15조제3항에서는 조합¹⁾의 설립, 조합원의 권리·의무, 조합의 임원의 직무, 총회의 의결 사항 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제35조에서는 정관의 변경(제1호), 개발계획 및 실시계획의 수립 및 변경(제2호) 등 같은 조 각 호의 사항은 총회의 의결을 거쳐야 한다고 규정하고 있는 한편,

「도시개발법」 제4조제4항에서는 지정권자는 환지(換地) 방식의 도시개발사업에 대한 개발계획²⁾을 수립하려면 환지 방식이 적용되는 지역의 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지 소유자와 그 지역의 토지 소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의를 받아야 한다고 규정하면서(전단), 환지 방식으로 시행하기 위하여 개발계획을 변경(대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 제외한다)하려는 경우에도 또한 같다고 규정하고(후단) 있는바,

「도시개발법」 제4조제4항 후단에 따른 개발계획의 경미한 사항의 변경은 「도시개발법 시행령」 제35조제2호에 따라 조합 총회의 의결을 거쳐야 하는 사항인 “개발계획 및 실시계획의 수립 및 변경”에서 제외되는지?

02 회답

「도시개발법」 제4조제4항 후단에 따른 개발계획의 경미한 사항의 변경은 같은 법 시행령 제35조제2호에 따라 조합 총회의 의결을 거쳐야 하는 사항인 “개발계획 및 실시계획의 수립 및 변경”에서 제외되지 않습니다.

1) 도시개발구역의 토지 소유자가 도시개발을 위하여 설립한 조합을 말하며(「도시개발법」 제11조제1항제6호 참조), 이하 같음

2) 도시개발구역에 대한 도시개발사업의 계획을 말하며(「도시개발법」 제4조제1항 참조), 이하 같음

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데³⁾, 「도시개발법 시행령」 제35조제2호에서는 조합 총회의 의결을 거쳐야 하는 사항 중 하나로 “개발계획 및 실시계획의 수립 및 변경”을 규정하고 있는바, 같은 조 제10호에서는 총회의 의결을 거쳐야 하는 사항 중 하나로 “조합의 합병 또는 해산에 관한 사항”을 규정하면서, “같은 법 제46조에 따른 청산금의 징수·교부를 완료한 후에 조합을 해산하는 경우는 제외한다”고 규정하고 있는 것과 달리, 같은 조 제2호에서는 단서 규정이나 괄호를 두어 총회 의결사항의 일부를 명시적으로 제외하는 등 예외사항을 별도로 규정하고 있지 않으므로, 같은 법 시행령 제35조제2호에 따른 개발계획의 변경에 해당한다면, 이 사안과 같이 「도시개발법」 제4조제4항 후단에 따른 개발계획의 경미한 사항의 변경에 해당하는지 여부와 관계없이 총회의 의결을 거쳐야 하는 사항으로 보는 것이 문언에 부합하는 해석입니다.

다음으로 「도시개발법」 제4조제4항에서는 지정권자가 환지 방식의 도시개발사업에 대한 개발계획을 수립하거나 변경하려는 경우 일정비율 이상의 토지소유자의 동의를 받도록 규정하고 있는데, 이는 환지 방식의 도시개발사업은 사업의 시행으로 새로 조성된 대지에 사업 시행 전에 존재하던 기존 토지 소유자의 권리를 이전하는 방식의 사업⁴⁾으로, 도시개발사업의 시행자가 도시개발사업에 필요한 토지등⁵⁾에 대한 수용 또는 사용 권한이 없어 안정적인 사업 추진을 위해서는 사업의 추진 여부뿐만 아니라, 토지이용계획(제5조제1항제7호), 기반시설의 설치계획(제5조제1항제11호) 등 사업의 구체적 내용에 대해서도 일정비율 이상 토지 소유자의 동의를 확보할 필요성이 있다는 점을 고려하여⁶⁾ 규정한 것입니다.

반면 「도시개발법」 제11조제1항 단서 및 제6호에 따르면 도시개발구역의 전부를 환지 방식으로 시행하는 경우 도시개발구역의 토지 소유자가 도시개발을 위하여 설립한 조합이 시행자로 지정될 수 있고, 같은 법 시행령 제35조에서는 조합 총회의 의결사항으로 정관의 변경(제1호), 개발계획 및 실시계획의 수립 및 변경(제2호), 조합임원의 선임(제9호) 등을 규정하고 있는바, 이는 조합이 시행하는 전부환지방식의 도시개발사업을 둘러싼 중요한

3) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

4) 헌법재판소 2012. 8. 23. 선고 전원재판부 2010헌바471 결정례 참조

5) 수용(收用) 또는 사용의 대상이 되는 토지·건축물 또는 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권 외의 권리, 광업권, 어업권, 양식업권, 물의 사용에 관한 권리를 말함(「도시개발법」 제5조제1항제14호)

6) 법제처 2023. 5. 22. 회신 23-0171 해석례 참조

의사결정을 수행하는 경우 조합의 최고 의사결정기관인 총회의 논의 및 의결을 거치도록 하려는 것으로, 이상의 사항을 종합하면 도시개발법령에서 환지방식 도시개발계획의 수립·변경 시 지정권자가 토지소유자의 동의를 받도록 하는 것과 사업시행자인 조합이 도시개발사업의 시행과 관련한 중요사항에 대해 총회의 의결을 거치도록 하는 것은 서로 목적이 다른 별개의 제도라 할 것이므로, 같은 법 제4조제4항 후단에 따라 지정권자가 토지소유자의 동의를 받지 않고도 개발계획을 변경할 수 있는 경미한 사항의 변경에 해당한다고 하여 곧바로 같은 법 시행령 제35조제2호에 따른 총회의 의결사항에서 제외되는 것으로 볼 것은 아닙니다.

이와 관련하여 「도시개발법」 제4조제6항에 따르면 전부환지방식 도시개발사업의 시행자인 조합이 총회에서 일정 비율 이상의 조합원 총수의 찬성으로 개발계획의 수립 또는 변경을 의결하여 지정권자에게 제출한 경우는 같은 조 제4항에도 불구하고 토지 소유자의 동의를 받은 것으로 의제되고, 같은 조 제4항 후단 괄호부분에서는 대통령령으로 정하는 개발계획의 경미한 사항의 변경은 토지 소유자의 동의를 받아야 하는 대상에서 제외하는 것으로 규정하고 있어, 경미한 사항의 변경의 경우 토지소유자의 동의를 갈음하는 조합 총회의 의결 또한 필요하지 않게 되므로, 「도시개발법」 제4조제4항 후단에 따른 개발계획의 경미한 사항의 변경은 같은 법 시행령 제35조제2호에 따른 조합 총회의 의결사항에서 제외된다는 의견이 있습니다.

그러나 「도시개발법」 제4조제3항에서는 지정권자는 ‘조합 등 도시개발사업 시행자의 요청’을 받아 개발계획을 변경할 수 있다고 규정하고 있고, 사업시행자인 조합이 개발계획 변경을 요청하기 위해서는 개발계획을 변경할 필요가 있는지 여부 또는 그 변경 요청의 구체적인 내용 등 개발계획의 변경과 관련한 일련의 사항을 조합의 총회에서 논의할 필요성이 크다 할 것인바, 이 경우 같은 법 제4조제4항 후단에 따라 지정권자가 토지소유자의 동의를 받지 않고도 개발계획을 변경할 수 있는 경미한 사항의 변경에 해당한다고 하여 총회에서 논의할 필요성이 없는 것은 아니므로, 명시적인 근거규정 없이 총회의 의결을 거치지 않아도 되는 예외를 확대하여 해석하기는 어렵다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않다고 할 것입니다.

아울러 「도시개발법 시행령」 제36조제1항에서는 의결권을 가진 조합원의 수가 50인 이상인 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 둘 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 대의원회는 같은 영 제35조에 따른 총회의 의결사항 중 같은 조 ‘제2호’ 등을 제외한 총회의 권한을 대행할 수 있다고 규정하면서, ‘제2호’ 뒤에 괄호를 두어 같은 영

제7조에 따른 사항과 관련된 개발계획의 경미한 변경은 제외한다고 규정하고 있는바, 그렇다면 ‘같은 영 제7조에 따른 사항과 관련된 개발계획의 경미한 변경’은 대의원회가 총회의 권한을 대행할 수 있는 사항으로, 이는 해당 사항이 총회의 의결사항에 해당함을 전제하는 것이라는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「도시개발법」 제4조제4항 후단에 따른 개발계획의 경미한 사항의 변경은 같은 법 시행령 제35조제2호에 따라 조합 총회의 의결을 거쳐야 하는 사항인 “개발계획 및 실시계획의 수립 및 변경”에서 제외되지 않습니다.



관계법령

도시개발법

제4조(개발계획의 수립 및 변경) ① ~ ③ (생략)

④ 지정권자는 환지(換地) 방식의 도시개발사업에 대한 개발계획을 수립하려면 환지 방식이 적용되는 지역의 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지 소유자와 그 지역의 토지 소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의를 받아야 한다. 환지 방식으로 시행하기 위하여 개발계획을 변경(대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 제외한다)하려는 경우에도 또한 같다.

⑤ (생략)

⑥ 지정권자가 도시개발사업의 전부를 환지 방식으로 시행하려고 개발계획을 수립하거나 변경할 때에 도시개발사업의 시행자가 제11조제1항제6호의 조합에 해당하는 경우로서 조합이 성립된 후 총회에서 도시개발구역의 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 조합원과 그 지역의 조합원 총수의 2분의 1 이상의 찬성으로 수립 또는 변경을 의결한 개발계획을 지정권자에게 제출한 경우에는 제4항에도 불구하고 토지 소유자의 동의를 받은 것으로 본다.

⑦ (생략)

도시개발법 시행령

제7조(개발계획의 경미한 변경) ① 법 제4조제4항 후단에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경”이란 개발계획을 변경하는 경우로서 다음 각 호에 해당하는 경우를 제외한 경우를 말한다.

1. ~ 11. (생략)

② (생략)

제35조(총회의 의결사항) 다음 각 호의 사항은 총회의 의결을 거쳐야 한다.

1. (생략)

2. 개발계획 및 실시계획의 수립 및 변경

3. ~ 10. (생략)

질의제목 25

▶ 안전번호 25-0224

민원인 - 건축물 바닥면적 산정 시 발코니에 두는 냉방설비 배기장치 전용 설치공간 면적의 산입 방법
(「건축법 시행령」 제119조제1항제3호 등 관련)

01 질의요지

「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에서는 건축물의 바닥면적의 산정방법에 대해 규정하면서, 같은 호 나목에서는 건축물의 노대등¹⁾의 바닥은 난간 등의 설치 여부에 관계없이 노대등의 면적(외벽의 중심선으로부터 노대등의 끝부분까지의 면적을 말함)에서 노대등이 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 1.5미터를 곱한 값을 뺀 면적을 건축물의 바닥면적에 산입한다고 규정하고 있고, 같은 호 라목에서는 건축물의 내부에 설치하는 냉방설비 배기장치 전용 설치공간(각 세대나 실별로 외부 공기에 직접 닿는 곳에 설치하는 경우로서 1제곱미터 이하로 한정함)은 건축물의 바닥면적에 산입하지 않는다고 규정하고 있는바,

공동주택에서 「건축법 시행령」 제2조제14호에 따른 발코니²⁾에 냉방설비 배기장치 전용 설치공간을 두는 경우, 건축물의 바닥면적 산정 시 해당 냉방설비 배기장치 전용 설치공간 부분에 대하여 같은 영 제119조제1항제3호나목 및 라목을 모두 적용할 수 있는지?

02 회답

이 사안의 경우, 건축물의 바닥면적 산정 시 발코니에 마련한 냉방설비 배기장치 전용 설치공간 부분에 대하여 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호나목 및 라목을 모두 적용할 수는 없습니다.

1) 노대(露臺)나 그 밖에 이와 비슷한 것을 말하며(「건축법 시행령」 제40조제1항 참조), 이하 같음

2) 발코니가 건축물의 노대등에 포함되는 것을 전제로 함

03 이유

건축물의 바닥면적은 건축허가·신고의 대상을 구분하거나(「건축법」 제14조제1항제1호) 건축물의 연면적(「건축법 시행령」 제119조제1항제4호) 및 용적률(「건축법」 제56조) 등의 산정 기초가 되는 등 건축행정의 중요한 기준으로,³⁾ 그 구체적인 산정방법과 관련하여 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에서는 바닥면적은 원칙적으로 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 산정하되, 예외적으로 특정 건축물·구조·시설 등의 바닥면적은 같은 호 각 목에서 정하는 바에 따라 산정하도록 그 특례를 정하고 있습니다.

이와 같이 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우에는 합리적인 이유 없이 예외규정을 확대하여 해석해서는 안 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것이고,⁴⁾ 특히 건축 관계 법령에서 특례규정을 중첩하여 적용할 수 있도록 할 때에는 「건축법」 제60조제4항, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조제7항 등과 같이 명시적인 규정을 별도로 두는 점을 고려할 때, 발코니에 냉방설비 배기장치 전용 설치공간을 두는 경우에는 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호 나목·라목의 특례규정을 모두 적용하도록 하는 명시적인 규정이 없음에도 불구하고, 이 중 어느 하나의 특례규정에 따라 이미 바닥면적 산정에서 제외된 면적이 다른 하나의 특례규정을 재차 적용받아 중첩적으로 제외될 수 있다고 해석하는 것은 바닥면적 산정에 관한 특례규정을 확대하여 적용하는 것으로서 타당하지 않습니다.

그리고 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호나목 및 라목의 규정 내용을 살펴보면, 같은 호 나목은 반(半) 내부, 반(半) 외부의 공간이면서 동시에 주택의 내부공간으로 편입될 수 있는 중립적인 공간인 발코니(노대 등)의 특성을 고려하여 건축물의 바닥면적에 발코니(노대 등)의 면적을 산입하는 방법을 정한 것이고,⁵⁾ 같은 호 라목은 도시 미관 개선 및 추락사고 위험 방지 등을 위하여 건축물 외부 창문 난간 등에 냉방설비 배기장치를 설치하는 대신 건축물 내부에 에어컨 실외기실 등 냉방설비 배기장치 전용 설치공간을 마련하는 경우에는 최대 1제곱미터까지 해당 부분을 바닥면적 산정에서 제외하도록 하는 특례를 정한 것으로⁶⁾ 두 규정은 그 입법취지와 목적을 달리하는 규정이라는 점을 고려하더라도, 발코니에 냉방설비

3) 법제처 2019. 5. 14. 회신 19-0050 해석례 참조

4) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

5) 법제처 2019. 5. 14. 회신 19-0050 해석례 참조

6) 2021. 1. 5. 국토교통부 보도자료 “「건축법 시행령」 개정안 국무회의 통과, 8일부터 시행” 등 참조

배기장치를 설치하는 경우 해당 부분에 대한 바닥면적을 산정할 때에는 해당 공간의 주된 용도, 설계도서의 내용 등을 고려하여 바닥면적 산정에 관한 특례를 적용하여야 할 것입니다.

그런데 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호라목에서 건축물의 내부에 설치하는 냉방설비 배기장치 전용 설치공간에 대한 특례를 마련한 취지는 건축물 내부에 냉방설비 배기장치 전용 설치공간을 별도로 마련하려 하더라도 해당 부분이 바닥면적을 차지함에 따라 건축물 설계상 공간 제약이 발생하던 불편을 해소하기 위하여 바닥면적 산정 시 일정 면적을 제외하도록 한 것으로서⁷⁾, 같은 목의 규정은 본래 건축물의 바닥면적에 산입되어야 하는 공간에 냉방설비 배기장치 전용 설치공간을 마련하는 경우에 한정하여 적용된다고 보아야 하고, 같은 호 나목 등에 따라 바닥면적에 산입되지 않는 부분에 냉방설비 배기장치 전용 설치공간을 마련하는 경우에는 적용되지 않는 것으로 보는 것이 합리적이라 할 것이므로, 같은 영 제119조제1항제3호나목·라목을 중복하여 적용할 수 없다고 해석하는 것이 해당 규정의 취지 및 체계에 부합한다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 건축물의 바닥면적 산정 시 발코니에 마련한 냉방설비 배기장치 전용 설치공간 부분에 대하여 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호나목 및 라목을 모두 적용할 수는 없습니다.

법령정비 권고사항

「건축법 시행령」 제119조제1항제3호 각 목에 따른 바닥면적 산정방법의 특례규정이 중첩적으로 적용될 수 있는지에 대하여 법령에 보다 명확하게 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

건축법

제84조(면적·높이 및 층수의 산정) 건축물의 대지면적, 연면적, 바닥면적, 높이, 처마, 천장, 바닥 및 층수의 산정방법은 대통령령으로 정한다.

7) 2021. 1. 5. 국토교통부 보도자료 “「건축법 시행령」 개정안 국무회의 통과, 8일부터 시행” 등 참조

건축법 시행령

제2조(정의) 이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 13. (생략)

14. “발코니”란 건축물의 내부와 외부를 연결하는 완충공간으로서 전망이나 휴식 등의 목적으로 건축물 외벽에 접하여 부가적(附加的)으로 설치되는 공간을 말한다. 이 경우 주택에 설치되는 발코니로서 국토교통부장관이 정하는 기준에 적합한 발코니는 필요에 따라 거실·침실·창고 등의 용도로 사용할 수 있다.

15. ~ 19. (생략)

제119조(면적 등의 산정방법) ① 법 제84조에 따라 건축물의 면적·높이 및 층수 등은 다음 각 호의 방법에 따라 산정한다.

1.·2. (생략)

3. 바닥면적: 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 목에서 정하는 바에 따른다.

가. (생략)

나. 건축물의 노대등의 바닥은 난간 등의 설치 여부에 관계없이 노대등의 면적(외벽의 중심선으로부터 노대등의 끝부분까지의 면적을 말한다)에서 노대등이 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 1.5미터를 곱한 값을 뺀 면적을 바닥면적에 산입한다.

다. (생략)

라. 승강기탑(옥상 출입용 승강장을 포함한다), 계단탑, 장식탑, 다락[층고(層高)가 1.5미터(경사진 형태의 지붕인 경우에는 1.8미터) 이하인 것만 해당한다], 건축물의 내부에 설치하는 냉방설비 배기장치 전용 설치공간(각 세대나 실별로 외부 공기에 직접 닿는 곳에 설치하는 경우로서 1제곱미터 이하로 한정한다), 건축물의 외부 또는 내부에 설치하는 굴뚝, 더스트슈트, 설비덕트, 그 밖에 이와 비슷한 것과 옥상·옥외 또는 지하에 설치하는 물탱크, 기름탱크, 냉각탑, 정화조, 도시가스 정압기, 그 밖에 이와 비슷한 것을 설치하기 위한 구조물과 건축물 간에 화물의 이동에 이용되는 컨베이어벨트만을 설치하기 위한 구조물은 바닥면적에 산입하지 않는다.

마. ~ 너. (생략)

4. ~ 10. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

질의제목 26

▶ 안전번호 25-0227, 25-0279

인천광역시 동구 - 시장등은 용도변경을 하려는 자에게 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 결의 관련 자료를 요구할 수 있는지(「건축법」 제19조 등 관련)

01 질의요지

「건축법」 제19조제2항에서는 같은 법 제22조에 따라 사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 “시장등”이라 함)의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제12조의2제1항에서는 같은 법 제19조제2항에 따라 용도변경의 허가를 받으려는 자는 별지 제1호의4서식의 건축·대수선·용도변경(변경)허가 신청서에, 용도변경의 신고를 하려는 자는 별지 제6호서식의 건축·대수선·용도변경(변경)신고서에 같은 항 각 호의 서류를 첨부하여 시장등에게 제출하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 용도를 변경하려는 층의 변경 후의 평면도를, 같은 항 제2호에서는 용도변경에 따라 변경되는 내화·방화·피난 또는 건축설비에 관한 사항을 표시한 도서를 각각 규정하고 있는 한편,

「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」(이하 “집합건물법”이라 함) 제15조제1항에서는 집합건물의 공용부분 변경에 관한 사항은 관리단집회에서 구분소유자의 3분의 2 이상 및 의결권의 3분의 2 이상의 결의로써 결정하되(본문), 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 법 제38조제1항에 따른 통상의 집회결의로써 결정할 수 있다고 규정(단서)하고 있는바,

집합건물의 공용부분을 포함하여 「건축법」 제19조제2항에 따라 ① 용도변경의 허가를 받거나 ② 용도변경 신고¹⁾를 하려는 경우, 시장등은 용도변경을 하려는 자에게 집합건물법 제15조제1항에 따른 결의(이하 “집회결의”라 함)에 관한 자료를 제출하도록 요구할 수 있는지?

1) 건축법상 인허가의제 효과를 수반하는 건축신고의 경우 수리를 요하는 신고(대법원 2010두14954 판결례 등 참조)로서 실질적 요건의 심사가 가능하므로, 이 사안의 경우 실질적 요건을 확인할 수 있는 수리를 요하는 신고임을 전제함

02 회답

이 사안의 경우, 시장등은 용도변경을 하려는 자에게 집회결의에 관한 자료를 제출하도록 요구할 수 있습니다.

03 이유

먼저 「건축법」 제19조제2항 및 같은 법 시행규칙 별지 제1호의4서식에 따른 용도변경 허가 신청서, 별지 제6호서식에 따른 용도변경 신고서에 따르면 용도변경에 관한 허가 신청 또는 신고를 할 때에는 신청서 또는 신고서에 용도변경을 하려는 건축주를 기재하도록 규정하고 있는바, 그렇다면 시장등은 「건축법」 제19조제2항에 따라 용도변경의 허가를 신청하거나 신고한 내용을 심사하는 과정에서 이를 신청한 자가 정당한 건축주인지 여부를 확인할 수 있다고 할 것인데, 이 사안과 같은 집합건물의 경우에는 다수의 구분소유자가 존재하므로, 이러한 구분소유자를 대상으로 「건축법」 제19조에 따른 용도변경을 하려는 것인지에 대해서 확인할 필요가 있을 수 있고, 그 과정에서 용도변경 대상에 집합건물의 공용부분이 포함되어 있다면 집합건물 공용부분의 변경 등 관리에 대해서는 집회결의의 방식으로 의사를 결정하도록 하고 있는 집합건물법 제15조의 규정을 고려할 때, 시장등은 「건축법」 제19조제2항에 따른 용도변경의 허가 신청 또는 신고 사항을 확인하는 과정에서 필요한 경우 용도변경 허가 신청 또는 신고가 정당한 권리자에 의해 이루어진 것인지 또는 적법한 의사결정을 통해 이루어진 것인지 확인하기 위해 집회결의에 관한 자료를 제출하도록 요구할 수 있다고 할 것²⁾입니다.

그리고 집합건물법 제30조제1항, 제39조 및 제41조에서는 집합건물의 구분소유자 등에게 규약, 의사록 및 집회결의 자료의 작성 및 보관 의무를 규정하고 있고, 이를 위반하는 경우 소관청³⁾은 같은 법 제66조제3항제5호에 따라 200만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있으며, 특히 같은 법 제26조의5제1항제6호 및 같은 법 시행령 제11조의2에서는 특별시장·광역시장·도지사 및 시장등은 집합건물의 효율적인 관리와 주민의 복리증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 전유부분이 50개 이상인 건물의 관리인⁴⁾에게

2) 수원지방법원 2017. 4. 27. 선고 2016구합67272 판결례 등 참조

3) 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장을 말하며(집합건물법 제24조제6항 참조), 이하 같음

4) 집합건물법 제24조에 따라 선임된 관리인을 말함

제30조제1항, 제39조제1항 및 제41조에 따른 규약, 관리단집회 의사록, 관리단집회의 서면 또는 전자적 방법으로 기록된 정보 등의 제출을 요구할 수 있도록 명시하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 시장등은 집합건물의 소유 및 관리가 집합건물법에 따라 제대로 이루어지고 있는지에 관하여 감독할 수 있는 권한을 부여받고 있는바, 「건축법」 제19조에 따른 용도변경을 하려는 경우에 집합건물법에 따라 이루어지는지를 확인·점검하기 위하여 집회결의 등에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있다고 보아야 할 것입니다.

또한 일반적으로 행정청은 관계 법규에서 정하는 어떠한 제한에 배치되는 경우에는 허가를 거부할 수 있고,⁵⁾ 신고 당시에 관계 법규를 위반한 사항이 있다면 신고 단계에서 이를 심사하여 신고의 수리를 거부할 수 있는 점,⁶⁾ 「건축법」상 건축허가 또는 건축신고의 경우에도 건축허가 또는 건축신고의 내용에 관련 법규를 위반하는 내용이 포함되어 있었다면 「건축법」상 기준을 갖추었다고 하더라도 그 허가 또는 신고의 수리를 거부할 수 있으며,⁷⁾ 이는 건축허가 및 건축신고에 관한 규정을 준용⁸⁾하고 있는 용도변경의 허가 및 신고에도 동일하게 적용되는바⁹⁾, 「건축법」상 용도변경의 허가 신청 또는 신고가 있을 때에는 관계 법규의 위반 여부를 함께 살필 수 있다고 할 것인데, 이 사안과 같이 「건축법」 제19조제2항에 따른 용도변경의 대상이 되는 건축물이 집합건물이고, 집합건물의 공용부분을 포함하여 「건축법」상 용도변경을 하려고 한다면 집합건물법 제15조에 따른 집회결의 절차를 거쳐야 하는바, 이 사안의 경우에는 「건축법」상 용도변경에 관한 허가 또는 신고의 수리 여부를 심사할 때 위반 사실이 있는지를 확인해야 하는 관련 법규에 집합건물법이 포함된다고 할 것이어서 집회결의에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있다고 할 것입니다.

아울러 시장등이 「건축법」 제19조제2항에 따른 용도변경을 하려는 자에게 집회결의에 관한 자료를 제출하도록 요구할 수 없다고 한다면, 이 사안과 같이 다수의 구분소유자로 구성되어 있는 집합건물의 공용부분을 포함한 용도변경 허가 신청 또는 신고가 정당한 권리자에 의해 이루어진 것인지 여부 또는 적법한 의사결정을 통해 이루어진 것인지 여부 등을 확인하지 않고 용도변경 허가를 하거나 신고를 수리하게 되는데, 그러한 경우 「건축법」 제19조에 따른 용도변경을 하는 과정에서 또는 용도변경된 결과에 따라 적법하지 않은 의사결정으로 인해 그 용도변경에 동의하지 않은 다른 구분소유자에게 손해가 발생할 우려가 있고, 구분소유자

5) 대법원 1992. 12. 11. 선고 92누3038 판결례 참조

6) 대법원 2009. 6. 11. 선고 2008두18021 판결례 참조

7) 대법원 2018. 6. 19. 선고 2015두43117 판결례 등 참조

8) 건축법 제19조제7항 참조

9) 서울고등법원 2023. 11. 16. 선고 2023누30200 판결례 참조

간의 분쟁으로 인하여 용도변경 절차가 사실상 진행될 수 없는 경우도 발생할 수 있는바, 시장등이 「건축법」 제19조제2항에 따른 용도변경을 하려는 자에게 집회결의에 관한 자료를 제출하도록 요구하고, 이를 확인하도록 하는 것이 불필요한 행정력을 낭비하거나 국민에게 피해가 발생하는 등의 문제를 예방할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 시장등은 용도변경을 하려는 자에게 집회결의에 관한 자료를 제출하도록 요구할 수 있습니다.



관계법령

건축법

제19조(용도변경) ① 건축물의 용도변경은 변경하려는 용도의 건축기준에 맞게 하여야 한다.

② 제22조에 따라 사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다.

1. 허가 대상: 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군(施設群)에 속하는 건축물의 용도를 상위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 작은 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우
2. 신고 대상: 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군에 속하는 건축물의 용도를 하위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 큰 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우

③ ~ ⑥ (생 략)

⑦ 제1항과 제2항에 따른 건축물의 용도변경에 관하여는 제3조, 제5조, 제6조, 제7조, 제11조제2항부터 제9항까지, 제12조, 제14조부터 제16조까지, 제18조, 제20조, 제27조, 제29조, 제38조, 제42조부터 제44조까지, 제48조부터 제50조까지, 제50조의2, 제51조부터 제56조까지, 제58조, 제60조부터 제64조까지, 제67조, 제68조, 제78조부터 제87조까지의 규정과 「녹색건축물 조성 지원법」 제15조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제54조를 준용한다.

건축법 시행규칙

제12조의2(용도변경) ①법 제19조제2항에 따라 용도변경의 허가를 받으려는 자는 별지 제1호의4 서식의 건축·대수선·용도변경(변경)허가 신청서에, 용도변경의 신고를 하려는 자는 별지 제6호서식의 건축·대수선·용도변경(변경)신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 제출(전자문서로 제출하는 것을 포함한다)하여야 한다.

1. 용도를 변경하려는 층의 변경 후의 평면도

2. 용도변경에 따라 변경되는 내화·방화·피난 또는 건축설비에 관한 사항을 표시한 도서
② ~ ⑥ (생 략)

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률

제15조(공용부분의 변경) ① 공용부분의 변경에 관한 사항은 관리단집회에서 구분소유자의 3분의 2 이상 및 의결권의 3분의 2 이상의 결의로써 결정한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제38조제1항에 따른 통상의 집회결의로써 결정할 수 있다.

1. 공용부분의 개량을 위한 것으로서 지나치게 많은 비용이 드는 것이 아닐 경우
 2. 「관광진흥법」 제3조제1항제2호나목에 따른 휴양 콘도미니엄업의 운영을 위한 휴양 콘도미니엄의 공용부분 변경에 관한 사항인 경우
- ② 제1항의 경우에 공용부분의 변경이 다른 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 받아야 한다.

질의제목 27

▶ 안전번호 25-0252

민원인 - 지하층의 지표면을 산정할 때 적용해야 하는 규정(「건축법 시행령」 제119조 등 관련)

01 질의요지

「건축법」 제2조제1항제5호에서는 “지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다고 규정하고 있고,

「건축법 시행령」 제119조제1항제10호에서는 「건축법」 제2조제1항제5호에 따른 지하층의 지표면은 각 층의 주위가 접하는 각 지표면 부분의 높이를 그 지표면 부분의 수평거리에 따라 가중평균한 높이의 수평면을 지표면으로 산정한다고 규정하고 있는 한편,

「건축법 시행령」 제119조제2항에서는 같은 조 제1항 각 호(제10호는 제외함)에 따른 기준에 따라 건축물의 면적·높이 및 층수 등을 산정할 때 지표면에 고저차가 있는 경우에는 건축물의 주위가 접하는 각 지표면 부분의 높이를 그 지표면 부분의 수평거리에 따라 가중평균한 높이의 수평면을 지표면으로 보되(전단), 고저차가 3미터를 넘는 경우에는 그 고저차 3미터 이내의 부분마다 그 지표면을 정한다고 규정(후단)하고 있는바,

「건축법」 제2조제1항제5호에 따른 지하층의 지표면을 산정할 때 같은 법 시행령 제119조제1항제10호를 적용해야 하는지, 아니면 같은 조 제2항을 적용할 수도 있는지?

02 회답

「건축법」 제2조제1항제5호에 따른 지하층의 지표면을 산정할 때에는 같은 법 시행령 제119조제1항제10호를 적용해야 합니다.

03 이유

「건축법」 제2조제1항제5호에서는 “지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다고 규정하고 있을 뿐, 같은 규정에서 지표면의 산정 방식까지 구체적으로 정하고 있지는 않습니다.

다만, 「건축법 시행령」 제119조에서는 「건축법」 제84조의 위임에 따라 건축물의 면적·높이 및 층수 등 「건축법」에서 필요한 각종 산정방법에 대하여 규정하고 있는데, 같은 법 시행령 제119조제1항제10호에서는 같은 법 제2조제1항제5호에 따른 지하층의 지표면은 각 층의 주위가 접하는 각 지표면 부분의 높이를 그 지표면 부분의 수평거리에 따라 가중평균한 높이의 수평면을 지표면으로 산정한다고 하여 지하층의 지표면 산정방식을 특정하여 규율하고 있습니다.

그리고 「건축법 시행령」 제119조제1항제2호, 제5호 및 제6호 등에서는 건축면적, 건축물의 높이, 처마높이 등을 판단할 때 “지표면”을 기준으로 판단하도록 하고 있고, 같은 조 제2항에서는 지표면에 고저차가 있는 경우에는 건축물의 주위가 접하는 각 지표면 부분의 높이를 그 지표면 부분의 수평거리에 따라 가중평균한 높이의 수평면을 지표면으로 보되(전단), 그 고저차가 3미터를 넘는 경우에는 그 고저차 3미터 이내의 부분마다 그 지표면을 정한다고 규정(후단)하여 「건축법 시행령」 제119조제1항제10호와 다른 방식으로 건축면적, 건축물의 높이, 처마면적 등을 판단할 때 기준이 되는 지표면을 산정하도록 하는 규정을 두고 있는데, 이 때 「건축법 시행령」 제119조제2항 전단에서는 괄호를 두어 같은 조 제1항제10호, 즉 지하층의 지표면 산정에 관하여는 같은 조 제2항에 따른 지표면 산정방식의 적용을 제외하고 있습니다.

그렇다면 「건축법」 제2조제1항제5호에 따른 지하층의 지표면을 산정할 때에는 「건축법 시행령」 제119조제2항이 적용될 수 없고, 같은 조 제1항제10호를 적용해야 한다는 것이 문언 및 조문 체계상 명확합니다.

아울러 「건축법」 제2조제1항제5호에 따른 “지하층”을 산정할 때 「건축법 시행령」 제119조제2항을 적용한다면, 지하층인지 여부를 판단해야 하는 대상 층 높이가 3미터를 초과하는 경우 같은 항 후단에 따라 둘 이상의 지표면이 산정되는바, 지하층 여부를 판단할 때의 기준이 되는 지표면이 확정되지 않아 혼란이 발생할 수 있는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「건축법」 제2조제1항제5호에 따른 지하층의 지표면을 산정할 때에는 같은 법 시행령 제119조제1항제10호를 적용해야 합니다.



관계법령

건축법

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 4. (생략)
5. “지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다.
6. ~ 21. (생략)
- ② (생략)

건축법 시행령

제119조(면적 등의 산정방법) ① 법 제84조에 따라 건축물의 면적·높이 및 층수 등은 다음 각 호의 방법에 따라 산정한다.

1. ~ 9. (생략)
10. 지하층의 지표면: 법 제2조제1항제5호에 따른 지하층의 지표면은 각 층의 주위가 접하는 각 지표면 부분의 높이를 그 지표면 부분의 수평거리에 따라 가중평균한 높이의 수평면을 지표면으로 산정한다.
- ② 제1항 각 호(제10호는 제외한다)에 따른 기준에 따라 건축물의 면적·높이 및 층수 등을 산정할 때 지표면에 고저차가 있는 경우에는 건축물의 주위가 접하는 각 지표면 부분의 높이를 그 지표면 부분의 수평거리에 따라 가중평균한 높이의 수평면을 지표면으로 본다. 이 경우 그 고저차가 3미터를 넘는 경우에는 그 고저차 3미터 이내의 부분마다 그 지표면을 정한다.
- ③ ~ ⑤ (생략)

질의제목 28

▶ 안전번호 25-0276

민원인 - 2층의 바닥면적 400제곱미터 이상을 노유자시설 중 아동 관련 시설 용도로 쓰는 건축물로서 지하층이 있는 2층 건축물의 경우 해당 건축물 지하층의 주요구조부 등만 내화구조로 할 수 있는지(「건축법 시행령」 제56조제1항 등 관련)

01 질의요지

「건축법」 제50조제1항 본문에서는 문화 및 집회시설, 의료시설, 공동주택 등 대통령령으로 정하는 건축물은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 주요구조부와 지붕을 내화(耐火)구조로 해야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물(같은 항 제5호에 해당하는 건축물로서 2층 이하인 건축물은 지하층 부분만 해당함)의 주요구조부와 지붕은 내화구조로 해야 한다고 규정하면서, 같은 항 제4호에서는 건축물의 2층이 노유자시설 중 아동 관련 시설 등의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400제곱미터 이상인 건축물을, 같은 항 제5호 본문에서는 3층 이상인 건축물 및 지하층이 있는 건축물을 주요구조부와 지붕을 내화구조로 해야 하는 건축물의 종류로 각각 규정하고 있는바,

2층의 바닥면적 400제곱미터 이상을 노유자시설 중 아동 관련 시설 용도로 쓰는 건축물로서 지하층이 있는 2층 건축물(이하 “이 사안 건축물”이라 함)의 경우, 「건축법 시행령」 제56조제1항제4호에 따라 건축물의 주요구조부와 지붕을 내화구조로 해야 하는지, 아니면 「건축법 시행령」 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문 및 같은 항 제5호 본문에 따라 지하층의 주요구조부와 지붕만 내화구조로 할 수 있는지?

02 회답

이 사안 건축물의 경우, 「건축법 시행령」 제56조제1항제4호에 따라 건축물의 주요구조부와 지붕을 내화구조로 해야 합니다.

03 이유

「건축법 시행령」 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 「건축법」 제50조제1항 본문에 따라 같은 영 제56조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물(제5호에 해당하는 건축물로서 2층 이하인 건축물은 지하층 부분만 해당함)의 주요구조부와 지붕은 내화구조로 해야 한다'고 규정하면서, 같은 항 제4호에서는 건축물의 2층이 단독주택 중 다중주택 및 다가구주택, 공동주택, 제1종 근린생활시설(의료의 용도로 쓰는 시설만 해당함), 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설, 의료시설, 노유자시설 중 아동 관련 시설 및 노인복지시설, 수련시설 중 유스호스텔, 업무시설 중 오피스텔, 숙박시설 또는 장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400제곱미터 이상인 건축물을, 같은 항 제5호 본문에서는 3층 이상인 건축물 및 지하층이 있는 건축물을 주요구조부와 지붕을 내화구조로 해야 하는 건축물의 종류로 각각 규정하고 있습니다.

그런데 이 사안 건축물은 해당 건축물 2층의 바닥면적 400제곱미터 이상을 노유자시설 중 아동 관련 시설의 용도로 쓰고 있으므로 「건축법 시행령」 제56조제1항제4호의 규정에 해당하여 건축물 전체의 주요구조부 및 지붕을 내화구조로 해야 하는 건축물에 해당하는 동시에, 지하층이 있는 2층 건축물이므로 「건축법 시행령」 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문 및 같은 항 제5호의 규정에 해당하여 지하층의 주요구조부와 지붕만 내화구조로 할 수 있는 건축물에 해당하는바, 해당 건축물에서 내화구조로 해야 하는 주요구조부와 지붕의 범위가 건축물 전체인지 아니면 지하층으로 한정될 수 있는지가 문제됩니다.

먼저 「건축법 시행령」 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 「건축법」 제50조제1항 본문에 따라 '같은 영 제56조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물'의 주요구조부와 지붕은 내화구조로 해야 한다고 규정하고 있는바, 문언상 같은 영 제56조제1항 각 호의 어느 하나에 해당한다면 건축물의 주요구조부와 지붕은 내화구조로 해야 한다고 보아야 할 것이고, 같은 영 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문의 괄호 부분(이하 "괄호규정"이라 함)은 '제5호에 해당하는 건축물'에 대하여 적용의 예외를 정한 것일 뿐, 해당 괄호규정이 같은 항의 다른 호에 해당하는 건축물에 대해서까지 적용되는 예외를 정한 것으로 보기 어려운 점 등을 고려하면, 괄호규정 및 같은 항 제5호에 해당하여 지하층만 주요구조부와 지붕을 내화구조로 할 수 있는 건축물에 해당한다고 하더라도, 이 사안 건축물과 같이 건축물의 2층을 노유자시설 중 아동 관련 시설의 용도로 쓰고 있고, 그 아동 관련 시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400제곱미터 이상이어서 「건축법 시행령」 제56조제1항제4호에 해당하는 건축물이라면

건축물 전체의 주요구조부와 지붕을 내화구조로 해야 한다고 보는 것이 타당한 해석입니다.

그리고 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데,¹⁾ 괄호규정은 「건축법」 제50조제1항 본문에 따라 건축물 전체의 주요구조부와 지붕을 내화구조로 해야 하는 것에 대한 예외로서 건축물 지하층의 주요구조부와 지붕만을 내화구조로 할 수 있도록 하는 것인바, 그렇다면 원칙에 대한 예외로서 지하층의 주요구조부 및 지붕만 내화구조로 할 수 있는 건축물의 범위에 대해서는 이를 확대 해석하기보다는 보다 엄격하게 해석할 필요가 있습니다.

특히 「건축법 시행령」 제2조제7호에 따르면, “내화구조”란 화재에 견딜 수 있는 성능을 가진 구조로서 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 구조를 가리키는 것으로, 화재사고를 미연에 방지하거나 일정수준의 화재에 견딜 수 있는 건축물의 구조를 의미하는데²⁾, 이러한 건축물의 안전·방화(防火) 등을 위한 규정을 해석할 때에는 안전·방화 등의 목적을 충실하게 실현할 수 있는 방향으로 해석해야 하는바³⁾, 이 사안 건축물과 같이 이미 2층에 일정 규모 이상의 노유자시설 중 아동 관련 시설 등의 용도로 사용되어 같은 영 제56조제1항제4호의 규정에 해당하는 경우에는 해당 층의 아동 관련 시설을 이용하는 사람들이 화재로부터 보다 안전할 수 있도록 건축물 전체의 주요구조부와 지붕을 내화구조로 하도록 해석하는 것이 해당 규정의 취지에 부합한다고 할 것입니다.

아울러 이 사안 건축물과 같이 지하층이 있는 2층 이하인 건축물에 대해서는 「건축법 시행령」 제56조제1항제5호 외에 같은 항 다른 호에 해당하더라도 같은 항 제5호 및 괄호규정에 따라 지하층의 주요구조부와 지붕만 내화구조로 할 수 있다고 본다면, 같은 2층 이하의 건축물이더라도 지하층이 없으면 괄호규정이 적용되지 않아 건축물 전체의 주요구조부와 지붕을 내화구조로 해야 하고, 지하층이 있으면 괄호규정이 적용되어 지하층의 주요구조부와 지붕만 내화구조로 할 수 있게 되어, 지하층이 있는 건축물의 내화구조 기준이 지하층이 없는 건축물보다 더 완화되어 적용되는 불합리한 결과가 초래된다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안 건축물의 경우, 「건축법 시행령」 제56조제1항제4호에 따라 건축물의 주요구조부와 지붕을 내화구조로 해야 합니다.

1) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

2) 법제처 2016. 12. 8. 회신 16-0480 해석례 참조

3) 법제처 2024. 11. 8. 회신 24-0801 해석례 참조



관계법령

건축법

제50조(건축물의 내화구조와 방화벽) ① 문화 및 집회시설, 의료시설, 공동주택 등 대통령령으로 정하는 건축물은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 주요구조부와 지붕을 내화(耐火)구조로 하여야 한다. 다만, 막구조 등 대통령령으로 정하는 구조는 주요구조부에만 내화구조로 할 수 있다.

② 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 방화벽으로 구획하여야 한다.

건축법 시행령

제56조(건축물의 내화구조) ① 법 제50조제1항 본문에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물(제5호에 해당하는 건축물로서 2층 이하인 건축물은 지하층 부분만 해당한다)의 주요구조부와 지붕은 내화구조로 해야 한다. 다만, 연면적이 50제곱미터 이하인 단층의 부속건축물로서 외벽 및 처마 밑면을 방화구조로 한 것과 무대의 바닥은 그렇지 않다.

1. ~ 3. (생략)

4. 건축물의 2층이 단독주택 중 다중주택 및 다가구주택, 공동주택, 제1종 근린생활시설(의료의 용도로 쓰는 시설만 해당한다), 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설, 의료시설, 노유자시설 중 아동 관련 시설 및 노인복지시설, 수련시설 중 유스호스텔, 업무시설 중 오피스텔, 숙박시설 또는 장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400제곱미터 이상인 건축물

5. 3층 이상인 건축물 및 지하층이 있는 건축물. 다만, 단독주택(다중주택 및 다가구주택은 제외한다), 동물 및 식물 관련 시설, 발전시설(발전소의 부속용도로 쓰는 시설은 제외한다), 교도소·소년원 또는 묘지 관련 시설(화장시설 및 동물화장시설은 제외한다)의 용도로 쓰는 건축물과 철강 관련 업종의 공장 중 제어 실로 사용하기 위하여 연면적 50제곱미터 이하로 증축하는 부분은 제외한다.

② (생략)

질의제목 29

▶ 안전번호 25-0314, 25-0366

민원인 - 「도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법」 제27조제1항제4호부터 제9호까지의 사업시행자가 산업정비구역계획 수립 및 실시계획 수립을 동시에 할 수 있는지 등(「도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법」 제50조제1항 등 관련)

01 질의요지

「도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법」(이하 “도시공업지역법”이라 함) 제50조제1항에서는 시장·군수등¹⁾은 공업지역정비사업²⁾의 시급성과 효율적인 사업시행을 위하여 같은 법 제13조에 따른 산업정비구역의 지정 및 산업정비구역계획의 수립, 같은 법 제22조에 따른 산업혁신구역의 지정 및 산업혁신구역계획의 수립, 같은 법 제30조에 따른 실시계획(이하 “실시계획”이라 함)의 수립을 동시에 할 수 있다고 규정하고 있는바,

도시공업지역법 제27조제1항제4호부터 제9호까지에 해당하는 사업시행자로서 같은 법 제15조제1항 또는 제22조제5항에 따라 산업정비구역의 지정을 제안하거나 산업혁신구역의 지정을 제안한 자(이하 “이 사안 사업시행자”라 함)는 같은 법 제50조제1항에 따라 ① 산업정비구역의 지정 및 산업정비구역계획의 수립, 실시계획의 수립을 동시에 하거나 ② 산업혁신구역의 지정 및 산업혁신구역계획의 수립, 실시계획의 수립을 동시에 할 수 있는지?

02 회답

이 사안 사업시행자는 도시공업지역법 제50조제1항에 따라 ① 산업정비구역의 지정 및 산업정비구역계획의 수립, 실시계획의 수립을 동시에 하거나 ② 산업혁신구역의 지정 및 산업혁신구역계획의 수립, 실시계획의 수립을 동시에 할 수 없습니다.

1) 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(광역시 관할구역에 있는 군의 군수는 제외함)를 말하며 (도시공업지역법 제6조제1항 참조), 이하 같음

2) 산업정비구역 또는 산업혁신구역에서 도시공업지역법 제13조, 제22조 및 제23조에 따라 수립·시행하는 사업을 말하며 (도시공업지역법 제2조제1항제7호 참조), 이하 같음

03 이유

도시공업지역법 제13조제1항에서는 시장·군수등은 공업지역기본계획에 적합한 범위에서 지원기반시설³⁾이 열악한 지역 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 공업지역의 전부 또는 일부에 대하여 같은 법 제20조에 따라 산업정비구역계획을 결정하여 산업정비구역을 지정할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제15조제1항에서는 공업지역 내 토지소유자 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자는 시장·군수등에게 산업정비구역의 지정을 제안할 수 있다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제17조제1항에서는 같은 법 제15조제1항에서 “공업지역 내 토지소유자 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자”란 같은 법 제27조제1항제2호부터 제9호까지의 규정에 해당하는 자를 말한다고 규정하고 있습니다.

또한 도시공업지역법 제22조제1항에서는 시장·군수등은 공업지역정비사업의 효율적인 추진과 산업·상업·주거·문화·행정 등의 기능이 집적된 복합적인 토지이용을 통한 산업혁신을 촉진하기 위하여 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 지역에 대하여 산업혁신구역계획을 결정하여 산업혁신구역을 지정할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제5항에서는 산업혁신구역에서 사업을 시행하려는 같은 법 제27조제1항제4호부터 제9호까지의 사업시행자는 산업혁신구역계획을 수립하여 시장·군수등에게 산업혁신구역의 지정을 제안할 수 있다고 규정하고 있습니다.

한편 도시공업지역법 제50조제1항에서는 시장·군수등은 공업지역정비사업의 시급성과 효율적인 사업시행을 위하여 같은 법 제13조에 따른 산업정비구역의 지정 및 산업정비구역 계획의 수립, 같은 법 제22조에 따른 산업혁신구역의 지정 및 산업혁신구역계획의 수립, 같은 법 제30조에 따른 실시계획의 수립을 동시에 할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 사안은 도시공업지역법 제27조제1항제4호부터 제9호까지에 해당하는 사업시행자로서 같은 법 제15조제1항 또는 제22조제5항에 따라 산업정비구역의 지정을 제안하거나 산업혁신구역의 지정을 제안한 자가 같은 법 제50조제1항에 따라 산업정비구역의 지정 및 산업정비구역 계획의 수립, 실시계획의 수립을 동시에 하거나 산업혁신구역의 지정 및 산업혁신구역계획의 수립, 실시계획의 수립을 동시에 할 수 있는지에 관한 것입니다.

3) 공업지역의 관리, 정비 및 산업기능 활성화에 필요한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 기반시설 등을 말하며(도시공업지역법 제2조제1항제4호 참조), 이하 같음

그런데 도시공업지역법 제50조제1항에서는 같은 법 제13조에 따른 산업정비구역의 지정 및 산업정비구역계획의 수립, 실시계획의 수립을 동시에 하거나 제22조에 따른 산업혁신구역의 지정 및 산업혁신구역계획의 수립, 실시계획의 수립을 동시에 할 수 있는 자를 시장·군수등으로 한정하고 있고, 이때 시장·군수등이란 같은 법 제6조제1항에 따르면 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(광역시 관할구역에 있는 군의 군수를 제외함)를 의미하는데, 시장·군수등은 같은 법 제27조제1항에 따른 사업시행자 중 같은 항 제1호에 따른 지방자치단체에 해당하므로, 문언 및 조문 체계상 이 사안 사업시행자인 같은 항 제4호부터 제9호까지의 사업시행자와는 명확하게 구분되는바, 이 사안 사업시행자와 같이 도시공업지역법 제15조제1항 또는 제22조제5항에 따라 산업정비구역의 지정이나 산업혁신구역의 지정을 제안하였다고 하더라도, 같은 법 제50조제1항에 따라 실시계획의 수립 등을 동시에 할 수는 없다고 할 것입니다.

특히 공업지역정비계획은 지역 산업생태계 구축을 통하여 도시 경쟁력을 강화하고 도시환경이 개선되도록 하기 위하여 마련된 공업지역기본계획⁴⁾을 계획적이고 체계적으로 추진하기 위해 토지이용 등에 관한 사항을 정하는 것으로,⁵⁾ 도시공업지역법에서는 공업지역정비계획에 토지이용계획, 유치업종계획, 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획 등을 포함하도록 하고 있어,⁶⁾ 공업지역정비계획은 지역 주민 등의 권리·의무에 미치는 영향이 크다고 할 것인데, 도시공업지역법에서는 제13조 및 제22조에서 산업정비구역의 지정 및 산업정비구역계획의 수립과 산업혁신구역의 지정 및 산업혁신구역계획의 수립 주체를 모두 시장·군수등으로 규정하고 있는 반면, 같은 법 제27조제1항제4호부터 제9호까지에 해당하는 민간사업시행자는 같은 법 제15조제1항 또는 제22조제5항에 따라 산업정비구역의 지정 또는 산업혁신구역의 지정을 제안만 할 수 있는바, 이 사안 사업시행자가 별도의 법률상 권한을 부여받지 않은 상황에서 산업정비구역의 지정 및 산업정비구역계획의 수립과 산업혁신구역의 지정 및 산업혁신구역계획의 수립과 같이 주민에게 중대한 영향을 미치는 권한을 직접 행사할 수 있는 것으로 해석하는 것은 타당하지 않습니다.

아울러 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데,⁷⁾ 도시공업지역법

4) 도시공업지역법 제2조제1항제2호, 제3호, 및 제6호

5) 도시공업지역법 제2조제1항제6호

6) 도시공업지역법 제16조제1항 및 제22조제3항

7) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

제13조 및 제22조에서는 각각 시장·군수등이 산업정비구역의 지정 및 산업정비구역계획의 수립과 산업혁신구역의 지정 및 산업혁신구역계획의 수립을 하도록 규정하고 있고, 같은 법 제27조 및 제38조에서는 제27조제1항 각 호의 자를 산업정비구역 및 산업혁신구역에 대한 공업지역정비사업의 사업시행자로 지정할 수 있도록 규정하고 있으며, 같은 법 제30조 및 제38조제2항에서는 사업시행자는 공업지역정비사업에 관한 실시계획을 작성하도록 규정하고 있는바, 이와 같은 규정 체계를 고려하면 공업지역정비사업은 구역 지정, 사업시행자 지정, 실시계획 수립 등이 순차적으로 진행되도록 하고 있는 반면, 도시공업지역법 제50조제1항에서 공업지역정비사업을 활성화하기 위하여 정비사업의 절차를 간소화하기 위해⁸⁾ 예외적으로 실시계획을 동시에 수립할 수 있도록 한 것으로서, 이러한 예외적인 경우에 대해서는 문언에 따라 엄격하게 해석할 필요가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안 사업시행자는 도시공업지역법 제50조제1항에 따라 ① 산업정비구역의 지정 및 산업정비구역계획의 수립, 실시계획의 수립을 동시에 하거나 ② 산업혁신구역의 지정 및 산업혁신구역계획의 수립, 실시계획의 수립을 동시에 할 수 없습니다.



관계법령

도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법

제13조(산업정비구역의 지정 및 산업정비구역계획의 결정) ① 시장·군수등은 공업지역기본계획에 적합한 범위에서 지원기반시설이 열악한 지역 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 공업지역의 전부 또는 일부에 대하여 제20조에 따라 산업정비구역계획을 결정(변경결정을 포함한다. 이하 같다)하여 산업정비구역을 지정(변경지정을 포함한다. 이하 같다)할 수 있다.

② ~ ④ (생 략)

제15조(산업정비구역의 지정 제한) ① 공업지역 내 토지소유자 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자는 시장·군수등에게 산업정비구역의 지정을 제안할 수 있다. 이 경우 제안서에는 산업정비구역 계획이 포함되어야 한다.

② ~ ④ (생 략)

제22조(산업혁신구역의 지정 및 산업혁신구역계획의 결정) ① 시장·군수등은 공업지역정비사업의 효율적인 추진과 산업·상업·주거·문화·행정 등의 기능이 집적된 복합적인 토지이용을 통한 산업혁신을 촉진하기 위하여 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 지역에 대하여 산업혁신구역계획을

8) 2020. 6. 12. 의안번호 2100445호로 의원발의된 도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

결정(변경결정을 포함한다. 이하 같다)하여 산업혁신구역을 지정(변경지정을 포함한다. 이하 같다)할 수 있다.

② ~ ④ (생략)

⑤ 산업혁신구역에서 사업을 시행하려는 제27조제1항제4호부터 제9호까지의 사업시행자는 제3항에 따른 산업혁신구역계획을 수립하여 시장·군수등에게 산업혁신구역의 지정을 제안할 수 있다.

⑥·⑦ (생략)

제27조(사업시행자 지정 등) ① 산업정비구역에 대한 공업지역정비사업의 경우에는 다음 각 호의 자 중에서 시장·군수등(제50조제2항에 따라 공공기관등이 시행하는 사업의 경우에는 국토교통부장관을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 사업시행자를 지정할 수 있다.

1. 지방자치단체
2. 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사 등 대통령령으로 정하는 공공기관
3. 「지방공기업법」 제3조에 따른 지방공기업
4. 산업정비구역 내의 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자 등(이하 “토지등소유자”라 한다) 또는 그들이 설립한 조합
5. 「건설산업기본법」 제9조에 따라 건설업을 등록하는 등 공업지역기본계획에 맞게 공업지역정비사업을 시행할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자
6. 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 등록한 부동산개발업자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자
7. 「수도권정비계획법」 제6조제1항제1호에 따른 과밀억제권역에서 수도권 외의 지역으로 이전하는 법인 중 과밀억제권역의 사업 기간 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인
8. 「부동산투자회사법」 제2조제1호가목 또는 나목에 따라 설립된 자기관리 부동산투자회사 또는 위탁관리 부동산투자회사로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인
9. 제1호부터 제8호까지의 규정에 해당하는 자가 공업지역정비사업을 시행할 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인

②·③ (생략)

제30조(실시계획의 작성 및 인가 등) ① 사업시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업정비구역의 공업지역정비사업에 관한 실시계획(이하 “실시계획”이라 한다)을 작성하여야 한다. 이 경우 실시계획에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조에 따른 지구단위계획이 포함되어야 한다.

② ~ ⑦ (생략)

제38조(산업혁신구역에서의 사업시행 등) ① 산업혁신구역에서의 사업은 제27조제1항 각 호에 해당하는 자가 시행할 수 있다.

② 산업혁신구역에서의 공업지역정비사업의 시행 등에 대하여는 제27조부터 제32조까지의 규정을 준용한다. 다만, 제32조제1항제21호 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호마목에 관한 부분은 제외한다.

제50조(공업지역정비계획과 실시계획의 동시 수립) ① 시장·군수등은 공업지역정비사업의 시급성과 효율적인 사업시행을 위하여 제13조에 따른 산업정비구역의 지정 및 산업정비구역계획의 수립, 제22조에 따른 산업혁신구역의 지정 및 산업혁신구역계획의 수립, 제30조에 따른 실시계획의 수립을 동시에 할 수 있다.

②·③ (생 략)

도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법 시행령

제17조(산업정비구역의 지정 제안 요건 등) ① 법 제15조제1항에서 “공업지역 내 토지소유자 등 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자”란 법 제27조제1항제2호부터 제9호까지의 규정에 해당하는 자를 말한다.

② ~ ④ (생 략)

질의제목 30

▶ 안전번호 25-0315, 25-0362

민원인 - 「주택법」 제5조제3항에 따라 고용자가 그 근로자의 주택을 건설을 하는 경우 같은 법 제15조에 따른 사업계획승인을 신청하기 위해 갖추어야 할 요건으로서 주택건설대지의 소유권 확보 여부(「주택법」 제5조제3항 등 관련)

01 질의요지

「주택법」 제5조제3항에서는 고용자¹⁾가 그 근로자의 주택을 건설하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 등록사업자²⁾와 공동으로 사업을 시행하여야 하고(전단), 이 경우 고용자와 등록사업자를 공동사업주체로 본다(후단)고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제16조제3항에서는 같은 법 제5조제3항에 따라 고용자가 등록사업자와 공동으로 주택을 건설하려는 경우에는 ‘고용자가 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하고 있을 것’(제2호) 등 같은 항 각 호의 요건을 모두 갖추어 같은 법 제15조에 따른 사업계획승인을 신청하여야 한다고 규정하고 있는 한편,

「주택법」 제21조제1항 본문에서는 같은 법 제15조제1항 또는 제3항에 따라 주택건설사업계획의 승인을 받으려는 자는 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하여야 하되, 같은 법 제21조제1항 단서 및 같은 항 제2호에서는 사업주체가 주택건설대지의 소유권을 확보하지 못하였으나 그 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바,

가. 고용자가 그 근로자의 주택을 건설하기 위해 등록사업자와 공동으로 사업을 시행하는 경우로서 고용자가 해당 주택건설대지를 담보신탁하여 신탁회사에게 그 소유권이 이전된 후 「주택법」 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인을 신청하는 경우, 위탁자인 고용자가 같은 법 제5조제3항 및 같은 법 시행령 제16조제3항제2호에 따른 주택건설사업계획의 승인 신청 요건으로서 해당 주택건설대지의 소유권을 확보한 것으로 볼 수 있는지?

1) 「주택법」 제5조제3항에 따라 등록사업자와 공동으로 주택건설사업을 시행하는 고용자만 해당하며(「주택법」 제4조제1항 제6호 참조), 이하 같음

2) 「주택법」 제4조에 따라 등록을 한 자를 말하며(「주택법」 제5조제1항 참조), 이하 같음

나. 고용자가 그 근로자의 주택을 건설하기 위해 등록사업자와 공동으로 사업을 시행하는 경우로서 고용자가 해당 주택건설대지를 담보신탁하여 신탁회사에게 그 소유권이 이전된 후 「주택법」 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인을 신청하는 경우, 고용자가 「주택법」 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인을 신청하기 위해서 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하지 않더라도 같은 법 제21조제1항제2호에 따라 수탁자인 신탁회사로부터 그 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보하기만 하면 되는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

이 사안의 경우, 위탁자인 고용자가 「주택법」 제5조제3항 및 같은 법 시행령 제16조제3항 제2호에 따른 주택건설사업계획의 승인 신청 요건으로서 해당 주택건설대지의 소유권을 확보한 것으로 볼 수 없습니다.

나. 질의 나에 대해

이 사안의 경우, 고용자가 「주택법」 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인을 신청하기 위해서는 주택건설대지의 소유권을 확보해야 합니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

「주택법」 제5조제3항 전단에서는 고용자가 그 근로자의 주택을 건설하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 등록사업자와 공동으로 사업을 시행하여야 한다고 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제16조제3항에서는 고용자가 등록사업자와 공동으로 주택을 건설하려는 경우에는 ‘고용자가 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하고 있을 것’(제2호) 등 같은 항 각 호의 요건을 모두 갖추어 같은 법 제15조에 따른 사업계획승인을 신청하여야 한다고 규정하고 있을 뿐, 해당 주택건설대지가 담보신탁된 경우 그 소유권의 귀속 주체에 대해서는 별도의 규정을 두고 있지 않은바, 먼저 이 사안에서는 고용자가 해당

주택건설대지를 담보신탁하여 수탁자에게 그 소유권이 이전된 후 「주택법」 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인을 신청하는 경우, 위탁자인 고용자가 주택건설사업계획의 승인 신청 요건으로서 해당 주택건설대지의 소유권을 확보한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제됩니다.

먼저 「주택법」의 목적은 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설·공급 및 주택시장의 관리 등에 관한 사항을 정함으로써 국민의 주거안정과 주거수준의 향상에 이바지하는 데에 있고(제1조), 주택법령에서 주택건설사업계획의 승인 신청 요건으로 사업시행자로 하여금 주택건설대지의 소유권을 확보하도록 한 것은 주택건설사업을 원활하고 안정적으로 시행함과 동시에 입주예정자들의 재산권을 보호하려는 데에 그 취지가 있는바³⁾, 이러한 취지를 고려하여 「주택법」 제61조에서는 사업주체로 하여금 입주자 모집공고 승인 신청일 이후부터 일정기간 동안 입주예정자의 동의 없이 주택건설대지에 담보물권 등을 설정하는 행위를 원칙적으로 금지하도록 하면서(제1항), 같은 조 제1항에 따른 저당권설정 등의 제한을 할 때 사업주체는 해당 대지가 입주예정자의 동의 없이는 양도, 제한물권의 설정, 압류·가압류·가처분 등의 목적물이 될 수 없는 재산임을 소유권등기에 부기등기하여야 하며(제3항), 같은 조 제3항에 따른 부기등기는 주택건설대지에 대하여는 입주자 모집공고 승인 신청과 동시에 하도록(제4항) 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 주택건설사업계획의 승인을 받기 위해서 주택건설대지의 소유권을 확보하여야 하는 사업주체는 원칙적으로 해당 주택건설대지의 등기부상 소유권자여야 한다고 보는 것이 같은 법 규정의 문언과 취지에 비추어 타당하다고 할 것입니다.⁴⁾

그런데 일반적으로 ‘부동산 담보신탁’은 담보의 목적으로 채무자 또는 제3자가 위탁자가 되어 위탁자 소유의 부동산을 「신탁법」에 따라 수탁자에게 이전하고 채무자가 그 채무를 불이행하면 수탁자가 담보목적 부동산을 처분하여 그 공매대금으로 채권자인 우선수익자에 대한 채무를 정산하고 잔액이 있을 때에는 다른 수익자 또는 위탁자에게 지급하는 방법을 취하게 되는바⁵⁾, 「신탁법」에 따라 토지를 담보신탁하여 수탁자 앞으로 소유권이전등기를 마치게 되면 대내외적으로 ‘소유권이 수탁자에게 완전히 이전’되고, 위탁자와의 내부관계에서 소유권이 위탁자에게 유보되어 있는 것은 아니라고 할 것이며⁶⁾, 수탁자는 신탁의 목적 범위 내에서 신탁계약에 정하여진 바에 따라 신탁재산을 관리하여야 하는 제한을

3) 법제처 2013. 8. 21. 회신 13-0284 해석례 참조

4) 법제처 2013. 8. 21. 회신 13-0284 해석례 참조

5) 법제처 2024. 5. 14. 회신 24-0088 해석례 및 대법원 2017. 5. 22. 선고 2014다225809 판결례 참조

6) 대법원 2002. 4. 12. 선고 2000다70460 판결례 참조

부담할 뿐, 신탁재산에 관하여는 수탁자만이 배타적인 처분·관리권을 갖는다고 할 것이고⁷⁾, 나아가 위탁자의 채무불이행 시 수탁자가 신탁계약에 따라 주택건설대지를 처분함으로써 사업의 안정적 시행이 저해될 수 있으므로, 결국 담보신탁에 따라 주택건설대지의 소유권이 위탁자인 고용자에서 수탁자로 이전된 경우, 해당 고용자가 주택건설사업계획의 승인 신청 요건으로서의 주택건설대지 소유권을 확보한 것으로 보기는 어렵습니다.

따라서 이 사안의 경우, 위탁자인 고용자가 「주택법」 제5조제3항 및 같은 법 시행령 제16조제3항제2호에 따른 주택건설사업계획의 승인 신청 요건으로서 해당 주택건설대지의 소유권을 확보한 것으로 볼 수 없습니다.

나. 질의 내에 대해

「주택법」 제15조제1항 본문에서는 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택건설사업을 시행하려는 자 등은 같은 항 각 호의 사업계획승인권자에게 사업계획승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제21조제1항에서는 같은 법 제15조제1항 등에 따라 주택건설사업계획의 승인을 받으려는 자는 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하여야 하되(본문), 다만 사업주체가 주택건설대지의 소유권을 확보하지 못하였으나 그 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우(제2호) 등에는 그러하지 아니하다(단서)고 규정하여 주택건설대지의 소유권 확보에 관한 사항을 규율하고 있습니다.

그런데 「주택법」 제5조제3항에서는 고용자가 그 근로자의 주택을 건설하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 등록사업자와 공동으로 사업을 시행하여야 한다고 규정하여, ‘공동사업주체’가 사업을 시행하는 경우에 대해 필요한 사항을 대통령령으로 정하도록 위임하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제16조제3항제2호에서는 고용자가 등록사업자와 공동으로 주택을 건설하려는 경우 같은 법 제15조에 따른 사업계획승인을 신청하기 위해 갖추어야 할 요건으로 ‘고용자가 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하고 있을 것’을 규정하고 있어, 특별히 ‘공동사업주체’가 주택건설사업을 시행하는 경우에 사업계획승인 신청을 위해 갖추어야 할 요건들에 관해 별도로 규정하고 있는바, 같은 법 제21조의 대지 소유권 확보에 관한 내용은 고용자와 등록사업자가 공동사업주체로서 주택건설사업을 시행하는 경우에도 그대로 적용된다고 보기는 어렵습니다.

7) 대법원 2003. 1. 27.자 2000마2997 결정례 참조

그리고 「주택법 시행령」 제16조제1항제2호 및 제3항제1호에 따르면 주택건설사업의 공동사업주체는 주택건설사업계획의 승인을 받기 위해서 주택건설대지가 저당권 등의 목적으로 되어 있는 경우 그 저당권 등을 말소하거나, 저당권 등의 권리자로부터 사업 시행에 대한 동의를 받아야 한다고 규정하고 있는데, 이는 저당권자의 저당권 실행 등으로 인하여 공동사업주체가 주택건설대지의 소유권을 상실하게 되는 경우 입주예정자가 불측의 손해를 입게 되는 것을 방지하기 위한 규정으로서, 이처럼 주택법령에서는 단순히 주택건설대지의 소유권을 확보하도록 하는 것을 넘어 해당 토지를 안정적이고 지속적인 사용이 가능한 상태로 소유할 것까지를 요구하고 있다고 할 것인바⁸⁾, 이러한 취지에 비추어 보면 「주택법」 제5조제3항 및 같은 법 시행령 제16조제3항제2호에서 고용자가 등록사업자와 공동으로 주택을 건설하려는 경우 주택건설사업계획의 승인 요건으로 고용자로 하여금 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하도록 한 것은 주택건설사업을 원활하고 안정적으로 시행하려는 취지로 보이고, 만약 고용자와 등록사업자가 공동사업주체로서 사업시행을 하는 경우 주택건설대지의 소유권을 확보할 의무가 부과되어 있는 고용자가 「주택법」 제21조제1항제2호를 근거로 주택건설대지를 사용할 수 있는 권원만을 확보한 상태에서 사업계획승인 신청이 가능하다고 보게 되면, 고용자에 의해 주택건설대지의 소유권이 안정적으로 확보되지 않은 상태에서 해당 주택건설사업이 진행될 수 있으므로, 위와 같은 주택법령의 취지에 부합하지 않는다고 할 것입니다.

아울러 대지의 소유권 확보에 대한 주택법령의 입법연혁을 살펴보면, 2005년 1월 8일 법률 제7334호로 일부개정된 「주택법」에서 현행 「주택법」 제21조제1항제2호에 해당하는 규정이 신설되었는데, 당시 법령의 개정 취지는 주로 투기를 목적으로 한 일부 비윤리적인 토지매입 행위를 방지하려는 데에 있었던 것으로서,⁹⁾ 해당 규정의 신설로 인해 종전부터 시행되어 오던 사업계획승인 신청 시 공동사업주체의 소유권 확보 규정에 대해서는 법률상 변동이 없었다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 고용자가 「주택법」 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인을 신청하기 위해서는 주택건설대지의 소유권을 확보해야 합니다.

8) 법제처 2018. 11. 2. 회신 18-0378 해석례 참조

9) 개정 당시 사용권원을 확보하지 못한 토지에 대한 매도청구권 규정이 함께 신설되었음(2004. 10. 22. 의안번호 제170618호로 발의된 주택법중개정법률안에 대한 국회 건설교통위원회 심사보고서 참조)

법령정비 권고사항

「주택법」 제5조제3항에 따라 고용자가 그 근로자의 주택을 건설하기 위해 등록사업자와 공동으로 사업을 시행하는 경우로서, 같은 법 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인을 신청하는 경우에는 같은 법 제21조제1항제2호의 규정이 적용되지 않음을 명시적으로 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

주택법

제5조(공동사업주체) ①·② (생략)

③ 고용자가 그 근로자의 주택을 건설하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 등록사업자와 공동으로 사업을 시행하여야 한다. 이 경우 고용자와 등록사업자를 공동사업주체로 본다.

④ (생략)

제15조(사업계획의 승인) ① 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택건설사업을 시행하려는 자 또는 대통령령으로 정하는 면적 이상의 대지조성사업을 시행하려는 자는 다음 각 호의 사업계획 승인권자(이하 “사업계획승인권자”라 한다. 국가 및 한국토지주택공사가 시행하는 경우와 대통령령으로 정하는 경우에는 국토교통부장관을 말하며, 이하 이 조, 제16조부터 제19조까지 및 제21조에서 같다)에게 사업계획승인을 받아야 한다. 다만, 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 주택건설사업 또는 대지조성사업으로서 해당 대지면적이 10만제곱미터 이상인 경우: 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 또는 「지방자치법」 제198조에 따라 서울특별시·광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상의 대도시(이하 “대도시”라 한다)의 시장
2. 주택건설사업 또는 대지조성사업으로서 해당 대지면적이 10만제곱미터 미만인 경우: 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수

② ~ ⑥ (생략)

제21조(대지의 소유권 확보 등) ① 제15조제1항 또는 제3항에 따라 주택건설사업계획의 승인을 받으려는 자는 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. (생략)
2. 사업주체가 주택건설대지의 소유권을 확보하지 못하였으나 그 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우
3. 4. (생략)

② (생 략)

주택법 시행령

제16조(공동사업주체의 사업시행) ①·② (생 략)

③ 법 제5조제3항에 따라 고용자가 등록사업자와 공동으로 주택을 건설하려는 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 법 제15조에 따른 사업계획승인을 신청하여야 한다.

1. 제1항 각 호의 요건을 모두 갖추고 있을 것
2. 고용자가 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하고 있을 것

질의제목 31

▶ 안전번호 25-0317

민원인 - 건축공사의 설계, 시험, 검사업무에 대해서만 2년 이상 종사한 경력이 있는 건축사보가 「건축법 시행령」 제19조제6항 전단에 따른 공사현장에서 감리업무를 수행할 수 있는지(「건축법 시행령」 제19조 등 관련)

01 질의요지

「건축법 시행령」 제19조제6항에서는 공사감리자는 같은 조 제5항 각 호에 해당하지 않는 건축공사로서 깊이 10미터 이상의 토지 굴착공사 또는 높이 5미터 이상의 옹벽 등의 공사(이하 “굴착공사등”이라고 함)를 감리하는 경우에는 건축사보¹⁾ 중 건축 또는 토목 분야의 건축사보 한 명 이상을 해당 공사기간 동안 공사현장에서 감리업무를 수행하게 해야 한다고 규정하면서(전단), 이 경우 건축사보는 건축공사의 시공·공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람이어야 한다고 규정(후단)하고 있는바,

건축공사의 설계·시험·검사업무에 대해서만 2년 이상 종사한 경력이 있는 건축사보가 「건축법 시행령」 제19조제6항에 따른 굴착공사등의 공사현장²⁾에서 감리업무를 수행할 수 있는지?

02 회답

건축공사의 설계·시험·검사업무에 대해서만 2년 이상 종사한 경력이 있는 건축사보는 「건축법 시행령」 제19조제6항에 따른 굴착공사등의 공사현장에서 감리업무를 수행할 수 없습니다.

1) 「건축사법」 제2조제2호에 따른 건축사보를 말하며, 「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 또는 「건축사법」 제23조제9항 각 호의 건설엔지니어링사업자 등에 소속되어 있는 사람으로서 「국가기술자격법」에 따른 해당 분야 기술계 자격을 취득한 사람과 「건설기술 진흥법 시행령」 제4조에 따른 건설사업관리를 수행할 자격이 있는 사람을 포함함(「건축법 시행령」 제19조제5항)

2) 「건축법」 제11조에 따라 건축허가를 받은 건축물 중 「건축법 시행령」 제19조제5항에 따른 공사를 제외한 건축공사의 공사현장을 전제함

03 이유

「건축법 시행령」 제19조제5항에서는 공사감리자는 수시로 또는 필요할 때 공사현장에서 감리업무를 수행해야 하며, 아파트 건축공사(제3호) 등 같은 항 각 호의 건축공사(이하 “아파트공사등”이라 함)를 감리하는 경우에는 건축사보 중 건축 분야의 건축사보 한 명 이상을 전체 공사기간 동안, 토목·전기 또는 기계 분야의 건축사보 한 명 이상을 각 분야별 해당 공사기간 동안 각각 공사현장에서 감리업무를 수행하게 해야 한다고 규정하면서, 이 경우 건축사보는 해당 분야의 건축공사의 설계·시공·시험·검사·공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람이어야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제7항에서는 공사감리자는 마감공사등을 감리하는 경우로서 국토교통부령으로 정하는 경우에는 건축 또는 안전관리 분야의 건축사보 한 명 이상이 마감재료 설치공사기간 동안 그 공사현장에서 감리업무를 수행하게 해야 한다고 규정하면서, 이 경우 건축사보는 건축공사의 설계·시공·시험·검사·공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람이어야 한다고 규정하고 있는바, 「건축법 시행령」 제19조제5항 및 제7항에서는 건축사보가 갖추어야 하는 경력으로 인정되는 업무분야를 해당 분야의 건축공사의 설계·시공·시험·검사·공사감독 또는 감리업무 등으로 규정하고 있습니다.

그런데 「건축법 시행령」 제19조제6항에서는 공사감리자는 같은 조 제5항에 따른 아파트공사등에 해당하지 않는 굴착공사등을 감리하는 경우에는 건축사보 중 건축 및 토목 분야의 건축사보 한 명 이상을 해당 공사기간 동안 공사현장에서 감리업무를 수행하게 해야 한다고 규정하면서, 이 경우 건축사보는 건축공사의 시공·공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람이어야 한다고 규정하여, 같은 조 제5항 후단 및 제7항 후단과는 달리 건축사보가 갖추어야 하는 경력에 건축공사의 설계·시험·검사업무에 종사한 경력은 규정하고 있지 않은바, 이 사안과 같이 건축공사의 설계·시험·검사업무에 대해서만 2년 이상 종사한 경력이 있는 건축사보의 경우에는 같은 조 제6항에 따른 굴착공사등의 공사현장에 배치될 수 있는지가 문제됩니다.

먼저 「건축법 시행령」 제19조제6항의 입법연혁을 살펴보면, 종전에는 건축사보가 굴착공사등의 현장에 공사기간 동안 상주하지 않아도 되어 적시에 부설시공을 발견하거나 시정하지 못하여 부실한 굴착공사등으로 인해 인접 건축물이 붕괴되거나 균열되는 피해를 유발할 수 있으므로 이를 방지하기 위하여³⁾ 2020년 4월 21일 대통령령 제30626호로

3) 2020. 4. 21. 대통령령 제30626호로 일부개정된 「건축법 시행령」 조문별 제·개정 이유서 참조

일부개정된 「건축법 시행령」에서 제19조제6항을 신설하여, 공사감리자가 굴착공사등을 감리하는 경우에는 건축 또는 토목 분야의 건축사보 한 명 이상을 해당 공사기간 동안 공사현장에서 감리업무를 수행하도록 한 것이고, 인근 건축물에 피해를 줄 수 있는 굴착공사 등의 특성 및 위험성을 고려하여 굴착공사등의 공사현장에서 감리업무를 수행할 수 있는 건축사보는 건축공사의 시공·공사감독 또는 감리업무 등 업무에 2년 이상 종사한 경력을 갖추도록 하여⁴⁾ 해당 건축공사 현장에 필요한 업무에 전문성을 갖춘 자를 배치할 수 있도록 한 것입니다.

특히 「건축법 시행령」 제19조에서 일정한 건축공사의 경우 해당 공사기간 동안 일정 분야의 건축사보로 하여금 공사현장에서 직접 감리업무를 수행하도록 한 취지는 대규모 건축공사 등에서 건축, 토목 등과 같은 중요한 분야의 공사를 할 때에는 해당 공사기간 동안 그 분야의 전문가로 하여금 공사현장에 상주하면서 감리업무를 수행하도록 하여 공사의 품질과 안전 등을 담보하려는 것인데⁵⁾, 굴착공사등은 시공과정에서 부실시공을 발견·시정하지 못하면 인접 건축물에서 붕괴 및 균열 등 안전사고가 발생할 수 있어 해당 분야의 전문기술과 경력을 갖춘 인력이 현장에 상주하여 설계도서 내용대로 시공하였는지 여부를 확인할 수 있어야 할 것인바⁶⁾, 이에 따라 「건축법 시행령」 제19조제6항에 따른 굴착공사등의 공사현장에서 감리업무를 수행할 수 있는 건축사보의 경우 건축공사와 직접 관련되는 경력인 건축공사의 시공·공사감독 또는 감리업무의 경력이 반드시 필요하다고 보는 것이 입법 취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

아울러 「건축법」 제40조제4항에서는 손괴의 우려가 있는 토지에 대지를 조성하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 옹벽을 설치하거나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제41조제1항에서는 공사시공자는 건축공사를 하기 위하여 토지를 굴착하는 경우 그 변경 부분에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사 중 비탈면 붕괴, 토사 유출 등 위험 발생의 방지, 환경 보존, 그 밖에 필요한 조치를 한 후 해당 공사현장에 그 사실을 게시하여야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제25조에서는 옹벽의 외벽면에는 이의 지지 또는 배수를 위한 시설외의 구조물이 밖으로 튀어나오지 아니하게 할 것(제3호) 등의 조치를 하도록 규정하고 있고, 같은 규칙 제26조 제1항에서는 같은 법 제41조제1항에 따라 건축공사에 수반하는 토지를 굴착하는 경우에는 지하에 묻은 수도관·하수도관·가스관 또는 케이블등이 토지굴착으로 인하여 파손되지

4) 2020. 4. 21. 대통령령 제30626호로 일부개정된 「건축법 시행령」 개정이유 및 주요내용 참조

5) 법제처 2016. 10. 13. 회신 16-0523 해석례 참조

6) 2020. 4. 21. 대통령령 제30626호로 일부개정된 「건축법 시행령」에 대한 규제영향분석서 참조

아니하도록 하는(제1호) 등의 조치를 하여야 한다고 규정하고 있는바, 위와 같이 건축법령에서 정하고 있는 굴착공사등에 따른 위험발생 방지조치의 내용은 건축공사의 시공 및 공사의 감독, 감리업무 등과 보다 밀접하게 관계된 내용이라는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

한편 「건축법 시행령」 제19조제5항 및 제7항에서는 해당 공사에 배치할 수 있는 건축사보의 경력에 대하여 건축공사의 설계·시공·시험·검사·공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람이야 한다고 규정하고 있으므로, 같은 조 제6항에 따른 굴착공사등에도 건축공사의 설계·시험·검사업무에 대해서만 2년 이상 종사한 경력이 있는 건축사보도 배치될 수 있다는 의견이 있으나, 같은 조 제5항에서는 부실공사를 막기 위한 조치로서 공사감리자는 아파트공사등을 감리하는 경우에는 건축 분야의 건축사보 한 명 이상을 전체 공사기간 동안, 토목·전기 또는 기계 분야의 건축사보 한 명 이상을 각 분야별 해당 공사기간 동안 각각 공사현장에서 감리업무를 수행하게 하도록 규정하여 각 분야별 공사에 2명 이상의 건축사보를 배치하도록 규정하고 있고, 같은 조 제6항은 굴착공사등의 안전을 강화해 인접 건축물의 피해를 방지하기 위하여 특정한 경력이 있는 건축사보 한 명 이상을 공사 기간 동안 배치하도록 규정하고 있으며, 같은 조 제7항은 공장, 창고시설 등의 용도로 쓰는 건축물의 마감재료 설치공사의 안전을 강화하기 위해 건축사보를 배치하도록 한 것이라는 점을 고려하면, 같은 조 제5항부터 제7항까지의 규정은 각각 성격이 다른 공사현장의 특수성을 고려하여 요구하는 경력을 다르게 규정한 것으로 보이므로, 그러한 주장은 타당하지 않습니다.

따라서 건축공사의 설계·시험·검사업무에 대해서만 2년 이상 종사한 경력이 있는 건축사보는 「건축법 시행령」 제19조제6항에 따른 굴착공사등의 공사현장에서 감리업무를 수행할 수 없습니다.



관계법령

건축법

제25조(건축물의 공사감리) ① 건축주는 대통령령으로 정하는 용도·규모 및 구조의 건축물을 건축하는 경우 건축사나 대통령령으로 정하는 자를 공사감리자(공사시공자 본인 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조에 따른 계열회사는 제외한다)로 지정하여 공사감리를 하게 하여야 한다.

② ~ ⑭ (생략)

건축법 시행령

제19조(공사감리) ① ~ ④ (생략)

⑤ 공사감리자는 수시로 또는 필요할 때 공사현장에서 감리업무를 수행해야 하며, 다음 각 호의 건축공사를 감리하는 경우에는 「건축사법」 제2조제2호에 따른 건축사보(「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 또는 「건축사법」 제23조제9항 각 호의 건설엔지니어링사업자 등에 소속되어 있는 사람으로서 「국가기술자격법」에 따른 해당 분야 기술계 자격을 취득한 사람과 「건설기술 진흥법 시행령」 제4조에 따른 건설사업관리를 수행할 자격이 있는 사람을 포함한다. 이하 같다) 중 건축 분야의 건축사보 한 명 이상을 전체 공사기간 동안, 토목·전기 또는 기계 분야의 건축사보 한 명 이상을 각 분야별 해당 공사기간 동안 각각 공사현장에서 감리업무를 수행하게 해야 한다. 이 경우 건축사보는 해당 분야의 건축공사의 설계·시공·시험·검사·공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람이어야 한다.

1. 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축공사. 다만, 축사 또는 작물 재배사의 건축공사는 제외한다.
2. 연속된 5개 층(지하층을 포함한다) 이상으로서 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 건축공사
3. 아파트 건축공사
4. 준다중이용 건축물 건축공사

⑥ 공사감리자는 제5항 각 호에 해당하지 않는 건축공사로서 깊이 10미터 이상의 토지 굴착공사 또는 높이 5미터 이상의 옹벽 등의 공사(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제14호에 따른 산업단지에서 바닥면적 합계가 2천제곱미터 이하인 공장을 건축하는 경우는 제외한다)를 감리하는 경우에는 건축사보 중 건축 또는 토목 분야의 건축사보 한 명 이상을 해당 공사기간 동안 공사현장에서 감리업무를 수행하게 해야 한다. 이 경우 건축사보는 건축공사의 시공·공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람이어야 한다.

⑦ 공사감리자는 제61조제1항제4호에 해당하는 건축물의 마감재료 설치공사를 감리하는 경우로서 국토교통부령으로 정하는 경우에는 건축 또는 안전관리 분야의 건축사보 한 명 이상이 마감재료 설치공사기간 동안 그 공사현장에서 감리업무를 수행하게 해야 한다. 이 경우 건축사보는 건축공사의 설계·시공·시험·검사·공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람이어야 한다.

⑧ 공사감리자는 제5항부터 제7항까지의 규정에 따라 건축사보로 하여금 감리업무를 수행하게 하는

경우 다른 공사현장이나 공정의 감리업무를 수행하고 있지 않는 건축사보가 감리업무를 수행하게 해야 한다.

⑨ 공사감리자가 수행하여야 하는 감리업무는 다음과 같다.

1. 공사시공자가 설계도서에 따라 적합하게 시공하는지 여부의 확인
2. 공사시공자가 사용하는 건축자재가 관계 법령에 따른 기준에 적합한 건축자재인지 여부의 확인
3. 그 밖에 공사감리에 관한 사항으로서 국토교통부령으로 정하는 사항

⑩ ~ ⑬ (생략)

제2절 주택관리·부동산

질의제목 1 ▶ 안전번호 24-0861

민원인 - 「주택법 시행령」 제16조제1항제2호의 “저당권등”의 범위에 질권이 포함되는지 여부(「주택법 시행령」 제16조제1항제2호 등 관련)

01 질의요지

「주택법」 제5조제1항 전단에서는 토지소유자가 주택¹⁾을 건설하는 경우에는 같은 법 제4조제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 같은 법 제4조에 따라 등록을 한 자(이하 “등록사업자”라 함)와 공동으로 사업을 시행할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제16조제1항에서는 공동으로 주택을 건설하려는 토지소유자와 등록사업자는 같은 항 각 호의 요건을 모두 갖추어 사업계획승인을 신청하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 제2호에서는 주택건설대지가 저당권·가등기담보권·가압류·전세권·지상권 등(이하 “저당권등”이라 함)의 목적으로 되어 있는 경우에는 그 저당권등을 말소할 것(본문), 다만 저당권등의 권리자로부터 해당 사업의 시행에 대한 동의를 받은 경우는 예외로 한다(단서)고 규정하고 있는바,

「주택법 시행령」 제16조제1항제2호의 “저당권등”의 범위에 질권²⁾이 포함되는지?

02 회답

「주택법 시행령」 제16조제1항제2호의 “저당권등”의 범위에 질권이 포함됩니다.

1) 「주택법」 제2조제1호에 따른 “주택”을 말하며, 이하 같음

2) 「민법」 제348조에 따른 저당권으로 담보한 채권을 목적으로 하는 질권의 경우임을 전제함

03 이유

「주택법 시행령」 제16조제1항에서는 공동으로 주택을 건설하려는 토지소유자와 등록사업자는 같은 항 각 호의 요건을 모두 갖추어 사업계획승인을 신청하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 제2호에서는 주택건설대지가 저당권·가등기담보권·가압류·전세권·지상권 등(이하 “저당권등”이라 함)의 목적으로 되어 있는 경우에는 그 저당권등을 말소할 것(본문)이라고 규정하여, “저당권등”에 관하여 저당권·가등기담보권·가압류·전세권·지상권 등이라고 규정하고 있을 뿐, 이러한 “저당권등”의 범위에 질권이 포함되는지 여부에 관해서는 별도로 규정하고 있지 않은바, 이는 주택법령의 문언, 전반적인 체계와 취지·목적, 해당 조항의 규정 형식과 내용 등을 종합적으로 고려하여 해석하여야 할 것입니다.³⁾

먼저 일반적으로 법령에서 하나 또는 수개의 사항을 열거하고 그 뒤에 “등”을 사용한 경우 열거된 사항은 예시사항이라 할 것이고, 별도로 해석해야 할 특별한 이유가 없는 한 그 “등”에는 열거된 예시사항과 규범적 가치가 동일하거나 그에 준하는 성질을 가지는 사항이 포함되는 것으로 해석함이 상당하다고 할 것인데,⁴⁾ 「주택법 시행령」 제16조제1항제2호에서 “등” 앞에 열거된 저당권, 가등기담보권, 가압류, 전세권, 지상권은 사업계획승인의 신청을 위해 갖추어야 할 요건으로서 토지소유자와 등록사업자가 주택법령에 따라 공동으로 주택을 건설하려는 경우 말소해야 하거나 그 권리자로부터 해당 사업의 시행에 대한 동의를 받아야 하는 대상들의 예시를 나열한 것이라는 점에서, 「주택법 시행령」 제16조제1항제2호에 따른 “저당권등”의 범위는 문언상 열거된 저당권, 가등기담보권, 가압류, 전세권, 지상권만으로 한정하여 해석해야 하는 것은 아니라 할 것입니다.

특히 「주택법 시행령」 제16조제1항제2호에 관한 입법연혁을 살펴보면, 공동사업주체의 사업시행과 관련하여 1988년 6월 16일 대통령령 제12461호로 일부개정된 「주택건설촉진법 시행령」에서 제34조의2제2호를 신설하여 “저당권”이라는 하나의 권리만을 말소 등의 대상으로 규정하였는데, 이후 1993년 2월 20일 대통령령 제13850호로 일부개정된 「주택건설촉진법시행령」 제34조의3제2호에서는 “저당권·가등기담보권·가압류·전세권·지상권 등”을 말소 등의 대상으로 규정하여 저당권 외에도 가등기담보권 등 다른 종류의 권리를 추가하고 해당 권리 뒤에 “등”을 덧붙여 규정하게 된 것인바, 이처럼 말소 등이 필요한 권리의

3) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2004도7807 판결례 참조

4) 법제처 2014. 10. 10. 회신 14-0498 해석례 참조

범위를 확대한 입법연혁을 고려하면, 저당권·가등기담보권·가압류·전세권·지상권 외에도 그 권리의 실행으로 사업주체가 주택건설대지의 소유권을 상실하거나 사용·수익권이 제한될 가능성이 있는 경우에는 해당 권리도 「주택법 시행령」 제16조제1항제2호의 “저당권등”에 포함될 수 있다고 해석하는 것이 합리적입니다.

그리고 「주택법」 제21조제1항 본문에서는 같은 법 제15조제1항 또는 제3항에 따라 주택건설사업계획의 승인을 받으려는 자는 원칙적으로 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제16조제1항제2호에서는 공동으로 주택을 건설하려는 토지소유자와 등록사업자는 주택건설사업계획의 승인을 받기 위해서 주택건설대지가 저당권등의 목적으로 되어 있는 경우 그 저당권등을 말소하거나, 그 저당권등의 권리자로부터 해당 사업의 시행에 대한 동의를 받도록 규정하고 있는데, 이는 주택건설사업을 원활하고 안정적으로 시행함과 동시에 저당권등의 실행으로 인하여 사업주체가 주택건설대지의 소유권을 상실하게 되는 경우 입주예정자가 예측할 수 없는 손해를 입게 되는 것을 방지하기 위한 데에 그 취지가 있는 점 등에 비추어 보면, 주택법령에서는 사업주체로 하여금 주택건설대지의 소유권을 확보하는 것뿐만 아니라, 주택건설대지를 목적으로 하여 설정된 저당권등에 대한 말소 또는 그 권리자로부터의 사업 시행에 대한 동의를 통해 해당 토지를 안정적이고 지속적으로 사용이 가능한 상태로 소유할 것까지를 요구하고 있다고 할 것인바,⁵⁾ 어떠한 권리가 「주택법 시행령」 제16조제1항제2호에 따른 “저당권등”의 범위에 포함되는지 여부는 주택건설대지 자체를 목적으로 하는지 여부만을 기준으로 한정하여 해석해야 하는 것은 아니고, 그 권리의 실행으로 인해 실질적으로 주택건설대지의 사용 등을 제한하는 법적 효과를 발생시킨다면, 그러한 권리도 같은 호에 따른 “저당권등”의 범위에 포함된다고 보는 것이 입법취지에 부합하는 해석입니다.

그런데 일반적으로 질권의 경우에는 부동산인 주택건설대지를 직접 그 목적으로 할 수 없으나, 이 사안과 같이 주택건설대지를 저당부동산으로 하는 저당권으로 담보된 채권(이하 “저당권부 채권”이라 함)에 질권이 설정된 경우, 해당 저당권부 채권의 질권자는 관련 법령상의 요건을 갖추게 되면⁶⁾ 그 질권에 기하여 저당권을 직접 실행할 수도 있게 되는데(「민법」 제348조·제353조·제354조), 이 경우 사업주체가 주택건설대지의 소유권을 상실하는 등 「주택법 시행령」 제16조제1항제2호의 저당권등의 실행과 실질적으로 동일하게 주택건설대지의 사용에 제한을 가하는 효과를 발생시킬 수 있는바, 이러한 법적 효과로 인하여 주택건설사업의 안정적인 시행을 어렵게 만들 수 있는 이 사안 질권의 경우에는 「주택법

5) 법제처 2018. 11. 2. 회신 18-0378 해석례 참조

6) 질권의 피담보채권이 이행지체되고, 질권이 설정된 저당권부 채권의 변제기가 도래하는 경우를 말함

시행령」 제16조제1항제2호에 따른 “저당권등”의 범위에 포함된다고 해석하는 것이 그 규정의 취지에 부합하는 해석입니다.

따라서 「주택법 시행령」 제16조제1항제2호의 “저당권등”의 범위에 질권이 포함됩니다.



관계법령

주택법

제5조(공동사업주체) ① 토지소유자가 주택을 건설하는 경우에는 제4조제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 제4조에 따라 등록을 한 자(이하 “등록사업자”라 한다)와 공동으로 사업을 시행할 수 있다. 이 경우 토지소유자와 등록사업자를 공동사업주체로 본다.

② ~ ④ (생략)

주택법 시행령

제16조(공동사업주체의 사업시행) ① 법 제5조제1항에 따라 공동으로 주택을 건설하려는 토지 소유자와 등록사업자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 법 제15조에 따른 사업계획승인을 신청하여야 한다.

1. (생략)
2. 주택건설대지가 저당권·가등기담보권·가압류·전세권·지상권 등(이하 “저당권등”이라 한다)의 목적으로 되어 있는 경우에는 그 저당권등을 말소할 것. 다만, 저당권등의 권리자로부터 해당 사업의 시행에 대한 동의를 받은 경우는 예외로 한다.

3. (생략)

②·③ (생략)

질의제목 2

▶ 안전번호 24-0949

민원인 - 지역주택조합 설립인가 신청 시 주택건설대지가 가압류의 목적으로 되어 있는 경우, 사업시행에 대한 가압류권리자의 동의서를 반드시 첨부하여 제출해야 하는지 여부(「주택법」 제11조제1항 등 관련)

01 질의요지

「주택법」 제11조제1항 전단에서는 많은 수의 구성원이 주택을 마련하거나 리모델링하기 위하여 주택조합¹⁾을 설립하려는 경우²⁾에는 관할 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 “시장·군수·구청장”이라 함)의 인가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 본문에서는 같은 조 제1항에 따라 주택을 마련하기 위하여 주택조합설립인가를 받으려는 자는 같은 항 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다고 규정하면서, 같은 항 제2호에서는 해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보할 것이라고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제20조제1항제1호 가목7)에서는 같은 법 제11조제1항에 따라 주택조합의 설립인가를 받으려는 자로서 지역주택조합³⁾의 경우에는 신청서에 해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보하였음을 증명하는 서류를 첨부하여 주택건설대지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 제출해야 한다고 규정하고 있는바,

주택건설대지가 가압류의 목적으로 되어 있는 경우⁴⁾, 「주택법」 제11조제1항에 따라 지역주택조합 설립인가를 받으려는 자는 같은 법 시행령 제20조제1항제1호가목7)에 따른 ‘해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보하였음을 증명하는 서류’로 해당 사업의 시행에 대한 가압류 권리자의 동의서를 반드시 신청서에 첨부하여 제출해야 하는지?

1) 「주택법」 제2조제11호에 따른 “주택조합”을 말하며, 이하 같음

2) 「주택법」 제11조제5항에 따른 직장주택조합의 경우는 제외하며, 이하 같음

3) 「주택법」 제2조제11호가목에 따른 “지역주택조합”을 말하며, 이하 같음

4) 해당 주택건설대지 중 「주택법」 제11조제2항제2호에 따라 지역주택조합 설립인가를 받으려는 자가 소유권을 확보한 토지에 가압류가 설정된 경우임을 전제로 함

02 회답

이 사안의 경우, 「주택법」 제11조제1항에 따라 지역주택조합 설립인가를 받으려는 자는 같은 법 시행령 제20조제1항제1호가목7)에 따른 ‘해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보하였음을 증명하는 서류’로 해당 사업의 시행에 대한 가압류 권리자의 동의서를 반드시 신청서에 첨부하여 제출해야 합니다.

03 이유

「주택법」 제11조제1항 전단에서는 많은 수의 구성원이 주택을 마련하기 위하여 주택조합을 설립하려는 경우에는 관할 시장·군수·구청장의 인가를 받아야 한다고 규정하면서, 같은 조 제2항제2호에서는 같은 조 제1항에 따라 주택을 마련하기 위하여 주택조합설립인가를 받으려는 자가 갖추어야 하는 요건 중 하나로 해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보할 것을 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제20조제1항제1호가목7)에서는 같은 법 제11조제1항에 따라 지역주택조합의 설립인가를 받으려는 자는 신청서에 해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보하였음을 증명하는 서류를 첨부하여 주택건설대지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 제출해야 한다고 규정하고 있는데, 토지 소유권의 확보에 관한 증명 서류의 구체적인 범위에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않은바, 이 사안과 같이 「주택법」 제11조제1항 및 같은 법 시행령 제20조제1항에 따른 지역주택조합 설립인가 신청 시 해당 주택건설대지가 가압류의 목적으로 되어 있는 경우, 토지 소유권의 확보를 증명하기 위해 반드시 해당 사업의 시행에 대한 가압류 권리자의 동의서를 신청서에 첨부하여 제출해야 하는지 여부를 판단하기 위해서는 주택법령의 전반적인 체계와 취지·목적 등을 종합적으로 고려하여 해석해야 할 것입니다⁵⁾.

먼저 주택법령에서는 주택조합사업에 대하여 사업 시행의 단계별로 구분하여 그 절차와 방법을 정하면서, 주택조합설립인가 단계와 사업계획승인 단계를 구분하여 규정하고 있는데, 「주택법」 제11조에서는 주택조합의 설립에 관하여 규정하면서 같은 조 제2항제2호에서는 주택조합설립인가 요건 중 하나로 해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의

5) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2004도7807 판결례 참조

소유권 확보를 규정하고 있고, 같은 법 제15조에서는 사업계획의 승인에 관하여 규정하면서 같은 법 제21조제1항에서는 같은 법 제15조에 따른 사업계획 승인의 요건 중 하나로 해당 주택건설대지의 소유권 확보를 규정하고 있는바, 「주택법」에서는 사업 단계별로 소유권 확보 비율상의 차이는 있으나, 주택조합의 설립인가와 사업계획의 승인 단계에서 모두 동일하게 그 요건으로 ‘토지 소유권의 확보’를 규정하고 있습니다.

그리고 「주택법 시행령」 제16조제2항에서는 주택을 건설하려는 주택조합⁶⁾과 등록사업자 등은 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 신청 시 주택건설대지가 저당권·가등기담보권·가압류·전세권·지상권 등(이하 “저당권등”이라 함)의 목적으로 되어 있는 경우에는 저당권등을 말소하거나, 그 권리자로부터 해당 사업의 시행에 대한 동의를 받아야 한다고 규정하면서, 이러한 요건은 소유권을 확보한 대지에 대해서만 적용한다고 규정하고 있어, 「주택법」에서 규정하고 있는 토지 소유권 확보의 의미를 하위법령에서 보다 구체적으로 정하고 있는 점을 고려하면, 법률 단계인 「주택법」상의 ‘토지 소유권 확보’는 단순히 주택건설대지의 소유권을 확보하는 것뿐만 아니라, 해당 토지를 안정적이고 지속적인 사용이 가능한 상태로 소유하는 것까지 의미한다고 할 것인바⁷⁾, 이러한 주택법령의 체계에 비추어 보면 이 사건과 같이 주택건설대지가 가압류의 목적으로 되어 있는 경우 「주택법 시행령」에서 주택조합설립인가의 요건으로 해당 가압류의 말소 또는 가압류 권리자의 동의를 명시적으로 규정하고 있지 않더라도 「주택법」에서 사용되는 토지 소유권 확보의 의미는 동일하게 해석·적용될 수 있을 것입니다.

또한 「주택법」은 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설·공급 및 주택시장의 관리 등에 관한 사항을 정함으로써 국민의 주거안정과 주거수준의 향상에 이바지함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 주택조합설립인가의 요건으로 같은 법 제11조제2항제2호에서 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보하도록 한 것은 주택조합제도에 대한 규제의 정도가 상대적으로 낮은 점으로 인하여 조합사업의 불투명한 운영 및 무주택 서민인 조합원들의 재산상 피해가 발생함에 따라 주택조합설립인가 요건을 강화하여 조합원의 재산권을 보호하고, 사업 추진의 안정성을 제고하려는 취지인바⁸⁾, 사업계획승인의 요건에 관한 같은 법 시행령 제16조제1항 및 제2항의 규정 또한 주택건설사업을 원활하고 안정적으로 시행함과 동시에 저당권등의 실행으로

6) 세대수를 늘리지 아니하는 리모델링주택조합은 제외함

7) 법제처 2018. 11. 2. 회신 18-0378 해석례 참조

8) 2020. 1. 23. 법률 제16870호로 일부개정된 「주택법」 개정이유 및 주요내용, 2019. 3. 15. 의안번호 제2019224호로 발의된 주택법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

인하여 사업주체가 주택건설대지의 소유권을 상실하게 되는 경우 입주예정자가 불측의 손해를 입게 되는 것을 방지하기 위한 취지의 규정⁹⁾인 점, 이 사안에서 만약 주택조합설립인가 후 가압류 권리자가 본안판결에서 승소함에 따라 채무자의 재산에 해당하는 주택건설대지에 대해 압류 절차가 진행될 경우, 토지 소유권을 충분히 확보하지 못하게 되어 사업 진행의 혼란, 조합원의 지위 불안 및 재산상 피해 등 각종 문제가 발생할 수 있는 점 등을 고려하면, 주택조합설립인가 단계에서부터 주택건설대지가 가압류의 목적으로 되어 있다면 가압류 권리자의 동의를 받은 경우에 「주택법」 제11조제2항제2호에 따른 토지의 소유권 확보 요건을 갖춘 것으로 보는 것이 주택법령의 입법 목적 및 취지에 부합합니다.

아울러 주택법령상 주택조합설립인가와 사업계획승인은 주택조합사업의 절차상 일련의 관계에 있고, 특히 주택조합설립인가의 경우에는 이후 단계인 사업계획의 승인 및 주택의 건설·공급 등 전체 주택건설사업의 안정적인 시행을 위한 토대가 되는데, 주택조합사업 과정에서 조합원의 피해를 줄이고, 신속하고 원활하게 사업을 추진하기 위해서는 안정적인 기반을 갖춘 주택조합의 설립이 필요하다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「주택법」 제11조제1항에 따라 지역주택조합 설립인가를 받으려는 자는 같은 법 시행령 제20조제1항제1호가목7)에 따른 ‘해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보하였음을 증명하는 서류’로 해당 사업의 시행에 대한 가압류 권리자의 동의서를 반드시 신청서에 첨부하여 제출해야 합니다.

법령정비 권고사항

「주택법」 제11조제1항에 따른 주택조합설립인가 시, 같은 조 제2항제2호에 따라 소유권을 확보한 토지가 저당권등의 목적으로 되어 있는 경우, 주택건설사업의 안정적인 시행을 위해 가압류·저당권등을 말소하거나 가압류·저당권 등의 권리자로부터 해당 사업의 시행에 대한 동의를 받아야 함을 조문에 명시하는 것이 바람직합니다.

9) 법제처 2018. 11. 2. 회신 18-0378 해석례 참조



관계법령

주택법

제11조(주택조합의 설립 등) ① 많은 수의 구성원이 주택을 마련하거나 리모델링하기 위하여 주택조합을 설립하려는 경우(제5항에 따른 직장주택조합의 경우는 제외한다)에는 관할 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 “시장·군수·구청장”이라 한다)의 인가를 받아야 한다. 인가받은 내용을 변경하거나 주택조합을 해산하려는 경우에도 또한 같다.

② 제1항에 따라 주택을 마련하기 위하여 주택조합설립인가를 받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 다만, 제1항 후단의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 해당 주택건설대지의 80퍼센트 이상에 해당하는 토지의 사용권원을 확보할 것
2. 해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보할 것

③ ~ ⑨ (생 략)

주택법 시행령

제20조(주택조합의 설립인가 등) ① 법 제11조제1항에 따라 주택조합의 설립·변경 또는 해산의 인가를 받으려는 자는 신청서에 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 첨부하여 주택건설대지(리모델링주택조합의 경우에는 해당 주택의 소재지를 말한다. 이하 같다)를 관할하는 시장·군수·구청장에게 제출해야 한다.

1. 설립인가신청: 다음 각 목의 구분에 따른 서류

가. 지역주택조합 또는 직장주택조합의 경우

1) ~ 6) (생 략)

7) 해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보하였음을 증명하는 서류

8) (생 략)

나. (생 략)

2. 3. (생 략)

② ~ ⑪ (생 략)

질의제목 3

▶ 안전번호 24-0990

민원인 - 「민간임대주택에 관한 특별법」 제44조제3항에 따른 임대사업자의 임대료 증액 청구 가능 여부
(「민간임대주택에 관한 특별법」 제44조제3항 등 관련)

01 질의요지

「민간임대주택에 관한 특별법」(이하 “민간임대주택법”이라 함) 제44조제2항에서는 임대사업자는 임대기간 동안 임대료의 증액을 청구하는 경우에는 임대료의 5퍼센트의 범위에서 주거비 물가지수, 인근 지역의 임대료 변동률, 임대주택 세대 수 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 증액 비율을 초과하여 청구해서는 아니 된다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제2항에 따른 임대료 증액 청구는 임대차계약 또는 약정한 임대료의 증액이 있는 후 1년 이내에는 하지 못한다고 규정하고 있는바,

임대사업자가 종전 임차인과 계약기간 1년의 임대차계약을 체결하였으나, 계약기간 만료 전에 해당 계약이 중도 해지되어 새로운 임차인과 임대료의 증액 없이 1년 미만의 종전 계약의 잔여기간으로 임대차계약을 체결하고¹⁾ 그 계약기간이 경과하여 종전 임차인과의 임대차계약 개시일부터 1년이 지난 시점에서 새로운 임차인과 계약기간을 연장하는 임대차계약을 체결하려는 경우,²⁾ 임대사업자는 임대료의 증액을 청구할 수 있는지?

02 회답

이 사안의 경우, 임대사업자는 임대료의 증액을 청구할 수 없습니다.

1) 종전 임차인의 법적 지위가 새로운 임차인에게 승계되지 않은 경우임을 전제로 함

2) 새로운 임차인과의 임대차계약 개시일부터 1년이 지나지 않음을 전제로 함

03 이유

민간임대주택법 제44조제3항에서는 같은 조 제2항에 따른 임대료 증액 청구는 임대차계약 또는 약정한 임대료의 증액이 있는 후 1년 이내에는 하지 못한다고 규정하여, 임대사업자가 임대료 증액을 청구할 수 없는 경우를 임대차계약 또는 약정한 임대료의 증액이 있는 후 “1년 이내”라고만 규정하고 있을 뿐이고, 별도로 그 임대차계약의 의미 등에 관해서는 규정하고 있지 않은바, 이는 “임대차계약이 있는 후 1년 이내” 또는 “약정한 임대료의 증액이 있는 후 1년 이내”에는 임대료의 증액 청구가 제한된다는 의미로서, 어떠한 민간임대주택에 대해 가장 최근에 체결된 임대차계약이 그 개시일부터 1년이 지나지 않은 경우라면 같은 조 제3항에 따라 임대료의 증액 청구가 제한되는 경우에 해당한다고 보아야 할 것이므로,³⁾ 이 사안과 같이 가장 최근에 체결한 임대차계약인 새로운 임차인과의 임대차계약이 개시일로부터 1년이 지나지 않은 경우에는 그 임대사업자는 임대료의 증액을 청구할 수 없다고 할 것입니다.

그리고 민간임대주택법 제44조제3항을 규정한 취지는 임대사업자의 빈번한 임대료 증액을 방지하여 임차인을 보호하기 위한 것이므로⁴⁾, 해당 규정은 임차인의 권익을 보호할 수 있는 방향으로 해석해야 할 것인데, 일반적으로 임대사업자가 종전 임차인과의 임대차계약 해지 후 새로운 임차인과 임대차계약을 체결하는 경우 종전 임차인의 법적 지위가 새로운 임차인에게 승계되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 각각의 임대차계약은 서로 별개의 계약인바, 만약 종전 임차인과의 임대차계약 개시일로부터 1년이 지났음을 이유로 새로운 임차인과의 임대차계약 개시일로부터 1년이 지나지 않은 시점에서 임대사업자가 같은 법 제44조제3항에 따라 임대료의 증액을 청구할 수 있다고 본다면, 임대차계약 개시일로부터 1년이 경과하지 않아 약정한 임대료가 증액되지 않을 것으로 기대하던 새로운 임차인은 예상하지 못한 손해를 입게 된다는 점에서, 임차인을 보호하려는 해당 규정의 입법 목적 및 취지에 부합하지 않습니다.

아울러 민간임대주택법에서는 국가 또는 지방자치단체는 민간임대주택의 공급 확대 등을 위해 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」 및 조례로 정하는 바에 따라 조세를 감면할 수 있다고 규정(제4조제1항)하여 임대사업자에게 세제혜택을 줄 수 있도록 하는 대신, 임대사업자에게는 임대의무기간(제43조) 및 임대료의 증액 청구 제한(제44조) 등의 의무를 부과하고 있다는 점에 비추어 볼 때, 같은 법 제44조제3항에 따른 임대료의 증액 청구의 제한

3) 법제처 2022. 3. 18. 회신 21-0797 해석례 참조

4) 2018. 8. 14. 법률 제15730호로 일부개정된 민간임대주택에법 개정이유 등 참조

사유를 임대사업자에게 유리한 방향으로 축소 해석하는 것은 타당하지 않다는 점⁵⁾도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 임대사업자는 임대료의 증액을 청구할 수 없습니다.



관계법령

민간임대주택에 관한 특별법

제44조(임대료) ① (생략)

② 임대사업자는 임대기간 동안 임대료의 증액을 청구하는 경우에는 임대료의 5퍼센트의 범위에서 주거비 물가지수, 인근 지역의 임대료 변동률, 임대주택 세대 수 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 증액 비율을 초과하여 청구해서는 아니 된다.

③ 제2항에 따른 임대료 증액 청구는 임대차계약 또는 약정한 임대료의 증액이 있는 후 1년 이내에는 하지 못한다.

④·⑤ (생략)

5) 법제처 2022. 3. 18. 회신 21-0797 해석례 참조

질의제목 4

▶ 안전번호 25-0008

민원인 - 「주택법」 제14조의2제2항에 따라 개최하는 총회에서의 주택조합 사업의 종결 여부에 관한 의결정족수 적용 여부(「주택법」 제14조의2제2항 등 관련)

01 질의요지

「주택법」 제14조의2제2항에서는 주택조합¹⁾의 발기인은 같은 법 제11조의3제1항에 따른 조합원 모집 신고가 수리된 날부터 2년이 되는 날까지 주택조합 설립인가를 받지 못하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 주택조합 가입 신청자 전원으로 구성되는 총회 의결을 거쳐 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하도록 하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제25조의2제3항에서는 같은 법 제14조의2제2항에 따라 개최하는 총회는 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결할 것(제1호) 등 같은 항 각 호의 요건을 모두 충족해야 한다고 규정하고 있는바,

「주택법」 제14조의2제2항에 따라 개최한 총회에서 주택조합 사업의 종결에 대한 찬성이 주택조합 가입 신청자의 3분의 2에 미달된 경우²⁾, 주택조합 사업의 진행을 결정한 것으로 보기 위해서는 별도로 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성으로 사업의 진행을 의결해야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 주택조합 사업의 진행을 결정한 것으로 보기 위해서 별도로 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성으로 사업의 진행을 의결해야 하는 것은 아닙니다.

1) 「주택법」 제2조제11호에 따른 “주택조합”을 말하며, 이하 같음

2) 해당 총회에서 주택조합 사업의 종결에 대한 반대도 주택조합 가입 신청자의 3분의 2에 미달된 경우임을 전제함

03 이유

먼저 「주택법」 제14조의2제2항에서는 주택조합의 발기인은 같은 법 제11조의3제1항에 따른 조합원 모집 신고가 수리된 날부터 2년이 되는 날까지 주택조합 설립인가를 받지 못하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 주택조합 가입 신청자 전원으로 구성되는 총회 의결을 거쳐 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하도록 하여야 한다고 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제25조의2제3항제1호에서는 같은 법 제14조의2제2항에 따라 개최하는 총회는 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결해야 한다고 규정하여 ‘사업의 종결 여부’에 대한 의결정족수에 관해 규정하고 있고, ‘사업 진행 여부’의 의결정족수에 관하여는 별도의 규정을 두고 있지 않은데, 만약 어떠한 안건이 이러한 의결정족수 요건을 충족하지 못하였다면, 이는 해당 안건을 의결하지 못한 것일 뿐, 해당 안건을 반대하는 경우, 즉 사업의 진행에 대해서까지 동일한 의결정족수가 별도로 요구된다고 보기는 어려운 점을 고려할 때, 「주택법」 제14조의2제2항에 따라 개최하는 총회에서 주택조합 사업을 종결하기로 결의하기 위해서는 같은 법 시행령 제25조의2제3항제1호에 따라 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결해야 하고, 만약 사업의 종결에 대하여 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하지 않았다면 이는 그 가부(可否)가 대상이 되는 의결 안건이 총회에서 부결(否決)된 것으로서, 문언상 사업의 종결 여부에 대한 부결은 사업이 종결되지 않음을 의미하는 것이어서 결국 사업이 진행됨을 의미한다고 보아야 할 것이므로, 이 사안의 경우 주택조합 사업의 진행을 결정한 것으로 보기 위해서 별도로 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성으로 사업의 진행을 의결해야 하는 것은 아닙니다.

특히 「주택법」에서는 조합원 모집 신고 및 수리(제11조의3), 주택조합의 설립인가(제11조), 사업계획의 승인(제15조) 등의 순서로 사업 단계를 구분하여 규정하고 있고, 각 단계별 요건을 충족하는 경우에는 관련 절차에 따라 사업이 다음 단계로 계속 진행된다고 할 것인데, 주택조합 설립인가의 요건 및 검토사항을 규정하고 있는 같은 법 제11조제2항 및 같은 법 시행령 제20조제9항 등에서는 ‘같은 영 제25조의2제3항제1호의 의결정족수를 충족한 총회 결의’를 주택조합 설립인가의 요건으로 규정하고 있지 않은바, 주택조합의 발기인으로서 총회에서 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성으로 사업의 종결을 의결하지 않는 이상 주택조합의 설립인가를 위한 요건을 갖춘 경우에는 주택법령에 따른 사업절차를 진행할 수 있다는 점을 고려하면, 같은 법 제14조의2제2항은 조합원 모집 신고가 수리된 이후 원래대로 사업이 진행되는 것을 전제로 하여 일정한 기간이 경과한 경우에는 주택조합 가입 신청자들이 중도에 사업을 종결할 수 있도록 하는 규정으로 보는 것이 규정의 체계에 비추어 볼 때 합리적인 해석입니다.

그리고 주택조합의 해산 등에 관하여 규정하고 있는 「주택법」 제14조의2는 장기간 주택사업이 지연되는 경우 납입금을 운영비용 등으로 사용함에 따라 조합원 납입금에 대한 환급 가능성이 낮아지는 점을 고려하여 조합원 등의 피해를 최소화하기 위해 조합원 모집신고 후 일정 기간 사업이 지연되면 조기에 주택조합 사업을 종결할 수 있도록 하여³⁾ 불안정한 조합 등의 법률관계에서 벗어나 조합원들의 재산권을 보호하려는 취지에서⁴⁾ 2020년 1월 23일 법률 제16870호로 일부개정된 「주택법」에서 신설된 규정인바, 「주택법」 제14조의2 및 같은 법 시행령 제25조의2는 주택조합 사업의 장기간 지연 시 사업 종결과 관련된 절차를 신속히 진행하기 위해 제정된 규정으로서, 같은 법 시행령 제25조의2제3항제1호의 의결정족수 규정은 ‘사업의 종결’을 결의하는 경우에 한해 적용되는 것으로 해석하는 것이 규정의 취지에 부합합니다.

아울러 ① 「주택법」 제14조의2제2항은 조합원 모집 신고 이후 설립인가를 받지 못한 경우 해산할 수 있는 실체가 없으므로 조합가입 신청자의 총회를 거쳐 사업의 종결 여부를 결정하도록 한 것으로, 같은 조 제1항에서 규정하고 있는 장기간 사업 지연 시 주택조합을 해산할 수 있도록 한 규정과 그 취지가 동일하다고 할 것인데⁵⁾, 같은 조 제1항에서는 주택조합은 같은 법 제11조제1항에 따른 주택조합의 설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업계획승인을 받지 못하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 총회의 의결을 거쳐 ‘해산 여부’를 결정하여야 한다고 규정하고 있고, 주택법령에서는 조합 해산의 결의를 위한 총회의 의결정족수를 ‘조합규약’에서 정하도록 규정하고 있으며⁶⁾, 지역·직장주택조합 표준규약서⁷⁾에서 조합 해산을 의결하는 경우에는 재적조합원 3분의 2 이상의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다고 규정하고 있는 점, ② 만약 주택조합 사업의 진행을 결정한 것으로 보기 위해서 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성이 별도로 필요하다고 본다면, 사업의 종결 또는 진행 모두 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성 요건을 충족하지 못할 경우에는 양자 중 어느 경우이든 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성이 있을 때까지 총회를 계속하여 개최해야 한다는 결론에 이르게 되어, 이로 인해 해당 사업의 법적 상태가 불안정한 상태로 지속되는 한편, 수차례 총회 개최에 따른 비용 부담으로 환급받을 납입금이 감소하는 등 주택조합 가입 신청자들의 재산상 피해가 확대될 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

3) 2019. 3. 15. 의안번호 제2019224호로 발의된 주택법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

4) 수원지방법원 성남지원 2021. 2. 10. 선고 2018가단239331 판결례(심리불속행 기각) 참조

5) 2019. 3. 15. 의안번호 제2019224호로 발의된 주택법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

6) 「주택법 시행령」 제20조제2항제9호, 같은 조 제3항, 같은 법 시행규칙 제7조제6항제8호 등 참조

7) 국토교통부, 지역·직장주택조합제도 해설서(2022) 중 지역·직장주택조합 표준규약서 제24조 참조

따라서 이 사안의 경우, 주택조합 사업의 진행을 결정한 것으로 보기 위해서 별도로 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성으로 사업의 진행을 의결해야 하는 것은 아닙니다.



관계법령

주택법

제14조의2(주택조합의 해산 등) ① (생 략)

② 주택조합의 발기인은 제11조의3제1항에 따른 조합원 모집 신고가 수리된 날부터 2년이 되는 날까지 주택조합 설립인가를 받지 못하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 주택조합 가입 신청자 전원으로 구성되는 총회 의결을 거쳐 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하도록 하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

주택법 시행령

제25조의2(주택조합의 해산 등) ①·② (생 략)

③ 법 제14조의2제2항에 따라 개최하는 총회는 다음의 요건을 모두 충족해야 한다.

1. 주택조합 가입 신청자의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결할 것

2.·3. (생 략)

④ (생 략)

질의제목 5

▶ 안전번호 25-0035

민원인 - 재개발사업의 정비구역에 상가를 소유한 토지등소유자가 「도시 및 주거환경정비법」 제76조제1항 제7호라목에 따라 2주택을 공급받을 수 있는지(「도시 및 주거환경정비법」 제76조제1항제7호 등 관련)

01 질의요지

「도시 및 주거환경정비법」(이하 “도시정비법”이라 함) 제74조제1항 본문에서는 사업시행자는 분양신청기간이 종료된 때에는 분양신청의 현황을 기초로 분양설계(제1호), 분양대상자의 주소 및 성명(제2호) 등 같은 항 각 호의 사항이 포함된 관리처분계획을 수립하여 시장·군수등¹⁾의 인가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제6항에서는 관리처분계획의 내용, 관리처분의 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련한 같은 법 시행령 제63조제1항제3호에서는 재개발사업의 관리처분은 정비구역의 토지등소유자²⁾(지상권자는 제외함)에게 분양하되(본문), 공동주택을 분양하는 경우 시·도조례로 정하는 금액·규모·취득 시기 또는 유형에 대한 기준에 부합하지 아니하는 토지등소유자는 시·도조례로 정하는 바에 따라 분양대상에서 제외할 수 있다고 규정(단서)하고 있는 한편,

도시정비법 제76조제1항에서는 관리처분계획의 내용은 같은 항 각 호의 기준에 따른다고 규정하면서, 같은 항 제6호에서는 1세대 또는 1명이 하나 이상의 주택 또는 토지를 소유한 경우 1주택을 공급한다고 규정하고 있고, 같은 항 제7호라목 본문에서는 같은 항 제6호에도 불구하고 같은 법 제74조제1항제5호에 따른 가격의 범위 또는 종전 주택의 주거전용면적의 범위에서 2주택을 공급할 수 있으며, 이 중 1주택은 주거전용면적을 60제곱미터 이하로 한다고 규정하고 있는바,

재개발사업의 정비구역에 상가를 소유한 토지등소유자로서 도시정비법 시행령 제63조제1항제3호 단서에 따른 분양 제외 대상에 해당하지 않는 토지등소유자³⁾에게 도시정비법 제76조제1항제7호라목에 따라 2주택을 공급하는 내용으로 관리처분계획을 수립할 수 있는지?

- 1) 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 자치구의 구청장을 말하며[도시정비법 제2조제2호나목1) 참조], 이하 같음
- 2) 재개발사업의 경우에는 정비구역에 위치한 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자를 말하며(도시정비법 제2조제9호 참조), 이하 같음
- 3) 주택 없이 상가 건물 및 해당 건물의 토지까지 함께 소유한 토지등소유자로서, 다른 규정 등에 따라 별도로 주택공급에 대한 제한을 받고 있지 않은 토지등소유자를 전제함

02 회답

재개발사업의 정비구역에 상가를 소유한 토지등소유자로서 도시정비법 시행령 제63조 제1항제3호 단서에 따른 분양 제외 대상에 해당하지 않는 토지등소유자에게 도시정비법 제76조제1항제7호라목에 따라 2주택을 공급하는 내용으로 관리처분계획을 수립할 수 있습니다.

03 이유

먼저 도시정비법 제74조제1항 본문에서는 사업시행자는 분양신청기간이 종료된 때에는 분양신청의 현황을 기초로 관리처분계획을 수립하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다고 규정하면서, 같은 법 시행령 제63조제1항제3호에서는 재개발사업의 경우 관리처분은 정비구역의 지상권자를 제외한 토지등소유자에게 분양하되, 공동주택을 분양하는 경우 시·도조례로 정하는 금액·규모·취득 시기 또는 유형에 대한 기준에 부합하지 아니하는 토지등소유자는 시·도조례로 정하는 바에 따라 분양대상에서 제외할 수 있다고 규정하고 있는바, 위에서 살펴본 규정을 종합하여 보면 재개발사업의 토지등소유자가 시·도조례 등으로 정한 공동주택 분양대상 제외 요건에 해당하지 않는 경우에는 그 토지등소유자에게 공동주택을 분양할 수 있고, 이러한 내용의 관리처분계획을 수립할 수 있다고 할 것입니다.

그리고 도시정비법 제76조제1항제6호에서는 관리처분계획의 내용과 관련하여 1세대 또는 1명이 하나 이상의 주택 또는 토지를 소유한 경우 1주택을 공급하도록 원칙을 정하면서 같은 항 제7호에서는 같은 항 제6호에 대한 예외를 규정하고 있는데, 같은 항 제7호라목에서는 같은 법 제74조제1항제5호에 따른 가격의 범위 또는 종전 주택의 주거전용면적의 범위에서 2주택을 공급할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제74조제1항제5호에서는 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물 명세 및 사업시행계획인가 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격을 규정하고 있는바, 이 경우 2주택을 공급할 것인지를 판단할 때 종전에 보유하고 있던 토지 또는 건축물이 상가였는지 여부는 고려하지 않고 있는 점, 도시정비법령에 따라 분양대상자 자격이 있다고 인정된다면 이러한 분양대상자에게는 같은 법 제76조제1항제7호라목에 따른 2주택 공급기준이 동일하게 적용되어야 하는 점⁴⁾, 재건축사업의 경우 같은 법 시행령

4) 서울행정법원 2022. 1. 7. 선고 2021구합62386 판결례 참조

제63조제2항제2호에서는 상가 등 부대시설·복리시설의 소유자에게는 부대시설·복리시설을 공급하는 것을 원칙으로 하면서, 예외적으로 ‘1주택’을 공급할 수 있는 경우를 규정하고 있는 반면, 재개발사업의 경우에는 도시정비법령에서 상가 등 복리시설을 소유한 토지등소유자에 대한 주택 공급의 원칙을 따로 규정하고 있지 않고 있는 점 등을 종합하여 보면 재개발사업의 정비구역에 토지등소유자가 소유하던 토지 또는 건축물이 상가였는지 여부와 무관하게 도시정비법 제76조제1항제7호라목의 요건에 부합한다면 2주택을 공급하는 내용의 관리처분계획을 수립할 수 있다고 해석해야 할 것입니다.

또한 구 도시정비법(2012년 2월 1일 법률 제11293호로 개정되기 전의 것을 말함) 제48조제2항제6호 본문에서는 1세대 1주택 공급원칙을 정하면서, 같은 호 단서 및 각 목에서는 일정 요건에 해당하는 토지등소유자에 대하여는 소유한 주택 수만큼 공급할 수 있다고 하여 다주택자에 대한 예외사유(현행 도시정비법 제76조제1항제7호나목1)부터 3)까지에 해당]만 규정하고 있었는데, 자산가격을 고려하지 않고 모든 조합원들에게 일률적으로 1주택만을 공급받을 수 있도록 제한하는 것은 개발이익의 정당한 분배라는 측면에서 타당하지 않으므로⁵⁾ 2012년 2월 1일 법률 제11293호로 일부개정된 도시정비법 제48조제2항에 제7호를 신설하여 종전 자산가격의 범위에서 다주택자가 아닌 자도 2주택까지 공급할 수 있는 예외를 규정하였고⁶⁾, 이후 소형주택 공급을 활성화하기 위하여⁷⁾ 2013년 12월 24일 법률 제12116호로 일부개정된 도시정비법에서 종전 자산가격의 범위에서만 2주택 공급을 허용하던 것을 종전 주택의 주거면적 범위에서도 2주택 공급이 가능하도록 규정하였는바, 상가의 소유자라는 이유만으로 그 자산가격의 규모와 상관없이 도시정비법 제76조제1항제7호라목에 따라 2주택을 공급받을 수 있는 자의 범위에서 배제하는 것은, 이러한 입법 연혁 및 취지에 비추어 볼 때 타당하지 않다고 할 것입니다.

한편 종전 주택의 주거전용면적 등을 고려하여 2주택 공급이 가능하도록 규정한 도시정비법 제76조제1항제7호라목의 개정 연혁을 고려할 때, 같은 목에 따른 2주택 공급을 받을 수 있는 자는 재개발사업의 정비구역에 주택을 소유한 토지등소유자로 한정된다는 의견이 있으나, 도시정비법 제76조제1항제7호라목에 따른 2주택 공급 기준이 되는 같은 법 제74조제1항제5호에 따른 가격은 “분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물 명세 및 사업시행계획인가 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격”으로서 토지 또는 건축물의 종류를 제한하고 있지 않고,

5) 서울행정법원 2022. 1. 7. 선고 2021구합62386 판결례 참조

6) 현행 도시정비법 제76조제1항제7호라목에 해당함

7) 2013. 4. 8. 의안번호 1904438호로 의원발의된 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 검토보고서 참조

재개발사업에서의 관리처분계획 수립은 이른바 계획재량행위에 해당하여 상당한 재량이 인정되어⁸⁾ 종전의 토지 또는 건축물의 면적·이용상황·환경 그 밖의 사항을 종합적으로 고려하여 대지 또는 건축물이 균형 있게 분양신청자에게 배분되고 합리적으로 이용되도록 정할 수 있는바(도시정비법 제76조제1항제1호), 이에 따라 실제 2주택을 공급할 것인지 여부를 정하는 것은 별론으로 하더라도 상황에 따라 필요한 경우 재량의 범위에서 재개발사업 정비구역의 상가 소유자에게 2주택을 공급하는 것을 내용으로 하는 관리처분계획을 수립하는 것이 금지되어 있는 것은 아니라고 할 것이므로, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 재개발사업의 정비구역에 상가를 소유한 토지등소유자로서 도시정비법 시행령 제63조제1항제3호 단서에 따른 분양 제외 대상에 해당하지 않는 토지등소유자에게 도시정비법 제76조제1항제7호라목에 따라 2주택을 공급하는 내용으로 관리처분계획을 수립할 수 있습니다.



관계법령

도시 및 주거환경정비법

제74조(관리처분계획의 인가 등) ① 사업시행자는 제72조에 따른 분양신청기간이 종료된 때에는 분양신청의 현황을 기초로 다음 각 호의 사항이 포함된 관리처분계획을 수립하여 시장·군수등의 인가를 받아야 하며, 관리처분계획을 변경·중지 또는 폐지하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다.

1. ~ 4. (생 략)

5. 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물 명세 및 사업시행계획인가 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격(사업시행계획인가 전에 제81조제3항에 따라 철거된 건축물은 시장·군수등에게 허가를 받은 날을 기준으로 한 가격)

6. ~ 9. (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ 제1항에 따른 관리처분계획의 내용, 관리처분의 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑦ (생 략)

제76조(관리처분계획의 수립기준) ① 제74조제1항에 따른 관리처분계획의 내용은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. ~ 5. (생 략)

6. 1세대 또는 1명이 하나 이상의 주택 또는 토지를 소유한 경우 1주택을 공급하고, 같은 세대에 속하지 아니하는 2명 이상이 1주택 또는 1토지를 공유했던 경우에는 1주택만 공급한다.

8) 대법원 2023. 9. 21. 선고 2022두56142 판결례 참조

7. 제6호에도 불구하고 다음 각 목의 경우에는 각 목의 방법에 따라 주택을 공급할 수 있다.

가. ~ 다. (생략)

라. 제74조제1항제5호에 따른 가격의 범위 또는 종전 주택의 주거전용면적의 범위에서 2주택을 공급할 수 있고, 이 중 1주택은 주거전용면적을 60제곱미터 이하로 한다. 다만, 60제곱미터 이하로 공급받은 1주택은 제86조제2항에 따른 이전고시일 다음 날부터 3년이 지나기 전에는 주택을 전매(매매·증여나 그 밖에 권리의 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되 상속의 경우는 제외한다)하거나 전매를 알선할 수 없다.

마. (생략)

② (생략)

도시 및 주거환경정비법 시행령

제63조(관리처분의 방법 등) ① 법 제23조제1항제4호의 방법으로 시행하는 주거환경개선사업과 재개발사업의 경우 법 제74조에 따른 관리처분은 다음 각 호의 방법에 따른다.

1.·2. (생략)

3. 정비구역의 토지등소유자(지상권자는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)에게 분양할 것. 다만, 공동주택을 분양하는 경우 시·도조례로 정하는 금액·규모·취득 시기 또는 유형에 대한 기준에 부합하지 아니하는 토지등소유자는 시·도조례로 정하는 바에 따라 분양대상에서 제외할 수 있다.

4. ~ 7. (생략)

② (생략)

질의제목 6

▶ 안전번호 25-0064, 25-0168, 25-0169

국토교통부 - 폐업 또는 등록취소된 부동산개발업 등록사업자는 폐업 또는 등록취소된 이후에도 사업실적을 보고해야 하는지(「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제17조 등 관련)

01 질의요지

「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」(이하 “부동산개발업법”이라 함) 제15조제1항에서는 등록사업자¹⁾가 해당 부동산개발업을 폐업하려는 경우에는 시·도지사²⁾에게 신고하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제17조에서는 등록사업자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 사업실적(제1호) 등 같은 조 각 호의 사항을 시·도지사에게 보고하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제25조제1항에서는 시·도지사는 등록사업자가 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 해당 부동산개발업의 등록을 취소하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 시·도지사는 등록사업자가 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 해당 부동산개발업의 등록을 취소할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 제26조제1항 본문에서는 같은 법 제25조에 따른 등록취소처분을 받은 등록사업자 및 그 포괄승계인은 그 처분을 받기 전에 「건설산업기본법」 제2조제7호의 건설사업자와 도급계약을 체결하였거나 관계 법령에 따라 인·허가 등을 받아 착수한 부동산개발을 계속 수행할 수 있다고 규정하고 있는바,

가. 부동산개발업법 제15조에 따라 폐업을 한 자³⁾는 시·도지사에게 폐업 전까지의 사업실적에 대해 같은 법 제17조에 따라 보고해야 하는지?

나. 부동산개발업법 제25조에 따라 등록취소가 된 자로서 부동산개발을 계속 수행하지 않는 자는 시·도지사에게 등록취소가 되기 전까지의 사업실적에 대해 같은 법 제17조에 따라 보고해야 하는지?

다. 부동산개발업법 제25조에 따라 등록취소가 된 자로서 같은 법 제26조에 따라 부동산개발을 계속 수행하는 자는 시·도지사에게 등록취소가 되기 전까지의 사업실적에 대해 같은 법 제17조에 따라 보고해야 하는지?

1) 부동산개발업법 제4조에 따라 등록을 한 부동산개발업자를 말하며(같은 법 제2조제4호 참조), 이하 같음

2) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사를 말하며(부동산개발업법 제4조제1항 참조), 이하 같음

3) 부동산개발업법 제27조제1항에서는 부동산개발업의 등록이 말소된 자가 1년 이내에 다시 등록사업자로 등록한 경우에는 폐업신고 전의 등록사업자의 지위를 승계한다고 규정하고 있는바, 이러한 지위 승계가 없는 상태를 전제로 함

02 회답

가. 질의 가에 대해

부동산개발업법 제15조에 따라 폐업을 한 자는 시·도지사에게 폐업 전까지의 사업실적에 대해 같은 법 제17조에 따른 보고의무가 없습니다.

나. 질의 나에 대해

부동산개발업법 제25조에 따라 등록취소가 된 자로서 부동산개발을 계속 수행하지 않는 자는 시·도지사에게 등록취소가 되기 전까지의 사업실적에 대해 같은 법 제17조에 따른 보고의무가 없습니다.

다. 질의 다에 대해

부동산개발업법 제25조에 따라 등록취소가 된 자로서 같은 법 제26조에 따라 부동산개발을 계속 수행하는 자는 시·도지사에게 등록취소가 되기 전까지의 사업실적에 대해 같은 법 제17조에 따라 보고해야 합니다.

03 이유

가. 질의 가, 나 및 다의 공통사항

부동산개발업법 제17조에서는 등록사업자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 사업실적(제1호), 자본금의 변경(제2호), 임원 및 부동산개발 전문인력의 변경(제3호)을 시·도지사에게 보고하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제16조제1항에서는 등록사업자는 같은 법 제17조제1호에 따른 사업실적(부동산을 개발하여 타인에게 공급한 실적을 말함)을 별지 제13호서식에 따라 사업근거서류를 첨부하여 매년 4월 10일(등록사업자가 개인인 경우 6월 10일을 말하며, 이하 “보고기한”이라 함)까지 등록등업무 수탁기관⁴⁾에 보고하여야 한다고 규정하고 있는바, 이 사안에서는 보고기한 전에 부동산개발업법 제15조에 따라 폐업신청을 하여 등록이 말소되거나 같은 법 제25조에 따른

4) 부동산개발업법 시행령 제25조제1항에 따라 업무를 위탁받은 기관을 말하며(같은 법 시행규칙 제3조제1항 참조), 이하 같음

등록취소처분을 받게 된 사업자의 경우 보고기한 시점에는 더 이상 등록되어 있는 사업자가 아니게 되므로, 이러한 사업자에게 폐업하거나 등록취소처분을 받기 전까지의 사업실적을 같은 법 제17조에 근거하여 보고기한까지 보고해야 하는 의무가 있는지가 문제됩니다.

나. 질의 가에 대해

먼저 부동산개발업법 제17조에서는 사업실적을 보고해야 하는 주체를 등록사업자로 규정하고 있고, 같은 법 제2조제4호에서는 등록사업자란 같은 법 제4조에 따라 등록을 한 부동산개발업자를 말한다고 규정하고 있는 한편, 같은 법 제15조제2항에 따르면 등록사업자가 폐업신고를 하는 경우 등록이 말소되는데, 그렇다면 부동산개발업을 폐업한 자는 같은 법 제4조에 따른 등록이 되어 있지 않은 자에 해당하므로 부동산개발업법 제17조제1호에 따라 사업실적을 보고해야 하는 주체인 등록사업자로 보기 어려운바, 부동산개발업의 폐업을 한 자는 폐업 전까지의 사업실적에 대해 부동산개발업법 제17조에 따른 보고의무가 없다고 보는 것이 타당합니다.

특히 국민에게 일정한 보고를 의무적으로 하게 하거나 자료제출을 하게 하는 것은 의무를 부과하는 것이므로 법률에 보고의무자를 명확하게 규정해야 하는 점⁵⁾, 부동산개발업법 제40조제2항제2호에서는 같은 법 제17조를 위반하여 사업실적을 보고하지 아니한 자는 1천만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있는데 이러한 제재처분의 대상은 엄격하게 해석해야 하는 점 등을 종합하여 보면, 부동산개발업법에서 폐업한 자에게 보고의무가 있다고 명확하게 규정하고 있지 않은 이상, 폐업한 자는 같은 법 제17조에 따른 보고의무는 없다고 할 것입니다.

그리고 부동산개발업법 제17조에서는 사업실적 외에 등록사업자가 시·도지사에게 보고해야 하는 사항으로 자본금의 변경(제2호), 임원 및 부동산개발 전문인력의 변경(제3호)을 규정하고 있는데, 자본금이나 부동산개발 전문인력의 경우에는 같은 법 제4조제2항에 따른 부동산개발업 등록 요건에 해당하는 점에 비추어 보면 부동산개발업법 제17조에서 보고의무를 둔 취지는 현재 부동산개발업을 하고 있는 자가 영업을 하고 있음을 전제로 그 등록 요건 등을 제대로 갖추고 적정하게 영업을 하고 있는지 등을 확인하기 위한 것이라고 할 수 있는바, 이러한 규정의 취지를 고려하면 폐업을 하여 부동산개발업을 영위하고 있지 않은 자에게까지 부동산개발업법 제17조에 따른 사업실적 보고의무가 있다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

5) 법제처 법령입안·심사기준(2023), p.478 참조

한편 부동산개발업법의 입법취지가 부동산개발업자의 난립과 사기분양, 거짓 광고 등으로 발생하는 소비자의 피해를 방지하기 위한 것⁶⁾이므로, 폐업을 통해 부동산개발업을 하는 과정에서의 위법행위를 은닉하지 못하도록 같은 법 제15조에 따라 폐업을 한 자라고 하더라도 부동산개발업을 영위하는 기간 중의 영업실적에 대해서는 같은 법 제17조제1항에 따른 보고를 해야 한다는 의견이 있으나, 같은 법 제27조제1항에서는 폐업신고에 따라 부동산개발업의 등록이 말소된 자가 1년 이내에 다시 등록사업자로 등록한 경우에는 해당 등록사업자는 폐업신고 전의 등록사업자의 지위를 승계한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 시·도지사는 등록사업자의 지위를 승계한 자에 대하여 폐업신고 전의 위반행위를 사유로 하여 시정조치, 소비자피해분쟁조정요청, 영업정지, 등록취소 등을 할 수 있다고 규정하고 있는 등 부동산개발업법령에서는 폐업 후 다시 등록한 자에게 폐업신고 전의 위법 사실에 대한 처분이 가능하도록 함으로써 폐업을 통해 행정처분 등을 회피하는 것을 제한하는 제도적 장치를 마련하고 있다는 점에서, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 부동산개발업법 제15조에 따라 폐업을 한 자는 시·도지사에게 폐업 전까지의 사업실적에 대해 같은 법 제17조에 따른 보고의무가 없습니다.

다. 질의 내에 대해

먼저 부동산개발업법 제17조에서는 사업실적을 보고해야 하는 주체를 등록사업자로 규정하고 있고, 같은 법 제2조제4호에서는 등록사업자란 같은 법 제4조에 따라 등록을 한 부동산개발업자를 말한다고 규정하고 있는 한편, 같은 법 제25조에 따른 처분을 받으면 등록이 취소되는데, 그렇다면 부동산개발업법 제25조에 따라 등록취소처분을 받은 자는 같은 법 시행규칙 제16조에 따라 보고기한에 보고할 당시에는 등록의 효력이 없어져 같은 법 제4조에 따른 등록이 되어 있지 않은 자에 해당하므로 부동산개발업법 제17조제1항에 따라 사업실적을 보고해야 하는 주체인 등록사업자로 보기 어려운데, 등록취소처분을 받은 자는 등록취소 전까지의 사업실적에 대해 부동산개발업법 제17조에 따른 보고의무가 있다고 보기 어렵습니다.

특히 국민에게 일정한 보고를 의무적으로 하게 하거나 자료제출을 하게 하는 것은 의무를 부과하는 것이므로 법률에 보고의무자 등을 명확하게 규정해야 하는 점,⁷⁾ 부동산개발업법 제40조제2항제2호에서는 같은 법 제17조를 위반하여 사업실적을 보고하지 아니한 자는

6) 2007. 5. 17. 법률 제8480호로 제정된 부동산개발업법 제정이유 참조

7) 법제처 법령입안·심사기준(2023), p.478 참조

1천만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있는데 이러한 제재처분의 대상은 엄격하게 해석해야 하는 점, 부동산개발업법 제26조제2항에서는 등록취소처분을 받고도 같은 조 제1항에 따라 부동산개발을 계속 수행하는 자는 부동산개발이 완료될 때까지는 등록사업자로 본다고 규정하고 있어 등록취소처분을 받고도 등록사업자로 볼 수 있는 자는 ‘부동산개발을 계속 수행하는 자’로 규정하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 부동산개발업법에서 등록취소가 된 자로서 부동산개발을 계속 수행하지 않는 자에게도 보고의무가 있다고 명확하게 규정하고 있지 않은 이상, 부동산개발업법 제25조에 따라 등록취소가 된 자로서 부동산개발을 계속 수행하지 않는 자는 같은 법 제17조에 따른 보고의무가 없다고 할 것입니다.

그리고 부동산개발업법 제17조에서는 사업실적 외에 등록사업자가 시·도지사에게 보고해야 하는 사항으로 자본금의 변경(제2호), 임원 및 부동산개발 전문인력의 변경(제3호)을 규정하고 있는데, 자본금이나 부동산개발 전문인력의 경우에는 같은 법 제4조제2항에 따른 부동산개발업 등록 요건에 해당하는 점에 비추어 보면 부동산개발업법 제17조에서 보고의무를 둔 취지는 현재 부동산개발업을 하고 있는 자가 영업을 하고 있음을 전제로 그 등록 요건 등을 제대로 갖추고 적정하게 영업을 하고 있는지 등을 확인하기 위한 것이라고 할 수 있는바, 이러한 규정의 취지를 고려하면 등록취소처분을 받고 부동산개발을 계속 수행하고 있지 않는 자에게까지 부동산개발업법 제17조에 따른 사업실적 보고의무가 있다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

아울러 부동산개발업법 제18조제1항에서는 시·도지사는 같은 법 제4조에 따른 등록요건에의 적합 여부 확인, 부동산개발의 적정성 등을 판단하기 위하여 필요한 때에는 등록사업자에게 그 업무나 재무관리상태 등에 관하여 보고할 것을 명할 수 있고, 소속 공무원으로 하여금 등록사업자의 경영실태를 조사하게 하거나 그 시설을 검사하게 할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 제21조제1항에서는 시·도지사는 등록취소 등을 위하여 조사가 필요한 때에는 당사자 출석요구나 경영상황에 대한 보고, 자료의 제출, 그 밖의 필요한 조사를 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 시·도지사는 부동산개발업의 등록취소 후에 등록이 취소된 자로서 부동산개발을 계속 수행하지 않는 자에게 사업실적 보고를 하게 하는 대신에, 등록취소를 하려는 경우 해당 등록사업자에게 등록취소 전까지의 사업실적을 보고하도록 명할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 부동산개발업법 제25조에 따라 등록취소가 된 자로서 부동산개발을 계속 수행하지 않는 자는 시·도지사에게 등록취소가 되기 전까지의 사업실적에 대해 같은 법 제17조에 따른 보고의무가 없습니다.

라. 질의 다에 대해

먼저 부동산개발업법 제26조제1항에서는 같은 법 제25조에 따른 등록취소처분을 받은 등록사업자 및 그 포괄승계인은 그 처분을 받기 전에 「건설산업기본법」 제2조제7호의 건설사업자와 도급계약을 체결하였거나 관계 법령에 따라 인·허가 등을 받아 착수한 부동산개발을 계속 수행할 수 있다고 규정하고 있고, 부동산개발업법 제26조제2항에서는 등록사업자가 부동산개발업의 등록이 취소된 후 제1항에 따라 부동산개발을 계속 수행하는 경우에는 해당 부동산개발을 완료할 때까지는 등록사업자로 본다고 간주규정을 두고 있는바, 이에 따라 부동산개발업법 제25조에 따라 등록취소가 된 자라고 하더라도 같은 법 제26조에 따라 부동산개발을 계속 수행하는 자라면 부동산개발업법에 따른 등록사업자에 포함된다고 할 것이고, 같은 법 제17조에서는 보고의무가 있는 자를 “등록사업자”로 규정하고 있으므로, 부동산개발업법 제25조에 따라 등록취소가 된 자로서 같은 법 제26조에 따라 부동산개발을 계속 수행하는 자는 등록사업자에 해당하여 등록취소 전까지의 사업실적에 대해 같은 법 제17조에 따라 시·도지사에게 보고해야 합니다.

특히 부동산개발업법 제25조에 따라 등록취소처분을 받은 자라고 하더라도 같은 법 제26조에 따라 부동산개발을 수행하고 있다면 사업자로서의 실체가 있어 법적 책임의 주체가 명확한 점, 부동산개발업법 제26조제2항은 등록취소처분을 받은 자라고 하더라도 같은 조 제1항에 따라 부동산개발을 계속 수행할 수 있음을 고려하여 부동산개발업법상의 등록사업자로 보아 등록사업자의 의무를 모두 적용받도록 하려는 취지로 보이는 점 등을 고려하면 부동산개발업법 제25조에 따른 등록취소처분을 받은 사업자라고 하더라도 같은 법 제26조에 따라 부동산개발을 계속 수행하고 있다면 같은 법 제17조에 따른 보고의무가 있다고 해석하는 것이 타당합니다.

그리고 부동산개발업법은 부동산개발업자의 난립과 사기분양, 거짓 광고 등으로 발생하는 소비자의 피해를 방지하기 위해 제정된 법률⁸⁾로서, 부동산개발업법 제17조에서 등록사업자의 사업실적 등 보고의무를 규정한 것은 사업실적 정보 등을 통해 드러나는 등록사업자의 사업시행능력과 건전성 유무를 소비자가 스스로 판단할 수 있도록 하기 위한 것인바⁹⁾, 부동산개발업법에 위반되는 등의 행위를 하여 등록취소를 받은 자¹⁰⁾가 부동산개발을 계속 수행하고 있다면, 같은 법 제17조에 따른 보고의무가 있다고 보아 그 사업실적 등에 대한

8) 2007. 5. 17. 법률 제8480호로 제정된 부동산개발업법 제정이유 참조

9) 2006. 12. 27. 의안번호 제175867호로 발의된 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률안에 대한 국회 건설교통위원회 검토보고서 참조

10) 부동산개발업법 제25조 참조

사항을 추가적으로 확인할 수 있도록 하는 것이 소비자의 피해를 방지하고자 하는 부동산개발업법의 입법 취지 및 보고의무 규정의 취지에도 부합한다고 할 것입니다.

따라서 부동산개발업법 제25조에 따라 등록취소가 된 자로서 같은 법 제26조에 따라 부동산개발을 계속 수행하는 자는 시·도지사에게 등록취소가 되기 전까지의 사업실적에 대해 같은 법 제17조에 따라 보고해야 합니다.



관계법령

부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률

제15조(부동산개발업의 폐업 등) ① 등록사업자가 해당 부동산개발업을 폐업하려는 경우에는 시·도지사에게 신고하여야 한다.

②·③ (생략)

제17조(등록사업자의 보고의무 등) 등록사업자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 시·도지사에게 보고하여야 한다.

1. 사업실적(개인인 등록사업자가 부동산개발업에 1년 이상 사용한 사업용 자산을 현물출자하여 법인을 설립한 경우에는 그 개인인 등록사업자의 사업실적을 포함한 실적을 말하며, 등록취소 후 다시 등록한 경우에는 다시 등록한 이후의 실적을 말한다)
2. 자본금(개인인 경우에는 영업용자산평가액을 말한다. 이하 같다)의 변경
3. 임원 및 부동산개발 전문인력의 변경

제25조(부동산개발업의 등록취소) ① 시·도지사는 등록사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 해당 부동산개발업의 등록을 취소하여야 한다.

1. ~ 7. (생략)

② 시·도지사는 등록사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 해당 부동산개발업의 등록을 취소할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

③·④ (생략)

제26조(영업정지처분 등을 받은 자의 부동산개발) ① 제24조에 따른 영업정지처분 또는 제25조에 따른 등록취소처분을 받은 등록사업자 및 그 포괄승계인은 그 처분을 받기 전에 「건설산업기본법」 제2조제7호의 건설사업자와 도급계약을 체결하였거나 관계 법령에 따라 인·허가 등을 받아 착수한 부동산개발을 계속 수행할 수 있다. 다만, 등록취소처분을 받은 등록사업자가 그 위반행위의 내용 및 정도에 비추어 해당 부동산개발을 계속 수행할 수 없는 중대한 사유가 있다고 시·도지사가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 등록사업자가 부동산개발업의 등록이 취소된 후 제1항에 따라 부동산개발을 계속 수행하는 경우에는 해당 부동산개발을 완료할 때까지는 등록사업자로 본다.

질의제목 7

▶ 안전번호 25-0129

민원인 - 「주택법」 제14조의2제1항에 따라 주택조합의 해산 여부를 결정하기 위하여 개최한 총회의 안전에 해산 시의 회계 보고에 관한 사항이 포함되어 있어야 하는지(「주택법 시행규칙」 제7조제6항 등 관련)

01 질의요지

「주택법」 제14조의2제1항에서는 주택조합¹⁾은 같은 법 제11조제1항에 따른 주택조합의 설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업계획승인을 받지 못하는 경우 총회의 의결을 거쳐 해산 여부를 결정하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제11조, 같은 법 시행령 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제7조제6항제8호에서는 주택조합이 반드시 총회의 의결을 거쳐야 하는 사항으로 조합해산의 결의 및 해산 시의 회계 보고를 규정하고 있는바,

「주택법」 제14조의2제1항에 따라 주택조합의 해산 여부를 결정하기 위하여 개최한 총회에서 해당 조합을 해산하지 않기로 결의한 경우에도 같은 법 시행규칙 제7조제6항제8호에 따른 해산 시의 회계 보고에 관한 사항이 해당 총회 안전에 포함되어 있어야 하는지?²⁾

02 회답

「주택법」 제14조의2제1항에 따라 주택조합의 해산 여부를 결정하기 위하여 개최한 총회에서 해당 조합을 해산하지 않기로 결의한 경우에도 같은 법 시행규칙 제7조제6항제8호에 따른 해산 시의 회계 보고에 관한 사항이 해당 총회 안전에 포함되어 있어야 합니다.

03 이유

먼저 「주택법」 제14조의2제1항에서는 주택조합은 같은 법 제11조제1항에 따른 주택조합의

1) 「주택법」 제2조제11호에 따른 “주택조합”을 말하며, 이하 같음

2) 이 사안에서는 「주택법 시행규칙」 제7조제6항제8호에 따른 해산 시의 회계 보고에 관한 사항을 주택조합 해산 여부에 관한 사항과 구분하여 별도의 안전으로 총회에 상정하고 그 의결을 거쳐야 하는지 여부는 별론으로 함

설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업계획승인을 받지 못하는 경우 총회의 의결을 거쳐 해산 여부를 결정해야 한다고 규정하고 있는 한편, 주택조합의 설립방법·설립절차 및 운영·관리 등에 관하여 정하고 있는 같은 법 시행령 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제7조제6항제8호에서는 주택조합이 반드시 총회의 의결을 거쳐야 하는 사항으로 조합해산의 결의 및 해산 시의 회계 보고를 규정하고 있는바, 해당 규정 및 문언을 종합하여 보면 주택조합이 주택조합 설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업계획승인을 받지 못한 경우에는 해산 여부를 결정하기 위한 총회를 개최할 의무가 있는데, 주택조합이 조합을 해산하려는 경우에는 총회의 의결을 거쳐 해산의 결의 및 해산 시의 회계 보고가 이루어져야 하고, 이때 의존명사인 “시(時)”는 일부 명사 뒤에 쓰여 “어떤 일이나 현상이 일어날 때나 경우”를 의미한다는 점³⁾을 고려할 때 “해산 시의 회계 보고”란 해산의 결의에 앞서 해산결의 시점을 기준으로 산출한 조합 회계에 관한 보고를 의미한다고 할 것이므로, 「주택법」 제14조의2제1항에 따라 해산 여부를 결정하기 위하여 개최한 총회에서 해산의 결의가 있는 경우에는 해산 시의 회계 보고가 이루어져야 함이 문언상 명확합니다.

그런데 「주택법」 제14조의2제3항에서는 같은 조 제1항에 따라 총회를 소집하려는 주택조합의 임원은 총회가 개최되기 7일 전까지 회의 목적, 안건, 일시 및 장소를 정하여 조합원에게 통지해야 한다고 규정하고 있는바, 같은 조 제1항에 따른 총회에서 해산을 결의하는 경우에는 같은 법 제11조, 같은 법 시행령 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제7조제6항제8호에 따라 총회에서 해산 시의 회계 보고가 이루어져야 하는데, 만약 「주택법」 제14조의2제1항에 따라 해산 여부를 결정하기 위하여 개최한 총회에서 해당 조합을 해산하지 않기로 결의한 경우에는 해산 시의 회계 보고에 관한 사항이 총회 안건에 포함되지 않아도 된다고 해석하게 된다면, 총회의 의결 결과에 따라 총회 안건에 포함되어 있어야 하는 사항이 달라질 수 있다고 보는 것이 되어 총회를 개최하기 전에 주택조합의 임원이 조합의 해산 여부를 미리 예상하고 해산 시의 회계 보고에 관한 사항을 안건에 포함시킬지 여부를 결정하여 이를 조합원에게 통지해야 하는 불합리한 결과가 초래될 수 있다는 점⁴⁾을 고려할 때, 총회의 의결 결과에 관계없이 「주택법」 제14조의2제1항에 따른 총회 안건에는 해산 시의 회계 보고에 관한 사항이 포함되어야 한다고 보는 것이 해당 법령의 문언 및 체계에 부합하는 해석입니다.

그리고 「주택법」 제14조의2제1항은 주택조합 사업이 장기간 지연되면 조합원의 분담금을 운영비용 등으로 사용하게 되면서 조합원이 탈퇴를 원하더라도 그 비용 환급 가능성이 낮아지게 되므로, 조합설립인가 후 일정 기간 사업이 지연될 경우에는 조합의 해산 여부를

3) 국립국어원 표준국어대사전 참조

4) 법제처 2024. 8. 29. 회신 24-0488 해석례 참조

조합원이 스스로 결정할 수 있도록 함으로써 조합원의 피해를 최소화할 수 있도록 2020년 1월 23일 법률 제16870호로 일부개정된 「주택법」에서 신설된 규정으로,⁵⁾ 조합원의 입장에서 조합의 해산 여부는 재산권과 관련된 중요한 사항이기에 합리적인 결정을 내리기 위해서는 해산결의 시점을 기준으로 산출한 해산 시 회계보고에 관한 사항 등 구체적이고 세부적인 자료에 근거하여 조합을 해산하는 경우와 조합 사업을 계속해서 진행하는 경우 각각의 상황에서 예상되는 이익 및 손실을 균형 있게 검토하고, 이를 바탕으로 총회에서 조합 해산에 관한 사항을 실질적으로 논의할 수 있어야 하는바⁶⁾, 「주택법」 제14조의2제1항에 따라 조합 해산 여부를 결정하기 위하여 개최하는 총회에서는 해산 시의 회계 보고에 관한 사항이 함께 검토되어야 한다고 보는 것이 해당 규정의 입법 취지에도 부합합니다.

한편 「주택법」 제14조의2제2항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제25조의2제2항 제1호에서는 같은 법 제14조의2제2항에 따라 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하기 위하여 개최하는 총회에서 사업 종결 시 회계보고에 관한 사항을 포함해야 한다고 명시적으로 규정하고 있는 것과 달리, 「주택법」 제14조의2제1항에 따라 조합의 해산 여부를 결정하기 위하여 개최하는 총회에서 포함해야 하는 사항에 대해서는 같은 법 시행령 제25조의2에서 별도로 규정한 바가 없으므로 「주택법」 제14조의2제1항에 따른 총회에서는 해산 시 회계보고에 관한 사항이 포함되지 않아도 된다는 의견이 있습니다.

그러나 「주택법」 제14조의2제2항 및 같은 법 시행령 제25조의2제2항 등은 조합원 모집 신고 이후 주택조합 설립인가를 받지 못한 경우, 즉 일반적으로 해산할 수 있는 조합의 실체가 없는 경우에 적용되는 규정으로, 이러한 경우에는 조합 해산 및 청산에 관한 일반규정의 적용이 어려우므로 조합 해산절차에 준하여 조합 가입 신청자 전원으로 구성되는 총회에서 회계보고 및 청산 절차 등에 관한 사항 등 필수적인 사항을 포함하여 조합 사업의 종결 여부를 결정하고 분담금을 환급받을 수 있는 절차를 마련할 수 있도록 별도의 법령상 근거를 둔 것⁷⁾이고, 이미 설립인가를 받은 조합의 경우에는 「주택법」 제11조, 같은 법 시행령 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제7조제6항제8호 등 주택법령상 조합 해산 및 청산에 관한 일반규정이 적용되므로 「주택법 시행령」 제25조의2 등에서 별도로 규정한 바가 없는 것으로 보이는 점에서 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

5) 2019. 3. 15. 의안번호 2019224호로 발의된 주택법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

6) 법제처 2024. 8. 29. 회신 24-0488 해석례 및 2019. 3. 15. 의안번호 2019224호로 발의된 주택법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

7) 2019. 3. 15. 의안번호 2019224호로 발의된 주택법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

따라서 「주택법」 제14조의2제1항에 따라 주택조합의 해산 여부를 결정하기 위하여 개최한 총회에서 해당 조합을 해산하지 않기로 결의한 경우에도 같은 법 시행규칙 제7조제6항제8호에 따른 해산 시의 회계 보고에 관한 사항이 해당 총회 안건에 포함되어 있어야 합니다.



관계법령

주택법

제11조(주택조합의 설립 등) ① 많은 수의 구성원이 주택을 마련하거나 리모델링하기 위하여 주택조합을 설립하려는 경우(제5항에 따른 직장주택조합의 경우는 제외한다)에는 관할 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 “시장·군수·구청장”이라 한다)의 인가를 받아야 한다. 인가받은 내용을 변경하거나 주택조합을 해산하려는 경우에도 또한 같다.

② ~ ⑥ (생 략)

⑦ 제1항에 따라 인가를 받는 주택조합의 설립방법·설립절차, 주택조합 구성원의 자격기준·제명·탈퇴 및 주택조합의 운영·관리 등에 필요한 사항과 제5항에 따른 직장주택조합의 설립요건 및 신고절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑧·⑨ (생 략)

제14조의2(주택조합의 해산 등) ① 주택조합은 제11조제1항에 따른 주택조합의 설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업계획승인을 받지 못하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 총회의 의결을 거쳐 해산 여부를 결정하여야 한다.

② ~ ⑤ (생 략)

주택법 시행령

제20조(주택조합의 설립인가 등) ① (생 략)

② 제1항제1호가목3)의 조합규약에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. ~ 8. (생 략)

9. 총회의 의결을 필요로 하는 사항과 그 의결정족수 및 의결절차

10. ~ 13. (생 략)

③ 제2항제9호에도 불구하고 국토교통부령으로 정하는 사항은 반드시 총회의 의결을 거쳐야 한다.

주택법 시행규칙

제7조(주택조합의 설립인가신청 등) ① (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ 영 제20조제3항에서 “국토교통부령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. ~ 7. (생략)

8. 조합해산의 결의 및 해산시의 회계 보고

⑦ ~ ⑩ (생략)

질의제목 8

▶ 안전번호 25-0179

민원인 - 「주택임대차보호법」 제6조제1항에 따라 갱신된 임대차계약의 임차인에게 일부보증에 대한 동의를 다시 받아야 하는지(「민간임대주택에 관한 특별법」 제49조 등 관련)

01 질의요지

「민간임대주택에 관한 특별법」(이하 “민간임대주택법”이라 함) 제49조제1항에서는 임대사업자¹⁾는 민간건설임대주택(제1호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 민간임대주택을 임대하는 경우 임대보증금에 대한 보증에 가입하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 본문에서는 같은 조 제1항에 따른 보증에 가입하는 경우 보증대상은 임대보증금 전액으로 하되, 같은 조 제3항 전단에서는 같은 항 각 호에 모두 해당하는 경우에는 담보권이 설정된 금액과 임대보증금을 합한 금액에서 주택가격의 100분의 60에 해당하는 금액을 뺀 금액 이상으로 대통령령에서 정하는 금액²⁾을 보증대상으로 할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제3항제4호에서는 같은 항에 따라 임대보증금 전액에 대해 보증대상으로 하지 않을 수 있는 요건 중 하나로 임차인이 같은 항 전단에 따른 대통령령으로 정하는 금액을 보증대상으로 하는 데 동의한 경우를 규정하고 있는 한편,

「주택임대차보호법」(이하 “주택임대차법”이라 함) 제6조제1항에서는 임대인이 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 2개월 전까지의 기간에 임차인에게 갱신거절(更新拒絶)의 통지를 하지 아니하거나 계약조건을 변경하지 아니하면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 끝난 때에 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 보되(전단), 임차인이 임대차기간이 끝나기 2개월 전까지 통지하지 아니한 경우에도 또한 같다(후단)고 규정하고 있는바³⁾,

민간임대주택법 제49조제3항에 따른 보증대상 금액에 대해서만 보증에 가입하는 것에 대해 같은 항 제4호에 따라 임차인이 동의한 임대차계약이 주택임대차법 제6조제1항에 따라

1) 「공공주택 특별법」 제4조제1항에 따른 공공주택사업자가 아닌 자로서 1호 이상의 민간임대주택을 취득하여 임대하는 사업을 할 목적으로 민간임대주택법 제5조에 따라 등록한 자를 말하며(민간임대주택법 제2조제7호 참조), 이하 같음

2) 담보권이 설정된 금액과 임대보증금을 합한 금액에서 주택가격의 100분의 60에 해당하는 금액(민간임대주택법 시행령 제39조제1항 참조)

3) 임대차계약의 묵시적 갱신에 관한 임대차보호법 제6조제1항은 민간임대주택에 대해서도 적용됨(민간임대주택법 제3조 참조)

갱신된 경우, 임대사업자는 갱신된 임대차계약에 대하여 다시 민간임대주택법 제49조제3항에 따른 보증대상 금액에 대해서만 보증에 가입하려면 같은 항 제4호에 따라 임차인의 동의를 다시 받아야 하는지?⁴⁾

02 회답

이 사안의 경우, 임대사업자는 주택임대차법 제6조제1항에 따라 갱신된 임대차계약에 대하여 다시 민간임대주택법 제49조제3항에 따른 보증대상 금액에 대해서만 보증에 가입하려면 같은 항 제4호에 따라 임차인의 동의를 다시 받아야 합니다.

03 이유

먼저 민간임대주택법 제49조제1항에서는 민간임대주택을 임대하는 경우 임대보증금에 대한 보증에 가입하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 본문에 따라 보증대상은 임대보증금 전액으로 하되, 같은 조 제3항 전단에서는 같은 항 각 호에 모두 해당하는 경우에는 담보권이 설정된 금액과 임대보증금을 합한 금액에서 주택가격의 100분의 60에 해당하는 금액을 뺀 금액 이상으로 대통령령에서 정하는 금액을 보증대상으로 할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항제4호에서는 그 요건 중 하나로 임차인이 같은 항 전단에 따른 대통령령으로 정하는 금액을 보증대상으로 하는 데 동의한 경우를 규정하고 있고, 이 경우 임차인 동의와 관련하여 민간임대주택법 시행규칙 별지 제25호서식에서는 임대보증금 일부보증에 대한 임차인 동의서를 정하면서 임대차계약기간을 명시하도록 하고 있는바, 이와 같은 규정을 종합하여 보면 임차인이 민간임대주택법 제49조제3항제4호에 따라 임대보증금의 일부보증에 동의하였다고 하더라도 이러한 동의는 주택임대차법 제6조제1항에 따른 갱신이 있기 전까지의 당초 임대차계약 기간에 대해서만 이루어진 것이라고 보아야 할 것입니다.

그리고 일반적으로 임대차계약은 당사자 가운데 한쪽이 상대방에게 물건을 사용하게 하고, 상대방은 이에 대하여 일정한 임차료를 지급할 것을 내용으로 하는 계약을 의미하는데⁵⁾,

4) 이 사안에서는 민간임대주택법 제49조제3항제4호 외의 다른 요건의 충족 여부는 별론으로 하고, 같은 항 제4호에 따른 동의를 받아야 하는지에 대해서만 한정하여 논의함

5) 국립국어원 표준국어대사전 참조

그렇다면 민간임대주택의 임대차계약은 임대사업자와 임차인 간에 해당 주택의 사용과 관련하여 효력이 발생하는 것이므로, 주택임대차법 제6조제1항에 따라 임대차계약이 갱신된다 하더라도 이러한 갱신의 효력은 민간임대주택의 임대차계약 그 자체에 대해서만 미치는 반면, 민간임대주택법 제49조제1항에 따른 임대보증금에 대한 보증은 임대사업자가 보증회사에 보증의 수수료를 납부하고 보증회사는 일정한 사유가 발생하였을 때 임차인에게 임대사업자를 대신하여 임대보증금 지급의무를 이행하는 내용의 계약에 해당하는바, 그렇다면 민간임대주택법 제49조제1항에 따른 보증과 임대차계약은 명확하게 구분되는 각각의 계약이므로, 민간임대주택의 임대차계약의 갱신 여부가 민간임대주택법 제49조제1항에 따른 보증이나 같은 조 제3항에 따른 일부보증에 대한 임차인의 동의에 영향을 미친다고 보기는 어렵다고 할 것이어서, 임대사업자가 갱신된 임대차계약의 임대보증금에 대하여 민간임대주택법 제49조제3항에 따른 보증대상 금액에 대해서만 보증에 가입하려는 경우 종전 임대차계약 기간 중의 임차인 동의 여부와 관계없이 민간임대주택법 제49조제3항제4호에 따라 새롭게 임차인의 동의를 받아야 한다고 해석하는 것이 타당합니다.

또한 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데⁶⁾, 임대보증금의 일부보증에 관하여 규정하고 있는 민간임대주택법 제49조제3항은 같은 조 제1항 및 제2항에 따른 임대보증금 전액을 대상으로 한 보증 가입 의무라는 원칙에 대한 예외에 해당하는바, 예외 사유가 확대 해석되지 않도록 일부보증에 대한 임차인 동意的 인정 범위 역시 엄격하게 해석할 필요가 있는 점, 특히 민간임대주택법 제49조에 따른 보증 가입 의무 규정은 임대사업자가 임대보증금 반환 의무를 이행할 수 없게 된 경우에 임차인이 임대보증금을 회수할 수 있도록 하여 임차인의 주거 안정을 도모하고자 임대사업자로 하여금 임대보증금 전체를 대상으로 한 보증에 반드시 가입하도록 한 것인 점⁷⁾ 등을 고려하면, 주택임대차법 제6조제1항에 따른 갱신이 있기 전에 이루어진 임차인의 동의는 같은 항에 따른 임대차계약 갱신 이후의 임대보증금에 대해서까지 효력을 미친다고 해석하기는 어렵습니다.

아울러 임차인이 민간임대주택법 제49조제3항제4호에 따라 임대보증금에 대한 일부보증에 동의할 당시에는 주택임대차법 제6조제1항에 따라 임대차계약을 갱신하게 될지 여부에 대해서 알 수 없었으므로, 이 경우 민간임대주택법 제49조제3항제4호에 따른 일부보증에 대한 임차인의 동의 의사가 갱신 이후에까지 있다고 추정하기는 어렵다고 할 것이고, 갱신된

6) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

7) 헌법재판소 2011. 11. 24. 선고 2010헌바120 결정례 참조

임대차계약 기간 중에도 일부보증을 허용할 것인지에 대해서는 일부보증으로 인하여 예측하기 어려운 손해를 감수할 수도 있는 임차인에게 다시 확인할 필요가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 임대사업자는 주택임대차법 제6조제1항에 따라 갱신된 임대차계약에 대하여 다시 민간임대주택법 제49조제3항에 따른 보증대상 금액에 대해서만 보증에 가입하려면 같은 항 제4호에 따라 임차인의 동의를 다시 받아야 합니다.



관계법령

민간임대주택에 관한 특별법

제49조(임대보증금에 대한 보증) ① 임대사업자(제5조제1항에 따라 임대사업자로 등록하려는 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 민간임대주택을 임대하는 경우 임대보증금에 대한 보증에 가입하여야 한다.

1. 민간건설임대주택
2. 제18조제6항에 따라 분양주택 전부를 우선 공급받아 임대하는 민간매입임대주택
3. 동일 주택단지에서 100호 이상으로서 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택을 임대하는 민간매입임대주택(제2호에 해당하는 민간매입임대주택은 제외한다)
4. 제2호와 제3호 외의 민간매입임대주택

② 제1항에 따른 보증에 가입하는 경우 보증대상은 임대보증금 전액으로 한다. 다만, 임대사업자가 사용검사 전에 임차인을 모집하는 경우 임차인을 모집하는 날부터 사용검사를 받는 날까지의 보증대상액은 임대보증금 중 사용검사 이후 납부하는 임대보증금을 제외한 금액으로 한다.

③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호에 모두 해당하는 경우에는 담보권이 설정된 금액과 임대보증금을 합한 금액에서 주택가격의 100분의 60에 해당하는 금액을 뺀 금액 이상으로 대통령령에서 정하는 금액을 보증대상으로 할 수 있다. 이 경우 주택가격의 산정방법은 대통령령으로 정한다.

1. 근저당권이 세대별로 분리된 경우(근저당권이 주택단지에 설정된 경우에는 근저당권의 공동담보를 해제하고, 채권최고액을 감액하는 근저당권 변경등기의 방법으로 할 수 있다)
2. 임대사업자가 임대보증금보다 선순위인 제한물권(다만, 제1호에 따라 세대별로 분리된 근저당권은 제외한다), 압류·가압류·가처분 등을 해소한 경우
3. 전세권이 설정된 경우 또는 임차인이 「주택임대차보호법」 제3조의2제2항에 따른 대항요건과 확정일자를 갖춘 경우
4. 임차인이 이 항 각 호 외의 부분 전단에 따른 대통령령으로 정하는 금액을 보증대상으로 하는 데 동의한 경우

5. 그 밖에 제1호에서 제4호까지에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

④ ~ ⑨ (생략)

주택임대차보호법

제6조(계약의 갱신) ① 임대인이 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 2개월 전까지의 기간에 임차인에게 갱신거절(更新拒絶)의 통지를 하지 아니하거나 계약조건을 변경하지 아니하면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 끝난 때에 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 본다. 임대인이 임대차기간이 끝나기 2개월 전까지 통지하지 아니한 경우에도 또한 같다.

② 제1항의 경우 임대차의 존속기간은 2년으로 본다.

③ 2기(期)의 차임액(借賃額)에 달하도록 연체하거나 그 밖에 임차인으로서의 의무를 현저히 위반한 임차인에 대하여는 제1항을 적용하지 아니한다.

질의제목 9

▶ 안전번호 25-0195

민원인 - 「공동주택관리법 시행령」 제26조제1항에 따른 “매 회계연도 개시 1개월 전까지”의 의미
(「공동주택관리법 시행령」 제26조제1항 등 관련)

01 질의요지

「공동주택관리법 시행령」 제26조제1항에서는 의무관리대상 공동주택의 관리주체¹⁾는 다음 회계연도에 관한 관리비등²⁾의 사업계획 및 예산안을 매 회계연도 개시 1개월 전까지 입주자대표회의³⁾에 제출하여 승인을 받아야 한다고 규정하고 있는바,

「공동주택관리법 시행령」 제26조제1항에 따른 “매 회계연도 개시 1개월 전까지”란 관리비등의 사업계획 및 예산안의 제출기한을 의미하는지, 아니면 제출 및 승인가한을 의미하는지?⁴⁾

02 회답

「공동주택관리법 시행령」 제26조제1항에 따른 “매 회계연도 개시 1개월 전까지”란 관리비등의 사업계획 및 예산안의 제출 및 승인가한을 의미합니다.

03 이유

먼저 「공동주택관리법 시행령」 제26조제1항에서는 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 다음 회계연도에 관한 관리비등의 사업계획 및 예산안을 매 회계연도 개시 1개월 전까지

- 1) 공동주택을 관리하는 관리사무소장, 주택관리업자 등 「공동주택관리법」 제2조제1항제10호 각 목의 자를 말하며, 이하 같음
- 2) 관리비, 사용료, 장기수선충당금과 그 적립금액, 하자보수보증금 등 공동주택단지에서 발생하는 모든 수입에 따른 금전을 말하며(「공동주택관리법」 제25조 참조), 이하 같음
- 3) 공동주택의 입주자등을 대표하여 관리에 관한 주요사항을 결정하기 위하여 구성하는 자치 의결기구를 말하며(「공동주택관리법」 제2조제1항제8호 참조), 이하 같음
- 4) 이 사안에서 「공동주택관리법 시행령」 제26조제1항 위반에 대한 제재 여부·기준에 대한 논의는 별론으로 함

입주자대표회의에 제출하여 승인을 받아야 한다고 규정하여, 예산의 성립을 위해 의무관리대상 공동주택의 관리주체에게 예산안 등의 ‘제출’과 ‘승인받음’을 모두 요구하고 있는데, 이때 ‘제출하여 승인을 받아야’ 한다는 표현은 ‘제출’ 및 ‘승인받음’을 예산의 성립을 위한 하나의 연속적인 의무이행과정, 즉 관리주체로 하여금 예산안 등의 제출을 통해 입주자대표회의의 승인을 받도록 함으로써 다음 회계연도의 예산이 성립될 수 있도록 규정한 것으로, 이와 같이 하나의 연속적인 의무이행과정 앞에 ‘매 회계연도 개시 1개월 전까지’라는 특정 기한을 명시한 경우 그 기한은 특별한 사정이 없는 한 전체 의무(제출 및 승인받음)의 완료기한을 의미하는 것으로 보아야 할 것입니다.

또한 「공동주택관리법 시행령」 제26조의 규정방식을 살펴보면, 같은 조 제1항에 따른 사업계획 및 예산과 같은 조 제3항에 따른 결산은 같은 영 제14조제2항에 따라 모두 입주자대표회의의 승인 사항인데, 같은 영 제26조제1항에서는 관리주체로 하여금 다음 회계연도에 관한 관리비 등의 사업계획 및 예산안을 매 회계연도 개시 1개월 전까지 입주자대표회의에 제출하여 승인을 받도록 규정한 반면, 같은 조 제3항에서는 매 회계연도마다 사업실적서 및 결산서를 작성하여 회계연도 종료 후 2개월 이내에 입주자대표회의에 제출하도록 규정하고 있을 뿐 승인을 받을 의무에 대해서는 별도로 규정하지 않고 있는바, 같은 조 제1항에서는 같은 조 제3항에서와 달리 해당 규정에서 정한 기한 내에 입주자대표회의의 승인까지 있어야 한다는 취지에서 이와 같이 규정한 것이라고 보는 것이 합리적인 해석입니다.

그리고 「공동주택관리법 시행령」 제26조제1항의 입법취지는 관리비 등의 집행과 관련한 각종 비리 등을 단절하고 예산 집행의 효율성 및 투명성을 제고하기 위해 관리주체로 하여금 매 회계연도마다 관리비 등의 사용용도 및 금액을 사전에 수립하여 입주자대표회의의 승인을 받도록 한 것인데,⁵⁾ 이를 통해 확정된 관리비등의 사업계획 및 예산안의 집행을 위한 준비행위 등에는 일반적으로 일정한 시간이 소요될 수 있는 점, 특히 공동주택의 입주자는 입주자대표회의의 승인으로 예산이 성립되어야 비로소 그 확정된 예산안 등을 「공동주택관리법」 제27조제3항 또는 같은 법 제18조에 따른 관리규약 등에서 정하는 바에 따라 확인하고 다음 회계연도에 부과·징수될 관리비등을 예측할 수 있게 되는 점 등을 고려할 때, 예산 집행을 효율적이고 투명하게 함으로써 입주자의 신뢰와 권익을 보호하려는 해당 규정의 입법취지에 비추어 보면, 같은 법 시행령 제26조제1항에 따른 “매 회계연도 개시 1개월 전까지”는 관리비등의 사업계획 및 예산안의 제출기한만을 의미하는 것이 아니라 제출하여 승인받는 기한을 의미한다고 보는 것이 타당할 것입니다.

5) 2010. 7. 6. 대통령령 제22254호로 일부개정된 「주택법 시행령」 조문별 제개정이유서 참조

따라서 「공동주택관리법 시행령」 제26조제1항에 따른 “매 회계연도 개시 1개월 전까지”란 관리비등의 사업계획 및 예산안의 제출 및 승인기한을 의미하는 것으로 보아야 합니다.

법령정비 권고사항

「공동주택관리법 시행령」 제26조제1항에 따른 관리비등의 사업계획 및 예산안의 승인기한이 매 회계연도 개시 1개월 전까지임을 법령에 보다 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

공동주택관리법 시행령

제26조(관리비등의 사업계획 및 예산안 수립 등) ① 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 다음 회계연도에 관한 관리비등의 사업계획 및 예산안을 매 회계연도 개시 1개월 전까지 입주자대표회의에 제출하여 승인을 받아야 하며, 승인사항에 변경이 있는 때에는 변경승인을 받아야 한다.

② 제10조제1항에 따라 사업주체 또는 의무관리대상 전환 공동주택의 관리인으로부터 공동주택의 관리업무를 인계받은 관리주체는 지체 없이 다음 회계연도가 시작되기 전까지의 기간에 대한 사업계획 및 예산안을 수립하여 입주자대표회의의 승인을 받아야 한다. 다만, 다음 회계연도가 시작되기 전까지의 기간이 3개월 미만인 경우로서 입주자대표회의의 의결이 있는 경우에는 생략할 수 있다.

③ 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 회계연도마다 사업실적서 및 결산서를 작성하여 회계연도 종료 후 2개월 이내에 입주자대표회의에 제출하여야 한다.

질의제목 10

▶ 안전번호 25-0200

민원인 - 「공동주택관리법」 제35조제1항제1호에 따른 공동주택을 사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위의 허가 신청 또는 신고에 관한 업무가 같은 법 시행령 제25조제1항제1호가목의 수선·유지에 포함되는지 여부(「공동주택관리법」 제35조제1항 등 관련)

01 질의요지

「공동주택관리법」 제35조제1항에서는 공동주택(일반인에게 분양되는 복리시설을 포함하며, 이하 이 조에서 같음)의 입주자등¹⁾ 또는 관리주체²⁾가 공동주택을 사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위(제1호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 경우에는 허가 또는 신고와 관련된 면적, 세대수 또는 입주자나 입주자등의 동의 비율에 관하여 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장·군수·구청장(이하 “시장등”이라 한다)의 허가를 받거나 시장등에게 신고를 하여야 한다고 규정하고 있는 한편,

「공동주택관리법」 제25조에서는 의무관리대상 공동주택의 관리주체 또는 입주자대표회의가 관리비등³⁾을 집행하기 위하여 사업자를 선정하려는 경우 같은 조 각 호의 기준을 따라야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제25조제1항에서는 관리주체 또는 입주자대표회의는 같은 항 각 호의 구분에 따라 사업자를 선정(계약의 체결을 포함하며, 이하 이 조에서 같음)하고 집행해야 한다고 규정하면서, 같은 항 제1호가목에서는 관리주체가 사업자를 선정하고 집행하는 사항으로서 수선·유지(냉방·난방시설의 청소를 포함하며, 이하 같음)를 위한 용역 및 공사를 규정하고 있는바,

관리주체가 「공동주택관리법」 제35조제1항제1호에 따른 공동주택을 사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위(이하 “용도변경”이라 함)를 하기 위해 시장등의 허가를 받거나 시장등에게 신고하려는 경우, 해당 용도변경의 허가신청 또는 신고에 관한 업무(이하 “용도변경 허가신청등 업무”라 함)가 같은 법 시행령 제25조제1항제1호가목의 “수선·유지”에 포함되는지?

- 1) 입주자와 사용자를 말하며(「공동주택관리법」 제2조제1항제7호 참조), 이하 같음
- 2) 공동주택을 관리하는 「공동주택관리법」 제6조제1항에 따른 자치관리기구의 대표자인 공동주택의 관리사무소장 등의 자를 말하며(「공동주택관리법」 제2조제1항제10호 참조), 이하 같음
- 3) 관리비, 사용료 등, 장기수선충당금과 그 적립금액, 하자보수보증금과 그 밖에 해당 공동주택단지에서 발생하는 모든 수입에 따른 금전을 말하며(「공동주택관리법」 제25조 참조), 이하 같음

02 회답

이 사안의 경우, 해당 용도변경 허가신청등 업무는 「공동주택관리법 시행령」 제25조제1항제1호가목의 “수선·유지”에 포함되지 않습니다.

03 이유

먼저 「공동주택관리법 시행령」 제25조제1항에서는 같은 법 제25조에 따라 관리주체 등은 같은 항 각 호의 구분에 따라 사업자를 선정하고 집행해야 한다고 규정하면서, 같은 항 제1호가목에서는 관리주체가 사업자를 선정하고 집행하는 사항으로서 “수선·유지”를 위한 용역 및 공사 등을 규정하고 있는데, 일반적으로 “수선(修繕)”이란 낡거나 헛 물건을 고침을, “유지(維持)”란 어떤 상태나 상황을 그대로 보존하거나 변함없이 계속하여 지탱함을 뜻하는 용어로서⁴⁾, 같은 목에서는 냉방·난방시설의 청소도 수선·유지 업무에 포함하고 있고, 「공동주택관리법」 제63조제1항제1호에서는 관리주체가 수행하는 업무 중 하나로 공동주택의 공용부분의 유지·보수 및 안전관리를 규정하고 있으며, 같은 법 제31조 및 같은 법 시행령 제32조제2항에서는 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 공용부분에 관한 시설의 교체, 유지보수 등을 한 경우에는 그 실적을 시설별로 이력관리하여야 한다고 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 같은 법 시행령 제25조제1항제1호가목의 “수선·유지”는 공동주택의 공용부분에 대한 보수 및 관리 등을 통해 기존 시설의 물리적 상태가 지속되도록 하는 사실행위를 의미한다고 할 것인데, 같은 법 제35조제1항제1호에 따른 “용도변경 허가신청등 업무”의 경우에는 공동주택의 종전 사업계획에 따른 법률상 용도를 바꾸어 새로운 용도로 사용하기 위해 시장등에게 허가를 신청하거나 신고하는 법률행위로서의 의미를 가지고 있으므로, 「공동주택관리법 시행령」 제25조제1항제1호가목에 따른 “수선·유지”와 「공동주택관리법」 제35조제1항제1호에 따른 “용도변경 허가신청등 업무”는 서로 다른 성격의 별개의 업무라고 할 것입니다.

그리고 「공동주택관리법 시행령」 제25조제1항제1호가목에 따른 “수선·유지”는 의무관리대상 공동주택의 공용부분을 대상으로 하면서, 해당 용역 및 공사에 대한 사업자 선정 및 집행의 권한을 관리주체에게만 부여하고 있는 반면, 「공동주택관리법」 제35조제1항

4) 국립국어원 표준국어대사전 참조.

제1호에 따른 “용도변경 허가신청등 업무”는 그 대상에 공동주택의 공용부분뿐만 아니라 일반인에게 분양되는 복리시설 및 전유부분이 포함되며(같은 영 별표 3 제1호가목), 용도변경 허가 등을 받아야 하는 의무를 관리주체 및 입주자등에게 부과하고 있는 점을 고려할 때, 공동주택관리법령상의 “수선·유지”와 “용도변경 허가신청등 업무”는 그 규율 목적·대상 및 행위주체 등을 달리하는바, 이 사안의 경우 “용도변경 허가신청등 업무”는 “수선·유지”에 포함되지 않는다고 해석하는 것이 공동주택관리법령의 체계에 비추어 타당하다고 할 것입니다.

또한 「공동주택관리법」 제23조제1항에서는 의무관리대상 공동주택의 입주자등은 그 공동주택의 유지관리를 위하여 필요한 관리비를 관리주체에게 납부하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제25조에서는 의무관리대상 공동주택의 관리주체 등이 관리비등을 집행하기 위하여 사업자를 선정하려는 경우 같은 조 각 호의 기준을 따라야 한다고 규정하여 관리주체의 경우에는 입주자등이 납부한 관리비로 사업자를 선정하여 관리비를 집행하게 되는데, 「공동주택관리법」이 공동주택의 관리에 관한 사항을 정함으로써 공동주택을 투명하고 안전하며 효율적으로 관리할 수 있게 하여 국민의 주거수준 향상에 이바지함을 목적(제1조)으로 하는 법률이라는 점에 비추어 볼 때, 관리비 등의 집행과 관련한 각종 비리 등을 단절하고 예산 집행의 효율성 및 투명성을 제고하기 위해서는 관리주체가 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정함에 있어서 법령에 명시된 규정에 따라야 하고, 그 집행의 기준이 되는 관리비 항목에 대해서는 엄격하게 해석해야 할 것입니다.

그런데 「공동주택관리법 시행령」 제23조제1항 및 별표 2에서는 관리비의 비목별 세부명세를 규정하면서, 같은 표 제9호에서는 관리비 항목 중 수선유지비의 구성 명세로서 같은 법 제29조제1항에 따른 장기수선계획에서 제외되는 공동주택의 공용부분의 수선·보수에 소요되는 비용으로 보수용역시에는 용역금액, 직영시에는 자재 및 인건비(가목), 냉난방시설의 청소비 등 공동으로 이용하는 시설의 보수유지비 및 제반 검사비(나목), 건축물의 안전점검비용(다목), 재난 및 재해 등의 예방에 따른 비용(라목)을 규정하고 있어, 수선유지비의 세부명세 중 같은 법 제35조제1항제1호에 따른 용도변경 허가신청등 업무에 소요되는 비용이 포함된다고 볼 만한 항목이 있다고 보기 어려운바,⁵⁾ 이러한 관리비의 비목별 명세에서 규정하고 있는 수선유지비 항목을 고려하더라도 「공동주택관리법 시행령」 제25조제1항제1호가목에 따른 “수선·유지”에는 「공동주택관리법」 제35조제1항제1호에 따른 “용도변경 허가신청등 업무”는 포함되지 않는다고 할 것입니다.

5) 용도변경 허가신청등 업무에 소요되는 비용이 「공동주택관리법 시행령」 별표 2의 관리비의 비목별 세부명세 중 수선유지비가 아닌 다른 항목에 해당하는지 여부는 별론으로 함

따라서 이 사안의 경우, 해당 용도변경 허가신청등 업무는 「공동주택관리법 시행령」 제25조제1항제1호가목의 “수선·유지”에 포함되지 않습니다.



관계법령

공동주택관리법

제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 의무관리대상 공동주택의 관리주체 또는 입주자 대표회의가 제23조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 금전 또는 제38조제1항에 따른 하자보수보증금과 그 밖에 해당 공동주택단지에서 발생하는 모든 수입에 따른 금전(이하 “관리비등”이라 한다)을 집행하기 위하여 사업자를 선정하려는 경우 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

1. 전자입찰방식으로 사업자를 선정할 것. 다만, 선정방법 등이 전자입찰방식을 적용하기 곤란한 경우로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 경우에는 전자입찰방식으로 선정하지 아니할 수 있다.
2. 그 밖에 입찰의 방법 등 대통령령으로 정하는 방식을 따를 것

제35조(행위허가 기준 등) ① 공동주택(일반인에게 분양되는 복리시설을 포함 한다. 이하 이 조에서 같다)의 입주자등 또는 관리주체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 경우에는 허가 또는 신고와 관련된 면적, 세대수 또는 입주자나 입주자등의 동의 비율에 관하여 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 한다.

1. 공동주택을 사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위
2. ~ 4. (생략)
- ② ~ ⑥ (생략)

공동주택관리법 시행령

제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) ① 법 제25조에 따라 관리주체 또는 입주자대표회의는 다음 각 호의 구분에 따라 사업자를 선정(계약의 체결을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하고 집행해야 한다.

1. 관리주체가 사업자를 선정하고 집행하는 다음 각 목의 사항
 - 가. 청소, 경비, 소독, 승강기유지, 지능형 홈네트워크, 수선·유지(냉방·난방시설의 청소를 포함한다)를 위한 용역 및 공사
 - 나. (생략)
- 2.·3. (생략)
- ② ~ ④ (생략)

질의제목 11

▶ 안전번호 25-0211

민원인 - 「공인중개사법」 제10조제1항제11호에서 규정하고 있는 중개사무소 개설등록 결격사유의 발생시기(「공인중개사법」 제10조제1항제11호 등 관련)

01 질의요지

「공인중개사법」 제9조제1항에서는 중개업¹⁾을 영위하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 중개사무소²⁾를 두려는 지역을 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 중개사무소의 개설등록을 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제10조제1항에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 중개사무소의 개설등록을 할 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 항 제11호에서는 중개사무소 개설등록의 결격사유 중 하나로 “이 법을 위반하여 300만원 이상의 벌금형의 선고를 받고 3년이 지나지 아니한 자”를 규정하고 있는바,

「공인중개사법」 제10조제1항제11호에서 규정하고 있는 결격사유 발생시기는 같은 법 위반에 따라 최초로 300만원 이상의 벌금형에 처하는 판결 선고일인지, 아니면 300만원 이상의 벌금형에 처하는 판결 확정일인지?³⁾

02 회답

「공인중개사법」 제10조제1항제11호에서 규정하고 있는 결격사유 발생시기는 같은 법 위반에 따라 300만원 이상의 벌금형에 처하는 판결 확정일입니다.

03 이유

「공인중개사법」 제10조제1항제11호에서는 중개사무소 개설등록 결격사유 중 하나로 “이

1) 다른 사람의 의뢰에 의하여 일정한 보수를 받고 중개를 업으로 행하는 것을 말하며(「공인중개사법」 제2조제3호 참조), 이하 같음

2) 법인의 경우에는 주된 중개사무소를 말하며, 이하 같음

3) 판결 선고일과 판결 확정일이 다를 경우 전제로 함

법을 위반하여 300만원 이상의 벌금형의 선고를 받고 3년이 지나지 아니한 자”를 규정하고 있어, 문언상 결격사유 발생시기를 같은 법 위반에 따라 최초로 300만원 이상의 벌금형에 처하는 판결 선고일인지, 아니면 같은 법 위반에 따라 300만원 이상의 벌금형에 처하는 판결 확정일인지 명확히 규정하고 있지 않은바, 이처럼 어떤 법률의 개념이 다의적이고 그 어의의 테두리 안에서 여러 가지 해석이 가능할 때 헌법을 그 최고 법규로 하는 통일적인 법질서의 형성을 위하여 가능한 한 헌법에 합치되는 해석을 하여야 할 것입니다⁴⁾.

먼저 「대한민국헌법」 제27조제4항에 따른 무죄추정의 원칙에 따라 피의자나 피고인은 유죄의 확정판결이 있기까지 원칙적으로 죄가 없는 자에 준하여 취급하여 형사절차 내에서나 기타 일반 법생활 영역에서 기본권 제한과 같은 불이익을 입혀서는 안 되고 불이익을 입힌다 하여도 필요한 최소한도에 그쳐야 하는데⁵⁾, 만약 「공인중개사법」 제10조제1항제11호에서 규정하고 있는 결격사유 발생시기를 같은 법 위반에 따라 최초로 300만원 이상의 벌금형에 처하는 판결 선고일로 보아 유죄판결이 확정되지 않은 경우에도 같은 호에 따라 중개사무소의 개설등록을 할 수 없다고 해석하게 된다면 형이 확정되지도 않은 상태에서 형 선고가 있었다는 사실만으로 죄가 있는 자에 준하여 불이익을 입히는 것으로 유죄의 확정판결이 있기까지는 원칙적으로 죄가 없는 자에 준하여 취급하여야 한다는 무죄추정의 원칙에 반한다고 할 것이므로⁶⁾, 「공인중개사법」 제10조제1항제11호에서 규정하고 있는 결격사유 발생시기는 같은 법 위반에 따라 300만원 이상의 벌금형에 처하는 판결 확정일로 보아 유죄판결이 확정된 경우에 비로소 같은 호에 따라 중개사무소의 개설등록을 할 수 없다고 해석하는 것이 합헌적 법률해석 원칙에 부합한다 할 것입니다⁷⁾.

그리고 결격사유란 각종 인허가, 등록 등을 필요로 하는 영업 또는 사업을 할 수 없는 사유로, 법률에서 결격사유를 두는 이유는 고도의 전문성 또는 윤리성, 공정성이 요구되는 직종이나 사업영역에 종사하는 자의 자질을 일정 수준 이상으로 유지하고 공공의 위험과 손실, 불완전한 서비스로부터 국민을 보호하려는 것인 반면, 결격사유에 해당하는 자는 특정 직종이나 사업영역에서 배제되어 헌법상 직업선택의 자유나 경제활동의 자유 등 기본권의 제한을 받게 되는바⁸⁾, 만약 판결이 확정되지 않았더라도 벌금형이 선고되었다는 사실만으로 「공인중개사법」 제10조제1항제11호에 따라 중개사무소의 개설등록을 할 수 없다고 본다면,

4) 대법원 2009. 2. 12. 선고 2004두10289 판결례 등 참조

5) 헌법재판소 1990. 11. 19. 선고 90헌가48 결정례, 헌법재판소 1997. 5. 29. 선고 96헌가17 결정례, 헌법재판소 2010. 9. 2. 선고 2010헌마418 결정례 등 참조

6) 헌법재판소 2010. 9. 2. 선고 2010헌마418 결정례 참조

7) 헌법재판소 2020. 9. 24. 선고 2018헌바374 결정례 참조

8) 법제처 법령입안·심사기준(2024) 183-184p 참조

상급심에서 무죄판결이 확정되는 경우에도 일정기간 개설등록을 할 수 없어 중개업을 영위하려는 자에 대하여 회복할 수 없는 불이익 등을 주게 되는 결과를 초래할 수 있다고 할 것입니다⁹⁾.

따라서 「공인중개사법」 제10조제1항제11호에서 규정하고 있는 결격사유 발생시기는 같은 법 위반에 따라 300만원 이상의 벌금형에 처하는 판결 확정일입니다.



관계법령

공인중개사법

제9조(중개사무소의 개설등록) ① 중개업을 영위하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 중개사무소(법인의 경우에는 주된 중개사무소를 말한다)를 두려는 지역을 관할하는 시장(구가 설치되지 아니한 시의 시장과 특별자치도 행정시의 시장을 말한다. 이하 같다)·군수 또는 구청장(이하 “등록관청”이라 한다)에게 중개사무소의 개설등록을 하여야 한다.

②·③ (생 략)

제10조(등록의 결격사유 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 중개사무소의 개설등록을 할 수 없다.

1. ~ 10. (생 략)

11. 이 법을 위반하여 300만원 이상의 벌금형의 선고를 받고 3년이 지나지 아니한 자

12. 사원 또는 임원 중 제1호부터 제11호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 있는 법인

② 제1항제1호부터 제11호까지의 어느 하나에 해당하는 자는 소속공인중개사 또는 중개보조원이 될 수 없다.

③ (생 략)

9) 헌법재판소 2010. 9. 2. 선고 2010헌마418 결정례 참조

제3절 도로·교통

질의제목 1

▶ 안전번호 24-0898

민원인 - 「철도사업법」 제10조제1항에 따른 부가 운임 징수 대상의 범위(「철도사업법」 제10조 등 관련)

01 질의요지

「철도사업법」 제10조제1항에서 철도사업자¹⁾는 열차를 이용하는 여객이 정당한 운임²⁾·요금을 지급하지 아니하고 열차를 이용한 경우에는 승차 구간에 해당하는 운임 외에 그의 30배의 범위에서 부가 운임을 징수할 수 있다고 규정하고 있는바,

철도사업자가 정당한 운임·요금을 지급하지 아니하고 열차를 이용한 행위(이하 “부정승차 행위”라 함)를 한 여객을 적발하여 「철도사업법」 제10조제1항에 따라 부가 운임을 징수하려는 경우, 적발 당시 부정승차 행위에 대한 부가 운임만 징수할 수 있는지, 아니면 적발 전에 있었던 부정승차 행위에 대한 부가 운임도 징수할 수 있는지?³⁾

02 회답

이 사안의 경우, 적발 전에 있었던 부정승차 행위에 대한 부가 운임도 징수할 수 있습니다.

- 1) 「한국철도공사법」에 따라 설립된 한국철도공사(이하 “철도공사”라 함) 및 「철도사업법」 제5조에 따라 철도사업 면허를 받은 자를 말함(「철도사업법」 제2조제8호 참조)
- 2) 여객운송에 대한 직접적인 대가를 말하고, 여객운송과 관련된 설비·용역에 대한 대가는 제외하며(「철도사업법」 제9조제1항 참조), 이하 같음
- 3) 이 사안은 적발 전에 있었던 부정승차 행위에 대하여 부가 운임을 징수할 수 있는지 여부에 관한 것으로, 그 외에 주체, 시기, 절차 등 부가 운임 징수에 필요한 다른 요건은 모두 충족된 것을 전제로 함

03 이유

먼저 「철도사업법」 제10조제1항에서 철도사업자는 열차를 이용하는 여객이 정당한 운임·요금을 지급하지 아니하고 열차를 이용하는 부정승차 행위를 한 경우에는 부가 운임을 징수할 수 있다고 규정하고 있고, 철도사업법령에서 부정승차 행위의 적발 시기에 따른 부가 운임 징수의 가능 여부 등에 관하여는 별도로 규정하고 있지 않으므로, 철도사업자는 특별한 사정이 없는 한 여객이 같은 항에 규정된 부정승차 행위를 하였다면 그 적발 시기에 관계없이 부가 운임을 징수할 수 있다고 할 것입니다.

그리고 「철도사업법」 제10조제1항에서 철도사업자가 부정승차 행위를 한 여객에 대하여 승차 구간에 해당하는 운임 외 부가 운임을 징수할 수 있도록 규정하고 있는 것은 여객이 열차 이용 전에 정당한 승차권을 구매하도록 함으로써 철도사업의 운영 여건을 조성하고 철도운송 질서를 확립하기 위함이라 할 것인데⁴⁾, 만약 이 사안의 경우 철도사업자가 적발 당시의 부정승차 행위에 대한 부가 운임만을 징수할 수 있고 그 전의 부정승차 행위에 대한 부가 운임을 징수할 수 없다고 해석한다면 이러한 부가 운임 징수제도의 실효성을 확보하기 어렵다고 할 것입니다.

아울러 부정승차 행위는 철도사업에 많은 적자를 발생시키는 등 악영향을 미치는 행위로서⁵⁾ 부가 운임의 징수는 부정승차라는 행위에 대한 일종의 징벌적, 예방적 성격이 있는데⁶⁾, 만약 적발 당시 부정승차 행위에 대한 부가 운임만을 징수할 수 있다고 해석하게 된다면 적발이 되더라도 그 동안의 부정승차 행위에 대한 부가 운임은 지불할 필요가 없게 되어 더 많은 부정승차 행위가 발생할 가능성이 있다는 점 등도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

한편, 이 사안의 경우 적발 전 과거 부정승차 행위에 대한 부가 운임까지 소급하여 징수하는 것은 법률불소급의 원칙에 위반된다는 의견이 있으나, 법률불소급의 원칙은 그 법률의 효력발생 전에 완성된 요건사실에 대하여 당해 법률을 적용할 수 없다는 것을 의미일 뿐, 계속 중인 사실이나 그 이후에 발생한 요건사실에 대한 법률적용까지를 제한하는 것은 아니라 할 것인바⁷⁾, 이 사안에서 철도사업자가 「철도사업법」 제10조제1항에 따라 적발 전에 있었던 부정승차 행위에 대한 부가 운임을 징수하는 것은 이미 해당 규정이 시행되어 효력이 발생한

4) 법제처 2014. 10. 29. 회신 14-0653 해석례 참조

5) 서울중앙지방법원 2018. 9. 6. 선고 2017가합537928 판결례 참조

6) 서울남부지방법원 2024. 4. 5. 선고 2023나60849 판결례 참조

7) 대법원 1994. 2. 25. 선고 93누20726 판결례, 대법원 2007. 10. 11. 선고 2005두5390 판결례 참조

후에 있었던 부정승차 행위에 대하여 해당 규정을 적용하는 것으로, 해당 규정을 소급하여 적용하는 것이 아니므로 법률불소급의 원칙에 반하지 않는다는 점에서, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 적발 전에 있었던 부정승차 행위에 대한 부가 운임도 징수할 수 있습니다.



관계법령

철도사업법

제10조(부가 운임의 징수) ① 철도사업자는 열차를 이용하는 여객이 정당한 운임·요금을 지급하지 아니하고 열차를 이용한 경우에는 승차 구간에 해당하는 운임 외에 그의 30배의 범위에서 부가 운임을 징수할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)

질의제목 2

▶ 안전번호 24-0923

민원인 - 「도로교통법」 제2조제19호의2에 따른 개인형 이동장치가 「자동차관리법」 제3조제1항제5호에 따른 이륜자동차에 해당하는지 여부(「자동차관리법」 제2조 등 관련)

01 질의요지

「자동차관리법」 제2조제1호 본문에서는 “자동차”란 원동기¹⁾에 의하여 육상에서 이동할 목적으로 제작한 용구 또는 이에 견인되어 육상을 이동할 목적으로 제작한 용구를 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제3조제1항에서는 자동차는 같은 항 각 호와 같이 구분한다고 규정하면서, 같은 항 제5호에서 이륜자동차는 총배기량 또는 정격출력의 크기와 관계없이 1인 또는 2인의 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 이륜의 자동차 및 그와 유사한 구조로 되어 있는 자동차라고 규정하고 있는 한편,

「도로교통법」 제2조제19호에서는 “원동기장치자전거”란 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 차를 말한다고 규정하면서, 같은 호 가목에서는 「자동차관리법」 제3조에 따른 이륜자동차 가운데 배기량 125cc 이하(전기를 동력으로 하는 경우에는 최고정격출력 11킬로와트 이하를 말하며, 이하 같음)의 이륜자동차를, 같은 호 나목에서는 그 밖에 배기량 125cc 이하의 원동기를 단 차를 규정하고 있고, 「도로교통법」 제2조제19호의2에서는 “개인형 이동장치”란 같은 조 제19호나목의 원동기장치자전거 중 시속 25킬로미터 이상으로 운행할 경우 전동기가 작동하지 아니하고 차체 중량이 30킬로그램 미만인 것으로서 행정안전부령으로 정하는 것을 말한다고 규정하고 있는바,

「도로교통법」 제2조제19호의2에 따른 개인형 이동장치가 「자동차관리법」 제3조제1항제5호에 따른 이륜자동차에 해당하는지?

1) 자동차의 구동을 주목적으로 하는 내연기관이나 전동기 등 동력발생장치를 말하며(「자동차관리법」 제2조제1호의2 참조), 이하 같음

02 회답

「도로교통법」 제2조제19호의2에 따른 개인형 이동장치는 「자동차관리법」 제3조제1항제5호에 따른 이륜자동차에 해당하지 않습니다.

03 이유

「자동차관리법」 제3조제1항제5호에서는 자동차의 종류 중 하나로 이륜자동차를 총배기량 또는 정격출력의 크기와 관계없이 1인 또는 2인의 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 이륜의 자동차 및 그와 유사한 구조로 되어 있는 자동차라고 규정하고 있고, 「도로교통법」 제2조제19호의2 및 같은 법 시행규칙 제2조의3에서는 “개인형 이동장치”란 같은 법 제2조제19호나목의 원동기장치자전거 중 시속 25킬로미터 이상으로 운행할 경우 전동기가 작동하지 아니하고 차체 중량이 30킬로그램 미만인 것으로서 전동킥보드, 전동이륜평행차, 전동기의 동력만으로 움직일 수 있는 자전거 중 어느 하나에 해당하는 것으로서 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」(이하 “전기용품생활안전법”이라 함) 제15조제1항에 따라 안전확인의 신고가 된 것을 말한다고 규정하고 있을 뿐, 「도로교통법」에 따른 개인형 이동장치가 「자동차관리법」에 따른 자동차의 종류 중 하나인 이륜자동차에 해당하는지는 명시적으로 규정하고 있지 않은바, 이를 해석하기 위해서는 「자동차관리법」 및 「도로교통법」의 문언과 함께 각 법률의 목적 및 체계 등을 종합적으로 고려해야 할 것입니다.

그런데 「자동차관리법」은 자동차의 등록, 안전기준, 자기인증, 점검, 검사 등에 관한 사항을 정하여 자동차를 효율적으로 관리하고 자동차의 성능 및 안전을 확보하려는 목적의 법률(제1조)로서, 이륜자동차는 주요 구조 및 장치가 안전기준에 적합하지 아니하면 운행하지 못하고(제50조), 이륜자동차 제작자 등이 이륜자동차의 형식이 안전기준에 적합함을 스스로 인증하는 이륜자동차의 자기인증제도(제30조 및 제52조)를 두고 있는 등 이륜자동차의 관리·성능·안전에 관한 기준과 의무 등을 정하고, 이를 위반한 경우 과태료²⁾나 벌칙³⁾ 등을 두어 이러한 기준과 의무를 준수하도록 규율하고 있습니다.

2) 안전기준에 적합하지 아니한 자동차·이륜자동차를 운행한 자 등에 대해 과태료를 부과하도록 함(「자동차관리법」 제84조제4항 제13호·제19호 등 참조)

3) 자동차안전기준에 적합하지 아니하게 자동차자기인증을 한 자에 대해 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있음(「자동차관리법」 제81조제9호부터 제12호의2까지 등 참조)

이에 따라 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」에서는 이륜자동차의 규격, 원동기출력, 주행장치, 제동장치, 승차장치 등 이륜자동차의 구조 및 장치에 적용할 안전기준을 마련하면서, 같은 규칙 제67조제1항에서는 이륜자동차의 제동장치와 제동능력의 경우 주제동장치는 운전자가 운전석에 정상적으로 앉아서 조향장치를 양손으로 잡은 채로 조종장치를 작동시킬 수 있는 구조(제1호)여야 한다고 규정하고 있고, 같은 규칙 제71조제1항에서는 이륜자동차의 승차장치의 경우 운전자의 좌석과 기타의 좌석에는 승차에 적합한 설비를 갖추어야 한다(제1호)고 규정하고 있는데, 「도로교통법」에 따른 개인형 이동장치는 통상적으로 좌석이 없어 앉아서 조종장치를 작동시키거나 운전자의 좌석 기준을 적용할 수 없는 등 주요한 구조적 장치의 설치 또는 장착이 현저히 곤란한바, 이처럼 자동차관리법령에 따른 이륜자동차에 관한 규정들이 「도로교통법」에 따른 개인형 이동장치에 적용되기 어렵다는 점을 고려하면, 양자는 각각의 법령의 적용을 받는 별개의 이동수단으로서, 「자동차관리법」에 따른 이륜자동차에 「도로교통법」에 따른 개인형 이동장치가 포함된다고 보기는 어렵습니다.

또한 「도로교통법」 제2조제19호의2 및 같은 법 시행규칙 제2조의3에 따르면 개인형 이동장치는 전기용품생활안전법 제15조제1항에 따라 안전확인 신고가 된 것을 말한다고 규정하고 있는데, 전기용품생활안전법 제15조제1항에서는 안전확인대상제품의 제조업자 등은 안전확인대상제품에 대하여 안전확인시험기관으로부터 안전확인시험을 받아, 같은 조 제4항에 따른 안전기준에 적합한 것임을 확인한 후 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제4항에서는 안전확인시험기관은 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 안전확인대상제품에 관한 안전기준을 적용하여 안전확인시험을 실시하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「안전확인대상생활용품의 안전기준」(국가기술표준원고시 제2023-330호)에서는 「도로교통법」에 따른 개인형 이동장치에 대한 안전기준을 규정하면서, 「자동차관리법」에 따른 자동차(이륜자동차 등)는 개인형 이동장치에 대한 안전기준의 적용 대상에서 제외하고 있는바⁴⁾, 이륜자동차는 「자동차관리법」에 따른 안전기준을, 「도로교통법」에 따른 개인형 이동장치는 전기용품생활안전법에 따른 안전기준을 각각 적용받도록 규정하고 있다는 점에서도, 「도로교통법」에 따른 개인형 이동장치를 자동차관리법령에 따라 규율할 수는 없다고 할 것입니다.

그리고 개인형 이동장치에 관한 「도로교통법」의 정의 규정을 살펴보면, 같은 법 제2조제19호의2에서는 개인형 이동장치는 같은 조 제19호나목의 원동기장치자전거 중 일정한

4) 「안전확인대상생활용품의 안전기준」 제2조제2항제72호에 따른 부속서 72의 서문 참조

요건을 갖춘 것을 말한다고 정의하고 있는데, 같은 조 제19호에서는 원동기장치자전거를 「자동차관리법」 제3조에 따른 이륜자동차 중 배기량 125cc 이하의 이륜자동차(가목) 또는 “그 밖에” 배기량 125cc 이하의 원동기를 단 차(나목)로 규정하여, 「도로교통법」 제2조제19호가목은 배기량 125cc 이하의 이륜자동차를, 같은 호 나목은 “이륜자동차가 아닌” 배기량 125cc 이하의 원동기를 단 차를 의미하는바, 「도로교통법」 제2조제19호의2에 따른 개인형 이동장치는 같은 조 제19호나목의 “이륜자동차가 아닌” 배기량 125cc 이하의 원동기를 단 차에 해당하게 되므로, 「도로교통법」에 따른 개인형 이동장치는 「자동차관리법」에 따른 이륜자동차에는 해당하지 않는다고 해석하는 것이 「도로교통법」의 규정 체계에도 부합하는 해석입니다.

따라서 「도로교통법」 제2조제19호의2에 따른 개인형 이동장치는 「자동차관리법」 제3조제1항제5호에 따른 이륜자동차에 해당하지 않습니다.



관계법령

자동차관리법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “자동차”란 원동기에 의하여 육상에서 이동할 목적으로 제작한 용구 또는 이에 견인되어 육상을 이동할 목적으로 제작한 용구를 말한다. 다만, 대통령령으로 정하는 것은 제외한다.
- 1의2. “원동기”란 자동차의 구동을 주목적으로 하는 내연기관이나 전동기 등 동력발생장치를 말한다.
- 1의3. ~ 14. (생략)

제3조(자동차의 종류) ① 자동차는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. ~ 4. (생략)
5. 이륜자동차: 총배기량 또는 정격출력의 크기와 관계없이 1인 또는 2인의 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 이륜의 자동차 및 그와 유사한 구조로 되어 있는 자동차
- ② 제1항에 따른 구분의 세부기준은 자동차의 크기·구조, 원동기의 종류, 총배기량 또는 정격출력 등에 따라 국토교통부령으로 정한다.
- ③ 제1항에 따른 자동차의 종류는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 세분할 수 있다.

도로교통법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 17의2. (생략)
18. “자동차”란 철길이나 가설된 선을 이용하지 아니하고 원동기를 사용하여 운전되는 차(견인되는 자동차도 자동차의 일부로 본다)로서 다음 각 목의 차를 말한다.

가. 「자동차관리법」 제3조에 따른 다음의 자동차. 다만, 원동기장치자전거는 제외한다.

- 1) 승용자동차
- 2) 승합자동차
- 3) 화물자동차
- 4) 특수자동차
- 5) 이륜자동차

나. 「건설기계관리법」 제26조제1항 단서에 따른 건설기계

19. “원동기장치자전거”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 차를 말한다.

가. 「자동차관리법」 제3조에 따른 이륜자동차 가운데 배기량 125cc 이하(전기를 동력으로 하는 경우에는 최고정격출력 11킬로와트 이하)의 이륜자동차

나. 그 밖에 배기량 125cc 이하(전기를 동력으로 하는 경우에는 최고정격출력 11킬로와트 이하)의 원동기를 단 차(「자전거 이용 활성화에 관한 법률」 제2조제1호의2에 따른 전기자전거 및 제21호의3에 따른 실외이동로봇은 제외한다)

19의2. “개인형 이동장치”란 제19호나목의 원동기장치자전거 중 시속 25킬로미터 이상으로 운행할 경우 전동기가 작동하지 아니하고 차체 중량이 30킬로그램 미만인 것으로서 행정안전부령으로 정하는 것을 말한다.

20. ~ 34. (생략)

도로교통법 시행규칙

제2조의3(개인형 이동장치의 기준) 법 제2조제19호의2에서 “행정안전부령으로 정하는 것”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제15조제1항에 따라 안전확인의 신고가 된 것을 말한다.

1. 전동킥보드
2. 전동이륜평행차
3. 전동기의 동력만으로 움직일 수 있는 자전거

질의제목 3

▶ 안전번호 24-0973

민원인 - 「화물자동차 운수사업법」 제40조의3제1항에 따른 위·수탁계약을 해지하기 위하여 서면통지 시마다 유예기간을 두어야 하는지 여부(「화물자동차 운수사업법」 제40조의3 등 관련)

01 질의요지

「화물자동차 운수사업법」(이하 “화물자동차법”이라 함) 제40조제1항에서는 운송사업자는 화물자동차 운송사업의 효율적인 수행을 위하여 필요하면 다른 사람(운송사업자를 제외한 개인을 말함)에게 차량과 그 경영의 일부를 위탁하거나 차량을 현물출자한 사람에게 그 경영의 일부를 위탁할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제40조의3제1항 본문에서는 운송사업자는 위·수탁계약을 해지하려는 경우에는 위·수탁차주에게 2개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히고 이를 시정하지 아니하면 그 계약을 해지한다는 사실을 서면으로 2회 이상 통지하여야 한다고 규정하고 있는바,

운송사업자가 화물자동차법 제40조의3제1항 본문에 따라 위·수탁계약을 해지하기 위하여 위·수탁차주에게 2개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히면서 이를 시정하지 아니하면 그 계약을 해지한다는 사실을 서면으로 통지(이하 “1차서면통지”라 함)한 후, 계약의 위반이 시정되지 않아 계약해지를 위하여 다시 서면으로 통지(이하 “2차서면통지”라 함)하는 경우에 2차서면통지로부터 다시 2개월 이상의 유예기간을 두어야 하는지?1)

02 회답

이 사안의 경우, 2차서면통지로부터 다시 2개월의 유예기간을 두지 않아도 됩니다.

1) 동일한 계약 위반 사유를 이유로 통지하는 경우로서, 위·수탁계약에서 유예기간과 관련하여 화물자동차법령의 규정과 다른 특약사항을 규정하지 않은 것을 전제함

03 이유

먼저 화물자동차법 제40조의3제1항 본문에서는 운송사업자가 위·수탁계약을 해지하려는 경우에는 위·수탁차주에게 2개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히고 이를 시정하지 아니하면 그 계약을 해지한다는 사실을 서면으로 2회 이상 통지하여야 한다고 규정하고 있을 뿐, 서면으로 통지할 때마다 그 통지로부터 다시 2개월 이상의 유예기간을 두도록 하는 등의 내용은 별도로 규정하고 있지 않은바, 화물자동차법 제40조의3제1항의 문언상 운송사업자가 위·수탁계약을 해지하려는 경우에는 위·수탁차주에게 2개월 이상의 유예기간을 두고, 계약의 위반을 시정하지 아니하면 계약을 해지한다는 사실을 2회 이상 서면통지하여야 한다는 것으로 볼 것이지, 2차서면통지로부터 다시 유예기간을 2개월 이상 두어야 한다는 의미로 보기는 어렵습니다.²⁾

그리고 화물자동차법 제40조의3은 운송사업자와 위·수탁차주의 계약 해지와 관련하여 위·수탁차주의 권리를 보호하기 위하여 절차 규정 등을 마련하는 내용으로 2014년 5월 28일 법률 제12707호로 일부개정된 화물자동차법에서 신설된 것³⁾으로서, 화물자동차법 제40조의3제1항 본문에서는 위·수탁차주에게 2개월의 유예기간을 두고 2회 이상 서면통지를 하도록 하고, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 절차를 거치지 아니한 위·수탁계약의 해지는 그 효력이 없다고 규정하고 있는 등 화물자동차법 제40조의3은 위·수탁차주로 하여금 그 유예기간 동안 계약해지사유에 대하여 해명하고 시정할 수 있는 기회를 충분히 가지도록 하기 위한 것인바⁴⁾, 운송사업자가 위·수탁계약을 해지하기 위하여 위·수탁차주에게 2개월 이상의 유예기간을 두고 그 유예기간 내에 1차서면통지를 한 후 위·수탁계약의 위반이 시정되지 않아 2차서면통지를 한 경우, 명시적 규정 없이 2차서면통지로부터 다시 2개월의 유예기간을 두어야 한다는 의미로 해석하기는 어렵습니다.

한편 화물자동차법 제40조의3은 위·수탁차주로 하여금 그 유예기간 동안 계약해지사유에 대하여 해명하고 시정할 기회를 충분히 부여하기 위한 규정이므로 서면통지 시마다 2개월 이상의 유예기간을 두어야 한다는 의견이 있으나, 화물자동차 운송사업의 위·수탁계약은 화물자동차법 제40조제1항에 따라 화물자동차 운송사업의 효율적인 수행을 위하여 체결하는 것으로 같은 조 제3항에 따라 공정하게 위·수탁계약을 체결하고 신의에 따라 성실하게

2) 서울고등법원 2019. 8. 16. 선고 2018나2060411 판결례 참조

3) 2013. 11. 11. 의안번호 1907706호 화물자동차 운수사업법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 검토보고서 참조

4) 수원지방법원 2021. 9. 15. 선고 2020가합18739 판결례 참조

위·수탁계약을 이행하여야 하는데, 만약 위·수탁차주의 절차적 권리를 보장한다는 이유로 2차서면통지로부터 반드시 2개월 이상의 유예기간을 다시 두어야 한다면 해당 계약의 위반 상태가 지속되는 등 화물자동차 운송사업의 위·수탁계약의 취지가 훼손될 수 있는바, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 2차서면통지로부터 다시 2개월의 유예기간을 두지 않아도 됩니다.



관계법령

화물자동차 운수사업법

제40조의3(위·수탁계약의 해지 등) ① 운송사업자는 위·수탁계약을 해지하려는 경우에는 위·수탁차주에게 2개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히고 이를 시정하지 아니하면 그 계약을 해지한다는 사실을 서면으로 2회 이상 통지하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 위·수탁계약을 지속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 절차를 거치지 아니한 위·수탁계약의 해지는 그 효력이 없다.

③ 운송사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 제19조제1항에 따른 허가취소 또는 감차 조치(위·수탁차주의 화물자동차가 감차 조치의 대상이 된 경우에만 해당한다)를 받은 경우 해당 운송사업자와 위·수탁차주의 위·수탁계약은 해지된 것으로 본다.

1. 제19조제1항제1호·제2호·제3호 또는 제5호

2. 그 밖에 운송사업자의 귀책사유(위·수탁차주의 고의에 의하여 허가취소 또는 감차 조치될 수 있는 경우는 제외한다)로 허가취소 또는 감차 조치되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

④ (생략)

질의제목 4

▶ 안전번호 24-0983

인천광역시 계양구 - 한국도로공사가 「도로법」 제112조제1항에 따라 고속국도의 도로공사에 관한 국토교통부장관의 권한을 대행하는 경우 「도로법」과 그 밖에 도로에 관한 법률을 적용할 때 한국도로공사가 도로관리청에 해당되는지 여부(「도로법」 제112조제2항 등 관련)

01 질의요지

「도로법」 제23조제1항제1호에서는 국토교통부장관을 고속국도의 도로관리청¹⁾으로 규정하고 있고, 같은 법 제112조제1항에서는 국토교통부장관은 「도로법」과 그 밖에 도로에 관한 법률에 규정된 고속국도에 관한 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국도로공사²⁾로 하여금 대행하게 할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 한국도로공사는 같은 조 제1항에 따라 고속국도에 관한 국토교통부장관의 권한을 대행하는 경우에 그 대행하는 범위에서 「도로법」과 그 밖에 도로에 관한 법률을 적용할 때에는 해당 고속국도의 도로관리청으로 본다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「도로법 시행령」 제103조제1항에서는 한국도로공사에게 대행하게 할 수 있는 권한의 하나로 고속국도에 관한 「도로법」 제31조제1항의 도로공사 수행에 관한 권한을 규정하고 있는바,

한국도로공사가 「도로법」 제112조제1항 및 같은 법 시행령 제103조제1항에 따라 같은 법 제31조에 따른 고속국도의 도로공사에 관한 국토교통부장관의 권한을 대행하여 같은 법 제2조제2호다목의 도로관리시설을 설치하는 경우, 「도로법」과 그 밖에 도로에 관한 법률을 적용할 때 한국도로공사를 「도로법」 제2조제5호의 도로관리청으로 보아야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 「도로법」과 그 밖에 도로에 관한 법률을 적용할 때 한국도로공사를 「도로법」 제2조제5호의 도로관리청으로 보아야 합니다.

1) 도로에 관한 계획, 건설, 관리의 주체가 되는 기관을 말하며(「도로법」 제2조제5호 참조), 이하 같음

2) 「한국도로공사법」에 따른 한국도로공사를 말하며, 이하 같음

03 이유

먼저 「도로법」 제23조제1항제1호에서는 고속국도의 도로관리청으로 국토교통부장관을 규정하고 있고, 같은 법 제31조제1항에서는 도로공사와 도로의 유지·관리는 「도로법」이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행하도록 규정하고 있어, 「도로법」이나 다른 법률에 특별한 규정이 없다면, 고속국도에 관한 도로공사는 고속국도의 도로관리청인 국토교통부장관이 수행해야 할 것입니다.

그런데 「도로법」 제112조제1항에서는 국토교통부장관은 같은 법과 그 밖에 도로에 관한 법률에 규정된 고속국도에 관한 권한의 일부를 한국도로공사로 하여금 대행하게 할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서 한국도로공사는 같은 조 제1항에 따라 고속국도에 관한 국토교통부장관의 권한을 대행하는 경우에 그 대행하는 범위에서 이 법과 그 밖에 도로에 관한 법률을 적용할 때에는 해당 고속국도의 ‘도로관리청으로 본다’고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제103조제1항에서는 한국도로공사에게 대행하게 할 수 있는 권한 중 하나로 고속국도에 관한 「도로법」 제31조제1항의 도로공사 수행 권한을 규정하고 있는바, 여기서 “본다”라는 문언은 ‘간주(看做)한다’는 것으로서 일정한 사실을 법적으로 그렇다고 여기겠다는 의미이므로³⁾, 한국도로공사가 「도로법」 제112조제1항 및 같은 법 시행령 제103조제1항에 따라 같은 법 제31조에 따른 국토교통부장관의 고속국도에 관한 도로공사 수행 권한을 대행하여 같은 법 제2조제2호다목의 도로관리시설을 설치하는 경우에는 같은 법 제112조제2항에 따라 국토교통부장관의 권한을 대행하는 범위에서는 「도로법」과 그 밖에 도로에 관한 법률을 적용할 때 해당 고속국도의 도로관리청은 한국도로공사라 할 것입니다.⁴⁾

그리고 「도로법」 제112조제1항에서 규정하고 있는 “대행”이란 일반적으로 행정기관이 법령상의 업무를 대행기관으로 하여금 사실상 행하게 하되, 그 명의는 원(原) 권한자인 행정기관으로 하고 책임도 원 권한자인 행정기관에 귀속되도록 하는 것으로⁵⁾, 이러한 대행의 일반적 법적성질을 고려하면 한국도로공사가 도로관리청인 국토교통부장관의 권한을 대행한 경우 특별한 규정이 없는 한 국토교통부장관이 도로관리청의 지위에 있다고 볼 수 있으나, 「도로법」 제112조제2항에서는 한국도로공사가 같은 조 제1항에 따라 고속국도에 관한 국토교통부장관의 권한을 대행하는 경우에 도로관리청으로 간주하는 명문의 규정을 두어

3) 법제처 2014. 10. 14. 회신 14-0553 해석례 참조

4) 부산고등법원 2015. 7. 22. 선고 2014누22786 판결례 참조

5) 법령 입안·심사 기준(2023) p. 509 참조

실제로 고속도로에 관한 업무를 수행하는 한국도로공사에 도로관리청으로서의 지위도 인정하고 있으므로, 이 사안과 같이 한국도로공사가 「도로법」 제112조제1항에 따라 고속국도에 관한 국토교통부장관의 업무 수행을 대행하는 경우에는 한국도로공사를 「도로법」 제2조제5호의 도로관리청으로 보아야 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 「도로법」과 그 밖에 도로에 관한 법률을 적용할 때 한국도로공사를 「도로법」 제2조제5호의 도로관리청으로 보아야 합니다.



관계법령

도로법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. (생 략)
2. “도로의 부속물”이란 도로관리청이 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통의 확보, 그 밖에 도로의 관리를 위하여 설치하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설 또는 공작물을 말한다.
가.·나. (생 략)
다. 통행료 징수시설, 도로관제시설, 도로관리사업소 등 도로관리시설
라. ~ 바. (생 략)
- 3.·4. (생 략)
5. “도로관리청”이란 도로에 관한 계획, 건설, 관리의 주체가 되는 기관으로서 도로의 구분에 따라 제23조에서 규정하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다.
가. 국토교통부장관
나. 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장
(이하 “행정청”이라 한다)

제23조(도로관리청) ① 도로관리청은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 제11조 및 제12조에 따른 고속국도와 일반국도: 국토교통부장관
- 2.·3. (생 략)
- ② (생 략)

제112조(고속국도에 관한 도로관리청의 업무 대행) ① 국토교통부장관은 이 법과 그 밖에 도로에 관한 법률에 규정된 고속국도에 관한 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국도로공사로 하여금 대행하게 할 수 있다.

② 한국도로공사는 제1항에 따라 고속국도에 관한 국토교통부장관의 권한을 대행하는 경우에 그 대행하는 범위에서 이 법과 그 밖에 도로에 관한 법률을 적용할 때에는 해당 고속국도의 도로관리청으로 본다.

③ (생 략)

질의제목 5

▶ 안전번호 24-1001

민원인 - 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제63조제1항의 영업구역 및 같은 규칙 별표 6 제1호나목의 영업행위의 범위(「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제63조제1항 및 별표 6 제1호나목 등 관련)

01 질의요지

「여객자동차 운수사업법」 제2조제4호에서는 “자동차대여사업”을 다른 사람의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여(貸與)하는 사업으로 규정하고 있고, 같은 법 제29조에서는 자동차대여사업의 등록기준이 되는 자동차 대수, 보유 차고 면적, 영업소, 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제61조 및 별표 6에서는 자동차대여사업의 기준을 규정하면서, 같은 표 제1호에서는 자동차대여사업의 등록기준 대수로 영업구역이 전국인 경우는 50대 이상(가목), 주사무소, 영업소 및 예약소가 모두 하나의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시·군(이하 “특별시등”이라 함)에 소재하고, 주사무소 등이 소재한 특별시등에서만 영업행위를 하는 경우는 50대 미만의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 대수(나목)로 규정하고 있고, 같은 규칙 제63조제1항 단서에서는 같은 규칙 별표 6 제1호나목에 따라 등록한 경우에는 주사무소가 설치된 특별시등 지역을 해당 영업구역으로 한다고 규정하고 있는바,

「여객자동차 운수사업법」 제29조, 같은 법 시행규칙 별표 6 제1호나목에 따라 등록한 자동차대여사업자의 사업용 자동차를 대여한 임차인이 같은 법 시행규칙 제63조제1항 단서에 따른 영업구역 내에서 그 자동차를 대여하여 해당 영업구역 밖에서 그 자동차를 운행한 경우, 자동차대여사업자가 해당 영업구역 밖에서 같은 규칙 별표 6 제1호나목에 따른 영업행위를 한 경우에 해당하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 자동차대여사업자가 해당 영업구역 밖에서 영업행위를 한 경우에 해당하지 않습니다.

03 이유

먼저 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것이 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데¹⁾, 「여객자동차 운수사업법」 및 그 하위 법령에서 “영업행위” 및 “영업구역”에 관하여 별도의 정의규정을 두고 있지 않으나, 통상 “영업”이란 영리를 목적으로 하는 사업 또는 그런 행위를 의미²⁾하므로 “영업행위”는 자동차대여사업자가 영리를 목적으로 자동차대여사업을 영위하기 위한 행위를, “영업구역”은 이러한 영업행위가 이루어져야 하는 지역적 범위를 의미한다고 할 것인바, 이 사안의 경우 대여한 사업용 자동차를 해당 영업구역 밖에서 운행한 것은 임차인이고, 자동차대여사업자는 영업구역 밖에서 별도의 행위를 한 것으로 보기는 어려우므로, 이 사안의 경우는 자동차대여사업자가 해당 영업구역 밖에서 영업행위를 한 경우에 해당하지 않는다고 보는 것이 문언의 통상적인 의미에 부합합니다.

그리고 「여객자동차 운수사업법」 제2조제4호에서는 “자동차대여사업”이란 다른 사람의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여(貸與)하는 사업을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제29조에서는 자동차대여사업의 등록기준이 되는 자동차 대수, 보유 차고 면적, 영업소, 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 같은 법 시행규칙 제61조와 별표 6에서는 “자동차대여사업자”가 준수해야 하는 등록기준을 정하고 있고, 같은 규칙 제63조의 제목도 “자동차대여사업”의 영업구역인 점을 고려하면, 같은 표 제1호나목에 따른 영업행위는 자동차대여사업자가 주체인 행위로, 같은 규칙 제63조제1항의 영업구역은 자동차대여사업자가 준수해야 하는 영업구역으로 보아야 할 것인바, 영업행위의 주체가 아닌 임차인이 자동차대여사업자의 영업구역 밖에서 대여 차량을 운행하였음을 이유로 이 사안의 경우를 자동차대여사업자가 해당 영업구역 밖에서 영업행위를 한 경우에 해당한다고 볼 수는 없습니다.

아울러 「여객자동차 운수사업법」 제34조제1항에서는 자동차대여사업자의 사업용 자동차를 임차한 자는 그 자동차를 유상으로 운송에 사용하거나 다시 남에게 대여하여서는 아니된다고 규정하고 있고, 같은 법 제34조의5에서는 자동차대여사업자의 사업용 자동차를 임차한 자는 임대차계약서에 운전자로 열거되지 아니한 자가 임차한 자동차를 운전하게

1) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

2) 국립국어원 표준국어대사전 참조

하여서는 아니 된다고 규정하는 등 사업용 자동차 임차인의 행위를 규제하려는 경우에는 명문의 규정을 두고 있는데, 영업구역이나 영업행위와 관련해서는 임차인의 행위를 규제하거나 임차인의 준수 사항 등을 별도로 규정하고 있지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 자동차대여사업자가 해당 영업구역 밖에서 영업행위를 한 경우에 해당하지 않습니다.



관계법령

여객자동차 운수사업법

제29조(등록기준) 자동차대여사업의 등록기준이 되는 자동차 대수, 보유 차고 면적, 영업소, 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

여객자동차 운수사업법 시행규칙

제61조(자동차대여사업의 등록기준) 법 제29조에 따른 자동차대여사업의 등록기준은 별표 6과 같다.

제63조(자동차대여사업의 영업구역 등) ① 자동차대여사업의 영업구역은 전국으로 한다. 다만, 별표 6 제1호나목에 따라 등록한 경우에는 주사무소가 설치된 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시·군 지역을 해당 영업구역으로 한다.

② (생 략)

[별표 6]

자동차대여사업의 등록기준(제61조 관련)

항목	등록기준
1. 등록기준 대수	가. 영업구역이 전국인 경우: 50대 이상 나. 주사무소, 영업소 및 예약소가 모두 하나의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시·군에 소재하고, 주사무소 등이 소재한 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시·군에서만 영업행위를 하는 경우: 50대 미만의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 대수
2.·3. (생 략)	(생 략)

비고

1. ~ 8. (생 략)

질의제목 6

▶ 안전번호 25-0108

경기도 - 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제5조제1항제1호다목에 따른 “운행계통의 단축”에는 기점과 종점 간의 운행대수를 줄이는 것도 포함되는지(「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제5조 등 관련)

01 질의요지

「여객자동차 운수사업법」(이하 “여객자동차법”이라 함) 제78조제1항 전단에서는 시·도지사는 여객자동차운송사업의 사업계획변경, 개선명령, 사업구역조정 등이 둘 이상의 시·도¹⁾에 걸칠 경우 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 관계 시·도지사²⁾와 협의하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제5조제1항 본문에서는 노선 여객자동차운송사업³⁾을 관할하는 시·도지사는 노선이 둘 이상의 시·도에 걸치는 경우 노선의 신설 또는 변경이나 노선과 관련되는 사업계획 변경의 인가·등록 또는 사업개선명령을 하려면 관계 시·도지사와 미리 협의하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 같은 항 각 호의 경우에는 그러하지 않다고 규정하고 있으며, 같은 항 제1호다목에서는 노선 여객자동차운송사업 중 시내버스운송사업에 관한 사항으로서 다른 시·도 구역에서의 운행계통의 단축 또는 도로·다리의 개설·확충 등으로 인한 운행경로의 변경(운행경로의 변경으로 거리가 연장되는 경우는 제외함)에 관한 사업계획 변경의 인가·등록 또는 사업개선명령의 경우를 규정하고 있는 한편,

「여객자동차 운수사업법 시행령」(이하 “여객자동차법 시행령”이라 함) 제2조제2호에서는 “운행계통”이란 노선의 기점(起點), 종점(終點)과 그 기점·종점 간의 운행경로·운행거리·운행횟수 및 운행대수를 총칭한 것을 말한다고 규정하고 있는바,

「여객자동차 운수사업법 시행규칙」(이하 “여객자동차법 시행규칙”이라 함) 제5조제1항 제1호다목에 따른 “운행계통의 단축”에는 기점과 종점 간의 운행거리나 운행경로를 줄이는 것 외에 운행대수를 줄이는 것도 포함되는지?

1) 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도를 말하며(여객자동차법 제25조제3항 참조), 이하 같음

2) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사를 말하며(여객자동차법 제3조제1항제3호다목 참조), 이하 같음

3) 다른 사람의 수요에 응하여 자동차를 사용하여 유상(有償)으로 여객을 운송하는 여객자동차운송사업 중 자동차를 정기적으로 운행하려는 구간을 정하여 여객을 운송하는 사업을 말함(여객자동차법 제2조제3호 및 제3조제1항제1호 참조)

02 회답

여객자동차법 시행규칙 제5조제1항제1호다목에 따른 “운행계통의 단축”에는 기점과 종점 간의 운행대수를 줄이는 것도 포함됩니다.

03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것⁴⁾인데, 여객자동차법 시행령 제2조제1호에서는 “노선”이란 자동차를 정기적으로 운행하거나 운행하려는 구간을 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2호에서는 “운행계통”이란 노선의 기점, 종점과 그 기점·종점 간의 운행경로·운행거리·운행횟수 및 운행대수를 총칭한 것을 말한다고 규정하고 있는바, 운행계통은 운행경로 및 운행거리와 같은 노선의 구간에 관한 사항뿐만 아니라 운행횟수나 운행대수와 같이 노선을 운행하는 차량에 관한 사항도 포함하는 개념으로서, 문언상 여객자동차법 시행규칙 제5조제1항제1호다목에 따른 운행계통의 단축에는 기점과 종점 간의 운행대수를 줄이는 것도 포함된다고 할 것입니다.

그리고 여객자동차법 시행규칙 제5조제1항 본문에서 노선 여객자동차운송사업을 관할하는 시·도지사는 노선이 둘 이상의 시·도에 걸치는 경우에 노선의 신설 또는 변경이나 노선과 관련되는 사업계획 변경의 인가·등록 등을 하려면 관계 시·도지사와 사전협의를 하도록 규정한 취지는 노선과 관련되는 사업계획의 변경 등으로 인하여 관계 시·도 내 기존의 여객운송사업자와 경업관계를 초래하거나 수송수급에 불균형을 초래하여 관계 시·도에 중대한 영향을 미치게 될 수 있어 사전협의를 하도록 한 것⁵⁾으로서, 같은 항 제1호다목에서 사전협의를 예외로 규정하고 있는 “다른 시·도 구역에서의 운행계통의 단축”은 운행계통의 연장과는 달리 같은 조 제3항에 따라 관계 시·도지사가 단축된 운행계통을 운행하게 하는 등 교통수급 등의 대책을 마련하도록 하고 있는⁶⁾ 등 기존의 여객운송사업자와 경업관계를 초래하거나 수송수급에 불균형을 초래한다고 보기 어려우므로 관계 시·도지사와의 협의를 거치지 않아도 되는 경우로 보아 사전협의를 예외로 정한 것⁷⁾으로 볼 수 있는데, 이러한 규정의

4) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

5) 대법원 2017. 10. 26 선고 2015두36294 판결례 참조

6) 여객자동차법 시행규칙 제5조제3항 참조

취지에 비추어 보면 운행경로나 운행거리를 줄이는 것과 운행횟수나 운행대수를 줄이는 것은 모두 운행계통을 줄이는 것에 해당하는 것으로서 양자를 달리 보기 어려운바, 기점과 종점 간의 운행경로·운행거리·운행횟수 및 운행대수를 줄이는 사업계획의 변경은 모두 운행계통의 단축으로서 사전협의 대상에서 제외된다고 해석하는 것이 여객자동차법 시행규칙 제5조에 따른 사전협의의 취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

한편 국토교통부훈령인 「여객자동차운수사업 인·면허업무처리요령」⁸⁾(이하 “인·면허업무처리요령”이라 함) 제2조제6호에서는 “단축”이란 기존노선 및 운행계통의 운행경로 중 일부를 폐지하는 것을 말한다고 규정하고 있어 “단축”은 노선이나 운행경로와 같은 거리를 줄이는 것에 한정되어 사용되는 것이므로 여객자동차법령에 따른 “운행계통의 단축”에는 운행대수를 줄이는 것이 포함되지 않는다는 의견이 있으나, 여객자동차법 시행령 제2조제2호에서는 “운행계통”이란 노선의 기점, 종점과 그 기점·종점 간의 운행경로·운행거리·운행횟수 및 운행대수를 총칭한 것을 말한다고 규정하고 있고, 여객자동차법 시행규칙에서는 노선 여객자동차운송사업 사업계획 변경의 기준으로써 운행경로 변경은 운행거리 또는 운행시간이 단축되는 경우로 한정한다(제32조)고 규정하고 있으며, 시내버스운송사업의 사업계획의 경미한 변경으로서 관할 관청에 신고해야 하는 사항 중 하나로 배차간격의 단축(제33조) 등을 규정하고 있다는 점을 고려하면, 여객자동차법령에서는 “단축”이라는 개념을 운행거리 및 운행경로와 같이 노선의 구간에 관한 사항에 국한하여 사용하지 않고, 운행횟수나 운행대수와 같이 노선을 운행하는 차량의 운행과 관련된 수량을 줄이는 의미로도 사용하고 있는바, 이러한 규정 체계에 비추어보면 여객자동차법 시행규칙 제5조제1항 제1호다목에 따른 “운행계통의 단축”에 운행대수를 줄이는 것을 배제할 만한 특별한 사유가 없다는 점에서, 그러한 주장은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 여객자동차법 시행규칙 제5조제1항제1호다목에 따른 “운행계통의 단축”에는 기점과 종점 간의 운행대수를 줄이는 것도 포함됩니다.

7) 창원지방법원 2017. 1. 19. 선고 2016구합51717 판결례 참조

8) 2022. 2. 10. 국토교통부훈령 제1510호로 일부개정된 것을 말함

법령정비 권고사항

노선이 둘 이상의 시·도에 걸치는 노선 여객자동차운송사업에서 여객자동차법 시행규칙 제5조제1항제1호다목에 따른 “운행계통의 단축”으로서 운행대수를 줄이는 것으로 사업계획이 변경되는 경우, 노선 여객자동차운송사업을 관할하는 시·도지사와 관계 시·도지사의 사전협의를 필요한지 여부에 대하여 정책적으로 검토하고, 필요하다고 인정되는 경우에는 여객자동차법령을 정비할 필요가 있습니다.



관계법령

여객자동차 운수사업법

제78조(협의·조정 등) ① 시·도지사는 여객자동차운송사업의 사업계획변경, 개선명령, 사업구역조정 등이 둘 이상의 시·도에 걸칠 경우 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 관계 시·도지사와 협의하여야 한다. 이 경우 시·도지사는 협의가 성립되지 아니하면 국토교통부장관에게 조정(調整)을 신청하여야 한다.

②·③ (생략)

여객자동차 운수사업법 시행령

제2조(정의) 이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “노선”이란 자동차를 정기적으로 운행하거나 운행하려는 구간을 말한다.
2. “운행계통”이란 노선의 기점(起點)·종점(終點)과 그 기점·종점 간의 운행경로·운행거리·운행횟수 및 운행대수를 총칭한 것을 말한다.
3. (생략)

여객자동차 운수사업법 시행규칙

제5조(협의·조정신청 등) ① 노선 여객자동차운송사업을 관할하는 시·도지사는 노선이 둘 이상의 시·도에 걸치는 경우 노선의 신설 또는 변경이나 노선과 관련되는 사업계획 변경의 인가·등록 또는 사업개선명령을 하려면 관계 시·도지사와 미리 협의하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 시내버스운송사업, 농어촌버스운송사업 및 마을버스운송사업에 관한 사항으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항에 관한 사업계획 변경의 인가·등록 또는 사업개선명령의 경우
가. 시내버스운송사업 또는 농어촌버스운송사업의 직행좌석형·좌석형·일반형 상호 간 운행형태의 전환
나. 관할 시·도 구역에만 해당되는 운행계통의 변경(둘 이상의 시·도지사가 공동배차 하는 노선은

제외한다)

다. 다른 시·도 구역에서의 운행계통의 단축 또는 도로·다리의 개설·확충 등으로 인한 운행경로의 변경(운행경로의 변경으로 거리가 연장되는 경우는 제외한다)

라. 제3항에 따른 교통대책을 수립하는 경우로서 그 대책에 따른 사항

2. (생략)

② 시·도지사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업계획 변경의 인가·등록 또는 사업개선명령을 하였을 때에는 1주일 이내에 그 사실을 관계 시·도지사에게 통보하여야 한다.

③ 제1항제1호다목에 따른 사업계획 변경에 관하여 제2항에 따른 통보를 받은 관계 시·도지사는 사업계획 변경 전과 같은 운행계통을 유지할 필요가 있다고 인정할 때에는 다른 노선의 여객자동차운송사업자로 하여금 단축된 운행계통을 운행하게 하는 등 교통대책을 수립·시행하여야 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

질의제목 7

▶ 안전번호 25-0112, 25-0335

세종특별자치시 - 사용 개시의 공고가 완료된 도로의 도로구역에서 공작물의 설치를 하려는 경우 「도로법」 제27조제1항에 따른 허가를 받아야 하는지 등(「도로법」 제27조제1항 등 관련)

01 질의요지

「도로법」 제27조제1항 전단에서는 도로구역 및 같은 법 제26조제1항에 따라 공고를 한 도로구역 결정·변경 또는 폐지 예정지(이하 “도로구역 예정지”라 함)에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석(土石)의 채취, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위, 그 밖에 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가(이하 “행위허가”라 함)를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제27조제7항 전단에서는 같은 조 제1항에 따라 행위허가를 받은 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 함) 제56조에 따라 허가를 받은 것으로 본다고 규정하고 있으며, 「도로법」 제39조제1항 본문에서는 도로관리청은 도로 구간의 전부 또는 일부의 사용을 개시하거나 폐지하려면 이를 공고하고 그 도면을 일반인이 열람할 수 있게 하여야 한다고 규정하고 있는 한편,

국토계획법 제56조제1항에서는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치(제1호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(이하 “시장등”이라 함)의 허가(이하 “개발행위허가”라 함)를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제61조제1항에서는 개발행위허가를 할 때에 시장등이 그 개발행위에 대한 같은 항 각 호의 인가·허가·승인·면허·협의·해제·신고 또는 심사 등(이하 “인·허가등”이라 함)에 관하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 그 인·허가등을 받은 것으로 본다고 규정하고 있으며, 같은 항 제6호에서는 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제52조에 따른 도로와 다른 시설의 연결허가 및 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가를 규정하고 있는바,

가. 「도로법」 제39조제1항에 따라 사용 개시의 공고를 한 도로의 도로구역에서 공작물의 설치(이하 “이 사안 설치행위”라 함)를 하려는 경우 같은 법 제27조제1항에 따른 행위허가를 받아야 하는지?

나. 이 사안 설치행위를 하기 위해 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가를 받은 경우에도 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 받아야 하는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

이 사안 설치행위를 하려는 경우 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 받아야 합니다.

나. 질의 나에 대해

이 사안 설치행위를 하기 위해 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가를 받은 경우에도 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 받아야 합니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데¹⁾, 「도로법」 제2조제6호에서는 “도로구역”을 도로를 구성하는 일단의 토지로서 같은 법 제25조에 따라 결정된 구역으로 정의하고 있고, 같은 법 제25조제1항에서는 도로관리청은 도로 노선의 지정·변경 또는 폐지의 고시가 있으면 지체 없이 해당 도로의 도로구역을 결정·변경 또는 폐지하여야 한다고 규정하고 있는바, 같은 법 제25조에 따라 도로구역으로 결정되면 「도로법」상 도로구역에 해당하게 됩니다.

그런데 「도로법」 제27조제1항 전단에서는 ‘도로구역’ 및 도로구역 예정지에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경 등의 행위를 하려는 자는 허가권자의 허가를 받아야

1) 「도로법 시행령」 제26조제1항제2호 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제51조제1항제2호에 해당하는 공작물의 설치로서 설치 부지 전부가 도로구역 안에 있고, 「도로법」 제27조제2항·제3항, 국토계획법 제56조제1항 단서 및 같은 조 제4항에 해당하지 않는 경우임을 전제함

2) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

한다고 규정하고 있고, 같은 법 제39조제1항 본문에서는 도로관리청은 도로 구간의 전부 또는 일부의 사용을 개시하거나 폐지하려면 이를 공고하여야 한다고 규정하고 있을 뿐, 도로법에서는 같은 법 제39조제1항에 따른 사용 개시 공고 여부에 따라 도로구역에 해당하는지 여부를 다르게 해석할 특별한 규정도 두고 있지 않은바, 이 사안 설치행위는 도로구역에서 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가 대상인 행위를 하는 것에 해당하므로 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 받아야 하는 것이 문언상 명백합니다.

그리고 「도로법」 제27조에서 도로구역 및 도로구역 예정지에서 허가를 받지 않고 건축물의 건축 및 공작물의 설치 등의 행위를 하는 것을 제한하는 규정을 둔 취지는 도로구역 내에서 건축물의 건축 및 공작물의 설치 등의 행위가 무분별하게 이루어질 경우 발생할 수 있는 도로 구조 및 시설 손상이나 도로이용자의 안전한 통행 저해 등 교통안전상의 위해(危害)를 방지하기 위한 것으로 보이는바, 「도로법」 제39조제1항에 따른 사용개시의 공고가 되지 않은 도로의 도로구역에서 이 사안 설치행위를 하는 경우뿐만 아니라 사용개시의 공고가 된 도로의 도로구역에서 이 사안 설치행위를 하는 경우에도 같은 법 제27조제1항에 따른 행위허가를 받아야 한다고 해석하는 것이 도로구역 내 행위제한 규정을 둔 취지에 부합하는 해석입니다.

따라서 이 사안 설치행위를 하려는 경우 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 받아야 합니다.

나. 질의 내에 대해

먼저 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가는 토지의 이용이 인접 토지의 이용과 부조화를 발생시키거나 사적인 개발행위가 도·시군관리계획 등 각종 계획과 상충되는 것을 방지하고 계획적 개발을 유도하여 국토를 효율적·합리적으로 이용하고 체계적으로 관리하기 위한 제도³⁾로서 일정한 용도지역이나 국토에서 일반적으로 행해지는 개발행위를 그 허가 대상으로 하는 반면, 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가는 도로구역 및 도로구역 예정지에서 건축물의 건축 및 공작물의 설치 등을 제한하여 도로의 구조·기능을 유지하고 향후 도로 건설이 원활히 이루어지도록 하기 위한 제도로써 도로구역 및 도로구역 예정지에서의 행위를 그 허가 대상으로 하고 있어, 두 제도는 입법목적 및 허가대상의 범위를 달리하는 별개의 제도라 할 것입니다.

3) 법제처 2018. 3. 8. 회신 25-0005 해석례 참조

그런데 입법 목적을 달리하는 법률들이 일정한 행위에 관한 요건을 각각 규정하고 있는 경우에는 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 이상 어떤 행위가 둘 이상의 법률의 요건에 모두 해당한다면 둘 이상의 법률이 모두 적용된다고 할 것인바⁴⁾, 앞서 살펴본 바와 같이 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가와 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가는 그 목적을 달리하는 별개의 제도로서, 국토계획법이나 「도로법」에서는 도로구역에서 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가를 받은 경우에 대하여 「도로법」의 적용을 배제하고 국토계획법을 따르도록 하는 규정을 두고 있지도 않으므로 이 사안 설치행위를 위해서는 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가 외에 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 별도로 받아야 할 것입니다.

그리고 국토계획법 제61조제1항에서는 개발행위허가 또는 변경허가를 할 때에 시장등이 미리 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대해서 그 인·허가등을 받은 것으로 보는 인·허가등의 의제 규정을 두고 있는데, 같은 항 제6호에서는 의제되는 「도로법」상 인·허가등의 종류로 같은 법 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제52조에 따른 도로와 다른 시설의 연결허가 및 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가만 규정하고 있을 뿐 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가는 의제대상 인·허가등의 범위에 포함되어 있지 않은바, 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가를 받으면 「도로법」상 행위허가가 의제되어 별도로 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 받지 않아도 된다고 보기도 어렵습니다.

한편 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 먼저 받은 경우 같은 조 제7항에 따라 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가를 받은 것으로 보는데, 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가를 먼저 받은 경우 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 별도로 받아야 한다고 본다면, 같은 행위에 대하여 허가를 받는 순서에 따라 별도의 절차를 거쳐 나머지 허가를 받아야 하는지 여부가 달라지는 불합리한 결과가 발생하게 되므로, 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가를 받으면 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 받은 것으로 의제되는 것으로 보아 별도의 행위허가를 받을 필요가 없다고 해석해야 한다는 의견이 있으나, 인·허가 의제 제도는 주된 인허가를 받으면 여러 법률에 규정된 인·허가를 함께 받은 것으로 간주하는 제도로서 인·허가에 대한 특례를 규정하는 것이므로 법률에 근거가 있어야 하는데⁵⁾, 국토계획법에서는 같은 법 제56조제1항에 따른 개발행위허가를 받은 경우 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 받은 것으로 의제하는

4) 대법원 1995. 1. 12. 선고 94누3216 판결례 참조

5) 법제처 법령 입안·심사 기준(2024), p.175 참조

규정을 두고 있지 않은바, 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 이 사안 설치행위를 하기 위해 국토계획법 제56조제1항에 따른 개발행위허가를 받은 경우에도 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 받아야 합니다.

법령정비 권고사항

국토계획법 제61조제1항에 따라 의제되는 인·허가에 「도로법」 제27조제1항에 따른 행위허가를 추가할 필요가 있는지를 정책적으로 검토하고, 필요하다고 판단되는 경우 이를 법령에 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

도로법

제27조(행위제한 등) ① 도로구역 및 제26조제1항에 따라 공고를 한 도로구역 결정·변경 또는 폐지 예정지(이하 “도로구역 예정지”라 한다)에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토석(土石)의 채취, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위, 그 밖에 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장(이하 이 조에서 “허가권자”라 한다)의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② ~ ⑥ (생략)

⑦ 제1항에 따라 허가를 받은 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따라 허가를 받은 것으로 본다. 이 경우 제1항에 따른 허가에 관하여 이 법에서 규정한 것을 제외하고는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제57조부터 제60조까지 및 제62조를 준용한다

⑧ (생략)

제39조(도로의 사용 개시 및 폐지) ① 도로관리청은 도로 구간의 전부 또는 일부의 사용을 개시하거나 폐지하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이를 공고하고 그 도면을 일반인이 열람할 수 있게 하여야 한다. 다만, 기존 도로와 중복하여 노선을 지정하였거나 변경하였을 경우 그 중복되는 구간의 도로에 대해서는 그러하지 아니하다.

② ~ ⑤ (생략)

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제56조(개발행위의 허가) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 대통령령으로 정하는

행위(이하 “개발행위”라 한다)를 하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가(이하 “개발행위허가”라 한다)를 받아야 한다. 다만, 도시·군계획사업(다른 법률에 따라 도시·군계획사업을 의제한 사업을 포함한다)에 의한 행위는 그러하지 아니하다.

1. 건축물의 건축 또는 공작물의 설치

2. ~ 5. (생략)

② ~ ④ (생략)

제61조(관련 인·허가등의 의제) ① 개발행위허가 또는 변경허가를 할 때에 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 그 개발행위에 대한 다음 각 호의 인가·허가·승인·면허·협의·해제·신고 또는 심사 등(이하 “인·허가등”이라 한다)에 관하여 제3항에 따라 미리 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 그 인·허가등을 받은 것으로 본다.

1. ~ 5. (생략)

6. 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제52조에 따른 도로와 다른 시설의 연결허가 및 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가

7. ~ 19. (생략)

질의제목 8

▶ 안전번호 25-0247

민원인 - 「화물자동차 운수사업법」 제2조제3호에 따른 화물자동차 운송사업에 이사화물에 대한 포장 및 보관 등 부대서비스를 함께 제공하는 사업도 포함되는지(「화물자동차 운수사업법」 제2조제3호 등 관련)

01 질의요지

「화물자동차 운수사업법」(이하 “화물자동차법”이라 함) 제2조제3호에서는 “화물자동차 운송사업”이란 다른 사람의 요구에 응하여 화물자동차를 사용하여 화물을 유상으로 운송하는 사업을 말한다고 정의하고 있고, 같은 조 제4호에서는 “화물자동차 운송주선사업”이란 다른 사람의 요구에 응하여 유상으로 화물운송계약을 중개·대리하거나 화물자동차 운송사업 또는 화물자동차 운송가맹사업을 경영하는 자의 화물 운송수단을 이용하여 자기 명의로 계산으로 화물을 운송하는 사업(화물이 이사화물인 경우에는 포장 및 보관 등 부대서비스를 함께 제공하는 사업을 포함함)을 말한다고 정의하고 있는바,

화물자동차법 제2조제3호에 따른 화물자동차 운송사업(이하 “운송사업”이라 함)에 해당 사업자가 운송하는 이사화물에 대한 포장 및 보관 등 부대서비스를 함께 제공하는 사업(이하 “포장이사등부대사업”이라 함)도 포함되는지?

02 회답

화물자동차법 제2조제3호에 따른 운송사업에는 포장이사등부대사업도 포함됩니다.

03 이유

화물자동차법 제2조제3호에서는 화물자동차 운송사업을 다른 사람의 요구에 응하여 화물자동차를 사용하여 화물을 유상으로 운송하는 사업으로, 같은 조 제4호에서는 화물자동차 운송주선사업(이하 “주선사업”이라 함)을 다른 사람의 요구에 응하여 유상으로 화물운송계약을 중개·대리하거나 화물자동차 운송사업 또는 화물자동차 운송가맹사업을

경영하는 자의 화물 운송수단을 이용하여 자기 명의와 계산으로 화물을 운송하는 사업으로 정의하여, 두 사업은 각각 화물자동차에 의한 화물의 운송사업과 운송주선사업을 고유의 업무영역으로 하여 나누어져 있는데, 같은 법 제2조제4호에서 주선사업에 대해 정의하면서 화물이 이사화물인 경우에는 포장이사등부대사업을 포함한다고 규정하고 있는 반면, 같은 조 제3호에 따른 운송사업의 경우에는 그러한 규정을 두지 않고 있는바, 화물자동차법 제2조제3호에 따른 운송사업에는 포장이사등부대사업이 포함되는지 여부가 문제됩니다.

먼저 화물자동차법에서는 “운송”에 관하여 별도로 정의하고 있지는 않으나, 통상 “운송”이란 사람을 태워 보내거나 물건 따위를 실어 보내는 행위를 의미¹⁾하는데, 운송을 하기 위해서 화물을 화물자동차까지 운반하는 것, 화물이 손상되는 것을 방지하기 위해서 화물을 포장하는 것 등은 운송을 하기 위해서 수반되는 행위로서, 화물을 운송하기 위하여 포장이사등부대사업의 용역을 제공하고 화물자동차로 운송하는 것도 운송사업의 업무영역에 속하는 사업을 하는 것이라고 할 것입니다.²⁾

그리고 화물자동차법령의 연혁을 살펴보면, 2018년 4월 17일 법률 제15602호로 일부개정되기 전의 화물자동차법(이하 “구 화물자동차법”이라 함)에서는 주선사업의 정의규정에 포장이사등부대사업이 포함된다는 내용은 없었고, 구 화물자동차법 시행령³⁾ 제9조에서 주선사업의 종류를 정하면서, 이사화물운송주선사업에 포장 및 보관 등 부대서비스를 포함한다고 규정하고 있었는데, 이러한 구 화물자동차법 시행령 제9조의 규정은 이사화물운송주선사업의 업무 특성에 따라 사업허가의 종류를 구분하여 규정한 것으로, 이를 근거로 포장이사등부대사업을 주선사업의 배타적 사업영역으로 보기는 어렵다고 할 것입니다.⁴⁾

이후 2018년 4월 17일 법률 제15602호로 일부개정된 화물자동차법 제2조제4호에서 주선사업에 포장이사등부대사업이 포함된다는 내용이 추가되었는데, 이는 주선사업의 종류 구분을 폐지하고 하나로 통합하기 위하여 주선사업의 종류를 삭제함에 따라 구 화물자동차법 시행령에서 이사화물운송주선사업의 범위로 규정하고 있던 포장이사등부대사업의 내용을 법률로 상향 규정한 것으로,⁵⁾ 구 화물자동차법령에서와 같이 주선사업에 포장이사등부대사업이

1) 국립국어원 표준국어대사전 참조

2) 대법원 2016. 6. 9. 선고 2013도13743 판결례 참조

3) 2019. 6. 25. 대통령령 제29919호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 같음

4) 대법원 2016. 6. 9. 선고 2013도13743 판결례 참조

5) 2016. 11. 4. 의안번호 제2003325호로 발의된 화물자동차 운수사업법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 및 2018. 4. 17. 법률 제15602호로 일부개정된 「화물자동차 운수사업법」 개정이유 및 주요내용 참조

포함된다는 점을 명확히 하려는 취지로 보이고, 포장이사등부대사업이 주선사업에만 포함되고 운송사업에는 포함되지 않도록 하려는 취지로 보이지는 않는 점을 고려하면, 포장이사등부대사업은 주선사업뿐만 아니라 운송사업에도 포함된다고 해석하는 것이 화물자동차법령의 입법연혁 및 개정취지에 부합하는 해석입니다.

따라서 화물자동차법 제2조제3호에 따른 운송사업에는 포장이사등부대사업도 포함됩니다.

법령정비 권고사항

화물자동차법 제2조제3호에 따른 운송사업의 범위에 포장이사등부대사업도 포함되는지 여부를 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

화물자동차 운수사업법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 1.·2. (생략)
3. “화물자동차 운송사업”이란 다른 사람의 요구에 응하여 화물자동차를 사용하여 화물을 유상으로 운송하는 사업을 말한다. 이 경우 화주(貨主)가 화물자동차에 함께 탈 때의 화물은 중량, 용적, 형상 등이 여객자동차 운송사업용 자동차에 싣기 부적합한 것으로서 그 기준과 대상차량 등은 국토교통부령으로 정한다.
4. “화물자동차 운송주선사업”이란 다른 사람의 요구에 응하여 유상으로 화물운송계약을 중개·대리하거나 화물자동차 운송사업 또는 화물자동차 운송가맹사업을 경영하는 자의 화물 운송수단을 이용하여 자기 명의로 계산으로 화물을 운송하는 사업(화물이 이사화물인 경우에는 포장 및 보관 등 부대서비스를 함께 제공하는 사업을 포함한다)을 말한다.
5. ~ 13. (생략)

질의제목 9

▶ 안전번호 25-0278

민원인 - 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 외의 시설 또는 공작물이 도로이용 지원시설에 포함될 수 있는지 여부(「도로법」 제2조제2호가목 등 관련)

01 질의요지

「도로법」 제2조제2호에서는 “도로의 부속물”이란 도로관리청이 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통의 확보, 그 밖에 도로의 관리를 위하여 설치하는 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설 또는 공작물을 말한다고 규정하면서, 같은 호 가목에서는 도로의 부속물 중 하나로 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 등 도로이용 지원시설을 규정하고 있는바,

도로관리청이 설치하는 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 외의 시설 또는 공작물이 「도로법」 제2조제2호가목에 따른 도로이용 지원시설에 포함될 수 있는지?

02 회답

도로관리청이 설치하는 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 외의 시설 또는 공작물은 「도로법」 제2조제2호가목에 따른 도로이용 지원시설에 포함될 수 있습니다.

03 이유

일반적으로 법령에서 하나 또는 수개의 사항을 열거하고 그 뒤에 “등”을 사용한 경우 열거된 사항은 예시사항이라 할 것이고, 별도로 해석해야 할 특별한 이유가 없는 한 그 “등”에는 열거된 예시사항과 규범적 가치가 동일하거나 그에 준하는 성질을 가지는 사항이 포함되는 것으로 해석함이 상당하다 할 것인바¹⁾, 「도로법」 제2조제2호가목에서 “등” 앞에 열거된 주차장, 버스정류시설, 휴게시설은 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통의 확보, 그 밖에 도로의 관리를 위하여 도로관리청이 설치하는 도로이용 지원시설의 예를 나열한 것이라는

1) 법제처 2014. 10. 10. 회신 14-0498 해석례 참조

점에서, 「도로법」 제2조제2호가목에 따른 도로이용 지원시설의 범위는 열거된 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 외에 다른 시설 또는 공작물도 포함될 수 있다고 해석하는 것이 해당 규정의 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 「도로법」 제2조제2호가목·나목 등에서는 “도로의 부속물”인 “도로이용 지원시설”, “도로안전시설” 등을 규정하면서 해당 시설에 포함되는 시설이나 공작물의 종류를 열거한 뒤에 “등”이라는 표현을 사용한 반면, 같은 호 바목의 위임에 따라 “도로의 부속물”을 규정하고 있는 같은 법 시행령 제3조제1호에서는 “주유소, 충전소, 교통·관광안내소, 줄음쉼터 및 대기소”를, 같은 조 제2호에서는 “환승시설 및 환승센터”를 각각 “도로의 부속물”로 규정하여 “등”이라는 표현 없이 한정적으로 규정하고 있는바, 도로법령의 이러한 규정 체계에 비추어 보면, 「도로법」 제2조제2호가목은 “도로이용 지원시설”로서 주차장, 버스정류시설, 휴게시설을 예시적으로 열거하면서 그 뒤에 “등”을 덧붙여 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 외의 다양한 시설 또는 공작물도 도로이용 지원시설에 포함될 수 있도록 규정한 것이라고 할 것입니다.

한편 「도로법」 제2조제2호가목에서 규정하고 있는 주차장, 버스정류시설, 휴게시설을 “도로이용 지원시설”의 예시로 볼 경우, 도로관리청이 설치하는 사실상 모든 시설 또는 공작물은 그 편의에 따라 “도로이용 지원시설”에 해당할 수 있게 되므로, 같은 목에 따른 “도로이용 지원시설”의 범위를 문언상 열거된 주차장, 버스정류시설, 휴게시설만으로 한정하여 해석해야 한다는 의견이 있으나, 같은 목에 따른 “도로이용 지원시설”은 ① 도로관리청이 설치하는 것으로서(주체) ② 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통의 확보, 그 밖에 도로의 관리를 위하여 설치해야 하며(목적), ③ 같은 목에 따른 “등” 앞에 열거된 주차장, 버스정류시설, 휴게시설과 규범적 가치가 동일하거나 그에 준하는 시설 또는 공작물에 해당하는 경우에만 도로이용 지원시설에 포함된다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 도로관리청이 설치하는 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 외의 시설 또는 공작물은 「도로법」 제2조제2호가목에 따른 도로이용 지원시설에 포함될 수 있습니다.

**도로법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “도로”란 차도, 보도(步道), 자전거도로, 측도(側道), 터널, 교량, 육교 등 대통령령으로 정하는 시설로 구성된 것으로서 제10조에 열거된 것을 말하며, 도로의 부속물을 포함한다.
2. “도로의 부속물”이란 도로관리청이 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통의 확보, 그 밖에 도로의 관리를 위하여 설치하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설 또는 공작물을 말한다.
 - 가. 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 등 도로이용 지원시설
 - 나. ~ 바. (생략)
3. ~ 9. (생략)

CHAPTER

10

기타

민원인 - 행정안전부가 「전자정부법」 제2조제4호에 따른 중앙사무관장기관으로서 관장하는 대상 기관의 범위에 같은 법 제2조제3호에 따른 공공기관이 포함되는지(「전자정부법」 제2조제4호 등 관련)

01 질의요지

「전자정부법」 제2조제1호에서는 “전자정부”란 정보기술을 활용하여 행정기관 및 공공기관(이하 “행정기관등”이라 함)의 업무를 전자화하여 행정기관등의 상호 간의 행정업무 및 국민에 대한 행정업무를 효율적으로 수행하는 정부를 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4호에서는 “중앙사무관장기관”이란 국회 소속 기관에 대하여는 국회사무처, 법원 소속 기관에 대하여는 법원행정처, 헌법재판소 소속 기관에 대해서는 헌법재판소사무처, 중앙선거관리위원회 소속 기관에 대하여는 중앙선거관리위원회사무처, 중앙행정기관 및 그 소속 기관과 지방자치단체에 대하여는 행정안전부를 말한다고 규정하고 있는바,

행정안전부가 「전자정부법」 제2조제4호에 따른 중앙사무관장기관으로서 관장하는 대상 기관의 범위에 같은 법 제2조제3호에 따른 공공기관이 포함되는지?

02 회답

행정안전부가 「전자정부법」 제2조제4호에 따른 중앙사무관장기관으로서 관장하는 대상 기관의 범위에 같은 법 제2조제3호에 따른 공공기관이 포함됩니다.

03 이유

「전자정부법」 제2조제4호에서는 “중앙사무관장기관”이란 국회 소속 기관에 대하여는 국회사무처, 법원 소속 기관에 대하여는 법원행정처, 헌법재판소 소속 기관에 대하여는 헌법재판소사무처, 중앙선거관리위원회 소속 기관에 대하여는 중앙선거관리위원회사무처, 중앙행정기관 및 그 소속 기관과 지방자치단체에 대하여는 행정안전부를 말한다고 규정하고 있어,

중앙사무관장기관을 ① 국회사무처, ② 법원행정처, ③ 헌법재판소사무처, ④ 중앙선거관리위원회 사무처, ⑤ 행정안전부로 한정하여 규정하면서, 같은 호에서는 공공기관에 대한 중앙사무관장기관에 대해서 명시적으로 규정하고 있지 않은바, 행정안전부가 중앙사무관장기관으로서 사무를 관장하는 대상 기관의 범위에 같은 조 제3호에 따른 공공기관이 포함되는지에 관해서는 「전자정부법」에서 규정하고 있는 중앙사무관장기관의 업무 범위, 입법취지 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 조화롭게 해석할 필요가 있습니다.

먼저 「전자정부법」 제2조제1호에서는 “전자정부”란 정보기술을 활용하여 “행정기관” 및 “공공기관”의 업무를 전자화하여 행정기관등 상호간의 행정업무 및 국민에 대한 행정업무를 효율적으로 수행하는 정부를 말한다고 규정하고 있고, 행정기관등의 장은 전자정부 구현을 촉진하고 국민의 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 이 법을 운영하고 관련 제도를 개선하도록 하는(제3조제1항) 등 「전자정부법」에서는 행정기관뿐만 아니라 공공기관도 전자정부 관련 정책을 추진하도록 규율하고 있는 한편, 중앙사무관장기관의 장은 전자정부의 구현·운영 및 발전을 위하여 5년마다 행정기관등의 기관별 계획을 종합하여 전자정부기본계획을 수립하도록 하고(제5조), 행정기관등의 장은 5년마다 기관별 계획을 수립하여 중앙사무관장기관의 장에게 제출하여야 하며, 중앙사무관장기관의 장은 행정기관등의 기관별 계획 추진현황 및 성과를 점검할 수 있고(제5조의2), 행정기관등에서 제공하는 전자정부서비스가 서로 유사하거나 중복되는 경우에는 중앙사무관장기관의 장이 서비스의 통합 또는 폐기 등 개선방안을 권고할 수 있으며(제23조), 행정기관등을 통합·연계하는 정보통신망의 구축·운영방안을 마련하도록(제52조제1항) 규정하고 있는바, 중앙사무관장기관의 장은 「전자정부법」에 따라 전자정부기본계획의 수립·추진, 행정기관등 통합·연계 정보통신망 구축 등 전자정부를 구현하기 위한 행정적·기술적 관리 업무를 총괄하는 업무를 수행하고 있습니다.

이러한 전자정부법령의 체계를 살펴보면, 「전자정부법」에서 공공기관을 관장하는 중앙사무관장기관을 명확히 규정하고 있지 않더라도 행정기관과 공공기관 상호 간의 행정업무를 효율적으로 수행하려는 「전자정부법」의 목적을 달성하기 위해서는 공공기관 업무의 통합·연계를 관장하는 기관인 중앙사무관장기관이 필수적으로 있어야 할 것인데, 같은 법에서 행정기관과 구분하여 공공기관만의 통합·연계 등의 사무를 관장할 수 있는 기관에 관한 별도의 규정을 두고 있지 않다면, 결국 「전자정부법」 제2조제4호에 따른 중앙사무관장기관 중 어느 하나가 그 역할을 수행해야 할 것이고, 그렇다면 중앙행정기관 또는 지방자치단체 등 주무기관의 장으로부터 업무에 관한 지도·감독을 받는 기관으로서¹⁾, 공익추구라는 사회적 기능을 담당하고 있어 국민생활과 밀접한 사업을 수행하는 경우가 많아 공공적인 성격이 큰

공공기관²⁾에 대해서는 중앙행정기관 및 그 소속 기관과 지방자치단체에 대한 중앙사무관장기관인 행정안전부가 중앙사무관장기관이 된다고 해석하는 것이 전자정부법령의 규정 체계에 부합한다고 할 것입니다.

아울러 종전에는 전자정부의 범위에 행정기관만을 포함하여 규율하던 것을 2010년 2월 4일 법률 제10012호로 전부개정된 「전자정부법」 제2조제1호에서 전자정부의 범위를 “행정기관 및 공공기관”의 업무까지 확대하여 규정하면서, 같은 법의 규율 대상을 행정기관 및 공공기관인 “행정기관등”으로 확대한 것인바, 「전자정부법」 제2조제4호에 따른 중앙사무관장기관이 관장하는 대상 기관에 공공기관이 규정되어 있지 않다고 해서 공공기관을 전자정부법의 규율 범위에서 제외하려는 의도가 있었다고 보기 어려운 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 행정안전부가 「전자정부법」 제2조제4호에 따른 중앙사무관장기관으로서 관장하는 대상 기관의 범위에 같은 법 제2조제3호에 따른 공공기관이 포함됩니다.

법령정비 권고사항

「전자정부법」 제2조제4호에 따라 중앙사무관장기관으로서 행정안전부가 사무를 관장하는 대상기관의 범위를 전자정부법령에서 명확히 규정할 필요가 있습니다.

1) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제51조 참조

2) 헌법재판소 2016. 12. 29. 선고 2015헌바225 결정례 참조



관계법령

전자정부법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “전자정부”란 정보기술을 활용하여 행정기관 및 공공기관(이하 “행정기관등”이라 한다)의 업무를 전자화하여 행정기관등의 상호 간의 행정업무 및 국민에 대한 행정업무를 효율적으로 수행하는 정부를 말한다.
2. “행정기관”이란 국회·법원·헌법재판소·중앙선거관리위원회의 행정사무를 처리하는 기관, 중앙행정기관(대통령 소속 기관과 국무총리 소속 기관을 포함한다. 이하 같다) 및 그 소속 기관, 지방자치단체를 말한다.
3. “공공기관”이란 다음 각 목의 기관을 말한다.
 - 가. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인·단체 또는 기관
 - 나. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단
 - 다. 특별법에 따라 설립된 특수법인
 - 라. 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 및 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 각급 학교
 - 마. 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인·단체 또는 기관
4. “중앙사무관장기관”이란 국회 소속 기관에 대하여는 국회사무처, 법원 소속 기관에 대하여는 법원행정처, 헌법재판소 소속 기관에 대하여는 헌법재판소사무처, 중앙선거관리위원회 소속 기관에 대하여는 중앙선거관리위원회사무처, 중앙행정기관 및 그 소속 기관과 지방자치단체에 대하여는 행정안전부를 말한다.

기획재정부 - 조합원인 의장이 「협동조합 기본법」 제30조제2항의 “총회에서 선출한 조합원 3인”에 포함되는지 여부(「협동조합 기본법」 제30조제2항 등 관련)

01 질의요지

「협동조합 기본법」 제28조제1항에서는 협동조합에 총회를 둔다고 규정하고 있고, 같은 법 제30조제1항에서는 총회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서 의사록에는 의사의 진행 상황과 그 결과를 적고 의장과 총회에서 선출한 조합원 3인 이상이 기명날인하거나 서명하여야 한다고 규정하고 있는바,

조합원인 의장이 「협동조합 기본법」 제30조제2항에서 규정하고 있는 “총회에서 선출한 조합원 3인”에 포함되는지?¹⁾

02 회답

조합원인 의장은 「협동조합 기본법」 제30조제2항에서 규정하고 있는 “총회에서 선출한 조합원 3인”에 포함되지 않습니다.

03 이유

「협동조합 기본법」 제28조제2항에서 총회는 이사장과 조합원으로 구성한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서 이사장은 총회를 소집하며, 총회의 의장이 된다고 규정하고 있는데, 둘 이상의 사물이나 사람을 같은 자격으로 이어 주는 접속조사인 “과”를 기준으로²⁾ 같은 법 제28조제2항에서는 총회의 의장이 되는 “이사장”과 “조합원”을 구분하여 규정하고 있고, 같은 법 제30조제2항에서도 의사록에는 의사의 진행 상황과 그 결과를 적고 의장과 총회에서

1) 「협동조합 기본법」 제30조제2항에 적합하게 작성되지 않은 의사록의 효력 유무는 별론으로 함

2) 국립국어원 표준국어대사전 참조

선출한 조합원 3인 이상이 기명날인하거나 서명하여야 한다고 규정하면서, 접속 조사 “과”를 기준으로 “의장”과 “총회에서 선출한 조합원 3인 이상”을 구분하여 규정하고 있는바, 문언상 “의장”과 “총회에서 선출한 조합원 3인 이상”은 각각 독립적으로 의사록에 기명날인하거나 서명하여야 하는 자들이므로³⁾, 의장이 조합원의 지위를 갖고 있다고 하더라도 같은 법 제30조제2항에 따라 의사록에 기명날인 또는 서명하여야 하는 “총회에서 선출한 조합원 3인”에는 포함되지 않는다고 할 것입니다.

그리고 「협동조합 기본법」 제30조에서는 총회의 의사에 관하여 의사록을 작성하게 하고 그 의사록에 의장과 총회에서 선출한 조합원 3인의 기명날인 또는 서명을 하도록 하여 총회의 의사에 관한 증거로서 의사록을 작성하도록 하고 있고⁴⁾, 이에 따라 같은 조 제2항에서는 의사록에 기명날인하거나 서명하여야 하는 최소 인원수를 정하고 있다 할 것인데, 만약 조합원인 의장이 “총회에서 선출한 조합원 3인”에 포함된다고 해석하게 되면, 의결권을 갖고 있고⁵⁾ 협동조합과 보다 밀접한 이해관계를 갖고 있는 ‘조합원인 의장’이 참석한 총회의 의사록에는 의장을 포함한 3인 이상의 기명날인 또는 서명이 있으면 되는 반면, 의결권을 가지지 않고 협동조합과 직접적인 이해관계가 있다고 보기 어려운 ‘비조합원인 의장’이 참석한 총회의 의사록에는 의장을 포함한 4인 이상의 기명날인 또는 서명이 있어야 하는 결과가 초래되어, 의장이 조합원인지 여부에 따라 총회의 의사에 관한 증거가 되는 의사록에 기명날인하거나 서명하여야 하는 최소 인원수가 합리적 이유 없이 달라지게 되는바, 해당 규정 취지와 의사록의 성격 등을 고려하더라도 조합원인 의장이 총회에서 선출한 조합원 3인에 포함되어 의사록에 기명날인하거나 서명할 수 있다고 해석할 수 없다 할 것입니다.

한편 조합원인 의장이 총회에서 선출한 조합원 3인에 포함되지 않는다고 해석하는 경우, 의장을 포함하여 조합원 수가 5인인 협동조합의 경우에는 「협동조합 기본법」 제29조제2항에 따라 조합원인 의장과 조합원 2인(총 3인)이 총회에 출석하여 의결이 이루어지더라도, 같은 법 제30조제2항에 따라 의장과 총회에서 선출한 조합원 3인 이상이 의사록에 기명날인 또는 서명할 수 없게 되는 결과가 발생하게 된다는 의견이 있습니다.

그러나 「협동조합 기본법」 제29조제2항에서 규정하고 있는 총회의 의결에 필요한 최소 인원수와 같은 법 제30조제2항에서 규정하고 있는 의사록의 기명날인 또는 서명에 필요한 최소 인원수는 서로 구분되는 별개의 것으로, 의결에 필요한 최소 인원수가 충족되면 반드시

3) 법제처 2023. 12. 20. 회신 23-0981 해석례 참조

4) 부산지방법원 2019. 4. 25. 선고 2018가합1325 판결례, 서울남부지방법원 2017. 3. 31. 선고 2016가합100417 판결례 참조

5) 조합원은 출자자수에 관계없이 각각 1개의 의결권과 선거권을 가짐(「협동조합 기본법」 제23조제1항 참조)

의사록 기명날인 등에 필요한 최소 인원수도 충족되어야 한다고 볼 수는 없고, 작성된 의사록은 총회 성립과 결의에 관한 증거문서로 의사록이 작성되지 않았거나 의사록에 기명날인 또는 서명이 없다고 하더라도 일단 성립된 결의의 효력에는 영향이 없으며⁶⁾, 녹음, 녹화자료 등 다른 증거를 통해 총회 성립과 결의를 확인할 수도 있다 할 것인바, 위 협동조합의 총회에 의장과 조합원 2인이 출석하는 경우, 총회에 출석한 조합원 전원이 기명날인 또는 서명한 의사록이 의사록으로서 효력을 가지는지는 별론으로 하더라도, 같은 법 제30조제2항에 따라 의사록에 기명날인 또는 서명을 할 수 있는 조합원이 부족하다는 점을 이유로, 조합원인 의장이 총회에서 의사록에 기명날인 또는 서명하여야 할 조합원 3인에 포함될 수 있다는 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 조합원인 의장은 「협동조합 기본법」 제30조제2항에서 규정하고 있는 “총회에서 선출한 조합원 3인”에 포함되지 않습니다.

법령정비 권고사항

「협동조합 기본법」 제29조제2항의 의결 정족수 등을 고려하여 의사록에 기명날인 또는 서명하여야 하는 최소 인원수를 변경해야 하는지 여부를 정책적으로 검토하고, 이를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

협동조합 기본법

제30조(총회의 의사록) ① 총회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 진행 상황과 그 결과를 적고 의장과 총회에서 선출한 조합원 3인 이상이 기명날인하거나 서명하여야 한다.

6) 대법원 2010. 11. 25. 선고 2009다78788 판결례, 광주고등법원 2022. 2. 9. 선고 2021나22373 판결례 및 이철송, 회사법강의, 박영사(2023) 592p 등 참조

질의제목 3

▶ 안전번호 25-0081

민원인 - 「평생교육법」 제31조에 따른 학교형태의 평생교육시설 등록 신청 대리 업무가 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지 여부(「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련)

01 질의요지

「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理) 업무를 행정사¹⁾의 업무로 규정하고 있는 한편, 「평생교육법」 제31조제1항에서는 학교형태의 평생교육시설을 설치·운영하고자 하는 자는 대통령령으로 정하는 시설·설비를 갖추어 교육감에게 등록하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제26조제1항에서는 학교형태의 평생교육시설을 설치·운영하려는 자는 시설의 명칭, 위치, 교육과정 등을 기재한 등록신청서를 교육감에게 제출하여야 한다고 규정하고 있는바,

「평생교육법」 제31조제1항 및 같은 법 시행령 제26조제1항에 따라 학교형태의 평생교육시설의 등록 신청을 대리하는 업무가 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지?

02 회답

「평생교육법」 제31조제1항 및 같은 법 시행령 제26조제1항에 따라 학교형태의 평생교육시설의 등록 신청을 대리하는 업무는 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당합니다.

03 이유

「행정사법」 제2조제1항 본문에서는 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 같은 항 각 호의 업무를 수행한다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 다른 법률에 따라 제한된 업무는 할 수

1) 「행정사법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조제1호에 따른 일반행정사를 말하며, 이하 같은

없다고 규정하고 있고, 같은 항 제5호에서는 행정사가 다른 사람의 위임을 받아 수행할 수 있는 업무의 하나로 인가·허가 및 면허 등(이하 “인허가등”이라 함)을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등(이하 “신청등”이라 함)의 대리(代理) 업무를 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 그 업무의 내용과 범위는 대통령령으로 정한다고 규정하면서, 같은 법 시행령 제2조제5호에서는 같은 법 제2조제1항제5호의 사무를 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일로 규정하고 있는 한편, 「평생교육법」 제31조제1항 및 같은 법 시행령 제26조제1항에서는 학교형태의 평생교육시설을 설치·운영하기 위하여 교육감에게 등록 신청을 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법에서는 행정사의 업무를 제한하는 별도의 규정을 두고 있지 않은바, 학교형태의 평생교육시설의 등록 신청을 대리하는 업무가 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무 범위에 포함되기 위해서는 ① 교육감이 ‘행정기관’에 해당하고, ② 학교형태의 평생교육시설을 등록 신청하는 것이 「행정사법」 제2조제1항제5호의 ‘인허가등의 신청등’에 해당하는지 살펴볼 필요가 있습니다.

먼저 「행정사법」에서 제2조제1항제5호에 따른 ‘행정기관’의 범위 및 종류에 대하여 별도로 규정하고 있지 않으나, 일반적으로 ‘행정기관’은 국가 또는 지방자치단체의 행정사무를 맡아보는 기관²⁾을 의미하는데, 「지방자치법」 제135조제1항에서는 지방자치단체의 교육·과학 및 체육에 관한 사무를 분장하기 위하여 별도의 기관을 둔다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 별도의 기관의 조직과 운영에 관한 사항을 「지방교육자치법」으로 정하도록 규정하고 있으며, 「지방교육자치법」 제18조에서는 시·도의 교육·학예에 관한 사무의 집행기관으로 시·도에 교육감을 둔다고 규정하여 교육감은 교육·학예에 관한 행정사무를 담당하기 위해 설치된 지방자치단체의 집행기관으로서 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 ‘행정기관’에 해당한다고 할 것입니다.

다음으로 학교형태의 평생교육시설을 등록 신청하는 것이 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 인허가등의 신청등에 해당하는지 살펴보면, 일반적으로 법령에서 하나 또는 수개의 사항을 열거하고 그 뒤에 “등”을 사용한 경우 열거된 사항은 예시사항이라 할 것이고, 별도로 해석해야 할 특별한 이유가 없는 한 그 “등”에는 열거된 예시사항과 규범적 가치가 동일하거나 그에 준하는 성질을 가지는 사항이 포함되는 것으로 해석함이 상당하다 할 것인바³⁾, 그렇다면 「행정사법」 제2조제1항제5호에서의 ‘인허가등’은 인가·허가 및 면허에 준하는 것으로서 복수의 대등한 당사자 사이의 사법상 법률관계가 아닌 공법적 효과 발생을 목적으로 하는

2) 국립국어원 표준국어대사전 참조

3) 법제처 2014. 10. 10. 회신, 14-0498 해석례 참조

공공적 성격의 공법적인 성질에 관한 것을 의미⁴⁾한다고 할 것입니다.

그런데 「평생교육법 시행령」 제26조제3항에서는 교육감이 등록신청서를 검토하여 등록요건에 해당하면 교육부령으로 정하는 등록증을 교부하도록 규정하고 있는 점, 등록된 평생교육시설은 「평생교육법」 제2조제2호에 따른 “평생교육기관”의 지위를 갖게 되는데, 평생교육기관은 국가 및 지방자치단체로부터 지원을 받을 수 있고(제16조제1항), 기관의 평생교육활동에 대하여 국가 및 지방자치단체에 지도 또는 지원을 요청할 수 있도록 규정한 점(제17조제1항), 평생교육시설이 등록 당시의 기준에 미달하게 된 경우 교육부장관 또는 교육감이 그 시설의 등록을 취소하거나 평생교육과정을 폐쇄할 수 있도록 규정(제42조제1항)하고 있는 점에 비추어볼 때, 학교형태 평생교육시설의 등록은 일정한 공법적 효과의 발생을 목적으로 하는 행위에 해당하므로 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 ‘인허가등’에 해당된다 할 것입니다.

따라서 「평생교육법」 제31조제1항 및 같은 법 시행령 제26조제1항에 따라 학교형태의 평생교육시설의 등록 신청을 대리하는 업무는 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당합니다.



관계법령

행정사법

제2조(업무) ① 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 다음 각 호의 업무를 수행한다. 다만, 다른 법률에 따라 제한된 업무는 할 수 없다.

1. 행정기관에 제출하는 서류의 작성
2. 권리·의무나 사실증명에 관한 서류의 작성
3. 행정기관의 업무에 관련된 서류의 번역
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 작성된 서류의 제출 대행(代行)
5. 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理)
6. 행정 관계 법령 및 행정에 대한 상담 또는 자문에 대한 응답
7. 법령에 따라 위탁받은 사무의 사실 조사 및 확인

② 제1항에 따른 업무의 내용과 범위는 대통령령으로 정한다.

평생교육법

제31조(학교형태의 평생교육시설) ① 학교형태의 평생교육시설을 설치·운영하고자 하는 자는 대통령령으로 정하는 시설·설비를 갖추어 교육감에게 등록하여야 한다.

4) 법제처 2016. 10. 24. 회신 16-0262 해석례 참조

충청남도 홍성군 - 「전기통신사업법」 제80조제3항 단서에 따른 전기통신설비 이전비용 감면대상의 범위
(「전기통신사업법」 제80조 등 관련)

01 질의요지

「전기통신사업법」 제80조제1항에서는 기간통신사업자¹⁾의 전기통신설비가 설치되어 있는 토지등²⁾이나 이에 인접한 토지등의 이용목적이나 이용방법이 변경되어 그 설비가 토지등의 이용에 방해가 되는 경우에는 그 토지등의 소유자나 점유자는 기간통신사업자에게 전기통신설비의 이전이나 그 밖에 방해 제거에 필요한 조치를 요구할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 기간통신사업자는 같은 조 제1항에 따른 요구를 받은 경우 해당 조치를 하는 것이 업무의 수행상 또는 기술상 곤란한 경우가 아니면 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항 본문에서는 같은 조 제2항의 조치에 필요한 비용은 해당 설비의 설치 이후에 그 설비의 이전이나 그 밖에 방해 제거에 필요한 조치의 원인을 제공한 자가 부담한다고 하면서, 같은 조 제3항 단서에서는 기간통신사업자는 그 비용을 부담하는 자가 해당 토지등의 소유자나 점유자인 경우로서 국가나 지방자치단체가 전기통신설비의 이전이나 그 밖에 방해요소 제거를 요구하는 경우(제3호) 등 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 설비를 설치할 때 보상금액, 설비기간 등을 고려하여 그 토지등의 소유자나 점유자가 부담하는 비용을 감면할 수 있다고 규정하고 있는바,

기간통신사업자의 전기통신설비가 설치되어 있는 토지등³⁾에 인접한 토지등의 소유자인 지방자치단체가 「전기통신사업법」 제80조제1항에 따라 기간통신사업자에게 전기통신설비의 이전을 요구하는 경우⁴⁾, 그 지방자치단체는 같은 조 제3항 단서에 따른 감면 대상인 “해당 토지등의 소유자”에 해당하는지?⁵⁾⁶⁾

- 1) 전기통신회선설비를 설치하거나 이용하여 기간통신역무를 제공하는 사업을 경영하기 위해 과학기술정보통신부장관에게 등록한 자를 말하며, 이하 같음(「전기통신사업법」 제5조·제6조 참조)
- 2) 토지 또는 이에 정착한 건물·인공구조물과 수면·수저(水底)를 말하며, 이하 같음(「전기통신사업법」 제72조제1항 참조)
- 3) 기간통신사업자가 소유하고 있는 토지등임을 전제함
- 4) 인접한 토지의 소유자인 지방자치단체가 「전기통신사업법」 제80조제1항에 따라 이전을 요구하여 같은 조 제2항에 따라 이전 조치의 원인을 제공한 자로서 비용을 부담함을 전제함
- 5) 인접한 토지의 소유자나 점유자는 전기통신설비를 설치할 때 보상받은 금액이 없음을 전제함
- 6) 이전비용과 관련하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」의 적용 여부에 대한 논의는 별론으로 함

02 회답

이 사안의 경우, 인접한 토지등의 소유자인 지방자치단체는 「전기통신사업법」 제80조 제3항 단서에 따른 감면 대상인 “해당 토지등의 소유자”에 해당되지 않습니다.

03 이유

「전기통신사업법」 제80조제3항 본문에서는 같은 조 제2항의 조치에 필요한 비용은 해당 설비의 설치 이후에 그 설비의 이전이나 그 밖에 방해 제거에 필요한 조치(이하 “이전등”이라 함)의 원인을 제공한 자가 부담한다고 규정하면서, 같은 조 제3항 단서에서는 기간통신사업자는 그 비용을 부담하는 자가 해당 토지등의 소유자나 점유자인 경우로서 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 설비를 설치할 때 보상금액, 설비기간 등을 고려하여 그 토지등의 소유자나 점유자가 부담하는 비용을 감면할 수 있다고 규정하고 있는바, 「전기통신사업법」 제80조제3항 단서에 따른 “해당 토지등의 소유자”는 전기통신설비가 설치되어 있는 토지등의 소유자만을 의미하는지, 아니면 같은 조 제1항에 따른 “그 토지등”을 지칭하는 것으로서 전기통신설비가 설치되어 있는 토지등의 소유자뿐만 아니라 인접한 토지등의 소유자를 모두 포함하는지가 문제됩니다.

그리고 「전기통신사업법」 제80조제3항 단서에서는 기간통신사업자는 전기통신설비를 설치할 때 보상금액 등을 고려하여 전기통신설비의 이전비용을 감면할 수 있도록 규정하고 있는데, 같은 법 제72조제1항에서는 기간통신사업자는 전기통신업무에 제공되는 선로 및 안테나와 그 부속설비를 설치하기 위하여 필요하면 타인의 토지등을 사용할 수 있되 이 경우 기간통신사업자는 미리 그 토지등의 소유자나 점유자와 협의하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 기간통신사업자는 같은 조 제1항에 따른 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없으면 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “토지보상법”이라 함)에서 정하는 바에 따라 타인의 토지등을 사용할 수 있다고 규정하여 전기통신설비가 설치되는 경우 보상에 대하여 규정하고 있는바, 기간통신사업자가 전기통신설비를 설치하려면 전기통신설비가 설치되는 토지의 소유자나 점유자와 협의하거나 토지보상법에 따라 보상하게 되고⁷⁾, 그 보상금액은 인접한 토지의 소유자나 점유자가 아니라

7) 토지보상법 제79조제1항 등 참조

전기통신설비가 설치된 토지등의 소유자나 점유자에 대해서만 지급되는 것이라는 점에 비추어 보면, 기간통신사업자는 전기통신설비가 설치될 당시 보상금을 지급받았던 토지등의 소유자나 점유자를 대상으로 그 지급받은 보상금액을 고려하여 이전등의 비용을 감면할 수 있다고 보는 것이 입법취지와 규정 체계에 부합하는 해석입니다.

아울러 ① 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데⁸⁾, 「전기통신사업법」 제80조제3항에서는 원칙적으로 전기통신설비의 이전등의 원인을 부담하는 자가 이전등의 필요한 조치에 따른 비용을 부담하도록 하되⁹⁾, 예외적으로 이전등의 비용을 부담하는 자가 그 토지등의 소유자나 점유자인 경우에는 그 비용을 감면할 수 있도록 한 점, ② 종전에는 「전기통신사업법 시행령」에서 이전등의 비용을 감면할 수 있는 사유를 국가 또는 지방자치단체가 전기통신설비의 이전등을 요구하는 경우에는 해당 토지등의 소유 및 점유 여부와 관계없이 협의하여 이전등의 비용을 감면할 수 있다고 규정하고 있었던 것을, 2007년 5월 11일 법률 제8425호로 일부개정된 「전기통신사업법」으로 상향입법하여 규정하면서¹⁰⁾ “그 비용을 부담하는 자가 해당 토지등의 소유자나 점유자”라는 요건을 추가한 입법 연혁이 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 인접한 토지등의 소유자인 지방자치단체는 「전기통신사업법」 제80조제3항 단서에 따른 감면 대상인 “해당 토지등의 소유자”에 해당되지 않습니다.

8) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례 참조

9) 대법원 2017. 6. 19. 선고 2016다278616 판결례 참조

10) 2006. 10. 27. 의안번호 제175206호로 발의된 전기통신사업법 일부개정법률안에 대한 국회 과학기술정보통신위원회 검토보고서 참조

법령정비 권고사항

「전기통신사업법」 제80조에 따라 국가나 지방자치단체가 공익 목적으로 전기통신설비의 이전이나 그 밖에 방해 제거에 필요한 조치를 요구하는 경우, 전기통신설비의 이전이나 그 밖에 방해 제거에 드는 비용 감면의 필요성(2007년 9월 18일 대통령령 제20277호로 일부개정되기 전의 「전기통신사업법 시행령」 규정 고려)을 정책적으로 검토하고, 필요하다고 판단되는 경우 이를 법령에 명확하게 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

전기통신사업법

제72조(토지등의 사용) ① 기간통신사업자는 전기통신업무에 제공되는 선로 및 안테나와 그 부속설비(이하 “선로등”이라 한다)를 설치하기 위하여 필요하면 타인의 토지 또는 이에 정착한 건물·인공구조물과 수면·수저(水底)(이하 “토지등”이라 한다)를 사용할 수 있다. 이 경우 기간통신사업자는 미리 그 토지등의 소유자나 점유자와 협의하여야 한다.

② 기간통신사업자는 제1항에 따른 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없으면 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 타인의 토지등을 사용할 수 있다.

제80조(설비의 이전 등) ① 기간통신사업자의 전기통신설비가 설치되어 있는 토지등이나 이에 인접한 토지등의 이용목적이나 이용방법이 변경되어 그 설비가 토지등의 이용에 방해가 되는 경우에는 그 토지등의 소유자나 점유자는 기간통신사업자에게 전기통신설비의 이전이나 그 밖에 방해 제거에 필요한 조치를 요구할 수 있다.

② 기간통신사업자는 제1항에 따른 요구를 받은 경우 해당 조치를 하는 것이 업무의 수행상 또는 기술상 곤란한 경우가 아니면 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 제2항의 조치에 필요한 비용은 해당 설비의 설치 이후에 그 설비의 이전이나 그 밖에 방해 제거에 필요한 조치의 원인을 제공한 자가 부담한다. 다만, 기간통신사업자는 그 비용을 부담하는 자가 해당 토지등의 소유자나 점유자인 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 설비를 설치할 때 보상금액, 설비기간 등을 고려하여 그 토지등의 소유자나 점유자가 부담하는 비용을 감면할 수 있다.

1. 기간통신사업자가 해당 전기통신설비의 이전이나 그 밖에 방해요소를 없애기 위한 계획을 수립하여 시행하는 경우
2. 해당 전기통신설비의 이전이나 그 밖에 방해요소 제거가 다른 전기통신설비에 유익하게 되는 경우
3. 국가나 지방자치단체가 전기통신설비의 이전이나 그 밖에 방해요소 제거를 요구하는 경우
4. 사유지 내의 전기통신설비가 해당 토지등을 이용하는 데에 크게 지장을 주어 이전하는 경우

국토교통부 - 주식회사인 감정평가법인이 자본금을 증액할 목적으로 주식을 발행하기 위하여 정관의 주식의 발행에 관한 사항을 변경하는 것이 국토교통부장관의 인가대상인지 여부(「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제29조 등 관련)

01 질의요지

「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 “감정평가법”이라 함) 제29조제1항에서는 감정평가사는 같은 법 제10조에 따른 업무를 조직적으로 수행하기 위하여 감정평가법인을 설립할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제29조제5항 본문에서는 감정평가법인을 설립하려는 경우에는 사원이 될 사람 또는 감정평가사인 발기인이 공동으로 같은 항 각 호의 사항을 포함한 정관을 작성하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 인가를 받아야 하며, 정관을 변경할 때에도 또한 같다고 규정하면서, 같은 항 제5호에서는 사원의 출자(주식회사의 경우에는 주식의 발행)에 관한 사항을 규정하고 있고, 같은 항 단서에서는 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 신고할 수 있다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제28조에서는 같은 법 제29조제5항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경”이란 같은 법 제29조제5항제3호부터 제5호까지의 사항의 변경을 말한다고 규정하고 있는바,

주식회사인 감정평가법인이 자본금을 증액할 목적으로 주식을 발행하기 위하여 정관의 주식의 발행에 관한 사항을 변경하는 것¹⁾은 감정평가법 제29조제5항 각 호 외의 부분 본문에 따른 인가대상인지, 아니면 같은 항 각 호 외의 부분 단서에 따른 신고대상인지?

02 회답

주식회사인 감정평가법인이 자본금을 증액할 목적으로 주식을 발행하기 위하여 정관의 주식의 발행에 관한 사항을 변경하는 것은 감정평가법 제29조제5항 각 호 외의 부분 단서에 따른 신고대상입니다.

1) 주식회사인 감정평가법인이 자본금을 증액하기 위하여 발행하는 주식의 수량을 늘리는 것으로 정관을 변경하는 경우를 전제함

03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데²⁾, 감정평가법 제29조제5항 본문에서는 감정평가법인을 설립하려는 경우에는 사원이 될 사람 또는 감정평가사인 발기인이 공동으로 같은 항 각 호의 사항을 포함한 정관을 작성하여 국토교통부장관의 인가를 받아야 하며, 정관을 변경할 때에도 또한 같다고 규정하면서, 같은 항 제5호에서는 사원의 출자(주식회사의 경우에는 주식의 발행)에 관한 사항을 규정하고 있고, 같은 항 단서 및 같은 법 시행령 제28조에 따르면 “감정평가법 제29조제5항제3호부터 제5호까지의 사항의 변경”은 신고할 수 있다고 규정하고 있는바, 감정평가법 제29조제5항제5호에서는 “주식회사의 경우에는 주식의 발행”이라고 규정하고 있고, 주식을 발행하는 목적 등에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않으므로, 문언상 정관에서 주식의 발행에 관한 사항을 변경하는 것은 감정평가법 제29조제5항 단서에 따른 신고대상에 포함된다고 할 것입니다.

그리고 감정평가법 제29조제5항은 감정평가법인의 설립인가를 받기 위하여 작성하는 정관에 포함되어야 하는 사항들을 규정하면서 원칙적으로 정관을 변경할 때에는 국토교통부장관의 인가를 받도록 하되, 정관의 변경 사항이 주사무소 및 분사무소의 소재지(제3호), 사원(주식회사의 경우에는 발기인)의 성명, 주민등록번호 및 주소(제4호), 사원의 출자(주식회사의 경우에는 주식의 발행)에 관한 사항(제5호)인 경우에는 경미한 사항의 변경으로서 국토교통부장관에게 신고할 수 있도록 하고 있는데, 이는 정관의 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 정관 변경의 절차를 간소화함으로써 영업상 편의를 증진시키려는 취지로 볼 수 있는바, 감정평가법 시행령 제28조에서 신고대상으로 규정하고 있는 주식회사의 주식 발행에 관한 사항에 대해, 명문의 규정 없이 주식 발행의 목적 등에 따라 이를 인가 대상으로 보는 것은 정관의 경미한 변경 사항에 대하여 감정평가법인의 정관 변경 절차를 간소화하려는 규정의 취지에 부합한다고 보기 어렵습니다.

한편 주식회사인 감정평가법인이 자본금을 증액하기 위하여 주식을 발행하는 경우 주식회사의 재정적 기반이 되는 자본금이 변경되므로 감정평가법 제29조제5항제5호에 따른 “주식의 발행”은 자본금의 변경을 수반하지 않는 주식의 종류나 방법 등 주식을 발행하는 절차로만 한정된다는 의견이 있으나, 감정평가법 제31조제1항에서는 감정평가법인의 자본금은 2억원 이상이어야 한다고 규정하여 주식회사인 감정평가법인에 대하여 자본금의

2) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

최저한도를 2억원으로 규정하고 있을 뿐, 자본금의 증액을 위한 주식의 발행에 대해서는 감정평가법 제29조제5항에 따라 정관의 변경 사항을 국토교통부장관에게 신고하는 것 외에는 특별한 규정을 두고 있지 않은 점, 감정평가법 제29조에 따라 감정평가법인은 재무제표를 작성하여 매 사업연도가 끝난 후 3개월 이내에 국토교통부장관에게 제출하여야 하고(제11항), 국토교통부장관은 필요한 경우 감정평가법인의 재무제표가 적정하게 작성되었는지 검사할 수 있도록(제12항) 하여 감정평가법인의 재무건전성을 확인하기 위한 별도의 감시 수단이 마련되어 있다는 점 등을 고려하면, 그러한 주장은 타당하지 않습니다.

따라서 주식회사인 감정평가법인이 자본금을 증액할 목적으로 주식을 발행하기 위하여 정관의 주식의 발행에 관한 사항을 변경하는 것은 감정평가법 제29조제5항 각 호 외의 부분 단서에 따른 신고대상입니다.



관계법령

감정평가 및 감정평가사에 관한 법률

제29조(설립 등) ① 감정평가사는 제10조에 따른 업무를 조직적으로 수행하기 위하여 감정평가법인을 설립할 수 있다.

② ~ ④ (생략)

⑤ 감정평가법인을 설립하려는 경우에는 사원이 될 사람 또는 감정평가사인 발기인이 공동으로 다음 각 호의 사항을 포함한 정관을 작성하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 인가를 받아야 하며, 정관을 변경할 때에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 신고할 수 있다.

1. 목적
2. 명칭
3. 주사무소 및 분사무소의 소재지
4. 사원(주식회사의 경우에는 발기인)의 성명, 주민등록번호 및 주소
5. 사원의 출자(주식회사의 경우에는 주식의 발행)에 관한 사항
6. 업무에 관한 사항

⑥ ~ ⑫ (생략)

⑬ 감정평가법인에 관하여 이 법에서 정한 사항을 제외하고는 「상법」 중 회사에 관한 규정을 준용한다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 시행령

제28조(정관변경 등의 신고) 제29조제5항 각 호 외의 부분 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경”이란 법 제29조제5항제3호부터 제5호까지의 사항의 변경을 말한다.

질의제목 6

▶ 안전번호 25-0189

민원인 - 「외국인투자 촉진법」 제5조에 따른 외국인투자 신고 대리 업무가 「행정사법」 제2조제1항 제5호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지 여부 (「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련)

01 질의요지

「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理) 업무를 행정사¹⁾의 업무로 규정하고 있는 한편, 「외국인투자 촉진법」 제2조제1항제1호에서는 “외국인”이란 외국의 국적을 가지고 있는 개인, 외국의 법률에 따라 설립된 법인(이하 “외국법인”이라 한다) 및 대통령령으로 정하는 국제경제협력기구를 말한다고 규정하고 있고, 같은 항 제4호에서는 “외국인투자”란 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제5조제1항에서는 외국인은 같은 법 제2조제1항제4호 각 목에 해당하는 방법에 따라 외국인투자를 하려는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 미리 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다고 규정하고 있는바,

「외국인투자 촉진법」 제5조제1항에 따른 외국인투자 신고를 대리하는 업무가 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지?

02 회답

「외국인투자 촉진법」 제5조제1항에 따른 외국인투자 신고를 대리하는 업무는 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당합니다.

03 이유

먼저 「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 행정사가 다른 사람의 위임을 받아 수행할 수

1) 「행정사법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조제1호에 따른 일반행정사를 말하며, 이하 같음

있는 업무의 하나로 ‘인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理)’ 업무를 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제2조제5호에서는 같은 법 제2조제1항제5호에 따라 행정사가 수행할 수 있는 업무의 내용과 범위를 ‘다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일’로 구체화하고 있습니다.

그런데 「외국인투자 촉진법」 제5조제1항에서는 외국인이 외국인투자를 하려는 경우에는 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다고 규정하고 있는바, “행정기관”은 일반적으로 국가 또는 지방자치단체의 행정사무를 맡아보는 기관²⁾으로서, 산업통상자원부장관은 국가행정기관의 설치·조직과 직무범위를 정하고 있는 「정부조직법」에 따라 설치되어 상업·무역·통상, 외국인 투자, 중견기업 등에 관한 사무를 관장하는 중앙행정기관으로(제2조제1항 및 제38조) 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 “행정기관”에 해당하고, 산업통상자원부장관에게 외국인투자 신고를 하는 것은 “행정기관에 신고하는 일”에 해당하므로 「외국인투자 촉진법」 제5조제1항에 따라 외국인투자의 신고를 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제2조제5호에 따라 “다른 사람의 위임을 받아 행정기관에 신고하는 일을 대리하는 일”로서 「행정사법」에 따른 행정사의 업무에 포함된다는 점이 문언상 명확합니다.

또한 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리 등 사인의 행정기관 상대 민원 업무를 대신하거나 도와주는 일을 하는 직역으로³⁾, 만약 외국인투자 신고를 대리하는 업무를 「행정사법」에 따른 행정사가 수행할 수 없도록 배제하려는 입법의도가 있었다면 외국인투자 촉진법령에서 외국인투자 신고 대리 업무를 할 수 있는 자를 특정 자격이 있는 자로 제한하는 규정을 두었을 것인데, 「외국인투자 촉진법」에서는 달리 외국인투자 신고의 대리를 특정 자격이 있는 자만 수행할 수 있도록 명시적으로 제한하는 규정을 두고 있지 않은 점 등을 고려하면 행정사가 외국인투자 신고의 대리를 수행할 수 있다고 해석하는 것⁴⁾이 국민의 편의 증진을 위하여 행정사로 하여금 기본적인 행정사무를 취급할 수 있도록 하고 있는 「행정사법」의 취지에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

따라서 「외국인투자 촉진법」 제5조제1항에 따른 외국인투자 신고를 대리하는 업무는 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당합니다.

2) 국립국어원 표준국어대사전 참조

3) 헌법재판소 2015. 3. 26. 선고 2013헌마131 결정례 참조

4) 법제처 2021. 5. 12. 회신 21-0133 해석례 참조



관계법령

행정사법

제2조(업무) ① 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 다음 각 호의 업무를 수행한다. 다만, 다른 법률에 따라 제한된 업무는 할 수 없다.

1. ~ 4. (생략)

5. 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理)

6.·7. (생략)

② (생략)

행정사법 시행령

제2조(업무의 내용과 범위) 「행정사법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항 각 호에 따른 행정사 업무의 내용과 범위는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 4. (생략)

5. 법 제2조제1항제5호의 사무: 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일

6.·7. (생략)

외국인투자 촉진법

제5조(외국인투자 신고) ① 외국인(제2조제1항제4호가목2)에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 특수관계에 있는 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 제2조제1항제4호 각 목에 해당하는 방법에 따라 외국인투자를 하려는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 미리 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

2025 법령해석 사례집 (상)

편집·발행 법제처 법령해석총괄과
전화 : 044-200-6706
팩스 : 044-200-6970
주소 : 30102
 세종특별자치시 도움5로 20,
 정부세종청사 법제처(7-1동)

홈 페이지 www.moleg.go.kr
인쇄일 2026년 1월
발행일 2026년 1월
제작·인쇄 한결엠 02-6952-0551 www.hgm6952.com

 세종장애인생산품생산시설

 사회적협동조합

 사회적기업

2025

법령해석 사례집

상



법제처

세종특별자치시 도움5로 20, 정부세종청사 법제처(7-1동)

Tel 044-200-6706

Fax 044-200-6970